

الفقه الحنفي
للمفرقة الثالثة
إعداد
لجنة من أساتذة قطاع الشريعة والقانون

العام الجامعي

2024-2023م

جامعة الأزهر الشريف

كلية الشريعة والقانون بدمنهور

قسم الفقه

كتاب الهداية في شرح بداية المبتدي

المؤلف: علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين
(المتوفى: 593هـ)

مقرر الدراسة النصية - الفرقة الثالثة بقسميها

تحقيق وتعليق

أ.د / عزت عبدالعزيز عبدالرحيم

أ.د / محمد علي عكاز

أستاذ الفقه المتفرغ

أستاذ الفقه

ووكيل كلية الشريعة بدمنهور السابق

ووكيل كلية الشريعة والقانون بدمنهور

أ.د / كمال محمد عواد

أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون بدمنهور

الدراسة النصية

كتاب أدب القاضي

شروط صحة ولاية القاضي

مدخل

...

كتاب أدب القاضي

قال: "ولا تصح ولاية القاضي حتى يجتمع في المولى شرائط الشهادة ويكون من أهل الاجتهاد" أما الأول فلأن حكم القضاء يستقى من حكم الشهادة لأن كل واحد منهما من باب الولاية، فكل من كان أهلاً للشهادة يكون أهلاً للقضاء وما يشترط لأهلية الشهادة يشترط لأهلية القضاء. والفاسق أهل للقضاء حتى لو قلد يصح، إلا أنه لا ينبغي أن يقلد كما في حكم الشهادة فإنه لا ينبغي أن يقبل القاضي شهادته، ولو قبل جاز عندنا.

القضاء يعني الحكم و(قضى) يقضي (قضاء) أي حكم⁽¹⁾ ومنه قوله تعالى: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾⁽²⁾ ، والياء في القضائية (يا) النسبة و(الهاء) ضمير متصل في محل جر بالإضافة يعود على الإنابة.

ومنه قوله تعالى ﴿وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ﴾⁽³⁾ أي يحكم ومنه قضى القاضي بين الخصوم أي قطع بينهم بالحكم ، ومنه قوله تعالى ﴿فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ﴾⁽⁴⁾ أي خلقهن وصنعهن وقدرهن وصيرهن ، ومنه قوله تعالى ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ﴾⁽⁵⁾ أي حكم وأمر ، ومنه قوله تعالى ﴿فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ﴾⁽⁶⁾ أي افعل ما أنت فاعل ، ومنه قوله تعالى ﴿وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ﴾⁽⁷⁾ أي أنهيناها إليه

¹- الجرجاني، التعريفات، مرجع سابق، ص177؛ ابن منظور، لسان العرب، المرجع السابق، ج15، ص186.

²- سورة الإسراء: من الآية (23).

³- سورة غافر: الآية (20)

⁴- سورة فصلت: الآية (12)

⁵- سورة الإسراء: الآية (23)

⁶- سورة طه: الآية (72)

⁷- سورة الحجر: الآية (66)

وأبلغناه ذلك ،ومنه قوله تعالى ﴿فَإِذَا قُضِيَتْ مَنَاسِكُكُمْ﴾⁽⁸⁾ أي أدبتموها وفرغتم ، ومنه قوله تعالى ﴿فَلَمَّا قُضِيَنا عَلَيْهِ﴾⁽⁹⁾ أي ألزمناه إياه .

وتعددت عبارات الفقهاء في بيان معنى القضاء :

فعرفه الحنفية :بأنه "الفصل في الخصومات وقطع المنازعات على وجه مخصوص".⁽¹⁰⁾

وعرفه المالكية :بأنه " الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام".⁽¹¹⁾

وعرفه الشافعية بأنه " رفع الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم الله تعالى وقيل هو إلزام من له الإلزام بحكم الشرع ".⁽¹²⁾

وعرفه الحنابلة : بأنه تبين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات".⁽¹³⁾

إذا فالفقهاء عبروا بتعبيرات قد تبدو فيها اختلاف ،ولكن تتفق ان القضاء هو: " فصل الخصومات بإظهار حكم الشارع فيها على سبيل الإلزام"⁽¹⁴⁾ ،واتفق أهل العلم من الفقهاء على أن قيام الإمام بتعيين القضاة على الأمصار للحكم بين الناس في منازعاتهم فرض عين عليه⁽¹⁵⁾، وذلك لأن الإمام هو القائم بأمر الرعية ،المتكلم بمصلحتهم ،المسؤول عنهم⁽¹⁶⁾.

وإقامة الدعوى لدى القضاء هي الوسيلة الأساسية لوصول الإنسان إلى حقه عند الإنكار و التجاحد والاعتداء، ولذلك تدخل في مقدمة الواجب ،وأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب⁽¹⁷⁾، ولعل أهم أسباب وجود الدعوى "الظلم والتعدي، والضرر والإضرار، وحفظ الحق من الضياع، وحفظ الأمن، وحفظ الحق العام، وتقويم المخطئ وتأديبه"⁽¹⁸⁾، قال ابن

8-سورة البقرة : الآية (200)

9- سورة سبأ : الآية (14)

10- ابن نجيم ، البحر الرائق ،سابق ، (277/1)

11- ابن فرحون ،تبصرة الحكام ، ط الحلبي 1387هـ (ج1/12)

12- الشربيني الخطيب ، مغنى المحتاج ، ط الحلبي 1352هـ (ج4/362)

13 - البهوتي ، كشف القناع ، المطبعة الشرقية 1320هـ (ج4/257)

14- د. محمد نعيم ياسين، نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات المدنية والتجارية، بدون طبعة، الرياض، دار عالم الكتب، (1423هـ/2003م)، ص28.

15-الكاساني ، بدائع الصنائع، ج7، ص2؛ الحطاب، مواهب الجليل، ج8، ص80، الشربيني، مغني المحتاج، ج4، ص430؛ البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ج6، ص462.

16- البهوتي ، كشف القناع عن متن الإقناع، ج6، ص363.

17- انظر د. محمد الزحيلي، التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي (دراسة مقارنة)، الطبعة الثانية، دمشق، دار الفكر، (1423هـ-)، ص294.

18-انظر د. عدنان الدقيلان، الدعوى القضائية في الفقه الإسلامي، الطبعة الأولى، الدمام، دار ابن الجوزي، (1429هـ-)، ص76 .

فرحون رحمه الله في حكمة القضاء أنها: "رفع التهارج"⁽¹⁹⁾، ورد الثوابت، وقطع الظالم، ونصر المظلوم، وقطع الخصومات، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"⁽²⁰⁾.

والقضاء فصل الخصومات وحل النزاعات بين الناس، وعلى مر التاريخ نجد أن هناك شريعة أو قانوناً يلزم القاضي بالرجوع إليه، وفي القضاء الإسلامي اتفق الفقهاء على وجوب الحكم بما أنزل الله، وبطلان الحكم بما عداه، فالحكم بما عداه جور وظلم⁽²¹⁾، قال تعالى: (وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ)⁽²²⁾.

دل النص الكريم على وجوب الحكم بما أنزل الله، وإن خالف القاضي هذا الأمر، وحكم بغير ما أنزل الله، فحكمه جور وظلم، ومخالفة لأمر الله تعالى، فهو حكم باطل، وقد استهل الإمام ابن حزم⁽²³⁾ بها كتاب الأفضية فقال: "ولا يحل الحكم إلا بما أنزل الله تعالى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الحق، وما عدا ذلك فهو جور وظلم لا يحل الحكم به"⁽²⁴⁾.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا⁽²⁵⁾ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: «كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟»، قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟»،

¹⁹- التهارج: هو الوقوع في الفتنة، والاختلاط والقتل. انظر الفيروز آبادي، القاموس المحيط، مرجع سابق، ص210.

²⁰- ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج1، ص12.

(²¹) علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين، الهداية في شرح المبتدي، تحقيق: طلال يوسف، بدون طبعة، بيروت، دار إحياء التراث العربي، بدون تاريخ، ج6، ص393.

²²(سورة المائدة: من الآية [49].

²³(هو: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، أبو محمد (456/384هـ): عالم الأندلس في عصره، وأحد أئمة الإسلام. كان في الأندلس خلق كثير ينتسبون إلى مذهبه، يقال لهم "الحزمية". ولد بقرطبة. وكانت له ولأبيه من قبله رئاسة الوزارة وتدبير المملكة، فزهد بها وانصرف إلى العلم والتأليف، فكان من صدور الباحثين فقيهاً حافظاً يستنبط الأحكام من الكتاب والسنة، بعيداً عن المصانعة. وانتقد كثيراً من العلماء والفقهاء، فتمالأوا على بغضه، وأجمعوا على تضليله وحذروا سلاطينهم من فتنته، ونهوا عوامهم عن الدنو منه، فأقصته الملوك وطاردته، فرحل إلى بادية ليلة (من بلاد الأندلس) فتوفي فيها. أشهر مصنفاته: الفصل في الملل والأهواء والنحل، المحلى، جمهرة الأنساب، والناسخ والمنسوخ وغيرها: انظر ترجمته في: الزركلي، الأعلام، ج4، ص254.

²⁴(ابن حزم، المحلى، ج9، ص362.

²⁵(هو: معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي بن كعب بن عمرو بن أدي بن علي بن أسد بن ساردة بن يزيد بن جشم بن عدي، أبو عبد الرحمن الأنصاري الخزرجي. الإمام المقدم في علم الحلال والحرام. وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث. روى عنه ابن عباس، وابن عمر، وابن عدي، وابن أبي أوفى الأشعري، وعبد الرحمن بن سمرة، وجابر بن أنس، وآخرون من كبار التابعين، وشهد بدرا وهو ابن إحدى وعشرين سنة، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم على اليمن. وكانت وفاته بالطاعون في الشام سنة سبع عشرة أو التي بعدها، وهو قول الأكثر. وعاش أربعاً وثلاثين سنة. وقيل غير ذلك. انظر ترجمته في: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن

قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟» قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي، وَلَا أَلُو فَضْرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ، وَقَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ».⁽²⁶⁾

دل النص الشريف على أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما عين معاذًا قاضيًا، أراد أن يبين له ما الذي يعتمد عليه القاضي في حكمه، فأجاب معاذ بأنه سيقضي بكتاب الله، فإن لم يجد فبالسنة، فإن لم يجد فبالاجتهاد، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على أن مستند الحكم ومرجعه ما ذكر، قال الإمام ابن الهمام⁽²⁷⁾ بعد أن ذكر نص الحديث والمصادر التي ذكرها معاذ: "وعليه إجماع المسلمين"⁽²⁸⁾، وهذا الحديث وحده مبيّنًا مفصلاً للمقضي به، وقد ذكره أكثر الفقهاء في كتبهم كبيان المصادر الحكم. فلا يجوز القضاء بغير دليل، ويجب أن يكون مستند القاضي في حكمه أحد الأدلة من الكتاب أو السنة، أما إذا كان قولًا بلا دليل، فهذا حكم باطل يستحق النقض.⁽²⁹⁾

وأما الشهادة فقد اختلف الفقهاء في تعريف الشهادة التي هي طريق من طريق الإثبات بناءً على اختلافهم في الأحكام المتعلقة بها عندهم، وفيما يلي نذكر أشهر تلك التعريفات:

أولاً: الشهادة عند الحنفية:

(1) الإخبار عن أمر حضره الشهود وشاهدوه، إما معاينة كالأفعال نحو القتل والزنا والسرقة، أو سماعًا كالعقود والإقرارات.⁽³⁰⁾

(2) إخبار صدق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء.⁽³¹⁾

أحمد بن حجر العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة، تحقيق: عادل أحمد، على محمد معوض، الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية، (1415هـ)، ج6، ص109.

⁽²⁶⁾ مسند الإمام أحمد حنبل، حديث رقم (22007)، ج36، ص333. حديث إسناده ضعيف لإبهام أصحاب معاذ وجهالة الحارث بن عمرو، لكن مال إلى القول بصحته غير واحد من المحققين من أهل العلم، منهم أبو بكر الرازي وأبو بكر بن العربي والخطيب البغدادي وابن قيم الجوزية.

⁽²⁷⁾ هو: محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد ابن مسعود، كمال الدين، المعروف بابن الهمام (790/861هـ): إمام، من علماء الحنفية. عارف بأصول الديانات والتفسير والفرائض والفقه والحساب، ولد بالإسكندرية، ونبغ في القاهرة، وأقام بطلب مدة، وجاور الحرمين، ثم كان شيخ الشيوخ بالخانقاه الشيخونية بمصر، وكان معظمًا عند الملوك وأرباب الدولة، توفي بالقاهرة. انظر ترجمته: الزركلي، الأعلام، ج6، ص255.

⁽²⁸⁾ ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج، ص357.

⁽²⁹⁾ محمد بن محمد محمود، أكمل الدين أبو عبد الله، شمس الدين جمال الدين الروني البابرّي، العناية شرح الهداية، بدون طبعة، بيروت، دار الفكر، بدون تاريخ، ج6، ص393؛ السيوطي، الأشباه والنظائر، ص105؛ ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري، تحفة المحتاج على أدلة المنهاج، تحقيق: عبد الله الليحاني، الطبعة الأولى، مكة المكرمة، دار حراء، (1406هـ)، ج4، ص365.

⁽³⁰⁾ عبد الله بن محمود بن مودود بن محمود أبو الفضل مجد الدين الموصلي، الاختيار لتعليل المختار، تعليق: محمود أبو دقيق: بدون طبعة، بيروت، دار الكتب العلمية، ج2، ص139.

فخرج بهذه القيود الواردة في التعريف الإخبارات الكاذبة والإخبار الصادقة في غير مجلس الحكم والتي تكون خالية من لفظ الشهادة، وكذلك الإخبار التي لم تثبت حقاً أمام القاضي، كما دخلت الشهادة المبنية على التسامع كالشهادة بالموت فهي مقبولة شرعاً وأن كانت غير مشاهدة أو معاينة.⁽³²⁾

والمراد بالحق منه حق أجد الذي هو في ذمة الآخر، ويخرج بهذا الإقرار؛ لأنه "إخبار الإنسان عن حق عليه لآخر". ويخرج بذلك أيضاً الدعوى لأنها: "إخبار أحد عن حقه في حضور القاضي".⁽³³⁾

فإخبار أحد عن حقه يخرج به الإخبار عن أمر حادث للقاضي في مجلس المحاكمة⁽³⁴⁾، فهو غير جامع، حيث شمل الإخبار في الحقوق، ولم يشمل الرؤية بالهلال. ثانياً: الشهادة عند المالكية:

(1) إخبار عدل حاكماً بما علم ولو بأمر عام ليحكم بمقتضاه.⁽³⁵⁾

(2) إخبار حاكم عن علم ليقضي بمقتضاه.⁽³⁶⁾

ويلاحظ أن السادة المالكية لم يشترطوا لفظاً خاصاً، بل كل لفظ يدل صراحة أو دلالة على الشهادة، فكل لفظ أدى إلى إظهار الحق يسمى شهادة.

ويؤخذ عليه أنه غير مانع، فيدخل فيه الإقرار على النفس بحق للغير، والدعوى وهي إخبار بحق للنفس على الغير.

ثالثاً: الشهادة عند الشافعية:

(1) إخبار بحق للغير على الغير بلفظ أشهد.⁽³⁷⁾

³¹ () محمد بن علي الحصكفي، الدر المختار شرح تنوير الأبصار، تحقيق: عبد المنعم خليل، الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية (2002م)، ص 483.

³² () العناية للبايرتي - بهامش شرح فتح القدير (ج 6/312)؛ ود. أحمد إبراهيم بك، طرق القضاء في الشريعة الإسلامية، بدون طبعة، القاهرة، المطبعة السلفية، (1347هـ)، ص 282.

³³ () علي حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، بدون طبعة، بيروت، دار الجيل، (1423هـ/2003م)، ج 3، ص 346.

³⁴ () الطرابلسي، معين الحكام في شرح أصول الأقضية ومناهج الأحكام، ط دار المعرفة (ج 1/ص 166) وعلى حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، ج 3، ص 346.

³⁵ () أحمد بن محمد بن محمد الدردير أبي البركات، الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك، تحقيق: مصطفى كمال وصفي، الطبعة الأولى، القاهرة، دار المعارف، (1986م)، ج 4، ص 238.

³⁶ () محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، بدون طبعة، بيروت، دار الفكر، بدون تاريخ، ج 4، ص 164.

وهذا التعريف يخرج به الإقرار وهو الإخبار بحق للغير على النفس، وتخرج به الشهادة التي لا تكون بهذا اللفظ فلا تقبل، وتخرج به الدعوى التي هي الإخبار بحق لنفسه على سواه، ويتناول حقوق الله تعالى كما يتناول حقوق العباد.

وهذا التعريف وإن منع الدعوى والإقرار من الدخول في الشهادة إلا أنه يشمل الإخبارات الكاذبة وغيرها.⁽³⁸⁾

(2) إخبار عن شيء بلفظ خاص.⁽³⁹⁾

رابعاً: الشهادة عند الحنابلة:

(1) إخبار بما علمه الشاهد بلفظ خاص كشهدت وأشهد.⁽⁴⁰⁾

(2) الإخبار بما علمه بلفظ خاص.⁽⁴¹⁾

واعترض على تعريفات الشهادة بأنه غير مانع، فيدخل فيه الإقرار وهو إخبار بحق للغير على الذات، كما تدخل فيه الدعوى وهي: إخبار الشخص بما علمه بلفظ بحق للشخص على غيره.⁽⁴²⁾

³⁷ (شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي، وشهاب الدين أحمد البرلسي الملقب بـ (عميرة)، حاشيتا قليوبي وعميرة على كنز الراغبية، شرح منهاج الطالبين للإمام النووي في فقه الشافعية، ضبطه وصححه وخرج آياته: عبد اللطيف عبد الرحمن، بدون طبعة، بيروت، دار الكتب العلمية، (2015م)، ج4، ص319؛ سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهرى، المعروف بالجمال، فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمال (منهج الطلاب اختصره زكريا الأنصاري من منهاج الطالبين للنووي ثم شرحه في شرح منهج الطلاب)، بدون طبعة، بيروت، دار الفكر، بدون تاريخ، ج5، ص377.

³⁸ (انظر مواهب الجليل على شرح مختصر خليل، ط دار صادر بيروت (ج4/165).

³⁹ (زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، بدون، طبعة، بيروت، دار الفكر، (1414هـ/1994م)، ج2، ص272؛ شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، بدون طبعة، بيروت، دار الفكر، ج2، ص612.

⁴⁰ (موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي، ثم الصالحي، شرف الدين، أبو النجا، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: عبد اللطيف محمد السبكي، بدون طبعة، القاهرة، المكتبة التجارية، (1335هـ)، ج4، ص430.

⁴¹ (منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي، كشف الإقناع عن متن الإقناع، بدون طبعة، بيروت، دار الكتب العلمية، بدون تاريخ، ج6، ص404.

⁴² (انظر د. أحمد حميد النعيمي، أحكام الشهادة في الفقه والقانون الوضعي (دراسة مقارنة)، بدون طبعة، المعتر للنشر والتوزيع، (2018م)، ص34.

التعريف المختار:

بعد استقرار تعريفات العلماء للشهادة وبيان ما وجه إليها من اعتراضات أرى أن التعريف المختار للشهادة هو أنها إخبار الشخص حاكمًا بما علمه بلفظ خاص لدى الحاكم.⁽⁴³⁾

وهذا التعريف هو المختار لأنه ذكر أهم شروط الشهادة وهي أن تكون بين يدي القاضي. ويلاحظ أن فقهاء المذاهب الأربعة عرفوا الشهادة بأنها الإخبار وذلك لدلالة لفظ الخبر على الشهادة، وإن كان فقهاء السادة المالكية جعلوا كل لفظ يدل على إظهار الحق يسمى شهادة.

وعلى ضوء ما تقدم من تعريف الشهادة في الاصطلاح يتبين الارتباط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، فإن صفة الشهادة الشرعية أن يحضر الشاهد المشهود عليه ويعاينه ويطلع عليه ثم يعلم الحاكم بذلك ويبينه له ويخبره به إخبارًا جازمًا.

قال " ولو كان القاضي عدلا ففسق بأخذ الرشوة أو غيره لا ينزل ويستحق العزل، وهذا هو ظاهر المذهب وعليه مشايخنا رحمهم الله. وقال الشافعي رحمه الله: الفاسق لا يجوز قضاؤه كما لا تقبل شهادته عنده، وعن علمائنا الثلاثة رحمهم الله في النواذر أنه لا يجوز قضاؤه. وقال بعض المشايخ رحمهم الله: إذا قلد الفاسق ابتداء يصح، ولو قلد وهو عدل ينزل بالفسق لأن المقلد اعتمد عدالته فلم يكن راضيا بتقليده دونها. وهل يصلح الفاسق مفتيا؟ قيل لا لأنه من أمور الدين وخبره غير مقبول في الديانات، وقيل يصلح لأنه يجتهد كل الجهد في إصابة الحق حذار النسبة إلى الخطأ، وأما الثاني فالصحيح أن أهلية الاجتهاد شرط الأولوية."

اتفق الفقهاء على اشتراط العدالة في القاضي والشاهد، فيجب أن يكون القاضي عدلاً. والعدالة، كما يعرفها الحنفية: هي الاستقامة على أمر الإسلام، واعتدال العقل، ومعارضة الهوى، والعدل: هو من لم يطعن عليه بطن ولا فرج، وهو من يكون مجتنباً للكبائر غير مصر على الصغائر، ومن يكون صلاحه أكثر من فساد، وصوابه أكثر من خطئه، وهو من تكون مروءته ظاهرة.⁽⁴⁴⁾

⁴³ (د. إبراهيم عبد الغفار، أحكام القضاء بالشاهد واليمين، مجلة كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، العدد (122)، (2019م)، ص 921.

⁴⁴ (الكاساني، بدائع الصنائع، ج 6، ص 268؛ ابن نجيم، البحر الرائق، ج 7، ص 104؛ ابن عابدين، رد المختار على الدر المختار، ج 5، ص 465؛ وانظر أيضاً: الحطاب، مواهب الجليل، ج 6، ص 150؛ الشربيني، مغنى المحتاج، ج 4، ص 427؛ الشيرازي، المهذب، ج 2، ص 343؛ ابن قدامة، المغني، ج 9، ص 167؛ الحجاوي، الإقناع، ج 4، ص 437؛ ابن حزم، المحلى، ج 9، ص 393 وما بعدها.

واستدلوا على اشتراط العدالة في القاضي، والشاهد، بالكتاب والسنة والمعقول، على الوجه التالي:

(أ) الكتاب: فقد استدلوا بقوله تعالى: (مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ)⁽⁴⁵⁾، فقد أوجب هذا النص الكريم، أن يكون الشاهد مرضياً، والشاهد المرضي هو الشاهد العدل. وقوله تعالى: (وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ)⁽⁴⁶⁾، فهذا النص واضح في وجوب أن يكون الشهود عدولاً، فقد قيد النص أن يكون الشاهدان من العدول. وقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ)⁽⁴⁷⁾، فقد أمر الله سبحانه وتعالى في هذا النص، بالتوقف في الأخذ بنبأ الفاسق، والشهادة نبأ، فوجدب التوقف والامتناع⁽⁴⁸⁾؛ لأن من ثبت فسقه، بطل قوله في الإخبار إجماعاً؛ لأن الخبر أمانه، والفسق قرينة يبطلها.⁽⁴⁹⁾

(ب) السنة: فقد استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ، وَلَا مَحْدُودٍ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا ذِي غَمْرٍ»⁽⁵⁰⁾ عَلَى أَخِيهِ»⁽⁵¹⁾. ويفسر بعض الفقهاء الخيانة: بأنها تشمل جميع ما افترض الله على العباد القيام به، واجتناب ما نهى عنه من صغر ذلك وكبيره، ولا يخصها بأمانات الناس؛ لأن الإنسان إذا كان خائناً، فليس له تقوى ترده عن محظورات الدين التي منها الكذب، فلا تحصل الثقة بخبره؛ لأنه مظنة تهمة⁽⁵²⁾، فلا تقبل شهادته.

(ج) المعقول: فقالوا: لأن دين الفاسق لم يزرعه عن ارتكاب محظورات الدين، فلا يؤمن أن لا يزرعه عن الكذب، فلا تحصل الثقة بخبره. إذا تقرر هذا، فالفسوق نوعان: أحدهما: من حيث الأفعال، ولا نعلم خلافاً في رد شهادته. والثاني: من جهة الاعتقاد، وهو اعتقاد البدعة، فيوجب رد الشهادة أيضاً.⁽⁵³⁾

⁴⁵ (سورة البقرة: من الآية [282].

⁴⁶ (سورة الطلاق: من الآية [2].

⁴⁷ (سورة الحجرات: الآية [6].

⁴⁸ (ابن قدامة، المغني، ج14، ص147.

⁴⁹ (القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج16، ص343.

⁵⁰ (الغمر: بفتح الغين وكسر ها: الحقد والبغضاء، وأصل الغمر، الشيء الكثير، ورجل غمر — بالفتح — لم يجرب الأمور. انظر: إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، مرجع سابق، ج2، ص685؛ الفيروز آبادي، القاموس المحيط، مرجع سابق، ج3، ص416.

⁵¹ (أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون، حديث رقم (6940)، الطبعة الأولى، بيروت، مؤسسة الرسالة، (2001م)، ج11، ص531. حديث حسن. الحجاج بن أرطاة على ضعفه متابع. يزيد: هو ابن هارون.

⁵² (محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، أبو إبراهيم، عز الدين، المعروف كأسلافه بالأمير، سبل السلام، بدون طبعة، القاهرة، دار الحديث، بدون تاريخ، ج4، ص128؛ ابن قدامة، المغني، ج14، ص(148/147).

⁵³ (ابن قدامة، المغني، ج14، ص148.

وضابط العدالة في القاضى: هو أن يكون مجتنبًا الكبار، وغير مصر على الصغائر، وسليم السريرة أي العقيدة، ومأمونًا عند الغضب، ومحافظًا على مروءة مثله.

قال: (فأما تقليد الجاهل فصحيح عندنا خلافا للشافعي رحمه الله، وهو يقول: إن الأمر بالقضاء يستدعي القدرة عليه ولا قدرة دون العلم. ولنا أنه يمكنه أن يقضي بفتوى غيره، ومقصود القضاء يحصل به وهو إيصال الحق إلى مستحقه. وينبغي للمقلد أن يختار من هو الأقدر والأولى لقوله عليه الصلاة والسلام: "من قلد إنسانا عملا وفي رعيته من هو أولى منه فقد خان الله ورسوله وجماعة المسلمين". وفي حد الاجتهاد كلام عرف في أصول الفقه

وحاصله أن يكون صاحب حديث له معرفة بالفقه ليعرف معاني الآثار أو صاحب فقه له معرفة بالحديث لئلا يشتغل بالقياس في المنصوص عليه وقيل أن يكون مع ذلك صاحب قريحة يعرف بها عادات الناس لأن من الأحكام ما يبتني عليها.

قال: "ولا بأس بالدخول في القضاء لمن يثق بنفسه أن يؤدي فرضه" لأن الصحابة رضي الله عنهم تقلدوه وكفى بهم قدوة، ولأنه فرض كفاية لكونه أمرا بالمعروف.

قال: "ويكره الدخول فيه لمن يخاف العجز عنه ولا بأس على نفسه الحيف فيه" كي لا يصير شرطا لمباشرته القبيح، وكره بعضهم الدخول فيه مختارا لقوله عليه الصلاة والسلام: "من جعل على القضاء فكأنما ذبح بغير سكين" والصحيح أن الدخول فيه رخصة طمعا في إقامة العدل والترك عزيمة فلعله يخطئ ظنه ولا يوفق له أو لا يعينه عليه غيره، ولا بد من الإعانة إلا إذا كان هو أهلا للقضاء دون غيره فحينئذ يفترض عليه التقلد صيانة لحقوق العباد وإخلاء للعالم عن الفساد.

قال: "وينبغي أن لا يطلب الولاية ولا يسألها" لقوله عليه الصلاة والسلام: "من طلب القضاء وكل إلى نفسه ومن أجبر عليه نزل عليه ملك يسدده" ولأن من طلبه يعتمد على نفسه فيحرم، ومن أجبر عليه يتوكل على ربه فيلهم. "ثم يجوز التقلد من السلطان الجائر كما يجوز من العادل" لأن الصحابة رضي الله عنهم تقلدوه من معاوية رضي الله عنه والحق كان بيد علي رضي الله عنه في نوبته، والتابعين تقلدوه من الحجاج وكان جائزا إلا إذا كان لا يمكنه من القضاء بحق لأن المقصود لا يحصل بالتقلد، بخلاف ما إذا كان يمكنه.

قال: "ومن قلد القضاء يسلم إليه ديوان القاضي الذي كان قبله" وهو الخرائط التي فيها السجلات وغيرها، لأنها وضعت فيها لتكون حجة عند الحاجة فتجعل في يد من له ولاية

القضاء. ثم إن كان البياض من بيت المال فظاهر، وكذا إذا كان من مال الخصوم في الصحيح لأنهم وضعوها في يده لعمله وقد انتقل إلى المولى، وكذا إذا كان من مال القاضي هو الصحيح لأنه اتخذه تدبيرا لا تمولا، ويبعث أمينين ليقبضها بحضرة المعزول أو أمينه ويسألانه شيئا فشيئا، ويجعلان كل نوع منها في خريطة كي لا يشتبه على المولى، وهذا السؤال لكشف الحال لا للإلزام.

قال: "وينظر في حال المحبوسين" لأنه نصب ناظرا "فمن اعترف بحق ألزمه إياه" لأن الإقرار ملزم "ومن أنكر لم يقبل قول المعزول عليه إلا ببينة" لأنه بالعزل التحق بالرعايا، وشهادة الفرد ليست بحجة لا سيما إذا كانت على فعل نفسه "فإن لم تقم بينة لم يعجل بتخليته حتى ينادى عليه وينظر في أمره" لأن فعل القاضي المعزول حق ظاهر فلا يعجل كي لا يؤدي إلى إبطال حق الغير. "وينظر في الودائع وارتفاع الوقوف فيعمل فيه على ما تقوم به البينة أو يعترف به من هو في يده" لأن كل ذلك حجة. "ولا يقبل قول المعزول" لما بينا "إلا أن يعترف الذي هو في يده أن المعزول سلمها إليه فيقبل قوله فيها" لأنه ثبت بإقراره أن اليد كانت للقاضي فيصح إقرار القاضي كأنه في يده في الحال، إلا إذا بدأ بالإقرار لغيره ثم أقر بتسليم القاضي فيسلم ما في يده إلى المقر له الأول لسبق حقه ويضمن قيمته للقاضي بإقراره الثاني ويسلم إلى المقر له من جهة القاضي.

قال: "ويجلس للحكم جلوسا ظاهرا في المسجد" كي لا يشتبه مكانه على الغرباء وبعض المقيمين، والمسجد الجامع أولى لأنه أشهر. وقال الشافعي رحمه الله: يكره الجلوس في المسجد للقضاء لأنه يحضره المشرك وهو نجس بالنص والحائض وهي ممنوعة عن دخوله. ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: "إنما بنيت المساجد لذكر الله تعالى والحكم". وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل الخصومة في معتكفه وكذا الخلفاء الراشدون كانوا يجلسون في المساجد لفصل الخصومات، ولأن القضاء عبادة فيجوز إقامتها في المسجد كالصلاة. ونجاسة المشرك في اعتقاده لا في ظاهره فلا يمنع من دخوله، والحائض تخبر بحالها فيخرج القاضي إليها أو إلى باب المسجد أو يبعث من يفصل بينها وبين خصمها كما إذا كانت الخصومة في الدابة. ولو جلس في داره لا بأس به ويأذن للناس بالدخول فيها، ويجلس معه من كان يجلس قبل ذلك لأن في جلوسه وحده تهمة.

قال: "ولا يقبل هدية إلا من ذي رحم محرم أو ممن جرت عادته قبل القضاء بمهاداته" لأن الأول صلة الرحم والثاني ليس للقضاء بل جرى على العادة، وفيما وراء ذلك يصير أكلا بقضائه، حتى لو كانت للقريب خصومة لا يقبل هديته، وكذا إذا زاد المهدي على المعتاد أو كانت له خصومة لأنه لأجل القضاء فيتحاماه. ولا يحضر دعوة إلا أن تكون عامة لأن الخاصة لأجل القضاء فيتهم بالإجابة، بخلاف العامة، ويدخل في هذا الجواب قريبه وهو

قولهما. وعن محمد رحمه الله أنه يجيبه وإن كانت خاصة كالهديّة، والخاصة ما لو علم المضيف أن القاضي لا يحضرها لا يتخذها.

قال: "ويشهد الجنازة ويعود المريض" لأن ذلك من حقوق المسلمين، قال عليه الصلاة والسلام: "للمسلم على المسلم ستة حقوق" وعد منها هذين. "ولا يضيف أحد الخصمين دون خصمه" لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ولأن فيه تهمة.

قال: "وإذا حضرا سوى بينهما في الجلوس والإقبال" لقوله عليه الصلاة والسلام: "إذا ابتلي أحدكم بالقضاء فليسو بينهم في المجلس والإشارة والنظر" "ولا يسار أحدهما ولا يشير إليه ولا يلقنه حجة" للتهمة ولأن فيه مكسرة لقلب الآخر فيتترك حقه "ولا يضحك في وجه أحدهما" لأنه يجترئ على خصمه "ولا يمازحهم ولا واحدا منهم" لأنه يذهب بمهابة القضاء.

قال: "ويكره تلقين الشاهد" ومعناه أن يقول له أتشهد بكذا وكذا، وهذا لأنه إعانة لأحد الخصمين فيكره كتلقين الخصم. واستحسنه أبو يوسف رحمه الله في غير موضع التهمة لأن الشاهد قد يحصر لمهابة المجلس فكان تلقينه إحياء للحق بمنزلة الإشخاص والتكفيل.

فصل: في الحبس

قال: "وإذا ثبت الحق عند القاضي وطلب صاحب الحق حبس غريمه لم يعجل بحبسه وأمره بدفع ما عليه" لأن الحبس جزاء المماطلة فلا بد من ظهورها، وهذا إذا ثبت الحق بإقراره لأنه لم يعرف كونه مماطلا في أول الوهلة فلعله طمع في الإمهال فلم يستصحب المال، فإذا امتنع بعد ذلك حبسه لظهور مطله، أما إذا ثبت بالبينة حبسه كما ثبت لظهور المطل بإنكاره".

الحبس مأخوذ من حبس يحبس حبساً فهو محبوس وحبيس، واحتبسه وحبسه أمسكه عن وجهه، والحبس ضد التخلية.

والحبسة: الاسم من الاحتباس يقال الصمت حبسه وحبسه ضبطه، واحتبسه اتخذه حبساً والحبس والمحبسة والمحبس - اسم الموضع.

ويقال للرجل: محبوس وحبيس، وللجماعة: محبوسون وحُبُس (بصمتين؛ والمرأة: حبيسة، وللجمع: حبائس، ولمن يقع منه الحبس: حابس) .⁵⁴

⁵⁴() لسان العرب فصل الزاى والسن - حرف النون والمصباح المنير - مادة حبس (1/ 42).

ويقصد بالتوقيف فى الاصطلاح الفقهي : هو تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه ، والخروج إلى أشغاله ومهامه الدينية والاجتماعية(.)⁵⁵

ومن الألفاظ المرادفة للتوقيف السجن يفتح السجين مصدر سجن ، أما بكسر السين فهو مكان الحبس ، والجمع سجون ، قال تعالى : (قَالَ رَبِّ السَّجُنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ)⁽⁵⁶⁾ حيث قرئ بفتح السين على المصدر ، وبكسرهما على المكان ، ولكن الأشهر هو الكسر (.)⁵⁷

ومن الألفاظ المرادفة للتوقيف أيضا الاعتقال ، والحصر ، يقال اعتقلت الرجل حبسته ، واعتقل لسانه إذا حبس ومنع من الكلام (.)⁵⁸

والحصر أيضا المنع والحبس ، ومنه قوله تعالى : (وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا)⁽⁵⁹⁾ أى سجنًا وحبسًا " (.)⁶⁰

ويجتمع الحصر والحبس فى أنه يراد بهما المنع ، ويفترق الحصر عن الحبس فى أن المحصر قد يكون غير متمكن منه بخلاف المحبوس⁽⁶¹⁾ ، فالصلة بينهما العموم والخصوص .

والمقصود بالحبس الاحتياطي :

يقصد بالحبس الاحتياطي هو إجراء تحفظي يتخذ قبل المتهم الذي لم تثبت إدانته بعد ، فالمحبوس احتياطياً أثناء التحقيق هو شخص لم تثبت إدانته، ويحتمل أن تظهر براءته ، والحبس بالنسبة له ليس عقوبة ، وإنما مجرد وسيلة احتياطية أثناء التحقيق لمنعه من الهروب أو عن التأثير على مجرى التحقيق ؛ ولذلك فإن المحبوس احتياطاً يعامل فى السجن معاملة تختلف عن المحكوم عليهم (.)⁶²

⁵⁵ () بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى الحنفى 174/7 .

⁵⁶ () سورة يوسف - جزء من الآية 33 .

⁵⁷ () تفسير الطبرى 125/12 .

⁵⁸ () المصباح المنير - مادة عقل (1/188) .

⁵⁹ () سورة الإسراء - جزء من الآية 8 .

⁶⁰ () وقد استعمل الفقهاء الإحصار فى المنع عن المضى فى أفعال الحج ، سواء أكان من العدو ، أم بالحبس ، أم بالمرض - شرح فتح القدير 296/2 .

⁶¹ () الفروق فى اللغة العسكرية ، ص 107 .

⁶² () د / أحمد فتحى بهنسى - العقوبة فى الفقه الإسلامى - ط دار الشروق 1983م (ص 204) نقلا عن الإجراء الجنائية للدكتور على زكى العرابى .

وبالرجوع إلى كتب المذاهب الفقهية نجد أنهم قد عرفوا التوقيف الاحتياطي بالمعنى الذي ذكرناه ، وسوف نذكر فيما يلي بعض أقوال الفقهاء بتعريف الحبس الاحتياطي.

قال السرخسي :

" إذا كان القاضي لا يعرف عدالة الشهود ، فإنه يحبسه (أى المتهم) حتى يسأل عن الشهود ، وهذا لأنه لو خلى سبيله هرب فلا يظفر به بعد ذلك، وحبسه هذا لأنه صار متهماً بارتكاب الفاحشة " (.)⁶³

وقال ابن عابدين :

" فإن لم يعرف القاضي عدالتها (أي الشاهدين في جريمة القذف) حبس القاضي المتهم حتى يسأل عنهما وكذا لو أقام شاهداً واحداً عدلاً ، وادعى أن الثاني في المصر حبسه يومين أو ثلاثة ، ولو زعم أن له بينه في المصر حبسه إلى آخر المجلس – قالوا : والمراد بالحبس في الأولين حقيقته وفي الثالث الملازمة " (.)⁶⁴

وقال الباجي – من المالكية :

" الحبس كعقوبة إنما يكون بعد تحقق الحكم عليه ، أما الحبس الذي كان قبل ذلك لاستبراء أمره والنظر فيه ، فليس من هذا الجنس في شئ بل حكمه مخالف لحكمه لما يختص به من التعبير وغيره " (.)⁶⁵

وقال الإمام الماوردي عند الحديث عن أحكام الجرائم :

" ولها عند التهمة حال استبراء تقتضيه السياسة الدينية ، ولها عند ثبوتها وصحتها حال استيفاء توجبه الأحكام الشرعية .

فأما حالها بعد التهمة وقبل ثبوتها وصحتها فمعتبر بحال النظر فيها ، ... فإن كان الناظر الذي رفع إليه هذا المتهم أميراً كان له مع هذا المتهم من أسباب الكشف والاستبراء ما ليس للقضاة والحكام " (.)⁶⁶

لقد اختلفت وجهة نظر الفقهاء في مدى مشروعية الحبس ، وانقسموا في ذلك على رأيين:

⁶³ () المبسوط للسرخسي (ج 38/9) ط دار المعرفة بيروت .

⁶⁴ () حاشية ابن عابدين (45/4) .

⁶⁵ () المنتقى للباجي (125/7) .

⁶⁶ () الماوردي – الأحكام السلطانية والولايات الدينية – ط دار ابن خلدون (ص 227) .

الرأي الأول : ذهب جمهور الفقهاء الحنفية (67) ، والمالكية ، وجمهور الشافعية ، والحنابلة والشيعة الزيدية والإمامية إلى مشروعية الحبس ، كوسيلة من ضمن الوسائل التعزيرية والتقديرية للقاضي .

قال الباجي : " وقد روى ابن حبيب عن مطرف من سرق متاع فاتهم من جيرانه رجلاً غير معروف أو اتهم رجلاً غريباً أنه يحبس حتى يكشف عن حاله ولا يطل حبسه ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حبس رجلاً اتهمه المسروق منه بسرقة وقد صحبه في السفر " . (68)

وجاء في المدونة " قلت أرأيت الرجل يشهد على الرجل بشرب الخمر والزنا فيقول القاضي أنا آتيك بالشهود أيضاً على ذلك ، قال : إن كان أمراً قريباً في الحضر حبسه القاضي " . (69)

وقال الإمام الشافعي : " وكل قصاص وجب لصبي أو مغلوب على عقله فليس لأب ولا وليه أخذ القصاص ولا عفوه ويحبس الجاني حتى يبلغ الصبي أو يفيق المعتوه " . (70)

(67) وتحقيق مذهب الحنفية في هذه المسألة أن لهم ثلاثة آراء أو ثلاث روايات تعبر عن مدى توافقهم أو اختلافهم مع الجمهور ، وسوف نذكرها فيما يلي :
الرواية الأولى : وهي المروية عن الصحابين أبو يوسف ومحمد والتي أفادت أنه إذا قامت البينة على ارتكاب الجريمة وبقي بعض الإجراءات الأخرى ، كما لو بقي السؤال عن الشهود أو تعديلهم ، فإن المتهم يحبس احتياطياً ، لأن قول البينة يصلح جحة لإثبات الحق ، وقبل إقامة البينة لا يحبس المتهم - الفتاوى الهندية - (ح 414/3) .
والرواية الثانية : ومقتضى هذه الرواية عدم جواز الحبس احتياطياً في الحدود والقصاص ، لإمكان الاستعاضة عنه بغيره وهو الاستيثاق بالكفالة ، وهذا ممكن سواء ثبتت الجريمة على المتهم ببينة كاملة ولم تزكى بعد أو كانت البينة شاهد واحد - الهداية للمرغيناني - مطبوع مع شرح فتح القدير (178/7) ، وتبيين الحقائق (152/4) .
الرواية الثالثة : وهي رواية ذكرها الكمال بن الهمام ومقتضاها عدم جواز حبس المتهم في دعوى القذف والقصاص مطلقاً ، أي سواء وجدت البينة وبقي تعديلها أو وجد شاهد عدل ، ويتخذ بدلاً من الحبس إجراء الكفالة والمقصود - وهو الاستيثاق - يحصل بها . =
وبذلك يكون روى عن الحنفية روايتان رواية يحبس ولا يكفل ، وفي أخرى يكفل ولا يحبس وقد جمع الكمال بين الروايتين بأن المراد بالرواية الأولى أنه يحبس إن لم يقدر على كفيل ، وبالثانية يكفل بلا حبس إن قدر على الكفيل - شرح فتح القدير (179/7) .

(68) المنتقى شرح موطأ الإمام مالك (166/7) .

(69) المدونة الكبرى طبعة دار الفكر العربي (404/4) .

(70) الأم للإمام الشافعي (53/6) .

وقال ابن النجار : ومن أقام بينة وسأل حبس خصمه ، أو أقام شاهداً وسأل حبسه حتى يقيم الآخر أجيب " (.)⁷¹

الرأي الثاني : ذهب بعض الحنفية فى رواية عن الصاحبين (72) ، وأبو سعيد الإصطخري – من الشافعية – وابن حزم الظاهري ، إلى أنه لا يجوز حبس المتهم إلا بعد ثبوت الحجة الكاملة
- الأدلة -

أدلة الرأي الأول :

استدل جمهور الفقهاء القائل بمشروعية التوقيف الاحتياطي بالقرآن والسنة والمعقول :

أولاً : القرآن :

1- قول الله تعالى : (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فاسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا) (.)⁷³

وجه الدلالة : أمر الله سبحانه وتعالى بإمساك النساء فى البيوت إذا فعلن الفاحشة والإمساك هو الحبس فى البيوت ، وكان فى صدر الإسلام قبل أن يكثر الجناة ، فلما كثروا وخشى فوتهن اتخذ لهن سجن والمعنى أمر الله بحبسهن فى البيوت حتى يمتن أو يجعل الله لهن سبيلاً " (.)⁷⁴

2- قول الله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهِادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ) (.)⁷⁵

وجه الدلالة بقوله تعالى : (تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ) المراد بالصلاة صلاة العصر ، لأن النبى – صلى الله عليه وسلم – حبس عديا وتميما إلى ما بعد صلاة العصر حتى يحلفا ، لأن العمل قد جرى عليه ، فكان التحليف فيه هو المعروف ، ولأنه هو الوقت الذى يقعد فيه

⁷¹ () شرح منتهى الإرادات (ج 2/488) .

⁷² () شرح فتح القدير (7/178) ، وشرح الكنز للعيني (2/70) ، وقد أشرنا الى نص هذه الرواية فى الرأي الأول .

⁷³ () سورة النساء – الآية (15) .

⁷⁴ () تفسير الطبرى (4/292) .

⁷⁵ () سورة المائدة – جزء من الآية (106) .

الحكام للفصل فى المظالم والدعاوى ، إذ يكون الناس قد فرغوا من معظم أعمال النهار –
فدل هذا على جواز الحبس الاحتياطى " (.)⁷⁶

3- قول الله تعالى : () إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ (.)⁷⁷
ومحل الشاهد فى الآية (أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ) ، أى : ينفوا من بلد إلى بلد ، ويسجنوا
فيه حتى تظهر توبتهم ، وقال أبو حنيفة : يحبس فى البلد بعينه ، ومذهب مالك : أن الإمام
مخير فى المحارب بين ما تقدم ، إلا أنه قال : إن كان قتل فلابد من قتله ، وإن لم يقتل
فالأحسن أن يؤخذ فيه بأيسر العقاب (.)⁷⁸

4- قول الله تعالى : () ثُمَّ بَدَأَ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيْسَجُنَّهُ حَتَّى حِينٍ وَدَخَلَ مَعَهُ
السَّجْنَ فَتَيَانٍ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ
رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (.)⁷⁹
وجه الدلالة : أن القرآن الكريم حكى أنه كان فى مصر سجن يدخله من حامت حوله
شبهة مثل خادمى العزيز اللذين اشتبه فيهما واتهمهما بدس السم له ، مما يدل على مشروعية
حبس التهمة ، وإلا لما أورده القرآن الكريم (.)⁸⁰

ثانياً : من السنة :

استدل جمهور الفقهاء على مشروعية حبس التهمة بما يلى :

1- ما روى عن ابى هريرة - رضى الله عنه - أنه قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم -
خيلاً قبل نجد ، فجاءت برجل من بنى حنيفة يقال له ثمامة بن أثال ، فربطوه
بسارية من سوارى المسجد ، فخرج إليه فقال : ما عندك يا ثمامة ؟ فقال : عندى خير
يا محمد ، إن تقتل تقتل ذامم ، وإن تنعم تنعم على شاكرك وإن كنت تريد المال فسل منه

⁷⁶ () تفسير المراعى - للدكتور محمد المراعى - طبعة دار إحياء التراث العربى بيروت (50/7) .

⁷⁷ () سورة المائدة - جزء من الآية (33) .

⁷⁸ () ابن عجيبة - البحر المديد فى تفسير القرآن المجيد للعلامة أبى العباس أحمد بن محمد المهدي
بن عجيبة الحسنى - ط دار الكتب العلمية - بيروت (173/2) ، وتفسير الإمام الشافعى للمطلبى
القرشى - الطبعة الأولى دار الترميزية (735/2) ، والتفسير الكبير للفخر الرازى ط دار التراث
العربى (217/11) .

⁷⁹ () سورة يوسف - عليه السلام - الآتيان (35-36) .

⁸⁰ () تفسير ابن كثير (216/2) ، وتفسير القرطبى (187/9) .

، فتركه النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى مرت ثلاث ليال يقول فيها ما قال في الأولى ، ثم أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بإطلاقه " (.)⁸¹

وجه الدلالة : أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - حبس ثمانية ثلاثة أيام ، وقد قال له ثمانية في اليوم الأول إن قتلتنى فمن حقك ، لأنك تقتل عدوا لك عنده ثأر ، وإن تعف عني وتنعم على وجدني شاكرًا مقدراً للمعروف ، وإن أردت مالاً فداء لى ، فسل منه ما شئت ، فتركه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محبوساً لليوم الثانى ، وأعاد ثمانية نفس الجواب فتركه لليوم الثالث ، فأعاد عليه نفس السؤال وأعاد ثمانية نفس الجواب .

وهذا فيه دليل كما يقول القاضى عياض على جواز ربط الأسير وتقييده ، وكذلك من عليه حق وألّده (.)⁸²

2- ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريح أخبرنى يحيى بن سعيد الأنصارى عن عراك بن مالك قال : أقبل رجلان من بنى غفار حتى نزلا منزلاً بضجنان (83) من مياه المدينة وعندها ناس من غطفان معهم ظهر لهم ، فأصبح الغطفانيون قد أضلوا بعيرين من إبلهم فأتهموا بهما الغفاريين ، فأقبلوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وذكروا أمرهم ، فحبس أحد الغفاريين ، وقال للآخر : أذهب فالتمس ، فلم يكن إلا يسيراً حتى جاء بهما ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لأحد الغفاريين - حسبت أنه المحبوس - استغفر لى ؟ فقال : غفر الله لك يا رسول الله ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ولك وقتلك فى سبيله ، قال : فقتل يوم اليمامة " (.)⁸⁴

3- ما روى من طريق عبد الرزاق عن معمر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية بن حيدة ، قال " أخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ناساً من قومه فى تهمة فحبسهم ، فجاء رجل من قومي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يخطب فقال : يا محمد ، على ما تحبس جيرتى ؟ فصمت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : " إن ناساً يقولون : إنك لتنتهى عن الشئ وتستخلى به ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يقول ؟ يقول الرواى : فجعلت أعرض بينهما بكلام مخافة أن يسمعها فيدعو على

⁸¹ () صحيح البخارى - كتاب المغازى - باب وفد بنى حنيفة رقم الحديث (4114) ، وصحيح مسلم - كتاب الجهاد والسير - باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه (1386/3) رقم الحديث (1764) ، والتوشيح على الجامع الصحيح للإمام السيوطى - ط دار الكتب العلمية (127/4) .

⁸² () إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضى أبى الفضل عياض بن موسى بنى عياض - ط دار الوفاء (98/6) وفتح البارى بشرح صحيح البخارى (88/8) ط دار المعرفة وفتح المنعم بشرح صحيح مسلم للدكتور موسى شاهين لاشين - ط دار الشروق (175/7) .

⁸³ () ضجنان : جبل قيل بتهامة ، وقيل على بعد بريد من مكة .
⁸⁴ () مصنف عبد الرزاق (216/10) ط المجلس العلمى بالهند ، وحاشية الشلبى - مع تبیین الحقائق (152/4) .

قوى دعوة لا يفلحون بعده .. فلم أزل على ذلك حتى قال النبي - صلى الله عليه وسلم - خلوا له عن جيرانه " (.)⁸⁵

وجه الدلالة : دل هذا الحديث كما ذكر الفقهاء على مشروعية التوقيف الاحتياطي ولو بتهمة (⁸⁶) ، ولأن القاضي نصب لإيصال الحقوق إلى مستحقيها ، فإن امتنع المطلوب من أداء حق الطالب لم يكن للقاضي بُد من أن يجبره على الأداء ، ولا خلاف أن لا جبر بالضرب فيكون بالحبس أولى (.)⁸⁷

4- ما رواه البخاري في صحيحة عن ابن عمر قال : أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل خيبر فقاتلهم حتى ألجأهم إلى قصدهم وغلبهم على الأرض والزرع والنخيل ، فصالحوه على أن يجلوها منها ولهم ما حملت ركابهم ، ولرسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصفراء والبيضاء والحلقة ويخرجون منها ، واشترطوا عليهم ألا يكذبوا ولا يغيبوا شيئاً فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد ، فغيبوا مسكاً فيه مال لحبي بن أخطب كان قد احتمله إلى خيبر حين أجلت النضير ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمى حبي : ما فعل مسك " أو كنز " حبي الذي جاء به من النضير ؟ فقال : أذهبت النفقات والحروب فحبسه النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال : العهد قريب والمال أكثر من ذلك " (.)⁸⁸

دل هذا الحديث على مشروعية الحبس الاحتياطي خاصة إذا ظهرت الأمارات والعلامات التي تستوجب إصدار الحكم بالحبس ، وظهر هذا من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - العهد قريب والمال أكثر من ذلك - .

وجه الدلالة :

ثالثاً : الآثار المروية عن الصحابة :

1- فقد سجن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - الحطيئة لهجائه الزبرقان بن بدر ، سجنه في مكان محكم مظلم يختلف عما كانت عليه أماكن السجن قبل الفاروق (.)⁸⁹ وسجن عمر أيضاً ضبيعاً على سؤاله عن الذاريات والمرسلات والنازعات ، وشبههن ، وأمره للناس بالنفقة في ذلك ، وضربه مرة بعد مرة ، ونفاه إلى العراق ، وقيل إلى البصرة ،

⁸⁵ () مسند الإمام أحمد ط الحلبي (2/5) ، والسنن الكبرى للبيهقي (53/6) .
⁸⁶ () سنن الترمذي - باب ما جاء في الحبس في التهمة ، رقم الحديث (1417) ، وتحفة الأحوذى (677/4) .

⁸⁷ () شرح فتح القدير (277/7) ، والعناية - بهامش شرح فتح القدير - (277/7 ، 278) .
⁸⁸ () صحيح البخاري (128/6) .

⁸⁹ () أوليات الفاروق في الإدارة والقضاء سابق (ص 211) .

وكتب أن لا يجالسه أحد ، قال المحدث فلو جاءنا ونحن مائة لتفرقنا عنه ، ثم كتب أبو موسى إلى عمر أنه قد حسنت توبته ، فأمره عمر - رضى الله عنه - فخلى بينه وبين الناس (.)⁹⁰

2- وسجن عثمان بن عفان - رضى الله تعالى عنه - صابئ بن حارث وكان من لصوص بنى تميم وقتالهم حتى مات فى الحبس .

3- وسجن - على بن أبى طالب - رضى الله عنه فى الكوفة متهمين حتى أقرؤا ، وسجن عبد الله بن الزبير بمكة ، وسجن أيضا فى سجن غارم محمد بن الحنفية إذ امتنع من بيعته (.)⁹¹

4- وفى نحو هذا كله يؤكد قول عمر بن عبد العزيز : المتاع يوجد مع الرجل المتهم فيقول إبتهته ، فاشدده فى السجن وثاقاً ، ولا تحله يأتبه أمر الله (.)⁹²

فهذه الآثار كلها تدل على مشروعية الحبس الاحتياطي ، وأنه قد فعله صحابة النبى - صلى الله عليه وسلم - وخاصة إذا اقترن بالتهمة قرائن تدل عليها .

ومن هذه القرائن ما إذا كان المتهم بسرقة شئ ما كثير التطواف والمجئ والذهاب فى مكان السرقة ، أو كان فى بدنه آثار ضرب ، أو كان معه حين أخذ منقب أو سلاح ، أو كانت التهمة لموظف فى الدولة ، وجرت العادة أن لا يتحصل ذلك المتاع لمثل هذا المتهم ، فإنه فى هذه الحالات تقوى التهمة ويجوز حبسه (.)⁹³

رابعاً : الإجماع :

دل على هذا الإجماع ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من مشروعية الحبس الاحتياطي واعتبروه من السياسة العادلة إذا تأديت التهمة بقريضة قوية ، أو ظهرت أمارات الريبة على المتهم أو عرف بالفجور .

واعتبر جمهور الفقهاء مشروعية الحبس الاحتياطي من ضمن السياسة العادلة التى هى جزء من أجزاء الشريعة ومكمل من مكملاتها ، ودل على هذا بعض الفقهاء (.)⁹⁴

حيث قال : " ولا تقول إن السياسة العادلة مخالفة للشريعة الكاملة ، بل هى جزء من أجزائها وباب من أبوابها وتسميتها السياسة أمر اصطلاحى ، فإذا كانت عدلا فهى من الشرع فقد حبس رسول الله فى تهمة لما ظهرت أمارات الريبة على المتهم " .

⁹⁰ () تبصرة الحكام لابن فرحون (216/2) .

⁹¹ () المرجع والموضع السابقان .

⁹² () المحلى بالآثار لابن حرم (24/12) .

⁹³ () الماوردى - الأحكام السلطانية (ص277 وما بعدها) .

⁹⁴ () ابن قيم الجوزية - أعلام الموقعين (310/4) .

وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية : " ما عملت أحداً من أئمة المسلمين يقول إن المدعى عليه فى جميع هذه الدعاوى والقصاص والحدود والتعازير يحلف ويرسل بلا حبس ولا غيره فليس هذا على إطلاقه مذهباً لأحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم من الأئمة " (.)⁹⁵

وقال أبو الحسن التسولى : " إن مجهول الحال عند الحاكم أو المشهور بالفساد الذى لا يعرف ببر ولا فجور إذا ادعى عليه بتهمة ، فإنه يحبس يكشف حاله عند عامة علماء الإسلام والمنصوص عليه عند أكثر الأئمة " (.)⁹⁶

وقال الإمام الشوكانى : " إن الحبس وقع فى زمن النبوة وفى أيام الصحابة والتابعين فمن بعدهم إلى الآن فى جميع الأعصار والأمصار من دون إنكار وفيه من المصالح ما لا يخفى " (.)⁹⁷

وبذلك اتفقت كلمة أكثر الفقهاء وأصحاب المذاهب الفقهية الأربعة على مشروعية الحبس الاحتياطى مما يعد إجماعاً .

ثانياً : أدلة الرأى الثانى القائلين بعدم جواز الحبس :

استدل أصحاب هذا الرأى بالكتاب والسنة ، والأثر .

أولاً : القرآن الكريم :

قول الله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ) (.)⁹⁸

وقوله - صلى الله عليه وسلم " مطل الغنى ظلم " (.)⁹⁹

وجه الدلالة من الآية والحديث : أن الله عز وجل أمر بالقيام بالقسط ونهى رسوله - صلى الله عليه وسلم - عن المطل والظلم فالسجن مطل وظلم ، ومنع الذى له الحق من تعجيل حقه مطل وظلم ، ثم ترك من صح إفلاسه لا يؤجر لغرمائه مطل وظلم ، فلا يجوز

⁹⁵ () الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية (ص 112) .

⁹⁶ () البهجة فى شرح التحفة (360/2) الطبعة الثانية .

⁹⁷ () نيل الأوطار (254/8) - طبعة سنة 1348هـ .

⁹⁸ () سورة النساء - جزء من الآية (135) .

⁹⁹ () صحيح البخارى - كتاب الاستقراض - باب مطل الغنى ظلم - رقم الحديث (2270)، وصحيح مسلم - كتاب المساقاة - باب تحريم مطل الغنى - رقم الحديث (1564) (1197/3)

شئ من ذلك ، وهو مفترض عليه إنصاف غرامة وإعطاؤهم حقهم ، فإن امتنع من ذلك وهو قادر عليه بالإجارة أجبر على ذلك (.)¹⁰⁰

2- استدلووا بقول الله تعالى : () إِلَّا أَنْ يُسَجَّنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (.)¹⁰¹

وجه الدلالة : أن السجن من العقوبات البليغة ، لأن الله سبحانه قرنه بالعذاب الأليم ، وقد وعد يوسف عليه السلام الإنطلاق من السجن إحساناً إليه، فقال تعالى على لسانه " وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن " وقالوا : إن السجن الطويل عذاب ، وحكى الله تعالى عن فرعون إذ أوعد موسى قائلاً " لأجعلنك من المسجونين " .

ثانياً : من السنة :

استدلوا من السنة أيضاً بحديث المرأة الغامدية التي قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طهرني قال " ويحك " ارجعي فاستغفري الله وتوبى إليه، قالت : لعلك تردني كما رددت ما عز بن مالك ، قالت : إني حبلى من الزنا ، قال : أثيب أنت ؟ قالت : نعم ، قال : فلا نرجمك حتى تضعي ما في بطنك ، قال : فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت ، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : قد وضعت الغامدية قال : إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيراً ليس له من يرضعه ؟ فقال رجل من الأنصار : إلى إرضاعة، فرجمها " (.)¹⁰²

وجه الدلالة كما قال أبو محمد : إن هذا الحديث فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر بحبس المرأة ولم يسجنها بالفعل وإنما سمح للأنصارى بتولى أمرها وحياطتها فقط (.)¹⁰³

وهذا ما يشهد لأصحاب هذا الرأي الذين يرون أنه لا يحبس المتهم ، ولكن يعوق بمكان من الأمكنة ، أو يقيم عليه حافظاً كما حدث في قصة المرأة الغامدية .

أما الأثر فما روى من طريق عبد الرزاق عن ابن جريح عن إبراهيم ابن خثيم، قال : سمعت عبد الله بن أبي ملكية يقول : أخبرني عبد الله بن أبي عامر قال : انطلقت في ركب حتى إذا جننا ذا المروة سُرقت عيبة لي ، ومعنا رجل متهم، فقال أصحابي : يا فلان أردد

¹⁰⁰ () المحلى بالآثار (212/9) ، ود / إبراهيم عطايا فردية العقوبة وأثرها في الفقه الإسلامي ، دار الفكر الجامعي الإسكندرية (ص268) .

¹⁰¹ () سورة يوسف - جزء من الآية (25) .

¹⁰² () صحيح الإمام مسلم (3/1323) ، ونصب الراية للزيلعي (3/332) ، المنتقى الهندي : منتخب كنز العمال مطبوع مع مسند الإمام أحمد (ج2/406) مطبعة الحلبي بمصر .

¹⁰³ () المحلى بالآثار (25/12) .

عليه عيبته ؟ فقال : ما أخذتها ، فرجعت إلى عمر بن الخطاب فأخبرته ، فقال : من أنتم ؟ فعددتهم ، فقال : أظنها صاحبها للذى أتهم ؟ فقلت لقد أردت يا أمير المؤمنين أن تأتي به مصفداً ، فقال عمر : أتأتى به مصفوداً بغير بينة لا أكتب لك فيها ، ولا أسألك عنها ، وغضب ! وما كتب لي فيها ، ولا سألت عنها ، فأنكر عمر -رضى الله عنه - أن يصفد أحد بغير بينة (.)¹⁰⁴

وما روى عن مروان بن الحكم لما استخلف ابنه على بعض المواضع أوصاه ألا يعاقب حين يغضب ، وحضه على أن يسجن حتى يسكن غضبه ثم رأيته رياه وكان يقول إن أول من اتخذ السجن كان حليماً ، ولم يرد مروان طول السجن ، وإنما أراد السجن الخفيف حتى سكن الغضب (.)¹⁰⁵

وناقش ابن حزم الظاهري أدلة الجمهور بجواز الحبس احتياطياً بأن حديث عراك بن مالك مرسل ، ثم لو صح لكان فيه الدليل على المنع من الحبس لاستغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم - من ذلك وقال : إن الأحاديث المذكورة لا حجة في شيء منها ، لأن إبراهيم بن خثيم ضعيف ، وبهز ابن حكيم ليس بالقوى (.)¹⁰⁶

وقال ابن حزم فإذا لم يبق لمن رأى السجن حجة ، فالواجب طلب البرهان على صحة القول الآخر ، فنظرنا في ذلك فوجدنا من قال بسجنه لا يخلوا من أحد وجهين :

إما أن يكون متهماً لم يصح قبله شيء ، أو يكون فتصح قبله شيء من الشر ، فإن كان متهماً بقتل ، أو زنى ، أو سرقة أو شرب ، أو غير ذلك : فلا يحل سجنه ، لأن الله تعالى يقول : (وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً) (.)¹⁰⁷

وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث " (108) وقد كان في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم المتهمون بالكفر - وهم المنافقون ، فما حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم - منهم أحداً (.)¹⁰⁹

ويجاب على المناقشات التي أوردها ابن حزم بما يلي :

¹⁰⁴ () مسند الإمام الشافعي - مطبعة السعادة بمصر 1951م (ص87).

¹⁰⁵ () ابن حزم الظاهري - المحل بالآثار (24/12) وما بعدها (.)

¹⁰⁶ () تبصرة الحكام لابن فرحون (215/2) .

¹⁰⁷ () سورة يونس - جزء من الآية (36) .

¹⁰⁸ () فتح الباري بشرح صحيح البخاري للعسقلاني - المطبعة البهية 1348هـ (ج10/395) .

¹⁰⁹ () المحلى بالآثار (25/12) .

أولاً : بأن استغفار النبي - صلى الله عليه وسلم - للمتهمين لا يعنى عدم مشروعية الحبس الاحتياطي ، وإنما يعنى معنى آخر وهو جبر الآثار المترتبة على حبس المتهم احتياطاً إذا ما ثبت بعد ذلك براءة المتهم ، وإلا ما أمر به الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأيده العقل واقتضته المصلحة العامة وهى مصلحة التحقيق ، ولو نظرنا إلى هذه الواقعة نجد أن المتهمين فيما بعد باتا بجوار المسروق منهم ولم يكن بجوارهم أحد غيرهما ، وقد أصبح القوم فاكتشفوا سرقة البعيرين ، وحينما حبس الرسول صلى الله عليه وسلم أحد المتهمين وأطلق الآخر ، فإذا بالبعيرين المسروقين قد ظهرا بالمكان الذى بات فيه الجميع وذلك حدث بعد إطلاق سراح المتهم الأول ، ومع هذا فإنهما قال للرسول - صلى الله عليه وسلم - " والله يا رسول إن كنا لبراء " ، ولم يعترفا بالسرقة وفى الحقيقة أنهما بريئان حيث لم يعترفا بالسرقة ، ولم تقم البينة عليهما ، بارتكابها ، وكذلك وافقهما الرسول على البراءة وقال لهما : " استغفرا لى " .

لهذا كله فإن طلب الرسول من المتهمين أن يستغفرا له لا يعنى عدم مشروعية التوقيف الاحتياطي كما ادعى ابن حزم الظاهري ، وإنما يعنى تعليم الرسول لنا بأنه ينبغى جبر الآثار المترتبة على الحبس الاحتياطي إذا ما صدر فى مواجهة المتهم الذى ظهرت براءته فيما بعد (.)¹¹⁰

ثانياً : وأما طعن ابن حزم بأن بهز بن حكيم راوى الحديث الدال على الحبس للتهمة ليس بالقوى فيجاب عنه بما قاله الإمام القرطبي أن الإمام البخارى أدخل بهز بن حكيم فى كتاب الوضوء مما يدل على أنه قوى (.)¹¹¹

وهذا فضلاً عن أن أحاديث الحبس للتهمة قد وردت بطرق أخرى يفوى بعضها بعضاً .

ثالثاً : ويجاب عن استدلالهم بالآية الكريمة والحديث الشريف " إن الظن لا يغنى من الحق شيئاً " وقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - " إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث " .

يجاب عنه بأن معنى الظن المحرم فى الآية والحديث هو أن يحكم فى دين الله تعالى بمجرد الظن دون أعمال نظر ولا استدلال بدليل ، وقال اله تعالى : (إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ

¹¹⁰ () د / عبد العزيز رمضان سمك - الحبس للتهمة وضمائنه فى الفقه الإسلامى - طبعة أولى 2008م (ص 166 وما بعدها) .

¹¹¹ () أقضية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للقرطبي (ص 11) .

إِثْمٌ⁽¹¹³⁾)⁽¹¹²⁾ فالآية تفيد أن هناك بعض الظن يفيد الإثم ، وهذا يدل على أن البعض الآخر من الظن لا يفيد إثماً ، وهو ما يتوصل إليه بالنظر والاجتهاد في حبس التهمة .

الرأى الراجع :

بعد عرض الأدلة والأقوال والمناقشات في هذه المسألة يتضح لنا أن الراجع رأى جمهور الفقهاء من مشروعية التوقيف الاحتياطي ، لما ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حبس رجلاً في تهمة ، وذكر الخصاف " أن ناساً من أهل الحجاز اقتتلوا فقتلوا بينهم قتيلاً ، فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حبسهم ولم يكن في عهده - صلى الله عليه وسلم - وأبى بكر سجن وإنما كان يحبس في المسجد أو الدهليز حتى اشترى عمر رضى الله عنه داراً بمكة بأربعة آلاف درهم واتخذة محبساً .

وإنما يعلل عدم اتخاذه - صلى الله عليه وسلم - مكاناً للحبس بقلة المجرمين في عصره - صلى الله عليه وسلم ، وعدم تفشى الإجرام بدليل أن أمير المؤمنين عمر بعد أن اتسعت رقعة البلاد ، وكثر المجرمون أعد مكاناً للحبس ، وكذلك صار من بعده من الخلفاء الراشدين

قال: "فإن امتنع حبسه في كل دين لزمه بدلا عن مال حصل في يده كضمن المبيع أو التزمه بعقد كالمهر والكفالة" لأنه إذا حصل المال في يده ثبت غناه به، وإقدامه على التزامه باختياره دليل يساره إذ هو لا يلتزم إلا ما يقدر على أدائه، والمراد بالمهر معجله دون مؤجله.

قال: "ولا يحبسه فيما سوى ذلك إذا قال إني فقير إلا أن يثبت غريمه أن له مالا فيحبسه" لأنه لم توجد دلالة اليسار فيكون القول قول من عليه الدين، وعلى المدعي إثبات غناه، ويروى أن القول لمن عليه الدين في جميع ذلك لأن الأصل هو العسرة. ويروى أن القول له إلا فيما بدله مال. وفي النفقة القول قول الزوج إنه معسر، وفي إعتاق العبد المشترك القول للمعتق، والمسألتان تؤيدان القولين الأخيرين، والتخريج على ما قال في الكتاب أنه ليس بدين مطلق بل هو صلة حتى تسقط النفقة بالموت على الاتفاق، وكذا عند أبي حنيفة رحمه الله ضمان الإعتاق، ثم فيما كان القول قول المدعي إن له مالا، أو ثبت ذلك بالبينة فيما كان القول قول من عليه يحبسه شهرين أو ثلاثة ثم يسأل عنه فالحبس لظهور ظلمه في الحال، وإنما يحبسه مدة ليظهر ماله لو كان يخفيه فلا بد من أن تمتد المدة ليفيد هذه الفائدة فقدره بما ذكره، ويروى غير ذلك من التقدير بشهر أو أربعة إلى ستة أشهر. والصحيح أن التقدير مفوض إلى رأي القاضي لاختلاف أحوال الأشخاص فيه".

¹¹²) (سورة الحجرات - آية رقم (12) .

¹¹³) (المنتقى للباقي (216/7) .

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا حد لأقل مدة الحبس ، وإنما إذا تبين براءة المتهم للنيابة ، أو للقاضي ، فينبغي أن يخرج من محبسه على الفور ، حتي ولو لم يقضي في الحبس إلا بضع دقائق .

وأما أكثر مدة الحبس فقد اختلف فيها الفقهاء بين من ينظر إلى حال المتهم ثم يحدد المدة على حسب حاله ، وبين من يحدد مدة محددة لا يتجاوزها القاضي بغض النظر عن حال المتهم ، ومنهم من يفوض تقدير المدة إلى القاضي وخلافهم يمكن حصره في ثلاثة أقوال .

القول الأول : ذهب المالكية ، والحنابلة ، وبعض الحنفية إلى أن مدة الحبس الاحتياطي ينظر فيها إلى حال المتهم ، فإن كان المتهم عدلاً فإنه لا يطال حبسه عن يوم أو يومين أو ثلاثة ، وأما إذا كان المتهم مجهول الحال فإنه يحبس حتي ينكشف حاله ، وأما إذا كان المتهم معروفاً بالفسق والفجور والفساد ، فللقاضي أن يطيل حبسه بحسب ما تقضيه ظروف القضية وتحقيق العدالة ، وبعض الفقهاء يقول في هذا النوع من المتهمين أنه يطال حبسه حتى الموت .

وهذا منقول عن عمر بن عبد العزيز ومطرف وابن الماجشون من فقهاء المالكية وغيرهم (114)

قال الماوردي - وهو يتكلم عن التعزير :

" ثم يعدل بمن دون ذلك إلى حبس الذي يحبسونه فيه على حسب ذنبهم وبحسب هفواتهم ، فمنهم من يحبس يوماً ، ومنهم من يحبس أكثر منه إلى غاية مقدرة " (115) .

القول الثاني : ذهب الحنفية في المعتمد عندهم إلى أن أقصى مدة للحبس الاحتياطي هو ما بين أربعة أشهر إلى ستة أشهر ، وذهب بعض الحنفية في غير رواية الحسن إلى أن أقصى مدة للحبس الاحتياطي هي شهر واحد ، وبعض الشافعية يرى أن أقصى مدة للحبس الاحتياطي ما بين شهر إلى ستة أشهر .

قال المير غيناني والكمال بن الهمام :

" ثم إنما يحبس مدة ليظهر ماله فيؤدي ما عليه ، فلا بد أن تمتد تلك المدة ليفيد هذه الفائدة ، فقدره بشهرين أو ثلاثة ، وهو رواية محمد عن أبي حنيفة ، ويروي غير ذلك من التقدير بشهر وهو اختيار الطحاوي ، لأن ما زاد على الشهر في حكم الأجل ، وما دون

¹¹⁴ () معمين الحكام للطرابلسي (ص176) ، وفتاوى ابن تيمية - مجلد 3999/15 .

¹¹⁵ () الأحكام السلطانية للماوردي ، ط دار ابن خلدون (ص243) .

الشهر فى حكم العاجل فصار أدنى الأجل شهراً والأقصى لا غاية له فيقدر بشهر وروى أو أربعة أشهر إلى ستة أشهر ، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة " (.)¹¹⁶

وجاء فى الفتاوى الهندية :

" وبعض مشايخنا - رحمهم الله تعالى - قالوا القاضي ينظر إلى المحبوس إن رأى عليه زى الفقر وهو صاحب عيال له تشكو وعياله إلى القاضي البؤس وضيق النفقة وكان ليناً عند جواب خصمه حبسه شهراً ثم يسأل ، وإن كان وقاحاً عند جواب خصمه وعرف تمرده ورأى عليه أماراة اليسار حبسه أربعة أشهر إلى ستة أشهر ثم يسأل ، وإن كان فيما دون ذلك حبسه شهرين إلى ثلاثة أشهر ثم يسأل وبه كان يفتي الشيخ الإمام ظهير الدين الميرغيناني وهو يحكي عن عمه شمس الأئمة الأوزجندی " (.)¹¹⁷

" وقال أبو عبد الله الزبيرى من أصحاب الشافعى تقدر غايته - أي الحبس - بشهر للاستبراء والكشف ، وبسته أشهر للتأديب والتقويم ، ثم يعدل بمن ذلك إلى النفي والإبعاد إذا تعدت ذنوبه إلى اجتذاب غيره إليها واستضراره بها " (.)¹¹⁸

وإنما اشترط الشافعية أن لا يصل الحبس إلى سنة ، وجعلوا أقصى مدة له ستة أشهر لأنهم يقيسونه على التغريب فى حد الزنا ، والتغريب لا يزيد على عام ، فوجب أن يقل الحبس عن عام حتى لا يعاقب بحد فى غير حد .

القول الثالث : ذهب الحنفية فى الأصح عندهم ، والشافعية فى الظاهر عندهم إلى أن مدة الحبس الاحتياطي مفوض إلى رأي القاضي ، فيترك لولى الأمر أو القاضي تقدير حدة الأعلى .

قال الميرغيناني :

" والصحة أن التقدير مفوض إلى رأي القاضي لاختلاف أحوال الأشخاص فيه " (.)¹¹⁹

وزاد العيني فى شرحه للهداية :

لأن بعض الناس يضجر بالحبس فى مدة قليلة ما لا يضجر آخر فى مدة كثيرة (.)¹²⁰

¹¹⁶ () الهداية مع شرح فتح القدير (282/7) ، والبنية فى شرح الهداية (31/9) .

¹¹⁷ () الفتاوى الهندية (415/3) ، والمحيط البرهاني (238/8) .

¹¹⁸ () الأحكام السلطانية للماوردي (ص243) .

¹¹⁹ () الهداية مع شرح فتح القدير (282/7) ، والفتاوى الهندية (415/3) .

¹²⁰ () البنية فى شرح الهداية (31/9) .

وقال الماوردي :

" فالظاهر من مذهب الشافعي - أن يقدر - الحبس الاحتياطي - بما دون الحول ولوبيوم واحد لئلا يصير مساوياً لتعزير الحول في الزنا " (.)¹²¹

الرأي الراجح :

وأري أن الرأي الراجح هو الرأي الثالث بتفويض تحديد مدة الحبس الاحتياطي إلى رأي القاضي ، لأنه ثبت أن النبي - ﷺ - تغير قضاؤه في تحديد المدة في الحبس الاحتياطي من متهم لآخر .

من ذلك ما رواه عبد الرزاق عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي - ﷺ - حبس رجلاً في تهمة ساعة من نهار ثم خلى عنه (.)¹²²

وطول المدة في حديث أبي هريرة أن النبي - ﷺ - حبس رجلاً في تهمة يوماً وليلة استظهاراً واحتياطاً (.)¹²³

ولأن القضايا تختلف من حيث أهميتها وبشاعتها وحال المتهم مما يقتضي تفويض الأمر إلى سلطة القاضي .

القضايا التي يجوز فيها الحبس :

اختلفت وجهة نظر الفقهاء بين مضيق وموسع في الجرائم والقضايا التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي .

فذهب الحنفية إلى أن الجرائم التي يجوز فيها الحبس للاحتياط من جرائم الحدود والقصاص والدية ، ولا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التعزيرية ودعاوى المال كالديون ، بل يتخذ في مواجهة المتهم إجراء بديل عن الحبس للاحتياط كإجراء الكفالة .

وعلة هذا القول عندهم هو أن الحبس يصلح تعزيراً في نفسه ، والحبس أقصى عقوبة في الأموال ، فإنه لو ثبت المال بتعديل الشهود كان الحبس تمام موجب ما شهدوا به ، ولو حبس قبله لزم إعطاء حكم السبب له قبل ثبوته بخلاف الحد والقصاص (.)¹²⁴

¹²¹() الأحكام السلطانية (ص243) .

¹²²() كنز العمال لعلاء الدين المنقي - طبعة البلاغة بحلب (ج5/850) ، والسنن الكبرى (6/53)

¹²³() المستدرك على الصحيحين (ج4/102) .

¹²⁴() در الحكام شرح غرر الأحكام لمنلا خسرو (ج2/298) ، وتبيين الحقائق (3/165) .

وقال العلامة الجصاص :

" وإذا كان الحق ديناً أو قرضاً أو نحو ذلك فإن المدعي عليه لا يحبس بشهادة الواحد وإن كان عدلاً ، لأن هذه الحقوق لا توجب التهمة حتي يحبس المتهم " (.)¹²⁵

وقد ذكر الإمام السر خسي – من الحنفية – أن المتهم في جناية القتل يحبس للتهمة ، والعمد في ذلك والخطأ وشبه العمد سواء ، وكان ينبغي في القياس أن لا يحبس في الخطأ وشبه العمد ، لأن الواجب فيهما المال ، وفي الديون التي هي غير مؤجلة لا يحبس ما لم تتم الحجة بظهور عدالة الشهود، ففيما يكون مؤجلاً إلى العاقلة أولى ولكنه ترك القياس ، لأن المتهم بالدم يحبس لعظم أمر القتل حتي يتبين موجه كظهور عذر القاتل من عدمه" (.)¹²⁶

الرأي الثاني : ذهب جمهور الفقهاء المالكية ، والشافعية والحنابلة والشيعة الأمامية إلى عدم التفرقة بين الجرائم فيما يتعلق بإصدار أمر الحبس الاحتياطي فالقاضي أن يصدر الأمر بالحبس بضوابطه السابقة سواء كان الاتهام متعلقاً بقضايا الحدود أو القصاص أو التعزير أو بدعوى المال .

قال الإمام العز بن عبد السلام :

" يحبس المدعي عليه إذا شهد عليه مستوران بالدين أو بشئ يتعلق ببذنه كالحد والقصاص والتعزير إلى أن تزكي البيئة " (.)¹²⁷

الرأي الرابع :

وأري أن الرأي الرابع هو رأي جمهور الفقهاء بعدم التفرقة بين الجرائم في إصدار أمر الحبس الاحتياطي ، وذلك لأن الحنفية فرقوا بين الجرائم على اعتبار أن الحبس عقوبة ، وهذا ليس بمسلم من كل الوجوه ، كما أن النصوص الواردة في مشروعية الحبس للتهمة لم تخص جرائم بعينها لجواز الحبس للتهمة فيها دون غيرها ، مما يبين لنا رجحان رأي الجمهور .

¹²⁵ () أدب القاضي للخصاف شرح الجصاص (ص114) .

¹²⁶ () المبسوط (106/26) واستاذنا عبد العزيز رمضان سمك – الحبس للتهمة وضماناته في الفقه الإسلامي (ص189) .

¹²⁷ () قواعد الأحكام في مصالح الأنعام (ج2/183) وانظر كشف القناع للبهوتي (6/352) وتبصرة الحكام (2/330) ، والبحر الزخار (6/170) ، وشرائع الإسلام (4/75) .

قال: "فإن لم يظهر له مال خلي سبيله" يعني بعد مضي المدة لأنه استحق النظرة إلى الميسرة فيكون حبسه بعد ذلك ظلما ; ولو قامت البينة على إفلاسه قبل المدة تقبل في رواية، ولا تقبل في رواية، وعلى الثانية عامة المشايخ رحمهم الله. قال في الكتاب خلي سبيله ولا يحول بينه وبين غرمائه، وهذا كلام في الملازمة وسنذكره في كتاب الحجر إن شاء الله تعالى.

وفي الجامع الصغير: رجل أقر عند القاضي بدين فإنه يحبسه ثم يسأل عنه، فإن كان موسرا أبد حبسه، وإن كان معسرا خلى سبيله، ومراده إذا أقر عند غير القاضي أو عنده مرة وظهرت مماطلته والحبس أولا ومدته قد بيناه فلا نعيده.

قال: "ويحبس الرجل في نفقة زوجته" لأنه ظالم بالامتناع "ولا يحبس والد في دين ولده" لأنه نوع عقوبة فلا يستحقه الولد على الوالد كالحدود والقصاص "إلا إذا امتنع من الإنفاق عليه" لأن فيه إحياء لولده، ولأنه لا يتدارك لسقوطها بمضي الزمان، والله أعلم بالصواب.

باب كتاب القاضي إلى القاضي

مدخل

...

باب كتاب القاضي إلى القاضي

قال: "ويقبل كتاب القاضي إلى القاضي في الحقوق إذا شهد به عنده" للحاجة على ما نبين "فإن شهدوا على خصم حاضر حكم بالشهادة" لوجود الحجة "وكتب بحكمه" وهو المدعو سجلا "وإن شهدوا به بغير حضرة الخصم لم يحكم" لأن القضاء على الغائب لا يجوز "وكتب بالشهادة" ليحكم المكتوب إليه بها وهذا هو الكتاب الحكمي، وهو نقل الشهادة في الحقيقة، ويختص بشرائط نذكرها إن شاء الله تعالى، وجوازه لمساس الحاجة لأن المدعي قد يتعذر عليه الجمع بين شهوده وخصمه فأشبه الشهادة على الشهادة. وقوله في الحقوق يندرج تحته الدين والنكاح والنسب والمغصوب والأمانة المجودة والمضاربة المجودة لأن كل ذلك بمنزلة الدين، وهو يعرف بالوصف لا يحتاج فيه إلى الإشارة، ويقبل في العقار أيضا لأن التعريف فيه بالتحديد. ولا يقبل في الأعيان المنقولة للحاجة إلى الإشارة. وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يقبل في العبد دون الأمة لغلبة الإباق فيه دونها. وعنه أنه يقبل فيهما بشرائط تعرف في موضعها. وعن محمد رحمه الله أنه يقبل في جميع ما ينقل ويحول وعليه المتأخرون رحمهم الله".

يوجد عند الأحناف نوعان من الكتب أولها أن يكون الكتاب بحكم القاضي لينفذه القاضي المكتوب إليه وذلك في حالة شهادة الشهود على الحاضر عن المدعي الغائب سواء كان وكيلا له أو مسخرا عنه وهو الشخص الذي ينصبه القضاء وكيلا عن الغائب لسمع الدعوى عليه، وبناء على هذه الشهادة يحكم القاضي في الدعوى ويكتب بالحكم إلى قاضي البلد الذي فيها الموكل ليقتضي منه الحق .

ويسمى كتاب القاضي في هذه الحالة "السجل" لأنه يتضمن الحكم ، كما يجوز كتابة السجل أيضا بالنسبة للخصم الحاضر ، وصورة ذلك أن يحكم القاضي على المدعي الخاص ويكتب بالحكم إلى القاضي المكتوب إليه لينفذه الأخير في بلده نظرا لاتفاق الخصمين على ذلك ،ومثاله أن يحكم القاضي الكاتب على الخصم في دين ثم يصطلح الطرفان على أخذ المبلغ

في بلد القاضي المكتوب إليه ويخشى من الإنكار فيكون كتاب القاضي لتنفيذ الحكم بمعرفة
القاضي المكتوب إليه .))¹²⁸

وأما تكييف القرار الصادر من القاضي بأنه حكم من عدمه فيرى الأحناف أن قول القاضي
ثبت عندي حكم في الصحيح وكذلك قوله صح أو ثبت عندي ، وقيل لا بد أن يقول حكمت أو
قضيت أو أنفذت .))¹²⁹

وثاني أنواع الكتب عند الأحناف هو الكتاب المتضمن ثبوت الشهادة بالحق-دون حضور
الخصم- وذلك لكي يحكم بها القاضي المكتوب إليه ، لأن القاضي الكاتب لا يحكم بهذه الشهادة
على الخصم الغائب إلا أن كتابه يشبه الشهادة على الشهادة فيجوز العمل بها .

ويسمى كتاب القاضي في هذه الحالة " الكتاب الحكمي " لأنه يكتب ليحكم به القاضي
المكتوب إليه (¹³⁰) ، فالحاصل أن سجل القاضي إلى القاضي لا يكون إلا بعد الحكم ، وكتاب
القاضي إلى القاضي الذي هو نقل الشهادة لا يكون إلا قبل الحكم .))¹³¹

والفرق بين السجل والكتاب الحكمي أن الأول يلزم العمل به من جانب القاضي المكتوب إليه
حتى وإن كان يخالف رأيه ، لأن الحكم صدر في محل مجتهد فيه ، أما الكتاب الحكمي فلا
ينفذه القاضي المكتوب إليه إلا إذا وافق رأيه أي مذهبه ، لأنه نقل للشهادة فقط .))¹³²

وأما الإجراء المطلوب عند المالكية فهو إما تنفيذ الحكم أو البناء على ما في الكتاب وذلك
يستفاد من كلامهم بشأن ما يقوم به القاضي المكتوب إليه ، وعلى ذلك فالنوع الأول من كتاب
القاضي هو المتضمن للحكم ويكون المطلوب من القاضي المكتوب إليه تنفيذه ، والنوع الثاني
المتضمن لثبوت شهادة الشهود أي ثبوت الحق بالبينه ، فالقاضي المكتوب إليه يبنى على ما
حصل عند القاضي وما كتب به أي يكمل ما بدأه الأول من إجراءات فإن كتب إليهم بثبوت
شهادتهم فقط لم يأمر بإعادتها وينظر في تعديلهم (عدالتهم) ، وإن كتب إليهم بتعديلهم يعذر
المشهود عليه ، وإن كتب بأنه أعذر إليه وعجز عن الدفع أي (دفع الدعوى) أمضى الحكم إليه
.))¹³³

¹²⁸ - حاشية ابن عابدين (433/5)

¹²⁹ - جامع الفصولين ، (ج1/115)

¹³⁰ - حاشية الشبلي - بهامش تبیین الحقائق- (4 / 184)

¹³¹ - درر الحکام في شرح غرر الأحكام لمنلا خسرو (ج2 / 413)

¹³² - شرح فتح القدير ، (287/7) ، وشرح العناية على الهداية للبايرتي (286/7)

¹³³ - شرح الخرشي على مختصر خليل، (ج4/171) ، وحاشية الدسوقي (4/189)

وعند الشافعية يتحدد الإجراء المطلوب من القاضي المكتوب إليه حسب نوع كتاب القاضي، والكتاب عندهم ثلاثة أنواع (أو درجات) ويطلق عليها كلها (الكتاب الحكمي).

والنوع الأول: إذا تضمن الكتاب نقل شهادة فقط فالقاضي الكاتب يشرح ما جرى عنده فقط بغير ثبوت شيء، وبدون الحكم بقبول البينة .

ويكون الإجراء المطلوب في هذه الحالة ثبوت الحق المدعى به والحكم به وتنفيذ الحكم.

والنوع الثاني: أن يتضمن الكتاب ثبوت الحق عند القاضي الكاتب وذلك ليحكم القاضي المكتوب إليه ويستوفى أى ينفذ حكمه .

والنوع الثالث: هو الكتاب الذى يشمل ثبوت الحق والحكم به وذلك لكى ينفذه المكتوب إليه، وبعض الشافعية أطلق " المحضر " على ما يكتب فيه القاضي ما جرى عنده وما ثبت به الحق "والسجل" فيكتب فيه ما كتب في المحضر ويشهد القاضي على إنفاذه ثم يسجله للمدعى .¹³⁴

والكتاب عند الحنابلة ثلاثة أنواع فقد يكون الكتاب بنقل الشهادة فقط كأن يسمع القاضي الكاتب البينة ويجعل تعديلها إلى المحكوم عليه والذى يصدر الحكم وينفذه، أو يكون الكتاب بثبوت الحق عند القاضي الكاتب ليحكم به المكتوب إليه، أو يتضمن الكتاب الحكم الذى أصدره الكاتب لينفذه المكتوب إليه .

ويلاحظ أنه على الصحيح من المذهب عندهم أن الكتاب المحتوى الحكم بموجب البينة يسمى "سجلاً" وغيره أى غير المتضمن الحكم بالبينة مثل أن يكون الحكم بالإقرار أو بالنكول يطلق عليه " المحضر "

فالسجل والمحضر كل منهما وصف للكتاب المتضمن الحكم بطريق معين من طرق الإثبات، وقيل أن المحضر هو شرح ثبوت الحق عند القاضي الكاتب لا الحكم بثبوته، وصفته اشتماله على عبارة "في مجلس حكمه " إذا ما ثبت الحق بغير الإقرار عن المدعى عليه، لأنه يجوز منه الإقرار في مجلس الحكم وغيره، وأما السجل فلأنفاذ ما ثبت عند القاضي الكاتب والحكم به وصفته تضمينه عبارة "في محضر من خصمين"¹³⁵

¹³⁴ - أدب القضاء لابن أبى الدم (ص 464-466) ، وحاشية قليوبى وعميرة ، ط دار احياء التراث العربى (ج 4/309) ، والمهذب (ج 2/306)

¹³⁵ - الإنصاف للمرداوى ، الطبعة الأولى 1377هـ (ج 11/322) ، وكشاف القناع (4/216) والكافي لموفق الدين ابن قدامة ط المكتب الإسلامى 1979م (ج 4/467)

قال: "ولا يقبل الكتاب إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين" لأن الكتاب يشبه الكتاب فلا يثبت إلا بحجة تامة وهذا لأنه ملزم فلا بد من الحجة، بخلاف كتاب الاستئمان من أهل الحرب لأنه ليس بملزم، وبخلاف رسول القاضي إلى المذكي ورسوله إلى القاضي لأن الإلزام بالشهادة لا بالتزكية.

لقد اشترط الفقهاء أن تقوم البيئة على كتاب القاضي للنائب، فقالوا: لا بد من الإشهاد على كتاب القاضي وإنابته للمكتوب إليه ، لأن الكتاب يشبه الكتاب ، وفيه مجال للتزوير ، فلا يثبت إلا بحجة تامة ، وهذا لأنه ملزم فلا بد من الحجة ، وذهب إلى ذلك الشافعي وأبو حنيفة وأكثر الفقهاء.))¹³⁶

ويشترط إشهاد رجلين عدلين فلا يقبل رجل وامرأتان ، وقيل يقبل إن كان الحق يتعلق بمال ، وقال الأحناف : يقبل رجل وامرأتان ، لأنه حق لا يسقط بالشبهات ، وهو مما يطلع عليه فيقبل فيه شهادة النساء.))¹³⁷

وذهب جمع من الحنابلة حتى ابن تيمية عزاه إلى جمهور العلماء إلى أنه يقبل كتاب القاضي إذا عرف المكتوب إليه أنه خط القاضي الكاتب وختمه ، جاز قبوله بدون شهادة ، لأن القبول هنا كتفويض الوصية ، ذلك أنه إذا وجدت وصية الرجل مكتوبة عند رأسه من غير أن يكون أشهد أو أعلم بها أحدا عند موته ، وعرف خطه وكان فإنه ينفذ ما فيها .¹³⁸

فمفهوم هذا الكلام أنه لا يقتصر على الشهادة في إثبات كتاب القاضي إلى القاضي بل يثبت بأي طريق كان.

قال ابن تيمية " من عرف خطه بإقرار أو إنشاء ، أو عقد أو شهادة عمل به ، كميته فإن حضر وأنكر مضمونه ، فكاعترافه بالصوت ، وإنكار مضمونه ، وذكر قولاً في المذهب ، أنه يحكم بخط شاهد ميت ، فقال : الخط كاللفظ إذا عرف أنه خطه ، وقال : إنه مذهب جمهور الفقهاء وهو يعرف أن هذا خطه كما يعرف أن هذا صوته.))¹³⁹

قال: "ويجب أن يقرأ الكتاب عليهم ليعرفوا ما فيه أو يعلمهم به" لأنه لا شهادة بدون العلم "ثم يختمه بحضرتهم ويسلمه إليهم" كي لا يتوهم التغيير، وهذا عند أبي حنيفة ومحمد

¹³⁶ - الفتاوى الهندية (3/ 381) ، وتبيين الحقائق (4/ 185) ، ونهاية المحتاج (8/ 273) ، وكشاف القناع (6/ 363)

¹³⁷ - حاشية ابن عابدين (5/ 433)

¹³⁸ - حاشية الروض المربع (3/ 404) ،

¹³⁹ - المبدع (10/ 190) ، والإنصاف (11/ 327) ، والاختيارات الفقهية (ص597)

رحمهما الله، لأن علم ما في الكتاب والختم بحضرتهم شرط، وكذا حفظ ما في الكتاب عندهما ولهذا يدفع إليهم كتاب آخر غير مختوم ليكون معهم معاونة على حفظهم. وقال أبو يوسف رحمه الله آخرًا: شيء من ذلك ليس بشرط، والشرط أن يشهدهم أن هذا كتابه وختمه وعن أبي يوسف أن الختم ليس بشرط أيضا فسهل في ذلك لما ابتلي بالقضاء وليس الخبر كالمعاينة. واختار شمس الأئمة السرخسي رحمه الله قول أبي يوسف رحمه الله.

قال: "وإذا وصل إلى القاضي لم يقبله إلا بحضرة الخصم" لأنه بمنزلة أداء الشهادة فلا بد من حضوره، بخلاف سماع القاضي الكاتب لأنه للنقل لا للحكم.

قال: "فإذا سلمه الشهود إليه نظر إلى ختمه، فإذا شهدوا أنه كتاب فلان القاضي سلمه إلينا في مجلس حكمه وقرأه علينا وختمه فتحه القاضي وقرأه على الخصم وألزمه ما فيه" وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله. وقال أبو يوسف رحمه الله: إذا شهدوا أنه كتابه وختمه قبله على ما مر، ولم يشترط في الكتاب ظهور العدالة للفتح، والصحيح أنه يفض الكتاب بعد ثبوت العدالة، كذا ذكره الخصاص رحمه الله لأنه ربما يحتاج إلى زيادة الشهود وإنما يمكنهم أداء الشهادة بعد قيام الختم، وإنما يقبله المكتوب إليه إذا كان الكاتب على القضاء، حتى لو مات أو عزل أو لم يبق أهلا للقضاء قبل وصول الكتاب لا يقبله لأنه التحق بواحد من الرعايا، ولهذا لا يقبل إخباره قاضيا آخر في غير عمله أو في غير عملهما، وكذا لو مات المكتوب إليه إلا إذا كتب إلى فلان بن فلان قاضي بلدة كذا وإلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين لأن غيره صار تبعا له وهو معرف، بخلاف ما إذا كتب ابتداء إلى كل من يصل إليه على ما عليه مشايخنا رحمهم الله لأنه غير معرف، ولو كان مات الخصم ينفذ الكتاب على وارثه لقيامه مقامه. "ولا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في الحدود والقصاص" لأن فيه شبهة البدلية فصار كالشهادة على الشهادة، ولأن مبناهما على الإسقاط وفي قبوله سعي في إثباتهما.

فصل: ويجوز قضاء المرأة في كل شيء إلا في الحدود والقصاص

...

فصل آخر: "ويجوز قضاء المرأة في كل شيء إلا في الحدود والقصاص"

اعتبارا بشهادتها. وقد مر الوجه. "وليس للقاضي أن يستخلف على القضاء إلا أن يفوض إليه ذلك" لأنه قلد القضاء دون التقليد به فصار كتوكيل الوكيل، بخلاف المأمور بإقامة الجمعة حيث يستخلف لأنه على شرف الفوات لتوقته فكان الأمر به إذنا بالاستخلاف

دلالة ولا كذلك القضاء. ولو قضى الثاني بمحضر من الأول أو قضى الثاني فأجاز الأول جاز كما في الوكالة، وهذا لأنه حضره رأي الأول وهو الشرط، وإذا فوض إليه يملكه فيصير الثاني نائباً عن الأصل حتى لا يملك الأول عزله إلا إذا فوض إليه العزل هو الصحيح.

قال: "وإذا رفع إلى القاضي حكم حاكم أمضاه إلا أن يخالف الكتاب أو السنة أو الإجماع بأن يكون قولاً لا دليل عليه. وفي الجامع الصغير: وما اختلف فيه الفقهاء فقضى به القاضي ثم جاء قاض آخر يرى غير ذلك أمضاه" والأصل أن القضاء متى لاقى فصلاً مجتهداً فيه ينفذه ولا يردده غيره، لأن اجتهاد الثاني كاجتهاد الأول، وقد يرجح الأول باتصال القضاء به فلا ينقض بما هو دونه. "ولو قضى في المجتهد فيه مخالفاً لرأيه ناسياً لمذهبه نفذ عند أبي حنيفة رحمه الله، وإن كان عامداً ففيه روايتان" ووجه النفاذ أنه ليس بخطأً بيقين، وعندهما لا ينفذ في الوجهين لأنه قضى بما هو خطأ عنده وعليه الفتوى، ثم المجتهد فيه أن لا يكون مخالفاً لما ذكرنا. والمراد بالسنة المشهورة منها وفيما اجتمع عليه الجمهور لا يعتبر مخالفة البعض وذلك خلاف وليس باختلاف والمعتبر الاختلاف في الصدر الأول.

قال: "وكل شيء قضى به القاضي في الظاهر بتحريم فهو في الباطن كذلك عند أبي حنيفة رحمه الله" وكذا إذا قضى بإحلال، وهذا إذا كانت الدعوى بسبب معين وهي مسألة قضاء القاضي في العقود والفسوخ بشهادة الزور وقد مرت في النكاح.

قال: "ولا يقضي القاضي على غائب إلا أن يحضر من يقوم مقامه" وقال الشافعي رحمه الله: يجوز لوجود الحجة وهي البينة فظهر الحق. ولنا أن العمل بالشهادة لقطع المنازعة، ولا منازعة دون الإنكار ولم يوجد، ولأنه يحتمل الإقرار والإنكار من الخصم فيشتبه وجه القضاء لأن أحكامهما مختلفة، ولو أنكر ثم غاب فكذلك لأن الشرط قيام الإنكار وقت القضاء، وفيه خلاف أبي يوسف رحمه الله، ومن يقوم مقامه قد يكون نائباً بإنابته كالوكيل أو بإنابة الشرع كالوصي من جهة القاضي، وقد يكون حكماً بأن كان ما يدعي على الغائب سبباً لما يدعيه على الحاضر وهذا في غير صورة في الكتب، أما إذا كان شرطاً لحقه فلا معتبر به في جعله خصماً عن الغائب وقد عرف تمامه في الجامع. قال: "ويقرض القاضي أموال اليتامى ويكتب ذكر الحق" لأن في الإقراض مصلحتهم لبقاء الأموال محفوظة مضمونة، والقاضي يقدر على الاستخراج والكتابة ليحفظه

"وإن أقرض الوصي ضمن" لأنه لا يقدر على الاستخراج، والأب بمنزلة الوصي في أصح الروايتين لعجزه عن الاستخراج.

باب التحكيم

مدخل

باب التحكيم

"وإذا حكم رجلان رجلا فحكم بينهما ورضيا بحكمه جاز" لأن لهما ولاية على أنفسهما فصح تحكيمهما وينفذ حكمه عليهما،"

التحكيم في اللغة مصدر حكمه في الأمر والشئ ،ويقال حكم فلانا عما يريد ،وفلانا في الشئ والأمر جعله حكما ، وفوض الحكم إليه .⁽¹⁴⁰⁾

والتحكيم لغة :جعل الحكم فيما لك لغيرك ،يقال :حكمته في مالى إذا جعلت الحكم إليه فيه فاحتكم على فى ذلك ،وحكمت (بالتشديد)الرجل فوضت الحكم إليه .⁽¹⁴¹⁾

وحكمه فى الأمر تحكيما أمره أن يحكم فاحتكم ،ويقال حكم فلانا عما يريد وفلانا فى الشئ جعله حكما⁽¹⁴²⁾، والمحكمة هيئة تتولى الفصل فى القضاء ،أو مكان انعقاد هيئة التحكيم .⁽¹⁴³⁾

والمحكم -بتشديد الكاف مع الفتح-هو الذى يفوض له الحكم فى الشئ ،وقيل هو الرجل المجرى ،وحكم الرجل بضم الكاف صار حكيماً ،والمحكم هو الذى لا اختلاف فيه ولا اضطراب ،⁽¹⁴⁴⁾ومنه قول الحق جل شأنه "آلم كتاب أحكمت آياته"⁽¹⁴⁵⁾

والحكيم هو الذى يرد نفسه عن هواها ومن هنا جاءت تسمية المحكم ، ويقال احتكم فلان فى مال فلان أى جاز حكمه فيه ،وحكمنا فلانا بيننا أمرناه أن يحكم .⁽¹⁴⁶⁾

¹⁴⁰ -المعجم الوسيط (1/197)

¹⁴¹ -المصباح المنير (ص100) ط بولاق ، والصاحح للجوهري (2/277)

¹⁴² - القاموس المحيط (4/98) ط 1281هـ

¹⁴³ - المعجم الوسيط (1/190)

¹⁴⁴ -مختار الصحاح (ص148)

¹⁴⁵ -سورة هود -جزء من الآية 1

¹⁴⁶ -إسماعيل بن عباد - المحيط فى اللغة - تحقيق د/محمد حسن آل ياسين - ط بيروت لبنان عالم الكتب 1994م (ج2/387).

ويقول ابن منظور لسان العرب :الحكم مصدر قولك حكم بينهم يحكم أى قضى ،وحكم له وحكم عليه والحكم والحكيم هما بمعنى الحاكم وهو القاضي ،والحكيم تطلق على من يحسن دقائق الصناعات ويتقنها ، والحكم منفذ الحكم والجمع حكام وحكموه بينهم :أمره أن يحكم ويقال حكمنا فلانا فيما بيننا أى أجزنا حكمه بيننا .¹⁴⁷

والحكم محركة اسم من أسناء الله تعالى ،وفى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم- أنه قال لأبى شريح عندما سمع القوم يكنونه بأبى الحكم قال له "إن الله هو الحكم فلم تكنى بأبى الحكم"¹⁴⁸

ويطلق الحكم على من يختار للفصل بين المتنازعين¹⁴⁹،قال تعالى "وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها"¹⁵⁰

ويتبين من العرض السابق أن التحكيم فى المعنى اللغوى يفيد إطلاق اليد فى الشئ ،أو تفويض الأمر للغير يقال حكم زيد عمرا فى ماله إذا أطلق يده فيه ،وحكم الخصمان فلانا إذا جعلنا له النظر فى منازعاتهما

وقى الاصطلاح عرفه الحنفية بأنه "تولية الخصمين حاكما يحكم بينهما" أى الفريقين المتخاصمين .¹⁵¹

وفى مجلة الأحكام العدلية "التحكيم عبارة عن اتخاذ الخصمين حاكما برضاهما لفصل خصومتهم ودعواهما"¹⁵²

وهذا التعريف هو خلاصة أقوال الفقهاء فى التحكيم وما يجوز فيه وشروطه ،إذ جاء تعريفهم للتحكيم شاملا لكل ذلك ،قال الميرغينانى "وإذا حكما رجلان رجلا ،فحكم بينهما ورضيا بحكمه جاز ،لأن لهما ولاية على أنفسهما فصح تحكيمهما وينفذ حكمه عليهما"¹⁵³

¹⁴⁷ - أبى الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقى المصرى - لسان العرب - ط دار صادر بيروت لبنان 1997م (ج12/140)

¹⁴⁸ - رواه البخارى فى الأدب المفرد (ص240)

¹⁴⁹ -المعجم الوسيط (ج1/290)

¹⁵⁰ -سورة النساء -جزء من الآية 25

¹⁵¹ -ابن عابدين - رد المحتار - (381/4)

¹⁵² -مجلة الأحكام العدلية (1/197)

¹⁵³ - الهداية شرح بداية المبتدى للميرغينانى (ج3/108)، وشرح فتح القدير للكمال بن الهمام (ج5/49)، وشرح الكنز لمحمد محمود العينى (ج2/92)

" وهذا إذا كان المحكم بصفة الحاكم لأنه بمنزلة القاضي فيما بينهما فيشترط أهلية القضاء، ولا يجوز تحكيم الكافر والعبد والذمي والمحدود في القذف والفسق والصبي لانعدام أهلية القضاء اعتبارا بأهلية الشهادة والفسق إذا حكم يجب أن يجوز عندنا كما مر في المولى"

فالتحكيم هو أحد الوسائل المشروعة لفض النزاع والخلاف بين الناس، فهو كالقضاء وسيلة لفض النزاع بين الناس وبين صاحب الحق، لذلك اشترط الفقهاء أن يكون المحكم صالحا للقضاء.¹⁵⁴)

لأنه بمنزلة القاضي بالنسبة للخصمين .

وقد ذهب جمهور الفقهاء الحنفية، والمالكية، والشافعية⁽¹⁵⁵⁾، والحنابلة⁽¹⁵⁶⁾ إلى جواز التحكيم ، وأن التحكيم مشروع .

واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة ، والإجماع ، والمعقول :

1-أما الكتاب فقوله تعالى "وإن خفتن شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما"⁽¹⁵⁷⁾

وجه الدلالة :

¹⁵⁴ -الخصاف - شرح أدب القاضي - مطبعة الإرشاد ط 1937هـ (483/4) ،الشريبي - مغنى

المحتاج (378/4)،،البهوتي - شرح منتهى الإرادات (467/3)

¹⁵⁵ - وتحقيق مذهب الشافعية فى هذه المسألة أن لهم ثلاثة آراء :

الرأى الأول: وهو رأى جمهور الشافعية أنه يجوز التحكيم بشرط أن تتوفر فى المحكم أهلية القضاء.

الرأى الثانى : أنه لايجوز التحكيم مطلقا ، لأن فيه افتئات - أى تعدى على رئيس الدولة ونوابه - فلا يجوز لهذا المعنى .

وقد أوجب على هذا بأن المحكم ليس له سلطة الحبس ، ولااستيفاء عقوبة لإنسان ثبت عنده مايستوجبها ، وبالتالي فلا يوجد هذا التعدى الذى ذكرتموه .

الرأى الثالث: يرى جواز التحكيم بشرط عدم وجود قاض بالبلد ، فتكون حالة ضرورة وهى تجبر ذلك ، أما إذا وجد قاضى بالبلد فلا يجوز التحكيم .

والرأى الراجح هو الرأى الأول القائل بجواز التحكيم مطلقا.

قال صاحب مغنى المحتاج " ولايشترط عدم القاضى ، لأنه وقع لجمع من كبار الصحابة ولم ينكره أحد ، وقال الماوردى : وإذا حكم خصمان رجلا من الرعية ليقضى بينهما فيما تنازعا فى بلد فيه قاضى أو ليس فيه قاض جاز .

مغنى المحتاج (378/4 ، 379) ، والحاوى الكبير للماوردى (325/16)

¹⁵⁶ - المحيط البرهاني فى الفقه النعماني للإمام برهان الدين بن مازة البخارى -الطبعة الأولى

1424هـ (117/8)، ومواهب الجليل (112/6)، ونهاية المحتاج (242/8)، والمغنى (483 /11)

¹⁵⁷ - سورة النساء جزء من الآية 35

دللت هذه الآية على أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين أو الحكام على أن يبعثوا عند الشقاق بين الزوجين رجلا صالحا من أهل الرجل ، ورجلا مثله من أهل المرأة ، فينظران أيهما المسيء

فإن كان الرجل هو المسيء حجبوا عنه امرأته وقصروه على النفقة ، وإن كانت المرأة هي المسيئة وعجز الرجل عن أن يعالج نشوزها بالوسائل الثلاثة المذكورة في الآية التي تسبق هذه الآية وهي الوعظ والهجر والضرب بحسب ترتيبها ، وجب على المؤمنين المتكافلين في مصالحهم ومنافعهم أن يبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ، لأن أقاربهما أعرف بحالهما من الأجانب ، وأشد طلبا للصالح ويجب على هذين الحكامين أن يوجها إرادتهما إلى إصلاح ذات البين ، ومتى صدقت الإرادة كان التوفيق الإلهي رفيقهما إن شاء الله تعالى .¹⁵⁸

وهذا يدل على مشروعية التحكيم .

فقد قال الإمام القرطبي "إن هذه الآية دليل إثبات التحكيم" ¹⁵⁹

2-وأما السنة فقد دل على مشروعية التحكيم فيها الأحاديث الآتية :

1-مارواه الإمام النسائي ، قال أبو شريح يارسول الله إن قومي إذا اختلفوا في شيء فأتوني فحكمت بينهم فرضى عنى الفريقان فقال عليه الصلاة والسلام ما أحسن هذا ...وما رواه أبو داود في سننه عن شريح بن هانئ عن أبيه هانئ أنه لما وفد إلى رسول الله مع قومه ، سمعهم يكنون هانئا أبا الحكم ، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم - إن الله هو الحكم ، وإليه الحكم فلم تكنى أبا

الحكم ؟ فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضى كلا الفريقان ، فقال رسول الله ما أحسن هذا قال : فما لك من الولد ؟ قال : لى شريح ، ومسلم ، وعبدالله قال : فما أكبرهم ؟ قلت : شريح قال : أنت أبو شريح ودعا له ولولده .¹⁶⁰

وجه الدلالة : أن النبي -صلى الله عليه وسلم - لما سأل عن عمل أبى شريح ، وأخبره بالتحكيم استحسنت فعله ، بل ودعا له ولولده ، وهذا يدل على مشروعية التحكيم ، فدل استحسان رسول

¹⁵⁸ -تفسير القرآن العظيم مسندا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين للحافظ عبدالرحمن بن محمد بن إدريس الرازى ابن ابى حاتم المتوفى سنة 327هـ ط دار الفكر - 2003م (ج3/157)، وتفسير الفخر الرازى المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب - ط دار الفكر (ج8/92)، وتفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار المجلد الخامس (ص77) ط دار المعرفة .

¹⁵⁹ -تفسير القرطبي - ط دار الشعب (ج2/1745)

¹⁶⁰ - السنن الكبرى للإمام أبى عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي - ط دار الكتب العلمية بيروت ط 1- 1991م (ج3/466)، وسنن أبى داود (5/240)، وسيرة ابن هشام (3/190)، وتاريخ الطبرى (2/587)

الله -صلى الله عليه وسلم- على ما كان يقع من شريح على جواز التحكيم ، فالرسول لا يستحسن إلا ما كان مشروعاً .

ووجه تغيير الرسول -صلى الله عليه وسلم- كنية هانئ من أبى الحكم إلى أبى شريح ،حتى لا يشارك الله فى صفته (161)،فالحكم أسم من أسماء الله تعالى الحسنى، وما يطلق على المحتكم إليه من اسم الحكم إنما هو على سبيل المجاز ،لأنه يقوم بتطبيق شرع الله على ما يعرض عليه من الخصومات والوقائع .

2-ماروته السيدة عائشة(162) -رضى الله عنها - قالت "كان بينى وبين النبی -صلى الله عليه وسلم- كلام فقال :اجعل بينى وبينك عمر ،فقلت :لا قال :اجعل بينى وبينك أباك ، قلت :نعم" (163)

وجه الدلالة :

أن النبی -صلى الله عليه وسلم- وافق على تحكيم أبى بكر بينه وبين زوجته ، وهذا دليل على مشروعية التحكيم .

3-ما كان يفعله رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مع أمراء الجيوش وقادة السريا فيما رواه الإمام مسلم عن بريدة " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه فى خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال " وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله ، فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك ،فإنك لاتدرى أتصيب حكم الله فيهم أم لا " (164)

161 -قال البغوى "الحكم : هو الحاكم الذى إذا حكم لايرد حكمه ، وهذه الصفة لاتليق بغير الله عز وجل " شرح السنة (ج12/343)، والنهاية فى غريب الحديث والآثر (ج1/281)
162 - هى أم المؤمنين عائشة بنت أبى بكر الصديق رضى الله عنها وعن أبيها ، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ، وذلك قبل الهجرة بثلاث سنين ، وقيل أنه تزوجها قبل سودة - رضى الله عنها- زوجه إياها أبوها فأصدقها مثلما أصدق سودة ، تزوجها وهى بنت ست سنين ، وبنى بها فى المدينة وعمرها تسع سنين ، وما تزوج بكرا سواها ، وقبض صلى الله عليه وسلم وهى بنت ثمانى عشرة سنة ، كانت فقهية زاهدة ، عالمة بأنساب العرب ، ماتت رضى الله عنها فى خلافة معاوية سنة ثمان وخمسون ولها سبع وستون سنة ، ودفنت بالبقيع - انظر فى ترجمتها الوافى بالوفيات - صلاح الدين -خليل بن أبيك بن عبدالله الصفدى المتوفى 764هـ - دار احياء التراث العربى بيروت 1420هـ (ج3/16)

163 -مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمى - ط دار الكتاب العربى بيروت -(4/196)

164 - صحيح مسلم بشرح النووى - (ج12/ص39)

وجه الدلالة :أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - المعصوم فيما يبلغه عن ربه فى مقام الهداية والتشريع أوصى قواده بقبول التحكيم إذا ما طلبه الخصوم ، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يوصى إلا بما هو مشروع ، فكان الحديث دليلا على جواز التحكيم .

وأما الإجماع :فقد أجمع المسلمون على أن النبى صلى الله عليه وسلم عمل بحكم سعد بن معاذ

لما اتفقت اليهود على الرضا بحكمه فيهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم .))¹⁶⁵

ولقد روى الإمام النسائي عن سعد بن إبراهيم قال :سمعت أبا إمامة يحدث عن سعيد أنه سمعه يقول لما نزل أهل قريظة على حكم سعد أتى النبى -صلى الله عليه وسلم -على حمار فقال : "هؤلاء نزلوا على حكمك ، قال :فإنى أحكم أن تقتل مقاتلهم وتسبى زرارهم قال :حكمت فيهم بحكم الملك "))¹⁶⁶

وقال الإمام السرخسي¹⁶⁷ -رحمه الله- والصحابة -رضى الله عنهم- كانوا مجمعين على جواز التحكيم ،ولهذا بدأ الباب بحديث الشعبي -رحمه الله -قال "كان بين عمر وأبى بن كعب -رضى الله عنهما مداراة -أي خصومة ولجاج- فحكما بينهما زيد بن ثابت -رضى الله عنهما- فأتياه فخرج زيد بن ثابت إليهما فقال عمر هلا بعثت الى فأتيتك يا أمير المؤمنين ،فقال عمر في بيته يؤتى الحكم ،فدخل بيته فألقى لعمر وسادة ،فقال عمر هذا أول جورك ،وكانت اليمين على عمر ،فقال زيد لأبى ،لو أعفيت أمير المؤمنين ،فقال عمر يميني لزممتي ،فقال أبى نعفى أمير المؤمنين ونصده "))¹⁶⁸

وقد وقع مثل ذلك لجمع من كبار الصحابة ولم ينكره أحد .

¹⁶⁵ -البحر الرائق (ج7/25)

¹⁶⁶ -السنن الكبرى (3/465)

¹⁶⁷ - هو محمد بن أحمد بن سهل أبو بكر السرخسى نسبة إلى بلاد سرخس فى خراسان الإمام الكبير شمس الأئمة صاحب المبسوط وغيره أحد فحول الأئمة الكبار أصحاب الفنون كان إماما علامة حجة متكلم فقيها أصوليا مناظرا لزم الإمام شمس الأئمة أبا محمد عبد العزيز الحلوانى حتى تخرج به وصار أنظر أهل زمانه وأخذ فى التصنيف وناظر الأقران فظهر إسمه وشاع خبره أملا المبسوط نحو خمسة عشر مجلدا وهو فى السجن بأزوجد وفاته 483هـ - انظر الجواهر المضية فى طبقات الحنفية لعبدالله بن محمد بن نصر الله القرشى ، أبو محمد محى الدين الحنفى (ج2/28)

¹⁶⁸ -المبسوط للسرخسى (21/62)

فقال الماوردي⁽¹⁶⁹⁾: فكان إجماعا. ⁽¹⁷⁰⁾

وأما المعقول: فلأن كثيرا من الناس الآن يحتاجون الى التحكيم، إما لوجودهم بعيدا عن مجلس القضاء، وإما لتعذر وتعقيد إجراءات التقاضى الآن، فلو لم نجز التحكيم لضاق الأمر على الناس، لأنه يشق على الناس الحضور لمجلس الحكم فجوزنا التحكيم للحاجة ⁽¹⁷¹⁾.

بالإضافة إلى أن كثيرا من الناس يفضلون التحكيم لبساطة إجراءاته وقلة نفقاته وقصر وقته، ورغبة في الابتعاد عن الخصومة واللدن فيها.

اشتراط الفقهاء وجوب توافر مافى القاضى من شروط للمحكم، وأهم هذه الشروط العدالة.

والمقصود بالعدالة المشترطة فى المحكم: أن يكون الشخص صادق اللهجة ظاهر الأمانة عفيفا عن المحارم التى حرمها الله متوخيا ما لا يوقعه فى الإثم بعيدا عن الريب وسوء السمع مأمونا فى الرضا والغضب، مستعملا لمروءة مثله فى دينه ودنياه. ⁽¹⁷²⁾

وتشترط العدالة فى المحكم لضرورة حفظ اموال الناس ودمائهم وأعراضهم، وأبضاعهم، إذ لو فوض الحكم لمن لا يوثق بهم لحكموا بالجور وانتشر الظلم، وضاعت المصالح وكثرت المفاسد ⁽¹⁷³⁾.

فذهب جمهور الفقهاء الحنفية فى رواية ⁽¹⁷⁴⁾، والمالكية، والشافعية، والحنابلة إلى أنه يشترط فى المحكم أن يكون عدلا كما هو الشرط فى القاضى، ولو كان فاسقا لا ينفذ حكمه حتى لو وافق الحق.

¹⁶⁹ - الماوردي هو على بن محمد بن حبيب البصرى الشافعي كان إماما فى الفقه والأصول والتفسير بصيرا بالعربية، ولى القضاء وله تصانيف مانعة منها الحاوى والأحكام السلطانية توفى سنة 450هـ انظر - وفيات الأعيان (ج3/282)، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي (267/5)

¹⁷⁰ - مغنى المحتاج (4/378)، فتح القدير (6/406)

¹⁷¹ - الطرابلسي - معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام - (ص24)، وتبيين الحقائق (ج4/193)، ود/ محمد رأفت عثمان - القضاء فى الفقه الإسلامى - ص28

¹⁷² - الأحكام السلطانية للماوردي (ص66)

¹⁷³ - الفروق للقرافي (4/34)

¹⁷⁴ - وتحقيق مذهب الحنفية فى هذه المسألة أن لهم رأيان:

الرأى الأول: وهو فى ظاهر المذهب عندهم أن العدالة ليست شرطا من شروط الحكم، لأنها ليست شرطا فى القاضى، وإنما هي شرط من شروط الكمال أى الأفضل والأكمل أن يكون المحكم عدلا. الرأى الثانى: وهو ما اختاره الطحاوي وعلى الرازي والخصاف من الحنفية أنه يشترط فى المحكم أن يكون عدلا وهو ما نرجحه - شرح فتح القدير والعناية - بهامشه - (6/358)

قال ابن فرحون "إنما يجوز التحكيم إذا كان المحكم عدلا من أهل الاجتهاد أو عاميا واسترشد العلماء، فإن حكم ولم يسترشد رد وإن وافق قول قائل، لأن ذلك تخاطر منهما وغرر، وقال المازري لا يحكم إلا من يصح أن يولى القضاء" (175)

وقال ابن ابي الدم "ويشترط في المحكم أن يكون حرا بالغا عاقلا عدلا مقبول الفتوى عالما بالشريعة، والضابط فيه أن يكون على صفة يجوز للإمام أن يوليه القضاء مطلقا" (176)

"ولكل واحد من المحكمين أن يرجع ما لم يحكم عليهما" لأنه مقلد من جهتهما فلا يحكم إلا برضاهما جميعا "وإذا حكم لزمهما" لصدور حكمه عن ولاية عليهما "وإذا رفع حكمه إلى القاضي فوافق مذهبه أمضاه" لأنه لا فائدة في نقضه ثم في إبرامه على ذلك الوجه "وإن خالفه أبطله" لأن حكمه لا يلزمه لعدم التحكيم منه.

"ولا يجوز التحكيم في الحدود والقصاص" لأنه لا ولاية لهما على دمه ولها لا يملكان الإباحة فلا يستباح برضاها قالوا: وتخصيص الحدود والقصاص يدل على جواز التحكيم في سائر المجتهديات كالطلاق والنكاح وغيرهما، وهو صحيح إلا أنه لا يفتى به، ويقال يحتاج إلى حكم المولى دفعا لتجاسر العوام وإن حكماء في دم خطا فقصى بالدية على العاقلة لم ينفذ حكمه لأنه لا ولاية له عليهم إذ لا تحكيم من جهتهم. ولو حكم على القاتل بالدية في ماله رده القاضي ويقضي بالدية على العاقلة لأنه مخالف لرأيه ومخالف للنص أيضا إلا إذا ثبت القتل بإقراره لأن العاقلة لا تعقله.

"ويجوز أن يسمع البينة ويقضي بالنكول وكذا بالإقرار" لأنه حكم موافق للشرع، ولو أخبر بإقرار أحد الخصمين أو بعدالة الشهود وهما على تحكيمهما يقبل قوله لأن الولاية قائمة ولو أخبر بالحكم لا يقبل قوله لانقضاء الولاية كقول المولى بعد العزل.

"وحكم الحاكم لأبويه وزوجته وولده باطل والمولى والمحكم فيه سواء" وهذا لأنه لا تقبل شهادته لهؤلاء لمكان التهمة فكذلك لا يصح القضاء لهم، بخلاف ما إذا حكم عليهم لأنه تقبل شهادته عليهم لانقضاء التهمة فكذا القضاء، ولو حكما رجلين لا بد من اجتماعهما لأنه أمر يحتاج فيه إلى الرأي، والله أعلم بالصواب.

فالالتجاء إلى التحكيم في الفقه الإسلامي لا يتحقق إلا بالاتفاق عليه بين أطرافه، ولم يشترط الفقهاء أن يتم الاتفاق عليه في شكل معين، أو أن يرد التراضي عليه كتابة، أو أن يرد في عبارات محددة، وإنما يتم هذا الاتفاق بمجرد التعبير عنه وفقا للقواعد العامة، فكل عبارة أو

¹⁷⁵ - تبصرة الحكام (44/1)

¹⁷⁶ - ابن أبي الدم - أدب القضاء (ص178)

شكل يتم الاتفاق في إطاره ،ويعبر بذاته عن حقيقة المقصود منه يجوز إجراء الاتفاق بمقتضاه.))¹⁷⁷

مسائل شتى من كتاب القضاء

قال: "وإذا كان علو لرجل وسفل لآخر فليس لصاحب السفل أن يتد فيه وتدا ولا ينقب فيه كوة عند أبي حنيفة رحمه الله" معناه بغير رضا صاحب العلو "وقالا: يصنع ما لا يضر بالعلو" وعلى هذا الخلاف إذا أراد صاحب العلو أن يبني على علوه. قيل ما حكي عنهما تفسير لقول أبي حنيفة رحمه الله فلا خلاف. وقيل الأصل عندهما الإباحة لأنه تصرف في ملكه والملك يقتضي الإطلاق والحرمة بعارض الضرر فإذا أشكل لم يجز المنع والأصل عنده الحظر لأنه تصرف في محل تعلق به حق محترم للغير كحق المرتهن والمستأجر والإطلاق بعارض فإذا أشكل لا يزول المنع على أنه لا يعرى عن نوع ضرر بالعلو من توهين بناء أو نقضه فيمنع عنه.

قال: "وإذا كانت زائغة مستطيلة تنتشعب منها زائغة مستطيلة وهي غير نافذة فليس لأهل الزائغة الأولى أن يفتحوا بابا في الزائغة القصوى" لأن فتحه للمرور ولا حق لهم في المرور إذ هو لأهلها خصوصا حتى لا يكون لأهل الأولى فيما بيع فيها حق الشفعة، بخلاف النافذة لأن المرور فيها حق العامة. قيل المنع من المرور لا من فتح الباب لأنه رفع بعض جداره. والأصح أن المنع من الفتح لأن بعد الفتح لا يمكنه المنع من المرور في كل ساعة. ولأنه عساه يدعي الحق في القصوى بتركيب الباب "وإن كانت مستديرة قد لزق طرفاها فلهم أن يفتحوا" بابا لأن لكل واحد منهم حق المرور في كلها إذ هي ساحة مشتركة ولهذا يشتركون في الشفعة إذا بيعت دار منها.

قال: "ومن ادعى في دار دعوى وأنكرها الذي هي في يده ثم صالحه منها فهو جائز وهي مسألة الصلح على الإنكار" وسنذكرها في الصلح إن شاء الله تعالى، والمدعي وإن كان مجهولا فالصلح على معلوم عن مجهول جائز عندنا لأنه جهالة في الساقط فلا تفضي إلى المنازعة على ما عرف.

قال: "ومن ادعى دارا في يد رجل أنه وهبها له في وقت كذا فسئل البينة فقال جحدني الهبة فاشتريتها منه وأقام المدعي البينة على الشراء قبل الوقت الذي يدعي فيه الهبة لا تقبل

¹⁷⁷ - الفتاوى الهندية (3/399)، والبحر الرائق (7/24)، والمبسوط (11/111)، وحاشية العدوى على الخرشي (7/145)، ونهاية المحتاج (8/231)

بينته" لظهور التناقض إذ هو يدعي الشراء بعد الهبة وهم يشهدون به قبلها، ولو شهدوا به بعدها تقبل لوضوح التوفيق، ولو كان ادعى الهبة ثم أقام البينة على الشراء قبلها ولم يقل جحدني الهبة فاشتريتها لم تقبل أيضا ذكره في بعض النسخ لأن دعوى الهبة إقرار منه بالملك للواهب عندها، ودعوى الشراء رجوع عنه فعد مناقضا، بخلاف ما إذا ادعى الشراء بعد الهبة لأنه تقرر ملكه عندها.

"ومن قال لآخر: اشتريت مني هذه الجارية فأنكر الآخر إن أجمع البائع على ترك الخصومة وسعه أن يطأها" لأن المشتري لما جحده كان فسحا من جهته، إذ الفسخ يثبت به كما إذا تجاحدا فإذا عزم البائع على ترك الخصومة ثم الفسخ، وبمجرد العزم إن كان لا يثبت الفسخ فقد اقترن بالفعل وهو إمساك الجارية ونقلها وما يضاهيه، ولأنه لما تعذر استيفاء الثمن من المشتري فات رضا البائع فيستبد بفسخه.

قال: "ومن أقر أنه قبض من فلان عشرة دراهم ثم ادعى أنها زيوف صدق" وفي بعض النسخ اقتضى، وهو عبارة عن القبض أيضا. ووجهه أن الزيوف من جنس الدراهم إلا أنها معيبة، ولهذا لو تجوز به في الصرف والسلم جاز، والقبض لا يختص بالحياد فيصدق لأنه أنكر قبض حقه، بخلاف ما إذا أقر أنه قبض الحياد أو حقه أو الثمن أو استوفى لإقراره بقبض الحياد صريحا أو دلالة فلا يصدق والنهرجة كالزيوف وفي الستوة لا يصدق لأنه ليس من جنس الدراهم، حتى لو تجوز به فيما ذكرنا لا يجوز. والزيف ما زيفه بيت المال، والنهرجة ما يرده التجار، والستوة ما يغلب عليه الغش.

قال: "ومن قال لآخر لك علي ألف درهم فقال ليس لي عليك شيء ثم قال في مكانه بل لي عليك ألف درهم فليس عليه شيء" لأن إقراره هو الأول وقد ارتد برد المقر له، والثاني دعوى فلا بد من الحجة أو تصديق خصمه، بخلاف ما إذا قال لغيره اشتريت وأنكر الآخر له أن يصدقه، لأن أحد المتعاقدين لا يتفرد بالفسخ كما لا يتفرد بالعقد، والمعنى أنه حقهما فبقي العقد فعمل التصديق، أما المقر له يتفرد برد الإقرار فافترقا.

قال: "ومن ادعى على آخر مالا فقال ما كان لك علي شيء قط فأقام المدعي البينة على ألف وأقام هو البينة على القضاء قبلت بينته" وكذلك على الإبراء. وقال زفر رحمه الله: لا تقبل لأن القضاء يتلو الوجوب وقد أنكره فيكون مناقضا. ولنا أن التوفيق ممكن لأن غير الحق قد يقضى ويبرأ منه دفعا للخصومة والشغب؛ ألا ترى أنه يقال قضى بباطل وقد يصالح على شيء فيثبت ثم يقضى، وكذا إذا قال ليس لك علي شيء قط لأن التوفيق أظهر "ولو قال ما كان لك علي شيء قط ولا أعرفك لم تقبل بينته على القضاء" وكذا على الإبراء لتعذر التوفيق لأنه لا يكون بين اثنين، أخذ وإعطاء وقضاء واقتضاء ومعاملة بدون المعرفة. وذكر

القدوري رحمه الله أنه تقبل أيضا لأن المحتجب أو المخدرة قد يؤذى بالشغب على بابه فيأمر بعض وكلائه بإرضائه ولا يعرفه ثم يعرفه بعد ذلك فأمكن التوفيق.

قال: "ومن ادعى على آخر أنه باعه جاريته فقال لم أبعها منك قط فأقام المشتري البينة على الشراء فوجد بها أصبعا زائدة فأقام البائع البينة أنه برئ إليه من كل عيب لم تقبل بينة البائع" وعن أبي يوسف رحمه الله أنها تقبل اعتبارا بما ذكرنا. ووجه الظاهر أن شرط البراءة تغيير للعقد من اقتضاء وصف السلامة إلى غيره فيستدعي وجود البيع وقد أنكره فكان مناقضا، بخلاف الدين لأنه قد يقضى وإن كان باطلا على ما مر.

قال: "ذكر حق كتب في أسفله ومن قام بهذا الذكر الحق فهو ولي ما فيه إن شاء الله تعالى، أو كتب في شراء فعلى فلان خلاص ذلك وتسليمه إن شاء الله تعالى بطل الذكر كله، وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله. وقالوا: إن شاء الله تعالى هو على الخلاص وعلى من قام بذكر الحق، وقولهما استحسان ذكره في الإقرار" لأن الاستثناء ينصرف إلى ما يليه لأن الذكر للاستيثاق، وكذا الأصل في الكلام الاستبداد وله أن الكل كشيء واحد بحكم العطف فيصرف إلى الكل كما في الكلمات المعطوفة مثل قوله عبده حر وامرأته طالق وعليه المشي إلى بيت الله تعالى إن شاء الله تعالى؛ ولو ترك فرجة قالوا: لا يلتحق به ويصير كفاصل السكوت، والله أعلم بالصواب.

فصل: في القضاء بالمواريث

قال: "وإذا مات نصراني فجاءت امرأته مسلمة وقالت أسلمت بعد موته وقالت الورثة أسلمت قبل موته فالقول قول الورثة" وقال زفر رحمه الله: القول قولها لأن الإسلام حادث فيضاف إلى أقرب الأوقات. ولنا أن سبب الحرمان ثابت في الحال فيثبت فيما مضى تحكيما للحال كما في جريان ماء الطاحونة؛ وهذا ظاهر نعتبره للدفع؛ وما ذكره يعتبره للاستحقاق؛ "ولو مات المسلم وله امرأة نصرانية فجاءت مسلمة بعد موته وقالت أسلمت قبل موته وقالت الورثة أسلمت بعد موته فالقول قولهم أيضا"، ولا يحكم الحال لأن الظاهر لا يصلح حجة للاستحقاق وهي محتاجة إليه، أما الورثة فهم الدافعون ويشهد لهم ظاهر الحدوث أيضا.

قال: "ومن مات وله في يد رجل أربعة آلاف درهم وديعة فقال المستودع هذا ابن الميت لا وارث له غيره فإنه يدفع المال إليه" لأنه أقر أن ما في يده حق الوارث خلافة فصار كما إذا أقر أنه حق المورث وهو حي أصالة، بخلاف ما إذا أقر لرجل أنه وكيل المودع بالقبض أو أنه اشتراه منه حيث لا يؤمر بالدفع إليه لأنه أقر بقيام حق المودع إذ هو حي فيكون إقرارا على مال الغير، ولا كذلك بعد موته، بخلاف المديون إذا أقر بتوكيل غيره

بالقبض لأن الديون تقضى بأمثالها فيكون إقرارا على نفسه فيؤمر بالدفع إليه "فلو قال المودع لآخر هذا ابنه أيضا وقال الأول ليس له ابن غيري قضى بالمال للأول" لأنه لما صح إقراره للأول انقطع يده عن المال فيكون هذا إقرارا على الأول فلا يصح إقراره للثاني، كما إذا كان الأول ابنا معروفا، ولأنه حين أقر للأول لا مكذب له فصح، وحين أقر للثاني له مكذب فلم يصح.

قال: "وإذا قسم الميراث بين الغرماء والورثة فإنه لا يؤخذ منهم كفيل ولا من وارث وهذا شيء احتاط به بعض القضاة وهو ظلم" وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله، وقالوا: يؤخذ الكفيل، والمسألة فيما إذا ثبت الدين والإرث بالشهادة ولم يقل الشهود لا نعلم له وارثا غيره. لهما أن القاضي ناظر للغيب، والظاهر أن في التركة وارثا غائبا أو غريما غائبا، لأن الموت قد يقع بغتة فيحتاج بالكفالة. كما إذا دفع الآبق واللقطة إلى صاحبه وأعطى امرأة الغائب النفقة من ماله. ولأبي حنيفة رحمه الله أن حق الحاضر ثابت قطعا، أو ظاهرا فلا يؤخر لحق موهوم إلى زمان التكفيل كمن أثبت الشراء ممن في يده أو أثبت الدين على العبد حتى بيع في دينه لا يكفل، ولأن المكفول له مجهول فصار كما إذا كفل لأحد الغرماء بخلاف النفقة لأن حق الزوج ثابت وهو معلوم. وأما الآبق واللقطة ففيه روايتان، والأصح أنه على الخلاف. وقيل إن دفع بعلامة اللقطة أو إقرار العبد يكفل بالإجماع لأن الحق غير ثابت، ولهذا كان له أن يمنع. وقوله ظلم: أي ميل عن سواء السبيل، وهذا يكشف عن مذهبه رحمه الله أن المجتهد يخطئ ويصيب لا كما ظنه البعض.

قال: "وإذا كانت الدار في يد رجل وأقام الآخر البينة أن أبوه مات وتركها ميراثا بينه وبين أخوه فلان الغائب قضى له بالنصف وترك النصف الآخر في يد الذي هي في يده ولا يستوثق منه بكفيل، وهذا عند أبي حنيفة. وقالوا: إن كان الذي هي في يده جاحدا أخذ منه وجعل في يد أمين، وإن لم يجحد ترك في يده" لهما أن الجاحد خائن فلا يترك المال في يده، بخلاف المقر لأنه أمين. وله أن القضاء وقع للميت مقصودا واحتمال كونه مختار الميت ثابت فلا تنقض يده كما إذا كان مقرا وجوده قد ارتفع بقضاء القاضي، والظاهر عدم الجحود في المستقبل لصيرورة الحادثة معلومة له وللقاضي، ولو كانت الدعوى في منقول فقد قيل يؤخذ منه بالاتفاق لأنه يحتاج فيه إلى الحفظ والنزع أبلغ فيه، بخلاف العقار لأنها محصنة بنفسها ولهذا يملك الوصي بيع المنقول على الكبير الغائب دون العقار، وكذا حكم وصي الأم والأخ والعم على الصغير. وقيل المنقول على الخلاف أيضا، وقول أبي حنيفة رحمه الله فيه أظهر لحاجته إلى الحفظ، وإنما لا يؤخذ الكفيل لأنه إنشاء خصومة والقاضي إنما نصب لقطعها لا لإنشائها، وإذا حضر الغائب لا يحتاج إلى إعادة البينة ويسلم النصف إليه بذلك القضاء لأن أحد الورثة ينتصب خصما عن الباقيين فيما يستحق له وعليه دينا كان أو عينا لأن المقضي له وعليه إنما هو الميت في الحقيقة وواحد من الورثة يصلح خليفة عنه

في ذلك، بخلاف الاستيفاء لنفسه لأنه عامل فيه لنفسه فلا يصلح نائباً عن غيره، ولهذا لا يستوفي إلا نصيبه وصار كما إذا قامت البينة بدين الميت، إلا أنه إنما يثبت استحقاق الكل على أحد الورثة إذا كان الكل في يده. ذكره في الجامع لأنه لا يكون خصماً بدون اليد فيقتصر القضاء على ما في يده.

قال: "ومن قال مالي في المساكين صدقة فهو على ما فيه الزكاة، وإن أوصى بثلاث ماله فهو على كل شيء" والقياس أن يلزمه التصديق بالكل، وبه قال زفر رحمه الله لعموم اسم المال كما في الوصية.

وجه الاستحسان أن إيجاب العبد معتبر بإيجاب الله تعالى فينصرف إيجابه إلى ما أوجب الشارع فيه الصدقة من المال. أما الوصية فأخت الميراث لأنها خلافة كهي فلا يختص بمال دون مال، ولأن الظاهر التزام الصدقة من فاضل ماله وهو مال الزكاة، أما الوصية تقع في حال الاستغناء فينصرف إلى الكل وتدخل فيه الأرض العشرية عند أبي يوسف رحمه الله لأنها سبب الصدقة، إذ جهة الصدقة في العشرية راجعة عنده، وعند محمد رحمه الله لا تدخل لأنها سبب المؤنة، إذ جهة المؤنة راجعة عنده، ولا تدخل أرض الخراج بالإجماع لأنه يتمحض مؤنة. ولو قال ما أملكه صدقة في المساكين فقد قيل يتناول كل مال لأنه أعم من لفظ المال. والمقيد بإيجاب الشرع وهو مختص بلفظ المال فلا مخصص في لفظ الملك فبقي على العموم، والصحيح أنهما سواء لأن الملتزم باللفظين الفاضل عن الحاجة على ما مر، "ثم إذا لم يكن له مال سوى ما دخل تحت الإيجاب يمسك من ذلك قوته، ثم إذا أصاب شيئاً تصدق بمثل ما أمسك" لأن حاجته هذه مقدمة ولم يقدر محمد بشيء لاختلاف أحوال الناس فيه. وقيل المحترف يمسك قوته ليوم وصاحب الغلة لشهر وصاحب الضياع لسنة على حسب التفاوت في مدة وصولهم إلى المال، وعلى هذا صاحب التجارة يمسك بقدر ما يرجع إليه ماله.

قال: "ومن أوصى إليه ولم يعلم الوصية حتى باع شيئاً من التركة فهو وصي والبيع جائز، ولا يجوز بيع الوكيل حتى يعلم". وعن أبي يوسف رحمه الله أنه لا يجوز في الفصل الأول أيضاً لأن الوصاية إنابة بعد الموت فتعتبر بالإنابة قبله وهي الوكالة. ووجه الفرق على الظاهر أن الوصاية خلافة لإضافتها إلى زمان بطلان الإنابة فلا يتوقف على العلم كما في تصرف الوارث. أما الوكالة فإنابة لقيام ولاية المنوب عنه فيتوقف على العلم، وهذا لأنه لو توقف لا يفوت النظر لقدرة الموكل، وفي الأول يفوت لعجز الموصي "ومن أعلمه من الناس بالوكالة يجوز تصرفه" لأنه إثبات حق لا إلزام أمر.

قال: "ولا يكون النهي عن الوكالة حتى يشهد عنده شاهدان أو رجل عدل" وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله، وقالوا: هو والأول سواء لأنه من المعاملات وبالواحد فيها كفاية. وله أنه خبر ملزم فيكون شهادة من وجه فيشترط أحد شطريها وهو العدد أو العدالة، بخلاف الأول،

وبخلاف رسول الموكل لأن عبارته كعبارة المرسل للحاجة إلى الإرسال، وعلى هذا الخلاف إذا أخبر المولى بجناية عبده والشفيع والبكر والمسلم الذي لم يهاجر إلينا.

قال: "وإذا باع القاضي أو أمينه عبدا للغرماء وأخذ المال فضاع واستحق العبد لم يضمن" لأن أمين القاضي قائم مقام القاضي والقاضي مقام الإمام وكل واحد منهم لا يلحقه ضمان كي لا يتقاعد عن قبول هذه الأمانة فيضيع الحقوق ويرجع المشتري على الغرماء، لأن البيع واقع لهم فيرجع عليهم عند تعذر الرجوع على العاقد، كما إذا كان العاقد محجورا عليه ولهذا يباع بطلبهم "وإن أمر القاضي الوصي ببيعه للغرماء ثم استحق أو مات قبل القبض وضاع المال رجع المشتري على الوصي" لأنه عاقد نيابة عن الميت وإن كان بإقامة القاضي عنه فصار كما إذا باعه بنفسه.

قال: "ورجع الوصي على الغرماء" لأنه عامل لهم، وإن ظهر للميت مال يرجع الغريم فيه بدينه. قالوا: ويجوز أن يقال يرجع بالمائة التي غرمها أيضا لأنه لحقه في أمر الميت، والوارث إذا بيع له بمنزلة الغريم لأنه إذا لم يكن في التركة دين كان العاقد عاملا له.

فصل: وإذا قال القاضي قد قضيت على هذا بالرجم فارجمه الخ

...

فصل آخر: "وإذا قال القاضي قد قضيت على هذا بالرجم فارجمه أو بالقطع فاقطعه أو بالضرب فاضربه وسعك أن تفعل"

وعن محمد رحمه الله أنه رجع عن هذا وقال: لا تأخذ بقوله حتى تعالين الحجة، لأن قوله يحتمل الغلط والخطأ والتدراك غير ممكن، وعلى هذه الرواية لا يقبل كتابه. واستحسن المشايخ هذه الرواية لفساد حال أكثر القضاة في زماننا إلا في كتاب القاضي للحاجة إليه. وجه ظاهر الرواية أنه أخبر عن أمر يملك إنشاءه فيقبل لخلوه عن التهمة، ولأن طاعة أولي الأمر واجبة، وفي تصديقه طاعة. وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: إن كان عدلا عالما يقبل قوله لانعدام تهمة الخطأ والخيانة، وإن كان عدلا جاهلا يستفسر، فإن أحسن التفسير وجب تصديقه وإلا فلا، وإن كان جاهلا فاسقا أو عالما فاسقا لا يقبل إلا أن يعالين سبب الحكم لتهمة الخطأ والخيانة.

قال: "وإذا عزل القاضي فقال لرجل أخذت منك ألفا ودفعتها إلى فلان قضيت بها عليك فقال الرجل أخذتها ظلما فالقول قول القاضي، وكذا لو قال قضيت بقطع يدك في حق، هذا إذا كان الذي قطعت يده والذي أخذ منه المال مقرين أنه فعل ذلك وهو قاض" ووجهه

أنهما لما توافقا أنه فعل ذلك في قضائه كان الظاهر شاهدا له. إذ القاضي لا يقضي بالجور ظاهرا "ولا يمين عليه" لأنه ثبت فعله في قضائه بالتصادق ولا يمين على القاضي.

"ولو أقر القاطع والآخذ بما أقر به القاضي لا يضمن أيضا" لأنه فعله في حال القضاء ودفع القاضي صحيح كما إذا كان معايينا.

"ولو زعم المقطوع يده أو المأخوذ ماله أنه فعل قبل التقليد أو بعد العزل فالقول للقاضي أيضا" هو الصحيح لأنه أسند فعله إلى حالة معهودة منافية للضمان فصار كما إذا قال طلقت أو أعتقت وأنا مجنون والجنون منه كان معهودا.

"ولو أقر القاطع أو الآخذ في هذا الفصل بما أقر به القاضي بضمان" لأنهما أقرّا بسبب الضمان، وقول القاضي مقبول في دفع الضمان عن نفسه لا في إبطال سبب الضمان على غيره، بخلاف الأول لأنه ثبت فعله في قضائه بالتصادق "ولو كان المال في يد الآخذ قائما وقد أقر بما أقر به القاضي والمأخوذ منه المال صدق القاضي في أنه فعله في قضائه أو ادعى أنه فعله في غير قضائه يؤخذ منه" لأنه أقر أن اليد كانت له فلا يصدق في دعوى تملكه إلا بحجة، وقول المعزول فيه ليس بحجة.

كتاب الجنایات

1-أوجه القتل:

الهداية: قَالَ⁽¹⁷⁸⁾ (الْقَتْلُ عَلَى خَمْسَةِ أَوْجِهٍ: عَمْدٌ، وَشِبْهُ عَمْدٍ، وَخَطَأٌ، وَمَا أُجْرِيَ مَجْرَى الْخَطَأِ، وَالْقَتْلُ بِسَبَبٍ) وَالْمُرَادُ⁽¹⁷⁹⁾ بَيَانُ قَتْلِ تَتَعَلَّقُ بِهِ الْأَحْكَامُ.

التعليق: تعريف الجنایات وسببها وشرطها:

1-شُرِعتِ الْجِنَايَاتُ لِصَيَانَةِ الْأَنْفُسِ وَالْأَطْرَافِ.

2-تعريف الجنایات: الجنایات جمع جِنَايَةٌ وهى لُغَةً⁽¹⁸⁰⁾: اسْمٌ لِمَا يُكْتَسَبُ مِنَ الشَّرِّ تَسْمِيَةً بِالْمَصْدَرِ مِنْ جَنَى عَلَيْهِ شَرًّا، وَهُوَ عَامٌّ.

¹⁷⁸(())القدوري، أبو الحسين أحمد بن محمد بن احمد بن جعفر بن حمدان الفقيه الحنفي، المعروف بالقدوري؛ انتهت إليه رئاسة الحنفية بالعراق. وكان حسن العبارة في النظر. وسمع الحديث، وروى عنه أبو بكر الخطيب صاحب التاريخ، وصنف في مذهبه المختصر المشهور وغيره. وكانت ولادته سنة اثنتين وستين وثلثمائة، وتوفي يوم الأحد الخامس من رجب سنة ثمان وعشرين وأربعمائة ببغداد. والْقُدُورِيُّ بِضَمِّ الْقَافِ وَالْدَّالِ وَسُكُونِ الْوَاوِ وَفِي آخِرِهَا رَاءُ نِسْبَةٍ إِلَى بَيْعِ الْقُدُورِ. ينظر: وفيات الأعيان لابن خلكان 79/1، الجواهر المضوية في طبقات الحنفية لمحيي الدين الحنفي 2/ 336.

¹⁷⁹(())(والمراد) أي مراد القدوري.

والجناية شرعا: كل اعتداء مُحَرَّمٌ شَرْعًا حَلَّ بِالنُّفُوسِ وَالْأَطْرَافِ، فإن حل بالنفس: يُسَمَّى قَتْلًا : وَهُوَ فِعْلٌ مِنَ الْعِبَادِ تَزْوُلُ بِهِ الْحَيَاةُ، وزوال الحياة بدون قتل العباد يسمى موتا. وإن حل بالأطراف: يُسَمَّى قَطْعًا وَجَرَحًا.

3-سَبَبُ الجَنَايَاتِ: كل اعتداء على النفس والأطراف.

4-شَرَطُ الجَنَايَاتِ: كَوْنُ الْمَجْنِي عَلَيْهِ إِنْسَانًا مَعْصُومَ الدَّمِ.

أوجه القتل:

قَالَ (الْقَتْلُ عَلَى خَمْسَةِ أَوْجُهٍ) المراد بالقتل هنا هو : الْقَتْلُ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ حُكْمٌ مِنْ قِصَاصٍ وَدِيَّةٍ وَكَفَّارَةٍ وَحِرْمَانِ إِرْثٍ خَمْسَةٌ أَوْجُهٍ، لأن القتل لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ حَصَلَ بِسِلَاحٍ أَوْ بِغَيْرِ سِلَاحٍ، فَإِنْ حَصَلَ بِسِلَاحٍ فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ كَانَ بِهِ قَصْدُ الْقَتْلِ أَوْ لَا، فَإِنْ كَانَ فَهُوَ الْعَمْدُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَهُوَ الْخَطَأُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِسِلَاحٍ فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ كَانَ مَعَهُ قَصْدُ التَّأْدِيبِ وَالضَّرْبِ أَوْ لَا، فَإِنْ كَانَ فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ كَانَ جَارِيًا مَجْرَى الْخَطَأِ أَمْ لَا، فَإِنْ كَانَ فَهُوَ هُوَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَهُوَ الْقَتْلُ بِالسَّبَبِ.

¹⁸⁰()لسان العرب لابن منظور، مادة(جنى)، 154/14.

2- القتل العمد وموجباته

الهداية: قَالَ (فَالْعَمْدُ مَا تَعَمَّدَ ضَرْبُهُ بِسِلَاحٍ أَوْ مَا أُجْرِيَ مَجْرَى السِّلَاحِ كَالْمُحَدَّدِ مِنَ الْخَشَبِ وَلِيطَةِ الْقَصَبِ)⁽¹⁸¹⁾ وَالْمَرْوَةِ الْمُحَدَّدَةِ⁽¹⁸²⁾ (وَالنَّارِ) ؛ لِأَنَّ الْعَمْدَ هُوَ الْقَصْدُ، وَلَا يُوقَفُ عَلَيْهِ إِلَّا بِدَلِيلِهِ وَهُوَ اسْتِعْمَالُ الْأَلَةِ الْقَاتِلَةِ فَكَانَ مُتَعَمِّدًا فِيهِ عِنْدَ ذَلِكَ

(وَمُوجِبُ ذَلِكَ الْمَأْثَمُ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} [النساء: 93] الْآيَةِ، وَقَدْ نَطَقَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ السُّنَّةِ، وَعَلَيْهِ انْعَقَدَ إِجْمَاعُ الْأُمَّةِ. قَالَ (وَالْقَوْدُ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ} [البقرة: 178] إِلَّا أَنَّهُ تَقَيَّدَ بِوَصْفِ الْعَمْدِيَّةِ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «الْعَمْدُ قَوْدٌ» أَيُّ مُوجِبُهُ، وَلِأَنَّ الْجِنَايَةَ بِهَا تَتَكَامَلُ وَحِكْمَةُ الزَّجْرِ عَلَيْهَا تَتَوَفَّرُ، وَالْعُقُوبَةُ الْمُتَنَاهِيَةُ لَا شَرَعَ لَهَا دُونَ ذَلِكَ.

التعليق:

القتل العمد: أن يقصد القتل بآلة موضوعة للقتل كالبنديقية، أو تقتل غالباً ، وهي ما أُجريت مجرى السلاح في تفريق الأجزاء كالمحدد من الخشب وليطة القصب وهي دليل القصد.

حكم القتل العمد: يحرم القتل العمد ، وموجب للإثم في الآخرة والقصاص في الدنيا:

أما وجوب المأثم فدل عليه النص من القرآن الكريم والسنة، وانعقد الإجماع على ذلك:

¹⁸¹() الليطة بكسر اللام قشر القصب.

¹⁸²() المروة المحددة: وهي القطعة من الحجر الصوان، يكون لها أطراف تقطع ما أصابته.

ففي القرآن الكريم قوله تعالى {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} [النساء: 93] الآية.

وفي السنة قوله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فِي خُطْبَتِهِ بِعَرَفَاتٍ «إِنْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ، كَحَرَمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بِلَدِكُمْ هَذَا»⁽¹⁸³⁾ وَمِنْهَا قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لِزَوَالِ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ»⁽¹⁸⁴⁾. وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَنْ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ، مَا لَمْ يُصِْبْ دَمًا حَرَامًا»⁽¹⁸⁵⁾.

وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَهُ إِلَّا رَجُلٌ يَمُوتُ كَافِرًا أَوْ الرَّجُلُ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا»⁽¹⁸⁶⁾. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا.

وأما وجوب القصاص في الدنيا فدل عليه النص من القرآن الكريم والسنة، والمعقول:

ففي القرآن الكريم: قَوْلُهُ تَعَالَى {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ} [البقرة: 178] الآية وَهُوَ بَظَاهِرِهِ لَمْ يَفْصَلْ بَيْنَ الْعَمْدِ وَالْخَطَا لَكِنَّهُ تَقَيَّدَ بِوَصْفِ الْعَمْدِيَّةِ بِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «الْعَمْدُ قَوْدٌ»⁽¹⁸⁷⁾ أَيِ مُوجِبُهُ، وَالْحَدِيثُ مَشْهُورٌ.

والمعقول: لِأَنَّ الْجَنَايَةَ بِالْعَمْدِيَّةِ تَتَكَامَلُ. وَقَوْلُهُ (لَا شَرَعَ لَهَا دُونَ ذَلِكَ) أَيِ لَا شَرْعِيَّةَ لِلْعُقُوبَةِ الْمُتَنَاهِيَةِ بِدُونِ الْعَمْدِيَّةِ.

¹⁸³() أخرجه مسلم في صحيحه 886/2 رقم 1218.

¹⁸⁴() أخرجه الترمذي في سننه 68/3 رقم 1395.

¹⁸⁵() أخرجه البخاري في صحيحه 2/9 رقم 6862.

¹⁸⁶() أخرجه الحاكم في المستدرک 391/4 رقم 8031.

¹⁸⁷() أخرجه الدارقطني في سننه 82/4 رقم 3136.

وَتَقْرِيرُ حُجَّتِهِ أَنَّ الْعَمْدِيَّةَ تَتَكَامَلُ بِهَا الْجِنَايَةُ، وَكُلُّ مَا تَتَكَامَلُ بِهِ الْجِنَايَةُ كَانَتْ حِكْمَةُ الزَّجْرِ عَلَيْهَا أَكْمَلَ، وَقَوْلُهُ (وَالْعُقُوبَةُ الْمُنْتَاهِيَةُ الْخ) حُجَّةٌ أُخْرَى.

3-مدى جواز العفو والمصالحة عن القصاص

الهداية: قَالَ (إِلَّا أَنْ يَعْفُو الْأَوْلِيَاءُ)⁽¹⁸⁸⁾ أَوْ يُصَالِحُوا⁽¹⁸⁹⁾؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمْ ثُمَّ هُوَ وَاجِبٌ عَيْنًا، وَلَيْسَ لِلْوَلِيِّ اخْذُ الدِّيَةِ إِلَّا بِرِضَا الْقَاتِلِ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلِي الشَّافِعِيِّ، إِلَّا أَنَّ لَهُ حَقَّ الْعُدُولِ إِلَى الْمَالِ مِنْ غَيْرِ مَرْضَاةِ الْقَاتِلِ؛ لِأَنَّهُ تَعَيَّنَ مَدْفَعًا لِلْهَلَاكِ فَيَجُوزُ بِدُونِ رِضَاهُ، وَفِي قَوْلِ الْوَاجِبِ أَحَدُهُمَا لَا بَعَيْنِهِ وَيَتَعَيَّنُ بِاخْتِيَارِهِ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْعَبْدِ شُرْعًا جَابِرًا وَفِي كُلِّ وَاحِدٍ نَوْعٌ جَبَرٌ فَيَتَخَيَّرُ

وَلَنَا مَا تَلَوْنَا مِنَ الْكِتَابِ وَرَوَيْنَا مِنَ السُّنَّةِ، وَلِأَنَّ الْمَالَ لَا يَصْلُحُ مُوجِبًا لِعَدَمِ الْمَمَاتِلَةِ، وَالْقِصَاصُ يَصْلُحُ لِلتَّمَاتِلِ، وَفِيهِ مَصْلَحَةُ الْأَحْيَاءِ زَجْرًا وَجَبْرًا فَيَتَعَيَّنُ، وَفِي الْخَطَا وَجُوبِ الْمَالِ ضَرُورَةُ صَوْنِ الدِّمِّ عَنِ الْإِهْدَارِ، وَلَا يُنَبِّهَنَّ بِعَدَمِ قَصْدِ الْوَلِيِّ بَعْدَ اخْذِ الْمَالِ فَلَا يَتَعَيَّنُ مَدْفَعًا لِلْهَلَاكِ،

التعليق:

¹⁸⁸() لفظ القدوري- رحمه الله-

¹⁸⁹() لفظ المصنف (المرغاني)- رحمه الله-

مدى جواز العفو والمصالحة عن القصاص؟، ومن له الحق في ذلك؟ ، وهل القصاص واجب على التعيين أم التخيير بينه وبين الدية؟، وهل يجوز للولي أخذ الدية بدون رضا القاتل؟.

مدى جواز العفو والمصالحة عن القصاص؟، يجوز العفو والمصالحة عن القصاص ومن له الحق في ذلك؟ الحق في ذلك لأولياء الدم

وهل القصاص واجب على التعيين أم التخيير بينه وبين الدية؟ القصاص واجب عينا عند الحنفية.

وهل يجوز للولي أخذ الدية بدون رضا القاتل؟. اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: القول الأول: ذهب الحنفية وأحد قولي الشافعي إلى أنه لا يجوز للولي أخذ الدية بدون رضا القاتل، إلا أن للولي حق العدول إلى المال من غير مرضاة القاتل، لأنه تعين مدفعا للهلاك فيجوز بدون رضاه.

القول الثاني: ذهب الشافعي في قول أن الواجب أحدهما لا بعينه -القصاص أو الدية- ويتعين باختياره، واستدلوا على ذلك بالمعقول وهو أَنَّ حَقَّ الْعَبْدِ شُرْعَ جَابِرًا وَفِي كُلِّ وَاحِدٍ -القصاص أو الدية- نَوْعٌ جَبْرٌ فَيُنْخَيرُ.

واستدل أصحاب القول الأول الحنفية وأحد قولي الشافعي على أنه لا يجوز للولي أخذ الدية بدون رضا القاتل بالكتاب والسنة والمعقول:

أما الكتاب، فقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ} [البقرة: 178] الْآيَةُ وَوَجْهُ التَّمَسُّكِ بِهِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَكَرَ فِي الْخَطَا الدِّيَّةَ فَتَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ الْقِصَاصُ الْمَذْكُورُ فِيهِ فِيمَا هُوَ ضِدُّ الْخَطَا وَهُوَ الْعَمْدُ، وَلَمَّا تَعَيَّنَ بِالْعَمْدِ لَا يُعْدَلُ عَنْهُ لِئَلَّا تَلْزَمَ الزِّيَادَةُ عَلَى النَّصِّ بِالرَّأْيِ.

وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: «الْعَمْدُ قَوْدٌ»⁽¹⁹⁰⁾ وَوَجْهُ التَّمَسُّكِ بِالسُّنَّةِ أَنَّ الْأَلْفَ وَاللَّامَ فِي قَوْلِهِ الْعَمْدُ قَوْدٌ لِلْجِنْسِ، إِذْ لَا مَعْهُودَ يَنْصَرِفُ إِلَيْهِ، فَفِيهِ تَنْصِيسٌ عَلَى أَنَّ حُكْمَ جِنْسِ الْعَمْدِ ذَلِكَ، فَمَنْ عَدَلَ عَنْهُ إِلَى غَيْرِهِ زَادَ عَلَى النَّصِّ أَثَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - فِي قَوْلِهِ: الْعَمْدُ قَوْدٌ لَا مَالَ فِيهِ إِلَى ذَلِكَ.

وَوَجْهُ الْمُعْقُولِ أَنَّ الْمَالَ لَا يَصْلُحُ مُوجِبًا فِي الْقَتْلِ الْعَمْدِ لِعَدَمِ الْمُمَاتَلَةِ، لِأَنَّ الْأَدَمِيَّ مَالِكٌ مُبْتَدِلٌ وَالْمَالُ مَمْلُوكٌ مُبْتَدَلٌ فَأَنَّى يَتِمَّاتَلَانِ، بِخِلَافِ الْقِصَاصِ فَإِنَّهُ يَصْلُحُ مُوجِبًا لِلتَّمَاتَلِ، وَفِيهِ زِيَادَةُ حِكْمَةٍ وَهِيَ مَصْلَحَةُ الْإِحْيَاءِ زَجْرًا لِلْغَيْرِ عَنْ وَقُوعِهِ فِيهِ وَجَبْرًا لِلْوَرَنَةِ فَيَتَعَيَّنُ.

فَإِنْ قِيلَ: فَكَيْفَ صَلَحَ الْمَالُ مُوجِبًا فِي الْخَطَا وَالْفَائِتُ فِيهِ أَيِ النَّفْسِ مِثْلُ الْفَائِتِ فِي الْعَمْدِ. فَيَجَابُ عَنْ ذَلِكَ بَأَنَّ فِي الْخَطَا وَجُوبَ الْمَالِ ضَرُورَةَ صَوْنِ الدِّمِّ عَنِ الْإِهْدَارِ، فَإِنَّهُ لَمَّا لَمْ يُمَكِّنِ الْإِقْتِصَاصُ فِيهِ هُدْرَ الدِّمِّ لَوْ لَمْ يَجِبِ الْمَالُ وَالْأَدَمِيُّ مُكْرَّمٌ لَا يَجِبُ إِهْدَارُ دَمِهِ، عَلَى أَنَّ ذَلِكَ ثَابِتٌ بِالنَّصِّ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ، وَالْعَمْدُ لَيْسَ فِي مَعْنَاهُ حَتَّى يُلْحَقَ بِهِ.

وَأُجِيبَ عَنْ قَوْلِهِ لِأَنَّهُ تَعَيَّنَ مَدْفَعًا لِلْهَلَاكِ بِقَوْلِهِ (وَلَا يُتَيَقَّنُ بَعْدَ قَصْدِ الْوَلِيِّ بَعْدَ اخْتِازِ الْمَالِ) وَذَلِكَ لِجَوَازِ أَنْ يَأْخُذَ الْوَلِيُّ الْمَالَ مِنَ الْقَاتِلِ بِدُونِ رِضَاةٍ ثُمَّ يَقْتُلُهُ. قِيلَ هَذَا الْوَهْمُ مَوْجُودٌ فِيمَا إِذَا أَخَذَ الْمَالُ صُلْحًا وَقَدْ جَازَ. أُجِيبَ بِأَنَّ فِي الصُّلْحِ الْمُرَاضَاةَ وَالْقَتْلُ بَعْدَهُ ظَاهِرُ الْعَدَمِ.

⁽¹⁹⁰⁾ أخرجه الدارقطني في سننه 82/4 رقم 3136.

وَعُورِضَ بَقُولِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِمَّا يُودَىٰ وَإِمَّا يُقَادُ » (191) وَبِأَنَّ الشَّرْعَ أَوْجَبَ الْقِصَاصَ لِمَعْنَى الْإِنْتِقَامِ وَتَشْفِي صُدُورِ الْأَوْلِيَاءِ، بِخِلَافِ الْقِيَاسِ فَإِنَّ الْجَمَاعَةَ تُقْتَلُ بِوَاحِدٍ وَالْقِيَاسُ لَا يَقْتَضِيهِ، فَكَانَ لِمَعْنَى النَّظَرِ لِلْوَلِيِّ وَذَلِكَ بِتَمَكُّنِهِ مِنَ الْقِصَاصِ وَأَخْذِ الدِّيَةِ.

وَالْجَوَابُ أَنَّ الْحَدِيثَ خَبَرٌ وَاحِدٌ فَلَا يُعَارِضُ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ الْمَشْهُورَةَ، وَأَنَّ الْقِصَاصَ لِمَعْنَى النَّظَرِ لِلْوَلِيِّ عَلَى وَجْهِ خَاصٍّ وَهُوَ الْإِنْتِقَامُ وَتَشْفِي الصُّدُورِ، فَإِنَّهُ شَرَعَ زَجْرًا عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ إِفْنَاءِ قَبِيلَةٍ بِوَاحِدٍ لَا لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَأْخُذُونَ أَمْوَالًا كَثِيرَةً عِنْدَ قَتْلِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، بَلْ الْقَاتِلُ وَأَهْلُهُ لَوْ بَذَلُوا مَا مَلَكُوهُ وَأَمْثَالُهُ مَا رَضِيَ بِهِ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ، فَكَانَ إِبْجَابُ الْمَالِ فِي مُقَابَلَةِ الْقَتْلِ الْعَمْدِ تَضْيِيعُ حِكْمَةِ الْقِصَاصِ، وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ الْأَصْلَ هُوَ الْقِصَاصُ لَمْ يَجْزُ الْمَصِيرُ إِلَى غَيْرِهِ بِغَيْرِ ضَرُورَةٍ مِثْلُ أَنْ يَعْفُو أَحَدُ الْأَوْلِيَاءِ فَإِنَّهُ تَعَدَّرَ الْإِسْتِيفَاءَ حِينَئِذٍ، أَوْ أَنْ يَكُونَ مَحَلُّ الْقِصَاصِ نَاقِصًا بِأَنْ تَكُونَ يَدُ قَاطِعِ الْيَدِ أَقَلَّ أَصْبَعًا وَأَمْثَالُ ذَلِكَ.

4-الكفارة والميراث في القتل العمد

الهداية: وَلَا كَفَّارَةَ فِيهِ عِنْدَنَا: وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - تَجِبُ؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ إِلَى التَّكْفِيرِ فِي الْعَمْدِ أَمْسُ مِنْهَا إِلَيْهِ فِي الْخَطَا فَكَانَ أَدْعَى إِلَى إِبْجَابِهَا

¹⁹¹() أخرجه البخاري في صحيحه 5/9 رقم 6880.

وَلَنَا أَنَّهُ كَبِيرَةٌ مَحْضَةٌ، وَفِي الْكَفَّارَةِ مَعْنَى الْعِبَادَةِ فَلَا تُنَاطُ بِمِثْلِهَا، وَلِأَنَّ الْكَفَّارَةَ مِنَ الْمَقَادِيرِ، وَتَعَيَّنُهَا فِي الشَّرْعِ لِدَفْعِ الْأَذْنَى لَا يُعَيَّنُهَا لِدَفْعِ الْأَعْلَى

وَمِنْ حُكْمِهِ حِرْمَانُ الْمِيرَاثِ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «لَا مِيرَاثَ لِقَاتِلٍ»¹⁹².

التعليق:

هل تجب الكفارة في القتل العمد؟ مستدلاً لما تذكر.

اختلف الفقهاء في وجوب الكفارة في القتل العمد على قولين: القول الأول: ذهب الحنفية إلى أنه لا كفارة في القتل العمد سواءً وجب فيه القصاص أو لم يجب كالأب إذا قتل ابنه عمداً.

القول الثاني: ذهب الشافعي - رحمه الله - إلى أنه تجب الكفارة في القتل العمد، لأن الحاجة إلى التكفير في العمد أمس منها إليه في الخطأ لأنها لسر الذنب والذنب في العمد أعظم.

¹⁹²(قال ابن حجر العسقلاني في الدراية في تخريج أحاديث الهداية 260/2 رقم 1005: "حديث" لا ميراث لقاتل "أصحاب السنن إلا أبا داود من حديث أبي هريرة رفعه القاتل لا يرث قال الترمذي لا يصح وفيه إسحاق بن أبي فروة وهو متروك وقال النسائي إسحاق متروك وإنما أخرجه لئلا يترك من الوسط يغنى بين الليث والزهري وروى أبو داود من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في حديث طويل ولا يرث القاتل شيئاً وللنسائي من هذا الوجه ليس للقاتل من الميراث شيء وقال الصواب رواية مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل شيء انتهى وهو في الموطأ وأخرجه الشافعي وعبد الرزاق عن مالك وأخرجه ابن ماجه من طريق أبي خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن أبا قتادة المدلجي قتل ابنه فأخذ منه عمر مائة من الإبل الحديث وفيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس لقاتل ميراث وفيه انقطاع وقد أخرجه الدارقطني من طريق عبد الله بن جعفر عن يحيى ابن سعيد فقال عن سعيد بن المسيب عن عمر والأول أصح. وأخرجه ابن ماجه وغيره في سننه بلفظ «القاتل لا يرث» 913/2 رقم 2735

واستدل الحنفية على عدم وجوب الكفارة في القتل العمد بالمعقول لأنَّه كَبِيرَةٌ مَحْضٌ، وَمَا هُوَ كَذَلِكَ لَا يَكُونُ سَبَبًا لِمَا فِيهِ
مَعْنَى الْعِبَادَةِ وَالْكَفَّارَةُ فِيهَا ذَلِكَ.

5- المقصود بالقتل شبه العمد

الهداية: قَالَ (وَشِبْهُ الْعَمْدِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ أَنْ يَتَعَمَّدَ الضَّرْبَ بِمَا لَيْسَ بِسِلَاحٍ وَلَا مَا أُجْرِيَ مَجْرَى السِّلَاحِ) وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ: إِذَا ضَرَبَهُ بِحَجَرٍ عَظِيمٍ أَوْ بِخَشَبَةٍ عَظِيمَةٍ فَهُوَ عَمْدٌ

وَشِبْهُ الْعَمْدِ أَنْ يَتَعَمَّدَ ضَرَبَهُ بِمَا لَا يُقْتَلُ بِهِ غَالِبًا؛ لِأَنَّهُ يَتَقَاصَرُ مَعْنَى الْعَمْدِيَّةِ بِاسْتِعْمَالِ آلَةٍ صَغِيرَةٍ لَا يُقْتَلُ بِهَا غَالِبًا لِمَا أَنَّه يَقْصِدُ بِهَا غَيْرَهُ كَالْتَّادِيْبِ وَنَحْوِهِ فَكَانَ شِبْهُ الْعَمْدِ، وَلَا يَتَقَاصَرُ بِاسْتِعْمَالِ آلَةٍ لَا تَلْبَثُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْصِدُ بِهِ إِلَّا الْقَتْلَ كَالسَّيْفِ فَكَانَ عَمْدًا مُوجِبًا لِلْقَوْدِ

وَلَهُ قَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «أَلَا إِنَّ قَتِيلَ خَطَا الْعَمْدِ قَتِيلُ السَّوْطِ وَالْعَصَا، وَفِيهِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ» وَلِأَنَّ الْآلَةَ غَيْرُ مَوْضُوعَةٍ لِلْقَتْلِ وَلَا مُسْتَعْمَلَةٌ فِيهِ؛ إِذْ لَا يُمَكِّنُ اسْتِعْمَالُهَا عَلَى غَرَّةٍ مِنَ الْمَقْصُودِ قَتْلَهُ، وَبِهِ يَحْصُلُ الْقَتْلُ غَالِبًا فَقُصِرَتْ الْعَمْدِيَّةُ نَظْرًا إِلَى الْآلَةِ، فَكَانَ شِبْهُ الْعَمْدِ كَالْقَتْلِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا الصَّغِيرَةِ.

التعليق:

ما المقصود بالقتل شبه العمد؟ مستدلا لما تذكر.

اختلف الفقهاء في المقصود بالقتل شبه العمد: القول الأول: قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - شِبْهُ الْعَمْدِ هُوَ أَنْ يَتَعَمَّدَ الضَّرْبَ بِمَا لَيْسَ بِسِلَاحٍ وَلَا أُجْرِيَ مَجْرَاهُ سِوَاءً كَانَ الْهَلَاكُ بِهِ غَالِبًا كَالْحَجَرِ وَالْعَصَا الْكَبِيرَيْنِ وَمِدَقَّةِ الْقَصَّارِ أَوْ لَمْ يَكُنْ كَالْعَصَا الصَّغِيرَةِ.

القول الثاني: قال صاحبان شبه العمد هو أن يتعمد الضرب بما لا يحصل الهلاك به غالباً كالعصا الصغيرة إذا لم يؤال في الضربات. فأمّا إذا والى فيها فقتل شبه عمد عندهما وقيل عمد محض، قالوا: سمي هذا النوع شبه العمد لاقتصار معنى العمد فيه وإلا لكان عمداً، واقتصاره إنما يتصور في استعمال آلة لا يقتل بها غالباً كالعصا الصغيرة فإنه يقصد باستعمالها غير القتل كالتأديب ونحوه. لا في استعمال آلة لا تلبث فإنه لا يقصد باستعمالها إلا القتل. واستدل الإمام أبو حنيفة - رحمه الله - بقوله - صلى الله عليه وسلم - «ألا وإن كل قتل خطأ العمد أو شبه العمد قتل السوط والعصا، فيه مائة من الإبل، منها أربعون في بطونها وأولادها» ((193) ووجه الاستدلال أنه - عليه الصلاة والسلام - جعل قتل السوط والعصا مطلقاً شبه عمد فتخصيصه به بالصغيرة إبطالاً للإطلاق وهو لا يجوز، ولأن العصا الكبيرة والصغيرة تساويان في كونهما غير موضوعتين للقتل ولا مستعملتين له، إذ لا يمكن الاستعمال على غرة من المقصود قتله، وبالإستعمال على غرة يحصل القتل غالباً، وإذا تساويان والقتل بالعصا الصغيرة شبه عمد فكذا بالكبيرة.

6-موجبات القتل شبه العمد

الهداية: قال (وموجب ذلك على القولين الإثم) ؛ لأنه قتل وهو قاصد في الضرب (والكفارة) لشبهه بالخطأ (والدية مغلظة على العاقلة) والأصل أن كل دية وجبت بالقتل ابتداءً لا بمعنى يحدث من بعد فهي على العاقلة اعتباراً بالخطأ، وتجب في

¹⁹³() أخرجه النسائي في السنن الكبرى 353/6 رقم 6972.

ثَلَاثِ سِنِينَ لِقَضِيَّةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، وَتَجِبُ مُعْلَظَةٌ، وَسُنْبِيْنُ صِفَةِ التَّغْلِيْظِ مِنْ بَعْدِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى (وَيَتَعَلَّقُ بِهِ حِرْمَانُ الْمِيرَاثِ) ؛ لِأَنَّهُ جَزَاءُ الْقَتْلِ، وَالشُّبْهَةُ تُؤَثِّرُ فِي سُقُوطِ الْقِصَاصِ دُونَ حِرْمَانِ الْمِيرَاثِ، وَمَالِكٌ وَإِنْ أَنْكَرَ مَعْرِفَةَ شُبْهِ الْعَمْدِ فَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا أَسْلَفْنَاهُ.

التعليق: ما موجبات القتل شبه العمد؟

مُوجِبُ الْقَتْلِ شِبْهُ الْعَمْدِ عَلَى الْقَوْلَيْنِ: يَعْنِي قَوْلَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَوْلَهُمَا الْإِثْمُ لِأَنَّهُ قَتْلٌ وَهُوَ قَاصِدٌ فِي الضَّرْبِ، وَالْكَفَّارَةُ لِشَبْهِهِ بِالْخَطَا، وَالِدِّيَّةُ مُعْلَظَةٌ عَلَى الْعَاقِلَةِ. وَدَلِيلُ ذَلِكَ: 1- أَنَّ كُلَّ دِيَّةٍ وَجَبَتْ بِالْقَتْلِ ابْتِدَاءً لَا بِمَعْنَى يَحْدُثُ مِنْ بَعْدِ فَهِيَ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ لَا بِمَعْنَى يَحْدُثُ مِنْ بَعْدِ عَمَّا تَصَالَحُوا فِيهِ عَلَى الدِّيَّةِ وَعَنْ قَتْلِ الْوَالِدِ وَلَدَهُ عَمْدًا وَعَنْ إِقْرَارِ الْقَاتِلِ بِالْقَتْلِ خَطًا وَقَدْ كَانَ قَتْلُهُ عَمْدًا فَإِنَّ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ تَجِبُ الدِّيَّةُ عَلَى الْقَاتِلِ فِي مَالِهِ. 2- وما روى أن عمر -رضي الله عنه- أَنَّهُ قَضَى بِالدِّيَّةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ، وَالْمَرْوِيُّ عَنْهُ كَالْمَرْوِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأَنَّهُ مِمَّا لَا يُعْرَفُ بِالرَّأْيِ.

7-القتل الخطأ وموجبه

الهداية: قَالَ (وَالْخَطَا عَلَى نَوْعَيْنِ: خَطَاً فِي الْقَصْدِ، وَهُوَ أَنْ يَرْمِيَ شَخْصًا يَظُنُّهُ صَيِّدًا، فَإِذَا هُوَ آدَمِيٌّ، أَوْ يَظُنُّهُ حَرْبِيًّا فَإِذَا هُوَ مُسْلِمٌ وَخَطَاً فِي الْفِعْلِ، وَهُوَ أَنْ يَرْمِيَ غَرَضًا فَيُصِيبُ آدَمِيًّا، وَمُوجِبُ ذَلِكَ الْكَفَّارَةُ، وَالِدِّيَّةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} [النساء: 92] الْآيَةِ، وَهِيَ عَلَى عَاقِلَتِهِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ، قَالَ (وَالْخَطَا عَلَى

نَوَعَيْنِ: خَطَأً فِي الْقَصْدِ، وَهُوَ أَنْ يَرْمِيَ شَخْصًا يَظُنُّهُ صَيْدًا، فَإِذَا هُوَ أَدَمِيٌّ، أَوْ يَظُنُّهُ حَرَبِيًّا فَإِذَا هُوَ مُسْلِمٌ وَخَطَأٌ فِي الْفِعْلِ، وَهُوَ أَنْ يَرْمِيَ غَرَضًا فَيُصِيبُ أَدَمِيًّا، وَمُوجِبُ ذَلِكَ الْكُفَّارَةُ، وَالذِّيَّةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسْلِمَةً إِلَى أَهْلِهِ} [النساء: 92] الْآيَةُ، وَهِيَ عَلَى عَاقِلَتِهِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ، لِمَا بَيَّنَّاهُ (وَلَا إِثْمَ فِيهِ) يَعْنِي فِي الْوَجْهَيْنِ قَالُوا: الْمُرَادُ إِثْمُ الْقَتْلِ، فَأَمَّا فِي نَفْسِهِ فَلَا يَغْرَى عَنْ الْإِثْمِ مِنْ حَيْثُ تَرَكَ الْعَزِيمَةَ وَالْمُبَالَغَةَ فِي التَّنَبُّتِ فِي حَالِ الرَّمِيِّ، إِذْ شَرَعُ الْكُفَّارَةُ يُؤْذِنُ بِاعْتِبَارِ هَذَا الْمَعْنَى (وَيُحَرِّمُ عَنْ الْمِيرَاثِ) ؛ لِأَنَّ فِيهِ إِثْمًا فَيَصِحُّ تَعْلِيْقُ الْحَرَمَانِ بِهِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا تَعَمَّدَ الضَّرْبَ مَوْضِعًا مِنْ جَسَدِهِ فَأَخْطَأَ فَأَصَابَ مَوْضِعًا آخَرَ فَمَاتَ حَيْثُ يَجِبُ الْقِصَاصُ؛ لِأَنَّ الْقَتْلَ قَدْ وَجَدَ بِالْقَصْدِ إِلَى بَعْضِ بَدَنِهِ، وَجَمِيعُ الْبَدَنِ كَالْمَحَلِّ الْوَاحِدِ

التعليق:

ما المقصود بالقتل الخطأ؟، وما أنواعه؟ وهل يأنم القاتل خطأ؟، وما موجهه؟.

المقصود بالقتل الخطأ: هو أن يرمي شخسا يظنه صيدا، أو يرمي غرضا فيصيب آدمياً.

أنواع القتل الخطأ: الخطأ عَلَى نَوَعَيْنِ: خطأ في القصد: وهو أن يرمي شخصا يظنه صيدا، وخطأ في الفعل: وهو أن يرمي غرضا فيصيب آدمياً .

لا يَأْتُمُ الْقَاتِلُ خَطَا فِي النُّوعَيْنِ، لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « إِنْ اللَّهَ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَا، وَالنَّسِيَانِ، وَمَا اسْتَكْرَهَا عَلَيْهِ»¹⁹⁴

موجب القتل الخطأ: الكفارة والدية على العاقلة مخففة في ثلاث سنين، وَيُحْرَمُ عَنِ الْمِيرَاثِ لِأَنَّ فِيهِ إِثْمًا، بِدَلِيلِ وَجُوبِ الْكَفَّارَةِ، وَالْحَرَمَانِ يَجِبُ بِأَنْوَاعِ الْقَتْلِ فِيمَا هُوَ جَنَائِيَّةٌ، قِيلَ عَلَى الْمَوْرَثِ تَضَمَّنَتْ تَهْمَةً الْإِسْتِعْجَالِ عَلَى الْمِيرَاثِ، وَهَذَا كَذَلِكَ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ قَصَدَهُ، إِلَّا أَنَّهُ أَظْهَرَ الْخَطَا مِنْ نَفْسِهِ.

8-حكم القتل الذي جرى مجرى الخطأ وموجبه

الهداية: قَالَ (وَمَا أُجْرِي مَجْرَى الْخَطَا مِثْلُ النَّائِمِ يَنْقَلِبُ عَلَى رَجُلٍ فَيَقْتُلُهُ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْخَطَا فِي الشَّرْعِ، التعليق:

المقصود بالقتل الذي جرى مجرى الخطأ، وحكمه.

المقصود بالقتل الذي جرى مجرى الخطأ، هو أنه لم يقصد الفعل أو الشخص لكنه انقلب عليه فقتله.

وحكمه: حكم القتل الخطأ من وجوب الكفارة والدية على العاقلة مخففة في ثلاث سنين.

8-حكم القتل بسبب، وموجبه

¹⁹⁴(أخرجه ابن ماجه في سننه 659/1 رقم 2043.

الهداية: وَأَمَّا الْقَتْلُ بِسَبَبِ كَحَافِرِ الْبُئْرِ وَوَاضِعِ الْحَجَرِ فِي غَيْرِ مُلْكِهِ، وَمُوجِبُهُ إِذَا تَلَفَ فِيهِ آدَمِيُّ الدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ ؛ لِأَنَّهُ سَبَبُ التَّلَفِ وَهُوَ مُتَعَدٌّ فِيهِ فَأُنْزِلَ مَوْقِعًا دَافِعًا فَوَجَبَتْ الدِّيَةُ (وَلَا كَفَّارَةٌ فِيهِ وَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حِرْمَانُ الْمِيرَاثِ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُلْحَقُ بِالْخَطَا فِي أَحْكَامِهِ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ أَنْزَلَهُ قَاتِلًا. وَلَنَا أَنَّ الْقَتْلَ مَعْدُومٌ مِنْهُ حَقِيقَةً فَأُلْحِقَ بِهِ فِي حَقِّ الضَّمَانِ فَبَقِيَ فِي حَقِّ غَيْرِهِ عَلَى الْأَصْلِ، وَهُوَ إِنْ كَانَ يَأْتُمُّ بِالْحَفْرِ فِي غَيْرِ مُلْكِهِ لَا يَأْتُمُّ بِالْمَوْتِ عَلَى مَا قَالُوا، وَهَذِهِ كَفَّارَةُ ذَنْبِ الْقَتْلِ وَكَذَا الْحِرْمَانُ بِسَبَبِهِ (وَمَا يَكُونُ شِبْهَ عَمْدٍ فِي النَّفْسِ فَهُوَ عَمْدٌ فِيمَا سِوَاهَا) ؛ لِأَنَّ إِتْلَافَ النَّفْسِ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَلَةِ، وَمَا دُونَهَا لَا يَخْتَصُّ إِتْلَافُهُ بِأَلَةٍ دُونَ أَلَةٍ.

التعليق:

ما المقصود بالقتل بسبب؟، وما موجب؟ ، وهل تجب به الكفارة والحرمان من الميراث؟. مستدلا لما تذكر.

المقصود بالقتل بسبب: أن يتسبب إنسان بحفر بئر أو وضع حجر في غير ملكه فيقتل شخصا.

موجب القتل بسبب: الدية على العاقلة، ؛ لِأَنَّهُ سَبَبُ التَّلَفِ وَهُوَ مُتَعَدٌّ فِيهِ فَأُنْزِلَ مَوْقِعًا دَافِعًا فَوَجَبَتْ الدِّيَةُ.

واختلف الفقهاء في وجوب الكفارة على القتل بسبب على قولين:

القول الأول: ذهب الحنفية إلى أنه لا تجب بالقتل بسبب الكفارة أو الحرمان من الميراث.

القول الثاني: ذهب الشافعية إلى أن القتل بسبب يلحق بالقتل الخطأ في أحكامه، ومنها وجوب الكفارة والحرمان من الميراث، لِأَنَّ الشَّرْعَ أَنْزَلَهُ قَاتِلًا فيضمن.

واستدل الحنفية على أن القتل بسبب لا يوجب كفارة أو الحرمان من الميراث، لأنَّ الْكَفَّارَةَ تَجِبُ بِالْقَتْلِ وَهُوَ مَعْدُومٌ مِنْهُ حَقِيقَةً لِعَدَمِ اتِّصَالِ فِعْلِهِ بِهِ، وَإِنَّمَا أُلْحِقَ بِهِ فِي حَقِّ الضَّمَانِ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ صِيَانَةً لِلدِّمَاءِ عَنِ الْهَدْرِ فَيَبْقَى فِي حَقِّ غَيْرِهِ عَلَى الْأَصْلِ. فَإِنْ قِيلَ: الْحَافِرُ فِي غَيْرِ مَلِكِهِ يَأْتُمُّ وَمَا فِيهِ إِنْ تَمَّ مِنَ الْقَتْلِ يَصِحُّ تَعْلِيْقُ الْحَرَمَانِ بِهِ كَمَا ذَكَرْتُمْ فِي الْخَطَأِ.

8- مَا يُوجِبُ الْقِصَاصَ وَمَا لَا يُوجِبُهُ

الهداية: قَالَ (الْقِصَاصُ وَاجِبٌ بِقَتْلِ كُلِّ مَحْقُونِ الدِّمِّ عَلَى التَّأْيِيدِ إِذَا قَتَلَ عَمْدًا) أَمَّا الْعَمْدِيَّةُ فَلِمَا بَيَّنَّاهُ، وَأَمَّا حَقُّ الدِّمِّ عَلَى التَّأْيِيدِ فَلِنَتَنَفَّى شُبْهَةَ الْإِبَاحَةِ وَتَتَحَقَّقَ الْمُسَاوَاةُ

التعليق:

لما فرغ من بيان أقسام القتل وكان من جملتها العمد: وهو قد يوجب القصاص، وقد لا يوجبه، احتاج إلى التفصيل ذلك في باب على حدة.

مَا يُوجِبُ الْقِصَاصَ وَمَا لَا يُوجِبُهُ: فالْقِصَاصُ وَاجِبٌ بِشُرُوطٍ وَمِنْهَا: أَنْ يَكُونَ الْمَقْتُولُ مَحْقُونِ الدِّمِّ عَلَى التَّأْيِيدِ ، وَأَنْ يَكُونَ الْقَتْلُ عَمْدًا. هَذِهِ ضَابِطَةٌ كُلِّيَّةٌ لِمَعْرِفَةِ مَنْ يَجِبُ لَهُ الْقِصَاصُ، وَحَقُّ الدِّمِّ مَنَعُهُ أَنْ يَسْفِكَ.

9- حكم قتل الحر بالعبد

قَالَ (وَيُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْحُرُّ بِالْعَبْدِ) لِلْعُمُومَاتِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: لَا يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} [البقرة: 178] وَمِنْ ضَرُورَةِ هَذِهِ الْمُقَابَلَةِ أَنْ لَا يُقْتَلَ حُرٌّ بِعَبْدٍ، وَلِأَنَّ مَبْنَى الْقِصَاصِ عَلَى الْمُسَاوَاةِ

وَهِيَ مُنْتَفِيَةٌ بَيْنَ الْمَالِكِ وَالْمَمْلُوكِ وَلِهَذَا لَا يُقْطَعُ طَرَفُ الْحُرِّ بِطَرَفِهِ، بِخِلَافِ الْعَبْدِ بِالْعَبْدِ؛ لِأَنَّهُمَا يَسْتَوِيَانِ، وَبِخِلَافِ الْعَبْدِ حَيْثُ يُقْتَلُ بِالْحُرِّ؛ لِأَنَّهُ تَفَاوُتٌ إِلَى نَقْصَانٍ
وَلَنَا أَنَّ الْقِصَاصَ يَعْتَمِدُ الْمُسَاوَاةَ فِي الْعِصْمَةِ وَهِيَ بِالذِّينِ وَبِالدَّارِ وَيَسْتَوِيَانِ فِيهِمَا، وَجَرِيَانُ الْقِصَاصِ بَيْنَ الْعَبْدَيْنِ يُؤْذَنُ بِإِنْتِفَاءِ شُبْهَةِ الْإِبَاحَةِ، وَالنَّصُّ تَخْصِيصٌ بِالذِّكْرِ فَلَا يَنْفِي مَا عَدَاهُ
التعليق:

هل يجب قتل الحر بالعبد؟

اختلف الفقهاء في وجوب قتل الحر بالعبد على قولين:

القول الأول: ذهب الحنفية إلى أنه يقتل الحر بالعبد، واستدلوا على ذلك بالعمومات مِثْلَ قَوْلِهِ تَعَالَى {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ} [البقرة: 178] وَقَوْلُهُ {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا} [الإسراء: 33] وَقَوْلُهُ {وَكُنْتُمْ عَلَيْكُمْ فِيهَا أَنْ أَنْفُسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة: 45] وَقَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «الْعَمْدُ قَوْدٌ»¹⁹⁵
القول الثاني: ذهب الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - إلى أنه لا يقتل الحر بالعبد لِقَوْلِهِ تَعَالَى {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} [البقرة: 178] وَمِنْ ضَرُورَةِ هَذِهِ الْمُقَابَلَةِ أَنْ لَا يُقْتَلَ حُرٌّ بِعَبْدٍ، وَلِأَنَّ مَبْنَى الْقِصَاصِ عَلَى الْمُسَاوَاةِ وَهِيَ مُنْتَفِيَةٌ بَيْنَ الْمَالِكِ وَالْمَمْلُوكِ وَلِهَذَا لَا يُقْطَعُ طَرَفُ الْحُرِّ بِطَرَفِهِ، بِخِلَافِ الْعَبْدِ بِالْعَبْدِ؛ لِأَنَّهُمَا يَسْتَوِيَانِ، وَبِخِلَافِ الْعَبْدِ حَيْثُ يُقْتَلُ بِالْحُرِّ؛ لِأَنَّهُ تَفَاوُتٌ إِلَى نَقْصَانٍ.

¹⁹⁵(سبق تخريجه).

واستدل الحنفية على ما ذهبوا إليه بأنه يقتل الحر بالعبد بالعصمة بالدين أو بالدار ، والعبد والحر يستويان فيهما فيجري القصاص بينهما.

10- حكم قتل المسلم الذمي

الهداية: قَالَ (وَالْمُسْلِمُ بِالذِّمِّيِّ) خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ. لَهُ قَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ» (196) وَلِأَنَّهُ لَا مُسَاوَاةَ بَيْنَهُمَا وَقَتَ الْجَنَازَةِ، وَكَذَا الْكُفْرُ مُبِيحٌ فَيُورِثُ الشُّبُهَةَ، وَلَنَا مَا رَوَى «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَتَلَ مُسْلِمًا بِذِمِّيٍّ» (197) وَلِأَنَّ الْمُسَاوَاةَ فِي الْعِصْمَةِ ثَابِتَةٌ نَظَرًا إِلَى التَّكْلِيفِ وَالذَّارِ وَالْمُبِيحِ كُفْرُ الْمُحَارِبِ دُونَ الْمُسَالِمِ، وَالْقَتْلُ بِمِثْلِهِ يُؤْذِنُ بِانْتِفَاءِ الشُّبُهَةِ، وَالْمُرَادُ بِمَا رَوَى الْحَرَبِيُّ لِسِيَاقِهِ «وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ» وَالْعَطْفُ لِلْمُعَايَرَةِ

التعليق:

هل يقتل المسلم بقتل الذمي؟

اختلف العلماء - رحمهم الله - في ثبوت اقتصاص المسلم بالذمي، إلى قولين: القول الأول: ذهب عامة العلماء إلى عدم اقتصاص المسلم من الذمي.

القول الثاني: ذهب أبو حنيفة وأصحابه - رضي الله عنهم - إلى ثبوته وهو مذهب النخعي والشعبي.

¹⁹⁶() أخرجه الترمذي في سننه 77/3 رقم 1412، وقال: "حديث حسن صحيح" ..

¹⁹⁷() قال ابن حجر في: الدراية في تخريج أحاديث الهداية 262/2 رقم 1008: "حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلماً بذي الدار قطني من طريق ربيعة عن عبد الرحمن البيلماني عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل مسلماً بمعاهد وقال أنا أكرم من وفي بدمته؟".

اسْتَدَلَ الْأَوَّلُونَ بِمَا رَوَى أَبُو جُحَيْفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: هَلْ عِنْدَكُمْ كِتَابٌ؟ قَالَ: " لَا، إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ، أَوْ فَهْمٌ أُعْطِيَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ، أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ. قَالَ: قُلْتُ: فَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ، وَفَكَانُكَ الْأَسِيرَ، وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ «(198). وَبِأَنَّ الْقِصَاصَ يَعْتَمِدُ الْمُسَاوَاةَ فِي وَقْتِ الْجَنَائَةِ وَلَا مُسَاوَاةَ بَيْنَهُمَا فِيهِ. وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِوَقْتِ الْجَنَائَةِ لِأَنَّ الْقَاتِلَ إِذَا كَانَ ذِمِّيًّا وَقَتَ الْقَتْلِ ثُمَّ أَسْلَمَ فَإِنَّهُ يُقْتَصُّ مِنْهُ بِالْإِجْمَاعِ، وَبِأَنَّ الْكُفْرَ مُبِيحٌ لِدَمِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ} [البقرة: 193] أَيْ فِتْنَةُ الْكُفْرِ فَيُورَثُ شُبُهَةٌ عَدَمِ الْمُسَاوَاةِ.

واستدل الحنفية إلى ثبوت القصاص من المسلم لو قتل ذمياً بما روى مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ رَجَمَهُمَا اللَّهُ «أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: أَنَا أَحَقُّ مَنْ وَفَى بِذِمَّتِهِ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فُقِّلَ» (199)، وَفِي دَلَالَتِهِ عَلَى الْمَطْلُوبِ جَلَاءٌ لَا يُمَارَى. وَرَدَّ بِأَنَّ مَدَارَهُ عَلَى ابْنِ السَّلْمَانِيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ. قَالَ صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَافِظُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - ابْنُ السَّلْمَانِيِّ حَدِيثُهُ مُنْكَرٌ، رُوِيَ عَنْهُ رَبِيعَةُ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَتَلَ مُسْلِمًا بِمُعَاهِدٍ» (200) وَهُوَ مُرْسَلٌ مُنْكَرٌ. وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: ابْنُ السَّلْمَانِيِّ لَا يَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ إِذَا وَصَلَ فَكَيْفَ إِذَا أُرْسِلَ. وَالْجَوَابُ أَنَّ الطَّعْنَ بِالْإِرْسَالِ وَالطَّعْنَ الْمُبْهِمُ مِنْ أَيْمَةِ الْحَدِيثِ غَيْرُ مَقْبُولٍ، وَقَدْ عُرِفَ فِي الْأُصُولِ .

¹⁹⁸() أخرجه البخاري في صحيحه 33/1 رقم 111.

¹⁹⁹() أخرجه مسند الإمام أبي حنيفة رواية أبي نعيم ص 104، ورفع الدراقطني في سننه 157/4 رقم 3260 بلفظ: "أن النبي صلى الله عليه وسلم «أقاد مسلماً قتل يهودياً». وقال الرمادي: أقاد مسلماً بذي، وقال: «أنا أحق من وفى بذيمة».

²⁰⁰() أخرجه الدراقطني في سننه 156/4 رقم 3259.

وأما المعقول فلأنَّ الْقِصَاصَ يَعْتَمِدُ الْمُسَاوَاةَ فِي الْعِصْمَةِ وَهِيَ ثَابِتَةٌ نَظَرًا إِلَى التَّكْلِيفِ عِنْدَهُ أَوْ الدَّارِ عِنْدَنَا فَيُثَبِّتُ.
والمختار أنه يقتل المسلم بالذمي

11-حكم قتل المسلم بالمستأمن والذمي بالمستأمن والمستأمن بالمستأمن:

الهداية: قَالَ (وَلَا يُقْتَلُ بِالْمُسْتَأْمَنِ) ⁽²⁰¹⁾؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَحْقُونِ الدِّمِّ عَلَى التَّأْيِيدِ، وَكَذَلِكَ كُفِّرُهُ بَاعِثٌ عَلَى الْحِرَابِ؛ لِأَنَّهُ عَلَى قَصْدِ الرُّجُوعِ. (وَلَا يُقْتَلُ الذِّمِّيُّ بِالْمُسْتَأْمَنِ) لِمَا بَيَّنَّا، (وَيُقْتَلُ الْمُسْتَأْمَنُ بِالْمُسْتَأْمَنِ) قِيَاسًا لِلْمُسَاوَاةِ، وَلَا يُقْتَلُ اسْتِحْسَانًا لِقِيَامِ الْمُبِيحِ
التعليق:

لو ان مسلما قتل مستأمنا فهل يجب القصاص من المسلم؟.

للحنفية في قتل المسلم بالمستأمن قولان:

القول الأول: ذهب الحنفية في ظاهر الرواية إلى أنه لا قصاص على مسلم أو ذمي بقتل مستأمن ، لأنهم اشترطوا في القصاص أن يكون المقتول في حق القاتل محقون الدم على التأييد ، والمستأمن عصمته مؤقتة ، لأنه مصون الدم في حال

²⁰¹(المستأمن، هو من دخل بلادنا دخولا قانونيا، من خلال تأشيرة الدخول من خلال الأجهزة المختصة.

أمانه فقط ، ولأنه من دار أهل الحرب حكما ؛ لقصد الانتقال إليها ، فلا يمكن المساواة بينه وبين من هو من أهل دارنا في العصمة ، والقصاص يعتمد المساواة ، ولكن عليه دية (202).

القول الثاني: وروي عن أبي يوسف أنه يقتل المسلم بالمستأمن (203)، واستدل بقوله تعالى : {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ } سورة التوبة / 6 .

والمختار أنه بدخول المستأمن إلى بلادنا تنطبق عليه احكام المواطنين، ومن ثم يقتص من قاتله، لأننا مأمورون بعدم الغدر

12- هل يقتل الذمي بالمستأمن؟

اختلف الفقهاء في قتل الذمي بالمستأمن على قولين:

القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه إذا ارتكب الذمي القتل العمد وجب عليه القصاص ، إذا كان القتيل مسلماً أو من أهل الذمة بلا خلاف ، وكذلك إن كان القتيل مستأماً.

القول الثاني: ذهب ابو حنيفة إلى أنه لا يُقتل الذمي بالمستأمن لأن المستأمن ليس محقون الدم على التأبيد، فكان في حقن دمه شبهة تسقط القصاص ؛ ولأن الذمي محرز نفسه بدارنا على التأبيد فلا تتحقق المساواة بينه وبين المستأمن.(204)

²⁰²() بدائع الصنائع 7 / 236 ، وحاشية ابن عابدين 5 / 343 ، 3 / 249 ، وفتح القدير 4 / 357 .

²⁰³() بدائع الصنائع 7 / 231 .

لو أن مستأمنًا قتل مستأمنًا فهل يقتل منه؟.

يُقْتَلُ الْمُسْتَأْمَنُ بِالْمُسْتَأْمَنِ قِيَاسًا لِلْمُسَاوَاةِ، وَلَا يُقْتَلُ اسْتِحْسَانًا لِقِيَامِ الْمُبِيحِ، وَهُوَ أَنَّهُ غَيْرُ مَحْقُونِ الدَّمِّ عَلَى التَّأْيِيدِ.

13-حكم قتل الرجل بالمرأة والكبير بالصغير والصحيح بالأعمى.

الهداية: (وَيُقْتَلُ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ، وَالْكَبِيرُ بِالصَّغِيرِ، وَالصَّحِيحُ بِالْأَعْمَى وَالزَّمِنُ وَبِنَاقِصِ الْأَطْرَافِ وَبِالْمَجْنُونِ) لِلْعُمُومَاتِ، وَلِأَنَّ فِي اعْتِبَارِ التَّفَاوُتِ فِيمَا وَرَاءَ الْعِصْمَةِ امْتِنَاعَ الْقِصَاصِ وَظُهُورَ التَّقَاتِلِ وَالتَّفَانِي.

التعليق:

ويقتص من الرجل بقتله للمرأة، والكبير بالصغير والصحيح بالأعمى والزمن وبناقص الأطراف وبالمجنون، للعُمومات، وَلِأَنَّ فِي اعْتِبَارِ التَّفَاوُتِ فِيمَا وَرَاءَ الْعِصْمَةِ امْتِنَاعَ الْقِصَاصِ وَظُهُورَ التَّقَاتِلِ وَالتَّفَانِي.

²⁰⁴(العناية شرح الهداية 220/10).

14- قتل الرجل بابنه

الهداية: قَالَ (وَلَا يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِابْنِهِ) لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ» وَهُوَ بِإِطْلَاقِهِ حُجَّةٌ عَلَى مَالِكٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي قَوْلِهِ يُقَادُ إِذَا ذَبَحَهُ ذَبْحًا، وَلِأَنَّهُ سَبَبٌ لِإِحْيَائِهِ، فَمِنْ الْمُحَالِ أَنْ يُسْتَحَقَّ لَهُ إِفْنَاؤُهُ وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ لَهُ قَتْلُهُ، وَإِنْ وَجَدَهُ فِي صَفِّ الْأَعْدَاءِ مُقَاتِلًا أَوْ زَانِيًا وَهُوَ مُحَصَّنٌ، وَالْقِصَاصُ يَسْتَحِقُّهُ الْمَقْتُولُ ثُمَّ يَخْلُفُهُ وَارِثُهُ، وَالْجَدُّ مِنْ قَبْلِ الرَّجَالِ أَوْ النِّسَاءِ، وَإِنْ عَلَا فِي هَذَا بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ، وَكَذَا الْوَالِدَةُ وَالْجَدَّةُ مِنْ قَبْلِ الْأَبِ أَوْ الْأُمِّ قَرُبَتْ أَوْ بَعُدَتْ لِمَا بَيَّنَّا، وَيُقْتَلُ الْوَلَدُ بِالْوَالِدِ لِعَدَمِ الْمُسْقِطِ.

التعليق:

هل يقتل الرجل وإن علا بابنه؟ وهل يختلف الحكم بالنسبة لقتل الولد والده؟
لَا يُقْتَلُ الْإِنْسَانُ بِوَلَدِهِ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ»⁽²⁰⁵⁾ وَهُوَ مَعْلُومٌ بِكَوْنِهِ سَبَبًا لِإِحْيَائِهِ وَهُوَ وَصَفٌ مُعَلَّلٌ ظَهَرَ أَثَرُهُ فِي جِنْسِ الْحُكْمِ الْمُعَلَّلِ بِهِ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُقْتَلَ وَالِدُهُ وَإِنْ عَلَا وَقَالَ مَالِكٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : إِنْ ذَبَحَهُ يُقَادُ بِهِ لِإِنْتِفَاءِ شُبْهَةِ الْخَطَا مِنْ كُلِّ وَجْهِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا رَمَاهُ بِسَيْفٍ أَوْ سَكِّينٍ فَإِنَّ فِيهِ تَوْهْمَ التَّأْدِيبِ، لِأَنَّ شَفَقَةَ الْأَبُوَّةِ تَمْنَعُهُ عَنْ ذَلِكَ فَيَتِمَّكَنُ فِيهِ نَوْعُ شُبْهَةٍ.
ويختلف الحكم بالنسبة لقتل الولد والده فيقتص منه لعدم وجود المسقط.

⁽²⁰⁵⁾ (أ) أخرجه الدراقطني في سننه 168/4 رقم 3277.

15- وَرِثَ قِصَاصًا عَلَى أَبِيهِ

الهداية: قَالَ (وَمَنْ وَرِثَ قِصَاصًا عَلَى أَبِيهِ سَقَطَ لِحُرْمَةِ الْأُبُوَّةِ
قَالَ (وَلَا يُسْتَوْفَى الْقِصَاصُ إِلَّا بِالسَّيْفِ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُفْعَلُ بِهِ مِثْلُ مَا فَعَلَ إِنْ كَانَ فِعْلًا مَشْرُوعًا، فَإِنْ مَاتَ وَإِلَّا تَحَزَّ
رَقَبَتُهُ؛ لِأَنَّ مَبْنَى الْقِصَاصِ عَلَى الْمُسَاوَاةِ
وَلَنَا قَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «لَا قَوْدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ» وَالْمُرَادُ بِهِ السَّلَاحُ، وَلِأَنَّ فِيهِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ اسْتِيفَاءُ الزِّيَادَةِ لَوْ لَمْ
يَحْصُلِ الْمَقْصُودُ بِمِثْلِ مَا فَعَلَ فَيَحْزُرُ فَيَجِبُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ كَمَا فِي كَسْرِ الْعَظْمِ
التعليق:

حكم مَنْ وَرِثَ قِصَاصًا عَلَى أَبِيهِ، مِثْلُ أَنْ يَقْتُلَ الرَّجُلُ أُمَّ ابْنِهِ مِثْلًا، سَقَطَ الْقِصَاصُ لِحُرْمَةِ الْأُبُوَّةِ.
ما أداة استيفاء القصاص؟ ، أي هل يستوفى القصاص بغير السيف؟
ذهب الحنفية إلى أنه وَجِدَ الْقَتْلُ الْمُوجِبُ لِلْقَوْدِ لَا يُسْتَوْفَى إِلَّا بِالسَّيْفِ.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يُنْظَرُ إِنْ كَانَ قَتْلٌ بِفِعْلِ مَشْرُوعٍ مِثْلُ أَنْ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ فَمَاتَ مِنْهُ فُِعْلٌ بِمِثْلِ ذَلِكَ وَيُمَهَّلُ مِثْلُ
تِلْكَ الْمُدَّةِ فَإِنْ مَاتَ وَإِلَّا تَحَزَّ رَقَبَتُهُ، وَإِنْ كَانَ بَغَيْرِ مَشْرُوعٍ كَأَنْ سَقَاهُ الْخَمْرَ حَتَّى قَتَلَهُ أَوْ لَاطَ بِصَغِيرٍ فَقَتَلَهُ يُقْتَلُ بِالسَّيْفِ،
لِأَنَّ مَبْنَى الْقِصَاصِ الْمُسَاوَاةَ، لِأَنَّ فِيهِ مُسَاوَاةً فِي أَصْلِ الْوَصْفِ وَالْفِعْلِ الْمَقْصُودِ بِهِ

واستدل الحنفية على أن القصاص لا يستوفى إلا بالسيف من السنة: وهو قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَا قَوْدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ»⁽²⁰⁶⁾ وَهُوَ نَصٌّ عَلَى نَفْيِ اسْتِيفَاءِ الْقَوْدِ بغيرِهِ وَيَلْحَقُ بِهِ مَا كَانَ سِلَاحًا.

16- قُتِلَ وَلَهُ أَوْلِيَاءُ صَغَارٍ وَكِبَارٍ

الهداية: قَالَ (وَمَنْ قُتِلَ وَلَهُ أَوْلِيَاءُ صَغَارٍ وَكِبَارٍ فَلِلْكَبَارِ أَنْ يَقْتُلُوا الْقَاتِلَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ لَا يَسْ لَهُمْ ذَلِكَ حَتَّى يُدْرِكَ الصَّغَارُ) ؛ لِأَنَّ الْقِصَاصَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمْ وَلَا يُمَكِّنُ اسْتِيفَاءُ الْبَعْضِ لِعَدَمِ التَّجْزِي، وَفِي اسْتِيفَائِهِمُ الْكُلَّ إِبْطَالُ حَقِّ الصَّغَارِ فَيُؤَخَّرُ إِلَى إِدْرَاكِهِمْ كَمَا إِذَا كَانَ بَيْنَ الْكَبِيرَيْنِ وَأَحَدُهُمَا غَائِبٌ أَوْ كَانَ بَيْنَ الْمَوْلَيْنِ وَلَهُ أَنَّهُ حَقٌّ لَا يَتَجَزَّأُ لِثُبُوتِهِ بِسَبَبٍ لَا يَتَجَزَّأُ وَهُوَ الْقَرَابَةُ، وَاحْتِمَالُ الْعَفْوِ مِنَ الصَّغِيرِ مُنْقَطِعٌ فَيَثْبُتُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَمَلًا كَمَا فِي وَلَايَةِ الْإِنْكَاحِ، بِخِلَافِ الْكَبِيرَيْنِ؛ لِأَنَّ احْتِمَالَ الْعَفْوِ مِنَ الْغَائِبِ ثَابِتٌ وَمَسْأَلَةُ الْمَوْلَيْنِ مَمْنُوعَةٌ

التعليق:

حكم من قُتِلَ وَلَهُ أَوْلِيَاءُ صَغَارٍ وَكِبَارٍ، فهل يقتص الكبار أم ينتظر حتى يدرك الصغار؟

إِذَا كَانَ أَوْلِيَاءُ الْقَتِيلِ صِغَارًا وَكِبَارًا، فإِذَا أَنْ يَكُونَ فِيهِمُ الْأَبُ أَوْ لَا، فَإِنْ كَانَ فِيهِمُ الْأَبُ فَلَهُمُ الْإِسْتِيفَاءُ عِنْدَ عُلَمَائِنَا - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - بِالِاتِّفَاقِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْأَبُ فِيهِمْ فَقَدْ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ عَلَى قَوْلَيْنِ: الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: لِأَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنْ لَهُمُ الْإِسْتِيفَاءُ.

²⁰⁶(أ) أخرجه ابن ماجه في سننه 889/2 رقم 2667.

القول الثاني: ذهب الصحابان إلى أنه ليس لهم ذلك حتى يُدرك الصغار ووجههما ظاهر على ما ذكر.
ووجه أبي حنيفة - رحمه الله - مبني على ثبوت التفرقة بين الصغار والغائب من حيث احتمال العفو في الحال وعدمه،
فإنه في الغائب موهوم فالاستيفاء يقع مع الشبهة وهو لا يجوز، وفي الصغير مأیوس حال الاستيفاء فانتفى الشبهة، وإذا
انتفى الشبهة وهو حق لا يتجزى لثبوته بسبب لا يتجزأ وهو القرابة يثبت لكل واحد كمالاً كالولاية في الإنكاح.

17-ضرب رجل بمر -فأس- فقتله

الهداية : قال (ومن ضرب رجلاً بمر فقتله، فإن أصابه بالحديد قتل به وإن أصابه بالعود فعليه الدية) قال - رضي الله
عنه -: وهذا إذا أصابه بحد الحديد لوجود الجرح فكمّل السبب، وإن أصابه بظهر الحديد فعندهما يجب، وهو رواية عن
أبي حنيفة اعتباراً منه للآلة، وهو الحديد

وعنه إنما يجب إذا جرح، وهو الأصح على ما نبينه إن شاء الله تعالى، وعلى هذا الضرب بسنجات الميزان؛ وأما إذا
ضربه بالعود فإنما تجب الدية لوجود قتل النفس المعصومة وامتناع القصاص حتى لا يهدر الدم، ثم قيل: هو بمنزلة
العصا الكبيرة فيكون قتلاً بالمتنقل، وفيه خلاف أبي حنيفة على ما نبين، وقيل هو بمنزلة السوط، وفيه خلاف الشافعي
وهي مسألة الموالاة

له أن الموالاة في ضربات إلى أن مات دليل العمدية فيتحقق الموجب

وَلَنَا مَا رَوَيْنَا «أَلَا إِنَّ قَتِيلَ خَطَا الْعَمْدِ» وَيُرْوَى " شِبْهِ الْعَمْدِ " الْحَدِيثَ وَلِأَنَّ فِيهِ شُبْهَةً عَدَمَ الْعَمْدِيَّةِ؛ لِأَنَّ الْمُوَالَاةَ قَدْ تُسْتَعْمَلُ لِلتَّأْدِيبِ أَوْ لَعَلَّهُ اعْتَرَاهُ الْقَصْدُ فِي خِلَالِ الضَّرَبَاتِ فَيَعْرِى أَوَّلُ الْفِعْلِ عَنْهُ وَعَسَاهُ أَصَابَ الْمَقْتُلَ، وَالشُّبْهَةُ دَارِئَةٌ لِلْقَوْدِ فَوَجَبَ الدِّيَّةُ

التعليق:

(ومن ضرب رجلا بمر²⁰⁷) فقتله فإن أصابه بالحديد الذي في أحد طرفي المر، قتل به بلا خلاف لوجود القتل على وجه الكمال.

وإن أصابه بالعود الذي هو أحد طرفي المر فعليه الدية.

²⁰⁷(مَرَّ: بفتح الميم وتشديد الراء: هو الذي يعمل به في الطين. ينظر: المغرب للمطري ص 439.

18- مَنْ غَرَّقَ صَبِيًّا أَوْ بَالِغًا فِي الْبَحْرِ

الهداية: قَالَ (وَمَنْ غَرَّقَ صَبِيًّا أَوْ بَالِغًا فِي الْبَحْرِ فَلَا قِصَاصَ) عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَالَ: يُقْتَصُّ مِنْهُ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، غَيْرَ أَنَّ عِنْدَهُمَا يُسْتَوْفَى حَزًّا وَعِنْدَهُ يُغَرَّقُ كَمَا بَيَّنَّاهُ مِنْ قَبْلُ

لَهُمْ قَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «مَنْ غَرَّقَ غَرَقْنَاهُ» وَلِأَنَّ الْأَلَةَ قَاتِلَةٌ فَاسْتِعْمَالُهَا أَمَارَةُ الْعَمْدِيَّةِ، وَلَا مِرَاءَ فِي الْعِصْمَةِ وَلَهُ قَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «أَلَا إِنَّ قَتِيلَ خَطَا الْعَمْدِ قَتِيلُ السَّوْطِ وَالْعَصَا» وَفِيهِ «وَفِي كُلِّ خَطَا أَرُشٌ» ؛ لِأَنَّ الْأَلَةَ غَيْرُ مُعَدَّةٍ لِلْقَتْلِ، وَلَا مُسْتَعْمَلَةٌ فِيهِ لِتَعَذُّرِ اسْتِعْمَالِهِ فَمَكَّنَتْ شُبُهَةً عَدَمِ الْعَمْدِيَّةِ وَلِأَنَّ الْقِصَاصَ يُنْبِئُ عَنِ الْمُمَائِلَةِ، وَمِنْهُ يُقَالُ: اقْتَصَّ أَثَرَهُ، وَمِنْهُ الْقُصَّةُ لِلْجَلَمِينَ، وَلَا تَمَائِلَ بَيْنَ الْجَرَحِ وَالْدَقِّ لِقُصُورِ الثَّانِي عَنْ تَخْرِيبِ الظَّاهِرِ، وَكَذَا لَا يَتِمَّائِلَانِ فِي حِكْمَةِ الزَّجْرِ؛ لِأَنَّ الْقَتْلَ بِالسَّلَاحِ غَالِبٌ وَبِالْمُتَقَلِّ نَادِرٌ، وَمَا رَوَاهُ غَيْرُ مَرْفُوعٍ أَوْ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى السِّيَاسَةِ، وَقَدْ أَوْمَتْ إِلَيْهِ إِضَافَتُهُ إِلَى نَفْسِهِ فِيهِ، وَإِذَا امْتَنَعَ الْقِصَاصُ وَجَبَتْ الدِّيَّةُ، وَهِيَ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ وَاخْتِلَافُ الرُّوَايَتَيْنِ فِي الْكَفَّارَةِ.

التعليق:

اختلف الفقهاء في من غرق صبيا أو بالغا هل يقتص منه؟. اختلف الفقهاء على قولين:

القول الأول: ذهب أبو حنيفة إلى أنه لا قصاص على من غرق صبيا أو بالغا في البحر

القول الثاني: وقال الشافعي: يقتص منه وقال صاحبان يستوفى حزا، واستدلوا على ذلك بالسنة والمعقول: فالسنة قَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «مَنْ غَرَّقَ غَرَقَانَهُ»⁽²⁰⁸⁾، وأما المعقول: فَلِأَنَّ الْآلَةَ قَاتِلَةٌ فَاسْتِعْمَالُهَا أَمَارَةٌ الْعَمْدِيَّةُ، وَلَا مِرَاءَ فِي الْعِصْمَةِ .

وَاسْتَدَلَّ الْإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ لِقَوْلِهِ بِالسَّيِّئَةِ وَالْمَعْقُولِ: أَمَّا السَّيِّئَةُ فَقَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «أَلَا وَإِنْ فِي قَتْلِ خَطَا الْعَمْدِ قَتِيلُ السُّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بَطُونِهَا أَوْ لَادِهَا»⁽²⁰⁹⁾ وَفِيهِ «وَفِي كُلِّ شَيْءٍ خَطَا أَرَشٌ»⁽²¹⁰⁾ ؛ وَأَمَّا الْمَعْقُولُ: فَلِأَنَّ الْآلَةَ غَيْرُ مُعَدَّةٍ لِلْقَتْلِ، وَلَا مُسْتَعْمَلَةٌ فِيهِ لِتَعَذُّرِ اسْتِعْمَالِهَا فَتَمَكَّنَتْ شُبُهَةٌ عَدَمِ الْعَمْدِيَّةِ وَلِأَنَّ الْقِصَاصَ يُنْبِئُ عَنِ الْمُمَاتِلَةِ، وَمِنْهُ يُقَالُ: اقْتَصَّ أَثَرَهُ، وَمِنْهُ الْقُصَّةُ لِلْجَلَمِيِّينَ⁽²¹¹⁾، وَلَا تَمَاتِلَ بَيْنَ الْجَرْحِ وَالْذَّقِّ لِقُصُورِ الثَّانِي عَنْ تَخْرِيبِ الظَّاهِرِ، وَكَذَا لَا يَتِمَاتِلَانِ فِي حِكْمَةِ الزَّجْرِ؛ لِأَنَّ الْقَتْلَ بِالسَّلَاحِ غَالِبٌ وَبِالْمُتَقَلِّ نَادِرٌ.

وَأَجَابَ عَنْ دَلِيلِ الشَّافِعِيِّ بِأَنَّهُ غَيْرُ مَرْفُوعٍ أَوْ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى السِّيَاسَةِ، وَقَدْ أُؤْمِتَ إِلَيْهِ إِضَافَتُهُ إِلَى نَفْسِهِ فِيهِ، وَإِذَا امْتَنَعَ الْقِصَاصُ وَجَبَتْ الدِّيَّةُ، وَهِيَ عَلَى الْعَاقِلَةِ.

²⁰⁸() قَالَ ابْنُ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيُّ فِي الدِّرَاسَةِ فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ الْهَدَايَةِ 266/2 رَقْم 1012: "حَدِيثٌ مِنْ غَرَقِ غَرَقَانِهِ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ بِهَذَا وَفِيهِ وَمَنْ حَرَّقَ حَرَقَانَهُ وَمَنْ عَرَضَ عَرْضَانَهُ وَفِي إِسْنَادِهِ مِنْ لَا يَعْرِفُ"

²⁰⁹() أَخْرَجَهُ الدَّارِقُطْنِيُّ فِي سَنَنِهِ 100/4 رَقْم 3168.

²¹⁰() أَخْرَجَهُ الدَّارِقُطْنِيُّ فِي سَنَنِهِ 1050/4 رَقْم 3176.

²¹¹() الْجَلْمُ : الَّذِي يُجْزَى بِهِ الشَّعْرُ وَالصُّوفُ، وَالْجَلْمَانِ شَفَرَتَاهُ، وَهَكَذَا يُقَالُ مُتَنَّى كَالْمِقْصَصِ وَالْمِقْصَصَيْنِ. وَالْجَلْمُ: مَصْدَرُ جَلَمَ الْجَزُورَ يَجْلِمُهَا جَلْمًا وَاجْتَلَمَهَا إِذَا أَخَذَ مَا عَلَى عِظَامِهَا مِنَ اللَّحْمِ. لِسَانُ الْعَرَبِ لِابْنِ مَنْظُورٍ 102/12.

19- جَرَحَ رَجُلًا عَمْدًا فَلَمْ يَزَلْ صَاحِبَ فِرَاشٍ حَتَّى مَاتَ

الهداية : قَالَ (وَمَنْ جَرَحَ رَجُلًا عَمْدًا فَلَمْ يَزَلْ صَاحِبَ فِرَاشٍ حَتَّى مَاتَ فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ) لَوْجُودِ السَّبَبِ وَعَدَمِ مَا يُبْطِلُ حُكْمَهُ فِي الظَّاهِرِ فَأُضِيفَ إِلَيْهِ.

التعليق:

مَنْ جَرَحَ رَجُلًا عَمْدًا فَلَمْ يَزَلْ صَاحِبَ فِرَاشٍ حَتَّى مَاتَ فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ، لَوْجُودِ السَّبَبِ يَعْنِي سَفْكَ دَمٍ مَحْقُونٍ عَلَى التَّأْيِيدِ عَمْدًا، وَعَدَمِ مَا يُبْطِلُ حُكْمَهُ يَعْنِي مِنْ عَفْوٍ أَوْ شُبْهَةٍ.

20- قَتَلَ مُسْلِمٌ مُسْلِمًا ظَنَّ أَنَّهُ مُشْرِكٌ أَثْنَاءَ التَّقَاءِ الصَّفِينِ

الهداية: قَالَ (وَإِذَا التَّقَى الصَّفَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ فَقَتَلَ مُسْلِمٌ مُسْلِمًا ظَنَّ أَنَّهُ مُشْرِكٌ فَلَا قَوْدَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ) ؛ لِأَنَّ هَذَا أَحَدُ نَوْعِي الْخَطَا عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ، وَالْخَطَا بِنَوْعِيهِ لَا يُوجِبُ الْقَوْدَ وَيُوجِبُ الْكَفَّارَةَ، وَكَذَا الدِّيَّةُ عَلَى مَا نَطَقَ بِهِ نَصُّ الْكِتَابِ «وَلَمَّا اخْتَلَفَتْ سُيُوفُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْيَمَانِ أَبِي حُدَيْفَةَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - بِالْدِّيَّةِ» قَالُوا:

إِنَّمَا تَحِبُّ الدِّيَّةَ إِذَا كَانُوا مُخْتَلَطِينَ، فَإِنْ كَانَ فِي صَفِّ الْمُشْرِكِينَ لَا تَحِبُّ لِسُقُوطِ عِصْمَتِهِ بِكَثِيرِ سَوَادِهِمْ قَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «مَنْ كَثُرَ سَوَادُ قَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»²¹²

التعليق:

وَإِذَا التَّقَى الصَّفَّانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ فَقَتَلَ مُسْلِمٌ مُسْلِمًا ظَنَّ أَنَّهُ مُشْرِكٌ فَلَا قَوْدَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ؛ لِأَنَّ هَذَا أَحَدُ نَوْعَيْ الْخَطَا وَهُوَ هَذَا الْخَطَا فِي الْقَصْدِ ، وَالْخَطَا بِنَوْعَيْهِ لَا يُوجِبُ الْقَوْدَ وَيُوجِبُ الْكَفَّارَةَ، وَكَذَا الدِّيَّةُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً} [النساء: 92] الْآيَةَ.

²¹²()أخرجه الزيلعي في نصب الراية 4 / 346.

21-تعدد أسباب الجريمة

الهداية: قَالَ (وَمَنْ شَجَّ نَفْسَهُ وَشَجَّهَ رَجُلٌ وَعَقَرَهُ أَسَدٌ وَأَصَابَتْهُ حَيَّةٌ فَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ فَعَلَى الْأَجْنَبِيِّ ثُلُثُ الدِّيَةِ) ؛ لِأَنَّ فِعْلَ الْأَسَدِ وَالْحَيَّةِ جِنْسٌ وَاحِدٌ لِكَوْنِهِ هَدْرًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَفِعْلُهُ بِنَفْسِهِ هَدْرٌ فِي الدُّنْيَا مُعْتَبَرٌ فِي الْآخِرَةِ حَتَّى يَأْتُمْ عَلَيْهِ فِي النُّوَادِرِ (213) أَنَّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ يُعَسَّلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يُعَسَّلُ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَفِي شَرْحِ السَّيْرِ الْكَبِيرِ (214) ذَكَرَ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ اخْتِلَافَ الْمَشَايخِ (215) عَلَى مَا كَتَبْنَاهُ فِي كِتَابِ التَّجْنِيسِ وَالْمَزِيدِ فَلَمْ يَكُنْ هَدْرًا مُطْلَقًا وَكَانَ جِنْسًا آخَرَ، وَفِعْلُ الْأَجْنَبِيِّ مُعْتَبَرٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَصَارَتْ ثَلَاثَةُ أَجْنَاسٍ فَكَانَ النَّفْسَ تَلِفَتْ بِثَلَاثَةِ أَفْعَالٍ فَيَكُونُ التَّلَافُ بِفِعْلِ كُلِّ وَاحِدٍ ثَلَاثَةً فَيَجِبُ عَلَيْهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

²¹³(النوادر، وهي غير ظاهر الرواية؛ لأنها لم تظهر كما ظهرت كتب ظاهر الرواية، ولم تُزَوَّ إلا بطريق الأحاد بين صحيح وضعيف، "كالرَّقِيَّاتِ"، و"الكَيْسَانِيَّاتِ"، و"الْجُزْجَانِيَّاتِ"، و"الْهَارُونِيَّاتِ" من تصانيف محمد التي رواها عنه الأحاد، ولم تبلغ حد التواتر، ولا الشهرة عنه.

²¹⁴(كتاب "شرح السير الكبير" لمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى: 483هـ).

²¹⁵(المراد بالمشايخ: مَنْ لم يدرك الإمام. وذلك بعد وفاة حسن بن زياد اللؤلؤي قرابة 204هـ.

22- مَنْ شَهَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ سَيْفًا

الهداية: قَالَ (وَمَنْ شَهَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ سَيْفًا فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْتُلُوهُ) لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «مَنْ شَهَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ سَيْفًا فَقَدْ أَطْلَ دَمَهُ» وَلِأَنَّهُ بَاغٍ فَتَسْقُطُ عِصْمَتُهُ بِبَغْيِهِ، وَلِأَنَّهُ تَعَيَّنَ طَرِيقًا لِدَفْعِ الْقَتْلِ عَنْ نَفْسِهِ فَلَهُ قَتْلُهُ وَقَوْلُهُ فَعَلَيْهِمْ وَقَوْلُ مُحَمَّدٍ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ فَحَقُّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَقْتُلُوهُ إِشَارَةً إِلَى الْوُجُوبِ، وَالْمَعْنَى وَجُوبُ دَفْعِ الضَّرَرِ

التعليق:

حكم من شهر على المسلمين سيفاً:

وَمَنْ شَهَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ سَيْفًا فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْتُلُوهُ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «مَنْ شَهَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ سَيْفًا فَقَدْ أَطْلَ دَمَهُ»⁽²¹⁶⁾ وَلِأَنَّهُ بَاغٍ فَتَسْقُطُ عِصْمَتُهُ بِبَغْيِهِ، وَلِأَنَّهُ تَعَيَّنَ طَرِيقًا لِدَفْعِ الْقَتْلِ عَنْ نَفْسِهِ فَلَهُ قَتْلُهُ.

23- شَهَرَ الْمَجْنُونُ عَلَى غَيْرِهِ سِلَاحًا فَقَتَلَهُ الْمَشْهُورُ عَلَيْهِ

الهداية: قَالَ (وَإِنْ شَهَرَ الْمَجْنُونُ عَلَى غَيْرِهِ سِلَاحًا فَقَتَلَهُ الْمَشْهُورُ عَلَيْهِ عَمْدًا فَعَلَيْهِ الدِّيَّةُ فِي مَالِهِ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ الصَّبِيُّ وَالِدَابَّةُ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يَجِبُ الضَّمَانُ فِي الدَّابَّةِ وَلَا يَجِبُ فِي الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ

²¹⁶() قال ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية 267/2 رقم 1015: "حَدِيثٌ مِنْ شَهَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ سَيْفًا فَقَدْ أَطْلَ دَمَهُ لَمْ أَجِدْ بِهِذَا اللَّفْظَ وَفِي النَّسَائِيِّ عَنْ ابْنِ الزَّبِيرِ رَفَعَهُ مِنْ شَهَرَ سَيْفَهُ ثُمَّ وَضَعَهُ فَدَمَهُ هَدَرَ وَأَخْرَجَهُ".

لِلشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَتَلَهُ دَافِعًا عَنْ نَفْسِهِ فَيُعْتَبَرُ بِالْبَالِغِ الشَّاهِرِ، وَلِأَنَّهُ يَصِيرُ مَحْمُولًا عَلَى قَتْلِهِ بِفِعْلِهِ فَأَشْبَهَ الْمُكْرَهَ
وَلِأَبِي يُوسُفَ أَنَّ فِعْلَ الدَّابَّةِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ أَصْلًا حَتَّى لَوْ تَحَقَّقَ لَا يُوجِبُ الضَّمَانُ أَمَّا فِعْلُهُمَا مُعْتَبَرٌ فِي الْجُمْلَةِ حَتَّى لَوْ حَقَّقْنَاهُ
يَجِبُ عَلَيْهِمَا الضَّمَانُ، وَكَذَا عِصْمَتُهُمَا لِحَقِّهِمَا وَعِصْمَةُ الدَّابَّةِ لِحَقِّ مَالِكِهَا فَكَانَ فِعْلُهُمَا مُسْقِطًا لِلْعِصْمَةِ دُونَ فِعْلِ الدَّابَّةِ،
وَلَنَا أَنَّهُ قَتَلَ شَخْصًا مَعْصُومًا أَوْ أَتْلَفَ مَالًا مَعْصُومًا حَقًّا لِلْمَالِكِ وَفِعْلُ الدَّابَّةِ لَا يَصْلُحُ مُسْقِطًا وَكَذَا فِعْلُهُمَا، وَإِنْ كَانَتْ
عِصْمَتُهُمَا حَقًّا لِعَدَمِ اخْتِيَارِ صَحِيحٍ وَلِهَذَا لَا يَجِبُ الْقِصَاصُ بِتَحَقُّقِ الْفِعْلِ مِنْهُمَا، بِخِلَافِ الْعَاقِلِ الْبَالِغِ؛ لِأَنَّ لَهُ اخْتِيَارًا
صَحِيحًا، وَإِنَّمَا لَا يَجِبُ الْقِصَاصُ لَوْجُودِ الْمُبِيحِ وَهُوَ دَفْعُ الشَّرِّ فَتَجِبُ الدِّيَّةُ.

التعليق:

ما الحكم إن شهر المجنون على غيره سلاحا فقتله المشهور عليه عمدا؟
إِنْ شَهَرَ الْمَجْنُونُ عَلَى غَيْرِهِ سِلَاحًا فَقَتَلَهُ الْمَشْهُورُ عَلَيْهِ عَمْدًا فَقَوْلَانِ لِلْفُقَهَاءِ:
القول الأول: ذهب الحنفية إلى أن عَلَيْهِ الدِّيَّةُ فِي مَالِهِ
القول الثاني: قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ قَتَلَهُ دَافِعًا عَنْ نَفْسِهِ فَيُعْتَبَرُ بِالْبَالِغِ الشَّاهِرِ، وَلِأَنَّهُ يَصِيرُ مَحْمُولًا عَلَى قَتْلِهِ
بِفِعْلِهِ فَأَشْبَهَ الْمُكْرَهَ.

وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ الصَّبِيُّ وَالدَّابَّةُ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يَجِبُ الضَّمَانُ فِي الدَّابَّةِ وَلَا يَجِبُ فِي الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ
وَلِأَبِي يُوسُفَ أَنَّ فِعْلَ الدَّابَّةِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ أَصْلًا حَتَّى لَوْ تَحَقَّقَ لَا يُوجِبُ الضَّمَانُ أَمَّا فِعْلُهُمَا مُعْتَبَرٌ فِي الْجُمْلَةِ حَتَّى لَوْ حَقَّقْنَاهُ
يَجِبُ عَلَيْهِمَا الضَّمَانُ، وَكَذَا عِصْمَتُهُمَا لِحَقِّهِمَا وَعِصْمَةُ الدَّابَّةِ لِحَقِّ مَالِكِهَا فَكَانَ فِعْلُهُمَا مُسْقِطًا لِلْعِصْمَةِ دُونَ فِعْلِ الدَّابَّةِ.

وَاسْتَدِلَّ الْحَنْفِيَّةُ لِقَوْلِهِمْ أَنَّ عَلَيْهِ الدِّيةَ فِي مَالِهِ لِأَنَّهُ قَتَلَ شَخْصًا مَعْصُومًا أَوْ أَتْلَفَ مَالًا مَعْصُومًا حَقًّا لِلْمَالِكِ وَفِعْلُ الدَّابَّةِ لَا يَصْلُحُ مُسْقِطًا وَكَذَا فِعْلُهُمَا، وَإِنْ كَانَتْ عِصْمَتُهُمَا حَقَّهُمَا لِعَدَمِ اخْتِيَارِ صَحِيحٍ وَلِهَذَا لَا يَجِبُ الْقِصَاصُ بِتَحَقُّقِ الْفِعْلِ مِنْهُمَا، بِخِلَافِ الْعَاقِلِ الْبَالِغِ؛ لِأَنَّ لَهُ اخْتِيَارًا صَحِيحًا، وَإِنَّمَا لَا يَجِبُ الْقِصَاصُ لَوْجُودِ الْمُبِيحِ وَهُوَ دَفْعُ الشَّرِّ فَتَجِبُ الدِّيَةُ.

- 24- مَنْ شَهَرَ عَلَى غَيْرِهِ سِلَاحًا فِي الْمِصْرِ فَضْرَبَهُ ثُمَّ قَتَلَهُ الْآخَرُ
الهداية: قَالَ (وَمَنْ شَهَرَ عَلَى غَيْرِهِ سِلَاحًا فِي الْمِصْرِ فَضْرَبَهُ ثُمَّ قَتَلَهُ الْآخَرُ فَعَلَى الْقَاتِلِ الْقِصَاصُ) مَعْنَاهُ: إِذَا ضْرَبَهُ
فَانْصَرَفَ؛ لِأَنَّهُ خَرَجَ مِنْ أَنْ يَكُونَ مُحَارِبًا بِالْإِنْصِرَافِ فَعَادَتْ عِصْمَتُهُ.
- 25- مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ لَيْلًا وَأَخْرَجَ السَّرِقَةَ فَاتَّبَعَهُ وَقَتَلَهُ
قَالَ (وَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ لَيْلًا وَأَخْرَجَ السَّرِقَةَ فَاتَّبَعَهُ وَقَتَلَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ) لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «قَاتِلْ دُونَ
مَالِكَ»⁽²¹⁷⁾ وَلِأَنَّهُ يُبَاحُ لَهُ الْقَتْلُ دَفْعًا فِي الْإِتِّبَاءِ فَكَذَا اسْتِرْدَادًا فِي الْإِنْتِهَاءِ، وَتَأْوِيلُ الْمَسْأَلَةِ إِذَا كَانَ لَا يَتِمَّكُنُ مِنَ
الْإِسْتِرْدَادِ إِلَّا بِالْقَتْلِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

²¹⁷(أخرجه النسائي في السنن الكبرى 450/3 رقم 3530، وقال ابن حجر العسقلاني في الدراية في تخريج أحاديث الهداية 268/2 رقم 1017: " حَدِيثُ قَاتِلِ دُونَ مَالِكِ الْبُخَارِيِّ فِي تَارِيخِهِ مِنْ طَرِيقِ قَهِيدِ بْنِ مَطْرِفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَتَى رَجُلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ أَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَأْخُذَ مَالِي قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْشُدْهُ اللَّهَ تَعَالَى وَالْإِسْلَامَ ثَلَاثًا قَالَ قَدْ فَعَلْتُ قَالَ قَاتِلْ دُونَ مَالِكِ الْحَدِيثِ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ قَاتِلِهِ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ".

[بَابُ الْقِصَاصِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ]

26- مَنْ قَطَعَ يَدَ غَيْرِهِ عَمْدًا مِنَ الْمِفْصَلِ

الهداية: قَالَ: (وَمَنْ قَطَعَ يَدَ غَيْرِهِ عَمْدًا مِنَ الْمِفْصَلِ قُطِعَتْ يَدُهُ)⁽²¹⁸⁾ وَإِنْ كَانَتْ يَدُهُ أَكْبَرَ مِنَ الْيَدِ الْمَقْطُوعَةِ⁽²¹⁹⁾ ((لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَالْجُرُوحُ قِصَاصٌ} [المائدة: 45] وَهُوَ يُنْبِئُ عَنِ الْمُمَاتَلَةِ، فَكُلُّ مَا أَمَكَنَ رِعَايَتُهَا فِيهِ يَجِبُ فِيهِ الْقِصَاصُ وَمَا لَا فَلَا، وَقَدْ أَمَكَنَ فِي الْقَطْعِ مِنَ الْمِفْصَلِ فَاعْتَبِرَ، وَلَا مُعْتَبَرٌ بِكِبَرِ الْيَدِ وَصِغَرِهَا لِأَنَّ مَنَفْعَةَ الْيَدِ لَا تَخْتَلِفُ بِذَلِكَ، وَكَذَلِكَ الرَّجُلُ وَمَارِنُ الْأَنْفِ وَالْأُذُنُ لِإِمْكَانِ رِعَايَةِ الْمُمَاتَلَةِ.

27- مَنْ ضَرَبَ عَيْنَ رَجُلٍ فَقَلَعَهَا

قَالَ: (وَمَنْ ضَرَبَ عَيْنَ رَجُلٍ فَقَلَعَهَا لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ) لِامْتِنَاعِ الْمُمَاتَلَةِ فِي الْقَلْعِ، وَإِنْ كَانَتْ قَائِمَةً فَذَهَبَ ضَوْءُهَا فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ لِإِمْكَانِ الْمُمَاتَلَةِ عَلَى مَا قَالَ فِي الْكِتَابِ⁽²²⁰⁾: تُحْمَى لَهُ الْمِرَاةُ وَيُجْعَلُ عَلَى وَجْهِهِ قُطْنٌ رَطْبٌ وَتُقَابَلُ عَيْنُهُ بِالْمِرَاةِ فَيَذْهَبُ ضَوْءُهَا، وَهُوَ مَأْثُورٌ عَنِ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -⁽²²¹⁾

²¹⁸() هذا كلام القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - .

²¹⁹() وهذا كلام المصنف المرغيناني .

²²⁰() يَعْنِي الْقُدُورِيَّ .

²²¹() رُوِيَ أَنَّ هَذَا حَدَّثَ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَسَأَلَ عَنْهُ الصَّحَابَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ فِيهِ شَيْءٌ حَتَّى جَاءَ عَلَيْهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَقَضَى بِذَلِكَ وَعَمِلَ عَلَيْهِ عُثْمَانُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَكَانَ بِمَحْضَرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -

28-القصاص في السن

قَالَ: (وَفِي السِّنِّ الْقِصَاصُ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَالسِّنُّ بِالسِّنِّ} [المائدة: 45] (وَإِنْ كَانَ سِنٌّ مَنْ يُقْتَصُّ مِنْهُ أَكْبَرَ مِنْ سِنِّ الْآخَرِ) لِأَنَّ مَنَفَعَةَ السِّنِّ لَا تَتَفَاوَتْ بِالصَّغَرِ وَالْكِبَرِ. قَالَ: (وَفِي كُلِّ شَجَةٍ تَنْحَقُّ فِيهَا الْمُمَاتِلَةُ الْقِصَاصُ) لِمَا تَلَوْنَا⁽²²²⁾. قَالَ (وَلَا قِصَاصَ فِي عَظْمٍ إِلَّا فِي السِّنِّ) ⁽²²³⁾ وَهَذَا اللَّفْظُ مَرْوِيٌّ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -، وَقَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «لَا قِصَاصَ فِي الْعَظْمِ»⁽²²⁴⁾ وَالْمُرَادُ غَيْرُ السِّنِّ، وَلِأَنَّ اعْتِبَارَ الْمُمَاتِلَةِ فِي غَيْرِ السِّنِّ مُتَعَدِّرٌ لِاحْتِمَالِ الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ، بِخِلَافِ السِّنِّ لِأَنَّهُ يُبْرَدُ بِالْمِبْرَدِ، وَلَوْ قَلَعَ مِنْ أَصْلِهِ يُقْلَعُ الثَّانِي فَيَنْمَاتَانِ.

29-شِبْهُ عَمْدٍ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ

الهداية: قَالَ: (وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ شِبْهُ عَمْدٍ إِنَّمَا هُوَ عَمْدٌ أَوْ خَطَأٌ) لِأَنَّ شِبْهُ الْعَمْدِ يَعُودُ إِلَى الْآلَةِ، وَالْقَتْلُ هُوَ الَّذِي يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِهَا دُونَ مَا دُونَ النَّفْسِ لِأَنَّهُ لَا يَخْتَلِفُ إِتْلَافُهُ بِاخْتِلَافِ الْآلَةِ فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الْعَمْدُ وَالْخَطَأُ.

⁽²²²⁾ (إِشَارَةٌ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى {وَالْجُرُوحُ قِصَاصٌ} [المائدة: 45].

⁽²²³⁾ (قَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي الدَّرَايَةِ فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ الْهَدَايَةِ 269/2 رَقْم 1018: "قَوْلُهُ رَوَى عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَمْرِو قَالَ لَا قِصَاصَ فِي عَظْمٍ إِلَّا فِي السِّنِّ لَمْ أَجِدْهُ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ وَالشَّعْبِيِّ قَالَا لَيْسَ فِي الْعِظَامِ قِصَاصٌ مَا خِلا السِّنِّ وَالرَّأْسِ".

⁽²²⁴⁾ (قَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي الدَّرَايَةِ فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ الْهَدَايَةِ 269/2 رَقْم 1018: "قَوْلُهُ رَوَى عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَمْرِو قَالَ لَا قِصَاصَ فِي عَظْمٍ إِلَّا فِي السِّنِّ لَمْ أَجِدْهُ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ وَالشَّعْبِيِّ قَالَا لَيْسَ فِي الْعِظَامِ قِصَاصٌ مَا خِلا السِّنِّ وَالرَّأْسِ".

30-القصاصَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ

(وَلَا قِصَاصَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ، وَلَا بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ، وَلَا بَيْنَ الْعَبْدَيْنِ) خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ إِلَّا فِي الْحُرِّ يَقْطَعُ طَرَفَ الْعَبْدِ. وَيُعْتَبَرُ الْأَطْرَافُ بِالنَّفْسِ لِكُونِهَا تَابِعَةً لَهَا. وَلَنَا أَنَّ الْأَطْرَافَ يُسَلَّكُ بِهَا مَسْلَكُ الْأَمْوَالِ فَيَنْعَدُّ التَّمَاثُلُ بِالتَّفَاوُتِ فِي الْقِيَمَةِ، وَهُوَ مَعْلُومٌ قَطْعًا بِتَقْوِيمِ الشَّرْعِ فَأَمَكَّنَ اعْتِبَارُهُ. بِخِلَافِ التَّفَاوُتِ فِي الْبَطْشِ لِأَنَّهُ لَا ضَابِطَ لَهُ فَاعْتَبِرَ أَصْلُهُ، وَبِخِلَافِ الْأَنْفُسِ لِأَنَّ الْمُتْلَفَ إِزْهَاقُ الرُّوحِ وَلَا تَفَاوُتَ فِيهِ.

(وَيَجِبُ الْقِصَاصُ فِي الْأَطْرَافِ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ) لِلتَّسَاوِي بَيْنَهُمَا فِي الْأَرْضِ²²⁵

التعليق:

هل يقتصر من الرجل للمرأة فيما دون النفس؟

اختلف الفقهاء في القصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس على قولين: القول الأول: ذهب الحنفية إلى أنه لا قصاصَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ.

القول الثاني: ذهب الشافعي إلى جريان القصاص بين الرجل والمرأة باعتبارِ الأطرافِ بالنُّفوسِ لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ لِلنُّفُوسِ فَكَمَا يَجْرِي الْقِصَاصُ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي النُّفُوسِ فَكَذَلِكَ فِي الْأَطْرَافِ.

²²⁵(يطلق الأرض عند الفقهاء على المال الواجب فيما دون النفس بالجناية عليه .

واستدل الحنفية على أنه لا قصاص بين الرجل والمرأة، لأن الأطراف يسلك بها مسلك الأموال فينعدم التماثل بالتفاوت في القيمة وهو معلوم قطعاً بتقويم الشرع. والمختار القول الثاني بجريان القصاص بين الرجل والمرأة باعتبار الأطراف بالنفوس لأنها تابعة للنفوس فكما يجري القصاص بين الرجال والنساء في النفوس فكذلك في الأطراف.

31- قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ مِنْ نِصْفِ السَّاعِدِ أَوْ جَرَحَهُ جَائِفَةً فَبَرَأَ مِنْهَا قَالَ: (وَمَنْ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ مِنْ نِصْفِ السَّاعِدِ أَوْ جَرَحَهُ جَائِفَةً فَبَرَأَ مِنْهَا فَلَا قِصَاصَ عَلَيْهِ) لِأَنَّهُ لَا يُمَكِّنُ اعْتِبَارُ الْمُمَائِلَةِ فِيهِ، إِذْ الْأَوَّلُ كَسْرُ الْعَظْمِ وَلَا ضَابِطٌ فِيهِ، وَكَذَا الْبُرءُ نَادِرٌ فَيُفْضَى الثَّانِي إِلَى الْهَلَاكِ ظَاهِرًا. التعليق:

الجائفة: لغة الجراحة التي وصلت الجوف. فلو وصلت إلى جوف عظم الفخذ لم تكن جائفة لأن العظم لا يعد مجوفاً²²⁶. ولا يخرج معناها الاصطلاح عن المعنى اللغوي، فهي الجرح الذي ينفذ ويصل إلى جوف، كبطن، وصدر، وثغرة نحر، وجنبين، وخاصرة، ومثانة، وعجان، وكذا لو أدخل من الشرج شيئاً فخرق به حاجزاً في البطن. ولو نفذت الطعنة أو الجرح في البطن وخرجت من محل آخر فجائفتان.

²²⁶(الجائفة: الطعنة التي بلغت الجوف أو نفذته. المغرب للمطرزي: 96/1).

وَتَحْصُلُ الْجَائِفَةُ بِكُلِّ مَا يُفْضِي إِلَى بَاطِنِ جَوْفٍ ، فَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَحِيفَ بِحَدِيدَةٍ أَوْ خَشَبَةٍ مُحَدَّدَةٍ ، وَلَا بَيْنَ أَنْ تَكُونَ الْجَائِفَةُ وَاسِعَةً أَوْ ضَيِّقَةً وَلَوْ قَدَّرَ إِبْرَةَ²²⁷)

وقد اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَا قِصَاصَ فِي الْجَائِفَةِ . وَأَنَّ فِيهَا ثُلُثَ الدِّيَةِ سَوَاءً أَكَانَتْ عَمْدًا أَمْ خَطَأً ، لِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي كِتَابِهِ ، وَحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ الَّذِي فِيهِ : " وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ " ⁽²²⁸⁾ . وَعَلَيْهِ الْإِجْمَاعُ ؛ وَلَأنَّهُ لَا تُؤْمَنُ الزِّيَادَةُ فِيهَا فَلَمْ يَجِبْ فِيهَا قِصَاصٌ وَلِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ : " لَا قَوْدَ فِي الْمَأْمُومَةِ وَلَا الْجَائِفَةِ " ⁽²²⁹⁾ . وَاتَّفَقُوا فِي الْجَائِفَةِ إِذَا نَفَذَتْ مِنْ جَانِبٍ لِأَخَرٍ أَنَّهَا جَائِفَتَانِ فِي كُلِّ مِنْهُمَا ثُلُثُ الدِّيَةِ . ⁽²³⁰⁾

²²⁷() حاشية ابن عابدين 5 / 356 .

²²⁸() أخرجه أحمد في مسنده 2 / 217 .

²²⁹() أخرجه ابن ماجه في سننه 2 / 881 ، وأعله المناوي بجهالة أحد رواته وضعف آخر . فيض القدير 6 / 436 .

²³⁰() حاشية ابن عابدين 5 / 356 ، ، ومواهب الجليل 6 / 246 ، وروضة الطالبين 9 / 256 ، وكشاف القناع 6 / 54 - 56 .

32- قطع اليد الشلاء أو ناقصة الأصابع بالصحيحة

قَالَ: (وَإِذَا كَانَتْ يَدُ الْمَقْطُوعِ صَحِيحَةً وَيَدُ الْقَاطِعِ شَلَاءً أَوْ نَاقِصَةً الْأَصَابِعِ فَالْمَقْطُوعُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ قَطَعَ الْيَدَ الْمَعْيِيَةَ وَلَا شَيْءَ لَهُ غَيْرُهَا وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الْأَرْضَ كَامِلًا) لِأَنَّ اسْتِيفَاءَ الْحَقِّ كَامِلًا مُتَعَذِّرٌ فَلَهُ أَنْ يَتَجَوَّزَ بِدُونِ حَقِّهِ وَلَهُ أَنْ يَعْدِلَ إِلَى الْعَوَضِ كَالْمِثْلِيِّ إِذَا انْصَرَمَ عَنِ أَيْدِي النَّاسِ بَعْدَ الْإِثْلَافِ ثُمَّ إِذَا اسْتَوْفَاهَا نَاقِصًا فَقَدْ رَضِيَ بِهِ فَيَسْقُطُ حَقُّهُ كَمَا إِذَا رَضِيَ بِالرَّدِيِّءِ مَكَانَ الْجَيِّدِ (وَلَوْ سَقَطَتِ الْمُؤْنَةُ قَبْلَ اخْتِيَارِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَوْ قُطِعَتْ ظُلْمًا فَلَا شَيْءَ لَهُ) عِنْدَنَا لِأَنَّ حَقَّهُ مُتَعَيَّنٌ فِي الْقِصَاصِ، وَإِنَّمَا يَنْتَقِلُ إِلَى الْمَالِ بِاخْتِيَارِهِ فَيَسْقُطُ بِفَوَاتِهِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا قُطِعَتْ بِحَقٍّ عَلَيْهِ مِنْ قِصَاصٍ أَوْ سَرِقَةٍ حَيْثُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْأَرْضُ لِأَنَّهُ أَوْفَى بِهِ حَقًّا مُسْتَحَقًّا فَصَارَتْ سَالِمَةً لَهُ مَعْنَى.

33- شَجَّ رَجُلًا فَاسْتَوْعَبَتِ الشَّجَّةُ مَا بَيْنَ قَرْنَيْهِ وَهِيَ لَا تَسْتَوْعِبُ مَا بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّاجِّ

قَالَ: (وَمَنْ شَجَّ رَجُلًا فَاسْتَوْعَبَتِ الشَّجَّةُ مَا بَيْنَ قَرْنَيْهِ وَهِيَ لَا تَسْتَوْعِبُ مَا بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّاجِّ فَالْمَشْجُوجُ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ اقْتَصَّ بِمِقْدَارِ شَجَّتِهِ يَبْتَدِئُ مِنْ أَيِّ الْجَانِبَيْنِ شَاءَ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الْأَرْضَ) لِأَنَّ الشَّجَّةَ مُوجِبَةٌ لِكُونِهَا مَشِينَةً فَقَطُّ فَيَزْدَادُ الشَّيْنُ بِزِيَادَتِهَا، وَفِي اسْتِيفَائِهِ مَا بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّاجِّ زِيَادَةٌ عَلَى مَا فَعَلَ، وَلَا يُلْحَقُهُ مِنَ الشَّيْنِ بِاسْتِيفَائِهِ قَدْرَ حَقِّهِ مَا يُلْحَقُ الْمَشْجُوجَ فَيَنْتَقِصُ فَيُخَيَّرُ كَمَا فِي الشَّلَاءِ وَالصَّحِيحَةِ، وَفِي عَكْسِهِ يُخَيَّرُ أَيْضًا لِأَنَّهُ يَتَعَذَّرُ الْإِسْتِيفَاءُ كَامِلًا لِلتَّعَدِّيِّ إِلَى غَيْرِهِ. حَقُّهُ، وَكَذَا إِذَا كَانَتْ الشَّجَّةُ فِي طُولِ الرَّأْسِ وَهِيَ تَأْخُذُ مِنْ جَبْهَتِهِ إِلَى قَفَاهُ وَلَا تَبْلُغُ إِلَى قَفَا الشَّاجِّ فَهُوَ بِالْخِيَارِ لِأَنَّ الْمَعْنَى لَا يَخْتَلِفُ.

التعليق:

قوله "فَاسْتَوْعَبْتَ الشَّجَّةَ مَا بَيْنَ قَرْنَيْهِ وَهِيَ لَا تَسْتَوْعِبُ مَا بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّاجِّ" وَهُوَ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الشَّاجِّ أَكْبَرَ مِنْ رَأْسِ
المشجوج. قوله "وَفِي عَكْسِهِ" أَي أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَشْجُوجِ أَكْبَرَ مِنْ رَأْسِ الشَّاجِّ .

34- الْقِصَاصُ فِي اللِّسَانِ وَفِي الذَّكْرِ

قَالَ: (وَلَا قِصَاصَ فِي اللِّسَانِ وَلَا فِي الذَّكْرِ) وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ إِذَا قُطِعَ مِنْ أَصْلِهِ يَجِبُ لِأَنَّهُ يُمَكِّنُ اعْتِبَارُ الْمُسَاوَاةِ. وَلَنَا
أَنَّهُ يَنْقَبِضُ وَيَنْبَسِطُ فَلَا يُمَكِّنُ اعْتِبَارُ الْمُسَاوَاةِ (إِلَّا أَنْ تُقَطَعَ الْحَشَفَةُ) لِأَنَّ مَوْضِعَ الْقُطْعِ مَعْلُومٌ كَالْمَفْصِلِ، وَلَوْ قُطِعَ بَعْضُ
الْحَشَفَةِ أَوْ بَعْضُ الذَّكْرِ فَلَا قِصَاصَ فِيهِ لِأَنَّ الْبَعْضَ لَا يُعْلَمُ مَقْدَارُهُ، بِخِلَافِ الْأُذُنِ إِذَا قُطِعَ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ لِأَنَّهُ لَا يَنْقَبِضُ
وَلَا يَنْبَسِطُ وَلَهُ حَدٌّ يُعْرَفُ فَيُمَكِّنُ اعْتِبَارُ الْمُسَاوَاةِ، وَالشَّفَةُ إِذَا اسْتَقْصَاهَا بِالْقُطْعِ يَجِبُ الْقِصَاصُ لِإِمْكَانِ اعْتِبَارِ الْمُسَاوَاةِ،
بِخِلَافِ مَا إِذَا قُطِعَ بَعْضُهَا لِأَنَّهُ يَتَعَذَّرُ اعْتِبَارُهَا.

35- اصْطَلَحَ الْقَاتِلُ وَأَوْلِيَاءُ الْقَتِيلِ عَلَى مَالٍ

ما الحكم إِذَا اصْطَلَحَ الْقَاتِلُ وَأَوْلِيَاءُ الْقَتِيلِ عَلَى مَالٍ؟

الهداية: قَالَ: (وَإِذَا اصْطَلَحَ الْقَاتِلُ وَأَوْلِيَاءُ الْقَتِيلِ عَلَى مَالٍ سَقَطَ الْقِصَاصُ وَوَجَبَ الْمَالُ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا) لِقَوْلِهِ تَعَالَى
{فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} [البقرة: 178] الْآيَةُ عَلَى مَا قِيلَ نَزَلَتْ الْآيَةُ فِي الصُّلْحِ. وَقَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -

:«مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ»⁽²³¹⁾ الْحَدِيثُ، وَالْمُرَادُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ الْأَخْذُ بِالرِّضَا عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَهُوَ الصُّلْحُ بِعَيْنِهِ، وَلِأَنَّهُ حَقٌّ ثَابِتٌ لِلْوَرَثَةِ يَجْرِي فِيهِ الْإِسْقَاطُ عَفْوًا فَكَذَا تَعْوِيضًا لِاشْتِمَالِهِ عَلَى إِحْسَانِ الْأَوْلِيَاءِ وَإِحْيَاءِ الْقَاتِلِ فَيَجُوزُ بِالتَّرَاضِي. وَالْقَلِيلُ وَالكَثِيرُ فِيهِ سَوَاءٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ نَصٌّ مُقَدَّرٌ فَيَفَوِّضُ إِلَى اصْطِلَاحِهِمَا كَالْخُلْعِ وَغَيْرِهِ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرُوا حَالًا وَلَا مُوَجَّلًا فَهُوَ حَالٌ لِأَنَّهُ مَالٌ وَاجِبٌ بِالْعَقْدِ، وَالْأَصْلُ فِي أَمْثَالِهِ الْحُلُولُ نَحْوُ الْمَهْرِ وَالنَّثَمِ، بِخِلَافِ الدِّيَةِ لِأَنَّهَا مَا وَجَبَتْ بِالْعَقْدِ.

36- عَفَا أَحَدُ الشُّرَكَاءِ مِنَ الدِّمِّ أَوْ صَالَحَ مِنْ نَصِيْبِهِ عَلَى عَوَضٍ
(وَإِذَا عَفَا أَحَدُ الشُّرَكَاءِ مِنَ الدِّمِّ أَوْ صَالَحَ مِنْ نَصِيْبِهِ عَلَى عَوَضٍ سَقَطَ حَقُّ الْبَاقِيْنَ عَنِ الْقِصَاصِ وَكَانَ لَهُمْ نَصِيْبُهُمْ مِنَ الدِّيَةِ).

وَأَصْلُ هَذَا أَنَّ الْقِصَاصَ حَقٌّ جَمِيعُ الْوَرَثَةِ، وَكَذَا الدِّيَةُ خِلَافًا لِمَالِكٍ وَالشَّافِعِيُّ فِي الزَّوْجَيْنِ. لَهُمَا أَنَّ الْوَرَاثَةَ خِلَافَةٌ وَهِيَ بِالنَّسَبِ دُونَ السَّبَبِ لِانْقِطَاعِهِ بِالْمَوْتِ، وَلَنَا «أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أَمَرَ بِتَوْرِيثِ امْرَأَةِ أَشِيمَ الضَّبَّابِيِّ مِنْ عَقْلِ زَوْجِهَا أَشِيمَ»⁽²³²⁾، وَلِأَنَّهُ حَقٌّ يَجْرِي فِيهِ الْإِرْثُ، حَتَّى أَنْ مَنْ قُتِلَ وَلَهُ ابْنَانِ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا عَنْ ابْنٍ كَانَ الْقِصَاصُ بَيْنَ الصُّلْبِيِّ وَابْنِ الْإِبْنِ فَيُثْبِتُ لِسَائِرِ الْوَرَثَةِ، وَالزَّوْجِيَّةُ تَبْقَى بَعْدَ الْمَوْتِ حُكْمًا فِي حَقِّ الْإِرْثِ أَوْ يَثْبُتُ بَعْدَ الْمَوْتِ مُسْتَنِدًا إِلَى سَبَبِهِ وَهُوَ الْجُرْحُ، وَإِذَا ثَبَتَ لِلْجَمِيعِ فَكُلُّ مِنْهُمْ يَتِمَكَّنُ مِنَ الْإِسْتِيفَاءِ وَالْإِسْقَاطِ عَفْوًا وَصُلْحًا وَمِنْ ضَرُورَةِ سُقُوطِ حَقِّ الْبَعْضِ فِي الْقِصَاصِ سُقُوطُ حَقِّ الْبَاقِيْنَ فِيهِ، لِأَنَّهُ لَا يَتَجَزَّأُ، بِخِلَافِ مَا إِذَا قُتِلَ رَجُلَيْنِ وَعَفَا أَحَدُ الْوَلِيِّينَ لِأَنَّ الْوَاجِبَ هُنَاكَ

²³¹() أخرجه البخاري في صحيحه 5/9 رقم 6880.

²³²() أخرجه الداقطني في سننه 135/5 رقم 4089.

قِصَاصَانِ مِنْ غَيْرِ شُبْهَةٍ لِاخْتِلَافِ الْقَتْلِ وَالْمَقْتُولِ وَهَاهُنَا وَاحِدٌ لِاتِّحَادِهِمَا، وَإِذَا سَقَطَ الْقِصَاصُ يَنْقَلِبُ نَصِيبُ الْبَاقِينَ مَالًا لِأَنَّهُ امْتَنَعَ لِمَعْنَى رَاجِعٍ إِلَى الْقَاتِلِ، وَلَيْسَ لِلْعَافِيِّ شَيْءٌ مِنَ الْمَالِ لِأَنَّهُ أَسْقَطَ حَقَّهُ بِفِعْلِهِ وَرِضَاهُ، ثُمَّ يَجِبُ مَا يَجِبُ مِنَ الْمَالِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ وَقَالَ زُفَرٌ: يَجِبُ فِي سَنَتَيْنِ فِيمَا إِذَا كَانَ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ وَعَفَا أَحَدُهُمَا، لِأَنَّ الْوَاجِبَ نِصْفُ الدِّيَةِ فَيُعْتَبَرُ بِمَا إِذَا قُطِعَتْ يَدُهُ خَطَأً.

وَلَنَا أَنَّ هَذَا بَعْضُ بَدَلِ الدَّمِ وَكُلُّهُ مُوجَلٌّ إِلَى ثَلَاثِ سِنِينَ فَكَذَلِكَ بَعْضُهُ، وَالْوَاجِبُ فِي الْيَدِ كُلِّ بَدَلِ الطَّرْفِ وَهُوَ فِي سَنَتَيْنِ فِي الشَّرْعِ وَيَجِبُ فِي مَالِهِ لِأَنَّهُ عَمْدٌ.

37- قَتَلَ جَمَاعَةً وَاحِدًا عَمْدًا

قَالَ: (وَإِذَا قَتَلَ جَمَاعَةً وَاحِدًا عَمْدًا أُقْتَصَّ مِنْ جَمِيعِهِمْ) لِقَوْلِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِيهِ: لَوْ تَمَالَأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ، وَلِأَنَّ الْقَتْلَ بِطَرِيقِ التَّغَالِبِ غَالِبٌ، وَالْقِصَاصُ مَزْجَرَةٌ لِلْسُّفَهَاءِ فَيَجِبُ تَحْقِيقًا لِحُكْمَةِ الْإِحْيَاءِ.

التعليق: إِذَا تَعَدَّدَ الْقَاتِلُ أُقْتَصَّ مِنْ جَمِيعِهِمْ، وَالْقِيَاسُ لَا يَفْتَضِيهِ لِإِنْتِفَاءِ الْمُسَاوَاةِ، لَكِنَّهُ تَرَكَ الْقِيَاسَ بِمَا رُوِيَ أَنَّ سَبْعَةً مِنْ أَهْلِ صَنْعَاءَ قَتَلُوا رَجُلًا فَقَضَى عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِالْقِصَاصِ عَلَيْهِمْ وَقَالَ: لَوْ تَمَالَأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ. وَالتَّمَالُؤُ التَّعَاوُنُ، وَصَنْعَاءُ الْيَمَنُ: قَصَبَتْهَا. وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَتَلَ ثَلَاثَةً بَوَاحِدٍ. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ قَتَلَ جَمَاعَةً بَوَاحِدٍ، وَكَانَتْ الصَّحَابَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - مُتَوَافِرِينَ وَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِمْ أَحَدٌ فَحَلَّ مَحَلَّ الْإِجْمَاعِ، وَلِأَنَّ الْقَتْلَ بِطَرِيقِ التَّغَالِبِ غَالِبٌ فَإِنَّ الْقَتْلَ بِغَيْرِ حَقٍّ لَا يَتَحَقَّقُ غَالِبًا إِلَّا بِالْإِجْتِمَاعِ، لِأَنَّ الْوَاحِدَ يُقَاوِمُ الْوَاحِدَ،

وَمَا غَلَبَ وَقُوعُهُ مِنَ الْفَسَادِ يُوجِبُ مَزْجَرَةً فَيَجِبُ الْقِصَاصُ تَحْقِيقًا لِحِكْمَةِ الْإِحْيَاءِ، فَإِنَّهُ لَوْ لَمْ يَجِبْ لَمَا عَجَزَ الْمُفْسِدُ عَنْ أَنْ يَجْمَعَ عَلَيْهِ أَمْثَالُهُ وَيَقْتُلَ لِعِلْمِهِ أَنْ لَا قِصَاصَ فَيُودِّي إِلَى سَدِّ بَابِ الْقِصَاصِ. وَلِقَائِلِ أَنْ يَقُولَ: مَا ذَكَرْتُمْ مِنَ الْمَعْقُولِ إِنْ لَمْ يَكُنْ قِيَاسًا عَلَى مُجْمَعٍ عَلَيْهِ لَا يَكُونُ مُعْتَبَرًا فِي الشَّرْعِ، وَإِنْ كَانَ فَلَا يَرَبُّو عَلَى الْقِيَاسِ الْمُقْتَضِي لِعَدَمِهِ الْمُؤَيَّدِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة: 45] وَالْجَوَابُ أَنَّهُ قِيَاسٌ عَلَى سَائِرِ أَبْوَابِ الْعُقُوبَاتِ الْمُتَرْتِبَةِ عَلَى مَا يُوجِبُ الْفَسَادَ مِنْ أَفْعَالِ الْعِبَادِ، وَيَرَبُّو عَلَى ذَلِكَ بِقُوَّةِ أَثَرِهِ الْبَاطِنِ وَهُوَ إِحْيَاءُ حِكْمَةِ الْإِحْيَاءِ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة: 45] لَا يُنَافِيهِمْ لِأَنَّهُمْ فِي إِزْهَاقِ الرُّوحِ الْغَيْرِ الْمُتَجَزِّي كَشَخْصٍ وَاحِدٍ، وَإِذَا كَانَتْ الْمَسْأَلَةُ بِالْعَكْسِ وَحَضَرَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِينَ قُتِلَ بِجَمَاعَتِهِمْ.

38- قَتَلَ وَاحِدٌ جَمَاعَةً

(وَإِذَا قَتَلَ وَاحِدٌ جَمَاعَةً فَحَضَرَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِينَ قُتِلَ لِجَمَاعَتِهِمْ وَلَا شَيْءَ لَهُمْ غَيْرُ ذَلِكَ، فَإِنْ حَضَرَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ قُتِلَ لَهُ وَسَقَطَ حَقُّ الْبَاقِينَ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُقْتَلُ بِالْأَوَّلِ مِنْهُمْ وَيَجِبُ لِلْبَاقِينَ الْمَالُ، وَإِنْ اجْتَمَعُوا وَلَمْ يَعْرِفِ الْأَوَّلُ قُتِلَ لَهُمْ وَقُسِمَتْ الدِّيَاتُ بَيْنَهُمْ، وَقِيلَ يُفْرَعُ بَيْنَهُمْ فَيُقْتَلُ لِمَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ. لَهُ أَنَّ الْمَوْجُودَ مِنَ الْوَاحِدِ قِتْلَاتٌ وَالَّذِي تَحَقَّقَ فِي حَقِّهِ قَتْلُ وَاحِدٍ فَلَا تَمَاطُلَ، وَهُوَ الْقِيَاسُ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ، إِلَّا أَنَّهُ عُرِفَ بِالشَّرْعِ. وَلَنَا أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قَاتِلٌ بِوَصْفِ الْكَمَالِ فَجَاءَ التَّمَاتُلُ أَصْلُهُ الْفَصْلُ الْأَوَّلُ، إِذْ لَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَمَا وَجَبَ الْقِصَاصُ، وَلِأَنَّهُ وَجِدَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ جُرْحٌ صَالِحٌ لِلِإِزْهَاقِ فَيُضَافُ إِلَى كُلِّ مِنْهُمْ إِذْ هُوَ لَا يَتَجَزَّأُ، وَلِأَنَّ الْقِصَاصَ شُرْعَ مَعَ الْمُنَافِي لِتَحْقِيقِ الْإِحْيَاءِ وَقَدْ حَصَلَ بِقَتْلِهِ فَانْتَفَى بِهِ.

التعليق: إِذَا قُتِلَ وَاحِدٌ جَمَاعَةً فَحَضَرَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِينَ قُتِلَ لِجَمَاعَتِهِمْ وَلَا شَيْءَ لَهُمْ غَيْرُ ذَلِكَ، فَإِنْ حَضَرَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ فَللفقهاء قولان:

القول الأول: ذهب الحنفية إلى أنه إن حَضَرَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ قُتِلَ لَهُ وَسَقَطَ حَقُّ الْبَاقِينَ .
القول الثاني: ذهب الشافعيُّ: إلى أنه يُقْتَلُ بِالأَوَّلِ مِنْهُمْ وَيَجِبُ لِلْبَاقِينَ الْمَالُ، وَإِنْ اجْتَمَعُوا وَلَمْ يُعْرِفِ الأَوَّلُ قُتِلَ لَهُمْ وَقُسِمَتِ الدِّيَّاتُ بَيْنَهُمْ، وَقِيلَ يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ فَيُقْتَلُ لِمَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ.
واستدل الشافعي على ذلك بقوله: أَنَّ الْمَوْجُودَ مِنَ الْوَاحِدِ قِتْلَاتٌ وَالَّذِي تَحَقَّقَ فِي حَقِّهِ قُتْلُ وَاحِدٍ فَلَا تَمَائِلَ، وَهُوَ الْقِيَاسُ فِي الْفَصْلِ الأَوَّلِ، إِلَّا أَنَّهُ عُرِفَ بِالشَّرْعِ.
واستدل الحنفية بأنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قَاتِلٌ بِوَصْفِ الْكَمَالِ فَجَاءَ التَّمَائِلُ أَصْلُهُ الْفَصْلُ الأَوَّلُ، إِذْ لَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَمَا وَجَبَ الْقِصَاصُ، وَلَئِنَّهُ وَجِدَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ جُرْحٌ صَالِحٌ لِلإِزْهَاقِ فَيُضَافُ إِلَى كُلِّ مِنْهُمْ إِذْ هُوَ لَا يَتَجَزَّأُ، وَلِأَنَّ الْقِصَاصَ شُرْعَ مَعَ الْمُنَافِي لِتَحْقِيقِ الْإِحْيَاءِ وَقَدْ حَصَلَ بِقَتْلِهِ فَكَتَفَى بِهِ.

39-سقوط القصاص بالموت

قَالَ: (وَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ إِذَا مَاتَ سَقَطَ الْقِصَاصُ) لِفَوَاتِ مَحِلِّ الإِسْتِيفَاءِ فَأَشْبَهَ مَوْتَ الْعَبْدِ الْجَانِي، وَيَتَأَتَّى فِيهِ خِلَافُ الشَّافِعِيِّ إِذْ الْوَاجِبُ أَحَدُهُمَا عِنْدَهُ.

40-قَطَعَ رَجُلَانِ يَدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ

قَالَ (وَإِذَا قَطَعَ رَجُلَانِ يَدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ فَلَا قِصَاصَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَعَلَيْهِمَا نِصْفُ الدِّيَةِ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: تُقَطَّعُ يَدَاهُمَا، وَالْمُفْرَضُ إِذَا أَخَذَ سَكِينًا وَأَمَرَهُ عَلَى يَدِهِ حَتَّى انْقَطَعَتْ لَهُ الْإِعْتِبَارُ بِالْأَنْفُسِ، وَالْأَيْدِي تَابِعَةٌ لَهَا فَأَخَذَتْ حُكْمَهَا، أَوْ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِجَامِعِ الزَّجْرِ. وَلَنَا أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَاطِعُ بَعْضِ الْيَدِ، لِأَنَّ الْإِنْقِطَاعَ حَصَلَ بِاعْتِمَادِيهِمَا وَالْمَحَلُّ مُتَجَزِّئٌ فَيُضَافُ إِلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَعْضُ فَلَا مُمَازَلَةَ، بِخِلَافِ النَّفْسِ لِأَنَّ الْإِنْزِهَاقَ لَا يَتَجَزَّأُ، وَلِأَنَّ الْقَتْلَ بِطَرِيقِ الْاجْتِمَاعِ غَالِبٌ حَذَارِ الْغَوْتِ، وَالْاجْتِمَاعُ عَلَى قَطْعِ الْيَدِ مِنَ الْمِفْصَلِ فِي حَيْزِ النُّدْرَةِ لِإِفْتِقَارِهِ إِلَى مُقَدَّمَاتٍ بَطِينَةٍ فَيُلْحَقُهُ الْغَوْتُ. قَالَ (وَعَلَيْهِمَا نِصْفُ الدِّيَةِ) لِأَنَّهُ دِيَّةُ الْيَدِ الْوَاحِدَةِ وَهُمَا قَطَعَاَهَا.

التعليق:

اختلف الفقهاء في قطع رجلين يد رجل على قولين:

القول الأول: ذهب الحنفية إلى أنه إِذَا قَطَعَ رَجُلَانِ يَدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ فَلَا قِصَاصَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَعَلَيْهِمَا نِصْفُ الدِّيَةِ.
القول الثاني: قَالَ الشَّافِعِيُّ: تُقَطَّعُ يَدَاهُمَا، وَالْمُفْرَضُ إِذَا أَخَذَ سَكِينًا وَأَمَرَهُ عَلَى يَدِهِ حَتَّى انْقَطَعَتْ لَهُ الْإِعْتِبَارُ بِالْأَنْفُسِ، وَالْأَيْدِي تَابِعَةٌ لَهَا فَأَخَذَتْ حُكْمَهَا، أَوْ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِجَامِعِ الزَّجْرِ.

واستدل الحنفية على قولهم بأنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَاطِعُ بَعْضِ الْيَدِ، لِأَنَّ الْإِنْقِطَاعَ حَصَلَ بِاعْتِمَادِيهِمَا وَالْمَحَلُّ مُتَجَزِّئٌ فَيُضَافُ إِلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَعْضُ فَلَا مُمَازَلَةَ، بِخِلَافِ النَّفْسِ لِأَنَّ الْإِنْزِهَاقَ لَا يَتَجَزَّأُ، وَلِأَنَّ الْقَتْلَ بِطَرِيقِ الْاجْتِمَاعِ غَالِبٌ حَذَارِ الْغَوْتِ، وَالْاجْتِمَاعُ عَلَى قَطْعِ الْيَدِ مِنَ الْمِفْصَلِ فِي حَيْزِ النُّدْرَةِ لِإِفْتِقَارِهِ إِلَى مُقَدَّمَاتٍ بَطِينَةٍ فَيُلْحَقُهُ الْغَوْتُ، وَعَلَيْهِمَا نِصْفُ الدِّيَةِ، لِأَنَّهُ دِيَّةُ الْيَدِ الْوَاحِدَةِ وَهُمَا قَطَعَاَهَا.

41- قَطَعَ وَاحِدٌ يَمِينِي رَجُلَيْنِ

(وَإِنْ قَطَعَ وَاحِدٌ يَمِينِي رَجُلَيْنِ فَحَضَرَا فَلَهُمَا أَنْ يَقْطَعَا يَدَهُ وَيَأْخُذَا مِنْهُ نِصْفَ الدِّيَةِ يَقْسِمَانِهِ نِصْفَيْنِ سَوَاءً قَطَعَهُمَا مَعًا أَوْ عَلَى التَّعَاقُبِ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: فِي التَّعَاقُبِ يُقْطَعُ بِالْأَوَّلِ، وَفِي الْقِرَانِ يُفْرَعُ لِأَنَّ الْيَدَ اسْتَحَقَّهَا الْأَوَّلُ فَلَا يَنْبُتُ الْإِسْتِحْقَاقُ فِيهَا لِلثَّانِي كَالرَّهْنِ بَعْدَ الرَّهْنِ، وَفِي الْقِرَانِ الْيَدُ الْوَاحِدَةُ لَا تَفِي بِالْحَقَّيْنِ فَتَرْجَحُ بِالْقُرْعَةِ. وَلَنَا أَنَّهُمَا اسْتَوَيَا فِي سَبَبِ الْإِسْتِحْقَاقِ فَيَسْتَوِيَانِ فِي حُكْمِهِ كَالْغَرِيمَيْنِ فِي التَّرَكَّةِ، وَالْقِصَاصُ مِلْكُ الْفِعْلِ يَنْبُتُ مَعَ الْمُنَافِي فَلَا يَظْهَرُ إِلَّا فِي حَقِّ الْإِسْتِيفَاءِ.

أَمَّا الْمَحِلُّ فَخُلُوُّ عَنْهُ فَلَا يَمْنَعُ ثُبُوتُ الثَّانِي، بِخِلَافِ الرَّهْنِ لِأَنَّ الْحَقَّ ثَابِتٌ فِي الْمَحَلِّ. فَصَارَ كَمَا إِذَا قَطَعَ الْعَبْدُ يَمِينَيْهِمَا عَلَى التَّعَاقُبِ فَاسْتَحَقَّ رَقَبَتَهُ لَهُمَا، وَإِنْ حَضَرَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَقَطَعَ يَدَهُ فَلِأَخَرِ عَلَيْهِ نِصْفُ الدِّيَةِ، لِأَنَّ لِلْحَاضِرِ أَنْ يَسْتَوْفِيَ لِنُبُوتِ حَقِّهِ وَتَرُدُّدِ حَقِّ الْعَائِبِ، وَإِذَا اسْتَوْفَى لَمْ يَبْقَ مَحِلُّ الْإِسْتِيفَاءِ فَيَتَعَيَّنُ حَقُّ الْآخَرِ فِي الدِّيَةِ لِأَنَّهُ أَوْفَى بِهِ حَقًّا مُسْتَحَقًّا. التعليق:

اختلف الفقهاء في قَطَعَ وَاحِدٌ يَمِينِي⁽²³³⁾ رَجُلَيْنِ فَحَضَرَا على قولين:

القول الأول: قال الحنفية: لَهُمَا أَنْ يَقْطَعَا يَدَهُ وَيَأْخُذَا مِنْهُ نِصْفَ الدِّيَةِ يَقْسِمَانِهِ نِصْفَيْنِ سَوَاءً قَطَعَهُمَا مَعًا أَوْ عَلَى التَّعَاقُبِ.

²³³(قَيَّدَ بِذَلِكَ، لِأَنَّهُ لَوْ قَطَعَ يَمِينِ أَحَدِهِمَا وَيَسَارَ الْآخَرِ قُطِعَتِ يَدَاهُ. لَا يُقَالُ: تَنْتَقِي الْمُمَاتِلَةُ حِينَئِذٍ، لِأَنَّهُ مَا فَوَّتَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جِنْسَ الْمَنْفَعَةِ وَهُوَ فَوَاتَاهُ عَلَيْهِ، لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي حَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ مَا اسْتَوْفَاهُ، وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ تَفْوِيتُ جِنْسِ الْمَنْفَعَةِ وَلَا زِيَادَةُ عَلَى حَقِّهِ.

القول الثاني: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: فِي التَّعَاقُبِ يُقَطَّعُ بِالْأَوَّلِ، وَفِي الْقِرَانِ يُقَرَّعُ لِأَنَّ الْيَدَ اسْتَحَقَّتْهَا الْأَوَّلُ فَلَا يَثْبُتُ الْإِسْتِحْقَاقُ فِيهَا لِلثَّانِي كَالرَّهْنِ بَعْدَ الرَّهْنِ، وَفِي الْقِرَانِ الْيَدُ الْوَاحِدَةُ لَا تَفِي بِالْحَقِّينِ فَتَرْجَحُ بِالْقُرْعَةِ. واستدل الحنفية على قولهم بأنهما استويا في سبب الاستحقاق فيستويان في حكمه كالغريمين في التركة، والقصاص ملك الفعل يثبت مع المنافى فلا يظهر إلا في حق الاستيفاء. أمّا المحل فخلو عنه فلا يمنع ثبوت الثاني، بخلاف الرهن لأن الحق ثابت في المحل. فصار كما إذا قطع العبد يمينيهما على التعاقب فستحق رقبته لهما، وإن حضر واحد منهما فقطع يده فلآخر عليه نصف الدية، لأن للحاضر أن يستوفي لثبوت حقه وتردد حق الغائب، وإذا استوفى لم يبق محل الاستيفاء فيتعين حق الآخر في الدية لأنه أوفى به حقا مستحقا.

42-رَمَى رَجُلًا عَمْدًا فَنَفَذَ السَّهْمَ مِنْهُ إِلَى آخِرِ فَمَاتَا

(وَمَنْ رَمَى رَجُلًا عَمْدًا فَنَفَذَ السَّهْمَ مِنْهُ إِلَى آخِرِ فَمَاتَا فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ لِلأَوَّلِ وَالدِّيَةُ لِلثَّانِي عَلَى عَاقِلَتِهِ) لِأَنَّ الْأَوَّلَ عَمْدٌ وَالثَّانِي أَحَدُ نَوْعِي الْخَطَا، كَأَنَّهُ رَمَى إِلَى صَيْدٍ فَأَصَابَ آدَمِيًّا وَالْفِعْلُ يَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّ الْأَثَرِ.

43-قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ خَطَاً ثُمَّ قَتَلَهُ عَمْدًا

في حكم الفعلين:

قَالَ: (وَمَنْ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ خَطَاً ثُمَّ قَتَلَهُ عَمْدًا قَبْلَ أَنْ تَبْرَأَ يَدُهُ أَوْ قَطَعَ يَدَهُ عَمْدًا ثُمَّ قَتَلَهُ خَطَاً قَبِرَتْ يَدُهُ ثُمَّ قَتَلَهُ خَطَاً أَوْ قَطَعَ يَدَهُ عَمْدًا فَبَرَأَتْ ثُمَّ قَتَلَهُ عَمْدًا فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ بِالْأَمْرَيْنِ جَمِيعًا) وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الْجَرَاحَاتِ وَاجِبٌ

مَا أَمْكَنَ تَنْمِيمًا لِلأَوَّلِ، لِأَنَّ الْقَتْلَ فِي الْأَعْمَ يَقَعُ بِضَرَبَاتٍ مُتَعَاقِبَةٍ، وَفِي اعْتِبَارِ كُلِّ ضَرْبَةٍ بِنَفْسِهَا بَعْضُ الْحَرَجِ، إِلَّا أَنْ لَا يُمَكِّنَ الْجَمْعُ فَيُعْطَى كُلُّ وَاحِدٍ حُكْمَ نَفْسِهِ، وَقَدْ تَعَذَّرَ الْجَمْعُ فِي هَذِهِ الْفُصُولِ فِي الْأَوَّلَيْنِ لِاخْتِلَافِ حُكْمِ الْفَعْلَيْنِ، وَفِي الْآخَرَيْنِ لِتَخَلُّلِ الْبُرءِ وَهُوَ قَاطِعٌ لِلْسَّرَايَةِ، حَتَّى لَوْ لَمْ يَتَخَلَّلْ وَقَدْ تَجَانَسَا بِأَنْ كَانَا خَطَائِنِ يَجْمَعُ بِالْإِجْمَاعِ لِإِمْكَانِ الْجَمْعِ وَاكْتَفَى بِدِيَّةٍ وَاحِدَةٍ (وَإِنْ كَانَ قَطَعَ يَدَهُ عَمْدًا ثُمَّ قَتَلَهُ عَمْدًا قَبْلَ أَنْ تَبْرَأَ يَدُهُ، فَإِنْ شَاءَ الْإِمَامُ قَالَ: اقْطَعُوهُ ثُمَّ أَقْتُلُوهُ، وَإِنْ شَاءَ قَالَ: أَقْتُلُوهُ) وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَالَا: يُقْتَلُ وَلَا تُقَطَّعُ يَدُهُ لِأَنَّ الْجَمْعَ مُمَكِّنٌ لِتَجَانُسِ الْفَعْلَيْنِ وَعَدَمِ تَخَلُّلِ الْبُرءِ فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا. وَلَهُ أَنْ الْجَمْعُ مُتَعَذِّرٌ، إِمَّا لِاخْتِلَافِ بَيْنِ الْفَعْلَيْنِ هَذَيْنِ لِأَنَّ الْمُوجِبَ الْقَوْدُ وَهُوَ يَعْتَمِدُ الْمُسَاوَاةَ فِي الْفِعْلِ وَذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ الْقَتْلُ بِالْقَتْلِ وَالْقَطْعُ بِالْقَطْعِ وَهُوَ مُتَعَذِّرٌ، أَوْ لِأَنَّ الْحَزَّ يَقْطَعُ إِضَافَةَ السَّرَايَةِ إِلَى الْقَطْعِ، حَتَّى لَوْ صَدَرَ مِنْ شَخْصَيْنِ يَجِبُ الْقَوْدُ عَلَى الْحَازِّ فَصَارَ كَتَخَلُّلِ الْبُرءِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا قَطَعَ وَسَرَى لِأَنَّ الْفِعْلَ وَاحِدٌ، وَبِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَا خَطَائِنِ لِأَنَّ الْمُوجِبَ الدِّيَّةَ وَهِيَ بَدَلُ النَّفْسِ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ الْمُسَاوَاةِ، وَلِأَنَّ أَرَشَ الْيَدِ إِنَّمَا يَجِبُ عِنْدَ اسْتِحْكَامِ أَثَرِ الْفِعْلِ وَذَلِكَ بِالْحَزِّ الْقَاطِعِ لِلْسَّرَايَةِ فَيَجْتَمِعُ ضَمَانُ الْكُلِّ وَضَمَانُ الْجُزْءِ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَا يَجْتَمِعَانِ. أَمَّا الْقَطْعُ وَالْقَتْلُ قِصَاصًا يَجْتَمِعَانِ.

التعليق:

الْقَطْعُ وَالْقَتْلُ إِذَا حَصَلَ فِي شَخْصٍ وَاحِدٍ كَانَا عَلَى وُجُوهِ: أَنْ يَكُونَا خَطَائِنِ أَوْ عَمْدَيْنِ، أَوْ يَكُونَ الْقَتْلُ خَطَاً وَالْقَطْعُ عَمْدًا أَوْ بِالْعَكْسِ، فَذَلِكَ بِالقِسْمَةِ الْعَقْلِيَّةِ أَرْبَعَةً. ثُمَّ إِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِمَّا أَنْ يَكُونَ قَبْلَ الْبُرءِ أَوْ بَعْدَهُ فَذَلِكَ ثَمَانِيَةٌ أَوْجُهُ، وَكُلُّ ذَلِكَ إِمَّا أَنْ يَتَحَقَّقَ مِنْ شَخْصٍ وَاحِدٍ أَوْ شَخْصَيْنِ فَذَلِكَ سِتَّةَ عَشَرَ وَجْهًا، فَإِنْ كَانَا مِنْ شَخْصَيْنِ يُفْعَلُ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُوجِبُ فِعْلِهِ مِنَ الْقِصَاصِ وَأَخَذِ الْأَرَشِ مُطْلَقًا، لِأَنَّ التَّدَاخُلَ إِنَّمَا يَكُونُ عِنْدَ اتِّحَادِ الْمَحَلِّ لَا غَيْرُ، وَإِنْ كَانَا مِنْ شَخْصٍ وَاحِدٍ

فَإِجَابُ مُوجِبِ الْفِعْلَيْنِ أَوْ إِهْدَارُ أَحَدِهِمَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَصْلِ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِقَوْلِهِ (وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ الْجَمْعَ) يَعْنِي الْإِكْتِفَاءَ بِمُوجِبِ أَحَدِهِمَا وَاجِبٌ مَا أَمَكَّنَ تَتَمِيمًا لِلأَوَّلِ، لِأَنَّ الْقَتْلَ فِي الْأَعْمَ: يَعْنِي فِي غَالِبِ الْأَوْقَاتِ يَقَعُ بِضَرَبَاتٍ مُتَعاقِبَةٍ، وَفِي اعْتِبَارِ كُلِّ ضَرْبَةٍ بِنَفْسِهَا بَعْضُ الْحَرَجِ فَيُجْعَلُ الثَّانِي مُتَمِّمًا لِلأَوَّلِ وَيُجْعَلُ الْكُلُّ وَاحِدًا، إِلَّا أَنْ لَا يُمَكِّنَ الْجَمْعُ إِمَّا بِاخْتِلَافِ الْفِعْلَيْنِ وَصَفًا أَوْ مُوجِبًا أَوْ بِتَخَلُّلِ الْبُرءِ، فَحِينَئِذٍ يُعْطَى كُلُّ وَاحِدٍ حُكْمَ نَفْسِهِ.

فَإِنْ تَخَلَّلَ الْبُرءُ فَلَا جَمْعَ أَصْلًا لِأَنَّ الْفِعْلَ الْأَوَّلَ قَدْ انْتَهَى فَيَكُونُ الْقَتْلُ بَعْدَهُ ابْتِدَاءً، فَلَا بُدَّ مِنْ اعْتِبَارِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَإِنْ لَمْ يَتَخَلَّلْ وَقَدْ اخْتَلَفَا جِنْسًا فَكَذَلِكَ كَمَا فِي الصُّورَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ، وَإِنْ تَجَانَسَا خَطَأً جُمِعَ بِالْإِجْمَاعِ لِإِمْكَانِ الْجَمْعِ بِانْتِفَاءِ الْمَانِعِ وَهُوَ تَخَلُّلُ الْبُرءِ وَالْإِخْتِلَافُ وَاكْتِفَاءُ بَدِيَّةٍ وَاحِدَةٍ، وَإِنْ تَجَانَسَا عَمْدًا بَأَن كَانَ قَطَعَ يَدُهُ عَمْدًا ثُمَّ قَتَلَهُ عَمْدًا قَبْلَ أَنْ تَبْرَأَ يَدُهُ، فَقَدْ اخْتَلَفَ فِيهِ عَلَى قَوْلَيْنِ:

القول الأول: قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - الْوَلِيُّ بِالْخِيَارِ بَيِّنَ أَنْ يَقْطَعَ ثُمَّ يَقْتُلَ وَبَيِّنَ أَنْ يَقْتُلَ
القول الثاني: قَالَ الصَّاحِبَانِ: يَقْتُلُ وَلَا يَقْطَعُ، لِأَنَّ الْجَمْعَ مُمَكِّنٌ لِتَجَانُسِ الْفِعْلَيْنِ وَعَدَمِ تَخَلُّلِ الْبُرءِ فَيُجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بَلْ الْجَمْعُ مُتَعَدِّرٌ إِمَّا لِلِاخْتِلَافِ بَيْنَ الْفِعْلَيْنِ لِأَنَّ الْمُوجِبَ الْقَوْدَ وَهُوَ يَعْتَمِدُ الْمُسَاوَاةَ فِي الْفِعْلِ وَذَلِكَ بِأَن يَكُونَ الْقَتْلُ بِالْقَتْلِ وَالْقَطْعُ بِالْقَطْعِ وَهُوَ مُتَعَدِّرٌ لِحُلُوِّ الْقَطْعِ إِذْ ذَاكَ عَنِ الْجَزَاءِ، وَإِمَّا لِأَنَّ الْحَزَّ يَقْطَعُ إِضَافَةَ السَّرَايَةِ إِلَى الْقَطْعِ حَتَّى لَوْ صَدَرَا مِنْ شَخْصَيْنِ وَجَبَ الْقَوْدُ عَلَى الْحَازِّ، وَإِذَا انْقَطَعَ إِضَافَةُ السَّرَايَةِ إِلَيْهِ صَارَ كَتَخَلُّلِ الْبُرءِ وَلَا جَمْعَ فِيهِ بِالِاتِّفَاقِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا قَطَعَ وَسَرَى لِأَنَّ الْفِعْلَ وَاحِدًا، وَبِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَا خَطَائِنِ لِأَنَّ الْمُوجِبَ هُوَ الدِّيَّةُ وَهُوَ بَدَلُ النَّفْسِ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ الْمُسَاوَاةِ. وَلِأَنَّ أَرَشَ الْيَدِ دَلِيلٌ آخَرُ عَلَى جَوَازِ الْجَمْعِ إِذَا كَانَا خَطَائِنِ.

44-قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ فَعَفَا الْمَقْطُوعَةُ يَدَهُ عَنِ الْقَطْعِ ثُمَّ مَاتَ مِنْ ذَلِكَ

قَالَ: (وَمَنْ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ فَعَفَا الْمَقْطُوعَةُ يَدَهُ عَنِ الْقَطْعِ ثُمَّ مَاتَ مِنْ ذَلِكَ فَعَلَى الْقَاطِعِ الدِّيَةُ فِي مَالِهِ، وَإِنْ عَفَا عَنِ الْقَطْعِ وَمَا يَحْدُثُ مِنْهُ ثُمَّ مَاتَ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ عَفْوٌ عَنِ النَّفْسِ، ثُمَّ إِنْ كَانَ خَطَأً فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ، وَإِنْ كَانَ عَمْدًا فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ) وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَالَا: إِذَا عَفَا عَنِ الْقَطْعِ فَهُوَ عَفْوٌ عَنِ النَّفْسِ أَيْضًا، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إِذَا عَفَا عَنِ الشَّجَةِ ثُمَّ سَرَى إِلَى النَّفْسِ وَمَاتَ، لَهُمَا أَنْ الْعَفْوَ عَنِ الْقَطْعِ عَفْوٌ عَنْ مُوجِبِهِ، وَمُوجِبُهُ الْقَطْعُ لَوْ اقْتَصَرَ أَوْ الْقَتْلُ إِذَا سَرَى، فَكَانَ الْعَفْوُ عَنْهُ عَفْوًا عَنْ أَحَدِ مُوجِبَيْهِ أَتَاهُمَا كَانَ، وَلِأَنَّ اسْمَ الْقَطْعِ يَتَنَاوَلُ السَّارِيَ وَالْمُقْتَصِرَ فَيَكُونُ الْعَفْوُ عَنْ قَطْعٍ عَفْوًا عَنْ نَوْعِيهِ وَصَارَ كَمَا إِذَا عَفَا عَنِ الْجَنَائَةِ فَإِنَّهُ يَتَنَاوَلُ الْجَنَائَةَ السَّارِيَةَ وَالْمُقْتَصِرَةَ. كَذَا هَذَا. وَلَهُ أَنْ سَبَبَ الضَّمَانِ قَدْ تَحَقَّقَ وَهُوَ قَتْلُ نَفْسٍ مَعْصُومَةٍ مُتَقَوِّمَةٍ وَالْعَفْوُ لَمْ يَتَنَاوَلْهُ بِصَرِيحِهِ لِأَنَّهُ عَفَا عَنِ الْقَطْعِ وَهُوَ غَيْرُ الْقَتْلِ، وَبِالسَّرَايَةِ تَبَيَّنَ أَنَّ الْوَاقِعَ قَتْلٌ وَحَقُّهُ فِيهِ وَنَحْنُ نُوَجِّبُ ضَمَانَهُ. وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ الْقِصَاصُ وَهُوَ الْقِيَاسُ لِأَنَّهُ هُوَ الْمُوَجِّبُ لِلْعَمْدِ، إِلَّا أَنْ فِي الْإِسْتِحْسَانِ تَجِبُ الدِّيَةُ، لِأَنَّ صُورَةَ الْعَفْوِ أَوْرَثَتْ شُبْهَةً وَهِيَ دَارِئَةٌ لِلْقَوْدِ. وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ السَّارِيَ نَوْعٌ مِنَ الْقَطْعِ، وَأَنَّ السَّرَايَةَ صِفَةٌ لَهُ، بَلْ السَّارِيَ قَتْلٌ مِنَ الْإِبْتِدَاءِ، وَكَذَا لَا مُوجِبَ لَهُ مِنْ حَيْثُ كَوْنِهِ قَطْعًا فَلَا يَتَنَاوَلْهُ الْعَفْوُ، بِخِلَافِ الْعَفْوِ عَنِ الْجَنَائَةِ لِأَنَّهُ اسْمُ جِنْسٍ، وَبِخِلَافِ الْعَفْوِ عَنِ الشَّجَةِ وَمَا يَحْدُثُ مِنْهَا لِأَنَّهُ صَرِيحٌ فِي الْعَفْوِ عَنِ السَّرَايَةِ وَالْقَتْلِ، وَلَوْ كَانَ الْقَطْعُ خَطَأً فَقَدْ أَجْرَاهُ مَجْرَى الْعَمْدِ فِي هَذِهِ الْوُجُوهِ وَفَاقًا وَخِلَافًا، أَدْنَى بِذَلِكَ إِطْلَاقَهُ، إِلَّا أَنَّهُ إِنْ كَانَ خَطَأً فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ، وَإِنْ كَانَ عَمْدًا فَهُوَ

مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ، لِأَنَّ مُوجِبَ الْعَمْدِ الْقَوْدُ وَلَمْ يَتَّعَلَقْ بِهِ حَقُّ الْوَرَثَةِ لِمَا أَنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ فَصَارَ كَمَا إِذَا أَوْصَى بِإِعَارَةِ أَرْضِهِ.
أَمَّا الْخَطَأُ فَمُوجِبُهُ الْمَالُ، وَحَقُّ الْوَرَثَةِ يَتَّعَلَقُ بِهِ فَيُغْتَبَرُ مِنَ الثَّلَاثِ.
التعليق:

اختلف الفقهاء في حكم سرية القطع والشجة والجراحة على النفس بعد العفو ، فهل يسري العفو إلى ذلك على قولين:
القول الأول: ذهب أبو حنيفة -رحمه الله- إلى أَنَّ الْعَفْوَ عَنِ الْقُطْعِ وَالشَّجَةِ وَالْجِرَاحَةِ لَيْسَ بِعَفْوٍ عَمَّا يَحْدُثُ مِنْهُ ، فَإِذَا وَقَعَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَعَفَا الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ عَنْهُ ثُمَّ سَرَى وَمَاتَ فَعَلَى الْجَانِي الدِّيَةُ فِي مَالِهِ عِنْدَهُ.
القول الثاني: ذهب الصحابان إلى أَنَّ الْعَفْوَ عَنِ الْقُطْعِ وَالشَّجَةِ وَالْجِرَاحَةِ عَفْوٌ عَمَّا يَحْدُثُ مِنْهُ ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْعَفْوَ عَنِ الْقُطْعِ عَفْوٌ عَنْ مُوجِبِهِ، لِأَنَّ الْفِعْلَ عَرَضٌ لَا يَبْقَى فَلَا يَتَصَوَّرُ الْعَفْوُ عَنْهُ فَيَكُونُ الْعَفْوُ عَنْهُ عَفْوًا عَنْ مُوجِبِهِ وَمُوجِبُهُ إِمَّا الْقُطْعُ أَوْ الْقَتْلُ إِذَا اقْتَصَرَ أَوْ سَرَى فَكَانَ الْعَفْوُ عَفْوًا عَنْهُمَا، وَلِأَنَّ اسْمَ الْقُطْعِ يَتَنَاوَلُ السَّارِيَ وَالْمُقْتَصِرَ فَإِنَّ الْإِذْنَ بِالْقُطْعِ إِذْنٌ بِهِ وَبِمَا حَدَثَ مِنْهُ. حَتَّى إِذَا قَالَ شَخْصٌ آخَرُ اقْطَعْ يَدِي فَقَطَعَهُ ثُمَّ سَرَى إِلَى النَّفْسِ لَمْ يَضْمَنْ وَالْعَفْوُ إِذْنٌ انْتِهَاءً فَيُغْتَبَرُ بِالْإِذْنِ ابْتِدَاءً، فَصَارَ كَمَا إِذَا عَفَا عَنْ الْجَنَائِيَةِ فَإِنَّهُ يَتَنَاوَلُ السَّارِيَةَ وَالْمُقْتَصِرَةَ، فَكَذَا هَذَا.

45-قَطَعَتْ الْمَرْأَةُ يَدَ رَجُلٍ فَتَزَوَّجَهَا عَلَى يَدِهِ ثُمَّ مَاتَ
قَالَ: (وَإِذَا قَطَعَتْ الْمَرْأَةُ يَدَ رَجُلٍ فَتَزَوَّجَهَا عَلَى يَدِهِ ثُمَّ مَاتَ فَلَهَا مَهْرٌ مِثْلُهَا، وَعَلَى عَاقِلَتِهَا الدِّيَةُ إِنْ كَانَ خَطَأً، وَإِنْ كَانَ عَمْدًا فَفِي مَالِهَا) وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، لِأَنَّ الْعَفْوَ عَنِ الْيَدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَفْوًا عَمَّا يَحْدُثُ مِنْهُ عِنْدَهُ فَالْتَّرَوُّجُ عَلَى الْيَدِ لَا يَكُونُ

تَزَوُّجًا عَلَى مَا يَحْدُثُ مِنْهُ. ثُمَّ الْقَطْعُ إِذَا كَانَ عَمْدًا يَكُونُ هَذَا تَزَوُّجًا عَلَى الْقِصَاصِ فِي الطَّرَفِ وَهُوَ لَيْسَ بِمَالٍ فَلَا يَصْلُحُ مَهْرًا، لَا سِيَّمَا عَلَى تَقْدِيرِ السَّقُوطِ فَيَجِبُ مَهْرُ الْمُثَلِّ، وَعَلَيْهَا الدِّيَّةُ فِي مَالِهَا لِأَنَّ التَّزَوُّجَ وَإِنْ كَانَ يَتَّصِفُ الْعَفْوُ عَلَى مَا تُبَيِّنُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى لَكِنْ عَنِ الْقِصَاصِ فِي الطَّرَفِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ، وَإِذَا سَرَى تَبَيَّنَ أَنَّهُ قَتْلُ النَّفْسِ وَلَمْ يَتَنَاوَلْهُ الْعَفْوُ فَتَجِبُ الدِّيَّةُ وَتَجِبُ فِي مَالِهَا لِأَنَّهُ عَمْدٌ. وَالْقِيَاسُ أَنْ يَجِبَ الْقِصَاصُ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ. وَإِذَا وَجَبَ لَهَا مَهْرُ الْمُثَلِّ وَعَلَيْهَا الدِّيَّةُ تَقَعُ الْمُقَاصَّةُ إِنْ كَانَا عَلَى السَّوَاءِ، وَإِنْ كَانَ فِي الدِّيَّةِ فَضْلٌ تَرُدُّهُ عَلَى الْوَرَثَةِ، وَإِنْ كَانَ فِي الْمَهْرِ فَضْلٌ يَرُدُّهُ الْوَرَثَةُ عَلَيْهَا، وَإِذَا كَانَ الْقَطْعُ خَطَأً يَكُونُ هَذَا تَزَوُّجًا عَلَى أَرَشِ الْيَدِ، وَإِذَا سَرَى إِلَى النَّفْسِ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَا أَرَشَ لِلْيَدِ وَأَنَّ الْمُسَمَّى مَعْدُومٌ فَيَجِبُ مَهْرُ الْمُثَلِّ، كَمَا إِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى مَا فِي الْيَدِ وَلَا شَيْءَ فِيهَا. وَلَا يَتَقَاصَّنِ لِأَنَّ الدِّيَّةَ تَجِبُ عَلَى الْعَاقِلَةِ فِي الْخَطَأِ وَالْمَهْرُ لَهَا.

التعليق:

قَطَعَتِ الْمَرْأَةُ يَدَ رَجُلٍ فَتَزَوَّجَهَا عَلَى يَدِهِ ، فَإِمَّا أَنْ يَفْتَصِرَ الْقَطْعُ أَوْ يَسْرِيَ عَلَى النَّفْسِ، فَإِنْ اقْتَصَرَ الْقَطْعُ صَحَّتِ التَّسْمِيَةُ وَيَصِيرُ الْأَرَشُ وَهُوَ خَمْسَةُ آلَافٍ دِرْهَمٍ مَهْرًا لَهَا بِالْإِجْمَاعِ سَوَاءٌ كَانَ الْقَطْعُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً وَتَزَوَّجَهَا عَلَى الْقَطْعِ فَقَطْ أَوْ عَلَيْهِ وَمَا يَحْدُثُ مِنْهُ، لِأَنَّهُ لَمَّا بَرَأَ تَبَيَّنَ أَنَّ مُوجِبَهَا الْأَرَشُ دُونَ الْقِصَاصِ لِأَنَّهُ لَا يَجْرِي فِي الْأَطْرَافِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَالْأَرَشُ يَصْلُحُ صَدَاقًا.

وإن سرى القطع إلى النفس فماتَ فإِمَّا أَنْ يَكُونَ الْقَطْعُ خَطَأً أَوْ عَمْدًا، فَإِنْ كَانَ خَطَأً فَلَهَا مَهْرُ مُثْلِهَا وَالدِّيَّةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَإِنْ كَانَ الْقَطْعُ عَمْدًا فَلَهَا مَهْرُ مُثْلِهَا وَالدِّيَّةُ فِي مَالِهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، لِأَنَّ الْعَفْوَ عَنِ الْيَدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَفْوًا عَمَّا

يَحْدُثُ مِنْهُ عِنْدَهُ فَالتَّزْوُجُ عَلَى الْيَدِ لَا يَكُونُ تَزْوُجًا عَلَى مَا يَحْدُثُ مِنْهُ فَيَكُونُ مَا لَهَا مِنَ الْمَهْرِ غَيْرَ مَا عَلَيْهَا مِمَّا يَحْدُثُ مِنْهُ ثُمَّ الْقَطْعُ إِذَا كَانَ عَمْدًا كَانَ التَّزْوُجُ تَزْوُجًا عَلَى الْقِصَاصِ فِي الطَّرَفِ وَهُوَ لَيْسَ بِمَالٍ فَلَا يَصْلُحُ مَهْرًا لَا سِيَّمَا عَلَى تَقْدِيرِ سُقُوطِ الْقِصَاصِ، فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَصْلُحْ مَهْرًا عَلَى تَقْدِيرِ ثُبُوتِهِ لَا يَصْلُحُ عَلَى تَقْدِيرِ سُقُوطِهِ بِطَرِيقِ الْأُولَى، وَالْقِصَاصُ يَسْقُطُ هَاهُنَا إِمَّا بِقَبُولِهَا التَّزْوُجَ لِأَنَّ سُقُوطَهُ مُتَعَلِّقٌ بِالْقَبُولِ فَلَمَّا قَبِلَتْ سَقَطَ، وَإِمَّا بِاعْتِبَارِ تَعَذُّرِ الْإِسْتِيفَاءِ، فَإِنَّهُ لَمَّا جَعَلَ الْقِصَاصَ مَهْرًا جَعَلَ لَهَا وَلَايَةَ الْإِسْتِيفَاءِ وَلَا يُمَكِّنُ اسْتِيفَاءَ الْقِصَاصِ عَنْ نَفْسِهِ. فَإِنْ قِيلَ: الْوَاجِبُ فِي الْأَطْرَافِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ هُوَ الْأَرْشُ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ وَهُوَ مَعْلُومٌ فَمَا الْمَانِعُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمَهْرُ؟ أَجِيبُ بِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُنْعَيْنِ لِحَوَازِ أَنْ يَكُونَ خَمْسَةَ آلَافٍ دِرْهَمٍ فَيَكُونُ مَجْهُولًا، وَإِذَا لَمْ يَصْلُحِ الْقِصَاصُ وَلَا بَدَلُهُ مَهْرًا يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ وَعَلَيْهَا الدِّيَّةُ فِي مَالِهَا.

46-تَزَوَّجَهَا عَلَى الْيَدِ وَمَا يَحْدُثُ مِنْهَا أَوْ عَلَى الْحِنَايَةِ ثُمَّ مَاتَ مِنْ ذَلِكَ وَالْقَطْعُ عَمْدٌ قَالَ: (وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى الْيَدِ وَمَا يَحْدُثُ مِنْهَا أَوْ عَلَى الْحِنَايَةِ ثُمَّ مَاتَ مِنْ ذَلِكَ وَالْقَطْعُ عَمْدٌ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا) لِأَنَّ هَذَا تَزْوُجٌ عَلَى الْقِصَاصِ وَهُوَ لَا يَصْلُحُ مَهْرًا فَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ، وَصَارَ كَمَا إِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى خَمْرِ أَوْ خَنْزِيرٍ وَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَيْهَا، لِأَنَّهُ لَمَّا جَعَلَ الْقِصَاصَ مَهْرًا فَقَدْ رَضِيَ بِسُقُوطِهِ بِجَهَةِ الْمَهْرِ فَيَسْقُطُ أَصْلًا كَمَا إِذَا أَسْقَطَ الْقِصَاصَ بِشَرْطِ أَنْ يَصِيرَ مَالًا فَإِنَّهُ يَسْقُطُ أَصْلًا (وَإِنْ كَانَ خَطَأً يُرْفَعُ عَنِ الْعَاقِلَةِ مَهْرُ مِثْلِهَا، وَلَهُمْ ثُلُثُ مَا تَرَكَ وَصِيَّةً) لِأَنَّ هَذَا تَزْوُجٌ عَلَى الدِّيَةِ وَهِيَ تَصْلُحُ مَهْرًا إِلَّا أَنَّهُ يُعْتَبَرُ بِقَدْرِ مَهْرِ الْمِثْلِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ لِأَنَّهُ مَرِيضٌ مَرَضَ الْمَوْتِ وَالتَّزْوُجُ مِنَ الْحَوَائِجِ الْأَصْلِيَّةِ وَلَا يَصِحُّ فِي حَقِّ الزِّيَادَةِ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ لِأَنَّهُ مُحَابَاةٌ فَيَكُونُ وَصِيَّةً فَيُرْفَعُ عَنِ الْعَاقِلَةِ لِأَنَّهُمْ يَتَحَمَّلُونَ عَنْهَا، فَمِنْ

الْمَحَالِ أَنْ تَرْجَعَ عَلَيْهِمْ بِمُوجِبِ جِنَايَتِهَا، وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ وَصِيَّةٌ لَهُمْ لِأَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ الْوَصِيَّةِ لِمَا أَنَّهُمْ لَيْسُوا بِقَتْلَةٍ، فَإِنْ كَانَتْ تَخْرُجُ مِنَ الثُّلُثِ تَسْقُطُ، وَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ يَسْقُطُ ثُلُثُهُ. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: كَذَلِكَ الْجَوَابُ فِيمَا إِذَا تَرَوَّجَهَا عَلَى الْيَدِ، لِأَنَّ الْعَفْوَ عَنِ الْيَدِ عَمَّا يَحْدُثُ مِنْهُ عِنْدَهُمَا فَاتَّفَقَ جَوَابُهُمَا فِي الْفَصْلَيْنِ.

47- قُطِعَتْ يَدُهُ فَاقْتُصَّ لَهُ مِنَ الْيَدِ ثُمَّ مَاتَ

قَالَ: (وَمَنْ قُطِعَتْ يَدُهُ فَاقْتُصَّ لَهُ مِنَ الْيَدِ ثُمَّ مَاتَ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ الْمُقْتَصُّ مِنْهُ) لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّ الْجِنَايَةَ كَانَتْ قَتْلَ عَمْدٍ وَحَقُّ الْمُقْتَصِّ لَهُ الْقَوْدُ، وَاسْتِيفَاءُ الْقَطْعِ لَا يُوجِبُ سُقُوطَ الْقَوْدِ كَمَا كَانَ لَهُ الْقَوْدُ إِذَا اسْتَوْفَى طَرَفَ مَنْ عَلَيْهِ الْقَوْدُ. وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يَسْقُطُ حَقُّهُ فِي الْقِصَاصِ، لِأَنَّهُ لَمَّا أَقْدَمَ عَلَى الْقَطْعِ فَقَدْ أَبْرَأَهُ عَمَّا وَرَاءَهُ. وَنَحْنُ نَقُولُ: إِنَّمَا أَقْدَمَ عَلَى الْقَطْعِ ظَنًّا مِنْهُ أَنَّ حَقَّهُ فِيهِ وَبَعْدَ السَّرَايَةِ تَبَيَّنَ أَنَّهُ فِي الْقَوْدِ فَلَمْ يَكُنْ مُبْرِنًا عَنْهُ بِدُونِ الْعِلْمِ بِهِ.

التعليق:

اختلف الفقهاء فمن قُطِعَتْ يَدُهُ فَاقْتُصَّ لَهُ مِنَ الْيَدِ ثُمَّ مَاتَ عَلَى قَوْلَيْنِ:

القول الأول: ذهب إلى أن مَنْ قُطِعَتْ يَدُهُ فَاقْتُصَّ لَهُ مِنَ الْيَدِ ثُمَّ مَاتَ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ الْمُقْتَصُّ مِنْهُ، لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّ الْجِنَايَةَ كَانَتْ قَتْلَ عَمْدٍ وَحَقُّ الْمُقْتَصِّ لَهُ الْقَوْدُ، وَاسْتِيفَاءُ الْقَطْعِ لَا يُوجِبُ سُقُوطَ الْقَوْدِ كَمَا كَانَ لَهُ الْقَوْدُ إِذَا اسْتَوْفَى طَرَفَ مَنْ عَلَيْهِ الْقَوْدُ.

القول الثاني: ذهب أبو يُوسُفَ إلى أَنَّهُ يَسْقُطُ حَقُّهُ فِي الْقِصَاصِ، لِأَنَّهُ لَمَّا أَقْدَمَ عَلَى الْقَطْعِ فَقَدْ أَبْرَأَهُ عَمَّا وَرَاءَهُ.

ويجاب عليه: إِنَّمَا أَقْدَمَ عَلَى الْقَطْعِ ظَنًّا مِنْهُ أَنَّ حَقَّهُ فِيهِ وَبَعْدَ السَّرَايَةِ تَبَيَّنَ أَنَّهُ فِي الْقَوْدِ فَلَمْ يَكُنْ مُبْرِنًا عَنْهُ بِدُونِ الْعِلْمِ بِهِ.

48-مَنْ قَتَلَ وَلِيَّهُ عَمْدًا فَقَطَعَ يَدَ قَاتِلِهِ ثُمَّ عَفَا

قَالَ: (وَمَنْ قَتَلَ وَلِيَّهُ عَمْدًا فَقَطَعَ يَدَ قَاتِلِهِ ثُمَّ عَفَا وَقَدْ قُضِيَ لَهُ بِالْقِصَاصِ أَوْ لَمْ يُقْضَ فَعَلَى قَاطِعِ الْيَدِ دِيَّةُ الْيَدِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَالَ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ) لِأَنَّهُ اسْتَوْفَى حَقَّهُ فَلَا يَضْمَنُهُ، وَهَذَا لِأَنَّهُ اسْتَحَقَّ إِتْلَافَ النَّفْسِ بِجَمِيعِ أَجْزَائِهَا، وَلِهَذَا لَوْ لَمْ يَعْفُ لَا يَضْمَنُهُ، وَكَذَا إِذَا سَرَى وَمَا بَرَأَ أَوْ مَا عَفَا وَمَا سَرَى، أَوْ قَطَعَ ثُمَّ حَزَّ رَقَبَتَهُ قَبْلَ الْبُرْءِ أَوْ بَعْدَهُ وَصَارَ كَمَا إِذَا كَانَ لَهُ قِصَاصٌ فِي الطَّرَفِ فَقَطَعَ أَصَابِعَهُ ثُمَّ عَفَا لَا يَضْمَنُ الْأَصَابِعَ. وَلَهُ أَنَّهُ اسْتَوْفَى غَيْرَ حَقِّهِ، لِأَنَّ حَقَّهُ فِي الْقَتْلِ. وَهَذَا قَطْعُ وَإِبَانَةٌ، وَكَانَ الْقِيَاسُ أَنْ يَجِبَ الْقِصَاصُ إِلَّا أَنَّهُ سَقَطَ لِلشُّبْهَةِ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يُتْلَفَ تَبَعًا، وَإِذَا سَقَطَ وَجَبَ الْمَالُ، وَإِنَّمَا لَا يَجِبُ فِي الْحَالِ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَصِيرَ قَتْلًا بِالسَّرَايَةِ فَيَكُونُ مُسْتَوْفِيًا حَقَّهُ، وَمِلْكُ الْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ ضَرُورِيٌّ لَا يَظْهَرُ إِلَّا عِنْدَ الْإِسْتِيفَاءِ أَوْ الْعَفْوِ أَوْ الْإِعْتِيَاضِ لِمَا أَنَّهُ تَصَرُّفٌ فِيهِ، فَأَمَّا قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ يَظْهَرُ لِعَدَمِ الضَّرُورَةِ بِخِلَافِ مَا إِذَا سَرَى لِأَنَّهُ اسْتِيفَاءٌ. وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَعْفُ وَمَا سَرَى، فُلْنَا: إِنَّمَا يَتَبَيَّنُ كَوْنُهُ قِطْعًا بِغَيْرِ حَقٍّ بِالْبُرْءِ حَتَّى لَوْ قَطَعَ وَمَا عَفَا وَبَرَأَ الصَّحِيحُ أَنَّهُ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ، وَإِذَا قَطَعَ ثُمَّ حَزَّ رَقَبَتَهُ قَبْلَ الْبُرْءِ فَهُوَ اسْتِيفَاءٌ وَلَوْ حَزَّ بَعْدَ الْبُرْءِ فَهُوَ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ هُوَ الصَّحِيحُ، وَالْأَصَابِعُ وَإِنْ كَانَتْ تَابِعَةً قِيَامًا بِالْكَفِّ فَالْكَفُّ تَابِعَةٌ لَهَا غَرْضًا، بِخِلَافِ الطَّرَفِ لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ لِلنَّفْسِ مِنْ كُلِّ وَجْهِ.

49-سرت الجناية إلى النفس بعد استيفاء القصاص من الطرف

قَالَ: (وَمَنْ لَهُ الْقِصَاصُ فِي الطَّرَفِ إِذَا اسْتَوْفَاهُ ثُمَّ سَرَى إِلَى النَّفْسِ وَمَاتَ يَضْمَنُ دِيَّةَ النَّفْسِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا: لَا يَضْمَنُ) لِأَنَّهُ اسْتَوْفَى حَقَّهُ وَهُوَ الْقَطْعُ، وَلَا يُمَكِّنُ التَّقْيِيدُ بِوَصْفِ السَّلَامَةِ لِمَا فِيهِ مِنْ سَدِّ بَابِ الْقِصَاصِ، إِذُ الْاِحْتِرَازُ عَنْ السَّرَايَةِ لَيْسَ فِي وَسْعِهِ فَصَّارَ كَالْإِمَامِ (234) وَالْبَزَاغِ وَالْحَجَّامِ وَالْمَأْمُورِ بِقَطْعِ الْيَدِ (235). وَلَهُ أَنَّهُ قَتْلٌ بِغَيْرِ حَقٍّ لِأَنَّ حَقَّهُ فِي الْقَطْعِ وَهَذَا وَقَعَ قَتْلًا وَلِهَذَا لَوْ وَقَعَ ظُلْمًا كَانَ قَتْلًا. وَلِأَنَّهُ جُرْحٌ أَفْضَى إِلَى فَوَاتِ الْحَيَاةِ فِي مَجْرَى الْعَادَةِ وَهُوَ مُسَمًّى الْقَتْلِ، إِلَّا أَنَّ الْقِصَاصَ سَقَطَ لِلشُّبْهَةِ فَوَجَبَ الْمَالُ بِخِلَافِ مَا اسْتَشْهَدَا بِهِ مِنَ الْمَسَائِلِ إِلَّا أَنَّهُ مُكَلَّفٌ فِيهَا بِالْفِعْلِ، إِمَّا تَقْلُدًا كَالْإِمَامِ أَوْ عَقْدًا كَمَا فِي غَيْرِهِ مِنْهَا.

وَالْوَاجِبَاتُ لَا تَتَقَيَّدُ بِوَصْفِ السَّلَامَةِ كَالرَّمِيِّ إِلَى الْحَرْبِيِّ، وَفِيمَا نَحْنُ فِيهِ لَا التَّزَامَ وَلَا وَجُوبَ، إِذْ هُوَ مَنْدُوبٌ إِلَى الْعَفْوِ فَيَكُونُ مِنْ بَابِ الْإِطْلَاقِ فَاشْبَهَ الْإِصْطِيَادَ.

التعليق:

اختلف الفقهاء فمن له القصاص في الطرف إذا استوفاه ثم سرى إلى النفس ومات على قولين:

القول الأول: قال أبو حنيفة -رحمه الله- من له القصاص في الطرف إذا استوفاه ثم سرى إلى النفس ومات يضمن دية النفس.

²³⁴(أَيُّ الْفَاضِي إِذَا قَطَعَ يَدَ السَّارِقِ فَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

²³⁵(كَمَا إِذَا قَالَ اقْطَعْ يَدِي فَفَعَلَ فَمَاتَ لَا شَيْءَ عَلَى الْقَاطِعِ.

القول الثاني: قَالَ الصَّاحِبَانِ: مَنْ لَهُ الْقِصَاصُ فِي الطَّرَفِ إِذَا اسْتَوْفَاهُ ثُمَّ سَرَى إِلَى النَّفْسِ وَمَاتَ لَا يَضْمَنُ، لِأَنَّهُ اسْتَوْفَى حَقَّهُ وَهُوَ الْقَطْعُ، وَلَا يُمَكِّنُ التَّقْيِيدُ بِوَصْفِ السَّلَامَةِ لِمَا فِيهِ مِنْ سَدِّ بَابِ الْقِصَاصِ، إِذِ الْإِحْتِرَازُ عَنِ السَّرَايَةِ لَيْسَ فِي وَسْعِهِ فَصَّارَ كَالْإِمَامِ وَالْبَزَّازِ وَالْحَجَّامِ وَالْمَأْمُورِ بِقَطْعِ الْيَدِ.

وَاسْتَدَلَّ لِأَبِي حَنِيفَةَ بِأَنَّهُ قَتَلَ بِغَيْرِ حَقٍّ لِأَنَّ حَقَّهُ فِي الْقَطْعِ وَهَذَا وَقَعَ قَتْلًا وَلِهَذَا لَوْ وَقَعَ ظُلْمًا كَانَ قَتْلًا. وَلِأَنَّهُ جُرْحٌ أَفْضَى إِلَى فَوَاتِ الْحَيَاةِ فِي مَجَرَى الْعَادَةِ وَهُوَ مُسَمًّى الْقَتْلِ، إِلَّا أَنَّ الْقِصَاصَ سَقَطَ لِلشُّبْهَةِ فَوَجَبَ الْمَالُ بِخِلَافِ مَا اسْتَشْهَدَا بِهِ مِنَ الْمَسَائِلِ إِلَّا أَنَّهُ مُكَلَّفٌ فِيهَا بِالْفِعْلِ.

50-(بَابُ الشَّهَادَةِ فِي الْقَتْلِ)

قُتِلَ وَلَهُ ابْنَانِ حَاضِرٌ وَغَائِبٌ فَأَقَامَ الْحَاضِرُ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْقَتْلِ ثُمَّ قَدِمَ الْغَائِبُ

قَالَ: (وَمَنْ قَتَلَ وَلَهُ ابْنَانِ حَاضِرٌ وَغَائِبٌ فَأَقَامَ الْحَاضِرُ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْقَتْلِ ثُمَّ قَدِمَ الْغَائِبُ فَإِنَّهُ يُعِيدُ الْبَيِّنَةَ) عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَالَا: لَا يُعِيدُ (وَإِنْ كَانَ خَطَأً لَمْ يُعِدْهَا بِالْإِجْمَاعِ) وَكَذَلِكَ الدِّينُ يَكُونُ لِأَبِيهِمَا عَلَى آخِرٍ. لَهُمَا فِي الْخِلَافَةِ أَنَّ الْقِصَاصَ طَرِيقُ الْوَرَاثَةِ كَالدَّيْنِ، وَهَذَا لِأَنَّهُ عَوَضٌ عَنْ نَفْسِهِ فَيَكُونُ الْمَلِكُ فِيهِ لِمَنْ لَهُ الْمَلِكُ فِي الْمَعْوَضِ كَمَا فِي الدِّيَةِ، وَلِهَذَا لَوْ انْقَلَبَ مَالًا يَكُونُ لِلْمَيِّتِ، وَلِهَذَا يَسْقُطُ بِعَفْوِهِ بَعْدَ الْجُرْحِ قَبْلَ الْمَوْتِ فَيَنْتَصِبُ أَحَدُ الْوَرَثَةِ خَصْمًا عَنِ الْبَاقِينَ.

وَلَهُ أَنَّ الْقِصَاصَ طَرِيقُ الْخِلَافَةِ دُونَ الْوَرَاثَةِ؛ أَلَا تَرَى أَنَّ مَلِكَ الْقِصَاصِ يَنْبُتُ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْمَيِّتُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ، بِخِلَافِ الدَّيْنِ وَالدِّيَةِ لِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْمَلِكِ فِي الْأَمْوَالِ، كَمَا إِذَا نَصَبَ شَبَكَةً فَتَعَلَّقَ بِهَا صَيْدٌ بَعْدَ مَوْتِهِ فَإِنَّهُ يَمْلِكُهُ، وَإِذَا كَانَ طَرِيقُهُ

الْإِثْبَاتِ ابْتِدَاءً لَا يَنْتَصِبُ أَحَدُهُمْ خَصْمًا عَنِ الْبَاقِينَ فَيُعِيدُ الْبَيِّنَةَ بَعْدَ حُضُورِهِ (فَإِنْ كَانَ أَقَامَ الْقَاتِلُ الْبَيِّنَةَ أَنَّ الْغَائِبَ قَدْ عَفَا فَالشَّاهِدُ خَصِمٌ وَيَسْقُطُ الْقِصَاصُ) لِأَنَّهُ ادَّعَى عَلَى الْحَاضِرِ سُقُوطَ حَقِّهِ فِي الْقِصَاصِ إِلَى مَالٍ، وَلَا يُمَكِّنُهُ إِبْتِائُهُ إِلَّا بِإِثْبَاتِ الْعَفْوِ مِنَ الْغَائِبِ فَيَنْتَصِبُ الْحَاضِرُ خَصْمًا عَنِ الْغَائِبِ (وَكَذَلِكَ عَبْدٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ قُتِلَ عَمْدًا وَأَحَدُ الرَّجُلَيْنِ غَائِبٌ فَهُوَ عَلَى هَذَا) لِمَا بَيَّنَّاهُ.

التعليق:

وَمَنْ قُتِلَ وَلَهُ ابْنَانِ حَاضِرٌ وَغَائِبٌ فَأَقَامَ الْحَاضِرُ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْقَتْلِ ثُمَّ قَدِمَ الْغَائِبُ فَالْقَتْلُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ خَطَأً أَوْ عَمْدًا، فَإِنْ كَانَ خَطَأً فَلَا يُعِيدُ بِالْإِجْمَاعِ، وَإِنْ كَانَ عَمْدًا فَلِلْفُقَهَاءِ قَوْلَانِ:

القول الأول: ذهب أبو حنيفة إلى أنه يُعِيدُ الْبَيِّنَةَ، لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ اسْتِيفَاءَ الْقِصَاصِ حَقُّ الْوَرَثَةِ عِنْدَهُ .

القول الثاني: ذهب الصحابان إلى أنه لَا يُعِيدُ، لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ اسْتِيفَاءَ الْقِصَاصِ حَقُّ الْمُورِثِ عِنْدَهُمَا.

وَكَذَلِكَ الدَّيْنُ يَكُونُ لِأَبِيهِمَا عَلَى آخَرٍ، وَلَيْسَ لِأَبِي حَنِيفَةَ تَمَسُّكَ بِصِحَّةِ الْعَفْوِ مِنَ الْوَارِثِ حَالَ حَيَاةِ الْمُورِثِ اسْتِحْسَانًا، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُمَا ذَلِكَ بِصِحَّةِ الْعَفْوِ مِنَ الْمُورِثِ الْمَجْرُوحِ اسْتِحْسَانًا لِلتَّدَافُعِ. وَالْقِيَاسُ عَدَمُ الْجَوَازِ، أَمَّا مِنْ جِهَةِ الْمُورِثِ فَلِأَنَّ الْقَتْلَ لَمْ يُوْجَدْ بَعْدُ، وَأَمَّا مِنْ جِهَةِ الْوَارِثِ فَلَوْ قُوعِهِ قَبْلَ ثُبُوتِ حَقِّهِ. وَوَجْهُ الْإِسْتِحْسَانِ أَنَّ السَّبَبَ قَدْ تَحَقَّقَ فَصَحَّ مِنْ كُلِّ مِنْهُمَا لِذَلِكَ، وَإِذَا ظَهَرَ ذَلِكَ ظَهَرَ وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ الْقِصَاصَ طَرِيقُ الْوَرَاثَةِ كَالدَّيْنِ، وَمَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ الدَّيْنِ، وَحُكْمُهُ أَنْ يَنْتَصِبَ أَحَدُ الْوَرَثَةِ خَصْمًا عَنِ الْبَاقِينَ، وَاسْتَدَلَّ لَهُمَا عَلَى أَنَّ طَرِيقَهُ الْوَرَاثَةِ بِقَوْلِهِ وَهَذَا لِأَنَّهُ عَوِضُ نَفْسٍ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة: 45] فَيَكُونُ الْمَلِكُ فِيهِ لِمَنْ لَهُ الْمَلِكُ فِي

الْمُعَوِّضِ كَمَا فِي الدِّيَةِ، وَلِهَذَا لَوْ انْقَلَبَ مَا لَا يَكُونُ لِلْمَيِّتِ تُقْضَى بِهِ دُيُونُهُ وَتُنْفَقَ مِنْهُ وَصَايَاهُ. وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ طَرِيقَهُ طَرِيقُ الْخِلَافَةِ، وَهُوَ أَنْ يَتَّبَعَ لِمَنْ يَخْلِفُ ابْتِدَاءً، كَالْعَبْدِ إِذَا انْتَهَبَ فَإِنَّهُ يَتَّبِعُ الْمَلِكَ لِلْمَوْلَى ابْتِدَاءً بِطَرِيقِ الْخِلَافَةِ لِأَنَّ الْعَبْدَ لَيْسَ بِأَهْلٍ لِلْمَلِكِ، كَمَا أَنَّ الْمَيِّتَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْقِصَاصِ لِكَوْنِهِ مَلَكُ الْفِعْلِ وَلَا يَتَصَوَّرُ الْفِعْلُ مِنَ الْمَيِّتِ وَالْوَرَاثَةُ هُوَ أَنْ يَتَّبَعَ الْمَلِكَ لِلْمُورِثِ ابْتِدَاءً ثُمَّ لِلْوَارِثِ.

51- كَانَ الْأَوْلِيَاءُ ثَلَاثَةً فَشَهِدَ اثْنَانِ مِنْهُمْ عَلَى الْآخَرِ أَنَّهُ قَدْ عَفَا

قَالَ: (فَإِنْ كَانَ الْأَوْلِيَاءُ ثَلَاثَةً فَشَهِدَ اثْنَانِ مِنْهُمْ عَلَى الْآخَرِ أَنَّهُ قَدْ عَفَا فَشَهِدَتْهُمَا بَاطِلَةٌ وَهُوَ عَفْوٌ مِنْهُمَا) لِأَنَّهُمَا يَجْرَانِ بِشَهِادَتِهِمَا إِلَى أَنْفُسِهِمَا مَغْنَمًا وَهُوَ انْقِلَابُ الْقَوْدِ مَالًا (فَإِنْ صَدَّقَهُمَا الْقَاتِلُ فَالدِّيَةُ بَيْنَهُمْ أَثَلَاثًا) مَعْنَاهُ: إِذَا صَدَّقَهُمَا وَحْدَهُ، لِأَنَّهُ لَمَّا صَدَّقَهُمَا فَقَدْ أَقَرَّ بِثُلُثِي الدِّيَةِ لَهُمَا فَصَحَّ إِقْرَارُهُ، إِلَّا أَنَّهُ يَدَّعِي سُقُوطَ حَقِّ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ وَهُوَ يُنْكِرُ فَلَا يُصَدِّقُ وَيَغْرُمُ نَصِيبَهُ (وَإِنْ كَذَّبَهُمَا فَلَا شَيْءَ لَهُمَا وَلِلْآخَرِ ثُلُثُ الدِّيَةِ) وَمَعْنَاهُ: إِذَا كَذَّبَهُمَا الْقَاتِلُ أَيْضًا، وَهَذَا لِأَنَّهُمَا أَقَرَّا عَلَى أَنْفُسِهِمَا بِسُقُوطِ الْقِصَاصِ فَقَبِلَ وَادَّعَى انْقِلَابَ نَصِيبِهِمَا مَالًا فَلَا يَقْبَلُ إِلَّا بِحُجَّةٍ، وَيَنْقَلِبُ نَصِيبُ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ مَالًا لِأَنَّ دَعْوَاهُمَا الْعَفْوُ عَلَيْهِ وَهُوَ يُنْكِرُ بِمَنْزِلَةِ ابْتِدَاءِ الْعَفْوِ مِنْهُمَا فِي حَقِّ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ، لِأَنَّ سُقُوطَ الْقَوْدِ مُضَافٌ إِلَيْهِمَا، وَإِنْ صَدَّقَهُمَا الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ وَحْدَهُ غَرِمَ الْقَاتِلُ ثُلُثَ الدِّيَةِ لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ لِإِقْرَارِهِ لَهُ بِذَلِكَ.

52- شَهِدَ الشُّهُودُ أَنَّهُ ضَرَبَهُ فَلَمْ يَزَلْ صَاحِبَ فِرَاشٍ حَتَّى مَاتَ

قَالَ: (وَإِذَا شَهِدَ الشُّهُودُ أَنَّهُ ضَرَبَهُ فَلَمْ يَزَلْ صَاحِبُ فِرَاشٍ حَتَّى مَاتَ فَعَلَيْهِ الْقَوْدُ إِذَا كَانَ عَمْدًا) لِأَنَّ الثَّابِتَ بِالشَّهَادَةِ كَالثَّابِتِ مُعَايَنَةً، وَفِي ذَلِكَ الْقِصَاصُ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ، وَالشَّهَادَةُ عَلَى قَتْلِ الْعَمْدِ تَتَحَقَّقُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ، لِأَنَّ الْمَوْتَ بِسَبَبِ الضَّرْبِ إِنَّمَا يُعْرَفُ إِذَا صَارَ بِالضَّرْبِ صَاحِبُ فِرَاشٍ حَتَّى مَاتَ، وَتَأْوِيلُهُ إِذَا شَهِدُوا أَنَّهُ ضَرَبَهُ بِشَيْءٍ جَارِحٍ.

53- اِخْتَلَفَ شَاهِدَا الْقَتْلِ فِي الْأَيَّامِ أَوْ فِي الْبَلَدِ أَوْ فِي الَّذِي كَانَ بِهِ الْقَتْلُ

قَالَ: (وَإِذَا اِخْتَلَفَ شَاهِدَا الْقَتْلِ فِي الْأَيَّامِ أَوْ فِي الْبَلَدِ أَوْ فِي الَّذِي كَانَ بِهِ الْقَتْلُ فَهُوَ بَاطِلٌ) لِأَنَّ الْقَتْلَ لَا يُعَادُ وَلَا يُكْرَرُ، وَالْقَتْلُ فِي زَمَانٍ أَوْ فِي مَكَانٍ غَيْرِ الْقَتْلِ فِي زَمَانٍ أَوْ مَكَانٍ آخَرَ، وَالْقَتْلُ بِالْعَصَا غَيْرُ الْقَتْلِ بِالسَّلَاحِ لِأَنَّ الثَّانِيَّ عَمْدٌ وَالْأَوَّلُ شِبْهُ الْعَمْدِ، وَيَخْتَلِفُ أَحْكَامُهُمَا فَكَانَ عَلَى كُلِّ قَتْلِ شَهَادَةٌ فَرُدَّ (وَكَذَا إِذَا قَالَ أَحَدُهُمَا: قَتَلَهُ بِعَصَا وَقَالَ الْآخَرُ لَا أُدْرِي بِأَيِّ شَيْءٍ قَتَلَهُ فَهُوَ بَاطِلٌ) لِأَنَّ الْمُطْلَقَ يُغَايِرُ الْمُقَيَّدَ.

54-شَهِدَا أَنَّهُ قَتَلَهُ وَقَالَا: لَا نَدْرِي بِأَيِّ شَيْءٍ قَتَلَهُ

قَالَ: (وَإِنْ شَهِدَا أَنَّهُ قَتَلَهُ وَقَالَا: لَا نَدْرِي بِأَيِّ شَيْءٍ قَتَلَهُ فَفِيهِ الدِّيَةُ اسْتِحْسَانًا) وَالْقِيَاسُ أَنَّ لَا تُقْبَلَ هَذِهِ الشَّهَادَةُ لِأَنَّ الْقَتْلَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَلَةِ فَجُهِلَ الْمَشْهُودُ بِهِ. وَجَهُ الْإِسْتِحْسَانِ أَنَّهُمْ شَهِدُوا بِقَتْلِ مُطْلَقٍ وَالْمُطْلَقُ لَيْسَ بِمُجْمَلٍ فَيَجِبُ أَقْلُ مُوجِبِيهِ وَهُوَ الدِّيَةُ وَلِأَنَّهُ يُحْمَلُ إجمالُهُمْ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى إجمالِهِمْ بِالْمَشْهُودِ عَلَيْهِ سِتْرًا عَلَيْهِ. وَأَوَّلُوا كَذِبَهُمْ فِي نَفْيِ الْعِلْمِ بِظَاهِرِ مَا وَرَدَ بِإِطْلَاقِهِ فِي إِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيِّنِ وَهَذَا فِي مَعْنَاهُ، فَلَا يَتَّبَعُ الْإِخْتِلَافُ بِالشَّكِّ، وَتَجِبُ الدِّيَةُ فِي مَالِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْفِعْلِ الْعَمْدُ فَلَا يُلْزَمُ الْعَاقِلَةُ.

55-أَقَرَّ رَجُلَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهُ قَتَلَ فُلَانًا

قَالَ: (وَإِذَا أَقَرَّ رَجُلَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهُ قَتَلَ فُلَانًا فَقَالَ الْوَلِيُّ: قَتَلْتُمَاهُ جَمِيعًا فَلَهُ أَنْ يَقْتُلَهُمَا، وَإِنْ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ قَتَلَ فُلَانًا وَشَهِدَ آخَرُونَ عَلَى آخَرَ بِقَتْلِهِ وَقَالَ الْوَلِيُّ: قَتَلْتُمَاهُ جَمِيعًا بَطَلَ ذَلِكَ كُلُّهُ) وَالْفَرْقُ أَنَّ الْإِقْرَارَ وَالشَّهَادَةَ يَتَنَاوَلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَجُودَ كُلِّ الْقَتْلِ وَوُجُوبَ الْقِصَاصِ، وَقَدْ حَصَلَ التَّكَذِيبُ فِي الْأُولَى مِنَ الْمُقَرَّرِ لَهُ وَفِي الثَّانِيَةِ مِنَ الْمَشْهُودِ لَهُ، غَيْرَ أَنَّ تَكْذِيبَ الْمُقَرَّرِ لَهُ الْمُقَرَّرُ فِي بَعْضٍ مَا أَقَرَّ بِهِ لَا يُبْطِلُ إِقْرَارَهُ فِي الْبَاقِي، وَتَكْذِيبُ الْمَشْهُودِ لَهُ الشَّاهِدَ فِي بَعْضٍ مَا شَهِدَ بِهِ يُبْطِلُ شَهَادَتَهُ أَصْلًا، لِأَنَّ التَّكَذِيبَ تَفْسِيقٌ وَفَسْقُ الشَّاهِدِ يَمْنَعُ الْقَبُولَ، أَمَّا فِسْقُ الْمُقَرَّرِ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الْإِقْرَارِ.

التعليق:

هاتان مسألتان مبناهما على أن تكذيب المقر له المقر في بعض ما أقر به لا يبطل إقراره في الباقي، فإن من أقر بألف درهم وصدق المقر له في النصف وكذبه في النصف يصح الإقرار فيما صدقه، وتكذيب المشهود له الشاهد في بعض ما يشهد به يبطل شهادته أصلاً لكونه تفسيفاً له، وفسق الشاهد يمنع القبول، بخلاف فسق المقر وقيد بقوله في بعض ما أقر به لأنه إذا أكذبه في كل ما أقر به بطل الإقرار لأنه رد لإقراره، وعلى هذا لو قال المقر له بطل قوله صدقتم ما صدقتم لم يكن له أن يقتل واحداً منهما لأن معنى قوله صدقتم معنى قوله صدقت لكل واحد منهما ومعناه أنت قتلت وحدك وفي ذلك تكذيب الآخر في الجميع وهو تكذيب لهما.

56-اعتبار حالة القتل

قال: (ومن رمى مسلماً فارتد المرمي إليه والعياذ بالله ثم وقع به السهم فعلى الرامي الدية عند أبي حنيفة. وقالوا: لا شيء عليه) لأنه بالارتداد أسقط تقوّم نفسه فيكون مبرئاً للرامي عن موجب كذا إذا أبرأه بعد الجرح قبل الموت. وله أن الضمان يجب بفعله وهو الرمي إذ لا فعل منه بعد فتعتبر حالة الرمي والرمي إليه فيها متقوم. ولهذا تعتبر حالة الرمي في حق الحل حتى لا يحرم بردة الرامي بعد الرمي، وكذا في حق التكفير حتى جاز بعد الجرح قبل الموت. والفعل وإن كان عمداً فالقود سقط للشبهة وجبت الدية.

التعليق:

ومن رمى مسلماً فارتد المرمي إليه والعياذ بالله ثم وقع به السهم فللفقهاء قولان:

القول الأول: قال أبو حنيفة - رحمه الله -: عَلَى الرَّامِي الدِّيَّةُ لَوَرَثَةِ الْمُرْتَدِّ.

القول الثاني: قال صاحبان: لَا شَيْءَ عَلَى الرَّامِي لِأَنَّهُ بِالْإِرْتِدَادِ أَسْقَطَ تَقْوَمَ نَفْسِهِ وَذَلِكَ إِبْرَاءٌ لِلضَّامِنِ، لِأَنَّ مَنْ أَخْرَجَ الْمُتَقَوِّمَ عَنِ التَّقَوُّمِ سَقَطَ حَقُّهُ كَالْمَغْصُوبِ مِنْهُ إِذَا أَعْتَقَ الْمَغْصُوبَ فَإِنَّهُ صَارَ مُبَرِّئًا لِلْغَاصِبِ عَنِ الضَّمَانِ بِإِسْقَاطِ حَقِّهِ وَصَارَ بِهِ مُبَرِّئًا كَمَا إِذَا أَبْرَأَهُ الرَّامِي عَنِ الْجَنَائِيَةِ أَوْ حَقِّهِ بَعْدَ الْجَرْحِ أَيْ انْعِقَادِ سَبَبِهِ وَهُوَ الرَّامِي قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهُ السَّهْمُ .
واستدل لأبي حنيفة أَنَّ الضَّمَانَ يَجِبُ بِفِعْلِهِ وَهُوَ الرَّمْيُ إِذْ لَا فِعْلَ مِنْهُ بَعْدَهُ، وَمَا هُوَ كَذَلِكَ فَالْمُعْتَبَرُ فِيهِ وَقْتُ الْفِعْلِ كَالْغَضَبِ ، فَيُعْتَبَرُ حَالَةُ الرَّمْيِ وَالْمَرْمِي إِلَيْهِ فِيهَا مُتَقَوِّمٌ، وَاسْتَوْضَحَ اعْتِبَارَ وَقْتِ الرَّمْيِ بِمَا إِذَا رَمَى صَيِّدًا ثُمَّ ارْتَدَّ وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ ثُمَّ أَصَابَ فَإِنَّ رِدَّتَهُ بَعْدَ الرَّمْيِ لَا تَحْرُمُ لِأَنَّ فِعْلَهُ ذِكَاةٌ شَرْعًا وَقَدْ تَمَّ مُوجِبًا لِلْحِلِّ بِشَرْطِهِ وَهُوَ التَّسْمِيَةُ، وَبِمَا إِذَا كَانَتْ الْجَنَائِيَةُ خَطَأً فَكَفَرَ بَعْدَ الرَّمْيِ قَبْلَ الْإِصَابَةِ فَإِنَّهُ صَحِيحٌ.

57-رَمَى إِلَيْهِ وَهُوَ مُرْتَدٌّ فَأَسْلَمَ

(وَلَوْ رَمَى إِلَيْهِ وَهُوَ مُرْتَدٌّ فَأَسْلَمَ ثُمَّ وَقَعَ بِهِ السَّهْمُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا، وَكَذَا إِذَا رَمَى حَرَبِيًّا فَأَسْلَمَ) لِأَنَّ الرَّمْيَ مَا انْعَقَدَ مُوجِبًا لِلضَّمَانِ لِعَدَمِ تَقَوُّمِ الْمَحِلِّ فَلَا يَنْقَلِبُ مُوجِبًا لِصَيْرُورَتِهِ مُتَقَوِّمًا بَعْدَ ذَلِكَ.

58-فُضِيَ عَلَيْهِ بِالرَّجْمِ فَرَمَاهُ رَجُلٌ ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُ الشُّهُودِ ثُمَّ وَقَعَ بِهِ الْحَجَرُ

قَالَ: (وَمَنْ قُضِيَ عَلَيْهِ بِالرَّجْمِ فَرَمَاهُ رَجُلٌ ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُ الشُّهُودِ ثُمَّ وَقَعَ بِهِ الْحَجَرُ فَلَا شَيْءَ عَلَى الرَّامِي) لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ حَالَةُ
الرَّمِي وَهُوَ مُبَاحُ الدَّمِ فِيهَا.

كِتَابُ الدَّعْوَى

تعريف المدعى ، والمدعى عليه⁽²³⁶⁾ : قَالَ (الْمُدَّعِي مَنْ لَا يُجْبَرُ عَلَى الْخُصُومَةِ إِذَا تَرَكَهَا ، وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَنْ يُجْبَرُ عَلَى الْخُصُومَةِ). (237)

الفرق بين المدعى والمدعى عليه : " وَمَعْرِفَةُ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا مِنْ أَهَمِّ مَا يُبْتَنَى عَلَيْهِ مَسَائِلُ الدَّعْوَى ، وَقَدْ اخْتَلَفَتْ عِبَارَاتُ الْمَشَايخ (238) - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - فِيهِ ، فَمِنْهَا مَا قَالَ فِي الْكِتَابِ⁽²³⁹⁾ (وَهُوَ حَدُّ عَامٍّ صَحِيحٌ ، وَقِيلَ الْمُدَّعَى : مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ إِلَّا بِحُجَّةٍ كَالْخَارِجِ ، وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ : مَنْ يَكُونُ مُسْتَحَقًّا بِقَوْلِهِ مِنْ غَيْرِ حُجَّةٍ كَذِي الْيَدِ ، وَقِيلَ الْمُدَّعَى مَنْ يَتَمَسَّكُ بِغَيْرِ الظَّاهِرِ وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَنْ يَتَمَسَّكُ بِالظَّاهِرِ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي الْأَصْلِ⁽²⁴⁰⁾ : الْمُدَّعَى عَلَيْهِ هُوَ الْمُنْكَرُ ، وَهَذَا صَحِيحٌ لَكِنَّ الشَّأْنَ فِي مَعْرِفَتِهِ ، وَالتَّرْجِيحُ بِالْفَقْهِ عِنْدَ الْحَذَّاقِ مِنْ أَصْحَابِنَا - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - لِأَنَّ الْإِعْتِبَارَ لِلْمَعَانِي دُونَ الصُّوَرِ ، فَإِنَّ الْمُودَعَ : إِذَا قَالَ رَدَدْتَ الْوَدِيعَةَ ، فَالْقَوْلُ لَهُ مَعَ الْيَمِينِ وَإِنْ كَانَ مُدَّعِيًا لِلرَّدِّ صُورَةً ، لِأَنَّهُ يُنْكَرُ الضَّمَانَ مَعْنَى.

شروط قبول الدعوى : قَالَ : (وَلَا تُقْبَلُ الدَّعْوَى حَتَّى يَذْكَرَ شَيْئًا مَعْلُومًا فِي جَنْسِهِ وَقَدْرِهِ) ، لِأَنَّ فَائِدَةَ الدَّعْوَى الْإِلْزَامُ بِوَاسِطَةِ إِقَامَةِ الْحُجَّةِ ، وَالْإِلْزَامُ فِي الْمَجْهُولِ لَا يَتَحَقَّقُ⁽²⁴¹⁾ .

(فَإِنْ كَانَ عَيْنًا فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، كُفِّلَ إِحْضَارَهَا لِتُسِيرَ إِلَيْهَا بِالدَّعْوَى ، وَكَذَا فِي الشَّهَادَةِ وَالِاسْتِحْلَافِ ، لِأَنَّ الْإِعْلَامَ بِأَقْصَى مَا يُمَكِّنُ شَرْطٌ ، وَذَلِكَ بِالْإِشَارَةِ فِي الْمَنْقُولِ ، لِأَنَّ النَّقْلَ مُمَكِّنٌ ، وَالْإِشَارَةُ أَبْلَغُ فِي التَّعْرِيفِ ، وَيَتَعَلَّقُ بِالدَّعْوَى وَجُوبُ الْحُضُورِ ، وَعَلَى هَذَا الْقَضَاءُ مِنْ آخِرِهِمْ فِي كُلِّ عَصْرٍ ، وَوُجُوبُ الْجَوَابِ إِذَا حَضَرَ لِتُفِيدَ حُضُورُهُ ، وَلِزُومِ إِحْضَارِ الْعَيْنِ الْمُدَّعَاةِ لِمَا قُلْنَا وَالْيَمِينِ إِذَا أَنْكَرَهُ⁽²⁴²⁾ ، وَسَنَذْكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

⁽²³⁶⁾ (كافة العناوين الجانبية المظله في كتاب الدعوى من وضع المحقق.

⁽²³⁷⁾ (الدعوى مشتقة من الدعاء وهو الطلب ، وفي الشرع: قول يطلب به الإنسان إثبات حق على الغير لنفسه . الاختيار لتعلييل المختار 109/2 ، مختار الصحاح ص205 ، المغرب في ترتيب المغرب ص164.

⁽²³⁸⁾ (المشايخ : يطلق على من لم يدرك الإمام أبا حنيفة من علماء مذهبه . مقدمة عمدة الرعاية ، للكنوى ص 15.

⁽²³⁹⁾ (وهو مختصر القدوري . البناءة 314/9.

⁽²⁴⁰⁾ (الأصل ويسمى المبسوط ، صنفه الإمام محمد بن الحسن الشيباني ، أحد كتب ظاهر الرواية ، وسمى بالأصل ، لأنه صنفه قبل سائر كتبه المعروفة . عقود رسم المفتى ، لابن عابدين ص56.

⁽²⁴¹⁾ (يستثنى من فساد الدعوى بالمجهول دعوى الرهن والغصب لما في الخانية معزيا إلى رهن الأصل : إذا شهدوا أنه رهن عنده ثوبا ولم يسموا الثوب، ولم يعرفوا عينه ، جازت شهادتهم ، والقول للمرتهن في أي ثوب كان ، وكذلك في الغصب ، فالدعوى بالأولى. البحر الرائق 195/7.

⁽²⁴²⁾ (البناءة 316/9

قَالَ : (وَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَاضِرَةً ذَكَرَ قِيَمَتَهَا لِيَصِيرَ الْمُدَّعَى مَعْلُومًا) ، لِأَنَّ الْعَيْنَ لَا تُعْرَفُ بِالْوَصْفِ ، وَالْقِيَمَةُ تُعْرَفُ بِهِ ، وَقَدْ تَعَذَّرَ مُشَاهَدَةُ الْعَيْنِ (243).

وَقَالَ الْفَقِيه أَبُو اللَّيْثِ (244): يُشْتَرَطُ مَعَ بَيَانِ الْقِيَمَةِ ذِكْرُ الذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ.

شروط المدعى به : "قَالَ (وَإِنْ ادَّعَى عَقَارًا حَدَّدَهُ وَذَكَرَ أَنَّهُ فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَأَنَّهُ يُطَالِبُهُ بِهِ) لِأَنَّهُ تَعَذَّرَ التَّعْرِيفُ بِالْإِشَارَةِ لِتَعَذُّرِ النَّقْلِ فَيُصَارُ إِلَى التَّجْدِيدِ فَإِنَّ الْعَقَارَ يُعْرَفُ بِهِ ، وَيَذَكَّرُ الْحُدُودَ الْأَرْبَعَةَ ، وَيَذَكَّرُ أَسْمَاءَ أَصْحَابِ الْحُدُودِ وَأَنْسَابَهُمْ ، وَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ الْجَدِّ ، لِأَنَّ تَمَامَ التَّعْرِيفِ بِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَى مَا عُرِفَ هُوَ الصَّحِيحُ ، وَلَوْ كَانَ الرَّجُلُ مَشْهُورًا يَكْتَفِي بِذِكْرِهِ ، فَإِنْ ذَكَرَ ثَلَاثَةً مِنَ الْحُدُودِ يَكْتَفَى بِهَا عِنْدَنَا ، خِلَافًا لِزُفَرٍ لَوْجُودِ الْأَكْثَرِ (245) ، بِخِلَافِ مَا إِذَا غَلِطَ فِي الرَّابِعَةِ ، لِأَنَّهُ يُخْتَلَفُ بِهِ الْمُدَّعَى وَلَا كَذَلِكَ بِتَرْكِهَا ، وَكَمَا يُشْتَرَطُ التَّحْدِيدُ فِي الدَّعْوَى يُشْتَرَطُ فِي الشَّهَادَةِ.

وَقَوْلُهُ فِي الْكِتَابِ (246) وَذَكَرَ أَنَّهُ فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَا بُدَّ مِنْهُ ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَنْتَصِبُ خَصْمًا إِذَا كَانَ فِي يَدِهِ ، وَفِي الْعَقَارِ لَا يَكْتَفَى بِذِكْرِ الْمُدَّعَى وَتَصَدِيقِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ فِي يَدِهِ ، بَلْ لَا تَنْبُتُ الْيَدُ فِيهِ إِلَّا بِالْبَيِّنَةِ ، أَوْ عِلْمِ الْقَاضِي ، هُوَ الصَّحِيحُ (247) نَفْيًا لِتُهْمَةِ الْمَوَاضَعَةِ ، إِذِ الْعَقَارُ عَسَاهُ فِي يَدِ غَيْرِهِمَا ، بِخِلَافِ الْمَنْقُولِ ، لِأَنَّ الْيَدَ فِيهِ مُشَاهَدَةٌ.

وَقَوْلُهُ : وَأَنَّهُ يُطَالِبُهُ بِهِ ، لِأَنَّ الْمُطَالِبَةَ حَقُّهُ فَلَا بُدَّ مِنْ طَلَبِهِ (248) ، وَلِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَرْهُونًا فِي يَدِهِ أَوْ مَحْبُوسًا بِالْثَّمَنِ فِي يَدِهِ ، وَبِالْمُطَالِبَةِ يَزُولُ هَذَا الْإِحْتِمَالُ ، وَعَنْ هَذَا قَالُوا فِي الْمَنْقُولِ : يَجِبُ أَنْ يَقُولَ : فِي يَدِهِ بِغَيْرِ حَقٍّ.

²⁴³ () لأنه إذا تعذر مشاهدة العين فالقيمة تقوم مقامها كما في الاستهلاك، إذ هي المقصود غالباً، ويذكر في القيمة شيئاً معيناً في قدره ووصفه وجنسه نفياً للجهالة لما بينا، وإن كان حيواناً يذكر الذكورة أو الأنوثة. الاختيار لتعليل المختار 110/2، البناية 317/9.

²⁴⁴ () أبو الليث : نصر بن محمد بن إبراهيم ، الإمام الفقيه الحنفي ، أبو الليث السمرقندي ، صاحب كتاب الفتاوى توفي سنة خمس وسبعين وثلاثمائة ، وقيل سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة هجرية. الفوائد البهية ، للكنوي ص 412 ، الوافي بالوفيات ، لصلاح الدين خليل بن أبيك بن عبد الله الصفدي (المتوفى: 764هـ) 54/27.

²⁴⁵ () لأن إقامة الأكثر مقام الكل أصل في الشرع . البناية 318/9.

²⁴⁶ () أي مختصر القدوري ، وهو أشهر المتون المعتمدة عند الحنفية . عقود رسم المفتي ص 45.

²⁴⁷ () الصحيح : هو لفظ يستعمل للترجيح بين الأقوال . الكواشف الجلية عن مصطلحات الحنفية عبد الإله بن محمد الملا ص 203.

²⁴⁸ () أي : لأن المطالبة حق المدعي ، فلا بد من طلبه حتى تجب على القاضي إعانتة . البناية 319/9.

قَالَ (249) (وَإِنْ كَانَ حَقًّا فِي الدَّيْنَةِ ذَكَرَ أَنَّهُ يُطَالِبُهُ بِهِ) لِمَا قُلْنَا (250)، وَهَذَا لِأَنَّ صَاحِبَ الدَّيْنَةِ قَدْ حَضَرَ ، فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الْمُطَالِبَةُ ، لَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ تَعْرِيفِهِ بِالْوَصْفِ لِأَنَّهُ يُعَرَّفُ بِهِ .

سؤال المدعى عليه عن الشيء المدعى به وإقراره بذلك : قَالَ (وَإِذَا صَحَّتِ الدَّعْوَى سَأَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْهَا)، لِيُنْكَشِفَ لَهُ وَجْهُ الْحُكْمِ ، (فَإِنْ اعْتَرَفَ قُضِيَ عَلَيْهِ بِهَا)، لِأَنَّ الْإِقْرَارَ مُوجِبٌ بِنَفْسِهِ ، فَيَأْمُرُهُ بِالْخُرُوجِ عَنْهُ .

مطالبة المدعى بالبينة عند إنكار المدعى عليه : (وَإِنْ أَنْكَرَ سَأَلَ الْمُدَّعِيَ الْبَيِّنَةَ) لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - " أَلَا بَيِّنَةٌ؟ فَقَالَ لَا ، فَقَالَ: "لَكَ يَمِينُهُ" (251) " سَأَلَ وَرَتَّبَ الْيَمِينَ عَلَى فَقْدِ الْبَيِّنَةِ ، فَلَا بُدَّ مِنَ السُّؤَالِ لِيُمكنَهُ الْإِسْتِحْلَافُ (252).

. قَالَ (فَإِنْ أَحْضَرَهَا قُضِيَ بِهَا)، لِإِنْتِفَاءِ التُّهْمَةِ عَنْهَا ، (وَإِنْ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ وَطَلَبَ يَمِينَ خَصْمِهِ) اسْتَحْلَفَهُ (عَلَيْهَا) ، لِمَا رَوَيْنَا، وَلَا بُدَّ مِنْ طَلْبِهِ ، لِأَنَّ الْيَمِينَ حَقُّهُ؛ أَلَا يَرَى أَنَّهُ كَيْفَ أُضِيفَ إِلَيْهِ بِحَرْفِ اللَّامِ فَلَا بُدَّ مِنْ طَلْبِهِ (253).

(249) (القدوري في مختصره . البناية 319/9).

(250) (إشارة إلى قوله: إن المطالبة حقه فلا بد من طلبه . البناية 320/9).

(251) (الإيمان لابن منده ، لأبي عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده العبدى (المتوفى: 395هـ) عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ رَقْم 580.

(252) (أي: فيمكن القاضي طلب اليمين من المدعى عليه . البناية 321/9).

(253) (قوله . " لِمَا رَوَيْنَا " ، يُرِيدُ بِهِ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَكَ يَمِينُهُ» ، وَلَا بُدَّ مِنْ طَلْبِهِ الْإِسْتِحْلَافَ ، لِأَنَّ الْيَمِينَ حَقُّهُ؛ أَلَا يَرَى أَنَّهُ كَيْفَ أُضِيفَ إِلَيْهِ بِحَرْفِ اللَّامِ فِي قَوْلِهِ " لَكَ يَمِينُهُ " ، قِيلَ : إِنَّمَا جَعَلَ يَمِينَ الْمُنْكَرِ حَقَّ الْمُدَّعِي ، لِأَنَّهُ يَزْعُمُ أَنَّ خَصْمَهُ أَتَوَى - أَهْلَكَ - حَقُّهُ بِإِنْكَارِهِ، فَالْشَّرْعُ جَعَلَ لَهُ حَقَّ اسْتِحْلَافِهِ، حَتَّى إِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَمَا زَعَمَ فَالْيَمِينَ الْعَمُوسُ مُهْلَكَةٌ لَخَصْمِهِ ، فَيَكُونُ إِثْوَاءً بِمُقَابَلَةِ إِثْوَاءٍ ، وَهُوَ مَشْرُوعٌ كَالْقَصَاصِ، وَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ بِخِلَافِ مَا زَعَمَ ، فَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَبَالُ الثَّوَابَ بِذِكْرِ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى صَادِقًا، ثُمَّ إِنَّمَا رَتَّبَ الْيَمِينَ عَلَى الْبَيِّنَةِ لَا عَلَى الْعَكْسِ ، لِأَنَّ نَفْسَ الدَّعْوَى لَيْسَتْ بِمُوجِبَةٍ اسْتِحْقَاقِ الْمُدَّعِي لِمَا ادَّعَاهُ، لِأَنَّ فِيهِ إِسَاءَةَ الظَّنِّ بِالْآخِرِ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ، فَوَجِبَ إِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْمُدَّعِي لِإثباتِ اسْتِحْقَاقِهِ بِهَا فَيُطَالِبُهُ الْقَاضِي بِذَلِكَ لَا عَلَى وَجْهِ الْإِلْزَامِ عَلَيْهِ بَلْ عَلَى وَجْهِ التَّذْكِيرِ لَهُ، فَلَوْ قَدَّمْنَا الْيَمِينَ لَمْ يَكُنْ فِيهِ نَظَرٌ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ، إِذْ إِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ مَشْرُوعَةٌ بَعْدَ الْيَمِينَ، فَمِنْ الْجَائِزِ إِقَامَتُهَا بَعْدَهَا، وَفِي ذَلِكَ افْتِصَاحُهُ بِالْيَمِينَ الْكَاذِبَةِ . العناية شرح الهداية 169/8.

(بَابُ الْيَمِينِ)

طلب اليمين من المدعى عليه مع وجود البيينة : " (وَإِذَا قَالَ الْمُدَّعِي لِي بَيِّنَةٌ حَاضِرَةٌ وَطَلَبَ الْيَمِينَ) ⁽²⁵⁴⁾ (لَمْ يُسْتَحْلَفْ) عِنْدَ أَبِي - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، مَعْنَاهُ : حَاضِرَةٌ فِي الْمِصْرِ ⁽²⁵⁵⁾ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : يُسْتَحْلَفُ ، لِأَنَّ الْيَمِينَ حَقُّهُ بِالْحَدِيثِ الْمَعْرُوفِ ، فَإِذَا طَالَبَهُ بِهِ يُجِيبُهُ ، وَلِأَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : أَنَّ ثُبُوتَ الْحَقِّ فِي الْعَيْنِ مُرْتَبِّ عَلَى الْعَجْزِ عَنْ إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ ، لِمَا رَوَيْنَا ، فَلَا يَكُونُ حَقُّهُ دُونَهُ ، كَمَا إِذَا كَانَتْ الْبَيِّنَةُ حَاضِرَةً فِي الْمَجْلِسِ ، وَمَحَمَّدٌ مَعَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ فِيمَا ذَكَرَهُ الْخَصَافُ ⁽²⁵⁶⁾ ، وَمَعَ أَبِي حَنِيفَةَ فِيمَا ذَكَرَهُ الطَّحَاوِيُّ .

رد اليمين على المدعى : قَالَ (وَلَا تُرَدُّ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي) لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - "الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ" ⁽²⁵⁷⁾ " قَسَمَ ، وَالْقِسْمَةُ تُنَافِي الشَّرَكَةَ ، وَجَعَلَ جِنْسَ الْأَيْمَانِ عَلَى الْمُنْكَرِينَ ، وَلَيْسَ وَرَاءَ الْجِنْسِ شَيْءٌ ⁽²⁵⁸⁾ ، وَفِيهِ خِلَافُ الشَّافِعِيِّ ⁽²⁵⁹⁾ - رَحِمَهُ اللَّهُ -

²⁵⁴ () اليمين لغة: اليد اليمنى ، أو هو خلاف اليسار ، وإنما سمي القسم يميناً ، لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل واحد منهم يمينه على يمين صاحبه ، وقيل اليمين لغة : القوة والقدرة ، وفي الشرع : عبارة عن تقوية الخبر بذكر الله تعالى ، أو بصفة من صفاته على وجه مخصوص ، أو تعليق الجزاء على الشرط على وجه ينزل الجزاء عند وجود الشرط " ، قال العيني : "قال الأتراسي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : ما كان يحتاج هنا إلى الفصل بالباب ، بل كان ينبغي أن يسوق الكلام متوالياً ، لأنه لما ذكر صحة الدعوى ترتب عليها الحكم بالإقرار والبيينة واليمين ، قلت - بدر الدين العيني- : الذي رتبته المصنف هو الأصل ، لأنه لما كانت اليمين مشروعة بعد فقد البيينة تعين ذكرها بعدها بأحكامها وشرائطها " . المغرب في ترتيب المعرب ، لأبي الفتح المطرزي ص 512 ، كشف اصطلاحات الفنون ، للتهانوي 418/3 ، البناية 323/9 .

²⁵⁵ () احترز به عن البيينة الحاضرة في مجلس الحكم ، فحينئذ لا يجوز الحكم باليمين بالإجماع ، وإن طلب الخصم ، واحترز به أيضاً عما إذا كانت البيينة غائبة عن المصير ، فحينئذ يستحلف بالاتفاق . البناية 323/9 .

²⁵⁶ () الخصاف : لقب أحمد بن عمرو الشيباني الإمام أبو بكر مؤلف الشروط 261 هـ . الجواهر المضية في طبقات الحنفية 400/1 ، معجم المؤلفين 35/2 .

²⁵⁷ () السنن الصغرى ، للبيهقي ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، مرسلاً ، رقم 3103 ، سنن الدار قطنى رقم 4508 .

²⁵⁸ () وبقول الحنفية ، قال بعض المالكية كاللخمي والمازري ، والظاهرية ، قال البابرتي : " وَلَا تُرَدُّ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَسَمَ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ فَجَعَلَ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ ، وَالْقِسْمَةُ تُنَافِي الشَّرَكَةَ ، لِأَنَّهَا تَقْتَضِي عَدَمَ التَّمْيِيزِ ، وَالْقِسْمَةُ تَقْتَضِيهِ الْعَيْنَاةُ 172/8 ، وفي هذا : التاج والإكليل 236/8 ، كشف القناع 567/6 ، المحلى 371/9 .

²⁵⁹ () حيث قال : برد اليمين إلى المدعى ، وهو مذهب مالك وكافة أصحابه ، وصوبه أحمد ، لقوله تعالى : {.. أَوْ يَخَافُوا أَنَّ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ..} سورة المائدة: 108 ، والآية واضحة الدلالة في رد

التعارض بين بينة صاحب اليد وبينة الخارج في الملك المطلق : "قَالَ (وَلَا تُقْبَلُ بَيِّنَةُ صَاحِبِ
الْيَدِ فِي الْمَلِكِ الْمُطْلَقِ)⁽²⁶⁰⁾، وَبَيِّنَةُ الْخَارِجِ أَوْلَى. ()⁽²⁶¹⁾

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُقْضَى بِبَيِّنَةِ ذِي الْيَدِ ، لِاعْتِصَادِهَا بِالْيَدِ ، فَيَتَقَوَّى الظُّهُورُ ، وَصَارَ كَالنَّتَاجِ
وَالنِّكَاحِ ، وَدَعْوَى الْمَلِكِ مَعَ الْإِعْتَاقِ وَالِاسْتِيلَادِ وَالتَّدْبِيرِ. ()⁽²⁶²⁾

وَلَنَا : أَنَّ بَيِّنَةَ الْخَارِجِ أَكْثَرُ إِبْتِنَاءًا أَوْ إِظْهَارًا ، لِأَنَّ قَدْرَ مَا أَتْبَهَتْ الْيَدُ لَا يُتْبَهُ بِبَيِّنَةِ ذِي الْيَدِ ، إِذْ
الْيَدُ دَلِيلُ مُطْلَقِ الْمَلِكِ ، بِخِلَافِ النَّتَاجِ ، لِأَنَّ الْيَدَ لَا تَدُلُّ عَلَيْهِ ، وَكَذَا عَلَى الْإِعْتَاقِ وَأَخْتِيهِ ،
وَعَلَى الْوَلَاءِ الثَّابِتِ بِهَا. ()⁽²⁶³⁾

اليمين على المدعى عند عجز المدعى عليه عن إقامة البينة ، وقد ردت اليمين على عمر (رضى
الله عنه) فحلف واستحق ، وردت على زيد بن ثابت (رضى الله عنه) واستحق ، وهذا مستفيض بين
الصحابه دون نكير ، فثبت أنه إجماع ، ولا حجة فيما تمسك به الحنفية من حديث : البينة على
المدعى .. " ، لأنه يفيد توجيه اليمين إلى المدعى عليه عند عجز المدعى عن إقامة البينة ، وإنما
محل الخلاف في نقل اليمين إلى المدعى ، عند نكول المدعى عليه عن اليمين ، فالراجح ما قال به
الشافعي ، ومن معه . التاج والإكليل 236/8 ، الذخيرة 46/11 ، الحاوي 140/17 ، نهاية
المحتاج 357/8 ، الطرق الحكيمة ، لابن القيم ص 126 .

⁽²⁶⁰⁾ () وَقَيَّدَ بِالْمَلِكِ الْمُطْلَقِ ، اخْتِرَازًا عَنِ الْمُفَيِّدِ بِدَعْوَى النَّتَاجِ ، وَعَنْ الْمُفَيِّدِ بِمَا إِذَا ادَّعَى تَلَقَّى الْمَلِكُ
مِنْ وَاحِدٍ وَأَحَدُهُمَا قَابِضٌ ، وَبِمَا إِذَا ادَّعَى الشَّرَاءَ مِنْ اثْنَيْنِ ، وَتَارِيخُ أَحَدِهِمَا أَسْبَقُ ، فَإِنَّ فِي هَذِهِ
الصُّورِ تُقْبَلُ بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ بِالْإِجْمَاعِ . العناية على الهداية 173/8 .

⁽²⁶¹⁾ () وهو قول أبي حنيفة ومحمد ، وهو المفتى به ، وقول عبد الملك بن المجشون ، ورواية عتن
أحمد وهو المشهور ، وقول الظاهرية ، واستدلوا : بحديث : "البينة على المدعى .." ، ولأن بينة
الخارج بها زيادة علم ، فتقدم ، كتقديم من من شهد له أنه اشتراه من أبيه على من شهد له أنه ورثه
عن أبيه . البسوط 65 / 15 ، منحة الخالق على البحر الرائق 193/7 ، الذخيرة 193/10 ، التوضيح
، لابن إسحاق 124/6 ، 130 ، كشف القناع 496/6 ، المحلى 436/9 .

⁽²⁶²⁾ () وهو قول أبي يوسف من الحنفية ، والمشهور عند المالكية ، وقول الأصحاب من الشافعية
، ورواية عن أحمد ، وبه قال شريح والنخعي وأبو ثور ، وهو المحكي عن الشيخ أبي علي ،
واستدلوا : بما رواه جابر بن عبد الله أن رجلين تداخيا بدابة ، فأقام كل واحد منهما البينة أنها دابته
، فقضى بها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) للذي هي في يديه " رواه البيهقي وإسناده ضعيف ،
ولأن كلا من الخارج وصاحب اليد تساويا في إقامة البينة وانفرد أحدهما باليد ، فوجب أن تقدم
بينته من أجل اليد ، وحديث البينة الذي استدل به الحنفية خارج عن محل النزاع ، قال : ابن القاسم
: " إن هذا إنما هو إذا لم يأت المدعى عليه بمثلما أتى به المدعى " ، فالراجح ما قال به الشافعية
ومن معهم . التوضيح لابن إسحاق 124/6 وفي هذا المبسوط 64/17 ، 65 ، الذخيرة 193/10 ،
11/11 ، نهاية المحتاج 362/8 ، كشف القناع 496/6 ، فتاوى ابن الصلاح 719/2 ، كفاية النبيه
شرح التنبيه 529/18 ، العزبز شرح الوجيز 417/6 .

⁽²⁶³⁾ () وهو قول بعض الشافعية : كما حكاه الشيخ أبو علي عن ابن سريج . كفاية النبيه في شرح
التنبيه 529/18 .

القضاء بالنكول على المدعى عليه: "قَالَ (وَإِذَا نَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنِ الْيَمِينِ قُضِيَ عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ ، وَالزَّمَهُ مَا ادَّعَى عَلَيْهِ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يُقْضَى بِهِ بَلْ يَرُدُّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى ، فَإِذَا حَلَفَ يَقْضَى بِهِ ، لِأَنَّ النُّكُولَ يَحْتَمِلُ التَّوَرُّعَ عَنِ الْيَمِينِ الْكَاذِبَةِ ، وَالتَّرَفُّعَ عَنِ الصَّادِقَةِ ، وَاسْتِبَاهَ الْحَالِ ، فَلَا يَنْتَصِبُ حُجَّةٌ مَعَ الْإِحْتِمَالِ ، وَيَمِينُ الْمُدَّعَى دَلِيلُ الظُّهُورِ ، فَيُصَارُ إِلَيْهِ.

وَلَنَا : أَنَّ النُّكُولَ دَلٌّ عَلَى كَوْنِهِ بَازِلًا أَوْ مُقَرًّا ، إِذْ لَوْلَا ذَلِكَ لَأَقْدَمَ عَلَى الْيَمِينِ إِقَامَةً لِلْوَاجِبِ ، وَدَفَعًا لِلضَّرَرِ عَنْ نَفْسِهِ ، فَتَرَجَّحَ هَذَا الْجَانِبُ ، وَلَا وَجْهَ لِرَدِّ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى لِمَا قَدَّمْنَاهُ²⁶⁴).

إنذار المدعى عليه بالقضاء بالنكول عند الإنكار: "قَالَ (وَيَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَقُولَ لَهُ إِنِّي أَعْرِضُ عَلَيْكَ الْيَمِينَ ثَلَاثًا ، فَإِنْ حَلَفْتَ ، وَإِلَّا قُضِيَتْ عَلَيْكَ بِمَا ادَّعَاهُ) ، وَهَذَا الْإِنْذَارُ ، لِإِعْلَامِهِ بِالْحُكْمِ إِذْ هُوَ مَوْضِعُ الْخَفَاءِ.

قَالَ (فَإِذَا كَرَّرَ الْعَرَضَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قُضِيَ عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ) وَهَذَا التَّكْرَارُ ذِكْرُهُ الْخَصَافُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لِزِيَادَةِ الْإِحْتِيَاطِ ، وَالْمُبَالَغَةِ فِي إِبْلَاءِ الْعُذْرِ ، فَأَمَّا الْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَوْ قُضِيَ بِالنُّكُولِ بَعْدَ الْعَرَضِ مَرَّةً جَازَ ، لِمَا قَدَّمْنَاهُ هُوَ الصَّحِيحُ ، وَالْأَوَّلُ أَوْلَى²⁶⁵).

كيفية النكول: ثُمَّ النُّكُولُ قَدْ يَكُونُ حَقِيقًا كَقَوْلِهِ لَا أَحْلِفُ ، وَقَدْ يَكُونُ حُكْمِيًّا بِأَنْ يَسْكُتَ ، وَحُكْمُهُ حُكْمُ الْأَوَّلِ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ لَا آفَةَ بِهِ مِنْ طَرَشٍ أَوْ خَرَسٍ هُوَ الصَّحِيحُ²⁶⁶).

الدعاوى التي لا يستحلف فيها المنكر: "قَالَ (وَإِنْ كَانَتْ الدَّعْوَى نِكَاحًا لَمْ يُسْتَحْلَفْ الْمُنْكَرُ) عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، وَلَا يُسْتَحْلَفُ عِنْدَهُ فِي النِّكَاحِ ، وَالرَّجْعَةِ ، وَالْفَيْءِ فِي الْإِيلَاءِ ،

²⁶⁴ () راجع في هذا مسألة رد اليمين على المدعى .

²⁶⁵ () قوله: "لما قدمناه": إشارة إلى ما ذكر، إذ النكول دل على كونه باذلاً أو مقراً، كذا قاله الأتراسي، والكاكي، والأكمل - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - .

وقال تاج الشريعة: قوله: "لما قدمناه": يعني أنه لولا كونه كاذباً لأقدم على اليمين إقامته للجواب ، وقوله: "هو الصحيح" ، قال الأتراسي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : احتراز عن قول الخصاف ، فإنه يشترط التكرار ، وقال الأكمل: احتراز عما قيل - لو قضى بالنكول مرة واحدة لا ينفذ ، وهذا هو الأوجه ، وقوله: "والأول أولى" ، أي ما ذكره الخصاف أولى ، كما في الإمهال للمرتد ، فإن قتل بلا إمهال جاز. البناية 329/9.

²⁶⁶ () أشار به إلى اختلاف الروايات فيما إذا سكت المدعى عليه بعد عرض اليمين عليه ولم يقل - لا أحلف ، فقال بعض أصحابنا: إذا سكت المدعى عليه سأل القاضي: هل به خرس أو طرش؟ فإذا قالوا: لا ، جعله ناكلاً ، وقضى عليه ، ومنهم من قال: يحبس حتى يجيب ، والأول هو الصحيح . البناية 329/9.

وَالرَّقِّ ، وَالِاسْتِيلَادِ ، وَالنَّسَبِ وَالْوَلَاءِ وَالْحُدُودِ وَاللَّعَانِ. وَقَالَا: يُسْتَحْلَفُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ، إِلَّا فِي الْحُدُودِ وَاللَّعَانِ.

وَصُورَةُ الْإِسْتِيلَادِ : أَنْ تَقُولَ الْجَارِيَةُ أَنَا أُمُّ وَلَدٍ لِمَوْلَايَ ، وَهَذَا ابْنِي مِنْهُ ، وَأَنْكَرَ الْمَوْلَى ، لِأَنَّهُ لَوْ ادَّعَى الْمَوْلَى ثَبَتَ الْإِسْتِيلَادُ بِإِقْرَارِهِ ، وَلَا يُلْتَقَتُ إِلَى إِنْكَارِهَا. لَهُمَا : أَنَّ النُّكُولَ إِقْرَارٌ ، لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى كَوْنِهِ كَاذِبًا فِي الْإِنْكَارِ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ، إِذْ لَوْ لَا ذَلِكَ لَأَقْدَمَ عَلَى الْيَمِينِ الصَّادِقَةِ إِقَامَةً لِلْوَاجِبِ ، فَكَانَ إِقْرَارًا ، أَوْ بَدَلًا عَنْهُ²⁶⁷) ، وَالْإِقْرَارُ يَجْرِي فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ لَكِنَّهُ إِقْرَارٌ فِيهِ شُبْهَةٌ، وَالْحُدُودُ تَنْدَرِي بِالشُّبُهَاتِ، وَاللَّعَانُ فِي مَعْنَى الْحَدِّ.

وَلِأَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - : أَنَّهُ بَدَلٌ ، لِأَنَّ مَعَهُ لَا تَبْقَى الْيَمِينُ وَاجِبَةً ، لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ ، وَإِنْزَالُهُ بِأَدْلَى أَوْلَى ، كَيْ لَا يَصِيرَ كَاذِبًا فِي الْإِنْكَارِ، وَالْبَدَلُ لَا يَجْرِي فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ.

فائدة الاستحلاف : "وَفَائِدَةُ الْإِسْتِحْلَافِ ، الْقَضَاءُ بِالنُّكُولِ ، فَلَا يُسْتَحْلَفُ، إِلَّا أَنْ هَذَا بَدَلٌ لِدَفْعِ الْخُصُومَةِ فَيَمْلِكُهُ الْمَكَاتِبُ وَالْعَبْدُ الْمَأْذُونُ ، بِمَنْزِلَةِ الضِّيَافَةِ الْيَسِيرَةِ، وَصِحَّتُهُ فِي الدِّينِ بِنَاءً عَلَى زَعْمِ الْمُدْعِي وَهُوَ مَا يَقْبِضُهُ حَقًّا لِنَفْسِهِ، وَالْبَدَلُ مَعْنَاهُ هَاهُنَا تَرْكُ الْمَنْعِ وَأَمْرُ الْمَالِ هَيْئًا.

استحلاف السارق : "قَالَ (وَيُسْتَحْلَفُ السَّارِقُ، فَإِنْ نَكَلَ ضَمِنَ وَلَمْ يَقْطَعْ) لِأَنَّ الْمَنُوطَ بِفِعْلِهِ شَيْئَانِ: الضَّمَانُ وَيَعْمَلُ فِيهِ النُّكُولُ ، وَالْقَطْعُ ، وَلَا يَتَّبْتُ بِهِ ، فَصَارَ كَمَا إِذَا شَهِدَ عَلَيْهَا رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ²⁶⁸).

استحلاف الزوج في دعوى الطلاق قبل الدخول والنسب: "قَالَ (وَإِذَا ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ طَلَاقًا قَبْلَ الدُّخُولِ أُسْتَحْلَفَ الزَّوْجُ، فَإِنْ نَكَلَ ضَمِنَ نِصْفَ الْمَهْرِ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا) ، لِأَنَّ الْإِسْتِحْلَافَ يَجْرِي فِي الطَّلَاقِ عِنْدَهُمْ ، لَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ الْمَقْصُودُ هُوَ الْمَالُ، وَكَذَا فِي النِّكَاحِ إِذَا ادَّعَتْ هِيَ الصَّدَاقَ ، لِأَنَّ ذَلِكَ دَعْوَى الْمَالِ، ثُمَّ يَتَّبْتُ الْمَالُ بِنُّكُولِهِ وَلَا يَتَّبْتُ النِّكَاحَ، وَكَذَا فِي النَّسَبِ ، إِذَا ادَّعَى حَقًّا ، كَالْإِرْثِ وَالْحَجْرِ فِي اللَّقِيطِ، وَالنَّفَقَةِ وَامْتِنَاعِ الرُّجُوعِ فِي الْهَبَةِ، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ هَذِهِ الْحُقُوقُ، وَإِنَّمَا يُسْتَحْلَفُ فِي النَّسَبِ الْمُجَرَّدِ عِنْدَهُمَا ، إِذَا كَانَ يَتَّبْتُ بِإِقْرَارِهِ ، كَالْأَبِ وَالْإِبْنِ فِي حَقِّ الرَّجُلِ ، وَالْأَبِ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ، لِأَنَّ فِي دَعْوَاهَا الْإِبْنَ تَحْمِيلَ النَّسَبِ عَلَى الْغَيْرِ وَالْمَوْلَى وَالزَّوْجَ فِي حَقِّهِمَا.

²⁶⁷ () أى خلفا عن الإقرار : يعنى أنه قائم مقام الإقرار . تكملة فتح القدير 182/8.

²⁶⁸ () قوله : "ولا يثبت به " ، أى ولا يثبت القطع بالنكول ، لأنه لا يجري البذل بالنكول في الحدود، ولا يثبت بما فيه شبهة الإقرار " فصار " حكم هذا ، "كما إذا شهد عليه" ، أى على السرقة "رجل وامرأتان " حيث يثبت المال فلا يثبت القطع. البناية 334/9.

استحلاف المدعى عليه بالقصاص: قَالَ (وَمَنْ أَدَّعَى قِصَاصًا عَلَى غَيْرِهِ فَجَدَّهَ اسْتَحْلَفَ) ، بِالْإِجْمَاعِ ، (ثُمَّ إِنْ نَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ ، يَلْزَمُهُ الْقِصَاصُ ، وَإِنْ نَكَلَ فِي النَّفْسِ ، حُبَسَ حَتَّى يَحْلِفَ أَوْ يَقْرَأَ) وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، وَقَالَا: لَزِمَهُ الْأَرْضُ فِيهِمَا ، لِأَنَّ النُّكُولَ إِقْرَارٌ فِيهِ شُبْهَةٌ عِنْدَهُمَا ، فَلَا يَثْبُتُ بِهِ الْقِصَاصُ ، وَيَجِبُ بِهِ الْمَالُ ، خُصُوصًا إِذَا كَانَ امْتِنَاعُ الْقِصَاصِ لِمَعْنَى مِنْ جِهَةٍ مَنْ عَلَيْهِ ، كَمَا إِذَا أَقْرَأَ بِالْخَطَا وَالْوَلِيِّ يَدَّعِي الْعَمَدَ (269) . وَلَا أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّ الْأَطْرَافَ يُسَلِّكُ بِهَا مَسْلَكَ الْأَمْوَالِ ، فَيَجْرِي فِيهَا الْبَذْلُ ، بِخِلَافِ الْأَنْفُسِ ، فَإِنَّهُ لَوْ قَالَ : أَقْطَعُ يَدِي ، فَقَطَعَهَا لَا يَجِبُ الضَّمَانُ ، وَهَذَا إِعْمَالٌ لِلْبَذْلِ ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يُبَاحُ ، لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ ، وَهَذَا الْبَذْلُ مُفِيدٌ لِانْدِفَاعِ الْخُصُومَةِ بِهِ ، فَصَارَ كَقَطْعِ الْيَدِ لِلْأَكْلَةِ ، وَقَلْعِ السِّنِّ لِلْوَجَعِ ، وَإِذَا امْتَنَعَ الْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ ، وَالْيَمِينُ حَقٌّ مُسْتَحَقٌّ يُحْبَسُ بِهِ (270) ، كَمَا فِي الْقِسَامَةِ (271) .

الكفالة بالنفس عن المدعى عليه للحضور أمام القضاء : "قَالَ (272) : (وَإِذَا قَالَ الْمُدَّعِي : لِي بَيِّنَةٌ حَاضِرَةٌ ، قِيلَ لَخَصْمَةٍ : أَعْطِهِ كَفِيلًا بِنَفْسِكَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) كَى لَا يَغِيبُ نَفْسَهُ ، فَيَضِيعَ حَقُّهُ ، وَالْكَفَالَةُ بِالنَّفْسِ جَائِزَةٌ عِنْدَنَا ، وَقَدْ مَرَّ مِنْ قَبْلُ ، وَأَخَذَ الْكَفِيلُ بِمُجَرَّدِ الدَّعْوَى اسْتِحْسَانًا عِنْدَنَا ، لِأَنَّ فِيهِ نَظَرًا لِلْمُدَّعِي ، وَلَيْسَ فِيهِ كَثِيرٌ ضَرَرٍ بِالْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، وَهَذَا لِأَنَّ الْحُضُورَ مُسْتَحَقٌّ عَلَيْهِ بِمُجَرَّدِ الدَّعْوَى حَتَّى يُعَدَّى عَلَيْهِ وَيُحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَشْغَالِهِ فَصَحَّ التَّكْفِيلُ بِإِحْضَارِهِ (273) ، وَالتَّقْدِيرُ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مَرُويٌّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَلَا

(269) () وَلِأَنَّهُ لَمْ يُصَرِّحْ بِالْإِقْرَارِ فَأَشْبَهَ الْخَطَا ، وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْاِمْتِنَاعُ مِنْ جَانِبِ مَنْ لَهُ ، كَمَا إِذَا أَقَامَ مُدَّعِي الْقِصَاصِ رَجُلًا وَأَمْرَأَتَيْنِ أَوْ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ فَإِنَّهُ لَا يُفْضَى بِشَيْءٍ ، لِأَنَّ الْحُجَّةَ قَامَتْ بِالْقِصَاصِ لَكِنْ تَعَدَّرَ اسْتِيفَاؤُهُ وَلَمْ يُشْبَهِ الْخَطَا فَلَا يَجِبُ شَيْءٌ ، وَلَا تَفَاوُتٌ فِي هَذَا الْمَعْنَى بَيْنَ النَّفْسِ وَمَا دُونَهَا. العناية 191/8.

(270) () وَلَا أَبِي حَنِيفَةَ : أَنَّ الْأَطْرَافَ يُسَلِّكُ بِهَا مَسْلَكَ الْأَمْوَالِ ، لِأَنَّهَا خُلِقَتْ وَقَايَةً لِلنَّفْسِ ، كَالْأَمْوَالِ فَيَجْرِي فِيهَا الْبَذْلُ ، إِلَّا تَرَى أَنَّهُ لَوْ قَالَ أَقْطَعُ يَدِي فَقَطَعَهَا لَا يَجِبُ الضَّمَانُ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا مِنْ حَيْثُ إِعْمَالُ الْبَذْلِ ، بِخِلَافِ الْأَنْفُسِ حَيْثُ لَا يَجْرِي فِيهَا الْبَذْلُ ، فَإِنَّهُ لَوْ قَالَ أَقْتُلْنِي فَقَتَلَهُ يُؤْخَذُ بِالْقِصَاصِ فِي رَوَايَةٍ وَبِالدِّيَةِ فِي أُخْرَى. فَإِنْ قِيلَ: لَوْ كَانَتْ الْأَطْرَافُ يُسَلِّكُ بِهَا مَسْلَكَ الْأَمْوَالِ لَجَازَ قَطْعُ يَدِهِ مِنْ غَيْرِ إِثْمٍ إِذَا قَالَ أَقْطَعُ يَدِي ، كَمَا يُبَاحُ لَهُ أَخْذُ مَالِهِ إِذَا قَالَ خُذْ مَالِي.

أَجَابَ بِقَوْلِهِ : إِلَّا أَنَّهُ لَا يُبَاحُ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ ، حَتَّى لَوْ كَانَ الْقَطْعُ مُفِيدًا كَالْقَطْعِ لِلْأَكْلَةِ وَقَلْعِ السِّنِّ لِلْوَجَعِ لَمْ يَأْتُمْ بِفِعْلِهِ ، وَمَا نَحْنُ فِيهِ مِنَ الْبَذْلِ: أَيْ الَّذِي بِالنُّكُولِ مُفِيدٌ ، لِانْدِفَاعِ الْخُصُومَةِ بِهِ فَيَكُونُ مُبَاحًا . العناية 191/8 ، 192.

(271) () فَإِنَّهُمْ إِذَا نَكَلُوا عَنِ الْيَمِينِ يَحْبَسُونَ ، حَتَّى يَقْرَأُوا أَوْ يَحْلِفُوا. قرة عيون الأخيار لتكملة رد المحتار 59/8.

(272) () الْقُدُورِي فِي مَخْتَصَرِهِ . تكملة فتح القدير 192/8.

(273) () أَمَّا جَوَازُ التَّكْفِيلِ فَهُوَ اسْتِحْسَانٌ ، وَالْفَيَاسُ يَأْبَاهُ قَبْلَ إِقَامَةِ الْحُجَّةِ ، وَوَجْهُ ذَلِكَ : أَنَّ الْحُضُورَ بِمُجَرَّدِ الدَّعْوَى مُسْتَحَقٌّ عَلَيْهِ حَتَّى لَوْ امْتَنَعَ عَنْهُ يُعَدَّى عَلَيْهِ ، وَيُحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَشْغَالِهِ فَيَصِحُّ

فَرَّقَ فِي الظَّاهِرِ بَيْنَ الْخَامِلِ وَالْوَجِيهِ وَالْحَقِيرِ مِنَ الْمَالِ وَالْخَطِيرِ، ثُمَّ لَا بُدَّ مِنْ قَوْلِهِ لِي بَيِّنَةٌ حَاضِرَةٌ لِلتَّكْفِيلِ وَمَعْنَاهُ فِي الْمِصْرِ، حَتَّى لَوْ قَالَ الْمُدَّعِي لَا بَيِّنَةٌ لِي أَوْ شُهُودِي غَيْبٌ لَا يُكْفَلُ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ.

قَالَ (فَإِنْ فَعَلَ وَإِلَّا أُمِرَ بِمُلَازِمَتِهِ) ، كَيْ لَا يَذْهَبَ حَقُّهُ ، (إِلَّا أَنْ يَكُونَ غَرِيبًا فَيُلَازِمَ مَقْدَارَ مَجْلِسِ الْقَاضِي) ، وَكَذَا لَا يُكْفَلُ إِلَّا إِلَى آخِرِ الْمَجْلِسِ، فَالِاسْتِثْنَاءُ مُنْصَرَفٌ إِلَيْهِمَا ، لِأَنَّ فِي اخْذِ الْكَفِيلِ وَالْمُلَازِمَةِ زِيَادَةً عَلَى ذَلِكَ إِضْرَارًا بِهِ بِمَنْعِهِ عَنِ السَّفَرِ ، وَلَا ضَرَرَ فِي هَذَا الْمَقْدَارِ ظَاهِرًا، وَكَيْفِيَّةُ الْمُلَازِمَةِ نَذْرُهَا فِي كِتَابِ الْحَجْرِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.(²⁷⁴)

(فَصَلِّ فِي كَيْفِيَّةِ الْيَمِينِ وَالِاسْتِحْلَافِ)

بِمَ يَكُونُ الْحَلْفُ لِلْمُسْلِمِ : "قَالَ (وَالْيَمِينُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ دُونَ غَيْرِهِ) لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - "مَنْ كَانَ مِنْكُمْ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَذَرُ"⁽²⁷⁵⁾ ، وَقَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - "مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ."⁽²⁷⁶⁾

كَيْفِيَّةُ تَغْلِيظِ الْيَمِينِ عَلَى الْمُسْلِمِ : (وَقَدْ تُؤَكَّدُ بِذِكْرِ أَوْصَافِهِ) وَهُوَ التَّغْلِيظُ، وَذَلِكَ مِثْلُ قَوْلِهِ: قُلْ وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، الَّذِي يَعْلَمُ مِنَ السِّرِّ مَا يَعْلَمُ مِنَ الْعَلَانِيَةِ، مَا لِفُلَانٍ هَذَا عَلَيْكَ ، وَلَا قَبْلَكَ هَذَا الْمَالُ الَّذِي ادَّعَاهُ وَهُوَ كَذَا وَكَذَا وَلَا شَيْءَ مِنْهُ ، وَلَهُ أَنْ يَزِيدَ فِي التَّغْلِيظِ عَلَى هَذَا ، وَلَهُ أَنْ يَنْقُصَ مِنْهُ، إِلَّا أَنَّهُ يَحْتَاطُ فِيهِ كَيْ لَا يَتَكَرَّرَ عَلَيْهِ الْيَمِينُ، لِأَنَّ الْمُسْتَحَقَّ يَمِينٌ وَاحِدَةً، وَالْقَاضِي بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ غَلَطَ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُغْلَظْ فَيَقُولُ: قُلْ بِاللَّهِ أَوْ بِاللَّهِ، وَقِيلَ: لَا يُغْلَظُ عَلَى الْمَعْرُوفِ بِالصَّلَاحِ ، وَيُغْلَظُ عَلَى غَيْرِهِ، وَقِيلَ: يُغْلَظُ فِي الْخَطِيرِ مِنَ الْمَالِ دُونَ الْحَقِيرِ.

التَّكْفِيلُ بِإِحْضَارِهِ نَظْرًا لِلْمُدَّعِي وَضَرَرُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِهِ يَسِيرُ فَيُتَحَمَّلُ كَالْإِعْدَاءِ وَالْحَيْلُولَةُ بَيِّنَةٌ وَبَيِّنٌ أَشْغَالِهِ. العناية على الهداية 193/8.

⁽²⁷⁴⁾ () وتفسير الملازمة : أن يدور معه حيث دار، ويبعث أميناً حتى يدور معه أينما دار، لكن لا يحبس في موضع ، لأن ذلك حبس، وهو غير مستحق عليه بنفس الدعوى، ولا يشغله عن التصرف ، بل يتصرف ، والمدعي يدور معه ، ولا يمنع من الدخول إلى أهله ، لكن المطلوب يجلس على باب داره . البناية على الهداية 340/9.

⁽²⁷⁵⁾ () متفق عليه بين الشيخين : البخاري رقم 2679، مسلم رقم 1646/3، عن ابن عمر (رضي الله عنهما) بلفظ : "... أو ليصمت".

⁽²⁷⁶⁾ () رواه ابن حبان في صحيحه ، ولأن المسلم الورع يعتقد تعظيم اسم الله تعالى ، فصلح ذكره . تبين الحقائق وحاشية الشلبي 419/3، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ، لابن بلبان رقم 4358.

الاستحلاف بالطلاق : قَالَ (وَلَا يَسْتَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ وَلَا بِالْعَتَاقِ) لِمَا رَوَيْنَا، وَقِيلَ فِي زَمَانِنَا إِذَا أَلَحَّ الْخَصْمُ سَاعَ لِلْقَاضِي أَنْ يَحْلِفَ بِذَلِكَ لِقَلَّةِ الْمُبَالَاةِ بِالْيَمِينِ بِاللَّهِ وَكَثْرَةِ الْإِمْتِنَاعِ بِسَبَبِ الْحَلْفِ بِالطَّلَاقِ).²⁷⁷

استحلاف غير المسلم : "قَالَ (وَيَسْتَحْلِفُ الْيَهُودِيُّ بِاللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَةَ عَلَى مُوسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ -، وَالنَّصْرَانِيُّ بِاللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ الْإِنْجِيلَ عَلَى عِيسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ -) «لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لِابْنِ صُورِيَّا الْأَعُورِ " أَنْشُدْكَ بِاللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَةَ عَلَى مُوسَى أَنْ حُكِمَ الزَّنا فِي كِتَابِكُمْ هَذَا (278)" ، وَلِأَنَّ الْيَهُودِيَّ يَعْتَقِدُ نُبُوَّةَ مُوسَى وَالنَّصْرَانِيَّ نُبُوَّةَ عِيسَى - عَلَيْهِمَا السَّلَامُ - فَيُعْلَظُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِذِكْرِ الْمَنْزَلِ عَلَى نَبِيِّهِ ، (و) يَسْتَحْلِفُ (الْمَجُوسِيُّ بِاللَّهِ الَّذِي خَلَقَ النَّارَ) (279)) وَهَكَذَا ذَكَرَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي الْأَصْلِ (280) ، يُرَوَى عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي النَّوَادِرِ (281): أَنَّهُ لَا يَسْتَحْلِفُ أَحَدًا إِلَّا بِاللَّهِ خَالِصًا، وَذَكَرَ الْخَصَّافُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّهُ لَا يَسْتَحْلِفُ غَيْرَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ إِلَّا بِاللَّهِ، وَهُوَ اخْتِيَارُ بَعْضِ مَشَايخِنَا ، لِأَنَّ فِي ذِكْرِ النَّارِ مَعَ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى تَعْظِيمًا ، وَمَا يَنْبَغِي أَنْ تُعْظَمَ (282)، بِخِلَافِ الْكِتَابَيْنِ ، لِأَنَّ كُتُبَ اللَّهِ مُعْظَمَةٌ (وَالْوَتْنِي لَا يَحْلِفُ إِلَّا بِاللَّهِ) ، لِأَنَّ الْكُفْرَةَ بِأَسْرِهِمْ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى (283)، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ .. [لقمان: 25] .

²⁷⁷ () وهذا قول عامة المتأخرين من الحنفية ، والقاضي أبى يعلى من الحنابلة ، واستدلوا: أن عبد الله بن عمرو بن العاص حلف بالطلاق عند النبي (صلى الله عليه وسلم) ولم ينكر عليه ، ولأنه لما ضعف الوازع الديني عند بعض الناس ، مست الحاجة إلى الوثيقة بالطلاق ، وما أشبهه. تبين الحقائق وحاشية الشلبى 419/3، كشف القناع 570/6.

²⁷⁸ () رواه مسلم فى صحيحه رقم 1700/28، شرح مشكل الآثار للطحاوى رقم 4539، نيل الأوطار للشوكانى رقم 3100.

²⁷⁹ () لأن المجوسى يعتقد الحرمة فى النار، فيمتنع عن اليمين الكاذبة ، فيحصل المقصود .تكملة فتح القدير 206/8، 207.

²⁸⁰ () كتاب للإمام محمد بن الحسن الشيبانى ، وهو من كتب ظاهر الرواية ، والتي تتضمن أيضا السير الصغير والكبير ، والجامع الصغير والكبير والزيادات ،وسمى بالأصل ، لأن الشيبانى صنفه قبل سائر كتبه المعروفة . مفتاح السعادة 263/2.

²⁸¹ () تطلق على المسائل التى رويت عن أئمة المذهب أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد فى غير كتب ظاهر الرواية ك" الرقيات ، والهارونيات ، والكيسانيات والجرجانيات ، أو كتب غيره من أصحاب أبى حنيفة ، كالأمالى ، لأبى يوسف والمجرد للحسن بن زياد ، أو تكون بروايات مفردة ، كروايات ابن سماعه ، والمعلى بن منصور وغيرهم . رد المحتار 50/1، 69.

²⁸² () روى عن أبى حنيفة ، وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة . تكملة فتح القدير 206/8، 207، الذخيرة 70/11، 73، الحاوى 116/17، كشف القناع 570/6.

²⁸³ () تكملة فتح القدير 207/8، الذخيرة 73/11، الحاوى 117/17، المغنى 228/9.

مكان استحلاف غير المسلم : "قَالَ (وَلَا يَخْلِفُونَ فِي بُيُوتِ عِبَادَتِهِمْ) ، لِأَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَحْضُرُهَا ، بَلْ هُوَ مَمْنُوعٌ عَنْ ذَلِكَ".²⁸⁴

حكم تغليظ اليمين على المسلم : "قَالَ (وَلَا يَجِبُ تَغْلِيظُ الْيَمِينِ عَلَى الْمُسْلِمِ بِزَمَانٍ وَلَا مَكَانٍ)، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ تَعْظِيمَ الْمُقْسَمِ بِهِ وَهُوَ حَاصِلٌ بِدُونِ ذَلِكَ، وَفِي إِيْجَابِ ذَلِكَ حَرَجٌ عَلَى الْقَاضِي حَيْثُ يُكَلَّفُ حُضُورَهَا وَهُوَ مَدْفُوعٌ".²⁸⁵

الحلف على الحاصل أو السبب : "قَالَ (وَمَنْ ادَّعَى أَنَّهُ ابْتِاعَ مِنْ هَذَا عَبْدَهُ بِأَلْفٍ ، فَجَحَدَ ، اسْتَحْلَفَ بِاللَّهِ مَا بَيْنَكُمَا بَيْنُ قَائِمٍ فِيهِ ، وَلَا يَسْتَحْلِفُ بِاللَّهِ مَا بَعْتَ)، لِأَنَّهُ قَدْ يُبَاغُ الْعَيْنُ ، ثُمَّ يُقَالُ فِيهِ (وَيَسْتَحْلِفُ فِي الْعَصَبِ : بِاللَّهِ مَا يَسْتَحِقُّ عَلَيْكَ رَدُّهُ ، وَلَا يَخْلِفُ بِاللَّهِ مَا غَصَبْتَ) ، لِأَنَّهُ قَدْ يَغْصِبُ ، ثُمَّ يَفْسَخُ بِالْهَبَةِ وَالْبَيْعِ (وَفِي النِّكَاحِ : بِاللَّهِ مَا بَيْنَكُمَا نِكَاحٌ قَائِمٌ فِي الْحَالِ) ، لِأَنَّهُ قَدْ يَطْرَأُ عَلَيْهِ الْخُلْعُ ، (وَفِي دَعْوَى الطَّلَاقِ : بِاللَّهِ مَا هِيَ بَائِنٌ مِنْكَ السَّاعَةَ بِمَا ذَكَرْتَ ، وَلَا يَسْتَحْلِفُ بِاللَّهِ مَا طَلَّقَهَا) ، لِأَنَّ النِّكَاحَ قَدْ يُجَدِّدُ بَعْدَ الْإِبَانَةِ ، فَيَخْلِفُ عَلَى الْحَاصِلِ فِي هَذِهِ الْوُجُوهِ، لِأَنَّهُ لَوْ حَلَفَ عَلَى السَّبَبِ يَتَضَرَّرُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ.

أَمَّا عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يَخْلِفُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ عَلَى السَّبَبِ ، إِلَّا إِذَا عَرَضَ بِمَا ذَكَرْنَا ، فَحِينَئِذٍ يَخْلِفُ عَلَى الْحَاصِلِ ، وَقِيلَ: يَنْظَرُ إِلَى انْكَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِنْ أَنْكَرَ السَّبَبَ يَخْلِفُ عَلَيْهِ، وَإِنْ أَنْكَرَ الْحُكْمَ يَخْلِفُ عَلَى الْحَاصِلِ ، فَالْحَاصِلُ هُوَ الْأَصْلُ عِنْدَهُمَا إِذَا كَانَ سَبَبًا يَرْتَفِعُ ، إِلَّا إِذَا كَانَ فِيهِ تَرَكُّ النَّظَرِ فِي جَانِبِ الْمُدَّعَى ، فَحِينَئِذٍ يَخْلِفُ عَلَى السَّبَبِ بِالْإِجْمَاعِ، وَذَلِكَ أَنْ تَدَّعِيَ مَبْنُوتَةً نَفَقَةَ الْعِدَّةِ ، وَالزَّوْجُ مِمَّنْ لَا يَرَاهَا، أَوْ ادَّعَى شَفْعَةً بِالْجَوَارِ، وَالْمُشْتَرِي لَا يَرَاهَا، لِأَنَّهُ لَوْ حَلَفَ عَلَى الْحَاصِلِ يَصْدُقُ فِي يَمِينِهِ فِي مُعْتَقَدِهِ ، فَيَفُوتُ النَّظَرُ فِي حَقِّ الْمُدَّعَى، وَإِنْ كَانَ سَبَبًا لَا يَرْتَفِعُ بِرَافِعٍ ، فَالتَّحْلِيفُ عَلَى السَّبَبِ بِالْإِجْمَاعِ (كَالْعَبْدِ الْمُسْلِمِ إِذَا ادَّعَى الْعَتَقَ عَلَى مَوْلَاهُ، بِخِلَافِ الْأَمَةِ وَالْعَبْدِ الْكَافِرِ) ، لِأَنَّهُ يُكْرَرُ الرِّقَّ عَلَيْهَا بِالرَّدَّةِ وَاللَّحَاقِ ، وَعَلَيْهِ بِنَقْضِ الْعَهْدِ وَاللَّحَاقِ⁽²⁸⁶⁾، وَلَا يُكْرَرُ عَلَى الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ".²⁸⁷

²⁸⁴ () ولأن في حضوره تعظيم لذلك المكان ، وما أمرنا بهذا . البناءة 345/9.

²⁸⁵ () ولأن في التغليظ بالزمان تأخير حق المدعي في اليمين إلى ذلك الزمان ، وأنه غير مشروع . البحر الرائق 213/7.

²⁸⁶ () أي اللحاق بدار الحرب . تكملة فتح القدير 201/8.

²⁸⁷ () الْيَمِينُ : وَهُوَ الْحَلْفُ عَلَى الْحَاصِلِ أَوْ السَّبَبِ، وَالضَّابِطُ فِي ذَلِكَ : أَنَّ السَّبَبَ، إِمَّا أَنْ كَانَ مِمَّا يَرْتَفِعُ بِرَافِعٍ أَوْ لَا، فَإِنْ كَانَ الثَّانِي فَالتَّحْلِيفُ عَلَى السَّبَبِ بِالْإِجْمَاعِ، وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ فَإِنْ تَضَرَّرَ الْمُدَّعَى بِالتَّحْلِيفِ عَلَى الْحَاصِلِ فَكَذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَتَضَرَّرْ يَخْلِفُ عَلَى الْحَاصِلِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ، وَعَلَى السَّبَبِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ، إِلَّا إِذَا عَرَضَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِرَفْعِ السَّبَبِ ، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ

اليمين على العلم أو البتات : "قَالَ: (وَمَنْ وَرِثَ عَبْدًا ، وَادَّعَاهُ آخَرُ يَسْتَحْلِفُ عَلَى عِلْمِهِ)، لِأَنَّهُ لَا عِلْمَ لَهُ بِمَا صَنَعَ الْمُورِثُ ، فَلَا يَحْلِفُ عَلَى الْبَتَاتِ ، (وَإِنْ وَهَبَ لَهُ أَوْ اشْتَرَاهُ يَحْلِفُ عَلَى الْبَتَاتِ) ، لَوْجُودِ الْمُطْلَقِ لِلْيَمِينِ ، إِذِ الشَّرَاءُ سَبَبٌ لِثُبُوتِ الْمَلِكِ وَضَعًا وَكَذَا الْهَبَةُ). (288)

افتداء اليمين : "قَالَ (وَمَنْ ادَّعَى عَلَى آخَرَ مَالًا ، فَافْتَدَى يَمِينَهُ ، أَوْ صَالَحَهُ مِنْهَا عَلَى عَشْرَةِ ، فَهُوَ جَائِزٌ) وَهُوَ مَأْثُورٌ عَنْ عُثْمَانَ (289) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - . (وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَحْلِفَهُ عَلَى تِلْكَ الْيَمِينِ أَبَدًا)، لِأَنَّهُ أَسْقَطَ حَقَّهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(بَابُ التَّحَالِفِ) :

حكم يمين المتبايعين : "قَالَ (290): (وَإِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايعَانِ فِي الْبَيْعِ فَادَّعَى أَحَدُهُمَا ثَمَنًا وَادَّعَى الْبَائِعُ أَكْثَرَ مِنْهُ أَوْ اعْتَرَفَ الْبَائِعُ بِقَدْرِ مِنَ الْمَبِيعِ ، وَادَّعَى الْمُشْتَرِي أَكْثَرَ مِنْهُ ، فَأَقَامَ أَحَدُهُمَا الْبَيِّنَةَ قَضَى لَهُ بِهَا)، لِأَنَّ فِي الْجَانِبِ الْآخَرَ مُجَرَّدَ الدَّعْوَى ، وَالْبَيِّنَةُ أَقْوَى مِنْهَا (وَإِنْ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً ، كَانَتْ الْبَيِّنَةُ الْمُثْبِتَةُ لِلزِّيَادَةِ أَوْلَى) ، لِأَنَّ الْبَيِّنَاتِ لِلْإِثْبَاتِ وَلَا تَعَارِضَ فِي الزِّيَادَةِ ، (وَلَوْ كَانَ الْإِخْتِلَافُ فِي الثَّمَنِ وَالْمَبِيعِ جَمِيعًا ، فَبَيِّنَةُ الْبَائِعِ أَوْلَى فِي الثَّمَنِ ، وَبَيِّنَةُ الْمُشْتَرِي أَوْلَى فِي الْمَبِيعِ) نَظَرًا إِلَى زِيَادَةِ الْإِثْبَاتِ، (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ ، قِيلَ لِلْمُشْتَرِي : إِمَّا أَنْ تَرْضَى بِالثَّمَنِ الَّذِي ادَّعَاهُ الْبَائِعُ وَإِلَّا فَسَخْنَا الْبَيْعَ، وَقِيلَ لِلْبَائِعِ : إِمَّا أَنْ تُسَلِّمَ مَا ادَّعَاهُ الْمُشْتَرِي مِنَ الْمَبِيعِ ، وَإِلَّا فَسَخْنَا الْبَيْعَ)، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ قَطْعَ الْمُنَازَعَةِ، وَهَذِهِ جِهَةٌ فِيهِ ، لِأَنَّهُ رُبَّمَا لَا يَرْضِيَانِ بِالْفَسْخِ ، فَإِذَا عَلِمَا بِهِ يَتَرَاضِيَانِ بِهِ ، (فَإِنْ لَمْ يَتَرَاضِيَا ، اسْتَحْلَفَ الْحَاكِمُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى دَعْوَى الْآخَرِ) ، وَهَذَا التَّحَالِفُ قَبْلَ الْقَبْضِ عَلَى وَفَاقِ الْقِيَاسِ، لِأَنَّ الْبَائِعَ يَدَّعِي زِيَادَةَ الثَّمَنِ وَالْمُشْتَرِي يُنْكِرُهُ، وَالْمُشْتَرِي يَدَّعِي وَجُوبَ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ بِمَا نَقَدَ ، وَالْبَائِعُ يُنْكِرُهُ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُنْكَرٌ فَيَحْلِفُ؛ فَأَمَّا بَعْدَ الْقَبْضِ ، فَمُخَالَفٌ لِلْقِيَاسِ ، لِأَنَّ

عِنْدَ قَوْلِ الْقَاضِي اخْلِفَ بِاللَّهِ مَا بَعْتَ أَبُوهَا الْقَاضِي إِنَّ الْإِنْسَانَ قَدْ يَبِيعُ شَيْئًا ثُمَّ يُقَالُ فِيهِ ، فَحِينَئِذٍ يَلْزَمُ الْقَاضِي الْإِسْتِحْلَافُ عَلَى الْحَاصِلِ، هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ . تكملة فتح القدير 198/8.

(288) (وَهَذَا نَوْعٌ آخَرُ مِنْ كَيْفِيَّةِ الْيَمِينِ ، وَهُوَ الْيَمِينُ عَلَى الْعِلْمِ أَوْ الْبَتَاتِ، الضَّابِطُ فِي ذَلِكَ : أَنَّ الدَّعْوَى إِذَا وَقَعَتْ عَلَى فِعْلِ الْغَيْرِ ، كَانَ الْحَلْفُ عَلَى الْعِلْمِ، وَإِنْ وَقَعَتْ عَلَى فِعْلِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، كَانَ عَلَى الْبَتَاتِ . العناية 201/8.

(289) (عن الشعبي ، أن المقداد ، استقرض من عثمان بن عفان رضي الله عنه سبعة آلاف درهم ، فلما تقاضاه ، قال: " إنما هي أربعة آلاف ، فخاصمه إلى عمر رضي الله عنه ، فقال: إني قد أقرضت المقداد سبعة آلاف درهم ، فقال المقداد: إنما هي أربعة آلاف ، فقال المقداد: أحلفه أنها سبعة آلاف ، فقال عمر رضي الله عنه: " أنصفك " ، فأبى أن يحلف ، فقال عمر: خذ ما أعطاك " ، قال: البيهقي : هذا إسناد صحيح ، إلا أنه منقطع ، .. والله أعلم . السنن الكبرى للبيهقي رقم 20740.

(290) (أى القدورى فى مختصره . تكملة فتح القدير 205/8.

الْمُشْتَرِي لَا يَدْعِي شَيْئًا ، لِأَنَّ الْمَبِيعَ سَالِمٌ لَهُ ، فَبَقِيَ دَعْوَى الْبَائِعِ فِي زِيَادَةِ الثَّمَنِ وَالْمُشْتَرِي يُنْكِرُهَا فَيُكْتَفَى بِحَلْفِهِ ، لَكِنَّا عَرَفْنَاهُ بِالنَّصِّ وَهُوَ قَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - "إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايعَانِ ، وَالسَّلْعَةُ قَائِمَةٌ بَعَيْنِهَا ، تَحَالَفَا وَتَرَادَا". (291)

البدء بيمين المشتري عند الاختلاف : "قال: (وَيَبْتَدِئُ بِيَمِينِ الْمُشْتَرِي) ، وَهَذَا قَوْلُ مُحَمَّدٍ وَأَبِي يُوسُفَ آخِرًا ، وَهُوَ رَوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَهُوَ الصَّحِيحُ ، لِأَنَّ الْمُشْتَرِي أَشَدُّهُمَا إِنْكَارًا ، لِأَنَّهُ يُطَالِبُ أَوَّلًا بِالثَّمَنِ ، وَلِأَنَّهُ يَتَعَجَّلُ فَائِدَةَ النُّكُولِ ، وَهُوَ الْإِزَامُ الثَّمَنِ ، وَلَوْ بُدِئَ بِيَمِينِ الْبَائِعِ تَتَأَخَّرُ الْمُطَالَبَةُ بِتَسْلِيمِ الْمَبِيعِ إِلَى زَمَانِ اسْتِيفَاءِ الثَّمَنِ ، وَكَانَ أَبُو يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يَقُولُ أَوَّلًا: يَبْدَأُ بِيَمِينِ الْبَائِعِ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - "إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايعَانِ فَالْقَوْلُ مَا قَالَهُ الْبَائِعُ" (292) ، خَصَّهُ بِالذِّكْرِ ، وَأَقْلَّ فَائِدَتِهِ التَّقْدِيمَ.

البدء بيمين أحد المتبايعين في المقايضة والصرف : (وَإِنْ كَانَ بَيْعٌ عَيْنٍ بِعَيْنٍ أَوْ ثَمَنِ بِثَمَنِ بَدَأَ الْقَاضِي بِيَمِينِ أَيُّهُمَا شَاءَ) لَا اسْتِوَاءَهُمَا.

صفة اليمين عند اختلاف المتبايعين : (وَصِفَةُ الْيَمِينِ : أَنْ يَحْلِفَ الْبَائِعُ بِاللَّهِ مَا بَاعَهُ بِأَلْفٍ ، وَيَحْلِفَ الْمُشْتَرِي بِاللَّهِ مَا اشْتَرَاهُ بِأَلْفَيْنِ) ، وَقَالَ فِي الزِّيَادَاتِ (293): يَحْلِفُ بِاللَّهِ مَا بَاعَهُ بِأَلْفٍ ، وَلَقَدْ بَاعَهُ بِأَلْفَيْنِ ، يَحْلِفُ الْمُشْتَرِي بِاللَّهِ مَا اشْتَرَاهُ بِأَلْفَيْنِ وَلَقَدْ اشْتَرَاهُ بِأَلْفٍ ، يَضْمَنُ الْإِثْبَاتُ إِلَى النَّفْيِ تَأْكِيدًا ، وَالْأَصَحُّ الْإِقْتِصَارُ عَلَى النَّفْيِ ، لِأَنَّ الْأَيْمَانَ عَلَى ذَلِكَ وَضِعَتْ ، دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيثُ الْقَسَّامَةِ "بِاللَّهِ مَا قَتَلْتُمْ وَلَا عَلِمْتُمْ لَهُ قَاتِلًا". (294)

قَالَ (فَإِنْ حَلَفَا ، فَسَخَ الْقَاضِي الْبَيْعَ بَيْنَهُمَا) ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَنْفَسِخُ بِنَفْسِ التَّحَالُفِ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ مَا ادَّعَاهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، فَيَبْقَى بَيْعٌ مَجْهُولٌ فَيَفْسُخُهُ الْقَاضِي ، قَطْعًا لِلنُّمُازَةِ ، أَوْ يَقَالُ : إِذَا لَمْ يَثْبُتِ الْبَدَلُ يَبْقَى بَيْعًا بِلا بَدَلٍ ، وَهُوَ فَاسِدٌ ، وَلَا بُدَّ مِنَ الْفَسْخِ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ. (295)

²⁹¹ () موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني رقم 786 ، شرح مشكل الآثار رقم 2389 .
²⁹² () المسند ، للشاشي ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، رقم 302 ، الآثار ، لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حنيفة الأنصاري (المتوفى: 182هـ) رقم 830 .

²⁹³ () كتاب للإمام محمد بن الحسن الشيباني ، شرحه قاضي خان ت 592 ، مطبوع . مفتاح السعادة ، كبرى زادة 2/ 263 .

²⁹⁴ () أخرجه البيهقي في السنن الكبرى رقم 16451 ، عن سعيد بن المسيب (رضي الله عنه)
²⁹⁵ () ولأن الاختلاف في البديل يوجب الاختلاف في العقد ، لأن كل واحد منهما ادعى عقدًا غير الذي ادعاه الآخر فكان البيع مجهولًا لجهالة البديل. البناية 9/356 .

نكول أحد المتبايعين : "قَالَ: (وَإِنْ نَكَلَ أَحَدُهُمَا عَنِ الْيَمِينِ لَزِمَهُ دَعْوَى الْآخَرِ) لِأَنَّهُ جُعِلَ بَازِلًا فَلَمْ يَبْقَ دَعْوَاهُ مُعَارِضًا لِدَعْوَى الْآخَرِ فَلَزِمَ الْقَوْلُ بِنُبُوتِهِ). (296)

اختلاف المتبايعين في الأجل وما أشبهه : "قَالَ (وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الْأَجَلِ ، أَوْ فِي شَرْطِ الْخِيَارِ ، أَوْ فِي اسْتِيفَاءِ بَعْضِ الثَّمَنِ ، فَلَا تَحَالَفَ بَيْنَهُمَا) ، لِأَنَّ هَذَا اخْتِلَافٌ فِي غَيْرِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ، وَالْمَعْقُودِ بِهِ ، فَاشْتَبَهَ الْاِخْتِلَافُ فِي الْحَطِّ وَالْإِبْرَاءِ ، وَهَذَا لِأَنَّ بَانْعِدَامِهِ لَا يَخْتُلُ مَا بِهِ قِوَامُ الْعَقْدِ ، بِخِلَافِ الْاِخْتِلَافِ فِي وَصْفِ الثَّمَنِ وَجِنْسِهِ حَيْثُ يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الْاِخْتِلَافِ فِي الْقَدْرِ فِي جَرِيَانِ التَّحَالُفِ ، لِأَنَّ ذَلِكَ يَرْجِعُ إِلَى نَفْسِ الثَّمَنِ ، فَإِنَّ الثَّمَنَ دَيْنٌ ، وَهُوَ يُعْرَفُ بِالْوَصْفِ ، وَلَا كَذَلِكَ الْأَجَلُ ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِوَصْفٍ ؛ أَلَا تَرَى أَنَّ الثَّمَنَ مَوْجُودٌ بَعْدَ مُضِيِّهِ.

قال: (وَالْقَوْلُ قَوْلٌ مَنْ يُنْكِرُ الْخِيَارَ وَالْأَجَلَ مَعَ يَمِينِهِ) لِأَنَّهُمَا يَنْبُتَانِ بِعَارِضِ الشَّرْطِ وَالْقَوْلِ لِمُنْكَرِ الْعَوَارِضِ.

اختلاف المتبايعين عند هلاك المبيع : "قَالَ: (فَإِنْ هَلَكَ الْمَبِيعُ ثُمَّ اخْتَلَفَا ، لَمْ يَتَحَالَفَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : يَتَحَالَفَانِ وَيُفْسَخُ الْبَيْعُ عَلَى قِيمَةِ الْهَالِكِ) ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ (297) - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، وَعَلَى هَذَا إِذَا خَرَجَ الْمَبِيعُ عَنْ مِلْكِهِ أَوْ صَارَ بِحَالٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى رَدِّهِ بِالْعَيْبِ.

لَهُمَا : أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَدَّعِي غَيْرَ الْعَقْدِ الَّذِي يَدَّعِيهِ صَاحِبُهُ ، وَالْآخَرُ يُنْكِرُهُ ، وَأَنَّهُ يُفِيدُ دَفْعَ زِيَادَةِ الثَّمَنِ فَيَتَحَالَفَانِ ؛ كَمَا إِذَا اخْتَلَفَا فِي جِنْسِ الثَّمَنِ بَعْدَ هَلَكَ السَّلْعَةِ ، وَلِأَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ : أَنَّ التَّحَالَفَ بَعْدَ الْقَبْضِ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ ، لِأَنَّهُ سَلَّمَ لِلْمُشْتَرِي مَا يَدَّعِيهِ ، وَقَدْ وَرَدَ الشَّرْعُ بِهِ فِي حَالِ قِيَامِ السَّلْعَةِ ، وَالتَّحَالَفُ فِيهِ يُفْضِي إِلَى الْفُسْخِ ، وَلَا كَذَلِكَ بَعْدَ هَلَكَهَا ، لِارْتِقَاعِ الْعَقْدِ فَلَمْ يَكُنْ فِي مَعْنَاهُ ، وَلِأَنَّهُ لَا يُبَالِي بِالْاِخْتِلَافِ فِي السَّبَبِ بَعْدَ حُصُولِ الْمُقْصُودِ ، وَإِنَّمَا يُرَاعَى مِنَ الْفَائِدَةِ مَا يُوجِبُهُ الْعَقْدُ ، وَفَائِدَةُ دَفْعِ زِيَادَةِ الثَّمَنِ لَيْسَتْ مِنْ مُوْجِبَاتِهِ ، وَهَذَا إِذَا كَانَ الثَّمَنُ دَيْنًا ، فَإِنْ كَانَ عَيْنًا يَتَحَالَفَانِ ، لِأَنَّ الْمَبِيعَ فِي أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ قَائِمٌ فَتَوْقُرُ فَائِدَةُ الْفُسْخِ ، ثُمَّ يَرُدُّ مِثْلَ الْهَالِكِ إِنْ كَانَ لَهُ مِثْلٌ أَوْ قِيمَتُهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِثْلٌ). (298)

اختلاف المتبايعين في الثمن عند هلاك أحد العبدَيْن : "قَالَ (وَإِنْ هَلَكَ أَحَدُ الْعَبْدَيْنِ ثُمَّ اخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ لَمْ يَتَحَالَفَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ إِلَّا أَنْ يَرْضَى الْبَائِعُ أَنْ يَتْرَكَ حِصَّةَ الْهَالِكِ مِنَ الثَّمَنِ ، وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي مَعَ يَمِينِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْبَائِعُ أَنْ يَأْخُذَ الْعَبْدَ

²⁹⁶ () لعدم المعارض. البناية 356/9.

²⁹⁷ () حاشية الشرواني على تحفة المحتاج 378/4.

²⁹⁸ () أي : أو يرد قيمته (إن لم يكن له مثل) ، كالحیوان فیما إذا تبايعا حیواناً بحیوان . البناية 360/9.

الْحَيِّ وَلَا شَيْءَ لَهُ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: يَتَحَالَفَانِ فِي الْحَيِّ وَيُفْسَخُ الْعَقْدُ فِي الْحَيِّ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي فِي قِيَمَةِ الْهَالِكِ. وَقَالَ مُحَمَّدٌ: يَتَحَالَفَانِ عَلَيْهِمَا، وَيَرُدُّ الْحَيَّ وَقِيَمَةَ الْهَالِكِ)، لِأَنَّ هَلَكَ كُلُّ السَّلْعَةِ لَا يَمْنَعُ التَّحَالَفَ عِنْدَهُ، فَهَلَاكَ الْبَعْضِ أَوْلَى، وَلِأَبِي يُوسُفَ أَنَّ امْتِنَاعَ التَّحَالَفِ لِلْهَالِكِ فَيَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهِ.

وَلِأَبِي حَنِيفَةَ: أَنَّ التَّحَالَفَ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ فِي حَالِ قِيَامِ السَّلْعَةِ، وَهِيَ اسْمٌ لِجَمِيعِ أَجْزَائِهَا، فَلَا تَبْقَى السَّلْعَةُ بِفَوَاتِ بَعْضِهَا، وَلِأَنَّهُ لَا يُمَكِّنُ التَّحَالَفُ فِي الْقَائِمِ إِلَّا عَلَى اعْتِبَارِ حِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ، فَلَا بُدَّ مِنَ الْقِسْمَةِ، وَهِيَ تُعْرَفُ بِالْحَذَرِ وَالظَّنِّ فَيُؤَدِّي إِلَى التَّحَالَفِ مَعَ الْجَهْلِ، وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ، إِلَّا أَنْ يَرْضَى الْبَائِعُ أَنْ يَتْرِكَ حِصَّةَ الْهَالِكِ أَصْلًا، لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ الثَّمَنُ كُلُّهُ بِمُقَابَلَةِ الْقَائِمِ، وَيَخْرُجُ الْهَالِكُ عَنِ الْعَقْدِ فَيَتَحَالَفَانِ، هَذَا تَخْرِيجُ بَعْضِ الْمَشَايخ، وَيُصَرِّفُ الْإِسْتِثْنَاءَ عِنْدَهُمْ إِلَى التَّحَالَفِ كَمَا ذَكَرْنَا، وَقَالُوا: إِنَّ الْمُرَادَ مِنْ قَوْلِهِ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ⁽²⁹⁹⁾: "يَأْخُذُ الْحَيَّ وَلَا شَيْءَ لَهُ"، مَعْنَاهُ: لَا يَأْخُذُ مِنْ ثَمَنِ الْهَالِكِ شَيْئًا أَصْلًا. وَقَالَ بَعْضُ الْمَشَايخ: يَأْخُذُ مِنْ ثَمَنِ الْهَالِكِ بِقَدْرِ مَا أَقَرَّ بِهِ الْمُشْتَرِي، وَإِنَّمَا لَا يَأْخُذُ الزِّيَادَةَ.

وَعَلَى قَوْلِ هَؤُلَاءِ يَنْصَرِفُ الْإِسْتِثْنَاءُ إِلَى يَمِينِ الْمُشْتَرِي لَا إِلَى التَّحَالَفِ، لِأَنَّهُ لَمَّا أَخَذَ الْبَائِعُ بِقَوْلِ الْمُشْتَرِي فَقَدْ صَدَّقَهُ فَلَا يَخْلِفُ الْمُشْتَرِي، ثُمَّ تَفْسِيرُ التَّحَالَفِ عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ مَا بَيَّنَّاهُ فِي الْقَائِمِ. وَإِذَا حَلَفَا وَلَمْ يَتَّفِقَا عَلَى شَيْءٍ فَادَّعَى أَحَدُهُمَا الْفُسْخَ أَوْ كِلَاهُمَا يُفْسَخُ الْعَقْدُ بَيْنَهُمَا وَيَأْمُرُ الْقَاضِي الْمُشْتَرِي بِرَدِّ الْبَاقِي وَقِيَمَةِ الْهَالِكِ.

وَاخْتَلَفُوا فِي تَفْسِيرِهِ عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَخْلِفُ الْمُشْتَرِي بِاللَّهِ مَا اشْتَرَيْتُهُمَا بِمَا يَدَّعِيهِ الْبَائِعُ، فَإِنْ نَكَلَ لَزِمَهُ دَعْوَى الْبَائِعِ، وَإِنْ حَلَفَ يَخْلِفُ الْبَائِعُ بِاللَّهِ مَا بَعَثْتُهُمَا بِالثَّمَنِ الَّذِي يَدَّعِيهِ الْمُشْتَرِي، فَإِنْ نَكَلَ لَزِمَهُ دَعْوَى الْمُشْتَرِي، وَإِنْ حَلَفَ يَفْسَخَانِ الْعَقْدَ فِي الْقَائِمِ وَتَسْقُطُ حِصَّتُهُ مِنَ الثَّمَنِ وَيَلْزِمُ الْمُشْتَرِي حِصَّةَ الْهَالِكِ وَيُعْتَبَرُ قِيَمَتُهُمَا فِي الْإِنْفِسَامِ يَوْمَ الْقَبْضِ⁽³⁰⁰⁾).

اختلف المتبايعين في قيمة الهالك يوم القبض: "وإن اختلفا في قيمة الهالك يوم القبض، فالقول قول البائع، وأيهما أقام البيّنة، تُقبل بيّنته، وإن أقامها، فبيّنة البائع أولى)، وهو قياس ما ذكر في بيوع الأصل (اشترى عبدين وقبضهما ثم رد أحدهما بالعيب وهلك الآخر عنده يجب عليه ثمن ما هلك عنده ويسقط عنه ثمن ما رده وينقسم الثمن على قيمتهما. فإن اختلفا في قيمة الهالك فالقول قول البائع) لأن الثمن قد وجب باتفاقهما ثم المشتري يدعي زيادة

⁽²⁹⁹⁾ (الجامع الصغير كتاب صنفه محمد بن الحسن الشيباني، أحد كتب ظاهر الرواية. مفتاح السعادة 263/2.

⁽³⁰⁰⁾ (الأصل المعروف بالمبسوط، للإمام محمد بن الحسن 70/5، البناية على الهداية 9/360، 361، الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير ص340.

السُّقُوطِ بِنُقْصَانِ قِيَمَةِ الْهَالِكِ وَالْبَائِعُ يُكْرِهُ وَالْقَوْلُ لِلْمُنْكَرِ (وَإِنْ أَقَامَا الْبَيِّنَةَ فَبَيِّنَةُ الْبَائِعِ أُولَى) لِأَنَّهَا أَكْثَرُ إِبْتَاتًا ظَاهِرًا لِإِثْبَاتِهَا الزِّيَادَةَ فِي قِيَمَةِ الْهَالِكِ وَهَذَا لِفَقْهِهِ ، وَهُوَ أَنَّ فِي الْأَيْمَانِ تُعْتَبَرُ الْحَقِيقَةُ ، لِأَنَّهَا تَتَوَجَّهُ عَلَى أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ ، وَهُمَا يَعْرِفَانِ حَقِيقَةَ الْحَالِ فَبَيِّنَةُ الْأَمْرِ عَلَيْهَا ، وَالْبَائِعُ مُنْكَرٌ حَقِيقَةً فَلَذَا كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ ، وَفِي الْبَيِّنَاتِ يُعْتَبَرُ الظَّاهِرُ ، لِأَنَّ الشَّاهِدَيْنِ لَا يَعْلَمَانِ حَقِيقَةَ الْحَالِ ، فَاعْتَبِرَ الظَّاهِرُ فِي حَقِّهِمَا ، وَالْبَائِعُ مَدَّعٍ ظَاهِرًا فَلِهَذَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ أَيْضًا ، وَتَتَرَجَّحُ بِالزِّيَادَةِ الظَّاهِرَةِ عَلَى مَا مَرَّ ، وَهَذَا يُبَيِّنُ لَكَ مَعْنَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ.

الإقالة واختلاف المتبعين في ثمن الجارية : "قَالَ (وَمَنْ اشْتَرَى جَارِيَةً وَقَبَضَهَا ثُمَّ تَقَايَلَا ثُمَّ اخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ فَإِنَّهُمَا يَتَحَالَفَانِ وَيَعُودُ الْبَيْعُ الْأَوَّلُ) وَنَحْنُ مَا أَثْبَتْنَا التَّحَالَفَ فِيهِ بِالنَّصِّ لِأَنَّهُ وَرَدَ فِي الْبَيْعِ الْمُطْلَقِ وَالْإِقَالَةِ فَسُخِّ فِي حَقِّ الْمُتَعَاقِدَيْنِ ، وَإِنَّمَا أَثْبَتْنَاهُ بِالْقِيَاسِ لِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ مَفْرُوضَةٌ قَبْلَ الْقَبْضِ ، وَالْقِيَاسُ يُوَفِّقُهُ عَلَى مَا مَرَّ ، وَلِهَذَا نَقِيسُ الْإِجَارَةَ عَلَى الْبَيْعِ قَبْلَ الْقَبْضِ ، وَالْوَارِثُ عَلَى الْعَاقِدِ ، وَالْقِيَمَةُ عَلَى الْعَيْنِ فِيمَا إِذَا اسْتَهْلَكَهُ فِي يَدِ الْبَائِعِ غَيْرِ الْمُشْتَرِي.

قَالَ (وَلَوْ قَبِضَ الْبَائِعُ الْمَبِيعَ بَعْدَ الْإِقَالَةِ فَلَا تَحَالَفَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ) لِأَنَّهُ يَرَى النَّصَّ مَعْلُومًا بَعْدَ الْقَبْضِ أَيْضًا.

السلم واختلاف المتبايعين في الثمن : "قَالَ (وَمَنْ أَسْلَمَ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ فِي كُرٍّ حِنْطَةٍ ثُمَّ تَقَايَلَا ثُمَّ اخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ ، فَأَلْقُوا قَوْلَ الْمُسْلِمِ إِلَيْهِ ، وَلَا يَعُودُ السَّلْمُ⁽³⁰¹⁾) ، لِأَنَّ الْإِقَالَةَ فِي بَابِ السَّلْمِ لَا تَحْتَمِلُ النَّقْضَ ، لِأَنَّهُ إِسْقَاطٌ فَلَا يَعُودُ السَّلْمُ ، بِخِلَافِ الْإِقَالَةِ فِي الْبَيْعِ ؛ أَلَا تَرَى أَنَّ رَأْسَ مَالِ السَّلْمِ لَوْ كَانَ عَرَضًا فَرَدَّهُ بِالْعَيْبِ ، وَهَلَاكَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ إِلَى رَبِّ السَّلْمِ لَا يَعُودُ السَّلْمُ ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ فِي بَيْعِ الْعَيْنِ يَعُودُ الْبَيْعُ دَلَّ عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا.

اختلاف الزوجين في المهر : "قَالَ (وَإِذَا اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي الْمَهْرِ فَادَّعَى الزَّوْجُ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِأَلْفٍ وَقَالَتْ تَزَوَّجَنِي بِأَلْفَيْنِ فَأَيُّهُمَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ) ، لِأَنَّهُ نَوَّرَ دَعْوَاهُ بِالْحُجَّةِ.

(وَإِنْ أَقَامَا الْبَيِّنَةَ فَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الْمَرْأَةِ) ، لِأَنَّهَا تُثَبِّتُ الزِّيَادَةَ ، مَعْنَاهُ : إِذَا كَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا أَقَلَّ مِمَّا ادَّعَتْهُ ، (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ تَحَالَفَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَلَا يُفْسَخُ النِّكَاحُ) ، لِأَنَّ أَثَرَ التَّحَالَفِ فِي انْعِدَامِ التَّسْمِيَةِ ، وَأَنَّهُ لَا يُخْلُ بِصِحَّةِ النِّكَاحِ ، لِأَنَّ الْمَهْرَ تَابِعٌ فِيهِ ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ ، لِأَنَّ عَدَمَ التَّسْمِيَةِ يُفْسِدُهُ عَلَى مَا مَرَّ فَيُفْسَخُ ، (وَلَكِنْ يَحْكُمُ مَهْرُ الْمِثْلِ ، فَإِنْ كَانَ مِثْلُ مَا اعْتَرَفَ بِهِ الزَّوْجُ أَوْ أَقَلَّ ، قُضِيَ بِمَا قَالَ الزَّوْجُ) ، لِأَنَّ الظَّاهِرَ شَاهِدٌ لَهُ ، (وَإِنْ كَانَ مِثْلُ مَا ادَّعَتْهُ الْمَرْأَةُ أَوْ

³⁰¹ () وهو في اللغة: التقديم والتسليم وكذلك السلف، وهو في الشرع: اسم لعقد يوجب الملك في الثمن عاجلا وفي المثلثن أجلا، وسمي به لما فيه من وجوب تقديم الثمن . الاختيار لتعليل المختار 33/2، المعرب ص 231.

أَكْثَرَ قَضَى بِمَا أَدَّعَتْهُ الْمَرْأَةُ، وَإِنْ كَانَ مَهْرُ الْمِثْلِ أَكْثَرَ مِمَّا اعْتَرَفَ بِهِ الزَّوْجُ وَأَقَلَّ مِمَّا أَدَّعَتْهُ الْمَرْأَةُ، قَضَى لَهَا بِمَهْرِ الْمِثْلِ، لِأَنَّهُمَا لَمَّا تَحَالَفَا، لَمْ تَثْبُتِ الزِّيَادَةُ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ وَلَا الْحُطُّ عَنْهُ.

قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: ذَكَرَ التَّحَالَفَ أَوَّلًا ثُمَّ التَّحْكِيمَ، وَهَذَا قَوْلُ الْكَرْخِيِّ⁽³⁰²⁾ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لِأَنَّ مَهْرَ الْمِثْلِ لَا اعْتِبَارَ لَهُ مَعَ وُجُودِ النَّسْمِيَّةِ، وَسُقُوطِ اعْتِبَارِهَا بِالتَّحَالَفِ وَلِهَذَا يُقَدَّمُ فِي الْوُجُوهِ كُلِّهَا، وَيَبْدَأُ بِبَيِّنِ الزَّوْجِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ تَعْجِيلًا لِفَائِدَةِ النُّكُولِ كَمَا فِي الْمُشْتَرَى، وَتَخْرِيجِ الرَّازِيِّ بِخِلَافِهِ وَقَدْ اسْتَفْصَيْنَاهُ فِي النِّكَاحِ وَذَكَرْنَا خِلَافَ أَبِي يُوسُفَ فَلَا نُعِيدُهُ⁽³⁰³⁾.

اختلاف الزوجين في نكاح العبد : "(وَلَوْ ادَّعَى الزَّوْجُ النِّكَاحَ عَلَى هَذَا الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةُ تَدَّعِيهِ عَلَى هَذِهِ الْجَارِيَةِ فَهُوَ كَالْمَسْأَلَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ، إِلَّا أَنَّ قِيمَةَ الْجَارِيَةِ إِذَا كَانَتْ مِثْلَ مَهْرِ الْمِثْلِ يَكُونُ لَهَا قِيمَتُهَا دُونَ عَيْنِهَا)، لِأَنَّ تَمْلُكَهَا لَا يَكُونُ إِلَّا بِالتَّرَاضِي، وَلَمْ يُوْجَدْ فَوَجَبَتْ الْقِيمَةُ.

اختلاف المؤجر والمستأجر قبل استيفاء المعقود عليه : "(وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الْإِجَارَةِ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ، تَحَالَفَا وَتَرَادَّا)، مَعْنَاهُ : اخْتَلَفَا فِي الْبَدَلِ أَوْ فِي الْمُبْدَلِ، لِأَنَّ التَّحَالَفَ فِي الْبَيْعِ قَبْلَ الْقَبْضِ عَلَى وَفَاقِ الْقِيَاسِ عَلَى مَا مَرَّ، وَالْإِجَارَةُ قَبْلَ الْقَبْضِ، الْمَنْفَعَةُ نَظِيرُ الْبَيْعِ قَبْلَ قَبْضِ الْمَبِيعِ وَكَلَامُنَا قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ، (فَإِنْ وَقَعَ الْاِخْتِلَافُ فِي الْأُجْرَةِ يَبْدَأُ بِبَيِّنِ الْمُسْتَأْجِرِ)، لِأَنَّهُ مُنْكَرٌ لَوْجُوبِ الْأُجْرَةِ، (وَإِنْ وَقَعَ فِي الْمَنْفَعَةِ يَبْدَأُ بِبَيِّنِ الْمُؤْجِرِ، وَأَيُّهُمَا نَكَلَ لَزِمَهُ دَعْوَى صَاحِبِهِ، وَأَيُّهُمَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ قُبِلَتْ، وَلَوْ أَقَامَاهَا، فَبَيِّنَةُ الْمُؤْجِرِ أَوْلَى إِنْ كَانَ الْاِخْتِلَافُ فِي الْأُجْرَةِ، وَإِنْ كَانَ فِي الْمَنَافِعِ فَبَيِّنَةُ الْمُسْتَأْجِرِ أَوْلَى، وَإِنْ كَانَ فِيهِمَا، قُبِلَتْ بَيِّنَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِيمَا يَدَّعِيهِ مِنَ الْفَضْلِ) نَحْوُ أَنْ يَدَّعِيَ هَذَا شَهْرًا بَعَشْرَةً، وَالْمُسْتَأْجِرُ شَهْرَيْنِ بِخَمْسَةِ يَفْضِي بِشَهْرَيْنِ بَعَشْرَةً.

اختلاف المؤجر والمستأجر بعد استيفاء جميع المعقود عليه : "قَالَ (وَإِنْ اخْتَلَفَا بَعْدَ الْاِسْتِيفَاءِ، لَمْ يَتَحَالَفَا، وَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُسْتَأْجِرِ)، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ ظَاهِرٌ، لِأَنَّ هَلَكَ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ يَمْنَعُ التَّحَالَفَ عِنْدَهُمَا، وَكَذَا عَلَى أَصْلِ مُحَمَّدٍ، لِأَنَّ الْهَلَكَ إِنَّمَا لَا يَمْنَعُ عِنْدَهُ فِي الْمَبِيعِ لَمَّا أَنَّ لَهُ قِيمَةً تَقُومُ مَقَامَهُ فَيَتَحَالَفَانِ عَلَيْهَا، وَلَوْ جَرَى التَّحَالَفُ هَاهُنَا وَفَسَخُ

³⁰² () عبید اللہ بن الحسین بن دلال بن دلہم ، أبو الحسن الكرخي ، كرخ حدان ، انتهت إليه رئاسة أصحاب أبي حنيفة بعد أبي خازم وأبي سعيد البردعي ، وانتشرت أصحابه ، وعنه أخذ أبو بكر الرازي ، وأبو عبد الله الدامغاني ، وأبو علي الشاشي ، وأبو القاسم علي بن محمد التنوخي ، وتوفي ليلة النصف من شعبان سنة أربعين وثلاث مائة ، ذكره في الأنساب في باب الدلال وفي باب الكرخي . الجواهر المضوية في طبقات الحنفية ، لعبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي ، أبو محمد ، محيي الدين الحنفي (المتوفى: 775 هـ) 337/1.

³⁰³ () وَهُوَ أَنَّ الْقَوْلَ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ قَوْلُ الزَّوْجِ قَبْلَ الطَّلَاقِ وَبَعْدَهُ ، إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِشَيْءٍ مُسْتَنْكَرٍ: يَعْنِي فِي بَابِ الْمَهْرِ فَلَا نُعِيدُهُ . العناية 231/8.

العقد ، فلا قيمة ، لأن المنافع لا تنقوم بنفسها ، بل بالعقد وتبين أنه لا عقد ، وإذا امتنع فالقول للمستأجر مع يمينه لأنه هو المستحق عليه .(304)

اختلاف المؤجر والمستأجر بعد استيفاء بعض المعقود عليه : " (وإن اختلفا بعد استيفاء بعض المعقود عليه تحالفاً وفسخ العقد فيما بقي ، وكان القول في الماضي قول المستأجر) ، لأن العقد ينعقد ساعة فساعة فيصير في كل جزء من المنفعة كأن ابتداء العقد عليها ، بخلاف البيع ، لأن العقد فيه دفعة واحدة ، فإذا تعدر في البعض تعدر في الكل .(305)

اختلاف المولى والمكاتب في مال الكتابة : " قال (وإذا اختلف المولى والمكاتب في مال الكتابة لم يتحالفا عند أبي حنيفة . وقالوا : يتحالفان وتفسخ الكتابة) وهو قول الشافعي لأنه عقد معاوضة يقبل الفسخ فأشبه البيع (306) ، والجامع أن المولى يدعي بدلاً زائداً ينكره العبد والعبد يدعي استحقاق العتق عليه عند أداء القدر الذي يدعيه والمولى ينكره فيتحالفان كما إذا اختلفا في الثمن ، ولأبي حنيفة أن البذل مقابل بفك الحجر في حق اليد والتصرف للحال وهو سالم للعبد وإنما ينقلب مقابلاً بالعتق عند الأداء فقبله لا مقابله ، فبقي اختلافاً في قدر البذل لا غير فلا يتحالفان .

اختلاف الزوجين في متاع البيت : " قال (وإذا اختلف الزوجان في متاع البيت فما يصلح للرجال فهو للرجال ، كالعمامة) ، لأن الظاهر شاهد له (وما يصلح للنساء فهو للمرأة ، كالوقاية) ، لشهادة الظاهر لها (وما يصلح لهما ، كالآنية فهو للرجل) ، لأن المرأة وما في يدها في يد الزوج ، والقول في الدعاوى لصاحب اليد ، بخلاف ما يختص بها ، لأنه يعارضه ظاهر أقوى منه ، ولا فرق بين ما إذا كان الاختلاف في حال قيام النكاح أو بعد ما وقعت الفرقة .

اختلاف أحد ورثة الزوجين في متاع البيت : (فإن مات أحدهما واختلفت ورثته مع الآخر ، فما يصلح للرجال والنساء فهو للباقي منهما) ، لأن اليد للحَيِّ دون الميت ، وهذا الذي ذكرناه قول أبي حنيفة .

وقال أبو يوسف : يدفع إلى المرأة ما يجهز به مثلها ، والباقي للزوج مع يمينه ، لأن الظاهر أن المرأة تأتي بالجهاز ، وهذا أقوى فيبطل به ظاهر يد الزوج ، ثم في الباقي لا معارض لظاهر فيعتبر (والطلاق والموت سواء) لقيام الورثة مقام مورثهم (وقال محمد : وما كان للرجال فهو

³⁰⁴ () ومتى وقع الخلاف في الاستحقاق كان القول قول المستحق عليه مع يمينه . البناية 371/9 .

³⁰⁵ () أى : فإذا تعدر الفسخ في بعضه بالهلاك ، تعدر في الكل ضرورة ، فظهر الفرق . البناية 372/9 .

³⁰⁶ () البيان في مذهب الشافعي 503/8 .

لِلرَّجُلِ، وَمَا كَانَ لِلنِّسَاءِ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ، وَمَا يَكُونُ لَهُمَا ، فَهُوَ لِلرَّجُلِ أَوْ لَوَرَثَتِهِ) لِمَا قُلْنَا لِأَبِي حَنِيفَةَ (وَالطَّلَاقُ وَالْمَوْتُ سَوَاءٌ) لِقِيَامِ الْوَارِثِ مَقَامَ الْمُورِثِ (وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مَمْلُوكًا فَالْمَتَاعُ لِلْحُرِّ فِي حَالَةِ الْحَيَاةِ) ، لِأَنَّ يَدَ الْحُرِّ أَقْوَى (وَلِلْحَيِّ بَعْدَ الْمَمَاتِ) ، لِأَنَّهُ لَا يَدَ لِلْمَيِّتِ فَخَلَّتْ يَدُ الْحَيِّ عَنِ الْمُعَارِضِ (وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَقَالَا: الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ لَهُ فِي التَّجَارَةِ وَالْمُكَاتَبُ بِمَنْزِلَةِ الْحُرِّ) لِأَنَّ لَهُمَا يَدًا مُعْتَبَرَةً فِي الْخُصُومَاتِ.

(فَصْلٌ فِيمَنْ لَا يَكُونُ خَصْمًا)

اندفاع خصومة المدعى عليه بقوله : أودعني فلان الغائب وما أشبهه : " (وَأِنْ قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ هَذَا الشَّيْءُ : أَوْدَعَنِيهِ فَلَانُ الْغَائِبُ أَوْ رَهْنَهُ عِنْدِي أَوْ غَصَبْتُهُ مِنْهُ ، وَأَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى ذَلِكَ ، فَلَا خُصُومَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُدَّعِي) وَكَذَا إِذَا قَالَ: أَجْرَنِيهِ ، وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ ، لِأَنَّهُ أَثْبَتَ بَيِّنَتَهُ أَنَّ يَدَهُ لَيْسَتْ بِيَدِ خُصُومَةٍ.

وَقَالَ ابْنُ شُبْرَمَةَ⁽³⁰⁷⁾: لَا تَنْدَفِعُ الْخُصُومَةُ ، لِأَنَّهُ تَعَذَّرَ إثْبَاتُ الْمَلِكِ لِلْغَائِبِ لِعَدَمِ الْخَصْمِ عَنْهُ وَدَفْعُ الْخُصُومَةِ بِنَاءً عَلَيْهِ).⁽³⁰⁸⁾

قُلْنَا: مُقْتَضَى الْبَيِّنَةِ شَيْئَانِ ، ثُبُوتُ الْمَلِكِ لِلْغَائِبِ ، وَلَا خَصْمَ فِيهِ فَلَمْ يَثْبُتْ ، وَدَفْعُ خُصُومَةِ الْمُدَّعِي ، وَهُوَ خَصْمٌ فِيهِ فَيَثْبُتْ ، وَهُوَ كَالْوَكِيلِ بِنَقْلِ الْمَرَاةِ ، وَإِقَامَتِهَا الْبَيِّنَةَ عَلَى الطَّلَاقِ ، كَمَا بَيَّنَّاهُ مِنْ قَبْلُ ، وَلَا تَنْدَفِعُ بِدُونِ إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى⁽³⁰⁹⁾ ، لِأَنَّهُ صَارَ خَصْمًا بِظَاهِرِ يَدِهِ ، فَهُوَ بِإِقْرَارِهِ يُرِيدُ أَنْ يُحَوَّلَ حَقًّا مُسْتَحَقًّا عَلَى نَفْسِهِ ، فَلَا يَصْدُقُ إِلَّا بِالْحُجَّةِ ، كَمَا إِذَا ادَّعَى تَحَوُّلَ الدَّيْنِ مِنْ ذِمَّتِهِ إِلَى ذِمَّةٍ غَيْرِهِ.

(وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: إِنْ كَانَ الرَّجُلُ صَالِحًا ، فَالْجَوَابُ كَمَا قُلْنَا ، وَإِنْ كَانَ مَعْرُوفًا بِالْحِيلِ ، لَا تَنْدَفِعُ عَنْهُ الْخُصُومَةُ) ، لِأَنَّ الْمُحْتَالَ مِنَ النَّاسِ قَدْ يَدْفَعُ مَالَهُ إِلَى مُسَافِرٍ يُودِعُهُ إِيَّاهُ وَيَشْهَدُ عَلَيْهِ الشُّهُودُ فَيَحْتَالُ لِإِبْطَالِ حَقِّ غَيْرِهِ ، فَإِذَا اتَّهَمَهُ الْقَاضِي بِهِ لَا يَقْبَلُهُ.

لا تندفع الخصومة عن المدعى عليه بقول الشهود: أودعه رجل لانعرفه : " (وَلَوْ قَالَ الشُّهُودُ: أَوْدَعَهُ رَجُلٌ لَا نَعْرِفُهُ لَا تَنْدَفِعُ عَنْهُ الْخُصُومَةُ) ، لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْمُوَدَّعُ هُوَ هَذَا الْمُدَّعِي ، وَلِأَنَّهُ مَا أَحَالَهُ إِلَى مُعَيَّنٍ يُمَكِّنُ لِلْمُدَّعِي اتِّبَاعَهُ ، فَلَوْ انْدَفَعَتْ لَتَضَرَّرَ بِهِ الْمُدَّعِي ، وَلَوْ قَالُوا:

()³⁰⁷ هو: أبو شبرمة، عبد الله بن شبرمة - بضم المعجمة، وسكون الموحدة، وضم الراء - ابن الطفيل بن حسان، الضبي، الكوفي، القاضي، توفي سنة أربع وأربعين ومائة، من الخامسة، ثقة، فقيه. المعجم الصغير لرواة الإمام ابن جرير الطبري، لأكرم بن محمد زيادة الفالوجي الأثري. 2/799

³⁰⁸ () أي دفع الخصومة عن الغائب، وإثبات الملك للغائب بدون الخصومة متعذر، إذ ليس لأحد ولاية إدخال شيء في ملك غيره بغير رضاه، (ودفع الخصومة بناء عليه) : أي على إثبات الملك والبناء على المتعذر متعذر. البناية 376/9.

()³⁰⁹ محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى يسار (وقيل: داود) ابن بلال الأنصاري الكوفي: قاض، فقيه، من أصحاب الرأي. ولي القضاء والحكم بالكوفة لبني أمية، ثم لبني العباس. واستمر 33 سنة ، له أخبار مع الإمام أبي حنيفة وغيره. مات بالكوفة سنة 148 هـ. الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة ، لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي (المتوفى: 74هـ/193، الوافي بالوفيات 3/184، 185.

نَعْرِفُهُ بِوَجْهِهِ وَلَا نَعْرِفُهُ بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ ، فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ ، لِلْوَجْهِ الثَّانِي، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ تَنْدَفَعُ ، لِأَنَّهُ أَثْبَتَ بَيِّنَتَهُ أَنَّ الْعَيْنَ وَصَلَ إِلَيْهِ مِنْ جِهَةٍ غَيْرِهِ حَيْثُ عَرَفَهُ الشَّهُودُ بِوَجْهِهِ، بِخِلَافِ الْفَصْلِ الْأَوَّلِ ، فَلَمْ تَكُنْ يَدُهُ يَدَ خُصُومَةٍ ، وَهُوَ الْمَقْصُودُ، وَالْمُدَّعِي هُوَ الَّذِي أَضَرَّ بِنَفْسِهِ حَيْثُ نَسِيَ خَصْمَهُ أَوْ أَضَرَّهُ شُهُودُهُ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مُخَمَّسَةٌ كِتَابِ الدَّعْوَى وَقَدْ ذَكَّرْنَا الْأَقْوَالَ الْخَمْسَةَ.

لا تندفع الخصومة عن المدعى عليه بقوله : ابتعته من الغائب : " (وَأِنْ قَالَ: ابْتَعْتُهُ مِنَ الْغَائِبِ فَهُوَ خَصْمٌ) ، لِأَنَّهُ لَمَّا زَعَمَ أَنَّ يَدَهُ يَدُ مَلِكٍ اعْتَرَفَ بِكَوْنِهِ خَصْمًا ، (وَأِنْ قَالَ الْمُدَّعِي: غَصَبْتُهُ مِنِّي أَوْ سَرَقْتُهُ مِنِّي ، لَا تَنْدَفَعُ الْخُصُومَةُ وَإِنْ أَقَامَ ذُو الْيَدِ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْوَدِيعَةِ)، لِأَنَّهُ إِنَّمَا صَارَ خَصْمًا بِدَعْوَى الْفِعْلِ عَلَيْهِ لَا بِيَدِهِ، بِخِلَافِ دَعْوَى الْمَلِكِ الْمُطْلَقِ ، لِأَنَّهُ خَصْمٌ فِيهِ بِاعْتِبَارِ يَدِهِ حَتَّى لَا يَصِحَّ دَعْوَاهُ عَلَى غَيْرِ ذِي الْيَدِ، وَيَصِحُّ دَعْوَى الْفِعْلِ.

اندفاع الخصومة في دعوى السرقة بقول صاحب اليد : أودعني فلان : " (وَأِنْ قَالَ الْمُدَّعِي: سَرَقَ مِنِّي ، وَقَالَ صَاحِبُ الْيَدِ: أَوْدَعَنِيهِ فُلَانٌ ، وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ لَمْ تَنْدَفَعِ الْخُصُومَةُ) وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَهُوَ اسْتِحْسَانٌ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ: تَنْدَفَعُ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَدَّعِ الْفِعْلَ عَلَيْهِ فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ: غُصِبَ مِنِّي عَلَى مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ، وَلَهُمَا : أَنَّ ذِكْرَ الْفِعْلِ يَسْتَدْعِي الْفَاعِلَ لَا مَحَالَةَ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ هُوَ الَّذِي فِي يَدِهِ ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُعَيِّنْهُ دَرَأًا لِلْحَدِّ شَفَقَةً عَلَيْهِ وَإِقَامَةً لِحِسْبَةِ السَّرِّ ، فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ: سَرَقْتَ، بِخِلَافِ الْغُصْبِ ، لِأَنَّهُ لَا حَدَّ فِيهِ فَلَا يُحْتَرَزُ عَنْ كَشْفِهِ).³¹⁰

اندفاع الخصومة في دعوى البيع بقول صاحب اليد : أودعني فلان : " (وَأِنْ قَالَ الْمُدَّعِي: ابْتَعْتُهُ مِنْ فُلَانٍ ، وَقَالَ صَاحِبُ الْيَدِ: أَوْدَعَنِيهِ فُلَانٌ ذَلِكَ ، أُسْقِطَتْ الْخُصُومَةُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ) ، لِأَنَّهُمَا تَوَافَقَا عَلَى أَنَّ أَصْلَ الْمَلِكِ فِيهِ لِعَيْرِهِ فَيَكُونُ وَصُولُهَا إِلَى يَدِ ذِي الْيَدِ مِنْ جِهَتِهِ ، فَلَمْ تَكُنْ يَدُهُ يَدَ خُصُومَةٍ ، إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّ فُلَانًا وَكَلَّهُ بِقَبْضِهِ ، لِأَنَّهُ أَثْبَتَ بَيِّنَتَهُ كَوْنَهُ أَحَقَّ بِإِمْسَاكِهَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

³¹⁰ () ولأنه غير معذور في التجهيل . البناية 380/9.

(بَابُ مَا يَدَّعِيهِ الرَّجُلَانِ)

إذا ادعى اثنان عينا في يد ثالث ببيئتهما : "قَالَ (وَإِذَا ادَّعَى اثنان عينا في يد آخر كل واحد منهما يزعم أنها له ، وأقاما البيّنة قضى بها ببيئتهما)⁽³¹¹⁾ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي قَوْلِهِ: تَهَاتَرَتَا⁽³¹²⁾، وَفِي قَوْلٍ يُقَرَّعُ بَيْنَهُمَا⁽³¹³⁾؛ لِأَنَّ إِحْدَى الْبَيِّنَتَيْنِ كَاذِبَةٌ بَيِّنٌ ، لِاسْتِحَالَةِ اجْتِمَاعِ الْمَلَكَيْنِ فِي الْكُلِّ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَقَدْ تَعَدَّرَ التَّمْيِيزُ فَيَتَهَاتَرَانِ أَوْ يُصَارُ إِلَى الْقُرْعَةِ ، "لِأَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أَفْرَعَ فِيهِ وَقَالَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ الْحَكَمُ بَيْنَهُمَا⁽³¹⁴⁾" ، وَلَنَا حَدِيثُ تَمِيمِ بْنِ طَرْفَةَ : " أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فِي نَاقَةٍ وَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ ، فَقَضَى بِهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ. " ⁽³¹⁵⁾

وَحَدِيثُ الْقُرْعَةِ كَانَ فِي الْإِبْتِدَاءِ ثُمَّ نُسِخَ ، وَلِأَنَّ الْمُطْلَقَ لِلشَّهَادَةِ فِي حَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُحْتَمَلُ الْوُجُودِ ، بَلْ يَعْتَمِدُ أَحَدُهُمَا سَبَبَ الْمَلِكِ ، وَالْآخَرُ الْيَدَ ، فَصَحَّتِ الشَّهَادَتَانِ ، فَيَجِبُ الْعَمَلُ بِهِمَا مَا أُمِّكَنْ ، وَقَدْ أُمِّكَنْ بِالتَّنْصِيفِ ، إِذِ الْمَحِلُّ يَقْبَلُهُ ، وَإِنَّمَا يُنْصَفُ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي سَبَبِ الْإِسْتِحْقَاقِ.) ⁽³¹⁶⁾

إذا ادعى اثنان نكاح امرأة وإقاما بيّنة مطلقة على ذلك : "قَالَ (فَإِنْ ادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِكَاحَ امْرَأَةٍ وَأَقَامَا بَيِّنَةً ، لَمْ يَقْضَ بِوَاحِدَةٍ مِنَ الْبَيِّنَتَيْنِ) ، لِتَعَدُّرِ الْعَمَلِ بِهِمَا؛ لِأَنَّ الْمَحِلَّ لَا يَقْبَلُ الْإِسْتِرَاكَ.

قَالَ (وَيَرْجِعُ إِلَى تَصْدِيقِ الْمَرْأَةِ لِأَحَدِهِمَا) ، لِأَنَّ النِّكَاحَ مِمَّا يُحْكَمُ بِهِ بِتَصَادُقِ الرَّوَجَيْنِ ، وَهَذَا إِذَا لَمْ تُؤَقَّتِ الْبَيِّنَتَانِ.

⁽³¹¹⁾ () به قال الحنفية ، وقول عند المالكية ، وقول عند الشافعية ورواية أبي الخطاب عن أحمد وقول الظاهرية ، واستدلوا بحديث الناقة ، ولأن البيّنة أقوى من اليد ، وقد ثبت أنها إذا تساويا في اليد جعل بينهما ، فكذلك إذا تساويا في البيّنة من باب أولى . الفتاوى التاتارخانية 5/502 ، الذخيرة 10/180 ، الحاوي 17/319 ، المغنى 14/234 ، المحلى 9/436 ، 437.

⁽³¹²⁾ () وهو قول مالك ، والأصح عند الشافعية ، ورواية عن أحمد ، واستدلوا : بأن البيّنة حجة في الشرع ، والبيّنتان حجتان تعارضتا دون مرجح ، فسقطتا ، كالخبرين إذا تعارضا. الذخيرة 10/120 ، 180 ، الحاوي 17/319 ، الكافي 6/158 ، المغنى 14/233.

⁽³¹³⁾ () وهو قول عند الشافعية ، ورواية أبي الخطاب عن أحمد البيان في مذهب الشافعي 7/169 ، المغنى 14/234 ، الكافي ، لابن قدامة 6/158.

⁽³¹⁴⁾ () رواه الطبراني في الأوسط 3/98 ، 99 ، وقال : تفرد به أبو مصعب ، أبو داود في مراسيله رقم 424.

⁽³¹⁵⁾ () رواه أبو داود ، وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه . السنن رقم 1613 ، المستدرک 4/95.

⁽³¹⁶⁾ () البحر الرائق 7/397 ، تصنيف المسامع بجمع الجوامع ، لتاج الدين السبكي 3/492.

إذا ادعى اثنان نكاح امرأة وإقاما بينة مؤرخة على ذلك : "فَأَمَّا إِذَا وَقَّتَا فَصَاحِبُ الْوَقْتِ الْأَوَّلُ أَوْلَى ، وَإِنْ أَقَرَّتْ لِأَحَدِهِمَا قَبْلَ إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ ، فَهِيَ أَمْرَأَتُهُ ، لِتَصَادُقَهُمَا (وَإِنْ أَقَامَ الْآخَرُ الْبَيِّنَةَ قُضِيَ بِهَا) ، لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ أَقْوَى مِنَ الْإِقْرَارِ ، وَلَوْ تَفَرَّدَ أَحَدُهُمَا بِالدَّعْوَى ، وَالْمَرْأَةُ تَجَحَّدُ ، فَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ ، وَقُضِيَ بِهَا الْقَاضِي لَهُ ، ثُمَّ ادَّعَى الْآخَرُ ، وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ ، لَا يَحْكُمُ بِهَا) ، لِأَنَّ الْقَضَاءَ الْأَوَّلَ قَدْ صَحَّ ، فَلَا يُنْقَضُ بِمَا هُوَ مِثْلُهُ ، بَلْ هُوَ دُونَهُ (إِلَّا أَنْ يُوقَّتَ شُهُودُ الثَّانِي سَابِقًا) ، لِأَنَّهُ ظَهَرَ الْخَطَأُ فِي الْأَوَّلِ بَيِّقِينَ ، وَكَذَا إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي يَدِ الزَّوْجِ وَنِكَاحُهُ ظَاهِرًا ، لَا تُقْبَلُ بَيِّنَةُ الْخَارِجِ إِلَّا عَلَى وَجْهِ السَّبْقِ).³¹⁷

ادعى اثنان شراء عبد وأقاما بينة مطلقة ، وكان العبد في يد ثالث : "قَالَ (وَلَوْ ادَّعَى اثْنَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهُ اشْتَرَى مِنْهُ هَذَا الْعَبْدَ) ، مَعْنَاهُ مَنْ صَاحِبِ الْيَدِ ، وَأَقَامَا بَيِّنَةً فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ ، إِنْ شَاءَ أَحَدٌ نَصَفَ الْعَبْدَ بِنِصْفِ الثَّمَنِ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ) ، لِأَنَّ الْقَاضِيَّ يَقْضِي بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، لِاسْتَوَائِهِمَا فِي السَّبَبِ ، فَصَارَ كَالْفُضُولِيِّينَ إِذَا بَاعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ رَجُلٍ ، وَأَجَازَ الْمَالِكُ الْبَيِّعَيْنِ ، يُخَيَّرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، لِأَنَّهُ تَغَيَّرَ عَلَيْهِ شَرْطُ عَقْدِهِ ، فَلَعَلَّ رَغْبَتَهُ فِي تَمْلُكِ الْكُلِّ فَبَرَدَتْ ، وَيَأْخُذُ كُلُّ الثَّمَنِ ، فَإِنْ قَضَى الْقَاضِي بِهِ بَيْنَهُمَا ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: لَا أَخْتَارُ ، لَمْ يَكُنْ لِلْآخَرِ أَنْ يَأْخُذَ جَمِيعَهُ) ، لِأَنَّهُ صَارَ مَقْضِيًّا عَلَيْهِ فِي النِّصْفِ ، فَانْفَسَخَ الْبَيْعُ فِيهِ ، وَهَذَا لِأَنَّهُ خَصَمَ فِيهِ لِظُهُورِ اسْتِحْقَاقِهِ بِالْبَيِّنَةِ لَوْلَا بَيِّنَةُ صَاحِبِهِ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ ذَلِكَ قَبْلَ تَخْيِيرِ الْقَاضِي ، حَيْثُ يَكُونُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْجَمِيعَ ، لِأَنَّهُ يَدَّعِي الْكُلَّ وَلَمْ يَفْسَخْ سَبَبَهُ ، وَالْعَوْدُ إِلَى النِّصْفِ لِلْمَزَاحِمَةِ ، وَلَمْ تُوجَدْ ، وَنَظِيرُهُ تَسْلِيمُ أَحَدِ الشَّفِيعَيْنِ قَبْلَ الْقَضَاءِ ، وَنَظِيرُ الْأَوَّلِ تَسْلِيمُهُ بَعْدَ الْقَضَاءِ .

ادعى اثنان شراء عبد وأقاما بينة مؤرخة ، وكان العبد في يد ثالث: وَلَوْ ذَكَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تَارِيخًا فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا) ، لِأَنَّهُ أَثْبَتَ الشِّرَاءَ فِي زَمَانٍ لَا يُنَازَعُ فِيهِ أَحَدٌ فَاذْدَفَعَ الْآخَرُ بِهِ .

ادعى اثنان شراء عبد وأقام أحدهما بينة مطلقة والآخر مقيدة: (وَلَوْ وَقَّتَتْ إِحْدَاهُمَا وَلَمْ تُوقَّتِ الْآخَرَى فَهُوَ لِصَاحِبِ الْوَقْتِ) لِثَبُوتِ مِلْكِهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَاحْتِمَالِ الْآخَرِ أَنْ يَكُونَ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ فَلَا يَقْضِي لَهُ بِالشَّكِّ .

ادعى اثنان شراء عبد وأقاما بينة مطلقة وكان العبد في يد أحدهما : (وَإِنْ لَمْ يَذْكُرَا تَارِيخًا وَمَعَ أَحَدِهِمَا قَبْضٌ فَهُوَ أَوْلَى) ، وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ فِي يَدِهِ ، لِأَنَّ تَمَكُّنَهُ مِنْ قَبْضِهِ يَدُلُّ عَلَى سَبْقِ شِرَائِهِ ، وَلِأَنَّهُمَا اسْتَوَيَا فِي الْإِثْبَاتِ فَلَا تُنْقَضُ الْيَدُ الثَّابِتَةُ بِالشَّكِّ ، وَكَذَا لَوْ ذَكَرَ الْآخَرُ وَقَّتَا لِمَا بَيَّنَّا ، إِلَّا أَنْ يَشْهَدُوا أَنَّ شِرَاءَهُ كَانَ قَبْلَ شِرَاءِ صَاحِبِ الْيَدِ ، لِأَنَّ الصَّرِيحَ يَفُوقُ الدَّلَالََةَ.

³¹⁷ () أي : إلا على وجه: أن بينته تشهد أن نكاحه قبل نكاح الأول، فحينئذ ينتقض نكاح الأول ، لظهور الخطأ فيه بيقين . البناية 384/9.

إذا ادعى أحدهما شراء العبد والآخر الهبة ببينة مطلقة وقبضاه من ثالث: " قَالَ: (وَإِنْ ادَّعى أَحَدُهُمَا شِرَاءً وَالْآخَرُ هِبَةً وَقَبْضًا) ، مَعْنَاهُ: مِنْ وَاحِدٍ (وَأَقَامَا بَيِّنَةً ، وَلَا تَارِيخَ مَعَهُمَا ، فَالشَّرَاءُ أَوْلَى) ، لِأَنَّ الشَّرَاءَ أَقْوَى ، لِكُونِهِ مُعَاوَضَةً مِنَ الْجَانِبَيْنِ ، وَلِأَنَّهُ يُثْبِتُ الْمَلِكُ بِنَفْسِهِ ، وَالْمَلِكُ فِي الْهِبَةِ يَتَوَقَّفُ عَلَى الْقَبْضِ ، وَكَذَا الشَّرَاءُ وَالصَّدَقَةُ مَعَ الْقَبْضِ لِمَا بَيَّنَّا .

(وَالْهِبَةُ وَالْقَبْضُ وَالصَّدَقَةُ مَعَ الْقَبْضِ سَوَاءٌ حَتَّى يَقْضِيَ بَيْنَهُمَا) ، لِاسْتِوَائِهِمَا فِي وَجْهِ التَّبَرُّعِ ، وَلَا تَرْجِيحَ بِالزُّرُومِ ، لِأَنَّهُ يَرْجِعُ إِلَى الْمَالِ ، وَالتَّرْجِيحُ بِمَعْنَى قَائِمٍ فِي الْحَالِ ، وَهَذَا فِيمَا لَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ صَحِيحٌ ، وَكَذَا فِيمَا يَحْتَمِلُهَا عِنْدَ الْبَعْضِ ، لِأَنَّ الشُّيُوعَ طَارِئٌ ، وَعِنْدَ الْبَعْضِ لَا يَصِحُّ ، لِأَنَّهُ تَنْفِيذُ الْهِبَةِ فِي الشَّائِعِ ، وَصَارَ كَأَقَامَةِ الْبَيِّنَتَيْنِ عَلَى الْإِرْتِهَانِ وَهَذَا أَصَحُّ .

إذا ادعى الزوج شراء العبد وادعت زوجته أنه مهرها: " قَالَ (وَإِذَا ادَّعى أَحَدُهُمَا الشَّرَاءَ ، وَادَّعَتْ امْرَأَتُهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا عَلَيْهِ فَهُمَا سَوَاءٌ) ، لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الْقُوَّةِ ، فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ ، يُثْبِتُ الْمَلِكُ بِنَفْسِهِ ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ: الشَّرَاءُ أَوْلَى ، وَلَهَا عَلَى الزَّوْجِ الْقِيَمَةُ ، لِأَنَّهُ أَمَكَّنَ الْعَمَلَ بِالْبَيِّنَتَيْنِ بِتَقْدِيمِ الشَّرَاءِ ، إِذِ التَّرَوُّجُ عَلَى عَيْنِ مَمْلُوكَةٍ لِلْغَيْرِ صَحِيحٌ ، وَتَجِبُ قِيَمَتُهُ عِنْدَ تَعَدُّرِ تَسْلِيمِهِ .

إذا ادعى أحدهما رهنا وقبضا والآخر هبة وقبضا: " وَإِذَا ادَّعى أَحَدُهُمَا رَهْنًا وَقَبْضًا وَالْآخَرُ هِبَةً وَقَبْضًا وَأَقَامَا بَيِّنَةً فَالرَّهْنُ أَوْلَى) وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ ، وَفِي الْقِيَاسِ الْهِبَةُ أَوْلَى لِأَنَّهَا تُثْبِتُ الْمَلِكُ وَالرَّهْنُ لَا يُثْبِتُهُ .

وَجْهُ الْإِسْتِحْسَانِ : أَنَّ الْمَقْبُوضَ بِحُكْمِ الرَّهْنِ مَضْمُونٌ ، وَبِحُكْمِ الْهِبَةِ غَيْرُ مَضْمُونٍ ، وَعَقْدُ الضَّمَانِ أَقْوَى ، بِخِلَافِ الْهِبَةِ بِشَرْطِ الْعَوَضِ ، لِأَنَّهُ يَبِيعُ انْتِهَاءً وَالْبَيْعُ أَوْلَى مِنَ الرَّهْنِ ، لِأَنَّهُ عَقْدُ ضَمَانٍ يُثْبِتُ الْمَلِكُ صُورَةً وَمَعْنًى ، وَالرَّهْنُ لَا يُثْبِتُهُ إِلَّا عِنْدَ الْهَلَاكِ مَعْنًى لَا صُورَةً ، فَكَذَا الْهِبَةُ بِشَرْطِ الْعَوَضِ .

إذا أقام الخارجان بينة مقيدة على الملك وتاريخ أحدهما أقدم: " (وَإِنْ أَقَامَ الْخَارِجَانِ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمَلِكِ وَالتَّارِيخَ ، فَصَاحِبُ التَّارِيخِ الْأَقْدَمُ أَوْلَى) ، لِأَنَّهُ أَثْبَتَ أَنَّهُ أَوَّلُ الْمَالِكَيْنِ ، فَلَا يَتَلَقَّى الْمَلِكُ إِلَّا مِنْ جِهَتِهِ ، وَلَمْ يَتَلَقَّ الْآخَرُ مِنْهُ³¹⁸).

³¹⁸() ولأن الملك ثبت للبينة الأقدم ، ومن القواعد الفقهية " إبقاء ما كان على ما كان " وما أثبتته البينة الأخرى محتمل ، لمعارضة هذه البينة له ، فتساقطتا فيما تعارضتا فيه ، ويبقى استصحاب الحال لذات الأقدم . البحر الرائق 397/7 ، خزانة الأكملة ، للرجاني 761/3 .

إذا ادعى الشراء من غير صاحب اليد وتاريخ أحدهما أقدم : "قَالَ: (وَلَوْ ادَّعَى الشَّرَاءَ مِنْ وَاحِدٍ) مَعْنَاهُ مِنْ غَيْرِ صَاحِبِ الْيَدِ ، وَأَقَامَا الْبَيِّنَةَ عَلَى تَارِيخَيْنِ فَلِأَوَّلِ أُولَى) ، لِمَا بَيَّنَّا أَنَّهُ أَثْبَتَهُ فِي وَفْتٍ لَا مُنَازَعٍ لَهُ فِيهِ .

إذا ادعى كل منهما الشراء من آخر ببينة مؤرخة : "(وَإِنْ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ عَلَى الشَّرَاءِ مِنْ آخَرَ ، وَذَكَرَا تَارِيخًا) ، فَهُمَا سَوَاءٌ ، لِأَنَّهُمَا يُثْبِتَانِ الْمَلِكَ لِبَائِعِيهِمَا ، فَيَصِيرُ كَأَنَّهُمَا حَضَرَا ، ثُمَّ يُخَيَّرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَمَا ذَكَرْنَا مِنْ قَبْلُ . ادعى كل منهما الشراء من آخر وإحدى البينتين مؤرخة دون الأخرى : "(وَلَوْ وَقَّتْ إِحْدَى الْبَيِّنَتَيْنِ وَقَّتَا ، وَلَمْ تُوقَّتِ الْأُخْرَى ، قَضَى بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ) ، لِأَنَّ تَوْقِيتَ إِحْدَاهُمَا لَا يَدُلُّ عَلَى تَقَدُّمِ الْمَلِكِ ، لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْآخَرُ أَقْدَمَ ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ الْبَائِعُ وَاحِدًا ، لِأَنَّهُمَا اتَّفَقَا عَلَى أَنَّ الْمَلِكَ لَا يُتْلَقَى إِلَّا مِنْ جِهَتِهِ ، فَإِذَا أَثْبَتَ أَحَدُهُمَا تَارِيخًا يَحْكُمُ بِهِ حَتَّى يَبَيَّنَ أَنَّهُ تَقَدَّمَ شِرَاءَ غَيْرِهِ (319).

إذا ادعى الأول الشراء من آخر ، والثاني الهبة والقبض ، والثالث الميراث من أبيه ، والرابع الصدقة : وَلَوْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا الشَّرَاءَ مِنْ رَجُلٍ ، وَالْآخَرُ الْهَبَةَ وَالْقَبْضَ مِنْ غَيْرِهِ ، وَالثَّالِثُ الْمِيرَاثَ مِنْ أَبِيهِ ، وَالرَّابِعُ الصَّدَقَةَ وَالْقَبْضَ مِنْ آخَرَ ، قَضَى بَيْنَهُمْ أَرْبَاعًا) ، لِأَنَّهُمْ يَتَلَقَّوْنَ الْمَلِكَ مِنْ بَاعَتِهِمْ فَيَجْعَلُ كَأَنَّهُمْ حَضَرُوا وَأَقَامُوا الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمَلِكِ الْمُطْلَقِ.

إذا أقام الخارج بيينة على ملك مؤرخ وصاحب اليد بيينة على ملك أقدم : "قَالَ: (وَإِنْ أَقَامَ الْخَارِجُ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَلِكٍ مُؤَرَّخٍ وَصَاحِبُ الْيَدِ بَيِّنَةً عَلَى مَلِكٍ أَقْدَمَ تَارِيخًا كَانَ أُولَى) ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَهُوَ رَوَايَةٌ عَنْ مُحَمَّدٍ ، وَعَنْهُ أَنَّهُ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ رَجَعَ إِلَيْهِ ، لِأَنَّ الْبَيِّنَتَيْنِ قَامَتَا عَلَى مُطْلَقِ الْمَلِكِ ، وَلَمْ يَتَعَرَّضَا لِجِهَةِ الْمَلِكِ ، فَكَانَ التَّقَدُّمُ وَالتَّأَخُّرُ سَوَاءً (320).

³¹⁹ () ، لِأَنَّ الْبَائِعَ إِنْ كَانَ وَاحِدًا كَانَ التَّعَاقُبُ ضَرُورِيًّا ، وَقَدْ ثَبَتَ لِأَحَدِهِمَا بِالْبَيِّنَةِ مَلِكٌ فِي وَفْتٍ ، وَمَلِكٌ غَيْرُهُ مَشْكُوكٌ إِنْ تَأَخَّرَ لَمْ يَضُرَّ ، وَإِنْ تَقَدَّمَ مَلِكٌ فَتَعَارَضَا فَيُرَجَّحُ بِالْوَفْتِ ، وَأَمَّا إِذَا كَانَ مُتَعَدِّدًا ، فَكَمَا جَازَ أَنْ يَقَعَ مُتَعَاقِبَيْنِ ، جَازَ أَنْ يَقَعَ مَعًا ، وَفِي ذَلِكَ تَعَارُضٌ أَيْضًا ، فَضَعُفُ قُوَّةِ الْوَفْتِ عَنِ التَّرْجِيحِ لِنُضَاعِفِ التَّعَارُضِ . العناية 261/8، 262.

³²⁰ () رَوَى ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْهُ - أَيْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ - أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ هَذَا الْقَوْلِ ، وَهُوَ أَنَّ بَيِّنَةَ ذِي الْيَدِ إِذَا كَانَتْ أَقْدَمَ تَارِيخًا كَانَتْ أُولَى مِنْ بَيِّنَةِ الْخَارِجِ ، وَقَالَ: لَا أَقْبَلُ مِنْ ذِي الْيَدِ بَيِّنَةً عَلَى تَارِيخٍ وَغَيْرِهِ إِلَّا لِلنَّتَاجِ ، لِأَنَّ النَّتَاجَ دَلِيلٌ عَلَى أُولِيَّةِ الْمَلِكِ دُونَ التَّارِيخِ ، لِأَنَّ الْبَيِّنَتَيْنِ قَامَتَا عَلَى مُطْلَقِ الْمَلِكِ وَلَمْ يَتَعَرَّضَا لِجِهَةِ الْمَلِكِ فَكَانَ التَّقَدُّمُ وَالتَّأَخُّرُ سَوَاءً . العناية 262/8.

وَلَهُمَا : أَنَّ الْبَيِّنَةَ مَعَ التَّارِيخِ مُتَضَمِّنَةٌ مَعْنَى الدَّفْعِ ، فَإِنَّ الْمَلِكَ إِذَا ثَبَتَ لِشَخْصٍ فِي وَقْتٍ ، قُبُورُهُ لِغَيْرِهِ بَعْدَهُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِالتَّلَقِّيِّ مِنْ جِهَتِهِ ، وَبَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ عَلَى الدَّفْعِ مَقْبُولَةٌ⁽³²¹⁾ ، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ لَوْ كَانَتْ الدَّارُ فِي أَيْدِيهِمَا وَالْمَعْنَى مَا بَيَّنَّا .

إذا أقام الخارج وذو اليد البينة على ملك مطلق ووقعت إحدى البينتين دون الأخرى : وَلَوْ أَقَامَ الْخَارِجُ وَذُو الْيَدِ الْبَيِّنَةَ عَلَى مِلْكٍ مُطْلَقٍ ، وَوَقَعَتْ إِحْدَاهُمَا دُونَ الْأُخْرَى ، فَعَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ الْخَارِجُ أَوْلَى .

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَهُوَ رَوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ: صَاحِبُ الْوَقْتِ أَوْلَى ، لِأَنَّهُ أَقْدَمُ ، وَصَارَ كَمَا فِي دَعْوَى الشَّرَاءِ إِذَا أُرْخَتْ إِحْدَاهُمَا كَانَ صَاحِبُ التَّارِيخِ أَوْلَى⁽³²²⁾ ، وَلَهُمَا: أَنَّ بَيِّنَةَ ذِي الْيَدِ إِنَّمَا تُقْبَلُ لِتَضَمُّنِهَا مَعْنَى الدَّفْعِ ، وَلَا دَفْعَ هَاهُنَا ، حَيْثُ وَقَعَ الشُّكُّ فِي التَّلَقِّيِّ مِنْ جِهَتِهِ⁽³²³⁾ ، وَعَلَى هَذَا إِذَا كَانَتْ الدَّارُ فِي أَيْدِيهِمَا .

إذا أقام الخارجان بينة على الملك المطلق ووقعت إحدى البينتين دون الأخرى : وَلَوْ كَانَتْ فِي يَدِ ثَالِثٍ ، وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا فَهُمَا سَوَاءٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: الَّذِي وَقَّتْ أَوْلَى ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ: الَّذِي أَطْلَقَ أَوْلَى ، لِأَنَّهُ ادَّعَى أَوَّلِيَّةَ الْمَلِكِ بِدَلِيلِ اسْتِحْقَاقِ الزَّوَادِ ، وَرُجُوعِ الْبَاعَةِ بَعْضِهِمْ عَلَى الْبَعْضِ ، وَلِأَبِي يُوسُفَ أَنَّ التَّارِيخَ يُوجِبُ الْمَلِكَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ بَيِّنِينَ ، وَالْإِطْلَاقُ يَحْتَمِلُ غَيْرَ الْأَوَّلِيَّةِ ، وَالتَّرْجِيحُ بِالتَّيَقُّنِ؛ كَمَا لَوْ ادَّعَى الشَّرَاءُ ، وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ التَّارِيخَ يُضَامُهُ⁽³²⁴⁾ (احْتِمَالُ عَدَمِ النِّقْدِ فَسَقَطَ اعْتِبَارُهُ ، فَصَارَ كَمَا لَوْ أَقَامَا الْبَيِّنَةَ عَلَى مِلْكٍ مُطْلَقٍ ، بِخِلَافِ الشَّرَاءِ ، لِأَنَّهُ أَمْرٌ حَادِثٌ ، فَيُضَافُ إِلَى أَقْرَبِ الْأَوْقَاتِ ، فَيَتَرَجَّحُ جَانِبُ صَاحِبِ التَّارِيخِ .

إذا أقام كل من الخارج وصاحب اليد بينة على نتائج الدابة أنها له : "قَالَ (وَإِنْ أَقَامَ الْخَارِجُ وَصَاحِبُ الْيَدِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً عَلَى النَّتَاجِ ، فَصَاحِبُ الْيَدِ أَوْلَى) ، لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ قَامَتْ عَلَى مَا لَا نَدْلُ عَلَيْهِ فَاسْتَوَيَا ، وَتَرَجَّحَتْ بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ بِالْيَدِ ، فَيَفْضِي لَهُ ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ ، خِلَافًا لِمَا

³²¹ () ولأن نقل الملكة حاصل لمن سبق ، والعقد عليه بعده لا يصح ، لأن بينة ذي اليد أولى من غير التاريخ ، فأولى أن يكون أولى مع التاريخ . الفتاوى الهندية 95/4 ، العقود الدرية 590/1 .

³²² () وهو المفتى به عند الحنفية ، وقول أشهب من المالكية ، وابن رزين من الحنابلة . قرة عيون الأخبار 22/12 ، 23 ، 39 ، الذخيرة 184/10 ، الإنصاف 359/11 .

³²³ () وهو قول عند المالكية ، ووجه عند الحنابلة ، ولأن الملك قد يكون ثابتاً لصاحب البينة المطلقة قبل ثبوته لصاحب البينة المؤرخة ، فترجح بينته ، وهذا مردود : لأن انتقال الملكية لا يثبت مع الشك . خزانة الأكمال 761/3 ، قرة عيون الأخبار 22/12 ، 23 . التاج والإكليل 253/8 ، الإنصاف 359/11 .

³²⁴ () أى : يزاحمه ، البناية 394/9 .

يَقُولُهُ عِيسَى بْنُ أَبَانَ⁽³²⁵⁾ إِنَّهُ تَنَهَّاتُرَ الْبَيْتَانِ ، وَيُتْرَكُ فِي يَدِهِ ، لَا عَلَى طَرِيقِ الْقَضَاءِ ، وَلَوْ تَلَقَّى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْمَلِكَ مِنْ رَجُلٍ أَقَامَ الْبَيْتَةَ عَلَى النَّتَاجِ عِنْدَهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ إِقَامَتِهَا عَلَى النَّتَاجِ فِي يَدِ نَفْسِهِ إِذَا أَقَامَ أَحَدُهُمَا الْبَيْتَةَ عَلَى الْمَلِكِ ، وَالْآخَرُ عَلَى النَّتَاجِ ، فَصَاحِبُ النَّتَاجِ أَوْلَى أُيُّهُمَا كَانَ) ، لِأَنَّ بَيْتَتَهُ قَامَتْ عَلَى أَوْلِيَّةِ الْمَلِكِ ، فَلَا يَثْبُتُ لِلْآخَرِ إِلَّا بِالتَّلَقِّي مِنْ جِهَتِهِ ، وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَتْ الدَّعْوَى بَيْنَ خَارَجَيْنِ فَبَيْتَةُ النَّتَاجِ أَوْلَى لِمَا ذَكَرْنَا (وَلَوْ قَضَى بِالنَّتَاجِ لِصَاحِبِ الْيَدِ ثُمَّ أَقَامَ ثَالِثُ الْبَيْتَةِ عَلَى النَّتَاجِ يَقْضِي لَهُ إِلَّا أَنْ يُعِيدَهَا ذُو الْيَدِ) لِأَنَّ الثَّالِثَ لَمْ يَصِرْ مَقْضِيًّا عَلَيْهِ بِتِلْكَ الْقَضِيَّةِ ، وَكَذَا الْمَقْضِي عَلَيْهِ بِالْمَلِكِ الْمُطْلَقِ إِذَا أَقَامَ الْبَيْتَةَ عَلَى النَّتَاجِ تُقْبَلُ وَيُنْقَضُ الْقَضَاءُ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ النَّصِّ. وَالْأَوَّلُ بِمَنْزِلَةِ الاجْتِهَادِ.

قَالَ (وَكَذَلِكَ النَّسْجُ فِي الثِّيَابِ الَّتِي لَا تُنْسَجُ إِلَّا مَرَّةً) كَغَزَلِ الْقُطْنِ (وَكَذَلِكَ كُلُّ سَبَبٍ فِي الْمَلِكِ لَا يَتَكَرَّرُ) ، لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى النَّتَاجِ ، كَحَلَبِ اللَّبَنِ ، وَاتِّخَاذِ الْحُبْنِ وَاللَّبْدِ ، وَالْمِرْعَزَى⁽³²⁶⁾ وَجَزَّ الصُّوفِ ، وَإِنْ كَانَ يَتَكَرَّرُ قُضِيَ بِهِ لِلخَارِجِ ، بِمَنْزِلَةِ الْمَلِكِ الْمُطْلَقِ ، وَهُوَ مِثْلُ الْخَزِّ وَالْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ وَزِرَاعَةِ الْحِنْطَةِ وَالْحُبُوبِ ، فَإِنْ أَشْكَلَ يَرْجِعُ إِلَى أَهْلِ الْخِبْرَةِ ، لِأَنَّهُمْ أَعْرَفُ بِهِ ، فَإِنْ أَشْكَلَ عَلَيْهِمْ قُضِيَ بِهِ لِلخَارِجِ ، لِأَنَّ الْقَضَاءَ بِبَيْتَتِهِ هُوَ الْأَصْلُ ، وَالْعُدُولُ عَنْهُ بِخَبَرِ النَّتَاجِ ، فَإِذَا لَمْ يَعْلَمْ يَرْجِعُ إِلَى الْأَصْلِ.

إِذَا أَقَامَ الْخَارِجُ الْبَيْتَةَ عَلَى الْمَلِكِ الْمُطْلَقِ ، وَصَاحِبُ الْيَدِ الْبَيْتَةَ عَلَى الشَّرَاءِ : "قَالَ (وَإِنْ أَقَامَ الْخَارِجُ الْبَيْتَةَ عَلَى الْمَلِكِ الْمُطْلَقِ ، وَصَاحِبُ الْيَدِ الْبَيْتَةَ عَلَى الشَّرَاءِ مِنْهُ ، كَانَ صَاحِبُ الْيَدِ أَوْلَى) ، لِأَنَّ الْأَوَّلَ إِنْ كَانَ يَدَّعِي أَوْلِيَّةَ الْمَلِكِ ، فَهَذَا تَلَقَّى مِنْهُ ، وَفِي هَذَا لَا تَنَافِي ، فَصَارَ كَمَا إِذَا أَقَرَّ بِالْمَلِكِ لَهُ ثُمَّ ادَّعَى الشَّرَاءَ مِنْهُ).⁽³²⁷⁾

إِذَا أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيْتَةً مُطْلَقَةً عَلَى الشَّرَاءِ مِنْ آخَرٍ : "قَالَ (وَإِنْ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيْتَةَ عَلَى الشَّرَاءِ مِنَ الْآخَرِ وَلَا تَارِيخَ مَعَهُمَا ، تَنَهَّاتُرَتِ الْبَيْتَانِ ، وَتُتْرَكُ الدَّارُ فِي يَدِ ذِي الْيَدِ) ، قَالَ : وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ ، وَعَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ يَقْضِي بِالْبَيْتَيْنِ ، وَيَكُونُ لِلخَارِجِ ، لِأَنَّ الْعَمَلَ بِهِمَا مُمَكِّنٌ ، فَيَجْعَلُ كَأَنَّهُ اشْتَرَى ذُو الْيَدِ مِنَ الْآخَرِ وَقَبِضَ ثُمَّ بَاعَ الدَّارَ ، لِأَنَّ

⁽³²⁵⁾ () عِيسَى بْنُ أَبَانَ بَنُ صَدَقَةَ ، وَلِي الْقَضَاءِ بِالْبَصْرَةِ ، فِي شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ سَنَةِ إِحْدَى عَشَرَ وَمِائَتَيْنِ . وَكَانَ عِيسَى سَهْلًا فَقِيهًا سَرِيعَ الْإِنْقَادِ لِلْأَحْكَامِ ، تَفَقَّهَ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ قِيلَ إِنَّهُ لَزِمَهُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ . أَخْبَارُ الْقَضَاءِ ، لِأَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ خَلْفٍ بْنِ حَيَّانَ بْنِ صَدَقَةَ الضَّبِّيِّ الْبَغْدَادِيِّ ، الْمُلقَّبُ بِ"وَكَيْعٍ" (المتوفى: 306هـ/170/2 ، الجواهر المضوية في طبقات الحنفية 1/401).

⁽³²⁶⁾ () والمرعزي : بكسر الميم والعين ، فإذا شددت الزاي قصرت ، وإذا خففت مدت ، وقد يقال : معزا بفتح الميم مخففا ممدودا ، وهي كالصوف تحت شعر الغنم ، أو الزغب الذي تحت شعر العنز .

البنية 396/9 ، البحر الرائق 1/192.

⁽³²⁷⁾ () فيقضى ببينته . البنية 379/9.

الْقَبْضَ دَلَالَةً السَّبْقِ عَلَى مَا مَرَّ، وَلَا يَعْكِسُ الْأَمْرَ ، لِأَنَّ الْبَيْعَ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا يَجُوزُ وَإِنْ كَانَ فِي الْعَقَارِ عِنْدَهُ، وَلَهُمَا : أَنَّ الْإِقْدَامَ عَلَى الشَّرَاءِ إِفْرَارٌ مِنْهُ بِالْمَلِكِ لِلْبَائِعِ ، فَصَارَ كَأَنَّهُمَا قَامَتَا عَلَى الْإِفْرَارَيْنِ وَفِيهِ التَّهَاتُرُ بِالْإِجْمَاعِ، كَذَا هَاهُنَا، وَلِأَنَّ السَّبَبَ يُرَادُ لِحُكْمِهِ وَهُوَ الْمَلِكُ ، وَلَا يُمَكِّنُ الْقَضَاءُ لِذِي الْيَدِ إِلَّا بِمَلِكٍ مُسْتَحَقٍّ ، فَبَقِيَ الْقَضَاءُ لَهُ بِمَجَرَّدِ السَّبَبِ وَأَنَّهُ لَا يُفِيدُهُ (328).

إذا أقام كل واحد منهما بينة مطلقة على نقد الثمن : "ثُمَّ لَوْ شَهِدَتِ الْبَيِّنَتَانِ عَلَى نَقْدِ الثَّمَنِ ، فَأَلَّافُ بِالْأَلْفِ قِصَاصٌ عِنْدَهُمَا إِذَا اسْتَوَيَا ، لَوْجُودِ قَبْضٍ مَضْمُونٍ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، وَإِنْ لَمْ يَشْهَدُوا عَلَى نَقْدِ الثَّمَنِ ، فَالْقِصَاصُ مَذْهَبٌ مُحَمَّدٌ لِلْوُجُوبِ عِنْدَهُ (329).

إذا أقام كل واحد منهما بينة مطلقة على البيع والقبض : "وَلَوْ شَهِدَ الْفَرِيقَانِ بِالْبَيْعِ وَالْقَبْضِ تَهَاتَرَتَا بِالْإِجْمَاعِ (330)، لِأَنَّ الْجَمْعَ غَيْرُ مُمَكِّنٍ عِنْدَ مُحَمَّدٍ ، لِحَوَازِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْبَيْعَيْنِ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ.

إذا أقام كل واحد منهما بينة مقيدة في العقار ولم تثبت قبضا وبينة الخارج أسبق : "وَإِنْ وَقَّتَتْ الْبَيِّنَتَانِ فِي الْعَقَارِ وَلَمْ تُثَبِّتَا قَبْضًا ، وَوَقَّتْ الْخَارِجُ أَسْبَقُ يُقْضَى لِصَاحِبِ الْيَدِ عِنْدَهُمَا ، فَيُجْعَلُ كَأَنَّ الْخَارِجَ اشْتَرَى أَوَّلًا ثُمَّ بَاعَ قَبْلَ الْقَبْضِ مِنْ صَاحِبِ الْيَدِ، وَهُوَ جَائِزٌ فِي الْعَقَارِ عِنْدَهُمَا ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَقْضَى لِلْخَارِجِ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ لَهُ بَيْعُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ فَبَقِيَ عَلَى مِلْكِهِ، وَإِنْ أَثَبَّتَا قَبْضًا ، يَقْضَى لِصَاحِبِ الْيَدِ ، لِأَنَّ الْبَيْعَيْنِ جَائِزَانِ عَلَى الْقَوْلَيْنِ، وَإِنْ كَانَ وَقَّتْ صَاحِبُ الْيَدِ أَسْبَقُ يُقْضَى لِلْخَارِجِ فِي الْوَجْهَيْنِ (331) ، فَيُجْعَلُ كَأَنَّهُ اشْتَرَاهَا ذُو الْيَدِ وَقَبِضَ ، ثُمَّ بَاعَ وَلَمْ يُسَلِّمْ ، أَوْ سَلَّمَ ، ثُمَّ وَصَلَ إِلَيْهِ بِسَبَبٍ آخَرَ.

إذا أقام أحد المدعين شاهدين والآخر أربعة : "قَالَ: (وَإِنْ أَقَامَ أَحَدُ الْمُدَّعِيَيْنِ شَاهِدَيْنِ وَالْآخَرُ أَرْبَعَةً فَهُمَا سَوَاءٌ) لِأَنَّ شَهَادَةَ كُلِّ الشَّاهِدَيْنِ عِلَّةٌ تَامَةٌ كَمَا فِي حَالَةِ الْإِنْفِرَادِ، وَالتَّرْجِيحُ لَا يَقَعُ بِكَثْرَةِ الْعِلَلِ بَلْ بِقُوَّةِ فِيهَا عَلَى مَا عُرِفَ.

(328) و لِأَنَّا إِذَا قَضَيْنَا بَيِّنَةً ذِي الْيَدِ ، إِنَّمَا نَقْضِي لِيَزُولَ مِلْكُهُ إِلَى الْخَارِجِ ، فَلَمْ يَكُنِ السَّبَبُ مُفِيدًا لِحُكْمِهِ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ ، فَبَقِيَ الْقَضَاءُ لَهُ بِمَجَرَّدِ السَّبَبِ) ، وَذَلِكَ غَيْرُ مُفِيدٍ الْعِنَايَةِ 273/8. (329) فَإِنَّ الْبَيْعَيْنِ لَمَّا ثَبَّتَا عِنْدَهُ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُوجِبًا الثَّمَنِ عِنْدَ مُسْتَرِيهِ فَيَنْقَاصُ الْوُجُوبُ بِالْوُجُوبِ الْعِنَايَةِ 273/8.

(330) لَكِنْ عَلَى اخْتِلَافِ التَّخْرِيجِ، فَعِنْدَهُمَا : بِاعْتِبَارِ أَنْ دَعَوَاهُمَا مِثْلُ هَذَا الْبَيْعِ إِفْرَارٌ مِنْ كُلِّ مِنْهُمَا بِالْمَلِكِ لِصَاحِبِهِ، وَفِي مِثْلِ الْإِفْرَارِ تَتَهَاتَرُ الشُّهُودُ ، فَكَذَلِكَ هَاهُنَا ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ بِاعْتِبَارِ أَنْ بَيْعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَائِزٌ لَوْجُودِ الْبَيْعِ بَعْدَ الْقَبْضِ ، وَلَيْسَ فِي الْبَيْعَيْنِ ذِكْرُ التَّارِيخِ ، وَلَا دَلَالَةُ تَارِيخٍ حَتَّى يُجْعَلَ أَحَدُهُمَا سَابِقًا وَالْآخَرُ لَاحِقًا، وَإِذَا جَازَ الْبَيْعَانِ وَلَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا أَوْلَى مِنَ الْآخَرِ فِي الْقَبُولِ تَسَاقَطًا ، فَبَقِيَ الْعَيْنُ عَلَى يَدِ صَاحِبِ الْيَدِ كَمَا كَانَتْ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ (لِأَنَّ الْجَمْعَ غَيْرُ مُمَكِّنٍ) لِأَنَّ الْجَمْعَ عِبَارَةٌ عَنْ إِمْكَانِ الْعَمَلِ بِهِمَا وَهَاهُنَا لَمْ يُمَكِّنْ . الْعِنَايَةِ 273/8، 274. (331) أَيِ فِي الْوَجْهِ الَّذِي شَهِدُوا بِالْقَبْضِ ، وَفِي الْوَجْهِ الَّذِي لَمْ يَشْهَدُوا بِهِ . الْبِنَايَةِ 400/9.

إذا ادعى أحدهما ببيئته على أن له جميع الدار ، وادعى الآخر ببيئته أن له نصفها ، والدار في يد ثالث لا يملكها : " قَالَ (وَإِذَا كَانَتْ دَارٌ فِي يَدِ رَجُلٍ ادَّعَاهَا اثْنَانِ ، أَحَدُهُمَا جَمِيعَهَا ، وَالْآخَرُ نِصْفَهَا ، وَأَقَامَا الْبَيِّنَةَ ، فَلصاحب الجميع ثلاثة أرباعها ، ولصاحب النصف ربعها عند أبي حنيفة) ، اعتباراً بطريق المنازعة ، فإن صاحب النصف لا يُنازع الآخر في النصف ، فسَلَّمْ لَهُ بِلاَ مُنازَعٍ ، واستوتَ مُنازَعَتُهُمَا في النصف الآخر ، فَيُنصَفُ بَيْنَهُمَا ، (وَقَالَا: هِيَ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا) فَأَعْتَبَرَا طَرِيقَ الْعَوْلِ ، وَالْمُضَارَبَةِ ، فَصاحب الجميع يَضْرِبُ بِكُلِّ حَقِّهِ سَهْمَيْنِ وَصاحب النصف بِسَهْمٍ وَاحِدٍ فَتُقَسَّمُ أَثْلَاثًا ، وَلِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ نَظَائِرُ وَأَضْدَادُ لَا يَحْتَمِلُهَا هَذَا الْمُخْتَصَرُ ، وَقَدْ ذَكَّرْنَا فِي الزِّيَادَاتِ.

إذا ادعى أحدهما ببيئته على أن له جميع الدار ، وادعى الآخر ببيئته أن له نصفها ، والدار في أيديهما : " قَالَ (وَلَوْ كَانَتْ فِي أَيْدِيهِمَا ، سَلَّمَ لِصاحب الجميع نصفها على وجه القضاء ، وَنِصْفَهَا لَا عَلَى وَجْهِ الْقَضَاءِ) ، لِأَنَّهُ خَارِجٌ فِي النِّصْفِ ، فَيُقْضَى بِبَيِّنَتِهِ ، وَالنِّصْفُ الَّذِي فِي يَدَيْهِ ، صَاحِبُهُ لَا يَدَّعِيهِ ، لِأَنَّ مُدَّعَاهُ النِّصْفُ وَهُوَ فِي يَدِهِ سَالِمٌ لَهُ ، وَلَوْ لَمْ يَنْصَرِفْ إِلَيْهِ دَعْوَاهُ كَانَ ظَالِمًا بِإِمْسَاكِهِ ، وَلَا قَضَاءٌ بِدُونِ الدَّعْوَى فَيُتْرَكُ فِي يَدِهِ) .³³²

إذا تنازعا في دابة وأقام كل منهما بينة مؤرخة أنها نتجت عنده وسن الدابة يوافق أحد التاريخين : " قَالَ (وَإِذَا تَنَازَعَا فِي دَابَّةٍ وَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً أَنَّهَا نَتَجَتْ عَنْهُ ، وَذَكَرَا تَارِيخًا ، وَسَنُ الدَّابَّةِ يُوَافِقُ أَحَدَ التَّارِيخَيْنِ فَهُوَ أَوْلَى) ، لِأَنَّ الْحَالَ يَشْهَدُ لَهُ فَيُتَرَجَّحُ ، (وَإِنْ أَشْكَلَ ذَلِكَ كَانَتْ بَيْنَهُمَا) ، لِأَنَّهُ سَقَطَ التَّوَقُّيْتُ فَصَارَ كَأَنَّهُمَا لَمْ يَذْكُرَا تَارِيخًا.

وَإِنْ خَالَفَ سِنُ الدَّابَّةِ الْوَقْتَيْنِ بَطَلَتْ الْبَيِّنَتَانِ ، كَذَا ذَكَرَهُ الْحَاكِمُ⁽³³³⁾ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لِأَنَّهُ ظَهَرَ كَذِبُ الْفَرِيقَيْنِ فَيُتْرَكُ فِي يَدِ مَنْ كَانَتْ فِي يَدِهِ) .³³⁴

³³² () وَلِأَنَّهُ اجْتَمَعَ فِيهِ بَيِّنَةُ الْخَارِجِ وَذِي الْيَدِ ، وَبَيِّنَةُ الْخَارِجِ أَوْلَى ، فَيُقْضَى لَهُ بِذَلِكَ وَنِصْفُهَا لَا عَلَى وَجْهِ الْقَضَاءِ وَهُوَ الَّذِي كَانَ بِيَدِهِ ، لِأَنَّ صَاحِبَهُ لَمْ يَدَّعِهِ ، وَلَا قَضَاءٌ بِدُونِ الدَّعْوَى فَيُتْرَكُ فِي يَدِهِ . العناية 278/8.

³³³ () هو : مُحَمَّدٌ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْحَاكِمِ ، أَبُو الْفَضْلِ الْمُرُوزِيُّ السَّلْمِيُّ الْحَنْفِيُّ الْوَزِيرُ الْحَاكِمُ الشَّهِيدُ ، عَالِمٌ مَرُورٌ الشَّهِيرُ بِالْحَاكِمِ ، قَتَلَهُ الْعُسْكُرُ وَهُوَ سَاجِدٌ فِي رَبِيعِ الْآخِرِ سَنَةِ أَرْبَعٍ وَثَلَاثِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ ، وَكَانَ يَحْفَظُ سِتِينَ أَلْفًا مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَتَصَانِيفَهُ تَدُلُّ عَلَى كَمَالِ فَضْلِهِ ، مِنْهَا ، الْكَافِيُّ ، وَالْمُنْتَقَى . الْفَوَائِدُ الْبَهِيَّةُ فِي تَرَاجُمِ الْحَنْفِيَّةِ ، لِأَبِي الْحَسَنِاتِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَيِّ الْكُنُوزِيِّ الْهَنْدِيِّ ص 186 ، إِتْحَافُ الْمُرْتَقِيِّ بِتَرَاجِمِ سُيُوْخِ الْبَيْهَقِيِّ ، مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْفَتَّاحِ النِّحَالِ ص 437.

³³⁴ () هَذَا إِذَا كَانَا خَارِجَيْنِ ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا ذَا الْيَدِ ، فَإِنْ وَافَقَ سِنُ الدَّابَّةِ تَارِيخَهُ أَوْ أَشْكَلَ ، فُضِيَ بِهَا لِذِي الْيَدِ ، إِمَّا لِيُظْهِرَ عَلَامَةَ الصِّدْقِ فِي شُهُودِهِ ، أَوْ لِيُفُوتَ اعْتِبَارُ التَّوَقُّيْتِ بِالْإِشْكَالِ ، وَإِنْ كَانَ

إذا أقام أحدهما بينة على آخر أن ما تحت يده عبده غصبته منى ، والآخر ادعى أنه له وديعة عنده : " قَالَ (وَإِذَا كَانَ عَبْدٌ فِي يَدِ رَجُلٍ أَقَامَ رَجُلَانِ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ أَحَدُهُمَا بِغَضَبٍ ، وَالْآخَرُ بِوَدِيعَةٍ فَهُوَ بَيْنَهُمَا) ، لَاسْتَوَاهُمَا فِي الْإِسْتِحْقَاقِ.

سِنَّ الدَّابَّةِ بَيْنَ وَقْتِ الْخَارِجِ وَذِي الْيَدِ قَالَ عَامَّةُ الْمَشَايخِ: تَهَانَرِ الْبَيِّنَتَانِ وَتُتْرَكُ الدَّابَّةُ فِي يَدِ ذِي الْيَدِ .
العناية / 278.

(فَصْلٌ فِي التَّنَازُعِ بِالْأَيْدِي)

إذا تنازعا في دابة أحدهما راكبها والآخر متعلق بلجامها أو غير هذا: "قَالَ (وَإِذَا تَنَازَعَا فِي دَابَّةٍ أَحَدُهُمَا رَاكِبُهَا وَالْآخَرُ مُتَعَلِّقٌ بِلِجَامِهَا ، فَالرَّاكِبُ أَوْلَى) ، لِأَنَّ تَصَرُّفَهُ أَظْهَرَ ، فَإِنَّهُ يَخْتَصُّ بِالْمَلِكِ ، (وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا رَاكِبًا فِي السَّرَجِ وَالْآخَرُ رَدِيفُهُ فَالرَّاكِبُ أَوْلَى) ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَا رَاكِبَيْنِ حَيْثُ تَكُونُ بَيْنَهُمَا ، لِاسْتَوَائِهِمَا فِي التَّصَرُّفِ .

إذا تنازعا في بعير وعليه حمل لأحدهما : "(وَكَذَا إِذَا تَنَازَعَا فِي بَعِيرٍ وَعَلَيْهِ حِمْلٌ لِأَحَدِهِمَا فَصَاحِبُ الْحِمْلِ أَوْلَى) ، لِأَنَّهُ هُوَ الْمُتَصَرِّفُ .

تنازعا في قميص أحدهما لابسها والآخر متعلق بكمه : "(وَكَذَا إِذَا تَنَازَعَا فِي قَمِيصٍ أَحَدُهُمَا لِابِسُهُ وَالْآخَرُ مُتَعَلِّقٌ بِكُمِّهِ فَالْإِبْسُ أَوْلَى) لِأَنَّهُ أَظْهَرُهُمَا تَصَرُّفًا (وَلَوْ تَنَازَعَا فِي بَسَاطٍ أَحَدُهُمَا جَالِسٌ عَلَيْهِ وَالْآخَرُ مُتَعَلِّقٌ بِهِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا) مَعْنَاهُ لَا عَلَى طَرِيقِ الْقَضَاءِ لِأَنَّ الْقُعُودَ لَيْسَ بِيَدٍ عَلَيْهِ فَاسْتَوَيَا.

تنازعا في ثوب في يد رجل وطرف منه في يد آخر : "قَالَ: (وَإِذَا كَانَ ثَوْبٌ فِي يَدِ رَجُلٍ وَطَرَفٌ مِنْهُ فِي يَدِ آخَرَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ) ، لِأَنَّ الزِّيَادَةَ مِنْ جِنْسِ الْحُجَّةِ ، فَلَا تُوجِبُ زِيَادَةً فِي الْإِسْتِحْقَاقِ.

ادعى صبي في يد رجل أنه حر أو أنه عبد فلان : "قَالَ: (وَإِذَا كَانَ صَبِيٌّ فِي يَدِ رَجُلٍ وَهُوَ يُعَبِّرُ عَنْ نَفْسِهِ ، فَقَالَ: أَنَا حُرٌّ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ) ، لِأَنَّهُ فِي يَدِ نَفْسِهِ ، (وَلَوْ قَالَ أَنَا عَبْدٌ لِفُلَانٍ ، فَهُوَ عَبْدٌ لِلَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ) ، لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِأَنَّهُ لَا يَدَ لَهُ حَيْثُ أَقَرَّ بِالرَّقِّ ، (وَإِنْ كَانَ لَا يُعَبِّرُ عَنْ نَفْسِهِ فَهُوَ عَبْدٌ لِلَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ) ، لِأَنَّهُ لَا يَدَ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ لَمَّا كَانَ لَا يُعَبِّرُ عَنْهَا وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَتَاعِ ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ يُعَبِّرُ ، فَلَوْ كَبِرَ ، وَادَّعَى الْحُرِّيَّةَ ، لَا يَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ ، لِأَنَّهُ ظَهَرَ الرَّقُّ عَلَيْهِ فِي حَالِ صِغَرِهِ.

إذا كان الحائط لرجل عليه جذوع وآخر عليه هرادي : "قَالَ: (وَإِذَا كَانَ الْحَائِطُ لِرَجُلٍ عَلَيْهِ جُذُوعٌ أَوْ مُنْصِلٌ بَيْنَانِهِ ، وَالْآخَرُ عَلَيْهِ هَرَادِيٌّ ⁽³³⁵⁾) ، فَهُوَ لِصَاحِبِ الْجُذُوعِ وَالْإِتِّصَالِ ، وَالْهَرَادِيُّ لَيْسَتْ بِشَيْءٍ) ، لِأَنَّ صَاحِبَ الْجُذُوعِ صَاحِبُ اسْتِعْمَالٍ ، وَالْآخَرُ صَاحِبُ تَعَلُّقٍ ، فَصَارَ كَذَابَةِ تَنَازُعًا فِيهَا ، وَلِأَحَدِهِمَا حِمْلٌ عَلَيْهَا ، وَلِالْآخَرِ كُوزٌ مُعَلَّقٌ بِهَا ، وَالْمُرَادُ بِالِاتِّصَالِ

³³⁵ (هرادي) : جمع هردية، قصبات تضم – ملتوية - بطاقات من الكرم ، فترسل عليها قضبان الكرم ، أو هي خشبات توضع على الجذوع ويلقى عليها التراب . البناية 408/9 ، درر الحكام شرح غرر الأحكام 350/2.

مُدَاخَلَةُ لَبِنِ جِدَارِهِ فِيهِ ، وَلَبِنِ هَذَا فِي جِدَارِهِ ، وَقَدْ يُسَمَّى اتِّصَالُ تَرْبِيعٍ⁽³³⁶⁾ ، وَهَذَا شَاهِدٌ ظَاهِرٌ لِصَاحِبِهِ ، لِأَنَّ بَعْضَ بِنَائِهِ عَلَى بَعْضٍ بِنَاءٌ هَذَا الْحَائِطِ.

وَقَوْلُهُ: "الْهَرَادِيُّ لَيْسَتْ بِشَيْءٍ" يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ لِلْهَرَادِيِّ أَصْلًا، وَكَذَا الْبَوَارِيُّ ، لِأَنَّ الْحَائِطَ لَا تُبْنَى لَهَا أَصْلًا ، حَتَّى لَوْ تَنَازَعَا فِي حَائِطٍ وَلِأَحَدِهِمَا عَلَيْهِ هَرَادِيٌّ ، وَلَيْسَ لِلْآخَرِ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، فَهُوَ بَيْنَهُمَا.

إِذَا كَانَ الْحَائِطُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَيْهِ جُذُوعٌ ثَلَاثَةٌ فَهُوَ بَيْنَهُمَا) لِاسْتِوَائِهِمَا ، وَلَا مُعْتَبَرٌ بِالْأَكْثَرِ مِنْهَا بَعْدَ الثَّلَاثَةِ ، وَإِنْ كَانَ جُذُوعُ أَحَدِهِمَا أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ ، فَهُوَ لِصَاحِبِ الثَّلَاثَةِ ، وَلِلْآخَرِ مَوْضِعُ جُذُعِهِ فِي رِوَايَةٍ، وَفِي رِوَايَةٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا تَحْتَ خَشْبَتِهِ، ثُمَّ قِيلَ مَا بَيْنَ الْخَشْبِ بَيْنَهُمَا، وَقِيلَ عَلَى قَدَرِ خَشْبِهِمَا، وَالْقِيَاسُ أَنَّ يَكُونَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، لِأَنَّهُ لَا مُعْتَبَرٌ بِالْكَثْرَةِ فِي نَفْسِ الْحُجَّةِ ، وَجْهُ الثَّانِي : أَنَّ الْإِسْتِعْمَالَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ بِقَدَرِ خَشْبَتِهِ ، وَوَجْهُ الْأَوَّلِ : أَنَّ الْحَائِطَ يُبْنَى لِمَوْضِعِ كَثِيرِ الْجُذُوعِ دُونَ الْوَاحِدِ وَالْمُتْنَى ، فَكَانَ الظَّاهِرُ شَاهِدًا لِصَاحِبِ الْكَثِيرِ، إِلَّا أَنَّهُ يَبْقَى لَهُ حَقُّ الْمَوْضِعِ ، لِأَنَّ الظَّاهِرَ لَيْسَ بِحُجَّةٍ فِي اسْتِحْقَاقِ يَدِهِ.

إِذَا كَانَ لِأَحَدِهِمَا جُذُوعٌ وَلِلْآخَرِ اتِّصَالٌ : "وَلَوْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا جُذُوعٌ وَلِلْآخَرِ اتِّصَالٌ فَالْأَوَّلُ أَوْلَى) وَيُرْوَى الثَّانِي أَوْلَى. وَجْهُ الْأَوَّلِ: أَنَّ لِصَاحِبِ الْجُذُوعِ التَّصَرُّفَ وَلِصَاحِبِ الْإِتِّصَالِ الْيَدَ وَالتَّصَرُّفُ أَفْوَى.

وَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ الْحَائِطَيْنِ بِالِاتِّصَالِ يَصِيرَانِ كِبْنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ ضَرُورَةِ الْقَضَاءِ لَهُ بِبَعْضِهِ الْقَضَاءُ بِكُلِّهِ ، ثُمَّ يَبْقَى لِلْآخَرِ حَقٌّ وَضَعُ جُذُوعِهِ لِمَا قُلْنَا، وَهَذِهِ رِوَايَةُ الطَّحَاوِيِّ⁽³³⁷⁾ ، وَصَحَّحَهَا الْجُرْجَانِيُّ⁽³³⁸⁾.

³³⁶ () صفة هذا الاتصال : أن يكون الحائط المتنازع فيه من الجانبين متصلًا بحائطين لأحدهما، والحائطان متصلان بحائط له مقابلة بالاتصال بحائط المتنازع . البنايه 409/9.

³³⁷ () الطحاوي : أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي الطحاوي، أبو جعفر: فقيه انتهت إليه رئاسة الحنفية بمصر. ولد ونشأ في (طحا) من صعيد مصر، وتفقّه على مذهب الشافعي، ثم تحول حنفياً ، ورحل إلى الشام سنة 268 هـ فاتصل بأحمد بن طولون، فكان من خاصته، وتوفي بالقاهرة سنة 321 هـ . الإعلام ، للزركلي 206/1

³³⁸ () الجرجاني : يوسف بن علي بن محمد الجرجاني، أبو عبد الله ، تفقه على أبي الحسن الكرخي ، كان عالماً تفقه على أبي حنيفة رضي الله عنه وأصحابه ومن تصانيفه خزانة الأكمّل في ست مجلدات ت بعد سنة 522 هـ. الجواهر المضية 228/2 ، 229.

إذا كانت دار منها في يد رجل عشرة أبيات وفي يد آخر بيت : "قَالَ: (وَإِذَا كَانَتْ دَارٌ مِنْهَا فِي يَدِ رَجُلٍ عَشْرَةُ أَبْيَاتٍ ، وَفِي يَدِ آخَرَ بَيْتٌ ، فَالَسَّاحَةُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ) ، لِاسْتَوَائِهِمَا فِي اسْتِعْمَالِهَا وَهُوَ الْمُرُورُ فِيهَا.

إذا ادعى رجلان أرضا أنها في يده : " قَالَ: (وَإِذَا ادَّعَى رَجُلَانِ أَرْضًا) يَعْنِي يَدَّعِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا (أَنَّهَا فِي يَدِهِ ، لَمْ يَقْضِ أَنَّهَا فِي يَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَتَّى يُقِيمَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا فِي أَيْدِيهِمَا) ، لِأَنَّ الْيَدَ فِيهَا غَيْرُ مُشَاهِدَةٍ لِتَعْدُرِ إِحْضَارَهَا، وَمَا غَابَ عَنْ عِلْمِ الْقَاضِي ، فَالْبَيِّنَةُ تُثَبِّتُهُ ، وَإِنْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا الْبَيِّنَةَ جُعِلَتْ فِي يَدِهِ) ، لِإِقْيَامِ الْحُجَّةِ ، لِأَنَّ الْيَدَ حَقٌّ مَقْصُودٌ ، (وَإِنْ أَقَامَا الْبَيِّنَةَ جُعِلَتْ فِي أَيْدِيهِمَا) ، لِمَا بَيَّنَّا فَلَا يَسْتَحِقُّ لِأَحَدِهِمَا مِنْ غَيْرِ حُجَّةٍ ، (وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا قَدْ لَبِنَ فِي الْأَرْضِ أَوْ بَنَى أَوْ حَفَرَ فَهِيَ فِي يَدِهِ) لَوْجُودِ التَّصَرُّفِ وَالِاسْتِعْمَالِ فِيهَا).³³⁹

³³⁹() الجامع الصغير وشرحه ص 383، 384.

(بَابُ دَعْوَى النَّسَبِ)

باع جارية فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر فادعاه البائع : "(وَإِذَا بَاعَ جَارِيَةً فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَادَّعَاهُ الْبَائِعُ) ، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلِّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ بَاعَ ، فَهُوَ ابْنُ الْبَائِعِ ، وَأُمُّهُ أُمُّ وَلَدِهِ لَهُ ، (وَفِي الْقِيَاسِ هُوَ قَوْلُ زُفَرٍ وَالشَّافِعِيِّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ دَعْوَتُهُ بَاطِلَةٌ) ، لِأَنَّ الْبَيْعَ اعْتِرَافٌ مِنْهُ بِأَنَّهُ عَبْدٌ فَكَانَ فِي دَعْوَاهُ مُنَاقِضًا وَلَا نَسَبَ بِدُونِ الدَّعْوَى.

وَجْهُ الْإِسْتِحْسَانِ : أَنَّ اتِّصَالَ الْعُلُوقِ بِمِلْكِهِ شَهَادَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى كَوْنِهِ مِنْهُ ، لِأَنَّ الظَّاهِرَ عَدَمُ الزَّوْنِ ، وَمَبْنَى النَّسَبِ عَلَى الْخَفَاءِ فَيُعْفَى فِيهِ التَّنَاقُضُ ، وَإِذَا صَحَّتِ الدَّعْوَى اسْتَدَّتْ إِلَى وَقْتِ الْعُلُوقِ ، فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ بَاعَ أُمَّ وَلَدِهِ فَيُفْسَخُ الْبَيْعُ ، لِأَنَّ بَيْعَ أُمِّ الْوَلَدِ لَا يَجُوزُ ، (وَيُرَدُّ التَّمَنُّ) ، لِأَنَّهُ قَبْضُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ (وَإِنْ ادَّعَاهُ الْمُشْتَرِي مَعَ دَعْوَةِ الْبَائِعِ أَوْ بَعْدَهُ فَدَعْوَةُ الْبَائِعِ أُولَى) ، لِأَنَّهَا أَسْبَقُ ، لِاسْتِنَادِهَا إِلَى وَقْتِ الْعُلُوقِ وَهَذِهِ دَعْوَةُ اسْتِيلَادٍ.

باع جارية فجاءت بولد لأكثر من سنتين فادعاه البائع : "(وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَكْثَرِ مِنْ سَنَتَيْنِ مِنْ وَقْتِ الْبَيْعِ لَمْ تَصِحَّ دَعْوَةُ الْبَائِعِ) ، لِأَنَّهُ لَمْ يُوْجَدْ اتِّصَالُ الْعُلُوقِ بِمِلْكِهِ تَيَقُّنًا ، وَهُوَ الشَّاهِدُ وَالْحُجَّةُ ، (إِلَّا إِذَا صَدَّقَهُ الْمُشْتَرِي) فَيُثْبِتُ النَّسَبَ ، وَيُحْمَلُ عَلَى الْإِسْتِيلَادِ بِالنِّكَاحِ ، وَلَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ ، لِأَنَّا تَيَقَّنَا أَنَّ الْعُلُوقَ لَمْ يَكُنْ فِي مِلْكِهِ فَلَا يُثْبِتُ حَقِيقَةَ الْعِنُقِ وَلَا حَقَّهُ ، وَهَذِهِ دَعْوَةُ تَحْرِيرٍ ، وَغَيْرُ الْمَالِكِ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ.

باع جارية فجاءت بولد لأكثر من ستة ولأقل من سنتين أشهر فادعاه البائع : "(وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَكْثَرِ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الْبَيْعِ وَلِأَقَلِّ مِنْ سَنَتَيْنِ ، لَمْ تُقْبَلْ دَعْوَةُ الْبَائِعِ فِيهِ إِلَّا أَنْ يُصَدَّقَهُ الْمُشْتَرِي) ، لِأَنَّهُ احْتَمَلَ أَنْ لَا يَكُونَ الْعُلُوقُ فِي مِلْكِهِ فَلَمْ تُوجَدْ الْحُجَّةُ فَلَا بُدَّ مِنْ تَصَدِيقِهِ ، وَإِذَا صَدَّقَهُ يَثْبُتُ النَّسَبُ ، وَيَبْطُلُ الْبَيْعُ ، وَالْوَلَدُ حُرٌّ ، وَالْأُمُّ أُمُّ وَلَدِهِ لَهُ ، كَمَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى لِتَصَادُقِهِمَا ، وَاحْتِمَالِ الْعُلُوقِ فِي الْمَلِكِ .

باع جارية فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر ثم مات فادعاه البائع : " قال: (فَإِنْ مَاتَ الْوَلَدُ فَادَّعَاهُ الْبَائِعُ ، وَقَدْ جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلِّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ، لَمْ يَثْبُتِ الْإِسْتِيلَادُ فِي الْأُمِّ) ، لِأَنَّهُ تَابِعَةٌ لِلْوَلَدِ ، وَلَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ بَعْدَ الْمَوْتِ ، لِعَدَمِ حَاجَتِهِ إِلَى ذَلِكَ فَلَا يَتَّبِعُهُ اسْتِيلَادُ الْأُمِّ .

باع جارية فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر ثم ماتت الأم فادعاه البائع : "(وَإِنْ مَاتَتْ الْأُمُّ فَادَّعَاهُ الْبَائِعُ وَقَدْ جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلِّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ، يَثْبُتُ النَّسَبُ فِي الْوَلَدِ وَأَخَذَهُ الْبَائِعُ) ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ هُوَ الْأَصْلُ فِي النَّسَبِ ، فَلَا يَضُرُّهُ فَوَاتُ النَّبْعِ ، وَإِنَّمَا كَانَ الْوَلَدُ أَصْلًا ، لِأَنَّهُا تُضَافُ إِلَيْهِ ، يُقَالُ : أُمُّ الْوَلَدِ ، وَتُسْتَفِيدُ الْحُرِّيَّةُ مِنْ جِهَتِهِ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - "أَعْتَقَهَا

وَلَدَهَا⁽³⁴⁰⁾ " ، وَالثَّابِتُ لَهَا حَقُّ الْحُرِّيَّةِ ، وَلَهُ حَقِيقَتُهَا ، وَالْأَدْنَى يَتَّبِعُ الْأَعْلَى (وَيُرَدُّ الثَّمَنُ كُلُّهُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالَا: يَرُدُّ حِصَّةَ الْوَلَدِ ، وَلَا يَرُدُّ حِصَّةَ الْأُمِّ) ، لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ بَاعَ أُمَّ وَلَدِهِ ، وَمَالَيْتُهَا غَيْرُ مُنْقَوْمَةٍ عِنْدَهُ فِي الْعَقْدِ وَالْعَصَبِ ، فَلَا يَضْمَنُهَا الْمُشْتَرِي ، وَعِنْدَهُمَا مُنْقَوْمَةٌ فَيَضْمَنُهَا.

وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: وَإِذَا حَمَلَتْ الْجَارِيَةُ فِي مَلِكٍ رَجُلٍ فَبَاعَهَا فَوَلَدَتْ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فَادَّعَى الْبَائِعُ الْوَلَدَ وَقَدْ أَعْتَقَ الْمُشْتَرِي الْأُمَّ فَهُوَ ابْنُهُ يَرُدُّ عَلَيْهِ بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ ، وَلَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي إِنَّمَا أَعْتَقَ الْوَلَدَ فَدَعَاَهُ بَاطِلَةً⁽³⁴¹⁾.

وَوَجْهُ الْفَرْقِ: أَنَّ الْأَصْلَ فِي هَذَا الْبَابِ الْوَلَدُ ، وَالْأُمُّ تَابِعَةٌ لَهُ عَلَى مَا مَرَّ ، وَفِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ: قَامَ الْمَانِعُ مِنَ الدَّعْوَةِ وَالِاسْتِيلَادِ ، وَهُوَ الْعَتَقُ فِي التَّبَعِ وَهُوَ الْأُمُّ ، فَلَا يَمْتَنِعُ ثُبُوتُهُ فِي الْأَصْلِ ، وَهُوَ الْوَلَدُ ، وَلَيْسَ مِنْ ضَرُورَاتِهِ ، كَمَا فِي وَلَدِ الْمَغْرُورِ فَإِنَّهُ حُرٌّ ، وَأُمُّهُ أَمَةٌ لِمَوْلَاهَا ، وَكَمَا فِي الْمُسْتَوْلَدَةِ بِالنِّكَاحِ ، وَفِي الْفَصْلِ الثَّانِي: قَامَ الْمَانِعُ بِالْأَصْلِ ، وَهُوَ الْوَلَدُ ، فَيَمْتَنِعُ ثُبُوتُهُ فِيهِ وَفِي التَّبَعِ ، وَإِنَّمَا كَانَ الْإِعْتَاقُ مَانِعًا ، لِأَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ النِّقْضَ ، كَحَقِّ اسْتِلْحَاقِ النَّسَبِ ، وَحَقِّ الْإِسْتِيلَادِ ، فَاسْتَوَيَا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، ثُمَّ الثَّابِتُ مِنَ الْمُشْتَرِي حَقِيقَةُ الْإِعْتَاقِ ، وَالثَّابِتُ فِي الْأُمِّ حَقُّ الْحُرِّيَّةِ ، وَفِي الْوَلَدِ لِلْبَائِعِ حَقُّ الدَّعْوَةِ ، وَالْحَقُّ لَا يُعَارِضُ الْحَقِيقَةَ ، وَالتَّدْبِيرُ ، بِمَنْزِلَةِ الْإِعْتَاقِ ، لِأَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ النِّقْضَ ، وَقَدْ ثَبَتَ بِهِ بَعْضُ أَثَارِ الْحُرِّيَّةِ ، وَقَوْلُهُ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ يَرُدُّ عَلَيْهِ بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ قَوْلُهُمَا ، وَعِنْدَهُ يَرُدُّ بِكُلِّ الثَّمَنِ ، هُوَ الصَّحِيحُ كَمَا ذَكَرْنَا فِي فَصْلِ الْمَوْتِ.

إِذَا بَاعَ عَبْدًا وَلَدَ عِنْدَهُ وَبَاعَهُ الْمُشْتَرِي مِنْ آخَرَ ثُمَّ ادَّعَاهُ الْبَائِعُ الْأَوَّلُ: "قَالَ: (وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَدَ عِنْدَهُ ، وَبَاعَهُ الْمُشْتَرِي مِنْ آخَرَ ، ثُمَّ ادَّعَاهُ الْبَائِعُ الْأَوَّلُ ، فَهُوَ ابْنُهُ ، وَيَبْطُلُ الْبَيْعُ) ، لِأَنَّ الْبَيْعَ يَحْتَمِلُ النِّقْضَ ، وَمَا لَهُ مِنْ حَقِّ الدَّعْوَةِ لَا يَحْتَمِلُهُ ، فَيَنْقُضُ الْبَيْعَ لِأَجْلِهِ ، وَكَذَا إِذَا كَاتَبَ الْوَلَدَ أَوْ رَهْنَهُ أَوْ أَجَرَهُ ، أَوْ كَاتَبَ الْأُمَّ أَوْ رَهْنَهَا أَوْ زَوَّجَهَا ، ثُمَّ كَانَتْ الدَّعْوَةُ ، لِأَنَّ هَذِهِ الْعَوَارِضَ تَحْتَمِلُ النِّقْضَ فَيَنْقُضُ ذَلِكَ كُلُّهُ ، وَتَصِحُّ الدَّعْوَةُ ، بِخِلَافِ الْإِعْتَاقِ وَالتَّدْبِيرِ عَلَى مَا مَرَّ ، وَبِخِلَافِ مَا إِذَا ادَّعَاهُ الْمُشْتَرِي أَوَّلًا ، ثُمَّ ادَّعَاهُ الْبَائِعُ ، حَيْثُ لَا يَتَّبِعُ النَّسَبُ مِنَ الْبَائِعِ ، لِأَنَّ النَّسَبَ الثَّابِتَ مِنَ الْمُشْتَرِي لَا يَحْتَمِلُ النِّقْضَ ، فَصَارَ كِإِعْتَاقِهِ.

ادَّعَى نَسَبَ أَحَدِ التَّوَأْمَيْنِ: " قَالَ (وَمَنْ ادَّعَى نَسَبَ أَحَدِ التَّوَأْمَيْنِ ثَبَتَ نَسَبُهُمَا مِنْهُ) ، لِأَنَّهُمَا مِنْ مَاءٍ وَاحِدٍ ، فَمِنْ ضَرُورَةِ ثُبُوتِ نَسَبِ أَحَدِهِمَا ثُبُوتُ نَسَبِ الْآخَرِ ، وَهَذَا لِأَنَّ التَّوَأْمَيْنِ وَلَدَانِ

⁽³⁴⁰⁾ () المستدرك ، للحاكم رقم 2191 ، وقال الذهبي في سنده : "حسين بن عبد الله متروك" ، السنن الصغرى للبيهقي رقم 3494 عن ابن عباس (رضى الله عنه)
⁽³⁴¹⁾ () الجامع الصغير ص 413.

بَيْنَ وَلادَتَهُمَا أَقْلَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ، فَلَا يُتَصَوَّرُ عُلوْقُ الثَّانِي حَادِثًا ، لِأَنَّهُ لَا حَبْلَ لِأَقْلَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ () .³⁴²

وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: إِذَا كَانَ فِي يَدِهِ غُلَامَانِ تَوَآمَنَ وَلَدَا عِنْدَهُ فَبَاعَ أَحَدُهُمَا وَأَعْتَقَهُ الْمُشْتَرِي ثُمَّ ادَّعَى الْبَائِعُ الَّذِي فِي يَدِهِ فَهُمَا ابْنَاهُ وَبَطَلَ عِنَقُ الْمُشْتَرِي⁽³⁴³⁾؛ لِأَنَّهُ لَمَّا ثَبَتَ نَسَبُ الْوَلَدِ الَّذِي عِنْدَهُ لِمُصَادَقَةِ الْعُلُوقِ وَالِدَعْوَةِ مِلْكُهُ إِذْ الْمَسْأَلَةُ مَفْرُوضَةٌ فِيهِ ، ثَبَتَ بِهِ حُرِّيَّةُ الْأَصْلِ فِيهِ ، فَيُثَبَّتُ نَسَبُ الْآخَرِ ، وَحُرِّيَّةُ الْأَصْلِ فِيهِ ضَرُورَةٌ ، لِأَنَّهُمَا تَوَآمَنَ ، فَتَبَيَّنَ أَنَّ عِنَقَ الْمُشْتَرِي وَشِرَاءَهُ لَا قَى حُرِّيَّةُ الْأَصْلِ فَبَطَلَ ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ الْوَلَدُ وَاحِدًا ، لِأَنَّ هُنَاكَ يَبْطُلُ الْعِنَقُ فِيهِ مَقْصُودًا ، لِحَقِّ دَعْوَةِ الْبَائِعِ ، وَهُنَا ثَبَتَ تَبَعًا لِحُرِّيَّتِهِ فِيهِ حُرِّيَّةُ الْأَصْلِ ، فَافْتَرَقَا (وَلَوْ لَمْ يَكُنْ أَصْلُ الْعُلُوقِ فِي مِلْكِهِ ، ثَبَتَ نَسَبُ الْوَلَدِ الَّذِي عِنْدَهُ ، وَلَا يُنْقَضُ الْبَيْعُ فِيمَا بَاعَ) ، لِأَنَّ هَذِهِ دَعْوَةُ تَحْرِيرٍ ، لِإِنْعَادِ شَاهِدِ الْإِتِّصَالِ ، فَيَقْتَصِرُ عَلَى مَحَلِّ وَلَايَتِهِ.

قَالَ : (وَإِذَا كَانَ الصَّبِيُّ فِي يَدِ رَجُلٍ فَقَالَ: هُوَ ابْنُ عَبْدِي فَلَانَ الْغَائِبِ ، ثُمَّ قَالَ: هُوَ ابْنِي ، لَمْ يَكُنْ ابْنُهُ أَبَدًا ، وَإِنْ جَحَدَ الْعَبْدُ أَنْ يَكُونَ ابْنَهُ) ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، (وَقَالَا: إِذَا جَحَدَ الْعَبْدُ فَهُوَ ابْنُ الْمَوْلَى) وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ ، إِذَا قَالَ: هُوَ ابْنُ فَلَانٍ وَلَدَ عَلَى فِرَاشِهِ ، ثُمَّ ادَّعَاهُ لِنَفْسِهِ ، لَهُمَا : أَنَّ الْإِفْرَارَ ارْتَدَّ بِرَدِّ الْعَبْدِ ، فَصَارَ كَأَنَّ لَمْ يَكُنْ الْإِفْرَارُ ، وَالْإِفْرَارُ بِالنَّسَبِ يَرْتَدُّ بِالرَّدِّ ، وَإِنْ كَانَ لَا يَحْتَمِلُ النِّقْضَ؛ أَلَا يَرَى أَنَّهُ يَعْمَلُ فِيهِ الْإِكْرَاهُ وَالْهَزْلُ ، فَصَارَ كَمَا إِذَا أَقَرَّ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِاعْتِقَاقِ الْمُشْتَرَى ، فَكَذَّبَهُ الْبَائِعُ ، ثُمَّ قَالَ : أَنَا أَعْتَقْتُهُ ، يَتَحَوَّلُ الْوَلَاءُ إِلَيْهِ ، بِخِلَافِ مَا إِذَا صَدَّقَهُ ، لِأَنَّهُ يَدَّعِي بَعْدَ ذَلِكَ نَسَبًا ثَابِتًا مِنَ الْغَيْرِ ، وَبِخِلَافِ مَا إِذَا لَمْ يُصَدِّقْهُ وَلَمْ يُكَذِّبْهُ ، لِأَنَّهُ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْمُقَرَّرِ لَهُ عَلَى اعْتِبَارِ تَصَدِيقِهِ ، فَيَصِيرُ كَوَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ ، فَإِنَّهُ لَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْ غَيْرِ الْمُلَاعَنِ؛ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يُكَذِّبَ نَفْسَهُ.

وَلِأَبِي حَنِيفَةَ : أَنَّ النَّسَبَ مِمَّا لَا يَحْتَمِلُ النِّقْضَ بَعْدَ ثُبُوتِهِ ، وَالْإِفْرَارُ بِمِثْلِهِ لَا يَرْتَدُّ بِالرَّدِّ ، فَبَقِيَ ، فَتَمْتَنِعُ دَعْوَتُهُ ، كَمَنْ شَهِدَ عَلَى رَجُلٍ بِنَسَبِ صَغِيرٍ فَرَدَّتْ شَهَادَتُهُ لِتَهْمَةٍ ، ثُمَّ ادَّعَاهُ لِنَفْسِهِ ،

³⁴² () (قال) : أي القدوري (ومن ادعى نسب أحد التوأمين) التوأم : اسم للولد إذا كان معه آخر في بطن واحد، يقال : هما توأمين ، كما يقال: هما زوجان ، وقولهما هما توأم ، وهما زوج خطأ؛ كذا في " المغرب " . وقال شمس الأئمة: يجوز أن يقال: غلامان توأم وتوأمين ، قال: ذكر التوأم مكان التوأمين صحيح في اللغة (ثبت نسبهما منه) أي نسب التوأمين من المدعي ، (لأنهما) خلقاً (من ماء واحد، فمن ضرورة ثبوت نسب أحدهما ثبوت نسب الآخر، وهذا) أشار به إلى قوله " فمن ضرورة ثبوت نسب أحدهما ثبوت الآخر " ، (لأن التوأمين ولدان بين ولادتهما أقل من ستة أشهر) إنما قيد بذلك ، لأنه إذا كان بينهما ستة أشهر فصاعداً بتوأمين، لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر (فلا يتصور علوق الثاني حادثاً، لأنه لا حبل في أقل من ستة أشهر) . البناية 419 / 10 ، المغرب في ترتيب المغرب ص 58.

³⁴³ () (الجامع الصغير وشرحه ص 413 ، 414 .

وَهَذَا لِأَنَّهُ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْمُقَرَّرِ لَهُ عَلَى اعْتِبَارِ تَصْدِيقِهِ، حَتَّى لَوْ صَدَّقَهُ بَعْدَ التَّكْذِيبِ يَثْبُتُ النَّسَبُ مِنْهُ، وَكَذَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْوَلَدِ ، فَلَا يَرْتَدُّ بِرَدِّ الْمُقَرَّرِ لَهُ.

وَمَسْأَلَةُ الْوَلَاءِ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ، وَلَوْ سَلِمَ ، فَالْوَلَاءُ قَدْ يَبْطُلُ بِاعْتِرَاضِ الْأَقْوَى ، كَجَرِّ الْوَلَاءِ مِنْ جَانِبِ الْأُمِّ إِلَى قَوْمِ الْأَبِ.

وَقَدْ اعْتَرَضَ عَلَى الْوَلَاءِ الْمَوْقُوفِ مَا هُوَ أَقْوَى ، وَهُوَ دَعْوَى الْمُشْتَرِي ، فَيَبْطُلُ بِهِ، بِخِلَافِ النَّسَبِ عَلَى مَا مَرَّ ، وَهَذَا يَصْلُحُ مَخْرَجًا عَلَى أَصْلِهِ فِيمَنْ يَبِيعُ الْوَلَدَ وَيَخَافُ عَلَيْهِ الدَّعْوَةَ بَعْدَ ذَلِكَ فَيَقْطَعُ دَعْوَاهُ إِقْرَارُهُ بِالنَّسَبِ لِغَيْرِهِ.

قَالَ: (وَإِذَا كَانَ الصَّبِيُّ فِي يَدِ مُسْلِمٍ ، وَنَصْرَانِيٍّ ، فَقَالَ النَّصْرَانِيُّ: هُوَ ابْنِي ، وَقَالَ الْمُسْلِمُ : هُوَ عَبْدِي ، فَهُوَ ابْنُ النَّصْرَانِيِّ ، وَهُوَ حُرٌّ) ، لِأَنَّ الْإِسْلَامَ مُرَجِّحٌ ، فَيَسْتَدْعِي تَعَارُضًا، وَلَا تَعَارُضَ ، لِأَنَّ نَظَرَ الصَّبِيِّ فِي هَذَا أَوْفَرُ ، لِأَنَّهُ يَنَالُ شَرَفَ الْحُرِّيَّةِ حَالًا ، وَشَرَفَ الْإِسْلَامِ مَالًا، إِذْ دَلَالَةُ الْوَحْدَانِيَّةِ ظَاهِرَةٌ، وَفِي عَكْسِهِ : الْحُكْمُ بِالْإِسْلَامِ تَبَعًا ، وَحِرْمَانُهُ عَنِ الْحُرِّيَّةِ ، لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي وَسْعِهِ اكْتِسَابُهَا (وَلَوْ كَانَتْ دَعْوَتُهُمَا دَعْوَةَ الْبُنُوَّةِ فَالْمُسْلِمُ أَوْلَى) تَرْجِيحًا لِلْإِسْلَامِ ، وَهُوَ أَوْفَرُ النَّظَرَيْنِ.

ادعت امرأة صبيًا أنه ابنها : "قَالَ (وَإِذَا ادَّعَتْ امْرَأَةٌ صَبِيًّا أَنَّهُ ابْنُهَا ، لَمْ تَجُزْ دَعْوَاهَا ، حَتَّى تَشْهَدَ امْرَأَةٌ عَلَى الْوِلَادَةِ) وَمَعْنَى الْمَسْأَلَةِ : أَنَّ تَكُونَ الْمَرْأَةُ ذَاتَ زَوْجٍ ، لِأَنَّهَا تَدَّعِي تَحْمِيلَ النَّسَبِ عَلَى الْغَيْرِ ، فَلَا تُصَدَّقُ إِلَّا بِحُجَّةٍ، بِخِلَافِ الرَّجُلِ ، لِأَنَّهُ يُحْمَلُ نَفْسُهُ النَّسَبَ، ثُمَّ شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ كَافِيَةٌ فِيهَا ، لِأَنَّ الْحَاجَةَ إِلَى تَعْيِينِ الْوَلَدِ).³⁴⁴

النسب يثبت بالفراش القائم : "أَمَّا النَّسَبُ فَيَثْبُتُ بِالْفِرَاشِ الْقَائِمِ، وَقَدْ صَحَّ "أَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - قَبِلَ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ عَلَى الْوِلَادَةِ"³⁴⁵ ، (وَلَوْ كَانَتْ مُعْتَدَّةً ، فَلَا بُدَّ مِنْ حُجَّةٍ تَامَةٍ) عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَدْ مَرَّ فِي الطَّلَاقِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَنكُوحَةً وَلَا مُعْتَدَّةً قَالُوا: يَثْبُتُ النَّسَبُ مِنْهَا بِقَوْلِهَا، لِأَنَّ فِيهِ الْإِزَامًا عَلَى نَفْسِهَا دُونَ غَيْرِهَا.

(وَإِنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ ، وَرَزَعَتْ أَنَّهُ ابْنُهَا مِنْهُ وَصَدَّقَهَا فَهُوَ ابْنُهَا ، وَإِنْ لَمْ تَشْهَدْ امْرَأَةً) ، لِأَنَّهُ التَّرَمُّ نَسَبُهُ ، فَأَغْنَى ذَلِكَ عَنِ الْحُجَّةِ.

³⁴⁴ () ولأن الولادة مما لا يحضرها الرجال، فإذا شهدت قابلة يثبت النسب، وإذا لم يكن لها زوج فالقول لها من غير بينة كما في الرجل. البناية 424/9.

³⁴⁵ () السنن الصغرى ، للبيهقي رقم 3294 ، وقال : "حديث حذيفة: أن النبي صلى الله عليه وسلم «أجاز شهادة القابلة» لم يصح إسناده"، سنن الدارقطني رقم 4556.

(وَإِنْ كَانَ الصَّبِيُّ فِي أَيْدِيهِمَا ، وَزَعَمَ الزَّوْجُ أَنَّهُ ابْنُهُ مِنْ غَيْرِهَا ، وَزَعَمَتْ أَنَّهُ ابْنُهَا مِنْ غَيْرِهِ ، فَهُوَ ابْنُهُمَا) ، لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْوَلَدَ مِنْهُمَا ، لِقِيَامِ أَيْدِيهِمَا ، أَوْ لِقِيَامِ الْفِرَاشِ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُرِيدُ إِبْطَالَ حَقِّ صَاحِبِهِ ، فَلَا يُصَدِّقُ عَلَيْهِ ، وَهُوَ نَظِيرُ ثَوْبٍ فِي يَدِ رَجُلَيْنِ ، يَقُولُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا : هُوَ بِنِّي وَبَيْنَ رَجُلٍ آخَرَ غَيْرِ صَاحِبِهِ ، يَكُونُ الثَّوْبُ بَيْنَهُمَا ، إِلَّا أَنَّ هُنَاكَ يَدْخُلُ الْمُقَرُّ لَهُ فِي نَصِيبِ الْمُقَرِّ ، لِأَنَّ الْمَحَلَّ يَحْتَمِلُ الشَّرَكَةَ ، وَهَاهُنَا لَا يَدْخُلُ ، لِأَنَّ النَّسَبَ لَا يَحْتَمِلُهَا.

اشترى جارية فولدت عنده فاستحقها آخر : "قَالَ (وَمَنْ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَلَدَتْ وَلَدًا عِنْدَهُ فَاسْتَحَقَّهَا رَجُلٌ ، غَرِمَ الْأَبُ قِيمَةَ الْوَلَدِ يَوْمَ يُخَاصِمُ) ، لِأَنَّهُ وَلَدُ الْمَغْرُورِ ، فَإِنَّ الْمَغْرُورَ : مَنْ يَطْأُ امْرَأَةً مُعْتَمِدًا عَلَى مِلْكٍ يَمِينٍ ، أَوْ نِكَاحٍ ، فَتَلِدُ مِنْهُ ، ثُمَّ تُسْتَحَقُّ ، وَوَلَدُ الْمَغْرُورِ (346) حُرٌّ بِالْقِيَمَةِ بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ (347) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - ، وَلِأَنَّ النَّظَرَ مِنَ الْجَانِبَيْنِ وَاجِبٌ ، فَيُجْعَلُ الْوَلَدُ حُرًّا الْأَصْلَ فِي حَقِّ أَبِيهِ ، رَقِيقًا فِي حَقِّ مُدَّعِيهِ ، نَظَرًا لَهُمَا ، ثُمَّ الْوَلَدُ حَاصِلٌ فِي يَدِهِ مِنْ غَيْرِ صُنْعِهِ فَلَا يَضْمَنُهُ إِلَّا بِالْمَنْعِ ، كَمَا فِي وَلَدِ الْمَغْصُوبَةِ ، فَلِهَذَا تُعْتَبَرُ قِيَمَةُ الْوَلَدِ يَوْمَ الْخُصُومَةِ ، لِأَنَّهُ يَوْمُ الْمَنْعِ.

(وَلَوْ مَاتَ الْوَلَدُ لَا شَيْءَ عَلَى الْأَبِ) ، لِإِنْعِدَامِ الْمَنْعِ ، وَكَذَا لَوْ تَرَكَ مَالًا ، لِأَنَّ الْإِرْثَ لَيْسَ بِبَدَلٍ عَنْهُ ، وَالْمَالُ لِأَبِيهِ ، لِأَنَّهُ حُرٌّ الْأَصْلَ فِي حَقِّهِ ، فَيَرِثُهُ ، (وَلَوْ قَتَلَهُ الْأَبُ يَغْرَمُ قِيَمَتَهُ) ، لَوْجُودِ الْمَنْعِ ، وَكَذَا لَوْ قَتَلَهُ غَيْرُهُ فَأَخَذَ دِيْنَتَهُ ، لِأَنَّ سَلَامَةَ بَدَلِهِ لَهُ كَسَلَامَتِهِ ، وَمَنْعَ بَدَلِهِ كَمَنْعِهِ ، فَيَغْرَمُ قِيَمَتَهُ ، كَمَا إِذَا كَانَ حَيًّا (وَيَرْجِعُ بِقِيَمَةِ الْوَلَدِ عَلَى بَائِعِهِ) ، لِأَنَّهُ ضَمِنَ لَهُ سَلَامَتَهُ ، كَمَا

³⁴⁶ () قال الزيلعي : "لِأَنَّ الْمَغْرُورَ أَنْ يَشْتَرِيَ رَجُلٌ جَارِيَةً ، وَيَتَمَلَّكُهَا بِسَبَبٍ مِنْ أَسْبَابِ الْمَلِكِ ظَاهِرًا ، فَاسْتَوْلَاهَا ، ثُمَّ تُسْتَحَقُّ الْجَارِيَةُ ، أَوْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ ، ثُمَّ يَظْهَرُ بِالْبَيِّنَةِ أَنَّهَا أُمَةٌ ، وَإِذَا ثَبِتَ أَنَّهُ وَلَدُ الْمَغْرُورِ ، فَهُوَ حُرٌّ بِالْقِيَمَةِ ، كَذَا رَوَى عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ . وقال الزرقاني البناية على الهداية 32/6 ، الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير ص 403 .

³⁴⁷ () قال الزرقاني : (حدثني مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَوْ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ) شَكَكَ الرَّأْيَ (فَقَضَى أَحَدُهُمَا فِي امْرَأَةٍ غَرَّتْ رَجُلًا بِنَفْسِهَا وَذَكَرَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ) ، وَهِيَ أُمَةٌ ، (فَتَزَوَّجَهَا فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا ، فَقَضَى أَنْ يَفْدِيَ وَلَدَهُ بِمِثْلِهِمْ) قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ رَوَى ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ جَمِيعًا ، وَوَلَدُ الْمَغْرُورِ حُرٌّ عِنْدَ الْجُمْهُورِ . وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ وَدَاوُدُ : رَقِيقٌ وَلَا قِيَمَةَ فِيهِمْ عَلَى أَحَدٍ . قَالَ الطَّحَاوِيُّ : وَهُوَ الْقِيَاسُ لَكِنَّهُمْ تَرَكَوهُ لِاتِّفَاقِ الصَّحَابَةِ عَلَى أَنَّهُمْ أَحْرَارٌ ، وَعَلَى الْأَبِ قِيَمَتُهُمْ . أَبُو عُمَرَ : لَا دَخْلَ لِلْقِيَاسِ فِيْمَا يُخَالِفُ السَّلَفَ فَاتَّبَاعُهُمْ خَيْرٌ مِنَ الْإِتِّدَاعِ . (قَالَ مَالِكٌ : وَالْقِيَمَةُ أَعْدَلُ) مِنَ الْمِثْلِ (فِي هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ) وَعَلَيْهِ اعْتَمَدَ أَهْلُ مَذْهَبِهِ ، وَقَالَ مَرَّةً : عَلَيْهِ الْمِثْلُ . ثُمَّ رَجَعَ . شرح الزرقاني على الموطأ 57/4 .

يَرْجِعُ بِثَمَنِهِ، بِخِلَافِ الْعَقْرِ ، لِأَنَّهُ لَزِمَهُ لِاسْتِيفَاءِ مَنَافِعِهَا ، فَلَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْبَائِعِ⁽³⁴⁸⁾، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

كتاب الصلح

أنواع الصلح وحكمه: ⁽³⁴⁹⁾

قَالَ (الصُّلْحُ)⁽³⁵⁰⁾ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ: صُلْحٌ مَعَ إِفْرَارٍ، وَصُلْحٌ مَعَ سُكُوتٍ: وَهُوَ أَنْ لَا يُقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَلَا يُنْكَرَ ، وَصُلْحٌ مَعَ انْكَارٍ ، وَكُلُّ ذَلِكَ جَائِزٌ ، لِإِطْلَاقِ قَوْلِهِ تَعَالَى {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} [النساء: 128] وَلِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: "كُلُّ صُلْحٍ جَائِزٌ فِيمَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا"⁽³⁵¹⁾، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَجُوزُ مَعَ انْكَارٍ أَوْ سُكُوتٍ لِمَا رَوَيْنَا، وَهَذَا بِهَذِهِ الصَّفَةِ ، لِأَنَّ الْبَدَلَ كَانَ حَلَالًا عَلَى الدَّافِعِ حَرَامًا عَلَى الْآخِذِ فَيَنْقَلِبُ الْأَمْرُ، وَلِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَدْفَعُ الْمَالَ لِقَطْعِ الْخُصُومَةِ ، وَهَذَا رِشْوَةٌ⁽³⁵²⁾ ، وَلَنَا مَا تَلَوْنَا وَأَوَّلُ مَا رَوَيْنَا ، وَتَأْوِيلُ آخِرِهِ "أَحَلَّ حَرَامًا" لِعَيْنِهِ ، كَالْخَمْرِ " أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا" لِعَيْنِهِ ، كَالصُّلْحِ عَلَى أَنْ لَا يَطَأَ الضَّرَّةَ ، وَلِأَنَّ هَذَا صُلْحٌ بَعْدَ دَعْوَى صَحِيحَةٍ فَيُقْضَى بِجَوَازِهِ ، لِأَنَّ الْمُدَّعَى يَأْخُذُهُ عَوْضًا عَنْ حَقِّهِ فِي زَعْمِهِ وَهَذَا مَشْرُوعٌ، وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَدْفَعُهُ لِدَفْعِ الْخُصُومَةِ عَنْ نَفْسِهِ ، وَهَذَا مَشْرُوعٌ أَيْضًا ، إِذْ الْمَالَ وَقَايَةُ الْأَنْفُسِ ، وَدَفْعُ الرِّشْوَةِ لِدَفْعِ الظُّلْمِ أَمْرٌ جَائِزٌ⁽³⁵³⁾.

⁽³⁴⁸⁾ () قَالَ الْعَيْنِيُّ : بِالنِّسْبَةِ لِلْعَقْرِ أَى الْمَهْر : مَعْنَاهُ " أَنْ الْمَغْرُور لَا يَرْجِعُ عَلَى بَائِعِهِ بَعْدَ وَجوب عَلَيْهِ، لَأَن - أَى الْمَهْر - ضَمَانُ الْمَنْفَعَةِ ، وَهِيَ لَيْسَتْ مِنْ أَجْزَاءِ الْمَبِيعِ حَقِيقَةً. الْبَنَاءُ عَلَى الْهَدَايَةِ 9/427.

⁽³⁴⁹⁾ () كَافَةُ الْعَنَاوِينِ الْجَانِبِيَّةِ الْمُظَلَّلَةِ فِي كِتَابِ الصَّلْحِ مِنْ وَضْعِ الْمُحَقِّقِ .

⁽³⁵⁰⁾ () الصِّلْحُ لُغَةً : اسْمٌ لِلْمَصَالِحَةِ ، وَاصْطِلَاحًا: عِبَارَةٌ عَنْ عَقْدٍ وَضَعُ لِرَفْعِ الْمُنَازَعَةِ .نَتَائِجُ الْأَفْكَارِ فِي كَشْفِ الرُّمُوزِ وَالْأَسْرَارِ ، لِقَاضِي زَادَةَ أَفْنَدِي ، وَهِيَ تَكْمِلَةٌ لِفَتْحِ الْقَدِيرِ 8/403 ، الْمَعْرَبُ فِي تَرْتِيبِ الْمَغْرَبِ ، لِأَبِي الْفَتْحِ الْمَطْرُزِي ص 270.

⁽³⁵¹⁾ () أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْنٍ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، بِرَقْمِ 7059، قَالَ الذَّهَبِيُّ : وَاه.

⁽³⁵²⁾ () وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: { وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ } [البقرة: 188] وَالصِّلْحُ عَلَى الْإِنْكَارِ مِنْ أَكْلِ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ ، وَلِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ حَقٌّ يَجُوزُ أَنْ يِعَاوُضَ عَلَيْهِ، وَالصِّلْحُ عَلَى الْإِنْكَارِ مُحْرَمٌ لِلْحَلَالِ وَمَحَلٌّ لِلْحَرَامِ ، لِأَنَّهُ يَحِلُّ الْمَعَاوُضَةُ عَلَى غَيْرِ حَقٍّ ثَابِتٍ وَذَلِكَ حَرَامٌ ، وَيَحْرَمُ عَلَى الْمُدَّعَى بَاقِي حَقِّهِ وَذَلِكَ حَلَالٌ ، وَلِأَنَّهُ صُلْحٌ عَلَى مَجْرَدِ الدَّعْوَى فَوْجِبَ أَنْ يَكُونَ بَاطِلًا ، كَمَا لَوْ ادَّعَى قَتْلَ عَمْدٍ فَصُلِحَ عَلَيْهِ مَعَ الْإِنْكَارِ ، وَلِأَنَّهُ اعْتِاضٌ عَنْ حَقٍّ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ ، فَوْجِبَ أَنْ لَا يَمْلِكَ عَوْضُهُ ، وَلِأَنَّهُ صَالِحٌ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ صِدْقَهُ فَوْجِبَ أَنْ لَا يَصِحَّ ، كَمَا لَوْ عَلِمَ كَذِبَهُ ، وَلِأَنَّهُ نَوْعٌ مَعَاضَةٍ لَا يَصِحُّ مَعَ الْجَهَالَةِ فَوْجِبَ أَنْ لَا يَصِحَّ مَعَ الْإِنْكَارِ كَالْبَيْعِ ، وَلِأَنَّ الصِّلْحَ لَمَّا لَمْ يَجْزِ عَلَى مَجْهُولٍ الْوَصْفِ فَأَوْلَى أَنْ لَا يَجُوزَ عَلَى مَجْهُولٍ الْعَيْنِ. الْحَاوِي لِلْمَوْرَدِي 6/369، 370، 7/293.

⁽³⁵³⁾ () دَفْعُ الرِّشْوَةِ لِدَفْعِ الضَّرَرِ عَنْ نَفْسِهِ فَجَائِزٌ لِلدَّافِعِ . الْعَنَاءُ 8/408.

المعتبر في الصلح عن إقرار : قَالَ (فَإِنْ وَقَعَ الصُّلْحُ عَنْ إِقْرَارٍ أُعْتَبِرَ فِيهِ مَا يُعْتَبَرُ فِي الْبَيَاعَاتِ إِنْ وَقَعَ عَنْ مَالٍ بِمَالٍ) ، لَوْجُودِ مَعْنَى الْبَيْعِ ، وَهُوَ مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ فِي حَقِّ الْمُتَعَاقِدَيْنِ بِتَرَاضِيهِمَا (فَنَجْزِي فِيهِ الشُّفْعَةَ³⁵⁴) إِذَا كَانَ عَقَارًا ، وَيُرَدُّ بِالْعَيْبِ ، وَيَثْبُتُ فِيهِ خِيَارُ الرُّوْيَةِ وَالشَّرْطِ ، وَيُفْسِدُهُ جَهَالَةُ الْبَدَلِ) ، لِأَنَّهَا هِيَ الْمُفْضِيَةُ إِلَى الْمُنَازَعَةِ دُونَ جَهَالَةِ الْمَصَالِحِ عَنْهُ ، لِأَنَّهُ يَسْقُطُ وَيُشْتَرَطُ الْقُدْرَةُ عَلَى تَسْلِيمِ الْبَدَلِ³⁵⁵).

المعتبر في الصلح عن مال بمنافع : (وَإِنْ وَقَعَ عَنْ مَالٍ بِمَنَافِعَ ، يُعْتَبَرُ بِالْإِجَارَاتِ) ، لَوْجُودِ مَعْنَى الْإِجَارَةِ ، وَهُوَ تَمْلِيكُ الْمَنَافِعِ بِمَالٍ ، وَالْإِعْتِبَارُ فِي الْعُقُودِ لِمَعَانِيهَا ، فَيُشْتَرَطُ التَّوَقُّيْتُ فِيهَا وَيَبْطُلُ، الصُّلْحُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا فِي الْمُدَّةِ لِأَنَّهُ إِجَارَةٌ.

الصلح عن السكوت والإنكار في حق المدعى والمدعى عليه لافتداء اليمين : قَالَ: (وَالصُّلْحُ عَنْ السُّكُوتِ وَالْإِنْكَارِ فِي حَقِّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، لِإِفْتِدَاءِ الْيَمِينِ ، وَقَطْعِ الْخُصُومَةِ ، وَفِي حَقِّ الْمُدَّعَى بِمَعْنَى الْمَعَاوَضَةِ) لِمَا بَيَّنَّا³⁵⁶).

(وَيَجُوزُ أَنْ يَخْتَلِفَ حُكْمُ الْعَقْدِ فِي حَقِّهِمَا كَمَا يَخْتَلِفُ حُكْمُ الْإِقَالَةِ³⁵⁷) فِي حَقِّ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَغَيْرِهِمَا) وَهَذَا فِي الْإِنْكَارِ ظَاهِرٌ، وَكَذَا فِي السُّكُوتِ ، لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ الْإِقْرَارَ وَالْجُودَ فَلَا يَثْبُتُ كَوْنُهُ عَوْضًا فِي حَقِّهِ بِالشَّكِّ.

³⁵⁴ () الشفعة لغة : الشفع ، الضم ، لِأَنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ: شَفَعْتَ الرَّسُولَ بآخر، أي جعلتهما اثنتين، واصطلاحاً : تملك البقعة جبرا على المشتري بما قام عليه . البحر الرائق 143/8، درة الغواص في أوهام الخواص ، للقاسم بن علي بن محمد بن عثمان، أبو محمد الحريري البصري (المتوفى: 516هـ) ص217.

³⁵⁵ () وَهَذَا لَيْسَ عَلَى إِطْلَاقِهِ بَلْ فِيهِ تَفْصِيلٌ، وَهُوَ أَنَّ الصُّلْحَ بِاعْتِبَارِ بَدَلِيهِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا عَلَى مَعْلُومٍ، وَهُوَ جَائِزٌ لَا مَحَالَةَ ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ عَنْ مَجْهُولٍ عَلَى مَجْهُولٍ، فَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ فِيهِ إِلَى التَّسْلِيمِ وَالتَّسَلُّمِ مِثْلَ أَنْ يَدَّعِيَ حَقًّا فِي دَارِ رَجُلٍ وَادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَقًّا فِي أَرْضِ بَيْدِ الْمُدَّعِي وَاصْطَلَحَا عَلَى تَرْكِ الدَّعْوَى جَارًا، وَإِنْ أُحْتِجَ إِلَيْهِ وَقَدْ اصْطَلَحَا عَلَى أَنْ يَدْفَعَ أَحَدُهُمَا مَالًا وَلَمْ يُبَيِّنْهُ عَلَى أَنْ يَتْرَكَ الْآخَرُ دَعْوَاهُ أَوْ عَلَى أَنْ يُسَلِّمَ إِلَيْهِ مَا ادَّعَاهُ لَمْ يَجُزْ ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ عَنْ مَجْهُولٍ عَلَى مَعْلُومٍ وَقَدْ أُحْتِجَ فِيهِ إِلَى التَّسْلِيمِ، كَمَا لَوْ ادَّعَى حَقًّا فِي دَارِ فِي يَدِ رَجُلٍ وَلَمْ يُسَمِّهِ فَاصْطَلَحَا عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ الْمُدَّعِي مَالًا مَعْلُومًا لَيْسَلَّمَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِلَى الْمُدَّعِي مَا ادَّعَاهُ وَهُوَ لَا يَجُوزُ، وَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ فِيهِ إِلَى التَّسْلِيمِ كَمَا إِذَا اصْطَلَحَا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ عَلَى أَنْ يَتْرَكَ الْمُدَّعِي دَعْوَاهُ جَارًا ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ عَنْ مَعْلُومٍ عَلَى مَجْهُولٍ وَقَدْ أُحْتِجَ فِيهِ إِلَى التَّسْلِيمِ لَا يَجُوزُ، وَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ إِلَيْهِ جَارًا.

وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ : أَنَّ الْجَهَالََةَ الْمُفْضِيَةَ إِلَى الْمُنَازَعَةِ الْمَانِعَةِ عَنِ التَّسْلِيمِ وَالتَّسَلُّمِ هِيَ الْمُفْسِدَةُ ، فَمَا لَا يَجِبُ فِيهِ التَّسْلِيمُ وَالتَّسَلُّمُ جَارًا، وَمَا وَجَبَا فِيهِ لَمْ يَجُزْ مَعَ الْجَهَالَةِ ، لِأَنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى تَسْلِيمِ الْبَدَلِ شَرْطٌ لِكَوْنِهِ فِي مَعْنَى الْبَيْعِ . العناية شرح الهداية 409/8.

³⁵⁶ () يشير بهذا إلى ما ذكره بقوله : "لأن المدعى يأخذه عوضا عن حقه في زعمه " تكملة فتح القدير 410/8.

أثر الصلح عن دار في وجوب الشفعة : قَالَ (وَإِذَا صَلَحَ عَنْ دَارٍ لَمْ يَجِبْ فِيهَا الشُّفْعَةُ) مَعْنَاهُ إِذَا كَانَ عَنْ إنْكَارٍ أَوْ سُكُوتٍ ، لِأَنَّهُ يَأْخُذُهَا عَلَى أَصْلِ حَقِّهِ ، وَيُدْفَعُ الْمَالُ دَفْعًا لِحُصُومَةِ الْمُدَّعِي ، وَزَعْمُ الْمُدَّعِي لَا يُلْزِمُهُ .(358)

أثر الصلح على دار في وجوب الشفعة: بِخِلَافِ مَا إِذَا صَلَحَ عَلَى دَارٍ حَيْثُ يَجِبُ فِيهَا الشُّفْعَةُ ، لِأَنَّ الْمُدَّعِيَّ يَأْخُذُهَا عَوَضًا عَنِ الْمَالِ ، فَكَانَ مُعَاوَضَةً فِي حَقِّهِ ، فَتُلْزِمُهُ الشُّفْعَةُ بِإِقْرَارِهِ وَإِنْ كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يُكَذِّبُهُ(359).

أثر استحقاق بعض المصالح عنه في الصلح عن إقرار : قَالَ (وَإِذَا كَانَ الصُّلْحُ عَنْ إِقْرَارٍ ، وَاسْتَحَقَّ بَعْضُ الْمَصَالِحِ عَنْهُ ، رَجَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِحِصَّةِ ذَلِكَ مِنَ الْعَوَضِ) ، لِأَنَّهُ مُعَاوَضَةٌ مُطْلَقَةٌ كَالْبَيْعِ ، وَحُكْمُ الْإِسْتِحْقَاقِ فِي الْبَيْعِ هَذَا (360).

أثر استحقاق بعض المصالح عنه في الصلح عن سكوت أو إنكار : (وَإِنْ وَقَعَ الصُّلْحُ عَنْ سُكُوتٍ أَوْ إنْكَارٍ فَاسْتَحَقَّ الْمُتَنَازِعُ فِيهِ رَجَعَ الْمُدَّعَى بِالْحُصُومَةِ ، وَرَدَّ الْعَوَضُ) ، لِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَا بَدَلَ الْعَوَضِ إِلَّا لِيُدْفَعَ حُصُومَتُهُ عَنْ نَفْسِهِ ، فَإِذَا ظَهَرَ الْإِسْتِحْقَاقُ تَبَيَّنَ أَنَّ لَا حُصُومَةَ لَهُ ، فَيَبْقَى الْعَوَضُ فِي يَدِهِ غَيْرَ مُشْتَمِلٍ عَلَى غَرَضِهِ فَيَسْتَرُدُّهُ ، وَإِنْ اسْتَحَقَّ بَعْضُ ذَلِكَ رَدَّ حِصَّتَهُ وَرَجَعَ بِالْحُصُومَةِ فِيهِ ، لِأَنَّهُ خَلَا الْعَوَضُ فِي هَذَا الْقَدْرِ عَنِ الْغَرَضِ(361).

أثر استحقاق المصالح عليه في الصلح عن إقرار أو إنكار : "وَلَوْ اسْتَحَقَّ الْمُصَالِحُ عَلَيْهِ عَنْ إِقْرَارٍ رَجَعَ بِكُلِّ الْمَصَالِحِ عَنْهُ ، لِأَنَّهُ مُبَادَلَةٌ ، وَإِنْ اسْتَحَقَّ بَعْضُهُ رَجَعَ بِحِصَّتِهِ. وَإِنْ كَانَ الصُّلْحُ عَنْ إنْكَارٍ أَوْ سُكُوتٍ رَجَعَ إِلَى الدَّعْوَى فِي كُلِّهِ ، أَوْ يَقْدَرُ الْمُسْتَحَقُّ إِذَا اسْتَحَقَّ بَعْضُهُ ، لِأَنَّ الْمُبْدَلَ فِيهِ هُوَ الدَّعْوَى ، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إِذَا بَاعَ مِنْهُ عَلَى الْإِنْكَارِ شَيْئًا ، حَيْثُ يَرْجِعُ بِالْمُدَّعَى ، لِأَنَّ الْإِقْدَامَ عَلَى الْبَيْعِ إِقْرَارٌ مِنْهُ بِالْحَقِّ لَهُ ، وَلَا كَذَلِكَ الصُّلْحُ ، لِأَنَّهُ قَدْ يَقَعُ لِدَفْعِ الْحُصُومَةِ ، وَلَوْ هَلَكَ بَدَلَ الصُّلْحِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ ، فَالْجَوَابُ فِيهِ كَالْجَوَابِ فِي الْإِسْتِحْقَاقِ فِي الْفَصْلَيْنِ(362).

357 () الإقالة : فسخ في حق المتعاقدين بيع جديد في حق ثالث ، عند أبي حنيفة ، وقال أبو يوسف: بيع جديد في حق الكل . الاختيار لتعليل المختار 11/2.

358 () أى لأن المدعى عليه يأخذها ، ليستبقى الدار على ملكه ، لا أنه يشتريها ، ويدفع المال ، لدفع الخصومة على زعمه ، والإنسان يؤخذ بما فى زعمه ، ولا يلزمه زعم غيره. العناية على الهداية 410/8.

359 () فصار كأنه قال: اشتريتها من المدعى عليه وهو ينكر ، فتجب فيها الشفعة. البناية 10/7.

360 () أي الرجوع بالحصة من العوض . البناية 7/10.

361 () أي عن غرض المدعى عليه . البناية 8/10.

362 () أي فصل الإقرار والإنكار ، فإن كان عن إقرار رجع بعد الهلاك إلى المدعى ، وإن كان عن إنكار رجع بالدعوى. العناية 411/8.

أثر استحقاق المصالح عليه في دعوى الحق غير الثابت : قَالَ (وَإِنْ ادَّعَى حَقًّا فِي دَارٍ وَلَمْ يُبَيِّنْهُ فَصُولِحَ مِنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ اسْتَحَقَّ بَعْضَ الدَّارِ لَمْ يَرُدَّ شَيْئًا مِنَ الْعَوَضِ ، لِأَنَّ دَعْوَاهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِيمَا بَقِيَ) ، بِخِلَافِ مَا إِذَا اسْتَحَقَّ كُلُّهُ ، لِأَنَّهُ يَعْرِى الْعَوَضُ عِنْدَ ذَلِكَ عَنْ شَيْءٍ يُقَابِلُهُ فَيَرْجِعُ بِكُلِّهِ عَلَى مَا قَدَّمَاهُ فِي النُّيُوعِ.

المصالحة على جزء من المدعى به : " وَلَوْ ادَّعَى دَارًا فَصَالَحَهُ عَلَى قِطْعَةٍ مِنْهَا ، لَمْ يَصِحَّ الصُّلْحُ ، لِأَنَّ مَا قَبَضَهُ مِنْ عَيْنِ حَقِّهِ ، وَهُوَ عَلَى دَعْوَاهُ فِي الْبَاقِي ، وَالْوَجْهُ فِيهِ أَحَدُ أَمْرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَزِيدَ دِرْهَمًا فِي بَدَلِ الصُّلْحِ فَيَصِيرَ ذَلِكَ عَوَضًا عَنْ حَقِّهِ فِيمَا بَقِيَ ، أَوْ يُلْحَقَ بِهِ ذِكْرُ الْبَرَاءَةِ عَنْ دَعْوَى الْبَاقِي).³⁶³

³⁶³ () مِثْلُ أَنْ يَقُولَ بَرَأْتُ مِنْ دَعْوَايَ فِي هَذِهِ الدَّارِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ لِمُصَادَفَةِ الْبَرَاءَةِ الدَّعْوَى وَهُوَ صَحِيحٌ ، حَتَّى لَوْ ادَّعَى بَعْدَ ذَلِكَ وَجَاءَ بِبَيِّنَةٍ لَمْ تُقْبَلْ. العناية 412/8.

فصل

الصلح في دعوى الأموال : (وَالصُّلْحُ جَائِزٌ عَنْ دَعْوَى الْأَمْوَالِ) ، لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْبَيْعِ عَلَى مَا مَرَّ (364).

الصلح في دعوى المنافع : قَالَ (وَالْمَنَافِعُ ، لِأَنَّهَا تُمْلِكُ بِعَقْدِ الْإِجَارَةِ ، فَكَذَا بِالصُّلْحِ) ، وَالْأَصْلُ فِيهِ : أَنَّ الصُّلْحَ يَجِبُ حَمْلُهُ عَلَى أَقْرَبِ الْعُقُودِ إِلَيْهِ وَأَشْبَهَهَا بِهِ اخْتِيَالًا لِلصَّحِيحِ تَصَرُّفِ الْعَاقِدِ مَا أَمَكَنَ (365).

الصلح عن جناية العمد والخطأ : قَالَ (وَيَصِحُّ عَنْ جِنَايَةِ الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ) أَمَّا الْأَوَّلُ : فَلَقَوْلِهِ تَعَالَى {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعْ} [البقرة: 178] الْآيَةُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - : "إِنَّهَا نَزَلَتْ فِي الصُّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ" (366) ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ النِّكَاحِ ، حَتَّى أَنَّ مَا صَلَحَ مُسَمًى فِيهِ صَلَحَ هَاهُنَا ، إِذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُبَادَلُهُ الْمَالِ بِغَيْرِ الْمَالِ إِلَّا أَنَّ عِنْدَ فَسَادِ التَّسْمِيَةِ هُنَا يُصَارُ إِلَى الدِّيَةِ ، لِأَنَّهَا مُوجِبُ الدَّمِ (367).

الصلح على خمر : "وَلَوْ صَلَحَ عَلَى خَمْرٍ ، لَا يَجِبُ شَيْءٌ" (368) ، لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ بِمُطْلَقِ الْعَفْوِ. الصلح في النكاح على خمر أو مال مجهول : "وَفِي النِّكَاحِ يَجِبُ مَهْرُ الْمُثَلِّ فِي الْفَصْلَيْنِ" (369) ، لِأَنَّهُ الْمَوْجِبُ الْأَصْلِيُّ ، وَيَجِبُ مَعَ السُّكُوتِ عَنْهُ حُكْمًا ، وَيَدْخُلُ فِي إِطْلَاقِ جَوَابِ الْكِتَابِ الْجِنَايَةِ فِي النَّفْسِ وَمَا دُونَهَا.

(364) فما جاز بيعه جاز الصلح عنه . البناية 10/10.

(365) أي بقدر الإمكان، فإن كان عن مال بمال اعتبر بالشبهات، وإن كان على منافع اعتبر بالإجازات. البناية 10/10.

(366) تفسير ابن كثير 490/1.

(367) قال البابر تي : " فَلَوْ صَلَحَهُ عَلَى سُكْنَى دَارٍ أَوْ خِدْمَةِ عَبْدٍ سَنَةً جَازَ ، لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ الْمَعْلُومَةَ صَلَحَتْ صَدَاقًا ، فَكَذَا بَدَلًا فِي الصُّلْحِ وَإِنْ صَلَحَ عَلَى ذَلِكَ أَبَدًا لَمْ يَجْزِ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَصْلُحْ صَدَاقًا لِجَهَالَتِهِ فَكَذَا بَدَلًا ، وَلَا يَتَوَهَّمُ لُزُومُ الْعَكْسِ فَإِنَّهُ غَيْرُ لَازِمٍ وَلَا هُوَ مُلْتَزِمٌ ، أَلَا تَرَى أَنَّ الصُّلْحَ عَنِ الْقَتْلِ الْعَمْدِ عَلَى أَقَلِّ مِنْ عَشْرَةٍ - دَرَاهِمٍ - صَحِيحٌ ، وَإِنْ لَمْ يَصْلُحْ صَدَاقًا ، وَأَنَّهُ إِذَا صَلَحَ عَلَى أَنْ يَغْفُوَ مَنْ عَلَيْهِ عَنْ قِصَاصٍ لَهُ عَلَى آخَرَ جَازَ ، وَإِنْ لَمْ يَصْلُحْ الْعَفْوُ عَنِ الْقِصَاصِ صَدَاقًا ، لِأَنَّ كَوْنَ الصَّدَاقِ مَالًا مَنْصُوصًا عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} [النساء: 24] وَبَدَلُ الصُّلْحِ فِي الْقِصَاصِ لَيْسَ كَذَلِكَ ، فَيَكْتَفَى بِكَوْنِ الْعَوَضِ فِيهِ مُتَقَوِّمًا ، وَالْقِصَاصُ مُتَقَوِّمٌ حَتَّى صَلَحَ الْمَالُ عَوَضًا عَنْهُ فَيَجُوزُ أَنْ يَقَعَ عَوَضًا عَنْ قِصَاصِ آخَرَ ، وَقَوْلُهُ : "إِلَّا أَنْ عِنْدَ فَسَادِ التَّسْمِيَةِ" اسْتِثْنَاءٌ مِنْ قَوْلِهِ : "إِنْ مَا صَلَحَ مُسَمًى فِيهِ صَلَحَ هَاهُنَا" بِمَعْنَى لَكِنْ : أَيْ لَكِنْ إِذَا فَسَدَتِ التَّسْمِيَةُ بِجَهَالَةٍ فَاحِشَةٍ أَوْ بِتَّسْمِيَةٍ مَا لَيْسَ بِمَالٍ مُتَقَوِّمٍ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا . العناية 415/8.

(368) لأنه لما لم يسم مالا متقوما ، صار ذكره والسكوت عنه شيئان، ولو سكت بعد العفو مطلقا وفيه لا يجب شيء فكذا في ذكر الخمر. البناية 11/10.

الصلح على مال في حق الشفعة: وَهَذَا بِخِلَافِ الصُّلْحِ عَنْ حَقِّ الشُّفْعَةِ عَلَى مَالٍ ، حَيْثُ لَا يَصِحُّ ، لِأَنَّهُ حَقُّ التَّمْلُكِ ، وَلَا حَقٌّ فِي الْمَحَلِّ قَبْلَ التَّمْلُكِ³⁷⁰).

الصلح على مال في القصاص: "وَأَمَّا الْقَاصَصُ فَمِلْكُ الْمَحَلِّ فِي حَقِّ الْفِعْلِ ، فَيَصِحُّ الْإِعْتِيَاظُ عَنْهُ ، وَإِذَا لَمْ يَصِحَّ الصُّلْحُ تَبَطَّلَ الشُّفْعَةُ ، لِأَنَّهَا تَبَطَّلُ بِالْإِعْرَاضِ وَالسُّكُوتِ ، وَالْكَفَالَةُ بِالنَّفْسِ بِمَنْزِلَةِ حَقِّ الشُّفْعَةِ ، حَتَّى لَا يَجِبَ الْمَالُ بِالصُّلْحِ عَنْهُ ، غَيْرَ أَنَّ فِي بَطْلَانِ الْكَفَالَةِ رَوَائِثَيْنِ³⁷¹) عَلَى مَا عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ.

الصلح على مال في جناية الخطأ والقصاص: وَأَمَّا الثَّانِي : وَهُوَ جِنَايَةُ الْخَطَأِ ، فَلِأَنَّ مُوجِبَهَا الْمَالُ ، فَيَصِيرُ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْعِ ، إِلَّا أَنَّهُ لَا تَصِحُّ الزِّيَادَةُ عَلَى قَدْرِ الدِّيَةِ ، لِأَنَّهُ مُقَدَّرٌ شَرْعًا ، فَلَا يَجُوزُ إِبْطَالُهُ فَتُرَدُّ الزِّيَادَةُ ، بِخِلَافِ الصُّلْحِ عَنِ الْقَاصَصِ ، حَيْثُ تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَى قَدْرِ الدِّيَةِ ، لِأَنَّ الْقَاصَصَ لَيْسَ بِمَالٍ ، وَإِنَّمَا يَتَقَوَّمُ بِالْعَقْدِ ، وَهَذَا إِذَا صَلَّحَ عَلَى أَحَدِ مَقَادِيرِ الدِّيَةِ ، أَمَّا إِذَا صَلَّحَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ جَازَ ، لِأَنَّهُ مُبَادَلَةٌ بِهَا ، إِلَّا أَنَّهُ يُسْتَرْطُ الْقَبْضُ فِي الْمَجْلِسِ ، كَيْ لَا يَكُونَ افْتِرَاقًا عَنْ دَيْنٍ بِدَيْنٍ ، وَلَوْ قَضَى الْقَاضِي بِأَحَدِ مَقَادِيرِهَا فَصَالَحَ عَلَى جِنْسٍ آخَرَ مِنْهَا بِالزِّيَادَةِ جَازَ ، لِأَنَّهُ تَعَيَّنَ الْحَقُّ بِالْقَضَاءِ ، فَكَانَ مُبَادَلَةً ، بِخِلَافِ الصُّلْحِ ابْتِدَاءً ، لِأَنَّ تَرَاضِيَهُمَا عَلَى بَعْضِ الْمَقَادِيرِ بِمَنْزِلَةِ الْقَضَاءِ فِي حَقِّ التَّعْيِينِ ، فَلَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَى مَا تَعَيَّنَ³⁷²).

الصلح عن دعوى حد أو حق عام: قَالَ (وَلَا يَجُوزُ عَنْ دَعْوَى حَدٍّ) ، لِأَنَّهُ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى لَا حَقَّهُ ، وَلَا يَجُوزُ الْإِعْتِيَاظُ عَنْ حَقِّ غَيْرِهِ ، وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ الْإِعْتِيَاظُ إِذَا ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ نَسَبَ وَلَدِهَا ، لِأَنَّهُ حَقُّ الْوَلَدِ لَا حَقَّهَا ، وَكَذَا لَا يَجُوزُ الصُّلْحُ عَمَّا أَسْرَعَهُ إِلَى طَرِيقِ الْعَامَّةِ ، لِأَنَّهُ حَقُّ الْعَامَّةِ ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُصَالِحَ وَاحِدٌ عَلَى الْإِنْفِرَادِ عَنْهُ؛ وَيَدْخُلُ فِي إِطْلَاقِ الْجَوَابِ حَدُّ الْقَذْفِ ، لِأَنَّ الْمُغْلَبَ فِيهِ حَقُّ الشَّرْعِ³⁷³).

³⁶⁹ () أى فى فصل تسمية المال المجهول ، وفصل الخمر ، لأن المهر هو الموجب الأصلي فى النكاح ، ويجب حكما مع السكوت عنه ، وتحقيقه أن المهر من ضرورات عقد النكاح ، فإنه ما شرع إلا بالمال ، فإذا لم يكن المسمى صالحا ، صار كما لو لم يسم مهرا. العناية على الهداية/8:416.

³⁷⁰ () وأخذ البذل هنا أخذ مال في مقابلة ما ليس بشيء ثابت في المحل ، وذلك رشوة حرام. البنائة/10:12.

³⁷¹ () فى رواية كتاب الشُّفْعَةِ وَالْحَوَالَةِ وَالْكَفَالَةِ تَبَطَّلَ وَهُوَ رِوَايَةُ أَبِي حَفْصٍ ، وَبِهِ يُفْنَى لِأَنَّ السُّقُوطَ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْعَوَضِ ، وَإِذَا سَقَطَتْ لَا تَعُودُ وَفِي الصُّلْحِ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي سُلَيْمَانَ لَا تَبَطَّلُ لِأَنَّ الْكَفَالَةَ بِالنَّفْسِ وَقَدْ تَكُونُ مُوصِلَةً إِلَى الْمَالِ فَأَخَذَتْ حُكْمَهُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ العناية /8:416.

³⁷² () وَلَوْ قَضَى الْقَاضِي بِأَحَدِ الْمَقَادِيرِ زِيَادَةً عَلَى مِقْدَارِ الدِّيَةِ لَمْ يَجَزْ ، فَكَذَا هَذَا. العناية /8:417.

³⁷³ () وَلِقَائِلِ أَنْ يَقُولَ: لَوْ كَانَ الْمُغْلَبُ فِيهِ حَقُّ الشَّرْعِ ، لَوَجَبَ أَنْ لَا يُحَدَّ الْمُسْتَأْمَنُ إِذَا قَذَفَ ، كَمَا لَوْ زَنَى ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ يُحَدُّ لِأَنَّهُ حَقُّ الْعَبْدِ. وَالْجَوَابُ: أَنَّ حَدَّ الْقَذْفِ يَشْتَمِلُ عَلَى الْحَقِّينِ لَا مَحَالَةَ ،

مصالحة المرأة رجلا في دعوى النكاح : قَالَ (وَإِذَا ادَّعى رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ نِكَاحًا وَهِيَ تَجْحَدُ ، فَصَالَحْتُهُ عَلَى مَالٍ بَدَلْتُهُ حَتَّى يَتْرُكَ الدَّعْوَى جَارَ ، وَكَانَ فِي مَعْنَى الْخُلْعِ) ، لِأَنَّهُ أَمَكَّنَ تَصْحِيحُهُ خُلْعًا فِي جَانِبِهِ بِنَاءً عَلَى زَعْمِهِ ، وَفِي جَانِبِهَا بَدَلًا لِلْمَالِ ، لِدَفْعِ الْخُصُومَةِ. قَالُوا: وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى إِذَا كَانَ مُبْطِلًا فِي دَعْوَاهُ³⁷⁴).

مصالحة الرجل امرأة في دعوى النكاح : قَالَ (وَإِذَا ادَّعَتْ امْرَأَةٌ عَلَى رَجُلٍ نِكَاحًا فَصَالَحَهَا عَلَى مَالٍ بَدَلْتُهُ لَهَا جَارَ) قَالَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : هَكَذَا ذَكَرَ فِي بَعْضِ نُسَخِ الْمُخْتَصَرِ⁽³⁷⁵⁾ ، وَفِي بَعْضِهَا قَالَ: لَمْ يَجْزُ ، وَجْهُ الْأَوَّلِ : أَنْ يَجْعَلَ زِيَادَةً فِي مَهْرِهَا، وَجْهُ الثَّانِي : أَنَّهُ بَدَلُ لَهَا الْمَالِ لِتَتْرُكَ الدَّعْوَى ، فَإِنْ جُعِلَ تَرَكُ الدَّعْوَى مِنْهَا فُرْقَةً فَالزَّوْجُ لَا يُعْطَى الْعِوَضَ فِي الْفُرْقَةِ، وَإِنْ لَمْ يُجْعَلْ فَالْحَالُ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ الدَّعْوَى ، فَلَا شَيْءَ يُقَابِلُهُ الْعِوَضُ فَلَمْ يَصِحَّ⁽³⁷⁶⁾).

صالح الرجل آخر على دعوى أنه عبده :قَالَ (وَإِنْ ادَّعى عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ عَبْدُهُ فَصَالَحَهُ عَلَى مَالٍ أَعْطَاهُ جَارَ ، وَكَانَ فِي حَقِّ الْمُدَّعِي بِمَنْزِلَةِ الْإِعْتَاقِ عَلَى مَالٍ) ، لِأَنَّهُ أَمَكَّنَ تَصْحِيحُهُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فِي حَقِّهِ لِرَّعْمِهِ ، وَلِهَذَا يَصِحُّ عَلَى حَيَوَانٍ فِي الذِّمَّةِ إِلَى أَجَلٍ ، وَفِي حَقِّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَكُونُ لِدَفْعِ الْخُصُومَةِ؛ لِأَنَّهُ يَزْعُمُ أَنَّهُ حُرٌّ فَجَارَ ، إِلَّا أَنَّهُ لَا وَلَاءَ لَهُ لِانْكَارِ الْعَبْدِ ، إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ فَتُقْبَلَ وَيَتَّبَعَ الْوَلَاءُ.

صلح العبد المأذون له في القتل العمد :قَالَ (وَإِذَا قَتَلَ الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ لَهُ رَجُلًا عَمْدًا ، لَمْ يَجْزُ لَهُ أَنْ يُصَالِحَ عَنْ نَفْسِهِ، وَإِنْ قَتَلَ عَبْدٌ لَهُ رَجُلًا عَمْدًا فَصَالَحَهُ ، جَارَ) ، وَوَجْهُ الْفَرْقِ أَنَّ رَقَبَتَهُ لَيْسَتْ مِنْ تِجَارَتِهِ ، وَلِهَذَا لَا يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِيهِ بَيْعًا فَكَذَا اسْتِخْلَاصًا بِمَالِ الْمُؤَلَى وَصَارَ كَالْأَجْنَبِيِّ، أَمَّا عَبْدُهُ فَمِنْ تِجَارَتِهِ وَتَصَرُّفُهُ فِيهِ نَافِذٌ بَيْعًا فَكَذَا اسْتِخْلَاصًا، وَهَذَا لِأَنَّ الْمُسْتَحَقَّ كَالزَّائِلِ عَنْ مِلْكِهِ وَهَذَا شِرَاؤُهُ فَيَمْلِكُهُ.

غصب ثوبا معلوم القيمة فصالح على أكثر من قيمته :قَالَ (وَمَنْ غَصَبَ ثَوْبًا يَهُودِيًّا⁽³⁷⁷⁾) قِيمَتُهُ دُونَ الْمِائَةِ ، فَاسْتَهْلَكَهُ فَصَالَحَهُ مِنْهَا عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ ، جَارَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالَ أَبُو

فَيَعْمَلُ بِكُلِّ مِنْهُمَا بِحَسَبِ مَا يَلِيقُ بِهِ، وَمَا يَلِيقُ بِالْحَرْبِيِّ أَنْ يَكُونَ حَقَّ الْعَبْدِ ، لِإِمْكَانِ الْإِسْتِيفَاءِ، وَمَا يَلِيقُ بِالْإِمَامِ أَنْ يَكُونَ حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى ، لِأَنَّهُ لَيْسَ فَوْقَهُ إِمَامٌ يَسْتَوْفِيهِ مِنْهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. العناية 277/5.

⁽³⁷⁴⁾ () فَإِنْ أَقَامَ عَلَى التَّزْوِيجِ بَيِّنَةٌ بَعْدَ الصُّلْحِ ، لَمْ تُقْبَلْ لِأَنَّ مَا جَرَى كَانَ خُلْعًا فِي زَعْمِهِ ، وَلَا فَائِدَةَ فِي إِقَامَتِهَا بَعْدَهُ، وَإِنْ كَانَ مُبْطِلًا فِي دَعْوَاهُ لَمْ يَحِلَّ لَهُ مَا أَخَذَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى، وَهَذَا عَامٌّ فِي جَمِيعِ أَنْوَاعِ الصُّلْحِ، إِلَّا أَنْ يُسَلِّمَهُ بِطِيبٍ عَنْ نَفْسِهِ فَيَكُونُ تَمْلِيكًا عَلَى طَرِيقِ الْهَبَةِ . العناية 419/8

⁽³⁷⁵⁾ () أى مختصر القدورى، أحمد بن محمد بن جعفر القدورى ت 428هـ .

⁽³⁷⁶⁾ () لِأَنَّ الْفُرْقَةَ لَمَّا لَمْ تُوجَدْ كَانَتْ دَعْوَاهَا عَلَى حَالِهَا لِبَقَاءِ النِّكَاحِ فِي زَعْمِهَا ، فَلَمْ يَكُنْ ثَمَّةَ شَيْءٍ يُقَابِلُهُ الْعِوَضُ ، فَكَانَ رِشْوَةً. العناية 419/8.

⁽³⁷⁷⁾ () يهود قوم من أهل الكتاب ينسب إليهم الثوب ، يقال : ثوب يهودى ، وإنما خصه بالذكر، إشارة إلى كونه معلوم القيمة ، وكل قيمى معلوم القيمة حكمه كذلك . العناية على الهداية 420/8.

يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: يَبْطُلُ الْفَضْلُ عَلَى قِيَمَتِهِ بِمَا لَا يَتَغَابَنُ⁽³⁷⁸⁾ (النَّاسُ فِيهِ) ، لِأَنَّ الْوَاجِبَ هِيَ الْقِيَمَةُ ، وَهِيَ مُقَدَّرَةٌ فَالزِّيَادَةُ عَلَيْهَا تَكُونُ رَبًّا ، بِخِلَافِ مَا إِذَا صَالَحَ عَلَى عَرَضٍ ، لِأَنَّ الزِّيَادَةَ لَا تَظْهَرُ عِنْدَ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ ، وَبِخِلَافِ مَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيهِ ، لِأَنَّهُ يَدْخُلُ تَحْتَ تَقْوِيمِ الْمُقَوِّمِينَ فَلَا تَظْهَرُ الزِّيَادَةُ ، وَلِأَبِي حَنِيفَةَ : أَنَّ حَقَّهُ فِي الْهَالِكِ بَاقٍ ، حَتَّى لَوْ كَانَ عَبْدًا وَتَرَكَ أَخَذَ الْقِيَمَةَ يَكُونُ الْكَفْ عَالِيَهُ ، أَوْ حَقُّهُ فِي مِثْلِهِ صُورَةً وَمَعْنَى ، لِأَنَّ ضَمَانَ الْعُدْوَانِ بِالْمِثْلِ ، وَإِنَّمَا يَنْتَقِلُ إِلَى الْقِيَمَةِ بِالْقَضَاءِ ، فَقَبْلَهُ إِذَا تَرَاضَيَا عَلَى الْأَكْثَرِ كَانَ اعْتِيَاظًا ، فَلَا يَكُونُ رَبًّا ، بِخِلَافِ الصُّلْحِ بَعْدَ الْقَضَاءِ ، لِأَنَّ الْحَقَّ قَدْ انْتَقَلَ إِلَى الْقِيَمَةِ⁽³⁷⁹⁾).

العبد بين رجلين أعتقه أحدهما فصالحه الآخر على أكثر من نصف قيمته: قَالَ (وَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا وَهُوَ مُوسِرٌ ، فَصَالَحَهُ الْآخَرُ عَلَى أَكْثَرِ مِنْ نِصْفِ قِيَمَتِهِ فَالْفَضْلُ بَاطِلٌ) وَهَذَا بِالِاتِّفَاقِ ، وَأَمَّا عِنْدَهُمَا : فَلَمَّا بَيَّنَّا. وَالْفَرْقُ لِأَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّ الْقِيَمَةَ فِي الْعَتَقِ مَنْصُوصٌ عَلَيْهَا ، وَتَقْدِيرُ الشَّرْعِ لَا يَكُونُ دُونَ تَقْدِيرِ الْقَاضِي ، فَلَا يَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ ، وَبِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ ، لِأَنَّهَا غَيْرُ مَنْصُوصٍ عَلَيْهَا (وَإِنْ صَالَحَهُ عَلَى عُرُوضٍ جَازٍ) ، لِمَا بَيَّنَّا أَنَّهُ لَا يَظْهَرُ الْفَضْلُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

³⁷⁸ () الغبن نوعان : غبن فاحش : وهو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين ، وهذا لا يتسامح فيه التجار ، وغبن غير فاحش ، أو بسير : وهو ما يدخل تحت تقويم المقومين ، ويتسامح فيه التجار . الاختيار لتعليل المختار 23/1.

³⁷⁹ () فتكون الزيادة ربا لا محالة. البناية 19/10.

باب التبرع بالصلح والتوكل به

التوكيل بالصلح عن دم العمد أو بعض ما يدعيه من الدين: (وَمَنْ وَكَّلَ رَجُلًا بِالصُّلْحِ عَنْهُ فَصَالَحَ ، لَمْ يَلْزَمْ الْوَكِيلَ مَا صَالَحَ عَنْهُ إِلَّا أَنْ يَضْمَنَهُ ، وَالْمَالُ لَازِمٌ لِلْمُوكِّلِ) وتَأْوِيلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إِذَا كَانَ الصُّلْحُ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ ، أَوْ كَانَ الصُّلْحُ عَنْ بَعْضِ مَا يَدَّعِيهِ مِنَ الدَّيْنِ ، لِأَنَّهُ إِسْقَاطٌ مَحْضٌ ، فَكَانَ الْوَكِيلُ فِيهِ سَفِيرًا وَمُعَبَّرًا ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ، كَالْوَكِيلِ بِالنِّكَاحِ ، إِلَّا أَنْ يَضْمَنَهُ ، لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ هُوَ مُوَآخِذٌ بِعَقْدِ الضَّمَّانِ لَا بِعَقْدِ الصُّلْحِ ، أَمَّا إِذَا كَانَ الصُّلْحُ عَنْ مَالٍ بِمَالٍ ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْعِ فَتَرْجِعُ الْحُقُوقُ إِلَى الْوَكِيلِ ، فَيَكُونُ الْمُطَالِبُ بِالْمَالِ هُوَ الْوَكِيلُ دُونَ الْمُوكِّلِ⁽³⁸⁰⁾).

صلح الفضولي: قَالَ (وَإِنْ صَالَحَ رَجُلٌ عَنْهُ بِغَيْرِ أَمْرِهِ ، فَهُوَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ⁽³⁸¹⁾): إِنْ صَالَحَ بِمَالٍ وَضَمَّنَهُ ، تَمَّ الصُّلْحُ) ، لِأَنَّ الْحَاصِلَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَيْسَ إِلَّا الْبَرَاءَةُ ، وَفِي حَقِّهَا هُوَ وَالْأَجَنْبِيُّ سَوَاءٌ ، فَصُلْحٌ أَصِيلًا فِيهِ إِذَا ضَمَّنَهُ ، كَالْفُضُولِيِّ⁽³⁸²⁾ بِالْخُلْعِ إِذَا ضَمَّنَ الْبَدَلَ ، وَيَكُونُ مُتَبَرِّعًا عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، كَمَا لَوْ تَبَرَّعَ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ بِأَمْرِهِ ، وَلَا يَكُونُ لِهَذَا الْمُصَالِحِ شَيْءٌ مِنَ الْمُدَّعَى ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ لِلَّذِي فِي يَدِهِ ، لِأَنَّ تَصْحِيحَهُ بِطَرِيقِ الْإِسْقَاطِ ، وَلَا فَرْقَ فِي هَذَا بَيْنَ مَا إِذَا كَانَ مُقْرًا أَوْ مُنْكَرًا⁽³⁸³⁾).

⁽³⁸⁰⁾ (قَالَ صَاحِبُ النَّهْأَةِ مَا مَعْنَاهُ: إِنَّهُ لَا بُدَّ لِتَأْوِيلِ الْمَسْأَلَةِ مِنْ قَيْدٍ آخَرَ ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْمُصَالِحُ فِي الْمُعَاوَضَاتِ عَلَى الْإِنْكَارِ ، فَإِنْ كَانَ لَا يَجِبُ عَلَى الْوَكِيلِ شَيْءٌ ، وَإِنْ كَانَ فِيهَا لِأَنَّ الصُّلْحَ عَلَى الْإِنْكَارِ مُعَاوَضَةٌ بِإِسْقَاطِ الْحَقِّ فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الطَّلَاقِ بِجَعْلٍ وَذَلِكَ جَائِزٌ مَعَ الْأَجَنْبِيِّ جَوَازُهُ مَعَ الْخَصْمِ 423/8 ، 424.

⁽³⁸¹⁾ (وَوَجْهٌ ذَلِكَ : أَنَّ الْفُضُولِيَّ عِنْدَ الصَّلْحِ عَلَى مَالٍ ، إِمَّا أَنْ قَرْنَ بِذِكْرِ الْمَالِ ضَمَانَ نَفْسِهِ ، أَوْ لَا ، فَالْأَوَّلُ : هُوَ الْوَجْهُ الْأَوَّلُ ، وَالثَّانِي : أَمَّا إِنْ أَضَافَ الْمَالُ إِلَى نَفْسِهِ ، أَوْ لَا ، فَالْأَوَّلُ : هُوَ الْوَجْهُ الثَّانِي ، وَالثَّانِي : إِمَّا أَنْ يَسْلَمَ الْمَالُ الْمَذْكُورُ أَمْ لَا ، فَالْأَوَّلُ : هُوَ الْوَجْهُ الثَّالِثُ ، وَالثَّانِي هُوَ الرَّابِعُ . حَاشِيَةُ سَعْدِي أَفَنَدَى عَلَى تَكْمِلَةِ فَتْحِ الْقَدِيرِ 424/8.

⁽³⁸²⁾ (الْفُضُولِي : " جَمْعُ فَضْلٍ ، غَلَبَ فِي الْأَشْتَغَالِ بِمَا لَا يَعْنِيهِ ، وَمَا لَا وِلَايَةَ لَهُ فِيهِ " . الْبَحْرُ الرَّائِقُ 147/3.

⁽³⁸³⁾ (أَمَّا إِذَا كَانَ مُنْكَرًا فَظَاهِرٌ ، لِأَنَّهُ فِي زَعْمِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، فَيَكُونُ مُتَبَرِّعًا فِي إِسْقَاطِ الْخُصُومَةِ مِنْهُ ، وَزَعْمُ الْمُدَّعَى لَمْ يَنْفِذْ إِلَيْهِ ، وَأَمَّا إِذَا كَانَ مُقْرًا بِالْدينِ وَبِالصَّلْحِ ، يَنْبَغِي أَنْ يَصِيرَ مُشْتَرِيًا مَا فِي ذِمَّتِهِ بِمَا أَدَّى ، إِلَّا أَنْ شَرَاءَ الدينِ مِنْ غَيْرِ الْمَذْكُورِ لَا يَصِحُّ ، لِأَنَّ فِيهِ تَمْلِيكَ الدينِ مِنْ غَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ الدينُ ، وَذَا لَا يَجُوزُ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ عَيْنًا ، وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُقْرًا ، فَإِنَّهُ يَصِيرُ مُشْتَرِيًا لِنَفْسِهِ إِذَا كَانَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ ، لِأَنَّ شَرَاءَ الشَّيْءِ مِنْ مَالِكِهِ صَحِيحٌ وَإِنْ كَانَ فِي يَدِ غَيْرِهِ. الْبَنَاءُ 22/10.

(وَكَذَلِكَ إِنْ قَالَ صَالِحُكَ عَلَى أَلْفٍ هَذِهِ أَوْ عَلَى عَبْدِي هَذَا ، صَحَّ الصُّلْحُ وَلَزِمَهُ تَسْلِيمُهَا) ،
لِأَنَّهُ لَمَّا أَضَافَهُ إِلَى مَالٍ نَفْسِهِ فَقَدْ التَّزَمَ تَسْلِيمَهُ ، فَصَحَّ الصُّلْحُ (وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ عَلَى أَلْفٍ
وَسَلَّمَهَا) ، لِأَنَّ التَّسْلِيمَ إِلَيْهِ يُوجِبُ سَلَامَةَ الْعَوَضِ لَهُ فَيَتِمُّ الْعَقْدُ لِحُصُولِ مَقْصُودِهِ (384).

(وَلَوْ قَالَ صَالِحُكَ عَلَى أَلْفٍ فَالْعَقْدُ مَوْقُوفٌ ، فَإِنْ أَجَازَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ جَازَ وَلَزِمَهُ الْأَلْفُ ،
وَإِنْ لَمْ يُجْزِهِ بَطَلَ) لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْعَقْدِ إِنَّمَا هُوَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، لِأَنَّ دَفْعَ الْخُصُومَةِ حَاصِلٌ
لَهُ ، إِلَّا أَنَّ الْفُضُولِيَّ يَصِيرُ أَصِيلًا بِوَاسِطَةِ إِضَافَةِ الضَّمَانِ إِلَى نَفْسِهِ ، فَإِذَا لَمْ يُضِفْهُ بَقِيَ عَاقِدًا
مِنْ جِهَةِ الْمَطْلُوبِ فَيَتَوَقَّفُ عَلَى إِجَازَتِهِ (385).

قَالَ الْعَبْدُ الضَّعِيفُ (386) عَصَمَهُ اللَّهُ : وَوَجْهُ آخِرٌ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ صَالِحُكَ عَلَى هَذِهِ الْأَلْفِ أَوْ
عَلَى هَذَا الْعَبْدِ وَلَمْ يَنْسُبْهُ إِلَى نَفْسِهِ ، لِأَنَّهُ لَمَّا عَيَّنَّهُ لِلتَّسْلِيمِ صَارَ شَارِطًا سَلَامَتَهُ لَهُ فَيَتِمُّ بِقَوْلِهِ .

وَلَوْ اسْتَحَقَّ الْعَبْدُ أَوْ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَرَدَّهُ فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَى الْمُصَالِحِ ، لِأَنَّهُ التَّزَمَ الْإِيْفَاءَ مِنْ
مَحَلِّ بَعْيِهِ وَلَمْ يَلْتَزِمْ شَيْئًا سِوَاهُ ، فَإِنْ سَلِمَ الْمَحَلُّ لَهُ تَمَّ الصُّلْحُ ، وَإِنْ لَمْ يَسَلِّمْ لَهُ لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ
بِشَيْءٍ . بِخِلَافِ مَا إِذَا صَالَحَ عَلَى دَرَاهِمٍ مُسَمَّاةٍ وَضَمِنَهَا وَدَفَعَهَا ، ثُمَّ أُسْتُحِقَّتْ ، أَوْ وَجَدَهَا
رُيُوفًا ، حَيْثُ يَرْجِعُ عَلَيْهِ ، لِأَنَّهُ جَعَلَ نَفْسَهُ أَصِيلًا فِي حَقِّ الضَّمَانِ ، وَلِهَذَا يُجْبَرُ عَلَى التَّسْلِيمِ ،
فَإِذَا لَمْ يُسَلِّمْ لَهُ مَا سَلَّمَهُ يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِبَدَلِهِ (387) ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .

³⁸⁴ () وهو سلامة البدل للمدعي ، فإذا حصل المقصود تم العقد لا محالة. البناية 23/10.
() ³⁸⁵ أي على إجازة المدعى عليه ، فإن قبل لزمه المال ، وإن رده بطل الصلح. البناية 23/10.

³⁸⁶ () أي مصنف كتاب الهداية ، وهو أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني
المرغيناني ت 593 هـ . البناية على الهداية 238/4.
³⁸⁷ () أي يرجع عليه ببذل ما لم يسلم إليه ، البناية 24/10.

باب الصلح في الدين

الصلح على المستحق بعقد المداينة: (وَكُلُّ شَيْءٍ وَقَعَ عَلَيْهِ الصُّلْحُ وَهُوَ مُسْتَحَقٌّ بِعَقْدِ الْمَدَايِنَةِ³⁸⁸) لَمْ يُحْمَلْ عَلَى الْمُعَاوَضَةِ، وَإِنَّمَا يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ اسْتَوْفَى بَعْضَ حَقِّهِ وَأَسْقَطَ بَاقِيَهُ، كَمَنْ لَهُ عَلَى آخَرٍ أَلْفٌ دِرْهَمٍ فَصَالَحَهُ عَلَى خَمْسِمِائَةٍ، وَكَمَنْ لَهُ عَلَى آخَرٍ أَلْفٌ جِيَادٌ، فَصَالَحَهُ عَلَى خَمْسِمِائَةِ زُيُوفٍ جَازَ ، وَكَأَنَّهُ أَبْرَأَهُ عَنْ بَعْضِ حَقِّهِ ، وَهَذَا لِأَنَّهُ تَصَرَّفَ الْعَاقِلُ يَتَحَرَّى تَصَحِيحَهُ مَا أَمَكَنَ، وَلَا وَجَهَ لِتَصْحِيحِهِ مُعَاوَضَةً لِإِفْضَائِهِ إِلَى الرَّبَا ، فَجَعَلَ إِسْقَاطًا لِلْبَعْضِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى ، وَلِلْبَعْضِ وَالصِّفَةِ فِي الثَّانِيَةِ (.)³⁸⁹

الصلح عن جميع الدين المؤجل : (وَلَوْ صَالَحَ عَلَى أَلْفٍ مُؤَجَّلَةٍ جَازَ ، وَكَأَنَّهُ أَجَلَ نَفْسَ الْحَقِّ) ، لِأَنَّهُ لَا يُمَكِّنُ جَعْلَهُ مُعَاوَضَةً ، لِأَنَّهُ يَبِيعُ الدَّرَاهِمَ بِمَثْلِهَا نَسِيبَةً لَا يَجُوزُ ، فَحَمَلْنَاهُ عَلَى التَّأْخِيرِ ، (وَلَوْ صَالَحَهُ عَلَى دَنَانِيرَ إِلَى شَهْرٍ لَمْ يَجُزْ) ، لِأَنَّ الدَّنَانِيرَ غَيْرُ مُسْتَحَقَّةٍ بِعَقْدِ الْمَدَايِنَةِ ، فَلَا يُمَكِّنُ حَمْلُهُ عَلَى التَّأْخِيرِ، وَلَا وَجَهَ لَهُ سِوَى الْمُعَاوَضَةِ، وَيَبِيعُ الدَّرَاهِمَ بِالدَّنَانِيرِ نَسِيبَةً لَا يَجُوزُ فَلَمْ يَصِحَّ الصُّلْحُ (.)³⁹⁰

الصلح عن بعض الدين المؤجل : قال: (وَلَوْ كَانَتْ لَهُ أَلْفٌ مُؤَجَّلَةٌ فَصَالَحَهُ عَلَى خَمْسِمِائَةٍ حَالَةً لَمْ يَجُزْ) ، لِأَنَّ الْمُعَجَّلَ خَيْرٌ مِنَ الْمُؤَجَّلِ ، وَهُوَ غَيْرُ مُسْتَحَقٍّ بِالْعَقْدِ ، فَيَكُونُ بِإِزَاءِ مَا حَطَّهُ عَنْهُ، وَذَلِكَ اعْتِيَاظٌ عَنِ الْأَجَلِ ، وَهُوَ حَرَامٌ (.)³⁹¹

الصلح عن الدين المؤجل مع زيادة في الوصف أو الجودة: (وَإِنْ كَانَ لَهُ أَلْفٌ سُودٌ فَصَالَحَهُ عَلَى خَمْسِمِائَةِ بَيْضٍ لَمْ يَجُزْ) ، لِأَنَّ الْبَيْضَ غَيْرُ مُسْتَحَقَّةٍ بِعَقْدِ الْمَدَايِنَةِ ، وَهِيَ زَائِدَةٌ وَصْفًا ، فَيَكُونُ مُعَاوَضَةً الْأَلْفِ بِخَمْسِمِائَةٍ وَزِيَادَةٍ وَصَفٍ وَهُوَ رَبَا، بِخِلَافِ مَا إِذَا صَالَحَ عَنِ الْأَلْفِ الْبَيْضَ عَلَى خَمْسِمِائَةِ سُودٍ ، حَيْثُ يَجُوزُ ، لِأَنَّهُ إِسْقَاطٌ كُلُّهُ قَدْرًا وَوَصْفًا، وَبِخِلَافِ مَا إِذَا

³⁸⁸ () أي من جنس ما يستحقه المدعي على المدعى عليه بعقد المداينة أى البيع بالدين. البناية 25/10،

³⁸⁹ () (فجعل إسقاطا للبعض) : أي لبعض الدين (في المسألة الأولى) وهي مسألة مسامحة الألف بخمسمائة (وللبعض) : أي وجعل إسقاطا لبعض الدين (والصفة) : أي وإسقاطا للصفة (في الثانية) : أي في المسألة الثانية وهي مصالححة الجياد بالزيوف. البناية 26/10.

³⁹⁰ () لأنه يؤدي إلى الربا . البناية 26/10.

³⁹¹ () (رُوي أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - فَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَقَالَ: إِنَّ هَذَا يُرِيدُ أَنَّ أَطْعَمَهُ الرَّبَا ، وَهَذَا لِأَنَّ حُرْمَةَ رَبَا النِّسَاءِ لَيْسَتْ إِلَّا لِشَبْهَةِ مُبَادَلَةِ الْمَالِ بِالْأَجَلِ، فَحَقِيقَةُ ذَلِكَ أَوْلَى . البناية 26/10، العناية 472/8.

صَالِحَ عَلَى قَدْرِ الدِّينِ وَهُوَ أَجَوْدُ ، لِأَنَّهُ مُعَاوَضَةُ الْمِثْلِ بِالْمِثْلِ ، وَلَا مُعْتَبَرٌ بِالصِّفَةِ إِلَّا أَنَّهُ يُشْتَرَطُ الْقَبْضُ فِي الْمَجْلِسِ (392).

الصلح على إسقاط أحد نوعي الثمن : وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَمِائَةُ دِينَارٍ فَصَالَحَهُ عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ حَالَةً أَوْ إِلَى شَهْرٍ ، صَحَّ الصُّلْحُ ، لِأَنَّهُ أَمَكَّنَ أَنْ يُجْعَلَ إِسْقَاطًا لِلدَّائِنِ كُلِّهَا ، وَالْدَّرَاهِمِ إِلَّا مِائَةً ، وَتَأْجِيلًا لِلْبَاقِي ، فَلَا يُجْعَلُ مُعَاوَضَةً تَصَحُّيحًا لِلْعَقْدِ ، أَوْ لِأَنَّ مَعْنَى الْإِسْقَاطِ فِيهِ الْأَزْمُ (393).

الصلح في الدين على بعضه مقابل إسقاط باقيه : قَالَ (وَمَنْ لَهُ عَلَى آخَرٍ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَقَالَ أَدِّ إِلَيَّ غَدًا مِنْهَا خَمْسِمِائَةً عَلَى أَنَّكَ بَرِيءٌ مِنَ الْفَضْلِ فَفَعَلَ ، فَهُوَ بَرِيءٌ ، فَإِنْ لَمْ يَدْفَعْ إِلَيْهِ الْخَمْسِمِائَةَ غَدًا عَادَ عَلَيْهِ الْأَلْفُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : لَا يَعُودُ عَلَيْهِ) ، لِأَنَّهُ إِبْرَاءٌ مُطْلَقٌ ؛ أَلَا تَرَى أَنَّهُ جَعَلَ أَدَاءَ الْخَمْسِمِائَةِ عَوَضًا حَيْثُ ذَكَرَهُ بِكَلِمَةٍ عَلَى وَهِيَ لِلْمُعَاوَضَةِ ، وَالْأَدَاءُ لَا يَصِحُّ عَوَضًا ، لِكُونِهِ مُسْتَحَقًّا عَلَيْهِ فَجَرَى وَجُودُهُ مَجْرَى عَدَمِهِ ، فَبَقِيَ الْإِبْرَاءُ مُطْلَقًا ، فَلَا يَعُودُ كَمَا إِذَا بَدَأَ بِالْإِبْرَاءِ ، وَلَهُمَا : أَنَّ هَذَا إِبْرَاءٌ مُقَيَّدٌ بِالشَّرْطِ ، فَيَقُوتُ بِقَوَاتِهِ ، لِأَنَّهُ بَدَأَ بِأَدَاءِ الْخَمْسِمِائَةِ فِي الْغَدِ ، وَأَنَّهُ يَصْلُحُ غَرَضًا جَذَارَ إِفْلَاسِهِ وَتَوَسُّلًا إِلَى تِجَارَةِ أَرْبَحٍ مِنْهُ ، وَكَلِمَةُ "عَلَى" إِنْ كَانَتْ لِلْمُعَاوَضَةِ فَهِيَ مُحْتَمِلَةٌ لِلشَّرْطِ ، لَوْجُودِ مَعْنَى الْمُقَابَلَةِ فِيهِ ، فَيَحْمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْحَمْلِ عَلَى الْمُعَاوَضَةِ تَصَحُّيحًا لِتَصَرُّفِهِ ، أَوْ لِأَنَّهُ مُتَعَارَفٌ ، وَالْإِبْرَاءُ مِمَّا يَتَقَيَّدُ بِالشَّرْطِ ، وَإِنْ كَانَ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ كَمَا فِي الْحَوَالَةِ ، وَسَتَخْرُجُ الْبُدْءُ بِالْإِبْرَاءِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

قَالَ الْعَبْدُ الضَّعِيفُ (394) : وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى وَجْهِ : أَحَدُهَا مَا ذَكَرْنَاهُ.

وَالثَّانِي : إِذَا قَالَ صَالِحُكَ مِنْ الْأَلْفِ عَلَى خَمْسِمِائَةٍ تَدْفَعُهَا إِلَيَّ غَدًا وَأَنْتَ بَرِيءٌ مِنَ الْفَضْلِ عَلَى أَنَّكَ إِنْ لَمْ تَدْفَعْهَا إِلَيَّ غَدًا فَالْأَلْفُ عَلَيْكَ عَلَى حَالِهِ.

وَجَوَابُهُ : أَنَّ الْأَمْرَ عَلَى مَا قَالَ لِأَنَّهُ أَتَى بِصَرِيحِ التَّقْيِيدِ فَيُعْمَلُ بِهِ.

وَالثَّلَاثُ : إِذَا قَالَ أَبْرَأْتُكَ مِنْ خَمْسِمِائَةٍ مِنَ الْأَلْفِ عَلَى أَنْ تُعْطِيَنِي الْخَمْسِمِائَةَ غَدًا وَالْإِبْرَاءُ فِيهِ وَاقِعٌ ، أَعْطَى الْخَمْسِمِائَةَ أَوْ لَمْ يُعْطَ ، لِأَنَّهُ أَطْلَقَ الْإِبْرَاءَ أَوَّلًا ، وَأَدَاءَ الْخَمْسِمِائَةِ لَا يَصْلُحُ عَوَضًا مُطْلَقًا ، وَلَكِنَّهُ يَصْلُحُ شَرْطًا فَوْقَ الشُّكِّ فِي تَقْيِيدِهِ بِالشَّرْطِ فَلَا يَتَقَيَّدُ بِهِ ، بِخِلَافِ مَا إِذَا

³⁹² () لأنه صرف ، والبخية : اسم لما هو الموجود من الدراهم السود ، وهو نقد بيت المال ، وقال : أبو الفتح المطرزي : "الدراهم البخية : نوع من أجود الدراهم ، نسبت فيما زعموا إلى "بخ" أمير ضربها ، وقيل : كتب عليها "بخ" ، وهى كلمة استحسان واستجادة ". البناية 27/10 ، العناية 472/8 ، المغرب في ترتيب المغرب ص 35.

³⁹³ () لأنه مبني على الحطيطة ، والخط هاهنا أكثر ، فيكون الإسقاط ألزم . البناية 27/10.

³⁹⁴ () أى المصنف صاحب الهداية ، وهو الإمام المرغينانى.

بَدَأَ بِأَدَاءِ خَمْسِمِائَةٍ لِأَنَّ الْإِبْرَاءَ حَصَلَ مَقْرُونًا بِهِ، فَمِنْ حَيْثُ إِنَّهُ لَا يَصْلُحُ عَوْضًا يَقَعُ مُطْلَقًا، وَمِنْ حَيْثُ إِنَّهُ يَصْلُحُ شَرْطًا لَا يَقَعُ مُطْلَقًا فَلَا يَنْبُتُ الْإِطْلَاقُ بِالشَّكِّ فَافْتَرَقَا.

وَالرَّابِعُ: إِذَا قَالَ أَدَّ إِلَيَّ خَمْسِمِائَةٍ عَلَى أَنَّكَ بَرِيءٌ مِنْ الْفَضْلِ وَلَمْ يُؤَقِّتْ لِلْأَدَاءِ وَقْتًا.

وَجَوَابُهُ: أَنَّهُ يَصِحُّ الْإِبْرَاءُ وَلَا يَعُودُ الدَّيْنُ لِأَنَّ هَذَا إِبْرَاءٌ مُطْلَقٌ، لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يُؤَقِّتْ لِلْأَدَاءِ وَقْتًا لَا يَكُونُ الْأَدَاءُ غَرْضًا صَحِيحًا لِأَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ فِي مُطْلَقِ الْأَرْزَاقِ فَلَمْ يَتَقَيَّدْ بَلْ يُحْمَلْ عَلَى الْمُعَاوَضَةِ وَلَا يَصْلُحُ عَوْضًا، بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ لِأَنَّ الْأَدَاءَ فِي الْغَدِ غَرْضٌ صَحِيحٌ.

وَالْخَامِسُ: إِذَا قَالَ إِنْ أَدَّيْتُ إِلَيَّ خَمْسِمِائَةٍ أَوْ قَالَ إِذَا أَدَّيْتُ أَوْ مَتَى أَدَّيْتُ.

فَالْجَوَابُ فِيهِ: أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْإِبْرَاءُ، لِأَنَّهُ عَلَقَهُ بِالشَّرْطِ صَرِيحًا، وَتَعْلِيْقُ الْبَرَاءَاتِ بِالشَّرْطِ بَاطِلٌ، لِمَا فِيهَا مِنْ مَعْنَى التَّمْلِيكِ حَتَّى يَرْتَدَّ بِالرَّدِّ، بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ، لِأَنَّهُ مَا أَتَى بِصَرِيحِ الشَّرْطِ فَحُمِلَ عَلَى التَّقْيِيدِ بِهِ³⁹⁵).

الصلح عن الإقرار: قَالَ (وَمَنْ قَالَ لِآخَرَ: لَا أَفِرُّ لَكَ بِمَالِكَ حَتَّى تُؤَخِّرَهُ عَنِّي، أَوْ تَحْطَ عَنِّي، فَفَعَلَ جَازَ عَلَيْهِ³⁹⁶))، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُكْرَهٍ، وَمَعْنَى الْمَسْأَلَةِ: إِذَا قَالَ ذَلِكَ سِرًّا، أَمَّا إِذَا قَالَ عَلَانِيَةً يُؤْخَذُ بِهِ³⁹⁷).

تدريبات:

³⁹⁵ () قَالَ صَاحِبُ النَّهَائَةِ: - وَهُوَ حَسَامُ الدِّينِ حَسَنُ السَّغْنَاقِيِّ - فِي حَصْرِ الْوُجُوهِ عَلَى خَمْسَةِ: إِنْ رَبَّ الدَّيْنِ فِي تَعْلِيْقِ الْإِبْرَاءِ بِأَدَاءِ الْبَعْضِ، لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ بَدَأَ بِالأَدَاءِ أَوْ لَا، فَإِنْ بَدَأَ بِهِ فَلَا يَخْلُو، وَإِمَّا أَنْ يَذْكُرَ مَعَهُ بَقَاءَ الْبَاقِي عَلَى الْمَدْيُونِ صَرِيحًا عِنْدَ عَدَمِ الْوَفَاءِ بِالشَّرْطِ أَوْ لَا، فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ، فَهُوَ الْوَجْهُ الْأَوَّلُ، وَإِنْ ذَكَرَهُ فَهُوَ الْوَجْهُ الثَّانِي، وَإِنْ لَمْ يَبْدَأْ بِالأَدَاءِ، فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ بَدَأَ بِالْإِبْرَاءِ أَوْ لَا، فَإِنْ بَدَأَ بِهِ، فَهُوَ الْوَجْهُ الثَّالِثُ، وَإِنْ لَمْ يَبْدَأْ بِالْإِبْرَاءِ فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ بَدَأَ بِحَرْفِ الشَّرْطِ أَوْ لَا، فَإِنْ لَمْ يَبْدَأْ فَالْوَجْهُ الرَّابِعُ وَإِنْ بَدَأَ فَهُوَ الْخَامِسُ.

أَمَّا الْوَجْهُ الْأَوَّلُ: فَقَدْ ذَكَرْنَاهُ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي: ظَهَرَ مِمَّا تَقَدَّمَ، وَالثَّالِثُ: وَهُوَ الْمَوْعُودُ بِاسْتِخْرَاجِ الْجَوَابِ مَبْنِيٍّ عَلَى أَنَّ الثَّابِتَ أَوَّلًا لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ، فَإِذَا قُدِّمَ الْإِبْرَاءُ حَصَلَ مُطْلَقًا ثُمَّ يَذْكُرُ مَا بَعْدَهُ وَقَعَ الشَّكُّ، لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ عَوْضًا فَهُوَ بَاطِلٌ لِمَا تَقَدَّمَ فَلَمْ يَزَلْ بِهِ الْإِطْلَاقُ، وَإِنْ كَانَ شَرْطًا يَقَيَّدُ بِهِ وَزَالَ الْإِطْلَاقُ، فَإِذَا وَقَعَ الشَّكُّ لَمْ يَبْطُلْ بِهِ الثَّابِتُ أَوَّلًا، وَفِي عَكْسِهَا عَكْسُ ذَلِكَ، وَالرَّابِعُ: وَجْهُهُ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُؤَقِّتْ لِلْأَدَاءِ وَقْتًا، ظَهَرَ أَنَّ أَدَاءَ الْبَعْضِ لَمْ يَكُنْ لِعَرْضٍ، لِكُونِهِ وَاجِبًا فِي مُطْلَقِ الْأَرْزَاقِ، فَلَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ فِي مَعْنَى الشَّرْطِ لِيَحْصَلَ بِهِ التَّقْيِيدُ فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا جِهَةُ الْعَوْضِ، وَهُوَ غَيْرُ صَالِحٍ لِذَلِكَ كَمَا تَقَدَّمَ، وَالْخَامِسُ تَعْلِيْقُ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْإِبْرَاءَ لَا يَحْتَمِلُهُ فَلَا يَكُونُ صَحِيحًا. العناية 429/8، 430.

³⁹⁶ () أَي هَذَا التَّصَرُّفُ وَهُوَ التَّأْخِيرُ أَوْ الْحُطُّ جَازٌ عَلَى رَبِّ الدِّينِ حَتَّى لَا يَتِمَّكَنَ مِنْ مَطَالِبَتِهِ فِي الْحَالِ، وَلَا مَطَالِبَتُهُ مَا حُطَّ عَنْهُ. الْبَنَاءُ 31/10.

³⁹⁷ () أَي يُؤْخَذُ الْمَقْرَرُ بِجَمِيعِ الْمَالِ فِي الْحَالِ بِلَا خِلَافٍ، لِأَنَّهُ إِقْرَارٌ مِنْهُ بِالْحَقِّ. الْبَنَاءُ 31/10.

فصل في الدين المشترك

صلح أحد الشريكين في الدين في جميع نصيبه : قَالَ (وَإِذَا كَانَ الدَّيْنُ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ ، فَصَالَحَ أَحَدُهُمَا مِنْ نَصِيبِهِ عَلَى ثَوْبٍ ، فَشَرِيكُهُ بِالْخِيَارِ ، إِنْ شَاءَ اتَّبَعَ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ بِصِفَةٍ ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ نِصْفَ الثَّوْبِ ، إِلَّا أَنْ يَضْمَنَ لَهُ شَرِيكُهُ رُبْعَ الدَّيْنِ) ، وَأَصْلُ هَذَا : أَنَّ الدَّيْنَ الْمُشْتَرَكَ⁽³⁹⁸⁾ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، إِذَا قَبِضَ أَحَدُهُمَا شَيْئًا مِنْهُ ، فَلِصَاحِبِهِ أَنْ يُشَارِكُهُ فِي الْمَقْبُوضِ ، لِأَنَّهُ ارْتَدَادٌ بِالْقَبْضِ ، إِذْ مَالِيَةُ الدَّيْنِ بِاعْتِبَارِ عَاقِبَةِ الْقَبْضِ ، وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ رَاجِعَةٌ إِلَى أَصْلِ الْحَقِّ ، فَتَصِيرُ كَزِيَادَةِ الْوَلَدِ وَالنَّمْرِ ، وَلَهُ حَقُّ الْمُشَارَكَةِ ، وَلَكِنَّهُ قَبْلَ الْمُشَارَكَةِ بَاقٍ عَلَى مَالِكِ الْقَابِضِ ، لِأَنَّ الْعَيْنَ غَيْرُ الدَّيْنِ حَقِيقَةً ، وَقَدْ قَبِضَهُ بَدَلًا عَنْ حَقِّهِ فَيَمْلِكُهُ حَتَّى يَنْفَذَ تَصَرُّفُهُ فِيهِ ، وَيَضْمَنَ لِشَرِيكِهِ حِصَّتَهُ ، وَالدَّيْنُ الْمُشْتَرَكُ يَكُونُ وَاجِبًا بِسَبَبٍ مُتَّحِدٍ ، كَتَمَنِ الْمَبِيعُ إِذَا كَانَ صَفَقَةً وَاحِدَةً ، وَتَمَنِ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ وَالْمَوْرُوثِ بَيْنَهُمَا ، وَقِيَمَةِ الْمُسْتَهْلَكِ الْمُشْتَرَكِ.

إِذَا عَرَفْنَا هَذَا فَنَقُولُ فِي مَسْأَلَةِ الْكِتَابِ: لَهُ أَنْ يَتَّبَعَ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَصْلُ ، لِأَنَّ نَصِيبَهُ بَاقٍ فِي ذِمَّتِهِ ، لِأَنَّ الْقَابِضَ قَبْضَ نَصِيبِهِ ، لَكِنَّ لَهُ حَقَّ الْمُشَارَكَةِ ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ نِصْفَ الثَّوْبِ ، لِأَنَّ لَهُ حَقَّ الْمُشَارَكَةِ إِلَّا أَنْ يَضْمَنَ لَهُ شَرِيكُهُ رُبْعَ الدَّيْنِ لِأَنَّ حَقَّهُ فِي ذَلِكَ⁽³⁹⁹⁾.

صلح أحد الشريكين في الدين في نصف نصيبه : قَالَ (وَلَوْ اسْتَوْفَى نِصْفَ نَصِيبِهِ مِنَ الدَّيْنِ كَانَ لِشَرِيكِهِ أَنْ يُشَارِكُهُ فِيمَا قَبِضَ) ، لِمَا قُلْنَا (ثُمَّ يَرْجِعَانِ عَلَى الْغَرِيمِ بِالْبَاقِي) ، لِأَنَّهُمَا لَمَّا اشْتَرَكَا فِي الْمَقْبُوضِ لَا بُدَّ أَنْ يَبْقَى الْبَاقِي عَلَى الشَّرِكَةِ.

صلح أحد الشريكين عن نصيبه بسلعة : قَالَ (وَلَوْ اشْتَرَى أَحَدُهُمَا بِنَصِيبِهِ مِنَ الدَّيْنِ سِلْعَةً ، كَانَ لِشَرِيكِهِ أَنْ يُضْمَنَهُ رُبْعَ الدَّيْنِ) ، لِأَنَّهُ صَارَ قَابِضًا حَقَّهُ بِالْمَقَاصَةِ كَامِلًا ، لِأَنَّ مَبْنَى الْبَيْعِ

³⁹⁸ () عُرِفَ الدَّيْنُ الْمُشْتَرَكُ : بِأَنَّهُ الَّذِي يَكُونُ وَاجِبًا بِسَبَبٍ مُتَّحِدٍ ، كَتَمَنِ مَبِيعَ صَفَقَةٍ وَاحِدَةٍ ، بِأَنَّ كَانَ لِكُلِّ مِنْهُمَا عَيْنٌ عَلَى حِدَةٍ ، فَبَاعَا صَفَقَةً وَاحِدَةً ، وَتَمَنِ مَالٍ مُشْتَرَكٍ ، وَمَوْرُوثٍ مُشْتَرَكٍ وَقِيَمَةٍ مُسْتَهْلَكٍ مُشْتَرَكٍ . العناية 8 / 433.

() ³⁹⁹ لَمَّا فَرَّغَ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مِنْ بَيَانِ الْأَصْلِ قَالَ: إِذَا عَرَفْنَا (هَذَا) : وَتَرَكَ عَلَيْهِ (فَنَقُولُ فِي مَسْأَلَةِ الْكِتَابِ) : أَيُّ مَخْتَصَرِ الْقُدُورِيِّ (لَهُ أَنْ يَتَّبِعَ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَصْلُ) : أَيُّ لِلْسَاكِتِ أَنْ يَتَّبِعَ الْمَدْيُونُ (لِأَنَّ نَصِيبَهُ بَاقٍ فِي ذِمَّتِهِ) : وَلَمْ يَسْتَوْفِهِ (لِأَنَّ الْقَابِضَ قَبْضَ نَصِيبِهِ لَكِنْ لَهُ حَقُّ الْمُشَارَكَةِ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ نِصْفَ الثَّوْبِ) وَنِصْفَ الثَّوْبِ قَدْرُ رُبْعِ الدَّيْنِ ، لِأَنَّ الثَّوْبَ صَوْلَحَ عَلَيْهِ بِنِصْفِ الدَّيْنِ ، فَيَكُونُ الثَّوْبُ قَدْرُ نِصْفِ الدَّيْنِ ، وَنِصْفُ النِّصْفِ رُبْعٌ لَا مُحَالَةَ (لِأَنَّ لَهُ حَقَّ الْمُشَارَكَةِ إِلَّا أَنْ يَضْمَنَ لَهُ شَرِيكُهُ رُبْعَ الدَّيْنِ ، لِأَنَّ حَقَّهُ فِي ذَلِكَ) أَيُّ لِأَنَّ حَقَّهُ فِي الْأَصْلِ كَانَ فِي الدَّيْنِ. البناية 33/10.

عَلَى الْمُمَاكَسَةِ⁽⁴⁰⁰⁾ ، بِخِلَافِ الصُّلْحِ ، لِأَنَّ مَبْنَاهُ عَلَى الْإِغْمَاضِ وَالْحَطِيطَةِ ، فَلَوْ أَلْزَمْنَاهُ دَفْعَ رُبْعِ الدَّيْنِ يَتَضَرَّرُ بِهِ ، فَيَتَخَيَّرُ الْقَابِضُ كَمَا ذَكَرْنَا ، وَلَا سَبِيلَ لِلشَّرِيكِ عَلَى التَّوْبِ فِي الْبَيْعِ ، لِأَنَّهُ مَلَكُهُ بِعَقْدِهِ ، وَالِاسْتِيفَاءُ بِالْمُقَاصَّةِ بَيْنَ ثَمَنِهِ وَبَيْنَ الدَّيْنِ .

وَاللَّشْرِيكِ أَنْ يَتَّبَعَ الْغَرِيمَ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَا ، لِأَنَّ حَقَّهُ فِي ذِمَّتِهِ بَاقٍ ، لِأَنَّ الْقَابِضَ اسْتَوْفَى نَصِيبَهُ حَقِيقَةً ، لَكِنَّ لَهُ حَقَّ الْمُشَارَكَةِ ، فَلَهُ أَنْ لَا يُشَارِكُهُ ، فَلَوْ سَلَّمَ لَهُ مَا قَبِضَ ، ثُمَّ تَوَى⁽⁴⁰¹⁾ مَا عَلَى الْغَرِيمِ لَهُ أَنْ يُشَارِكَ الْقَابِضَ ، لِأَنَّهُ رَضِيَ بِالتَّسْلِيمِ لِيُسَلَّمَ لَهُ مَا فِي ذِمَّةِ الْغَرِيمِ ، وَلَمْ يُسَلِّمْ ، وَلَوْ وَقَعَتِ الْمُقَاصَّةُ⁽⁴⁰²⁾ بِدَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ ، لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ الشَّرِيكُ⁽⁴⁰³⁾ ، لِأَنَّهُ قَاضٍ بِنَصِيبِهِ لَا مُقْتَضٍ ، وَلَوْ أَبْرَاهُ عَنْ نَصِيبِهِ ، فَكَذَلِكَ لِأَنَّهُ إِنْ تَلَفَ وَلَيْسَ بِقَبْضٍ ، وَلَوْ أَبْرَاهُ عَنْ الْبَعْضِ كَانَتْ قِسْمَةُ الْبَاقِي عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ السَّهَامِ ، وَلَوْ آخَرَ أَحَدُهُمَا عَنْ نَصِيبِهِ صَحَّ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ، اعْتِبَارًا بِالْإِبْرَاءِ الْمُطْلَقِ ، وَلَا يَصِحُّ عِنْدَهُمَا ، لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى قِسْمَةِ الدَّيْنِ قَبْلَ الْقَبْضِ ، وَلَوْ غَصَبَ أَحَدُهُمَا عَيْنًا مِنْهُ أَوْ اشْتَرَاهَا شِرَاءً فَاسِدًا وَهَلَكَ فِي يَدِهِ فَهُوَ قَبْضٌ ، وَالِاسْتِجَارُ بِنَصِيبِهِ قَبْضٌ ، وَكَذَا الْإِحْرَاقُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ⁽⁴⁰⁴⁾ -

⁴⁰⁰ () المماكسة : من المكس في البيع ، وهو استتقااص الثمن من باب ضرب . البناية 5 / 171 ، المغرب في ترتيب المغرب ص 431 ، 432 .

⁴⁰¹ () "التوى : الهلاك ، مقصور يكتب بالياء ، لأنهم يقولون : توى ما له يتوى توى ، إذا هلك " . المقصور والممدود ، لابن ولاد أبو العباس أحمد بن محمد بن الوليد التميمي المصري (المتوفى : 332 هـ) 22/1 .

⁴⁰² () أصل المقاصة : المماثلة ، من قولهم : قص الخبر : إذا حكاها ، فأداه على مثل ما سمع ، والقصاص في الجراح : أن يستوفى مثل جرحه ، وكذلك سميت المقاصة في الدين ؛ لأن على كل واحد منهما لصاحبه مثل ما للآخر . النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهدب ، لابن بطال 114/2 .

⁴⁰³ () وَإِذَا تَزَوَّجَ بِنَصِيبِهِ مِنَ الدَّيْنِ لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ الشَّرِيكُ فِي ظَاهِرِ الرَّوَايَةِ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَقْبِضْ مِنْ حِصَّتِهِ شَيْئًا مَضْمُونًا يَقْبَلُ الشَّرَكَةُ ، فَإِنَّهُ يَمْلِكُ بِهِ الْبُضْعَ ، وَإِنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ مُتَقَوِّمٍ وَلَا مَضْمُونٍ عَلَى أَحَدٍ ، فَكَانَ كَالْجَنَائَةِ ، وَرَوَى بَشْرٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يَرْجِعُ ، لِأَنَّ التَّزَوُّجَ وَإِنْ كَانَ بِالنَّصِيبِ لَفْظًا ، فَهُوَ بِمِثْلِهِ مَعْنًى ، فَيَكُونُ دَيْنُ الْمَهْرِ الْوَاجِبُ لِلْمَرْأَةِ آخِرَ الدَّيْنَيْنِ ، فَيَصِيرُ قَضَاءً لِلأَوَّلِ فَيَنْحَقُّ الْقَضَاءُ وَالِافْتِضَاءُ ، وَالصُّلْحُ عَلَى نَصِيبِهِ بِجَنَائَةِ الْعَمْدِ إِنْ تَلَفَ كَالْتَّزَوُّجِ بِهِ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَقْبِضْ شَيْئًا قَابِلًا لِلشَّرَكَةِ بَلْ أْتَلَفَ نَصِيبَهُ . العناية 437/8 .

⁴⁰⁴ () وَصُورَةُ الْإِحْرَاقِ : مَا إِذَا رَمَى النَّارَ عَلَى ثَوْبِ الْمَذْيُونِ فَأَحْرَقَهُ وَهُوَ يُسَاوِي نَصِيبَ الْمُحْرَقِ ، وَأَمَّا إِذَا أَخَذَ الثَّوْبَ ثُمَّ أَحْرَقَهُ فَإِنَّ لِلشَّرِيكِ السَّاكِتِ أَنْ يَتَّبَعَ الْمُحْرَقَ بِالْإِجْمَاعِ ، لِمُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّ الْإِحْرَاقَ إِنْ تَلَفَ لِمَالٍ مَضْمُونٍ فَكَانَ كَالْغَصَبِ ، وَالْمَذْيُونُ صَارَ قَاضِيًا لِنَصِيبِهِ بِطَرِيقِ الْمُقَاصَّةِ ، فَيُجْعَلُ الْمُحْرَقُ مُقْتَضِيًا ، وَلِأَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّ مُتْلَفَ نَصِيبِهِ بِمَا صَنَعَ لَا قَابِضٌ ، لِأَنَّ الْإِحْرَاقَ إِنْ تَلَفَ فَكَانَ هَذَا نَظِيرَ الْجَنَائَةِ ، فَإِنَّهُ لَوْ جَنَى عَلَى نَفْسِ الْمَذْيُونِ حَتَّى سَقَطَ نَصِيبُهُ مِنَ الدَّيْنِ لَمْ يَكُنْ لِلْآخِرِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ ، فَكَذَا إِذَا جَنَى بِالْإِحْرَاقِ . العناية 437/8 .

رَحِمَهُ اللَّهُ - وَالتَّزْوُجُ بِهِ إِتْلَافٌ فِي ظَاهِرِ الرَّوَايَةِ⁽⁴⁰⁵⁾ ، وَكَذَا الصُّلْحُ عَلَيْهِ مِنْ جِنَايَةِ الْعَمْدِ
(.)⁽⁴⁰⁶⁾

صلح أحد الشريكين في السلم على رأس المال : قَالَ (وَإِذَا كَانَ السَّلْمُ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ ، فَصَالَحَ أَحَدُهُمَا مِنْ نَصِيبِهِ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ ، لَمْ يَجُزْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يَجُوزُ الصُّلْحُ) ، اِعْتِبَارًا بِسَائِرِ الدُّيُونِ ، وَبِمَا إِذَا اشْتَرِيَا عَبْدًا فَأَقَالَ أَحَدُهُمَا فِي نَصِيبِهِ. وَلَهُمَا أَنَّهُ لَوْ جَازَ فِي نَصِيبِهِ خَاصَّةً يَكُونُ قِسْمَةُ الدَّيْنِ فِي الدِّمَّةِ ، وَلَوْ جَازَ فِي نَصِيبِهِمَا لَا بُدَّ مِنْ إِجَازَةِ الْآخِرِ بِخِلَافِ شِرَاءِ الْعَيْنِ ، وَهَذَا لِأَنَّ الْمُسْلِمَ فِيهِ صَارَ وَاجِبًا بِالْعَقْدِ ، وَالْعَقْدُ قَامَ بِهِمَا فَلَا يَنْفَرِدُ أَحَدُهُمَا بِرَفْعِهِ ، وَلِأَنَّهُ لَوْ جَازَ لَشَارَكَهُ فِي الْمَقْبُوضِ ، فَإِذَا شَارَكَهُ فِيهِ رَجَعَ الْمُصَالِحُ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ بِذَلِكَ فَيُؤَدِّي إِلَى عَوْدِ السَّلْمِ بَعْدَ سُقُوطِهِ. قَالُوا: هَذَا إِذَا خَلَطَا رَأْسَ الْمَالِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُونَا قَدْ خَلَطَاهُ فَعَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ هُوَ عَلَى الْخِلَافِ ، وَعَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي هُوَ عَلَى الْإِتِّفَاقِ⁽⁴⁰⁷⁾).

⁽⁴⁰⁵⁾ () ظاهر الرواية : وَهِيَ مَسَائِلُ مَرْوِيَّةٌ عَنْ أَصْحَابِ الْمَذْهَبِ ، وَهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ ، وَيَلْحَقُ بِهِمْ زُفَرٌ ، وَالْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ وَغَيْرُهُمَا مِمَّنْ أَخَذَ عَنِ الْإِمَامِ ، لَكِنَّ الْغَالِبَ الشَّائِعُ فِي ظَاهِرِ الرَّوَايَةِ أَنْ يَكُونَ قَوْلُ الثَّلَاثَةِ ، وَكُنْتُ ظَاهِرِ الرَّوَايَةِ ، كُنْتُ مُحَمَّدَ السَّنَّةِ: الْمُبْسُوطُ وَالزِّيَادَاتُ وَالْجَامِعُ الصَّغِيرُ وَالسَّيَرُ الصَّغِيرُ وَالْجَامِعُ الْكَبِيرُ ، وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ بِظَاهِرِ الرَّوَايَةِ؛ لِأَنَّهَا رُوِيَتْ عَنْ مُحَمَّدٍ بِرَوَايَاتِ الثَّقَاتِ ، فَهِيَ ثَابِتَةٌ عَنْهُ إِمَّا مُتَوَاتِرَةً أَوْ مَشْهُورَةً عَنْهُ.. رد المحتار 69/1 ، رسم المفتى ص 16.

⁽⁴⁰⁶⁾ () وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِقَوْلِهِ عَمْدًا لِأَنَّهُ فِي الْخَطَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ ، وَأُطْلِقَ فِي الْإِيضَاحِ فَقَالَ: وَلَوْ شَجَّهَ مُوضِحَةً فَصَالَحَهُ عَلَى حَصَّتِهِ لَمْ يَلْزَمْ الشَّرِيكَ شَيْءٌ لِأَنَّ الصُّلْحَ عَنِ الْمَوْضِحَةِ بِمَنْزِلَةِ النِّكَاحِ ، وَأَرَى أَنَّهُ قَيَّدَهُ بِذَلِكَ لِأَنَّ الْأَرْضَ قَدْ يَلْزَمُ الْعَاقِلَةَ فَلَمْ يَكُنْ مُفْتَضِيًّا لِشَيْءٍ. العناية 437/8.

⁽⁴⁰⁷⁾ () قوله (فعلى الوجه الأول) : أَرَادَ بِهِ النِّكْتَةُ الْأُولَى ، وَهِيَ لَزُومُ قِسْمَةِ الدَّيْنِ فِي الذِّمَّةِ (هُوَ عَلَى الْخِلَافِ) : الْمَذْكُورُ (وَعَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي) : أَرَادَ بِهِ النِّكْتَةُ الثَّانِيَّةُ (هُوَ) : قَوْلُهُ : "وَلِأَنَّهُ لَوْ جَازَ لَشَارَكَهُ ... إِلَى آخِرِهِ " (عَلَى الْإِتِّفَاقِ) : أَيِ صَحِّ صَلَاحِ أَحَدِهِمَا عَلَى الْإِتِّفَاقِ عَلَى رَأْسِ مَالِهِ ، لِأَنَّ رَأْسَ الْمَالِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَخْلُوطًا ، وَقَبْضُهُ صَاحِبُهُ لَمْ يَكُنْ لَشَرِيكَهِ أَنْ يَشَارَكَهُ فِيهِ ، لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِيهِ لِأَنَّهُ مَالُ الْغَيْرِ. البناية 37/10.

فصل في التخرج

تخرج أحد الورثة من تركة العقار أو العروض : (وَإِذَا كَانَتْ الشَّرِكَةُ بَيْنَ وَرَثَةٍ فَأَخْرَجُوا)⁴⁰⁸ أَحَدَهُمْ مِنْهَا بِمَالٍ أَعْطَوْهُ إِيَّاهُ ، وَالتَّرِكَةُ عَقَارٌ أَوْ عُرُوضٌ ، جَازَ قَلِيلًا كَانَ مَا أَعْطَوْهُ إِيَّاهُ أَوْ كَثِيرًا) ، لِأَنَّهُ أَمَكَّنَ تَصْحِيحَهُ بَيِّنًا ، وَفِيهِ أَثَرُ عُثْمَانَ ، فَإِنَّهُ صَالِحٌ تَمَاضَرَ الْأَشْجَعِيَّةَ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ رُبْعِ ثَمَانِيْنَ ، عَلَى ثَمَانِيْنَ أَلْفِ دِينَارٍ).⁴⁰⁹

تخرج أحد الورثة من تركة أثمان : قَالَ (وَإِنْ كَانَتْ التَّرِكَةُ فِضَّةً فَأَعْطَوْهُ ذَهَبًا ، أَوْ كَانَ ذَهَبًا فَأَعْطَوْهُ فِضَّةً ، فَهُوَ كَذَلِكَ) ، لِأَنَّهُ بَيَّنَّ الْجِنْسَ بِخِلَافِ الْجِنْسِ ، فَلَا يُعْتَبَرُ التَّسَاوِي ، وَيُعْتَبَرُ التَّقَابُضُ فِي الْمَجْلِسِ ، لِأَنَّهُ صَرَّفَ ، غَيْرَ أَنَّ الَّذِي فِي يَدِهِ بَقِيَّةُ التَّرِكَةِ إِنْ كَانَ جَاحِدًا ، يَكْتَفِي بِذَلِكَ الْقَبْضِ ، لِأَنَّهُ قَبْضُ ضَمَانٍ ، فَيُنُوبُ عَنْ قَبْضِ الصُّلْحِ ، وَإِنْ كَانَ مُقِرًّا لَا بُدَّ مِنْ تَجْدِيدِ الْقَبْضِ ، لِأَنَّهُ قَبْضُ أَمَانَةٍ ، فَلَا يَنْبُؤُ عَنْ قَبْضِ الصُّلْحِ ، (وَإِنْ كَانَتْ التَّرِكَةُ ذَهَبًا وَفِضَّةً وَغَيْرَ ذَلِكَ فَصَالِحُهُ عَلَى ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ ، فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَا أَعْطَوْهُ أَكْثَرَ مِنْ نَصِيبِهِ مِنْ ذَلِكَ الْجِنْسِ حَتَّى يَكُونَ نَصِيبُهُ بِمِثْلِهِ ، وَالزِّيَادَةُ بِحَقِّهِ مِنْ بَقِيَّةِ التَّرِكَةِ) اخْتِرَازًا عَنْ الرَّبَا ، وَلَا بُدَّ مِنَ التَّقَابُضِ فِيمَا يُقَابَلُ نَصِيبَهُ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، لِأَنَّهُ صَرَّفَ فِي هَذَا الْقَدْرِ ، وَلَوْ كَانَ بَدَلَ الصُّلْحِ عَرَضًا جَازَ مُطْلَقًا ، لِعَدَمِ الرَّبَا ، وَلَوْ كَانَ فِي التَّرِكَةِ دَرَاهِمُ وَدَنَانِيرُ ، وَبَدَلَ الصُّلْحِ دَرَاهِمُ وَدَنَانِيرُ أَيْضًا ، جَازَ الصُّلْحُ كَيْفَمَا كَانَ صَرَفًا لِلْجِنْسِ إِلَى خِلَافِ الْجِنْسِ ، كَمَا فِي الْبَيْعِ ، لَكِنْ يُشْتَرَطُ التَّقَابُضُ لِلصَّرْفِ).⁴¹⁰

الصلح على دين التركة بإخراج المصالح عنه على أن يكون الدين له : قَالَ (وَإِذَا كَانَ فِي التَّرِكَةِ دَيْنٌ عَلَى النَّاسِ ، فَأَدْخَلُوهُ فِي الصُّلْحِ عَلَى أَنْ يُخْرِجُوا الْمُصَالِحَ عَنْهُ وَيَكُونَ الدَّيْنُ لَهُ ، فَالْصُّلْحُ بَاطِلٌ) ، لِأَنَّ فِيهِ تَمْلِيكَ الدَّيْنِ مِنْ غَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ وَهُوَ حِصَّةُ الْمُصَالِحِ .

الصلح عن دين التركة بشرط براءة الغرماء : (وَإِنْ شَرَطُوا أَنْ يَبْرَأَ الْغَرَمَاءُ مِنْهُ ، وَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهِمْ بِنَصِيبِ الْمُصَالِحِ ، فَالْصُّلْحُ جَائِزٌ) ، لِأَنَّهُ إِسْقَاطٌ ، وَهُوَ تَمْلِيكَ الدَّيْنِ مِمَّنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ ، وَهُوَ جَائِزٌ ، وَهَذِهِ حِيلَةُ الْجَوَازِ ، وَأُخْرَى : أَنْ يُعْجَلُوا قَضَاءُ نَصِيبِهِ مُتَبَرِّعِينَ ، وَفِي الْوَجْهَيْنِ

⁴⁰⁸ () التَّخَارُجُ تَفَاعُلٌ مِنَ الْخُرُوجِ ، وَهُوَ أَنْ يَصْطَلِحَ الْوَرَثَةُ عَلَى إِخْرَاجِ بَعْضِهِمْ مِنَ الْمِيرَاثِ بِمَالٍ مَعْلُومٍ ، وَوَجْهٌ تَأْخِيرُهُ : قَلَّةُ وَقُوعِهِ ، فَإِنَّهُ قَلَّمَا يَرْضَى أَحَدٌ بِأَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْبَيْنِ بِغَيْرِ اسْتِيفَاءِ حَقِّهِ ، وَسَبَبُهُ : طَلَبُ الْخَارِجِ مِنَ الْوَرَثَةِ ذَلِكَ عِنْدَ رِضَا غَيْرِهِ بِهِ . العناية شرح الهداية 439/8.

⁴⁰⁹ () أخرجه البيهقي بسنده عن معاوية بن عبد الله بن جعفر ، عن السائب بن يزيد ابن أخت نمر ، وقال : وهذا إسناد موصول . معرفة السنن رقم 14843 ، 44.

⁴¹⁰ () أي : لأجل كونه صرفاً . البناية 39/10.

ضَرَرُ بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ⁽⁴¹¹⁾، وَالْأَوْجُهُ : أَنْ يُقْرِضُوا الْمُصَالِحَ مِقْدَارَ نَصِيبِهِ ، وَيُصَالِحُوا عَمَّا وَرَاءَ الدَّيْنِ.

وَيُجْبِلُهُمْ عَلَى اسْتِيفَاءِ نَصِيبِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي التَّرَكَةِ دَيْنٌ وَأَعْيَانُهَا غَيْرُ مَعْلُومَةٍ وَالصُّلْحُ عَلَى الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ، قِيلَ لَا يَجُوزُ لِاحْتِمَالِ الرَّبَا، وَقِيلَ : يَجُوزُ لِأَنَّهُ شُبْهَةٌ الشُّبْهَةِ، وَلَوْ كَانَتْ التَّرَكَةُ غَيْرَ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ لَكِنَّهَا أَعْيَانٌ غَيْرُ مَعْلُومَةٍ ، قِيلَ : لَا يَجُوزُ ، لِكَوْنِهِ بَيْعًا ، إِذَا الْمُصَالِحُ عَنْهُ عَيْنٌ ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَجُوزُ، لِأَنَّهَا لَا تُفْضِي إِلَى الْمُنَازَعَةِ ، لِقِيَامِ الْمُصَالِحِ عَنْهُ فِي يَدِ الْبَقِيَّةِ مِنَ الْوَرَثَةِ، وَإِنْ كَانَ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ مُسْتَعْرِقٌ لَا يَجُوزُ الصُّلْحُ وَلَا الْقِسْمَةُ ، لِأَنَّ التَّرَكَةَ لَمْ يَتَمَلَّكْهَا الْوَارِثُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَعْرِقًا لَا يَنْبَغِي أَنْ يُصَالِحُوا مَا لَمْ يَقْضُوا دَيْنَهُ فَتَقَدَّمَ حَاجَةُ الْمَيِّتِ، وَلَوْ فَعَلُوا قَالُوا يَجُوزُ. وَذَكَرَ الْكَرْخِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي الْقِسْمَةِ أَنَّهَا لَا تَجُوزُ اسْتِحْسَانًا وَتَجُوزُ قِيَاسًا⁽⁴¹²⁾.

⁴¹¹ () أَمَّا فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ: فَلَا بَقِيَّةَ الْوَرَثَةِ لَا يُمْكِنُهُمُ الرُّجُوعُ عَلَى الْغُرَمَاءِ، وَفِي الْوَجْهِ الثَّانِي : لُزُومُ النَّقْدِ عَلَيْهِمْ بِمُقَابَلَةِ الدَّيْنِ الَّذِي هُوَ نَسِيبُهُ ، وَالنَّقْدُ خَيْرٌ مِنَ النَّسِيبَةِ . العناية 422/8 .
⁴¹² () وَجْهُ الاسْتِحْسَانِ : أَنَّ الدَّيْنَ يَمْنَعُ تَمَلُّكَ الْوَرَاثِ، إِذَا مَا مِنْ جُزْءٍ إِلَّا وَهُوَ مُشْغُولٌ بِالدَّيْنِ، فَلَا تَجُوزُ الْقِسْمَةُ قَبْلَ قَضَائِهِ، وَجْهُ الْقِيَاسِ : أَنَّ التَّرَكَةَ لَا تَخْلُو عَنْ قَلِيلِ الدَّيْنِ ، فَتُقَسَّمُ نَفْيًا لِلضَّرَرِ عَنِ الْوَرَثَةِ . العناية 444/8.

كِتَابُ الدَّعْوَى

تعريف المدعى ، والمدعى عليه⁽⁴¹³⁾ : قَالَ (الْمُدَّعِي مَنْ لَا يُجْبَرُ عَلَى الْخُصُومَةِ إِذَا تَرَكَهَا ، وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَنْ يُجْبَرُ عَلَى الْخُصُومَةِ)⁽⁴¹⁴⁾ .

الفرق بين المدعى والمدعى عليه : " وَمَعْرِفَةُ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا مِنْ أَهَمِّ مَا يُبْتَنَى عَلَيْهِ مَسَائِلُ الدَّعْوَى ، وَقَدْ اخْتَلَفَتْ عِبَارَاتُ الْمَشَايخ ⁽⁴¹⁵⁾ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - فِيهِ ، فَمِنْهَا مَا قَالَ فِي الْكِتَابِ⁽⁴¹⁶⁾) وَهُوَ حَدُّ عَامٍّ صَحِيحٌ ، وَقِيلَ الْمُدَّعِي : مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ إِلَّا بِحُجَّةٍ كَالْخَارِجِ ، وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ : مَنْ يَكُونُ مُسْتَحَقًّا بِقَوْلِهِ مِنْ غَيْرِ حُجَّةٍ كَذِي الْيَدِ ، وَقِيلَ الْمُدَّعَى مَنْ يَتَمَسَّكُ بِغَيْرِ الظَّاهِرِ وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَنْ يَتَمَسَّكُ بِالظَّاهِرِ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي الْأَصْلِ⁽⁴¹⁷⁾ : الْمُدَّعَى عَلَيْهِ هُوَ الْمُنْكَرُ ، وَهَذَا صَحِيحٌ لَكِنَّ الشَّانَ فِي مَعْرِفَتِهِ ، وَالتَّرْجِيحُ بِالْفَقْهِ عِنْدَ الْحُذَّاقِ مِنْ أَصْحَابِنَا - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - لِأَنَّ الْإِعْتِبَارَ لِلْمَعَانِي دُونَ الصُّوَرِ ، فَإِنَّ الْمُودِعَ : إِذَا قَالَ رَدَدْتُ الْوَدِيعَةَ ، فَالْقَوْلُ لَهُ مَعَ الْيَمِينِ وَإِنْ كَانَ مُدَّعِيًا لِلرَّدِّ صُورَةً ، لِأَنَّهُ يُنْكَرُ الضَّمَانَ مَعْنَى.

شروط قبول الدعوى : قَالَ : (وَلَا تُقْبَلُ الدَّعْوَى حَتَّى يَذْكَرَ شَيْئًا مَعْلُومًا فِي جَنْبِهِ وَقَدْرِهِ) ، لِأَنَّ فَائِدَةَ الدَّعْوَى الْإِلْزَامُ بِوَاسِطَةِ إِقَامَةِ الْحُجَّةِ ، وَالْإِلْزَامُ فِي الْمَجْهُولِ لَا يَتَحَقَّقُ⁽⁴¹⁸⁾ .

(فَإِنْ كَانَ عَيْنًا فِي يَدِ الْمُدَّعَى) عَلَيْهِ ، كُلَّفَ إِحْضَارَهَا لِيشِيرَ إِلَيْهَا بِالدَّعْوَى ، وَكَذَا فِي الشَّهَادَةِ وَالِاسْتِخْلَافِ ، لِأَنَّ الْإِعْلَامَ بِأَفْصَى مَا يُمَكِّنُ شَرْطٌ ، وَذَلِكَ بِالْإِشَارَةِ فِي الْمُنْقُولِ ، لِأَنَّ النُّقْلَ مُمَكِّنٌ ، وَالْإِشَارَةُ أُنْبِغُ فِي التَّعْرِيفِ ، وَيَتَعَلَّقُ بِالدَّعْوَى وَجُوبُ الْحُضُورِ ، وَعَلَى هَذَا

⁽⁴¹³⁾ (كافة العناوين الجانبية المظلمة في كتاب الدعوى من وضع المحقق.

⁽⁴¹⁴⁾ (الدعوى مشتقة من الدعاء وهو الطلب ، وفي الشرع: قول يطلب به الإنسان إثبات حق على الغير لنفسه . الاختيار لتعليل المختار 109/2 ، مختار الصحاح ص205 ، المغرب في ترتيب المغرب ص164.

⁽⁴¹⁵⁾ (المشايخ : يطلق على من لم يدرك الإمام أبا حنيفة من علماء مذهبه . مقدمة عمدة الرعاية ، للكنوى ص15.

⁽⁴¹⁶⁾ (وهو مختصر القدوري . البناية 314/9.

⁽⁴¹⁷⁾ (الأصل ويسمى المبسوط ، صنفه الإمام محمد بن الحسن الشيباني ، أحد كتب ظاهر الرواية ، وسمى بالأصل ، لأنه صنفه قبل سائر كتبه المعروفة . عقود رسم المفتى ، لابن عابدين ص56.

⁽⁴¹⁸⁾ (يستثنى من فساد الدعوى بالمجهول دعوى الرهن والغصب لما في الخائنية معزيا إلى رهن الأصل : إذا شهدوا أنه رهن عنده ثوبا ولم يسموا الثوب، ولم يعرفوا عينه ، جازت شهادتهم ، والقول للمرتهن في أي ثوب كان ، وكذلك في الغصب ، فالدعوى بالأولى. البحر الرائق 195/7.

الْقَضَاءُ مِنْ آخِرِهِمْ فِي كُلِّ عَصْرِ، وَوُجُوبُ الْجَوَابِ إِذَا حَضَرَ لِإِفْيِدِ حُضُورُهُ ، وَلَزُومُ إِحْضَارِ الْعَيْنِ الْمُدَّعَاةِ لِمَا قُلْنَا وَالْيَمِينِ إِذَا أَنْكَرَهُ⁽⁴¹⁹⁾، وَسَنَذْكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

قَالَ : (وَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَاضِرَةً ذَكَرَ قِيمَتَهَا لِيَصِيرَ الْمُدَّعَى مَعْلُومًا) ، لِأَنَّ الْعَيْنَ لَا تُعْرَفُ بِالْوَصْفِ، وَالْقِيَمَةُ تُعْرَفُ بِهِ ، وَقَدْ تَعَذَّرَ مُشَاهَدَةُ الْعَيْنِ⁽⁴²⁰⁾.

وَقَالَ الْفَقِيه أَبُو اللَّيْثِ⁽⁴²¹⁾: يُشْتَرَطُ مَعَ بَيَانِ الْقِيَمَةِ ذِكْرُ الذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ.

شروط المدعى به : "قَالَ (وَإِنْ ادَّعَى عَقَارًا حَدَّدَهُ وَذَكَرَ أَنَّهُ فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَأَنَّهُ يُطَالِبُهُ بِهِ) لِأَنَّهُ تَعَذَّرَ التَّعْرِيفُ بِالْإِشَارَةِ لِتَعَذُّرِ النَّفْلِ فَيُصَارُ إِلَى التَّجْدِيدِ فَإِنَّ الْعَقَارَ يُعْرَفُ بِهِ، وَيَذَكَّرُ الْحُدُودَ الْأَرْبَعَةَ، وَيَذَكَّرُ أَسْمَاءَ أَصْحَابِ الْحُدُودِ وَأَنْسَابَهُمْ، وَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ الْجَدِّ ، لِأَنَّ تِمَامَ التَّعْرِيفِ بِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَى مَا عُرِفَ هُوَ الصَّحِيحُ، وَلَوْ كَانَ الرَّجُلُ مَشْهُورًا يَكْتَفِي بِذِكْرِهِ، فَإِنْ ذَكَرَ ثَلَاثَةً مِنَ الْحُدُودِ يَكْتَفَى بِهَا عِنْدَنَا ، خِلَافًا لِزُفَرٍ لَوْجُودِ الْأَكْثَرِ⁽⁴²²⁾، بِخِلَافِ مَا إِذَا غَلِطَ فِي الرَّابِعَةِ ، لِأَنَّهُ يُخْتَلَفُ بِهِ الْمُدَّعَى وَلَا كَذَلِكَ بِتَرْكِهَا، وَكَمَا يُشْتَرَطُ التَّحْدِيدُ فِي الدَّعْوَى يُشْتَرَطُ فِي الشَّهَادَةِ.

وَقَوْلُهُ فِي الْكِتَابِ⁽⁴²³⁾ وَذَكَرَ أَنَّهُ فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَا بُدَّ مِنْهُ ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَنْتَصِبُ خَصَمًا إِذَا كَانَ فِي يَدِهِ، وَفِي الْعَقَارِ لَا يَكْتَفَى بِذِكْرِ الْمُدَّعَى وَتَصَدِيقِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ فِي يَدِهِ ، بَلْ لَا تَنْبُتُ الْيَدُ فِيهِ إِلَّا بِالْبَيِّنَةِ، أَوْ عِلْمِ الْقَاضِي ، هُوَ الصَّحِيحُ⁽⁴²⁴⁾ نَفْيًا لِتَهْمَةِ الْمُوَاضَعَةِ ، إِذْ الْعَقَارُ عَسَاهُ فِي يَدِ غَيْرِهِمَا، بِخِلَافِ الْمَنْقُولِ ، لِأَنَّ الْيَدَ فِيهِ مُشَاهَدَةٌ.

⁽⁴¹⁹⁾ البناية 316/9

⁽⁴²⁰⁾ لأنه إذا تعذر مشاهدة العين فالقيمة تقوم مقامها كما في الاستهلاك، إذ هي المقصود غالباً، ويذكر في القيمة شيئاً معيناً في قدره ووصفه وجنسه نفياً للجهالة لما بينا، وإن كان حيواناً يذكر الذكورة أو الأنوثة. الاختيار لتعليل المختار 110/2، البناية 317/9.

⁽⁴²¹⁾ أبو الليث : نصر بن محمد بن إبراهيم ، الإمام الفقيه الحنفي ، أبو الليث السمرقندي ، صاحب كتاب الفتاوى توفي سنة خمس وسبعين وثلاثمائة ، وقيل سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة هجرية. الفوائد البهية ، للكنوى ص 412، الوافي بالوفيات ، لصلاح الدين خليل بن أبيك بن عبد الله الصفدي (المتوفى: 764هـ) 54/27.

⁽⁴²²⁾ لأن إقامة الأكثر مقام الكل أصل في الشرع . البناية 318/9.

⁽⁴²³⁾ أي مختصر القدوري ، وهو أشهر المتون المعتمدة عند الحنفية . عقود رسم المفتى ص 45.

⁽⁴²⁴⁾ الصحيح : هو لفظ يستعمل للترجيح بين الأقوال . الكواشف الجلية عن مصطلحات الحنفية عبد الإله بن محمد الملا ص 203.

وَقَوْلُهُ : وَأَنَّهُ يُطَالِبُهُ بِهِ ، لِأَنَّ الْمُطَالِبَةَ حَقُّهُ فَلَا بُدَّ مِنْ طَلْبِهِ⁽⁴²⁵⁾ ، وَلِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَرْهُونًا فِي يَدِهِ أَوْ مَحْبُوسًا بِالنَّهْنِ فِي يَدِهِ، وَبِالْمُطَالِبَةِ يَزُولُ هَذَا الْإِحْتِمَالُ، وَعَنْ هَذَا قَالُوا فِي الْمَنْثُولِ : يَجِبُ أَنْ يَقُولَ : فِي يَدِهِ بِغَيْرِ حَقٍّ .

قَالَ⁽⁴²⁶⁾ (وَإِنْ كَانَ حَقًّا فِي الذِّمَّةِ ذَكَرَ أَنَّهُ يُطَالِبُهُ بِهِ) لِمَا قُلْنَا⁽⁴²⁷⁾، وَهَذَا لِأَنَّ صَاحِبَ الذِّمَّةِ قَدْ حَضَرَ ، فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الْمُطَالِبَةُ ، لَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ تَعْرِيفِهِ بِالْوَصْفِ لِأَنَّهُ يُعْرِفُ بِهِ .

سؤال المدعى عليه عن الشيء المدعى به وإقراره بذلك : قَالَ (وَإِذَا صَحَّتِ الدَّعْوَى سَأَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْهَا)، لِيَنْكَشِفَ لَهُ وَجْهُ الْحُكْمِ ، (فَإِنْ اعْتَرَفَ قُضِيَ عَلَيْهِ بِهَا)، لِأَنَّ الْإِقْرَارَ مُوجِبٌ بِنَفْسِهِ ، فَيَأْمُرُهُ بِالْخُرُوجِ عَنْهُ .

مطالبة المدعى بالبينة عند إنكار المدعى عليه : (وَإِنْ أَنْكَرَ سَأَلَ الْمُدَّعِيَ الْبَيِّنَةَ) لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - " أَلَيْكَ بَيِّنَةٌ؟ فَقَالَ لَا، فَقَالَ: "لَكَ يَمِينُهُ"⁽⁴²⁸⁾ " سَأَلَ وَرَتَّبَ الْيَمِينَ عَلَى فَقْدِ الْبَيِّنَةِ ، فَلَا بُدَّ مِنَ السُّؤَالِ لِيُمْكِنَهُ الْإِسْتِحْلَافُ⁽⁴²⁹⁾ .

. قَالَ (فَإِنْ أَحْضَرَهَا قُضِيَ بِهَا)، لِإِنْتِفَاءِ التُّهْمَةِ عَنْهَا ، (وَإِنْ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ وَطَلَبَ يَمِينَ خَصْمِهِ) اسْتَحْلَفَهُ (عَلَيْهَا) ، لِمَا رَوَيْنَا، وَلَا بُدَّ مِنْ طَلْبِهِ ، لِأَنَّ الْيَمِينَ حَقُّهُ؛ أَلَا يَرَى أَنَّهُ كَيْفَ أَضِيفَ إِلَيْهِ بِحَرْفِ اللَّامِ فَلَا بُدَّ مِنْ طَلْبِهِ⁽⁴³⁰⁾ .

⁽⁴²⁵⁾ أي : لأن المطالبة حق المدعي ، فلا بد من طلبه حتى تجب على القاضي إعانتة البناية 319/9.

⁽⁴²⁶⁾ (القدوري في مختصره . البناية 319/9).

⁽⁴²⁷⁾ (إشارة إلى قوله: إن المطالبة حقه فلا بد من طلبه . البناية 320/9).

⁽⁴²⁸⁾ (الإيمان لابن منده، لأبي عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده العبدى (المتوفى: 395هـ) عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَاثِلِ بْنِ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ رَقْم 580.

⁽⁴²⁹⁾ أي: فيمكن القاضي طلب اليمين من المدعى عليه . البناية 321/9.

⁽⁴³⁰⁾ قوله . " لِمَا رَوَيْنَا " ، يُرِيدُ بِهِ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " لَكَ يَمِينُهُ " ، وَلَا بُدَّ مِنْ طَلْبِهِ الْإِسْتِحْلَافَ ، لِأَنَّ الْيَمِينَ حَقُّهُ؛ أَلَا يَرَى أَنَّهُ كَيْفَ أَضِيفَ إِلَيْهِ بِحَرْفِ اللَّامِ فِي قَوْلِهِ " لَكَ يَمِينُهُ " . قِيلَ : إِنَّمَا جَعَلَ يَمِينَ الْمُنْكَرِ حَقَّ الْمُدَّعِي ، لِأَنَّهُ يَزْعُمُ أَنَّ خَصْمَهُ أَتَوَى - أَهْلَكَ - حَقُّهُ بِإِنْكَارِهِ، فَالْتَّسَرُّعُ جَعَلَ لَهُ حَقَّ اسْتِحْلَافِهِ، حَتَّى إِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَمَا زَعَمَ فَالْيَمِينَ الْعُمُوسُ مُهْلِكَةٌ لِخَصْمِهِ ، فَيَكُونُ إِنْوَاءٌ بِمُقَابَلَةِ إِنْوَاءٍ ، وَهُوَ مَشْرُوعٌ كَالْقَصَاصِ، وَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ بِخِلَافِ مَا زَعَمَ ، فَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَبَالُ الثَّوَابَ بِذِكْرِ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى صَادِقًا، ثُمَّ إِنَّمَا رَتَّبَ الْيَمِينَ عَلَى الْبَيِّنَةِ لَا عَلَى الْعَكْسِ ، لِأَنَّ نَفْسَ الدَّعْوَى لَيْسَتْ بِمُوجِبَةٍ اسْتِحْقَاقِ الْمُدَّعِي لِمَا ادَّعَاهُ، لِأَنَّ فِيهِ إِسَاءَةَ الظَّنِّ بِالْآخِرِ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ، فَوَجِبَ إِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْمُدَّعِي لِإِثْبَاتِ اسْتِحْقَاقِهِ بِهَا فَيُطَالِبُهُ الْقَاضِي بِذَلِكَ لَا عَلَى وَجْهِ الْإِلْزَامِ عَلَيْهِ، بَلْ عَلَى وَجْهِ التَّذْكِيرِ لَهُ، فَلَوْ قَدَّمْنَا الْيَمِينَ لَمْ يَكُنْ فِيهِ نَظَرٌ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ، إِذْ إِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ مَشْرُوعَةٌ بَعْدَ الْيَمِينَ، فَمِنْ الْجَائِزِ إِقَامَتُهَا بَعْدَهَا، وَفِي ذَلِكَ افْتِصَاحُهُ بِالْيَمِينَ الْكَاذِبَةِ ، وَبِهَذَا أَخَذَتْ مَجْلَةُ الْأَحْكَامِ الْعَدْلِيَّةِ نَصْتَ الْمَادَّةِ 1742 عَلَى أَنَّهُ "أحد أسباب الحكم اليمين أو النكول عن اليمين ، وهو أنه إذا أظهر المدعى عجزه عن إثبات دعواه يحلف المدعى عليه بطلبه" وطبقا

(بَابُ الْيَمِينِ)

طلب اليمين من المدعى عليه مع وجود البينة : " (وَإِذَا قَالَ الْمُدَّعِي لِي بَيِّنَةٌ حَاضِرَةٌ وَطَلَبَ الْيَمِينَ) ⁽⁴³¹⁾ (لَمْ يُسْتَحْلَفْ) عِنْدَ أَبِي - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، مَعْنَاهُ : حَاضِرَةٌ فِي الْمَصْرِ ⁽⁴³²⁾ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : يُسْتَحْلَفُ ، لِأَنَّ الْيَمِينَ حَقُّهُ بِالْحَدِيثِ الْمَعْرُوفِ ، فَإِذَا طَالَبَهُ بِهِ يُجِيبُهُ ، وَلِأَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : أَنَّ ثُبُوتَ الْحَقِّ فِي الْعَيْنِ مُرْتَبِّ عَلَى الْعَجْزِ عَنْ إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ ، لِمَا رَوَيْنَا ، فَلَا يَكُونُ حَقُّهُ دُونَهُ ، كَمَا إِذَا كَانَتْ الْبَيِّنَةُ حَاضِرَةً فِي الْمَجْلِسِ ، وَمُحَمَّدٌ مَعَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ فِيمَا ذَكَرَهُ الْخَصَّافُ ⁽⁴³³⁾ ، وَمَعَ أَبِي حَنِيفَةَ فِيمَا ذَكَرَهُ الطَّحَاوِيُّ .

رد اليمين على المدعى : قَالَ (وَلَا تُرَدُّ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي) لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - "الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ" ⁽⁴³⁴⁾ " قَسَمَ ، وَالْقِسْمَةُ تُنَافِي الشَّرِكَةَ ، وَجَعَلَ جِنْسَ الْإِيمَانِ عَلَى الْمُنْكَرِينَ ، وَلَيْسَ وَرَاءَ الْجِنْسِ شَيْءٌ " ⁽⁴³⁵⁾ ، وَفِيهِ خِلَافُ الشَّافِعِيِّ ⁽⁴³⁶⁾ - رَحِمَهُ اللَّهُ -

للقانون المدني المصري اليمين نوعان : حاسمة ، وهي التي يوجهها الخصم إلى خصمه حسما للنزاع إذا ما أعوزه دليل الإثبات ، واليمين المتممة ، وهي اليمين التي يوجهها القاضي من تلقاء نفسه إلى أى من الخصمين ، ليستكمل بها اقتناعه . العناية شرح الهداية 169/8 ، وفي هذا: قواعد الإثبات ، توفيق حسن فرج ص 174 ، 176 ، 181 ، 182 .

⁽⁴³¹⁾ (اليمين لغة: اليد اليمنى ، أو هو خلاف اليسار ، وإنما سمي القسم يمينا ، لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل واحد منهم يمينه على يمين صاحبه ، وقيل اليمين لغة : القوة والقدرة ، وفي الشرع : عبارة عن تقوية الخبر بذكر الله تعالى ، أو بصفة من صفاته على وجه مخصوص ، أو تعليق الجزاء على الشرط على وجه ينزل الجزاء عند وجود الشرط " ، قال العيني : "قال الأتراسي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : ما كان يحتاج هنا إلى الفصل بالباب ، بل كان ينبغي أن يسوق الكلام متواليا ، لأنه لما ذكر صحة الدعوى ترتب عليها الحكم بالإقرار والبينة واليمين ، قلت - بدر الدين العيني-: الذي رتبته المصنف هو الأصل ، لأنه لما كانت اليمين مشروعة بعد فقد البينة تعين ذكرها بعدها بأحكامها وشرائطها " . المغرب في ترتيب المعرب ، لأبى الفتح المطرزي ص 512 ، كشف اصطلاحات الفنون ، للتهانوي 418 / 3 ، البناية 323/ 9 .

⁽⁴³²⁾ (احترز به عن البينة الحاضرة في مجلس الحكم ، فحينئذ لا يجوز الحكم باليمين بالإجماع ، وإن طلب الخصم ، واحترز به أيضا عما إذا كانت البينة غائبة عن المصر ، فحينئذ يستحلف بالاتفاق . البناية 323/9 .

⁽⁴³³⁾ (الخصاف : لقب أحمد بن عمرو الشيباني الإمام أبو بكر مؤلف الشروط ت 261 هـ . الجواهر المضية في طبقات الحنفية 400/1 ، معجم المؤلفين 35/2 . ⁽⁴³⁴⁾ (السنن الصغرى ، للبيهقي ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، مرسلا ، رقم 3103 ، سنن الدار قطنى رقم 4508 .

⁽⁴³⁵⁾ (وبقول الحنفية ، قال بعض المالكية كاللخمي والمازري ، والظاهرية ، قال البابرتي : " وَلَا تُرَدُّ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَسَمَ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ فَجَعَلَ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي

التعارض بين بينة صاحب اليد وبينة الخارج في الملك المطلق : "قَالَ (وَلَا تُقْبَلُ بَيِّنَةُ صَاحِبِ الْيَدِ فِي الْمَلِكِ الْمُطْلَقِ)⁽⁴³⁷⁾، وَبَيِّنَةُ الْخَارِجِ أُولَى⁽⁴³⁸⁾)).

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُقْضَى بِبَيِّنَةِ ذِي الْيَدِ ، لِاعْتِصَادِهَا بِالْيَدِ ، فَيَتَقَوَّى الظُّهُورُ ، وَصَارَ كَالنَّتَاجِ وَالنِّكَاحِ ، وَدَعْوَى الْمَلِكِ مَعَ الْإِعْتِقَاقِ وَالِاسْتِيلَادِ وَالتَّنْذِيرِ⁽⁴³⁹⁾.

وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ، وَالْقِسْمَةُ تُنَافِي الشَّرَكَةَ ، لِأَنَّهَا تَقْتَضِي عَدَمَ التَّمْيِيزِ ، وَالْقِسْمَةُ تَقْتَضِيهِ الْعِنَايَةَ^{172/8}، وَفِي هَذَا : التَّاجُ وَالْإِكْلِيلُ^{236/8}، كَشَافُ الْقَنَاقِ^{567/6}، الْمَحَلَّى^{371،9}.

(⁴³⁶) حَيْثُ قَالَ : بَرَدُ الْيَمِينِ إِلَى الْمَدْعَى ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَكَافَّةِ أَصْحَابِهِ ، وَصَوْبُهُ أَحْمَدُ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿... أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدُّ أَيْمَانُهُمْ...﴾ سُورَةُ الْمَائِدَةِ: 108، وَالْآيَةُ وَاضِحَةٌ الدَّلَالَةِ

فِي رَدِّ الْيَمِينِ عَلَى الْمَدْعَى عِنْدَ عَجْزِ الْمَدْعَى عَلَيْهِ عَنِ إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ ، وَقَدْ رَدَّتِ الْيَمِينُ عَلَى عَمْرِ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) فَحَلَفَ وَاسْتَحَقَّ ، وَرَدَّتْ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) وَاسْتَحَقَّ، وَهَذَا مُسْتَفِيزٌ بَيْنَ الصَّحَابَةِ دُونَ نَكِيرٍ ، فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ إِجْمَاعٌ ، وَلَا حُجَّةَ فِيهِمَا تَمَسُّكُ بِهِ الْحَنْفِيَّةُ مِنْ حَدِيثِ : الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمَدْعَى .." ، لِأَنَّهُ يَفِيدُ تَوْجِيهَ الْيَمِينِ إِلَى الْمَدْعَى عَلَيْهِ عِنْدَ عَجْزِ الْمَدْعَى عَنِ إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ ، وَإِنَّمَا مَحَلُّ الْخِلَافِ فِي نَقْلِ الْيَمِينِ إِلَى الْمَدْعَى ، عِنْدَ نَكْوَلِ الْمَدْعَى عَلَيْهِ عَنِ الْيَمِينِ، فَالرَّاجِحُ مَا قَالَ بِهِ الشَّافِعِيُّ ، وَمِنْ مَعِهِ . التَّاجُ وَالْإِكْلِيلُ^{236/8}، الذَّخِيرَةُ^{46/11}، الْحَاوِي^{140/17}،

نَهَايَةُ الْمَحْتَاجِ^{357/8}، الطَّرُقُ الْحَكْمِيَّةُ ، لِابْنِ الْقَيْمِ ص¹²⁶.
(⁴³⁷) وَقَفَّيْدَ بِالْمَلِكِ الْمُطْلَقِ ، اخْتِرَازًا عَنِ الْمُقَيَّدِ بِدَعْوَى النَّتَاجِ، وَعَنْ الْمُقَيَّدِ بِمَا إِذَا ادَّعَى تَلَقَّى الْمَلِكُ مِنْ وَاحِدٍ وَأَحَدُهُمَا قَابِضٌ، وَبِمَا إِذَا ادَّعَى الشَّرَاءُ مِنْ اثْنَيْنِ ، وَتَارِيخُ أَحَدِهِمَا أَسْبَقُ ، فَإِنَّ فِي هَذِهِ الصُّورِ تُقْبَلُ بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ بِالْإِجْمَاعِ. الْعِنَايَةُ عَلَى الْهَدَايَةِ^{173/8}.

(⁴³⁸) وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ ، وَهُوَ الْمَفْتَى بِهِ ، وَقَوْلُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمَجْشُونِ ، وَرَوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ وَهُوَ الْمَشْهُورُ ، وَقَوْلُ الظَّاهِرِيَّةِ ، وَاسْتَدَلُّوا : بِحَدِيثِ : "الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمَدْعَى .." ، وَلِأَنَّ بَيِّنَةَ الْخَارِجِ بِهَا زِيَادَةُ عِلْمٍ ، فَتَقْدِمُ ، كَتَقْدِيمِ مَنْ مِنْ شَهِدَ لَهُ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ مِنْ أَبِيهِ عَلَى مَنْ شَهِدَ لَهُ أَنَّهُ وَرَثَهُ عَنْ أَبِيهِ، نَصَتْ الْمَادَّةُ¹⁷⁵⁷ مِنْ مَجْلَةِ الْأَحْكَامِ الْعَدْلِيَّةِ عَلَى أَنَّهُ : "بَيِّنَةُ الْخَارِجِ أُولَى فِي دَعْوَى الْمَلِكِ الْمُطْلَقِ الَّتِي لَمْ يُبَيَّنْ فِيهَا تَارِيخٌ. مَثَلًا: إِذَا ادَّعَى أَحَدُ الدَّارِ الَّتِي هِيَ فِي يَدِ آخَرَ قَائِلًا: إِنَّهَا مِلْكِي، وَأَنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَدْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا بِغَيْرِ حَقٍّ، وَأَنَا أَطْلُبُ أَنْ تُسَلَّمَ لِي وَقَالَ ذُو الْيَدِ: إِنَّ هَذِهِ الدَّارَ مِلْكِي وَإِذَا فَأَنَا وَاضِعُ الْيَدِ عَلَيْهَا بِحَقٍّ تُرَجِّحُ بَيِّنَةُ الْخَارِجِ وَتُسَمَّعُ. الْبَسُوطُ^{65 / 15}، مَنَحَةُ الْخَالِقِ عَلَى الْبَحْرِ الرَّائِقِ^{193/7}، الذَّخِيرَةُ^{193/10}، التَّوْضِيحُ ، لِابْنِ إِسْحَاقَ^{124/6}،¹³⁰، كَشَافُ الْقَنَاقِ^{496/6}، الْمَحَلَّى^{436/9}.

(⁴³⁹) وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ مِنَ الْحَنْفِيَّةِ ، وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ ، وَقَوْلُ الْأَصْحَابِ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ ، وَرَوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ ، وَبِهِ قَالَ شَرِيحُ وَالنَّخَعِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ، وَهُوَ الْمَحْكِيُّ عَنِ الشَّيْخِ أَبِي عَلِيٍّ ، وَاسْتَدَلُّوا : بِمَا رَوَاهُ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلَيْنِ تَدَاخِيَا بِدَابَّةٍ ، فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا دَابَّتُهُ ، فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) لِلَّذِي هِيَ فِي يَدَيْهِ" رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ ، وَلِأَنَّ كِلَا مِنْ الْخَارِجِ وَصَاحِبِ الْيَدِ تَسَاوَيَا فِي إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ وَانْفَرَدَ أَحَدُهُمَا بِالْيَدِ ، فَوَجِبَ أَنْ تَقْدَمَ بَيِّنَتُهُ مِنْ أَجْلِ الْيَدِ ، وَحَدِيثُ الْبَيِّنَةِ الَّذِي اسْتَدَلَّ بِهِ الْحَنْفِيَّةُ خَارِجٌ عَنْ مَحَلِّ النِّزَاعِ ، قَالَ : ابْنُ الْقَاسِمِ : "إِنْ هَذَا إِنَّمَا هُوَ إِذَا لَمْ يَأْتِ الْمَدْعَى عَلَيْهِ بِمِثْلِمَا أَتَى بِهِ الْمَدْعَى" ، فَالرَّاجِحُ مَا قَالَ بِهِ الشَّافِعِيَّةُ وَمِنْ مَعِهِمْ . التَّوْضِيحُ لِابْنِ إِسْحَاقَ^{124/6} وَفِي هَذَا الْمَبْسُوطُ^{64/17}،⁶⁵، الذَّخِيرَةُ

وَلَنَا : أَنَّ بَيِّنَةَ الْخَارِجِ أَكْثَرُ إِبْتِاتًا أَوْ إِظْهَارًا ، لِأَنَّ قَدْرَ مَا أَثْبَتَهُ الْيَدُ لَا يُثْبِتُهُ بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ ، إِذْ الْيَدُ دَلِيلٌ مُطْلَقُ الْمَلِكِ ، بِخِلَافِ النَّتَاجِ ، لِأَنَّ الْيَدَ لَا تَدُلُّ عَلَيْهِ ، وَكَذَا عَلَى الْإِعْتَاقِ وَأُخْتِيهِ ، وَعَلَى الْوَلَاءِ الثَّابِتِ بِهَا⁽⁴⁴⁰⁾.

القضاء بالنكول على المدعى عليه : "قَالَ (وَإِذَا نَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنِ الْيَمِينِ قُضِيَ عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ ، وَالزَّمَهُ مَا ادَّعَى عَلَيْهِ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا يُقْضَى بِهِ بَلَّ يَرُدُّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى ، فَإِذَا حَلَفَ يَقْضَى بِهِ ، لِأَنَّ النُّكُولَ يَحْتَمِلُ التَّوَرُّعَ عَنِ الْيَمِينِ الْكَاذِبَةِ ، وَالتَّرَفُّعَ عَنِ الصَّادِقَةِ ، وَاسْتِثْنَاءَ الْحَالِ ، فَلَا يَنْتَصِبُ حُجَّةٌ مَعَ الْإِحْتِمَالِ ، وَيَمِينُ الْمُدَّعَى دَلِيلُ الظُّهُورِ ، فَيَصَارُ إِلَيْهِ.

وَلَنَا : أَنَّ النُّكُولَ دَلٌّ عَلَى كَوْنِهِ بَازِلًا أَوْ مُقَرَّرًا ، إِذْ لَوْلَا ذَلِكَ لَأَقْدَمَ عَلَى الْيَمِينِ إِقَامَةً لِلْوَاجِبِ ، وَدَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْ نَفْسِهِ ، فَتَرَجَّحَ هَذَا الْجَانِبُ ، وَلَا وَجْهَ لِرَدِّ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى لِمَا قَدَّمْنَاهُ⁽⁴⁴¹⁾.

إنذار المدعى عليه بالقضاء بالنكول عند الإنكار : "قَالَ (وَيَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَقُولَ لَهُ إِنِّي أَعْرِضُ عَلَيْكَ الْيَمِينَ ثَلَاثًا ، فَإِنْ حَلَفْتَ ، وَإِلَّا قُضِيَ عَلَيْكَ بِمَا ادَّعَاهُ) ، وَهَذَا الْإِنْذَارُ ، لِإِعْلَامِهِ بِالْحُكْمِ إِذْ هُوَ مَوْضِعُ الْخَفَاءِ.

قَالَ (فَإِذَا كَرَّرَ الْعَرَضَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قُضِيَ عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ) وَهَذَا التَّكْرَارُ ذَكَرَهُ الْخَصَافُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لِزِيَادَةِ الْإِحْتِيَاظِ ، وَالْمُبَالَغَةِ فِي إِبْلَاءِ الْعُذْرِ ، فَأَمَّا الْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَوْ قُضِيَ بِالنُّكُولِ بَعْدَ الْعَرَضِ مَرَّةً جَازَ ، لِمَا قَدَّمْنَاهُ هُوَ الصَّحِيحُ ، وَالْأَوَّلُ أَوْلَى⁽⁴⁴²⁾.

كيفية النكول : ثُمَّ النُّكُولُ قَدْ يَكُونُ حَقِيقِيًّا كَقَوْلِهِ لَا أَحْلِفُ ، وَقَدْ يَكُونُ حُكْمِيًّا بِأَنْ يَسْكُتَ ، وَحُكْمُهُ حُكْمُ الْأَوَّلِ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ لَا آفَةَ بِهِ مِنْ طَرَشٍ أَوْ خَرَسٍ هُوَ الصَّحِيحُ⁽⁴⁴³⁾.

193/10 ، 11/11 ، نهاية المحتاج 362/8 ، كشف القناع 496/6 ، فتاوى ابن الصلاح 719/2 ، كفاية النبيه شرح التنبيه 529/18 ، العزيز شرح الوجيز 417/6 .
(⁴⁴⁰) وهو قول بعض الشافعية: كما حكاه الشيخ أبو علي عن ابن سريج . كفاية النبيه فى شرح التنبيه 529/18 .

(⁴⁴¹) راجع في هذا مسألة رد اليمين على المدعى .

(⁴⁴²) قوله : " لما قدمناه " : إشارة إلى ما ذكر ، إذ النكول دل على كونه باذلاً أو مقراً ، كذا قاله الأتراسي ، والكاكي ، والأكمل - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - .

وقال تاج الشريعة: قوله: "لما قدمناه" : يعني أنه لو لا كونه كاذباً لأقدم على اليمين إقامته للجواب ، وقوله : "هو الصحيح" ، قال الأتراسي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : احتراز عن قول الخصاف ، فإنه يشترط التكرار ، وقال الأكمل: احتراز عما قيل - لو قضى بالنكول مرة واحدة لا ينفذ ، وهذا هو الأوجه ، وقوله : "والأول أولى" ، أي ما ذكره الخصاف أولى ، كما في الإمهال للمرتد ، فإن قتل بلا إمهال جاز . البناية 329/9 .

الدعوى التي لا يستحلف فيها المنكر: "قَالَ (وَإِنْ كَانَتْ الدَّعْوَى نِكَاحًا لَمْ يُسْتَحْلَفِ الْمُنْكَرُ) عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، وَلَا يُسْتَحْلَفُ عِنْدَهُ فِي النِّكَاحِ ، وَالرَّجْعَةِ ، وَالْفَيْءِ فِي الْإِبْلَاءِ ، وَالرَّقِّ ، وَالْإِسْتِيلَادِ ، وَالنَّسَبِ وَالْوَلَاءِ وَالْحُدُودِ وَاللَّعَانِ. وَقَالَا: يُسْتَحْلَفُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ، إِلَّا فِي الْحُدُودِ وَاللَّعَانِ.

وَصُورَةُ الْإِسْتِيلَادِ : أَنْ تَقُولَ الْجَارِيَةُ أَنَا أُمُّ وَلَدٍ لِمَوْلَايَ ، وَهَذَا ابْنِي مِنْهُ ، وَأَنْكَرَ الْمَوْلَى ، لِأَنَّهُ لَوْ ادَّعَى الْمَوْلَى ثَبَتَ الْإِسْتِيلَادُ بِإِقْرَارِهِ ، وَلَا يُلْتَفَتُ إِلَى إنْكَارِهَا. لَهُمَا : أَنَّ النُّكُولَ إِقْرَارٌ ، لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى كَوْنِهِ كَاذِبًا فِي الْإِنْكَارِ عَلَى مَا قَدَّمَاهُ، إِذْ لَوْ لَا ذَلِكَ لَأَقْدَمَ عَلَى الْيَمِينِ الصَّادِقَةِ إِقَامَةً لِلْوَاجِبِ ، فَكَانَ إِقْرَارًا ، أَوْ بَدَلًا عَنْهُ(444) ، وَالْإِقْرَارُ يَجْرِي فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ لَكِنَّهُ إِقْرَارٌ فِيهِ شُبْهَةٌ، وَالْحُدُودُ تَنْدَرِي بِالشُّبُهَاتِ، وَاللَّعَانُ فِي مَعْنَى الْحَدِّ.

وَلِأَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - : أَنَّهُ بَذَلٌ ، لِأَنَّ مَعَهُ لَا تَبْقَى الْيَمِينُ وَاجِبَةً ، لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ ، وَإِنْزَالُهُ بَاذِلًا أَوَّلَى ، كَيْ لَا يَصِيرَ كَاذِبًا فِي الْإِنْكَارِ، وَالْبَذَلُ لَا يَجْرِي فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ.

فائدة الاستحلاف : "وَفَائِدَةُ الْإِسْتِحْلَافِ ، الْقَضَاءُ بِالنُّكُولِ ، فَلَا يُسْتَحْلَفُ، إِلَّا أَنْ هَذَا بَذَلٌ لِدَفْعِ الْخُصُومَةِ فَيَمْلِكُهُ الْمُكَاتَبُ وَالْعَبْدُ الْمَأْنُونُ ، بِمَنْزِلَةِ الضِّيَافَةِ الْيَسِيرَةِ، وَصَحَّتُهُ فِي الدِّينِ بِنَاءً عَلَى زَعْمِ الْمُدَّعِي وَهُوَ مَا يَقْبِضُهُ حَقًّا لِنَفْسِهِ، وَالْبَذَلُ مَعْنَاهُ هَاهُنَا تَرْكُ الْمَنْعِ وَأَمْرُ الْمَالِ هَيْئًا.

استحلاف السارق : "قَالَ (وَيُسْتَحْلَفُ السَّارِقُ، فَإِنْ نَكَلَ ضَمِنَ وَلَمْ يَقْطَعْ) لِأَنَّ الْمَنُوطَ بِفِعْلِهِ شَيْئَانِ: الضَّمَانُ وَيَعْمَلُ فِيهِ النُّكُولُ ، وَالْقَطْعُ ، وَلَا يَتَّبَعُ بِهِ ، فَصَارَ كَمَا إِذَا شَهِدَ عَلَيْهَا رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ(445).

استحلاف الزوج في دعوى الطلاق قبل الدخول والنسب: "قَالَ (وَإِذَا ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ طَلَاقًا قَبْلَ الدُّخُولِ أُسْتُحْلَفَ الزَّوْجُ، فَإِنْ نَكَلَ ضَمِنَ نِصْفَ الْمَهْرِ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا) ، لِأَنَّ الْإِسْتِحْلَافَ يَجْرِي فِي الطَّلَاقِ عِنْدَهُمْ ، لَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ الْمَقْصُودُ هُوَ الْمَالُ، وَكَذَا فِي النِّكَاحِ إِذَا ادَّعَتْ هِيَ الصَّدَاقَ ، لِأَنَّ ذَلِكَ دَعْوَى الْمَالِ، ثُمَّ يَتَّبَعُ الْمَالُ بِنُكُولِهِ وَلَا يَتَّبَعُ النِّكَاحُ، وَكَذَا

(443) أشار به إلى اختلاف الروايات فيما إذا سكت المدعى عليه بعد عرض اليمين عليه ولم يقل - لا أحلف، فقال بعض أصحابنا: إذا سكت المدعى عليه سأل القاضي: هل به خرس أو طرش؟ فإذا قالوا: لا، جعله ناكلا، وقضى عليه، ومنهم من قال: يحبس حتى يجيب، والأول هو الصحيح. البناية 329/9.

(444) أى خلفا عن الإقرار : يعنى أنه قائم مقام الإقرار . تكملة فتح القدير 182/8.

(445) قوله : "ولا يثبت به " ، أى ولا يثبت القطع بالنكول ، لأنه لا يجري البذل بالنكول في الحدود، ولا يثبت بما فيه شبهة الإقرار " فصار " حكم هذا ، "كما إذا شهد عليه" ، أى على السرقة "رجل وامرأتان " حيث يثبت المال فلا يثبت القطع. البناية 334/9.

فِي النَّسَبِ ، إِذَا ادَّعَى حَقًّا ، كَالْإِرْثِ وَالْحَجْرِ فِي اللَّقِيطِ ، وَالنَّفَقَةِ وَامْتِنَاعِ الرُّجُوعِ فِي الْهَبَةِ ، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ هَذِهِ الْحُقُوقُ ، وَإِنَّمَا يُسْتَحْلَفُ فِي النَّسَبِ الْمُجَرَّدِ عِنْدَهُمَا ، إِذَا كَانَ يَتَبَيَّنُ بِإِفْرَارِهِ ، كَالْأَبِ وَالْإِبْنِ فِي حَقِّ الرَّجُلِ ، وَالْأَبِ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ ، لِأَنَّ فِي دَعْوَاهَا الْإِبْنَ تَحْمِيلَ النَّسَبِ عَلَى الْغَيْرِ وَالْمَوْلَى وَالزَّوْجِ فِي حَقِّهِمَا .

استحلاف المدعى عليه بالقصاص : قَالَ (وَمَنْ ادَّعَى قِصَاصًا عَلَى غَيْرِهِ فَجَحَدَهُ أُسْتُحْلَفَ) ، بِالْإِجْمَاعِ ، (ثُمَّ إِنْ نَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ ، يَلْزَمُهُ الْقِصَاصُ ، وَإِنْ نَكَلَ فِي النَّفْسِ ، حُبِسَ حَتَّى يَخْلِفَ أَوْ يُقِرَّ) وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، وَقَالَا : لَزِمَهُ الْأَرْضُ فِيهِمَا ، لِأَنَّ النُّكُولَ إِفْرَارٌ فِيهِ شَبَهَةٌ عِنْدَهُمَا ، فَلَا يَتَبَيَّنُ بِهِ الْقِصَاصُ ، وَيَجِبُ بِهِ الْمَالُ ، خُصُوصًا إِذَا كَانَ امْتِنَاعُ الْقِصَاصِ لِمَعْنَى مِنْ جِهَةٍ مِنْ عَلَيْهِ ، كَمَا إِذَا أَقَرَّ بِالْخَطَا وَالْوَلِيُّ يَدَّعِي الْعَمْدَ ⁽⁴⁴⁶⁾ . وَلِأَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّ الْأَطْرَافَ يُسَلِّكُ بِهَا مَسَلَّكَ الْأَمْوَالِ ، فَيَجْرِي فِيهَا الْبَذْلُ ، بِخِلَافِ الْأَنْفُسِ ، فَإِنَّهُ لَوْ قَالَ : أَقْطَعُ يَدِي ، فَقَطَعَهَا لَا يَجِبُ الضَّمَانُ ، وَهَذَا إِعْمَالٌ لِلْبَذْلِ ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يُبَاحُ ، لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ ، وَهَذَا الْبَذْلُ مُفِيدٌ لِإِنْدِفَاعِ الْخُصُومَةِ بِهِ ، فَصَارَ كَقَطْعِ الْيَدِ لِلْأَكْلَةِ ، وَقَلْعِ السِّنِّ لِلْوَجَعِ ، وَإِذَا امْتَنَعَ الْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ ، وَالْيَمِينُ حَقٌّ مُسْتَحَقٌّ يُحْبَسُ بِهِ ⁽⁴⁴⁷⁾ ، كَمَا فِي الْقِسَامَةِ ⁽⁴⁴⁸⁾ .

الكفالة بالنفس عن المدعى عليه للحضور أمام القضاء : " قَالَ ⁽⁴⁴⁹⁾) : (وَإِذَا قَالَ الْمُدَّعِي : لِي بَيِّنَةٌ حَاضِرَةٌ ، قِيلَ لَخَصْمَةٍ : أَعْطِهِ كَفِيلًا بِنَفْسِكَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) كَى لَا يَغِيبُ نَفْسَهُ ، فَيُضَيِّعَ حَقَّهُ ، وَالْكَفَالَةُ بِالنَّفْسِ جَائِزَةٌ عِنْدَنَا ، وَقَدْ مَرَّ مِنْ قَبْلُ ، وَأَخَذَ الْكَفِيلُ بِمُجَرَّدِ الدَّعْوَى اسْتِحْسَانًا عِنْدَنَا ، لِأَنَّ فِيهِ نَظَرًا لِلْمُدَّعِي ، وَلَيْسَ فِيهِ كَثِيرُ ضَرَرٍ بِالْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، وَهَذَا لِأَنَّ الْحُضُورَ مُسْتَحَقٌّ عَلَيْهِ بِمُجَرَّدِ الدَّعْوَى حَتَّى يُعَدَّى عَلَيْهِ وَيَحَالَ بَيْنَهُ وَيَبِينَ أَشْغَالُهُ فَصَحَّ التَّكْفِيلُ

⁽⁴⁴⁶⁾) وَلِأَنَّهُ لَمْ يُصَرِّحْ بِالْإِفْرَارِ فَأَشْبَهَ الْخَطَا ، وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْإِمْتِنَاعُ مِنْ جَانِبِ مَنْ لَهُ ، كَمَا إِذَا أَقَامَ مُدَّعِي الْقِصَاصِ رَجُلًا وَامْرَأَتَيْنِ أَوْ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ فَإِنَّهُ لَا يُفْضَى بِشَيْءٍ ، لِأَنَّ الْحُجَّةَ قَامَتْ بِالْقِصَاصِ لَكِنْ تَعَذَّرَ اسْتِيفَاؤُهُ وَلَمْ يُشَبَّهِ الْخَطَا فَلَا يَجِبُ شَيْءٌ ، وَلَا تَفَاوُتٌ فِي هَذَا الْمَعْنَى بَيْنَ النَّفْسِ وَمَا دُونَهَا . العناية 191/8 .

⁽⁴⁴⁷⁾) وَلِأَبِي حَنِيفَةَ : أَنَّ الْأَطْرَافَ يُسَلِّكُ بِهَا مَسَلَّكَ الْأَمْوَالِ ، لِأَنَّهَا خُلِقَتْ وَقَايَةً لِلنَّفْسِ ، كَالْأَمْوَالِ فَيَجْرِي فِيهَا الْبَذْلُ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ قَالَ أَقْطَعُ يَدِي فَقَطَعَهَا لَا يَجِبُ الضَّمَانُ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا مِنْ حَيْثُ إِعْمَالُ الْبَذْلِ ، بِخِلَافِ الْأَنْفُسِ حَيْثُ لَا يَجْرِي فِيهَا الْبَذْلُ ، فَإِنَّهُ لَوْ قَالَ أَقْتُلْنِي فَقَتَلَهُ يُؤْخَذُ بِالْقِصَاصِ فِي رِوَايَةٍ وَبِالْذِّبَةِ فِي أُخْرَى . فَإِنْ قِيلَ : لَوْ كَانَتْ الْأَطْرَافُ يُسَلِّكُ بِهَا مَسَلَّكَ الْأَمْوَالِ لَجَازَ قَطْعُ يَدِهِ مِنْ غَيْرِ إِثْمٍ إِذَا قَالَ أَقْطَعُ يَدِي ، كَمَا يُبَاحُ لَهُ أَخْذُ مَالِهِ إِذَا قَالَ خُذْ مَالِي . أَجَابَ بِقَوْلِهِ : إِلَّا أَنَّهُ لَا يُبَاحُ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ ، حَتَّى لَوْ كَانَ الْقَطْعُ مُفِيدًا كَالْقَطْعِ لِلْأَكْلَةِ وَقَلْعِ السِّنِّ لِلْوَجَعِ لَمْ يَأْتُمْ بِفِعْلِهِ ، وَمَا نَحْنُ فِيهِ مِنَ الْبَذْلِ : أَيُّ الَّذِي بِالنُّكُولِ مُفِيدٌ ، لِإِنْدِفَاعِ الْخُصُومَةِ بِهِ فَيَكُونُ مُبَاحًا . العناية 191/8 ، 192 .

⁽⁴⁴⁸⁾) فَإِنَّهُمْ إِذَا نَكَلُوا عَنِ الْيَمِينِ يَحْبَسُونَ ، حَتَّى يَقْرَأُوا أَوْ يَحْلِفُوا . قرة عيون الأخيار لتكملة رد المحتار 59/8 .

⁽⁴⁴⁹⁾) القُدُورَى فِي مَخْتَصَرِهِ . تكملة فتح القدير 192/8 .

بإحضاره (450)، والتقدير بثلاثة أيام مروى عن أبي حنيفة - رحمه الله -، وهو الصحيح، ولا فرق في الظاهر بين الخامل والوجيه والحقير من المال والخطير، ثم لا بد من قوله لي بيّنة حاضرة للتكفيل ومعناه في المصر، حتى لو قال المدعي لا بيّنة لي أو شهودي غيب لا يكفل لعدم الفائدة.

قال (فإن فعل وإلا أمر بملازمته)، كي لا يذهب حقه، (إلا أن يكون غريباً فيلزم مقداره مجلس القاضي)، وكذا لا يكفل إلا إلى آخر المجلس، فالاستثناء منصرف إليهما، لأن في أخذ الكفيل والملازمة زيادة على ذلك إضراراً به بمنعه عن السفر، ولا ضرر في هذا المقدار ظاهراً، وكيفية الملازمة نذكرها في كتاب الحبر إن شاء الله تعالى (451).

(فصل في كيفية اليمين والاستخلاف)

بم يكون الحلف للمسلم: "قال (واليمين بالله عز وجل دون غيره) لقوله - عليه الصلاة والسلام - "من كان منكم حالفاً فليحلف بالله أو ليذر" (452)، وقال - عليه الصلاة والسلام - "من حلف بغير الله فقد أشرك" (453).

كيفية تغليظ اليمين على المسلم: (وقد تؤكد بذكر أوصافه) وهو التغليظ، وذلك مثل قوله: قل والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية، ما لفلان هذا عليك، ولا قبلك هذا المال الذي ادعاه وهو كذا وكذا ولا شيء منه، وله أن يزيد في التغليظ على هذا، وله أن ينقص منه، إلا أنه يخطأ فيه كي لا يتكرر عليه اليمين، لأن المستحق يمين واحدة، والقاضي بالخيار إن شاء غلظ وإن شاء لم يغلظ فيقول: قل بالله أو والله، وقيل: لا يغلظ على المعروف بالصالح، ويغلظ على غيره، وقيل: يغلظ في الخطير من المال دون الحقير.

(450) أما جواز التكفيل فهو استحسان، والقياس يابأه قبل إقامة الحجة، ووجه ذلك: أن الحضور بمجرد الدعوى مستحق عليه حتى لو امتنع عنه يعدى عليه، ويحال بينه وبين أشغاله فيصبح التكفيل بإحضاره نظراً للمدعي وضرراً للمدعى عليه به يسير فيتحمل كالأعداء والحيلولة بينه وبين أشغاله. العناية على الهداية 193/8.

(451) وتفسير الملازمة: أن يدور معه حيث دار، ويبعث أميناً حتى يدور معه أينما دار، لكن لا يحبسه في موضع، لأن ذلك حبس، وهو غير مستحق عليه بنفس الدعوى، ولا يشغله عن التصرف، بل يتصرف، والمدعي يدور معه، ولا يمنعه من الدخول إلى أهله، لكن المطلوب يجلس على باب داره. البناية على الهداية 340/9.

(452) متفق عليه بين الشيخين: البخاري رقم 2679، مسلم رقم 1646/3، عن ابن عمر (رضي الله عنهما) بلفظ: "... أو ليصمت".

(453) رواه ابن حبان في صحيحه، ولأن المسلم الورع يعتقد تعظيم اسم الله تعالى، فصلح ذكره. تبين الحقائق وحاشية الشلبي 419/3، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، لابن بلبان رقم 4358.

الاستحلاف بالطلاق : قَالَ (وَلَا يَسْتَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ وَلَا بِالْعَتَاقِ) لِمَا رَوَيْنَا، وَقِيلَ فِي زَمَانِنَا إِذَا أَلَحَّ الْخَصْمُ سَاعَ الْقَاضِي أَنْ يَحْلِفَ بِذَلِكَ لِقَلَّةِ الْمَبَالَاةِ بِالْيَمِينِ بِاللَّهِ وَكَثْرَةِ الْإِمْتِنَاعِ بِسَبَبِ الْحَلْفِ بِالطَّلَاقِ⁽⁴⁵⁴⁾.

استحلاف غير المسلم : "قَالَ (وَيَسْتَحْلِفُ الْيَهُودِيَّ بِاللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَةَ عَلَى مُوسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ، وَالنَّصْرَانِيَّ بِاللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ الْإِنْجِيلَ عَلَى عِيسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ -) «لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لِابْنِ صُورِيَّا الْأَعُورِ " أَنْشُدْكَ بِاللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَةَ عَلَى مُوسَى أَنَّ حُكْمَ الزَّنا فِي كِتَابِكُمْ هَذَا (455) " ، وَلِأَنَّ الْيَهُودِيَّ يَعْتَقِدُ نُبُوَّةَ مُوسَى وَالنَّصْرَانِيَّ نُبُوَّةَ عِيسَى - عَلَيْهِمَا السَّلَامُ - فَيُعْلَظُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِذِكْرِ الْمُنْزَلِ عَلَى نَبِيِّهِ ، (و) يَسْتَحْلِفُ (الْمَجُوسِيَّ بِاللَّهِ الَّذِي خَلَقَ النَّارَ)⁽⁴⁵⁶⁾) وَهَكَذَا ذَكَرَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي الْأَصْلِ⁽⁴⁵⁷⁾ ، يُرَوَى عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي النَّوَائِرِ⁽⁴⁵⁸⁾ : أَنَّهُ لَا يَسْتَحْلِفُ أَحَدًا إِلَّا بِاللَّهِ خَالِصًا، وَذَكَرَ الْخَصَّافُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّهُ لَا يَسْتَحْلِفُ غَيْرَ الْيَهُودِيَّ وَالنَّصْرَانِيَّ إِلَّا بِاللَّهِ، وَهُوَ اخْتِيَارُ بَعْضِ مَشَائِخِنَا ، لِأَنَّ فِي ذِكْرِ النَّارِ مَعَ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى تَعْظِيمًا ، وَمَا يَنْبَغِي أَنْ تُعْظَمَ⁽⁴⁵⁹⁾ ، بِخِلَافِ الْكِتَابَيْنِ ، لِأَنَّ كُتُبَ اللَّهِ مُعْظَمَةٌ (وَالْوَثْنِي لَا يَحْلِفُ إِلَّا بِاللَّهِ) ، لِأَنَّ الْكُفْرَةَ

⁽⁴⁵⁴⁾ وهذا قول عامة المتأخرين من الحنفية ، والقاضي أبى يعلى من الحنابلة ، واستدلوا: أن عبد الله بن عمرو بن العاص حلف بالطلاق عند النبي (صلى الله عليه وسلم) ولم ينكر عليه ، ولأنه لما ضعف الوازع الديني عند بعض الناس ، مست الحاجة إلى الوثيقة بالطلاق ، وما أشبهه. تبين الحقائق وحاشية الشلبي 419/3، كشف القناع 570/6.

⁽⁴⁵⁵⁾ رواه مسلم في صحيحه رقم 1700/28، شرح مشكل الآثار للطحاوى رقم 4539، نيل الأوطار للشوكاني رقم 3100.

⁽⁴⁵⁶⁾ لأن المجوسى يعتقد الحرمة فى النار، فيمتنع عن اليمين الكاذبة ، فيحصل المقصود .تكملة فتح القدير 206/8، 207.

⁽⁴⁵⁷⁾ كتاب للإمام محمد بن الحسن الشيبانى ، وهو من كتب ظاهر الرواية ، والتي تتضمن أيضا السير الصغير والكبير ، والجامع الصغير والكبير والزيادات ، وسمى بالأصل ، لأن الشيبانى صنّفه قبل سائر كتبه المعروفة . مفتاح السعادة 263/2.

⁽⁴⁵⁸⁾ تطلق على المسائل التى رويت عن أئمة المذهب أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد في غير كتب ظاهر الرواية ك" الرقيات ، والهارونيات ، والكيسانيات والجرجانيات ، أو كتب غيره من أصحاب أبى حنيفة ، كالأمالى ، لأبى يوسف والمجرد للحسن بن زياد ، أو تكون بروايات مفردة ، كروايات ابن سماعة ، والمعلى بن منصور وغيرهم . رد المحتار 50/1، 69.

⁽⁴⁵⁹⁾ روى عن أبى حنيفة ، وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة . تكملة فتح القدير 206/8، 207، الذخيرة 70/11، 73، الحاوى 116/17، كشف القناع 570/6.

بِأَسْرِهِمْ يَعْتَقُونَ اللَّهَ تَعَالَى⁴⁶⁰، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَلَنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ
وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لِيَقُولَنَّ اللَّهُ .. ﴾ [لقمان: 25] .

مكان استحلاف غير المسلم : "قَالَ (وَلَا يَخْلِفُونَ فِي بُيُوتِ عِبَادَتِهِمْ) ، لِأَنَّ الْقَاضِيَ لَا
يَحْضُرُهَا ، بَلْ هُوَ مَمْنُوعٌ عَنْ ذَلِكَ"⁽⁴⁶¹⁾.

حكم تغليظ اليمين على المسلم : "قَالَ (وَلَا يَجِبُ تَغْلِيظُ الْيَمِينِ عَلَى الْمُسْلِمِ بِزَمَانٍ وَلَا مَكَانٍ)،
لِأَنَّ الْمَقْصُودَ تَعْظِيمَ الْمُقْسَمِ بِهِ وَهُوَ حَاصِلٌ بِدُونِ ذَلِكَ، وَفِي إِجَابِ ذَلِكَ حَرَجٌ عَلَى الْقَاضِيَ
حَيْثُ يُكَلِّفُ حُضُورَهَا وَهُوَ مَدْفُوعٌ"⁽⁴⁶²⁾.

الحلف على الحاصل أو السبب : "قَالَ (وَمَنْ ادَّعَى أَنَّهُ ابْتِاعَ مِنْ هَذَا عَبْدَهُ بِأَلْفٍ ، فَجَحَدَ ،
اسْتَحْلَفَ بِاللَّهِ مَا بَيْنَكُمَا بَيْعٌ قَائِمٌ فِيهِ ، وَلَا يَسْتَحْلِفُ بِاللَّهِ مَا بَعْتَ)، لِأَنَّهُ قَدْ يُبَاعُ الْعَيْنُ ، ثُمَّ
يُقَالُ فِيهِ (وَيَسْتَحْلِفُ فِي الْغَضَبِ : بِاللَّهِ مَا يَسْتَحِقُّ عَلَيْكَ رَدُّهُ ، وَلَا يَحْلِفُ بِاللَّهِ مَا غَضِبْتَ) ،
لِأَنَّهُ قَدْ يَغْضِبُ ، ثُمَّ يَفْسَخُ بِالْهَبَةِ وَالْبَيْعِ (وَفِي النِّكَاحِ : بِاللَّهِ مَا بَيْنَكُمَا نِكَاحٌ قَائِمٌ فِي الْحَالِ) ،
لِأَنَّهُ قَدْ يَطْرَأُ عَلَيْهِ الْخُلْعُ ، (وَفِي دَعْوَى الطَّلَاقِ : بِاللَّهِ مَا هِيَ بَائِنٌ مِنْكَ السَّاعَةَ بِمَا ذَكَرْتَ ،
وَلَا يَسْتَحْلِفُ بِاللَّهِ مَا طَلَّقَهَا) ، لِأَنَّ النِّكَاحَ قَدْ يُجَدِّدُ بَعْدَ الْإِبَانَةِ ، فَيَحْلِفُ عَلَى الْحَاصِلِ فِي هَذِهِ
الْوُجُوهِ، لِأَنَّهُ لَوْ حَلَفَ عَلَى السَّبَبِ يَتَضَرَّرُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ
رَحِمَهُمَا اللَّهُ.

أَمَّا عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يَحْلِفُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ عَلَى السَّبَبِ ، إِلَّا إِذَا عَرَّضَ بِمَا
ذَكَرْنَا ، فَحِينَئِذٍ يَحْلِفُ عَلَى الْحَاصِلِ ، وَقِيلَ: يَنْظُرُ إِلَى انْكَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِنْ أَنْكَرَ السَّبَبَ
يَحْلِفُ عَلَيْهِ، وَإِنْ أَنْكَرَ الْحُكْمَ يَحْلِفُ عَلَى الْحَاصِلِ ، فَالْحَاصِلُ هُوَ الْأَصْلُ عِنْدَهُمَا إِذَا كَانَ
سَبَبًا يَرْتَفِعُ ، إِلَّا إِذَا كَانَ فِيهِ تَرَكُّ النَّظَرِ فِي جَانِبِ الْمُدَّعَى ، فَحِينَئِذٍ يَحْلِفُ عَلَى السَّبَبِ
بِالْإِجْمَاعِ، وَذَلِكَ أَنْ نَدَّعِيَ مَبْنُوتَةً نَفَقَةَ الْعِدَّةِ ، وَالزَّوْجَ مِمَّنْ لَا يَرَاهَا، أَوْ ادَّعَى شَفْعَةً
بِالْجَوَارِ، وَالْمُشْتَرِي لَا يَرَاهَا، لِأَنَّهُ لَوْ حَلَفَ عَلَى الْحَاصِلِ يَصْدُقُ فِي يَمِينِهِ فِي مُعْتَقَدِهِ ،
فَيَفُوتُ النَّظَرُ فِي حَقِّ الْمُدَّعَى، وَإِنْ كَانَ سَبَبًا لَا يَرْتَفِعُ بِرَافِعٍ ، فَالْتَّحْلِيفُ عَلَى السَّبَبِ
بِالْإِجْمَاعِ (كَالْعَبْدِ الْمُسْلِمِ إِذَا ادَّعَى الْعِتْقَ عَلَى مَوْلَاهُ، بِخِلَافِ الْأَمَةِ وَالْعَبْدِ الْكَافِرِ) ، لِأَنَّهُ

⁽⁴⁶⁰⁾ (تكملة فتح القدير 207/8، الذخيرة 73/11، الحاوى 117/17، المغنى 228/9.

⁽⁴⁶¹⁾ (ولأن في حضوره تعظيم لذلك المكان ، وما أمرنا بهذا .البنية 345/9.

⁽⁴⁶²⁾ (ولأن في التغليظ بالزمان تأخير حق المدعي في اليمين إلى ذلك الزمان ، وأنه غير
مشروع . البحر الرائق 213/7.

يُكَرِّرُ الرَّقَّ عَلَيْهَا بِالرَّدَّةِ وَاللَّحَاقِ ، وَعَلَيْهِ بِنَقِضِ الْعَهْدِ وَاللَّحَاقِ⁽⁴⁶³⁾، وَلَا يُكَرِّرُ عَلَى الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ⁽⁴⁶⁴⁾.

اليمين على العلم أو البتات : "قَالَ: (وَمَنْ وَرِثَ عَبْدًا ، وَادَّعَاهُ آخَرُ يَسْتَحْلِفُ عَلَى عِلْمِهِ)، لِأَنَّهُ لَا عِلْمَ لَهُ بِمَا صَنَعَ الْمُورِثُ ، فَلَا يَحْلِفُ عَلَى الْبَتَاتِ ، (وَإِنْ وَهَبَ لَهُ أَوْ اشْتَرَاهُ يَحْلِفُ عَلَى الْبَتَاتِ) ، لَوْجُودِ الْمُطْلَقِ لِلْيَمِينِ ، إِذِ الشَّرَاءُ سَبَبٌ لِثُبُوتِ الْمُلْكِ وَضَعًا وَكَذَا الْهَبَةُ⁽⁴⁶⁵⁾.

افتداء اليمين : "قَالَ (وَمَنْ ادَّعَى عَلَى آخَرٍ مَالًا ، فَافْتَدَى يَمِينَهُ ، أَوْ صَالَحَهُ مِنْهَا عَلَى عَشْرَةِ ، فَهُوَ جَائِزٌ) وَهُوَ مَأْثُورٌ عَنْ عُثْمَانَ⁽⁴⁶⁶⁾ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - . (وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَحْلِفَهُ عَلَى تِلْكَ الْيَمِينِ أَبَدًا)، لِأَنَّهُ أَسْقَطَ حَقَّهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(بَابُ التَّحَالِفِ) :

حكم يمين المتبايعين : "قَالَ⁽⁴⁶⁷⁾: (وَإِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايعَانِ فِي الْبَيْعِ فَادَّعَى أَحَدُهُمَا ثَمَنًا وَادَّعَى الْبَائِعُ أَكْثَرَ مِنْهُ أَوْ اعْتَرَفَ الْبَائِعُ بِقَدْرِ مِنَ الْمَبِيعِ ، وَادَّعَى الْمُشْتَرِي أَكْثَرَ مِنْهُ ، فَأَقَامَ أَحَدُهُمَا الْبَيِّنَةَ قَضَى لَهُ بِهَا)، لِأَنَّ فِي الْجَانِبِ الْآخَرَ مُجَرَّدَ الدَّعْوَى ، وَالْبَيِّنَةُ أَقْوَى مِنْهَا (وَإِنْ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً ، كَانَتْ الْبَيِّنَةُ الْمُثْبِتَةُ لِلزِّيَادَةِ أَوْلَى) ، لِأَنَّ الْبَيِّنَاتِ لِلْإِثْبَاتِ وَلَا تَعَارِضُ فِي الزِّيَادَةِ ، (وَلَوْ كَانَ الْإِخْتِلَافُ فِي الثَّمَنِ وَالْمَبِيعِ جَمِيعًا ، فَبَيِّنَةُ الْبَائِعِ أَوْلَى فِي الثَّمَنِ ، وَبَيِّنَةُ الْمُشْتَرِي أَوْلَى فِي الْمَبِيعِ) نَظَرًا إِلَى زِيَادَةِ الْإِثْبَاتِ، (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِكُلِّ وَاحِدٍ

⁽⁴⁶³⁾ أى اللحاق بدار الحرب . تكملة فتح القدير 201/8.

⁽⁴⁶⁴⁾ (الْيَمِينِ : وَهُوَ الْحَلْفُ عَلَى الْحَاصِلِ أَوْ السَّبَبِ، وَالضَّابِطُ فِي ذَلِكَ : أَنَّ السَّبَبَ، إِمَّا أَنْ كَانَ مِمَّا يَرْتَفِعُ بِرَافِعٍ أَوْ لَا، فَإِنْ كَانَ الثَّانِي فَالتَّحْلِيفُ عَلَى السَّبَبِ بِالْإِجْمَاعِ، وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ فَإِنْ تَضَرَّرَ الْمُدَّعِي بِالتَّحْلِيفِ عَلَى الْحَاصِلِ فَكَذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَتَضَرَّرْ يَحْلِفُ عَلَى الْحَاصِلِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ، وَعَلَى السَّبَبِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ، إِلَّا إِذَا عَرَضَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَرَفَعِ السَّبَبِ ، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ عِنْدَ قَوْلِ الْقَاضِي احْلِفْ بِاللَّهِ مَا بَعْتَ أَيُّهَا الْقَاضِي إِنَّ الْإِنْسَانَ قَدْ يَبِيعُ شَيْئًا ثُمَّ يُقَالُ فِيهِ ، فَجَبِينِذِ يَلْزِمُ الْقَاضِي الْإِسْتِحْلَافَ عَلَى الْحَاصِلِ، هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ . تكملة فتح القدير 198/8.

⁽⁴⁶⁵⁾ (وَهَذَا نَوْعٌ آخَرُ مِنْ كَيْفِيَّةِ الْيَمِينِ ، وَهُوَ الْيَمِينُ عَلَى الْعِلْمِ أَوْ الْبَتَاتِ، الضَّابِطُ فِي ذَلِكَ : أَنَّ الدَّعْوَى إِذَا وَقَعَتْ عَلَى فِعْلِ الْغَيْرِ ، كَانَ الْحَلْفُ عَلَى الْعِلْمِ، وَإِنْ وَقَعَتْ عَلَى فِعْلِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، كَانَ عَلَى الْبَتَاتِ . العناية 201/8.

⁽⁴⁶⁶⁾ (عن الشعبي ، أن المقداد ، استقرض من عثمان بن عفان رضي الله عنه سبعة آلاف درهم ، فلما تقاضاه ، قال: " إنما هي أربعة آلاف ، فخاصمه إلى عمر رضي الله عنه ، فقال: إني قد أقرضت المقداد سبعة آلاف درهم ، فقال المقداد: إنما هي أربعة آلاف ، فقال المقداد: أحلفه أنها سبعة آلاف ، فقال عمر رضي الله عنه: " أنصفك " ، فأبى أن يحلف ، فقال عمر: خذ ما أعطاك " ، قال: البيهقي : هذا إسناد صحيح ، إلا أنه منقطع ، .. والله أعلم . السنن الكبرى للبيهقي رقم 20740.

⁽⁴⁶⁷⁾ (أى القدورى فى مختصره . تكملة فتح القدير 205/8.

مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ ، قِيلَ لِلْمُشْتَرِي : إِمَّا أَنْ تَرْضَى بِالثَّمَنِ الَّذِي ادَّعَاهُ الْبَائِعُ وَإِلَّا فَسَخْنَا الْبَيْعَ ، وَقِيلَ
لِلْبَائِعِ : إِمَّا أَنْ تُسَلِّمَ مَا ادَّعَاهُ الْمُشْتَرِي مِنَ الْمَبِيعِ ، وَإِلَّا فَسَخْنَا الْبَيْعَ ، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ قَطْعَ
الْمُنَازَعَةِ ، وَهَذِهِ جِهَةٌ فِيهِ ، لِأَنَّهُ رَبَّمَا لَا يَرْضِيَانِ بِالْفَسْخِ ، فَإِذَا عَلِمَا بِهِ يَتَرَاضِيَانِ بِهِ ، (فَإِنْ
لَمْ يَتَرَاضِيَا ، اسْتَحْلَفَ الْحَاكِمُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى دَعْوَى الْآخَرِ) ، وَهَذَا التَّحَالُفُ قَبْلَ
الْقَبْضِ عَلَى وِفَاقِ الْقِيَاسِ ، لِأَنَّ الْبَائِعَ يَدَّعِي زِيَادَةَ الثَّمَنِ وَالْمُشْتَرِي يُنْكِرُهُ ، وَالْمُشْتَرِي يَدَّعِي
وُجُوبَ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ بِمَا نَقَدَ ، وَالْبَائِعُ يُنْكِرُهُ ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُنْكَرٌ فَيَحْلِفُ ؛ فَأَمَّا بَعْدَ الْقَبْضِ
، فَمُخَالَفٌ لِلْقِيَاسِ ، لِأَنَّ الْمُشْتَرِي لَا يَدَّعِي شَيْئًا ، لِأَنَّ الْمَبِيعَ سَالِمٌ لَهُ ، فَبَقِيَ دَعْوَى الْبَائِعِ
فِي زِيَادَةِ الثَّمَنِ وَالْمُشْتَرِي يُنْكِرُهَا فَيُكْتَفَى بِحَلْفِهِ ، لَكِنَّا عَرَفْنَاهُ بِالنَّصِّ وَهُوَ قَوْلُهُ - عَلَيْهِ
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - "إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايعَانِ ، وَالسَّلْعَةُ قَائِمَةٌ بَعَيْنَهَا ، تَحَالَفَا وَتَرَادَا"⁽⁴⁶⁸⁾ .

البدء بيمين المشتري عند الاختلاف : "قال: (وَيَبْدِئُ بيمينِ الْمُشْتَرِي) ، وَهَذَا قَوْلُ مُحَمَّدٍ
وَأَبِي يُوسُفَ آخِرًا ، وَهُوَ رَوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَهُوَ الصَّحِيحُ ، لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَّ
أَشَدُّهُمَا إِنْكَارًا ، لِأَنَّهُ يُطَالِبُ أَوَّلًا بِالثَّمَنِ ، وَلِأَنَّهُ يَتَعَجَّلُ فَائِدَةَ النُّكُولِ ، وَهُوَ الْإِزَامُ الثَّمَنِ ، وَلَوْ
بَدِئَ بِيمينِ الْبَائِعِ تَتَأَخَّرُ الْمُطَالَبَةُ بِتَسْلِيمِ الْمَبِيعِ إِلَى زَمَانِ اسْتِيفَاءِ الثَّمَنِ ، وَكَانَ أَبُو يُوسُفَ -
رَحِمَهُ اللَّهُ - يَقُولُ أَوَّلًا: يَبْدَأُ بِيمينِ الْبَائِعِ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - "إِذَا اخْتَلَفَ
الْمُتَبَايعَانِ فَالْقَوْلُ مَا قَالَهُ الْبَائِعُ"⁽⁴⁶⁹⁾ ، خَصَّهُ بِالذِّكْرِ ، وَأَقْلُ فَائِدَتِهِ التَّقْدِيمُ .

البدء بيمين أحد المتبايعين في المقايضة والصرف : (وَإِنْ كَانَ بَيْعٌ عَيْنٍ بِعَيْنٍ أَوْ ثَمَنِ بِثَمَنِ
بَدَأَ الْقَاضِي بِيمينِ أَيُّهُمَا شَاءَ) لِاسْتِوَائِهِمَا .

صفة اليمين عند اختلاف المتبايعين : (وَصِفَةُ الْيَمِينِ : أَنْ يَحْلِفَ الْبَائِعُ بِاللَّهِ مَا بَاعَهُ بِأَلْفٍ ،
وَيَحْلِفَ الْمُشْتَرِي بِاللَّهِ مَا اشْتَرَاهُ بِأَلْفَيْنِ) ، وَقَالَ فِي الزِّيَادَاتِ⁽⁴⁷⁰⁾ : يَحْلِفُ بِاللَّهِ مَا بَاعَهُ بِأَلْفٍ
، وَلَقَدْ بَاعَهُ بِأَلْفَيْنِ ، يَحْلِفُ الْمُشْتَرِي بِاللَّهِ مَا اشْتَرَاهُ بِأَلْفَيْنِ وَلَقَدْ اشْتَرَاهُ بِأَلْفٍ ، يَضْمَنُ الْإِثْبَاتُ
إِلَى النَّفْيِ تَأَكِيدًا ، وَالْأَصَحُّ الْإِفْتِصَارُ عَلَى النَّفْيِ ، لِأَنَّ الْأَيْمَانَ عَلَى ذَلِكَ وَضِعَتْ ، دَلَّ عَلَيْهِ
حَدِيثُ الْقَسَامَةِ "بِاللَّهِ مَا قَتَلْتُمْ وَلَا عَلِمْتُمْ لَهُ قَاتِلًا"⁽⁴⁷¹⁾ .

قَالَ (فَإِنْ حَلَفَا ، فَسَخَ الْقَاضِي الْبَيْعَ بَيْنَهُمَا) ، وَهَذَا يُدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَنْفَسِخُ بِنَفْسِ التَّحَالُفِ ،
لِأَنَّهُ لَمْ يَنْبُتْ مَا ادَّعَاهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، فَيَبْقَى بَيْعٌ مَجْهُولٌ فَيَفْسُخُهُ الْقَاضِي ، قَطْعًا لِلْمُنَازَعَةِ

⁽⁴⁶⁸⁾ موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني رقم 786 ، شرح مشكل الآثار رقم 2389 .
⁽⁴⁶⁹⁾ المسند ، للشاشي ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ،
رقم 302 ، الآثار ، لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبة الأنصاري
(المتوفى: 182 هـ) رقم 830 .
⁽⁴⁷⁰⁾ كتاب للإمام محمد بن الحسن الشيباني ، شرحه قاضي خان ت 592 ، مطبوع . مفتاح
السعادة ، كبرى زادة 2 / 263 .

⁽⁴⁷¹⁾ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى رقم 16451 ، عن سعيد بن المسيب (رضي الله عنه)

، أَوْ يُقَالُ : إِذَا لَمْ يَثْبُتِ الْبَدَلُ يَبْقَى بَيِّنًا بِلَا بَدَلٍ ، وَهُوَ فَاسِدٌ ، وَلَا بُدَّ مِنَ الْفَسْخِ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ⁽⁴⁷²⁾.

نكول أحد المتبايعين : "قَالَ: (وَإِنْ نَكَلَ أَحَدُهُمَا عَنِ الْيَمِينِ لَزِمَهُ دَعْوَى الْآخَرِ) لِأَنَّهُ جُعِلَ بَازِلًا فَلَمْ يَبْقَ دَعْوَاهُ مُعَارِضًا لِدَعْوَى الْآخَرِ فَلَزِمَ الْقَوْلُ بِنُبُوتِهِ⁽⁴⁷³⁾.

اختلاف المتبايعين في الأجل وما أشبهه : "قَالَ (وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الْأَجَلِ ، أَوْ فِي شَرْطِ الْخِيَارِ ، أَوْ فِي اسْتِيفَاءِ بَعْضِ الثَّمَنِ ، فَلَا تَحَالَفَ بَيْنَهُمَا) ، لِأَنَّ هَذَا اخْتِلَافٌ فِي غَيْرِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ، وَالْمَعْقُودِ بِهِ ، فَأَشْبَهَ الْاِخْتِلَافَ فِي الْحَطِّ وَالْإِبْرَاءِ ، وَهَذَا لِأَنَّ بَانْعِدَامِهِ لَا يَخْتُلُ مَا بِهِ قَوَامُ الْعَقْدِ ، بِخِلَافِ الْاِخْتِلَافِ فِي وَصْفِ الثَّمَنِ وَجِنْسِهِ حَيْثُ يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الْاِخْتِلَافِ فِي الْقَدْرِ فِي جَرَيَانِ التَّحَالَفِ ، لِأَنَّ ذَلِكَ يَرْجِعُ إِلَى نَفْسِ الثَّمَنِ ، فَإِنَّ الثَّمَنَ ذَيْنَ ، وَهُوَ يُعْرَفُ بِالْوَصْفِ ، وَلَا كَذَلِكَ الْأَجَلُ ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِوَصْفٍ ؛ أَلَا تَرَى أَنَّ الثَّمَنَ مَوْجُودٌ بَعْدَ مُضِيِّهِ.

قال: (وَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ يُنْكِرُ الْخِيَارَ وَالْأَجَلَ مَعَ يَمِينِهِ) لِأَنَّهُمَا يَنْتَبَتَانِ بِعَارِضِ الشَّرْطِ وَالْقَوْلِ لِمُنْكَرِ الْعَوَارِضِ.

اختلاف المتبايعين عند هلاك المبيع : "قَالَ: (فَإِنْ هَلَكَ الْمَبِيعُ ثُمَّ اخْتَلَفَا ، لَمْ يَتَحَالَفَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : يَتَحَالَفَانِ وَيُفْسَخُ الْبَيْعُ عَلَى قِيمَةِ الْهَالِكِ) ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ⁽⁴⁷⁴⁾ - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، وَعَلَى هَذَا إِذَا خَرَجَ الْمَبِيعُ عَنْ مِلْكِهِ أَوْ صَارَ بِحَالٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى رَدِّهِ بِالْعَيْبِ.

لَهُمَا : أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَدَّعِي غَيْرَ الْعَقْدِ الَّذِي يَدَّعِيهِ صَاحِبُهُ ، وَالْآخَرُ يُنْكِرُهُ ، وَأَنَّهُ يُفِيدُ دَفْعَ زِيَادَةِ الثَّمَنِ فَيَتَحَالَفَانِ ؛ كَمَا إِذَا اخْتَلَفَا فِي جِنْسِ الثَّمَنِ بَعْدَ هَلَاكِ السَّلْعَةِ ، وَلِأَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ : أَنَّ التَّحَالَفَ بَعْدَ الْقَبْضِ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ ، لِأَنَّهُ سَلَّمَ لِلْمُشْتَرِي مَا يَدَّعِيهِ ، وَقَدْ وَرَدَ الشَّرْعُ بِهِ فِي حَالِ قِيَامِ السَّلْعَةِ ، وَالتَّحَالَفُ فِيهِ يُفْضِي إِلَى الْفَسْخِ ، وَلَا كَذَلِكَ بَعْدَ هَلَاكِهَا ، لِارْتِفَاعِ الْعَقْدِ فَلَمْ يَكُنْ فِي مَعْنَاهُ ، وَلِأَنَّهُ لَا يُبَالِي بِالْاِخْتِلَافِ فِي السَّبَبِ بَعْدَ حُصُولِ الْمَقْصُودِ ، وَإِنَّمَا يَرَاعَى مِنَ الْفَائِدَةِ مَا يُوجِبُهُ الْعَقْدُ ، وَفَائِدَةُ دَفْعِ زِيَادَةِ الثَّمَنِ لَيْسَتْ

(472) ولأن الاختلاف في البديل يوجب الاختلاف في العقد، لأن كل واحد منهما ادعى عقداً غير الذي ادعاه الآخر فكان البيع مجهولاً لجهالة البديل. البناية 356/9.

(473) لعدم المعارض. وبهذا أخذت مجلة الأحكام العدلية ، نصت المادة 1742 منها على أنه "أحد أسباب الحكم اليميني أو النكول عن اليمين". وفي هذا. البناية 356/9.

(474) حاشية الشرواني على تحفة المحتاج 378/4.

مِنْ مُوجِبَاتِهِ ، وَهَذَا إِذَا كَانَ الثَّمَنُ دَيْنًا، فَإِنْ كَانَ عَيْنًا يَتَحَالَفَانِ ، لِأَنَّ الْمَبِيعَ فِي أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ قَائِمٌ قَنُوقَرٌ قَائِدَةُ الْفَسْخِ، ثُمَّ يَرُدُّ مِثْلَ الْهَالِكِ إِنْ كَانَ لَهُ مِثْلٌ أَوْ قِيمَتُهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِثْلٌ⁽⁴⁷⁵⁾.

اختلاف المتبايعين في الثمن عند هلاك أحد العبدَيْنِ ثُمَّ اخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ لَمْ يَتَحَالَفَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ إِلَّا أَنْ يَرْضَى الْبَائِعُ أَنْ يَتْرِكَ حِصَّةَ الْهَالِكِ مِنَ الثَّمَنِ، وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي مَعَ يَمِينِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْبَائِعُ أَنْ يَأْخُذَ الْعَبْدَ الْحَيَّ وَلَا شَيْءَ لَهُ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: يَتَحَالَفَانِ فِي الْحَيِّ وَيُفْسَخُ الْعَقْدُ فِي الْحَيِّ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي فِي قِيمَةِ الْهَالِكِ. وَقَالَ مُحَمَّدٌ: يَتَحَالَفَانِ عَلَيْهِمَا ، وَيَرُدُّ الْحَيَّ وَقِيمَةَ الْهَالِكِ) ، لِأَنَّ هَلَكَ كُلِّ السَّلْعَةِ لَا يَمْنَعُ التَّحَالَفَ عِنْدَهُ ، فَهَلَاكَ الْبَعْضِ أَوْلَى، وَلِأَبِي يُوسُفَ أَنَّ امْتِنَاعَ التَّحَالَفِ لِلْهَالِكِ فَيَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهِ.

وَلِأَبِي حَنِيفَةَ : أَنَّ التَّحَالَفَ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ فِي حَالِ قِيَامِ السَّلْعَةِ ، وَهِيَ اسْمُ لَجَمِيعِ أَجْزَائِهَا ، فَلَا تَبْقَى السَّلْعَةُ بِقَوَاتٍ بَعْضُهَا، وَلِأَنَّهُ لَا يُمَكِّنُ التَّحَالَفُ فِي الْقَائِمِ إِلَّا عَلَى اعْتِبَارِ حِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ ، فَلَا بُدَّ مِنَ الْقِسْمَةِ ، وَهِيَ تُعْرَفُ بِالْحَذَرِ وَالظَّنِّ فَيُؤَدِّي إِلَى التَّحَالَفِ مَعَ الْجَهْلِ ، وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ ، إِلَّا أَنْ يَرْضَى الْبَائِعُ أَنْ يَتْرِكَ حِصَّةَ الْهَالِكِ أَصْلًا ، لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ الثَّمَنُ كُلُّهُ بِمُقَابَلَةِ الْقَائِمِ ، وَيَخْرُجُ الْهَالِكُ عَنِ الْعَقْدِ فَيَتَحَالَفَانِ ، هَذَا تَخْرِيجُ بَعْضِ الْمَشَايخِ ، وَيُصْرَفُ الْإِسْتِثْنَاءُ عِنْدَهُمْ إِلَى التَّحَالَفِ كَمَا ذَكَرْنَا ، وَقَالُوا: إِنَّ الْمُرَادَ مِنْ قَوْلِهِ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ⁽⁴⁷⁶⁾: "يَأْخُذُ الْحَيَّ وَلَا شَيْءَ لَهُ"، مَعْنَاهُ: لَا يَأْخُذُ مِنْ ثَمَنِ الْهَالِكِ شَيْئًا أَصْلًا. وَقَالَ بَعْضُ الْمَشَايخِ: يَأْخُذُ مِنْ ثَمَنِ الْهَالِكِ بِقَدْرِ مَا أَقَرَّ بِهِ الْمُشْتَرِي، وَإِنَّمَا لَا يَأْخُذُ الزِّيَادَةَ.

وَعَلَى قَوْلِ هَؤُلَاءِ يَنْصَرِفُ الْإِسْتِثْنَاءُ إِلَى يَمِينِ الْمُشْتَرِي لَا إِلَى التَّحَالَفِ، لِأَنَّهُ لَمَّا أَخَذَ الْبَائِعُ بِقَوْلِ الْمُشْتَرِي فَقَدْ صَدَّقَهُ فَلَا يَخْلِفُ الْمُشْتَرِي، ثُمَّ تَفْسِيرُ التَّحَالَفِ عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ مَا بَيَّنَّاهُ فِي الْقَائِمِ. وَإِذَا حَلَفَا وَلَمْ يَتَّفَقَا عَلَى شَيْءٍ فَادَّعَى أَحَدُهُمَا الْفَسْخَ أَوْ كِلَاهُمَا يُفْسَخُ الْعَقْدُ بَيْنَهُمَا وَيَأْمُرُ الْقَاضِي الْمُشْتَرِي بِرَدِّ الْبَاقِي وَقِيمَةِ الْهَالِكِ.

وَاخْتَلَفُوا فِي تَفْسِيرِهِ عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَخْلِفُ الْمُشْتَرِي بِاللَّهِ مَا اشْتَرَيْتُهُمَا بِمَا يَدَّعِيهِ الْبَائِعُ، فَإِنْ نَكَلَ لَزِمَهُ دَعْوَى الْبَائِعِ، وَإِنْ حَلَفَ يَخْلِفُ الْبَائِعُ بِاللَّهِ مَا بَعَثَهُمَا بِالثَّمَنِ الَّذِي يَدَّعِيهِ الْمُشْتَرِي، فَإِنْ نَكَلَ لَزِمَهُ دَعْوَى الْمُشْتَرِي، وَإِنْ

⁽⁴⁷⁵⁾ أي : أو يرد قيمته (إن لم يكن له مثل) ، كالحیوان فیما إذا تبايعا حیواناً بحیوان .
البنایة 360/9.

⁽⁴⁷⁶⁾ الجامع الصغير كتاب صنفه محمد بن الحسن الشيباني ، أحد كتب ظاهر الرواية . مفتاح السعادة 263/2.

حَلَفَ يَفْسَخَانِ الْعَقْدَ فِي الْقَائِمِ وَتَسْقُطُ حِصَّتُهُ مِنَ الثَّمَنِ وَيُلْزَمُ الْمُشْتَرِي حِصَّةَ الْهَالِكِ وَيُعْتَبَرُ قِيمَتُهُمَا فِي الْإِنْقِسَامِ يَوْمَ الْقَبْضِ⁽⁴⁷⁷⁾.

اختلاف المتبايعين في قيمة الهالك يوم القبض: "وَإِنْ اُخْتَلَفَا فِي قِيَمَةِ الْهَالِكِ يَوْمَ الْقَبْضِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ ، وَأَيُّهُمَا أَقَامَ الْبَيِّنَةُ ، تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ ، وَإِنْ أَقَامَاهَا ، فَبَيِّنَةُ الْبَائِعِ أُولَى) ، وَهُوَ قِيَاسُ مَا ذُكِرَ فِي بُيُوعِ الْأَصْلِ (اشْتَرَى عَبْدَيْنِ وَقَبَضَهُمَا ثُمَّ رَدَّ أَحَدَهُمَا بِالْعَيْبِ وَهَلَكَ الْآخَرُ عِنْدَهُ يَجِبُ عَلَيْهِ ثَمَنُ مَا هَلَكَ عِنْدَهُ وَيَسْقُطُ عَنْهُ ثَمَنُ مَا رَدَّهُ وَيَنْقَسِمُ الثَّمَنُ عَلَى قِيَمَتَيْهِمَا . فَإِنْ اُخْتَلَفَا فِي قِيَمَةِ الْهَالِكِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ) لِأَنَّ الثَّمَنَ قَدْ وَجَبَ بِاتِّفَاقِهِمَا ثُمَّ الْمُشْتَرِي يَدَّعِي زِيَادَةَ السُّقُوطِ بِنُقْصَانِ قِيَمَةِ الْهَالِكِ وَالْبَائِعُ يُنْكِرُهُ وَالْقَوْلُ لِلْمُنْكَرِ (وَإِنْ أَقَامَا الْبَيِّنَةَ فَبَيِّنَةُ الْبَائِعِ أُولَى) لِأَنَّهَا أَكْثَرُ إِبْتَاتًا ظَاهِرًا لِإِتْبَاتِهَا الزِّيَادَةَ فِي قِيَمَةِ الْهَالِكِ وَهَذَا لِفَقْهِ ، وَهُوَ أَنَّ فِي الْإِيمَانِ تُعْتَبَرُ الْحَقِيقَةُ ، لِأَنَّهَا تَتَوَجَّهُ عَلَى أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ ، وَهُمَا يَعْرِفَانِ حَقِيقَةَ الْحَالِ فَبَيِّنَةُ الْأَمْرِ عَلَيْهَا ، وَالْبَائِعُ مُنْكَرٌ حَقِيقَةً فَلِذَا كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ ، وَفِي الْبَيِّنَاتِ يُعْتَبَرُ الظَّاهِرُ ، لِأَنَّ الشَّاهِدَيْنِ لَا يَعْلَمَانِ حَقِيقَةَ الْحَالِ ، فَاعْتَبِرَ الظَّاهِرُ فِي حَقِّهِمَا ، وَالْبَائِعُ مُدَّعٍ ظَاهِرًا فَلِهَذَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ أَيْضًا ، وَتَتَرَجَّحُ بِالزِّيَادَةِ الظَّاهِرَةِ عَلَى مَا مَرَّ ، وَهَذَا يُبَيِّنُ لَكَ مَعْنَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ .

الإقالة واختلاف المتبايعين في ثمن الجارية: "قَالَ (وَمَنْ اشْتَرَى جَارِيَةً وَقَبَضَهَا ثُمَّ تَقَايَلَا ثُمَّ اُخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ فَإِنَّهُمَا يَتَحَالَفَانِ وَيَعُودُ الْبَيْعُ الْأَوَّلُ) وَنَحْنُ مَا أَثْبَتْنَا التَّحَالَفَ فِيهِ بِالنَّصِّ لِأَنَّهُ وَرَدَ فِي الْبَيْعِ الْمَطْلُوقِ وَالْإِقَالَةِ فَسُخِّ فِي حَقِّ الْمُتَعَاقِدَيْنِ ، وَإِنَّمَا أَثْبَتْنَاهُ بِالْقِيَاسِ لِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ مَفْرُوضَةٌ قَبْلَ الْقَبْضِ ، وَالْقِيَاسُ يُوَافِقُهُ عَلَى مَا مَرَّ ، وَلِهَذَا نَقِيسُ الْإِجَارَةَ عَلَى الْبَيْعِ قَبْلَ الْقَبْضِ ، وَالْوَارِثُ عَلَى الْعَاقِدِ ، وَالْقِيَمَةُ عَلَى الْعَيْنِ فِيمَا إِذَا اسْتَهْلَكَهُ فِي يَدِ الْبَائِعِ غَيْرُ الْمُشْتَرِي .

قَالَ (وَلَوْ قَبَضَ الْبَائِعُ الْمَبِيعَ بَعْدَ الْإِقَالَةِ فَلَا تَحَالَفَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ) لِأَنَّهُ يَرَى النَّصَّ مَعْلُومًا بَعْدَ الْقَبْضِ أَيْضًا .

السلم واختلاف المتبايعين في الثمن: "قَالَ (وَمَنْ أَسْلَمَ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ فِي كُرٍّ حِنْطَةٍ ثُمَّ تَقَايَلَا ثُمَّ اُخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُسْلِمِ إِلَيْهِ ، وَلَا يَعُودُ السَّلْمُ⁽⁴⁷⁸⁾) ، لِأَنَّ الْإِقَالَةَ فِي بَابِ السَّلْمِ لَا تَحْتَمِلُ النُّقْصَ ، لِأَنَّهُ إِسْقَاطٌ فَلَا يَعُودُ السَّلْمُ ، بِخِلَافِ الْإِقَالَةِ فِي الْبَيْعِ؛ أَلَا تَرَى أَنَّ رَأْسَ مَالِ السَّلْمِ لَوْ كَانَ عَرْضًا فَرَدَّهُ بِالْعَيْبِ ، وَهَلَكَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ إِلَى رَبِّ السَّلْمِ لَا يَعُودُ السَّلْمُ ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ فِي بَيْعِ الْعَيْنِ يَعُودُ الْبَيْعُ دَلَّ عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا .

(477) الأصل المعروف بالمبسوط ، للإمام محمد بن الحسن 5/ 70 ، البناية على الهداية 360/9 ، 361 ، الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير ص 340 .

(478) وهو في اللغة: التقديم والتسليم وكذلك السلف، وهو في الشرع: اسم لعقد يوجب الملك في الثمن عاجلا وفي المثلثن أجلا، وسمي به لما فيه من وجوب تقديم الثمن . الاختيار لتعليل المختار 33/2 ، المعرب ص 231 .

اختلاف الزوجين في المهر : "قَالَ (وَإِذَا اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي الْمَهْرِ فَادَّعَى الزَّوْجُ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِأَلْفٍ وَقَالَتْ تَزَوَّجَنِي بِأَلْفَيْنِ فَأَيُّهُمَا أَقَامَ الْبَيِّنَةُ تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ) ، لِأَنَّهُ نَوَّرَ دَعْوَاهُ بِالْحُجَّةِ .

(وَإِنْ أَقَامَا الْبَيِّنَةَ فَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الْمَرْأَةِ) ، لِأَنَّهُا تُثَبِّتُ الزِّيَادَةَ، مَعْنَاهُ : إِذَا كَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا أَقَلَّ مِمَّا ادَّعَتْهُ ، (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ تَحَالَفَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَلَا يُفْسَخُ النِّكَاحُ) ، لِأَنَّ أَثَرَ التَّحَالِفِ فِي انْعِدَامِ التَّسْمِيَةِ، وَأَنَّهُ لَا يُخْلُ بِصِحَّةِ النِّكَاحِ ، لِأَنَّ الْمَهْرَ تَابِعٌ فِيهِ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ ، لِأَنَّ عَدَمَ التَّسْمِيَةِ يُفْسِدُهُ عَلَى مَا مَرَّ فَيُفْسَخُ، (وَلَكِنْ يَحْكُمُ مَهْرُ الْمِثْلِ، فَإِنْ كَانَ مِثْلَ مَا اعْتَرَفَ بِهِ الزَّوْجُ أَوْ أَقَلَّ ، قَضَى بِمَا قَالَ الزَّوْجُ) ، لِأَنَّ الظَّاهِرَ شَاهِدٌ لَهُ ، (وَإِنْ كَانَ مِثْلَ مَا ادَّعَتْهُ الْمَرْأَةُ أَوْ أَكْثَرَ قَضَى بِمَا ادَّعَتْهُ الْمَرْأَةُ، وَإِنْ كَانَ مَهْرُ الْمِثْلِ أَكْثَرَ مِمَّا اعْتَرَفَ بِهِ الزَّوْجُ وَأَقَلَّ مِمَّا ادَّعَتْهُ الْمَرْأَةُ ، قَضَى لَهَا بِمَهْرِ الْمِثْلِ) ، لِأَنَّهُمَا لَمَّا تَحَالَفَا ، لَمْ تُثَبِّتِ الزِّيَادَةُ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ وَلَا الْحُطُّ عَنْهُ.

قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : ذَكَرَ التَّحَالِفَ أَوَّلًا ثُمَّ التَّحْكِيمَ، وَهَذَا قَوْلُ الْكَرْخِيِّ⁽⁴⁷⁹⁾ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لِأَنَّ مَهْرَ الْمِثْلِ لَا اعْتِبَارَ لَهُ مَعَ وُجُودِ التَّسْمِيَةِ ، وَسُقُوطِ اعْتِبَارِهَا بِالتَّحَالِفِ وَلِهَذَا يُقَدَّمُ فِي الْوُجُوهِ كُلِّهَا، وَيَبْدَأُ بَيَمِينَ الزَّوْجِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ تَعْجِيلًا لِفَائِدَةِ النُّكُولِ كَمَا فِي الْمُشْتَرِي، وَتَخْرِيجِ الرَّازِيِّ بِخِلَافِهِ وَقَدْ اسْتَفْصَيْنَاهُ فِي النِّكَاحِ وَذَكَرْنَا خِلَافَ أَبِي يُوسُفَ فَلَا نُعِيدُهُ⁽⁴⁸⁰⁾ .

اختلاف الزوجين في نكاح العبد : "(وَلَوْ ادَّعَى الزَّوْجُ النِّكَاحَ عَلَى هَذَا الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةُ تَدَّعِيهِ عَلَى هَذِهِ الْجَارِيَةِ فَهُوَ كَالْمَسْأَلَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ، إِلَّا أَنَّ قِيَمَةَ الْجَارِيَةِ إِذَا كَانَتْ مِثْلَ مَهْرِ الْمِثْلِ يَكُونُ لَهَا قِيَمَتُهَا دُونَ عَيْنِهَا) ، لِأَنَّ تَمْلُكَهَا لَا يَكُونُ إِلَّا بِالتَّرَاضِي ، وَلَمْ يُوجَدْ فَوَجَبَتْ الْقِيَمَةُ .

اختلاف المؤجر والمستأجر قبل استيفاء المعقود عليه : "(وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الْإِجَارَةِ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ، تَحَالَفَا وَتَرَادَا) ، مَعْنَاهُ : اخْتَلَفَا فِي الْبَدَلِ أَوْ فِي الْمُبْدَلِ ، لِأَنَّ التَّحَالِفَ فِي الْبَيْعِ قَبْلَ الْقَبْضِ عَلَى وَفَاقِ الْقِيَاسِ عَلَى مَا مَرَّ، وَالْإِجَارَةُ قَبْلَ الْقَبْضِ ، الْمَنْفَعَةُ نَظِيرُ الْبَيْعِ قَبْلَ قَبْضِ الْمَبِيعِ وَكَلَامُنَا قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ ، (فَإِنْ وَقَعَ الْاِخْتِلَافُ فِي الْأَجْرَةِ يَبْدَأُ بَيَمِينَ الْمُسْتَأْجِرِ)، لِأَنَّهُ مُنْكَرٌ لَوْجُوبِ الْأَجْرَةِ ، (وَإِنْ وَقَعَ فِي الْمَنْفَعَةِ يَبْدَأُ بَيَمِينَ الْمُؤْجِرِ، وَأَيُّهُمَا

(479) عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دلهم ، أبو الحسن الكرخي ، كرخ حدان ، انتهت إليه رئاسة أصحاب أبي حنيفة بعد أبي خازم وأبي سعيد البردعي ، وانتشرت أصحابه ، وعنه أخذ أبو بكر الرازي ، وأبو عبد الله الدامغاني ، وأبو علي الشاشي ، وأبو القاسم علي بن محمد التنوخي ، وتوفي ليلة النصف من شعبان سنة أربعين وثلاث مائة، ذكره في الأنساب في باب الدلال وفي باب الكرخي . الجواهر المضوية في طبقات الحنفية ، لعبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي، أبو محمد، محيي الدين الحنفي (المتوفى: 775هـ) 337/1.

(480) وَهُوَ أَنَّ الْقَوْلَ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ قَوْلُ الزَّوْجِ قَبْلَ الطَّلَاقِ وَبَعْدَهُ ، إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِشَيْءٍ مُسْتَنَكِرٍ: يَعْنِي فِي بَابِ الْمَهْرِ فَلَا نُعِيدُهُ . العناية 231/8.

نَكَلَ لَزَمَهُ دَعْوَى صَاحِبِهِ، وَائْتُهُمَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ قُبِلَتْ، وَلَوْ أَقَامَهَا ، فَبَيِّنَةُ الْمُؤَجَّرِ أُولَى إِنْ كَانَ الْإِخْتِلَافُ فِي الْأُجْرَةِ، وَإِنْ كَانَ فِي الْمَنَافِعِ فَبَيِّنَةُ الْمُسْتَأْجِرِ أُولَى، وَإِنْ كَانَ فِيهِمَا ، قُبِلَتْ بَيِّنَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِيمَا يَدَّعِيهِ مِنَ الْفَضْلِ) نَحْوُ أَنْ يَدَّعِيَ هَذَا شَهْرًا بَعَشْرَةً ، وَالْمُسْتَأْجِرُ شَهْرَيْنِ بِخَمْسَةِ يَفْضِي بِشَهْرَيْنِ بَعَشْرَةً.

اختلاف المؤجر والمستأجر بعد استيفاء جميع المعقود عليه : "قَالَ (وَإِنْ اخْتَلَفَا بَعْدَ اسْتِيفَاءِ ، لَمْ يَتَحَالَفَا ، وَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُسْتَأْجِرِ)، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ ظَاهِرٌ، لِأَنَّ هَلَكَ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ يَمْنَعُ التَّحَالَفَ عِنْدَهُمَا، وَكَذَا عَلَى أَصْلِ مُحَمَّدٍ ، لِأَنَّ الْهَلَكَ إِنَّمَا لَا يُمْنَعُ عِنْدَهُ فِي الْمَبِيعِ لِمَا أَنَّ لَهُ قِيمَةً تَقُومُ مَقَامَهُ فَيَتَحَالَفَانِ عَلَيْهَا، وَلَوْ جَرَى التَّحَالَفُ هَاهُنَا وَفَسَخَ الْعَقْدُ ، فَلَا قِيمَةَ ، لِأَنَّ الْمَنَافِعَ لَا تَتَقَوَّمُ بِنَفْسِهَا ، بَلْ بِالْعَقْدِ وَتَبَيَّنَ أَنَّهُ لَا عَقْدَ، وَإِذَا امْتَنَعَ فَأَلْقَوْلُ لِلْمُسْتَأْجِرِ مَعَ يَمِينِهِ لِأَنَّهُ هُوَ الْمُسْتَحَقُّ عَلَيْهِ (481).

اختلاف المؤجر والمستأجر بعد استيفاء بعض المعقود عليه : "وَإِنْ اخْتَلَفَا بَعْدَ اسْتِيفَاءِ بَعْضِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ تَحَالَفَا وَفَسَخَ الْعَقْدُ فِيمَا بَقِيَ ، وَكَانَ الْقَوْلُ فِي الْمَاضِي قَوْلَ الْمُسْتَأْجِرِ)، لِأَنَّ الْعَقْدَ يَنْعَقِدُ سَاعَةً فَسَاعَةً فَيَصِيرُ فِي كُلِّ جُزْءٍ مِنَ الْمُنْفَعَةِ كَأَنَّ ابْتِدَاءَ الْعَقْدِ عَلَيْهَا، بِخِلَافِ الْبَيْعِ ، لِأَنَّ الْعَقْدَ فِيهِ دَفْعَةٌ وَاحِدَةٌ، فَإِذَا تَعَدَّرَ فِي الْبَعْضِ تَعَدَّرَ فِي الْكُلِّ (482).

اختلاف المولى والمكاتب في مال الكتابة : "قَالَ (وَإِذَا اخْتَلَفَ الْمَوْلَى وَالْمُكَاتَبُ فِي مَالِ الْكِتَابَةِ لَمْ يَتَحَالَفَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ. وَقَالَا: يَتَحَالَفَانِ وَتُفْسَخُ الْكِتَابَةُ) وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ لِأَنَّهُ عَقْدٌ مُعَاوَضَةٌ يَقْبَلُ الْفَسْخَ فَأَشْبَهَ الْبَيْعَ (483)، وَالْجَامِعُ أَنَّ الْمَوْلَى يَدَّعِي بَدَلًا زَائِدًا يُنْكِرُهُ الْعَبْدُ وَالْعَبْدُ يَدَّعِي اسْتِحْقَاقَ الْعَتَقِ عَلَيْهِ عِنْدَ آدَاءِ الْقَدْرِ الَّذِي يَدَّعِيهِ وَالْمَوْلَى يُنْكِرُهُ فَيَتَحَالَفَانِ كَمَا إِذَا اخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ، وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْبَدَلَ مُقَابِلُ بَقَا الْحَبْرِ فِي حَقِّ الْيَدِ وَالتَّصَرُّفِ لِلْحَالِ وَهُوَ سَالِمٌ لِلْعَبْدِ وَإِنَّمَا يَنْقَلِبُ مُقَابِلًا بِالْعَتَقِ عِنْدَ الْآدَاءِ فَقَبْلَهُ لَا مُقَابِلَةَ ، فَبَقِيَ اخْتِلَافًا فِي قَدْرِ الْبَدَلِ لَا غَيْرُ فَلَا يَتَحَالَفَانِ.

اختلاف الزوجين في متاع البيت : "قَالَ (وَإِذَا اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ فَمَا يَصْلُحُ لِلرِّجَالِ فَهُوَ لِلرِّجَالِ ، كَالْعِمَامَةِ) ، لِأَنَّ الظَّاهِرَ شَاهِدٌ لَهُ (وَمَا يَصْلُحُ لِلنِّسَاءِ فَهُوَ لِلْمَرَأَةِ ، كَالْوَقَايَةِ) ، لِشَهَادَةِ الظَّاهِرِ لَهَا (وَمَا يَصْلُحُ لَهُمَا ، كَالْأَنْيَةِ فَهُوَ لِلرِّجْلِ) ، لِأَنَّ الْمَرَأَةَ وَمَا فِي يَدِهَا فِي يَدِ الزَّوْجِ ، وَالْقَوْلُ فِي الدَّعَاوَى لِصَاحِبِ الْيَدِ، بِخِلَافِ مَا يَخْتَصُّ بِهَا ، لِأَنَّهُ يُعَارِضُهُ ظَاهِرٌ أَقْوَى مِنْهُ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ مَا إِذَا كَانَ الْإِخْتِلَافُ فِي حَالِ قِيَامِ النِّكَاحِ أَوْ بَعْدَمَا وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ.

(481) ومتى وقع الخلاف في الاستحقاق كان القول قول المستحق عليه مع يمينه . البناية 371/9.

(482) أى : فإذا تعذر الفسخ في بعضه بالهلاك ، تعذر في الكل ضرورة ، فظهر الفرق. البناية 372/9.

(483) البيان فى مذهب الشافعى 503/8.

اختلاف أحد ورثة الزوجين في متاع البيت : (فَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا وَاخْتَلَفَتْ وَرَثَتُهُ مَعَ الْآخَرِ ، فَمَا يَصْلُحُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَهُوَ لِلْبَاقِي مِنْهُمَا) ، لِأَنَّ الْيَدَ لِلْحَيِّ دُونَ الْمَيِّتِ ، وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ.

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: يَدْفَعُ إِلَى الْمَرْأَةِ مَا يُجَهِّزُ بِهِ مِثْلَهَا، وَالْبَاقِي لِلزَّوْجِ مَعَ يَمِينِهِ ، لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْمَرْأَةَ تَأْتِي بِالْجِهَازِ ، وَهَذَا أَقْوَى فَيَبْطُلُ بِهِ ظَاهِرُ يَدِ الزَّوْجِ، ثُمَّ فِي الْبَاقِي لَا مُعَارِضَ لِظَاهِرٍ فَيُعْتَبَرُ (وَالطَّلَاقُ وَالْمَوْتُ سَوَاءٌ) لِإِقْيَامِ الْوَرَثَةِ مَقَامَ مُورَثِهِمْ (وَقَالَ مُحَمَّدٌ: وَمَا كَانَ لِلرِّجَالِ فَهُوَ لِلرَّجُلِ، وَمَا كَانَ لِلنِّسَاءِ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ، وَمَا يَكُونُ لَهُمَا ، فَهُوَ لِلرَّجُلِ أَوْ لَوَرَثَتِهِ) لِمَا قُلْنَا لِأَبِي حَنِيفَةَ (وَالطَّلَاقُ وَالْمَوْتُ سَوَاءٌ) لِإِقْيَامِ الْوَارِثِ مَقَامَ الْمُورِثِ (وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مَمْلُوكًا فَالْمَتَاعُ لِلْحُرِّ فِي حَالَةِ الْحَيَاةِ) ، لِأَنَّ يَدَ الْحُرِّ أَقْوَى (وَالْحَيُّ بَعْدَ الْمَمَاتِ) ، لِأَنَّهُ لَا يَدَ لِلْمَيِّتِ فَخَلَّتْ يَدُ الْحَيِّ عَنِ الْمُعَارِضِ (وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَقَالَا: الْعَبْدُ الْمَأْدُونُ لَهُ فِي التِّجَارَةِ وَالْمُكَاتَبُ بِمَنْزِلَةِ الْحُرِّ) لِأَنَّ لَهُمَا يَدًا مُعْتَبَرَةً فِي الْخُصُومَاتِ.

(فصل فيمن لا يكون خصماً)

اندفاع خصومة المدعى عليه بقوله : أودعني فلان الغائب وما أشبهه : "(وَإِنْ قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ هَذَا الشَّيْءُ : أَوْدَعَنِي فَلَانُ الْغَائِبُ أَوْ رَهَنَهُ عِنْدِي أَوْ غَصَبْتُهُ مِنْهُ ، وَأَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى ذَلِكَ ، فَلَا خُصُومَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُدَّعِي) وَكَذَا إِذَا قَالَ: أَجْرَنِيهِ ، وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ ، لِأَنَّهُ أَثْبَتَ بَيِّنَتَهُ أَنَّ يَدَهُ لَيْسَتْ بِيدِ خُصُومَةٍ.

وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ⁽⁴⁸⁴⁾: لَا تَنْدَفِعُ الْخُصُومَةُ ، لِأَنَّهُ تَعَذَّرَ إَثْبَاتُ الْمَلِكِ لِلْغَائِبِ لِعَدَمِ الْخَصْمِ عَنْهُ وَدَفْعُ الْخُصُومَةِ بِنَاءً عَلَيْهِ⁽⁴⁸⁵⁾.

قُلْنَا: مُقْتَضَى الْبَيِّنَةِ شَيْئَانِ ، ثُبُوتُ الْمَلِكِ لِلْغَائِبِ ، وَلَا خَصْمَ فِيهِ فَلَمْ يَثْبُتْ، وَدَفْعُ خُصُومَةِ الْمُدَّعِي ، وَهُوَ خَصْمٌ فِيهِ فَيَثْبُتُ ، وَهُوَ كَالْوَكِيلِ بِنَفْلِ الْمَرْأَةِ ، وَإِقَامَتِهَا الْبَيِّنَةَ عَلَى الطَّلَاقِ ، كَمَا بَيَّنَّاهُ مِنْ قَبْلُ، وَلَا تَنْدَفِعُ بِدُونِ إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ كَمَا قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى⁽⁴⁸⁶⁾ ، لِأَنَّهُ صَارَ خَصْماً بَظَاهِرِ يَدِهِ، فَهُوَ بِإِقْرَارِهِ يُرِيدُ أَنْ يُحَوَّلَ حَقًّا مُسْتَحَقًّا عَلَى نَفْسِهِ ، فَلَا يَصْدُقُ إِلَّا بِالْحُجَّةِ، كَمَا إِذَا ادَّعَى تَحَوُّلَ الدَّيْنِ مِنْ دِمَّتِهِ إِلَى دِمَّةٍ غَيْرِهِ.

(وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: إِنْ كَانَ الرَّجُلُ صَالِحًا ، فَالْجَوَابُ كَمَا قُلْنَا، وَإِنْ كَانَ مَعْرُوفًا بِالْحِيلِ ، لَا تَنْدَفِعُ عَنْهُ الْخُصُومَةُ) ، لِأَنَّ الْمُحْتَالَ مِنَ النَّاسِ قَدْ يَدْفَعُ مَالَهُ إِلَى مُسَافِرٍ يُودِعُهُ إِيَّاهُ وَيَشْهَدُ عَلَيْهِ الشُّهُودُ فَيَحْتَالُ لِإِبْطَالِ حَقِّ غَيْرِهِ، فَإِذَا اتَّهَمَهُ الْقَاضِي بِهِ لَا يَقْبَلُهُ.

(⁴⁸⁴) هو: أبو شبرمة، عبد الله بن شبرمة - بضم المعجمة، وسكون الموحدة، وضم الراء - ابن الطفيل بن حسان، الضبي، الكوفي، القاضي، توفي سنة أربع وأربعين ومائة، من الخامسة، ثقة، فقيه. المعجم الصغير لرواة الإمام ابن جرير الطبري، لأكرم بن محمد زيادة الفالوجي الأثري 799/2.

(⁴⁸⁵) أي دفع الخصومة عن الغائب، وإثبات الملك للغائب بدون الخصومة متعذر، إذ ليس لأحد ولاية إدخال شيء في ملك غيره بغير رضاه، (ودفع الخصومة بناء عليه) : أي على إثبات الملك والبناء على المتعذر متعذر، وقد أخذت مجلة الأحكام العدلية بقول الحنفية ، نصت المادة 1742 منها على أنه "أحد أسباب الحكم اليمين أو النكول عن اليمين وهو أنه إذا أظهر المدعي عجزه عن إثبات دعواه يحلف المدعي عليه بطلبه ولكن إذا ادعى أحد على آخر قائلاً: أنت وكيل فلان وأنكر الوكالة فلا يلزم تحليفه، كذلك إذا ادعى كل من الشخصين المال الذي هو في يد آخر بأنه اشتراه منه وأقر المدعي عليه بأنه باعه لأحدهما وأنكر دعوى الآخر فلا يتوجه عليه اليمين والاستتجار والإرتهان والاثتهاب كالإشتراء في هذا الخصوص" وفي هذا : البناية 376/9.

(⁴⁸⁶) محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى يسار (وقيل: داود) ابن بلال الأنصاري الكوفي: قاض، فقيه، من أصحاب الرأي. ولي القضاء والحكم بالكوفة لبني أمية، ثم لبني العباس. واستمر 33 سنة ، له أخبار مع الإمام أبي حنيفة وغيره. مات بالكوفة سنة 148 هـ. الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة ، لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي (المتوفى: 74هـ/193، الوافي بالوفيات 184/3، 185.

لاتندفع الخصومة عن المدعى عليه بقول الشهود: أودعه رجل لانعرفه : "(وَلَوْ قَالَ الشُّهُودُ: أَوْدَعَهُ رَجُلٌ لَا نَعْرِفُهُ لَا تَنْدَفِعُ عَنْهُ الْخُصُومَةُ) ، لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْمُودِعُ هُوَ هَذَا الْمُدَّعِي، وَلِأَنَّهُ مَا أَحَالَهُ إِلَى مُعَيَّنٍ يُمَكِّنُ لِلْمُدَّعِي اتِّبَاعَهُ، فَلَوْ انْدَفَعَتْ لَتَضَرَّرَ بِهِ الْمُدَّعِي، وَلَوْ قَالُوا: نَعْرِفُهُ بِوَجْهِهِ وَلَا نَعْرِفُهُ بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ ، فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ ، لِلْوَجْهِ الثَّانِي، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ تَنْدَفِعُ ، لِأَنَّهُ أَثْبَتَ بَيِّنَتَهُ أَنَّ الْعَيْنَ وَصَلَ إِلَيْهِ مِنْ جِهَةٍ غَيْرِهِ حَيْثُ عَرَفَهُ الشُّهُودُ بِوَجْهِهِ، بِخِلَافِ الْفَصْلِ الْأَوَّلِ ، فَلَمْ تَكُنْ يَدُهُ يَدَ خُصُومَةٍ ، وَهُوَ الْمَقْصُودُ، وَالْمُدَّعِي هُوَ الَّذِي أَضَرَّ بِنَفْسِهِ حَيْثُ نَسِيَ خَصْمَهُ أَوْ أَضَرَّهُ شُهُودُهُ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مُخَمَّسَةٌ كِتَابِ الدَّعْوَى وَقَدْ ذَكَرْنَا الْأَقْوَالَ الْخَمْسَةَ.

لا تندفع الخصومة عن المدعى عليه بقوله : ابتعته من الغائب : "(وَإِنْ قَالَ: ابْتَعْتُهُ مِنَ الْغَائِبِ فَهُوَ خَصْمٌ) ، لِأَنَّهُ لَمَّا زَعَمَ أَنَّ يَدَهُ يَدَ مَلِكٍ اعْتَرَفَ بِكَوْنِهِ خَصْمًا ، (وَإِنْ قَالَ الْمُدَّعِي: غَصَبْتُهُ مِنِّي أَوْ سَرَقْتُهُ مِنِّي ، لَا تَنْدَفِعُ الْخُصُومَةُ وَإِنْ أَقَامَ ذُو الْيَدِ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْوَدِيعَةِ)، لِأَنَّهُ إِنَّمَا صَارَ خَصْمًا بِدَعْوَى الْفِعْلِ عَلَيْهِ لَا بِيَدِهِ، بِخِلَافِ دَعْوَى الْمَلِكِ الْمُطْلَقِ ، لِأَنَّهُ خَصْمٌ فِيهِ بِاعْتِبَارِ يَدِهِ حَتَّى لَا يَصِحَّ دَعْوَاهُ عَلَى غَيْرِ ذِي الْيَدِ، وَيَصِحُّ دَعْوَى الْفِعْلِ.

اندفاع الخصومة في دعوى السرقة بقول صاحب اليد : أودعني فلان : "(وَإِنْ قَالَ الْمُدَّعِي: سَرَقَ مِنِّي ، وَقَالَ صَاحِبُ الْيَدِ: أَوْدَعَنِي فَلَانٌ ، وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ لَمْ تَنْدَفِعِ الْخُصُومَةُ) وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَهُوَ اسْتِحْسَانٌ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ: تَنْدَفِعُ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَدَّعِ الْفِعْلَ عَلَيْهِ فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ: غَصِبَ مِنِّي عَلَى مَا لَمْ يُسَمِّ فَاعِلُهُ، وَلَهُمَا : أَنَّ ذِكْرَ الْفِعْلِ يَسْتَدْعِي الْفَاعِلَ لَا مَحَالَةَ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ هُوَ الَّذِي فِي يَدِهِ ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُعَيِّنْهُ دَرَاءً لِلْحَدِّ شَفَقَةً عَلَيْهِ وَإِقَامَةً لِحِسْبَةِ السَّرِّ ، فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ: سَرَقْتَ، بِخِلَافِ الْغَصَبِ ، لِأَنَّهُ لَا حَدَّ فِيهِ فَلَا يُحْتَرَزُ عَنْ كَشْفِهِ⁽⁴⁸⁷⁾.

اندفاع الخصومة في دعوى البيع بقول صاحب اليد : أودعني فلان : "(وَإِنْ قَالَ الْمُدَّعِي: ابْتَعْتُهُ مِنْ فَلَانٍ ، وَقَالَ صَاحِبُ الْيَدِ: أَوْدَعَنِي فَلَانٌ ذَلِكَ ، أَسْقَطَتْ الْخُصُومَةُ بغير بَيِّنَةٍ) ، لِأَنَّهُمَا تَوَافَقَا عَلَى أَنَّ أَصْلَ الْمَلِكِ فِيهِ لِغَيْرِهِ فَيَكُونُ وَصُولُهَا إِلَى يَدِ ذِي الْيَدِ مِنْ جِهَتِهِ ، فَلَمْ تَكُنْ يَدُهُ يَدَ خُصُومَةٍ ، إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّ فَلَانًا وَكَلَّهُ بِقَبْضِهِ ، لِأَنَّهُ أَثْبَتَ بَيِّنَتَهُ كَوْنَهُ أَحَقَّ بِإِمْسَاكِهَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(487) ولأنه غير معذور في التجهيل . البناية 380/9.

(بَابُ مَا يَدْعِيهِ الرَّجُلَانِ)

إذا ادعى اثنان عينا في يد ثالث ببيئتهما : "قَالَ (وَإِذَا ادَّعى اثنان عينا في يد آخر كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَزْعُمُ أَنَّهَا لَهُ ، وَأَقَامَا الْبَيِّنَةَ قَضَىٰ بِهَا بَيْنَهُمَا) (488) ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي قَوْلٍ: تَهَاتَرَتَا (489)، وَفِي قَوْلٍ يُفَرِّعُ بَيْنَهُمَا (490)؛ لِأَنَّ إِحْدَى الْبَيِّنَتَيْنِ كَاذِبَةٌ بَيِّقِينَ ، لِاسْتِحَالَةِ اجْتِمَاعِ الْمَلَكَيْنِ فِي الْكُلِّ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَقَدْ تَعَذَّرَ التَّمْيِيزُ فَيَتَهَاتَرَانِ أَوْ يُصَارُ إِلَى الْفُرْعَةِ ، "لِأَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أَفْرَعَ فِيهِ وَقَالَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ الْحَكَمُ بَيْنَهُمَا (491)" ، وَلَنَا حَدِيثُ تَمِيمِ بْنِ طَرْفَةَ : " أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فِي نَاقَةٍ وَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ ، فَقَضَىٰ بِهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ (492)" .

وَحَدِيثُ الْفُرْعَةِ كَانَ فِي الْإِبْتِدَاءِ ثُمَّ نُسِخَ، وَلِأَنَّ الْمُطْلَقَ لِلشَّهَادَةِ فِي حَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُحْتَمَلُ الْوُجُودِ ، بَلْ يَعْتَمِدُ أَحَدُهُمَا سَبَبَ الْمَلِكِ ، وَالْآخِرُ الْيَدَ ، فَصَحَّتِ الشَّهَادَتَانِ ، فَيَجِبُ الْعَمَلُ بِهِمَا مَا أُمِّكَنْ، وَقَدْ أُمِّكَنْ بِالنَّصِيفِ ، إِذُ الْمَحِلُّ يَقْبَلُهُ، وَإِنَّمَا يُنْصَفُ لِاسْتَوَائِهِمَا فِي سَبَبِ الْإِسْتِحْقَاقِ (493).

إذا ادعى اثنان نكاح امرأة وإقاما بيينة مطلقة على ذلك : "قَالَ (فَإِنْ ادَّعى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِكَاحَ امْرَأَةٍ وَأَقَامَا بَيِّنَةً ، لَمْ يَقْضَ بِوَاحِدَةٍ مِنَ الْبَيِّنَتَيْنِ)، لِتَعَذُّرِ الْعَمَلِ بِهِمَا؛ لِأَنَّ الْمَحِلَّ لَا يَقْبَلُ الْإِشْتِرَاكَ.

قَالَ (وَيَرْجِعُ إِلَى تَصْدِيقِ الْمَرْأَةِ لِأَحَدِهِمَا)، لِأَنَّ النِّكَاحَ مِمَّا يُحْكَمُ بِهِ بِتَصَادُقِ الزَّوْجَيْنِ، وَهَذَا إِذَا لَمْ تُؤَقَّتِ الْبَيِّنَتَانِ.

(488) به قال الحنفية ، وقول عند المالكية ، وقول عند الشافعية ورواية أبي الخطاب عن أحمد وقول الظاهرية ، واستدلوا بحديث الناقة ، ولأن البيينة أقوى من اليد ، وقد ثبت أنها إذا تساويا في اليد جعل بينهما ، فكذلك إذا تساويا في البيينة من باب أولى . الفتاوى التاتارخانية 502/5، الذخيرة 180/10، الحاوي 319/17، المغنى 234/14، المحلى 436/9، 437.

(489) وهو قول مالك ، والأصح عند الشافعية ، ورواية عن أحمد ، واستدلوا : بأن البيينة حجة في الشرع ، والبيئتان حجتان تعارضتا دون مرجح ، فسقطتا ، كالخبرين إذا تعارضا. الذخيرة 120/10 ، 180، الحاوي 319/17، الكافي 158/6، المغنى 233/14.

(490) وهو قول عند الشافعية ، ورواية أبي الخطاب عن أحمد البيان في مذهب الشافعي 169/7، المغنى 234/14، الكافي ، لابن قدامة 158/6.

(491) رواه الطبراني في الأوسط 98/3، 99، وقال : تفرد به أبو مصعب ، أبو داود في مراسيله رقم 424.

(492) رواه أبو داود ، وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه . السنن رقم 1613، المستدرک 95/4.

(493) وقد أخذت مجلة الأحكام العدلية بقول الحنفية . درر الحكام شرح مجلة الأحكام 466/4، البحر الرائق 397/7، تشنيف المسامع بجمع الجوامع ، لتاج الدين السبكي 492/3.

إذا ادعى اثنان نكاح امرأة وإقاما بينة مؤرخة على ذلك : "فَأَمَّا إِذَا وَقَّتَا فَصَاحِبُ الْوَقْتِ الْأَوَّلُ أُولَى ، وَإِنْ أَقَرَّتْ لِأَحَدِهِمَا قَبْلَ إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ ، فَهِيَ امْرَأَتُهُ) ، لِتَصَادُقَهُمَا (وَإِنْ أَقَامَ الْآخَرُ الْبَيِّنَةَ قُضِيَ بِهَا) ، لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ أَقْوَى مِنَ الْإِقْرَارِ ، وَلَوْ تَقَرَّدَ أَحَدُهُمَا بِالْأَدْعَى ، وَالْمَرْأَةُ تَجَحَّدُ ، فَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ ، وَقَضَى بِهَا الْقَاضِي لَهُ ، ثُمَّ أَدْعَى الْآخَرُ ، وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ ، لَا يَحْكُمُ بِهَا) ، لِأَنَّ الْقَضَاءَ الْأَوَّلَ قَدْ صَحَّ ، فَلَا يُنْقَضُ بِمَا هُوَ مِثْلُهُ ، بَلْ هُوَ دُونُهُ (إِلَّا أَنْ يُؤَقَّتْ شَهُودُ الثَّانِي سَابِقًا) ، لِأَنَّهُ ظَهَرَ الْخَطَأُ فِي الْأَوَّلِ بَيِّقِينَ ، وَكَذَا إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي يَدِ الزَّوْجِ وَنِكَاحُهُ ظَاهِرٌ ، لَا تُقْبَلُ بَيِّنَةُ الْخَارِجِ إِلَّا عَلَى وَجْهِ السَّبْقِ (494).

ادعى اثنان شراء عبد وأقاما بينة مطلقة ، وكان العبد في يد ثالث : "قَالَ (وَلَوْ أَدْعَى اثْنَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهُ اشْتَرَى مِنْهُ هَذَا الْعَبْدَ) ، مَعْنَاهُ مِنْ صَاحِبِ الْيَدِ ، وَأَقَامَا بَيِّنَةً فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ ، إِنْ شَاءَ أَخَذَ نِصْفَ الْعَبْدِ بِنِصْفِ الثَّمَنِ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ) ، لِأَنَّ الْقَاضِيَ يَقْضِي بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، لِاسْتَوَائِهِمَا فِي السَّبَبِ ، فَصَارَ كَالْفُضُولِيِّينَ إِذَا بَاعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ رَجُلٍ ، وَأَجَازَ الْمَالِكُ الْبَيِّعَيْنِ ، يُخَيَّرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، لِأَنَّهُ تَغَيَّرَ عَلَيْهِ شَرْطُ عَقْدِهِ ، فَلَعَلَّ رَغْبَتَهُ فِي تَمْلُكِ الْكُلِّ فَيَرُدُّهُ ، وَيَأْخُذُ كُلَّ الثَّمَنِ ، فَإِنْ قَضَى الْقَاضِي بِهِ بَيْنَهُمَا ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: لَا أَخْتَارُ ، لَمْ يَكُنْ لِلْآخِرِ أَنْ يَأْخُذَ جَمِيعَهُ) ، لِأَنَّهُ صَارَ مَقْضِيًّا عَلَيْهِ فِي النِّصْفِ ، فَانْفَسَخَ الْبَيْعُ فِيهِ ، وَهَذَا لِأَنَّهُ خَصِمَ فِيهِ لِظُهُورِ اسْتِحْقَاقِهِ بِالْبَيِّنَةِ لَوْلَا بَيِّنَةُ صَاحِبِهِ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ ذَلِكَ قَبْلَ تَخْيِيرِ الْقَاضِي ، حَيْثُ يَكُونُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْجَمِيعَ ، لِأَنَّهُ يَدَّعِي الْكُلَّ وَلَمْ يَفْسَخْ سَبَبَهُ ، وَالْعَوْدُ إِلَى النِّصْفِ لِلْمُزَاحِمَةِ ، وَلَمْ تَوْجَدْ ، وَنَظِيرُهُ تَسْلِيمُ أَحَدِ الشَّفِيعَيْنِ قَبْلَ الْقَضَاءِ ، وَنَظِيرُ الْأَوَّلِ تَسْلِيمُهُ بَعْدَ الْقَضَاءِ .

ادعى اثنان شراء عبد وأقاما بينة مؤرخة ، وكان العبد في يد ثالث: وَلَوْ ذَكَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تَارِيخًا فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا) ، لِأَنَّهُ أَثْبَتَ الشِّرَاءَ فِي زَمَانٍ لَا يُنَازَعُهُ فِيهِ أَحَدٌ فَانْدَفَعَ الْآخَرُ بِهِ .

ادعى اثنان شراء عبد وأقاما أحدهما بينة مطلقة والآخر مقيدة: (وَلَوْ وَقَّتَتْ إِحْدَاهُمَا وَلَمْ تُؤَقَّتِ الْآخَرَى فَهُوَ لِصَاحِبِ الْوَقْتِ) لِثُبُوتِ مُلْكِهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَاحْتِمَالِ الْآخَرِ أَنْ يَكُونَ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ فَلَا يَقْضِي لَهُ بِالشَّكِّ .

ادعى اثنان شراء عبد وأقاما بينة مطلقة وكان العبد في يد أحدهما : (وَإِنْ لَمْ يَذْكُرَا تَارِيخًا وَمَعَ أَحَدِهِمَا قَبْضٌ فَهُوَ أُولَى) ، وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ فِي يَدِهِ ، لِأَنَّ تَمَكُّنَهُ مِنْ قَبْضِهِ يَدُلُّ عَلَى سَبْقِ شِرَائِهِ ، وَلِأَنَّهُمَا اسْتَوَيَا فِي الْإِثْبَاتِ فَلَا تُنْقَضُ الْيَدُ الثَّابِتَةُ بِالشَّكِّ ، وَكَذَا لَوْ ذَكَرَ الْآخَرُ وَقَّتَا لِمَا بَيَّنَّا ، إِلَّا أَنْ يَشْهَدُوا أَنَّ شِرَاءَهُ كَانَ قَبْلَ شِرَاءِ صَاحِبِ الْيَدِ ، لِأَنَّ الصَّرِيحَ يَفُوقُ الدَّلَالَهَ.

(494) أي : إلا على وجه: أن بينته تشهد أن نكاحه قبل نكاح الأول، فحينئذ ينتقض نكاح الأول ، لظهور الخطأ فيه بيقين . البناية 384/9.

إذا ادعى أحدهما شراء العبد والآخر الهبة ببينة مطلقة وقبضاه من ثالث : " قَالَ: (وَإِنْ ادَّعى أَحَدُهُمَا شِرَاءً وَالْآخَرُ هِبَةً وَقَبْضًا) ، مَعْنَاهُ: مِنْ وَاحِدٍ (وَأَقَامَا بَيِّنَةً ، وَلَا تَارِيخَ مَعَهُمَا ، فَالشَّرَاءُ أَوْلَى) ، لِأَنَّ الشَّرَاءَ أَقْوَى ، لِكَوْنِهِ مُعَاوَضَةً مِنَ الْجَانِبَيْنِ ، وَلِأَنَّهُ يُثْبِتُ الْمَلِكُ بِنَفْسِهِ ، وَالْمَلِكُ فِي الْهِبَةِ يَتَوَقَّفُ عَلَى الْقَبْضِ ، وَكَذَا الشَّرَاءُ وَالصَّدَقَةُ مَعَ الْقَبْضِ لِمَا بَيَّنَّا .

(وَالْهِبَةُ وَالْقَبْضُ وَالصَّدَقَةُ مَعَ الْقَبْضِ سَوَاءٌ حَتَّى يَقْضِيَ بَيْنَهُمَا) ، لِاسْتَوَائِهِمَا فِي وَجْهِ التَّبَرُّعِ ، وَلَا تَرْجِيحَ بِاللُّزُومِ ، لِأَنَّهُ يَرْجِعُ إِلَى الْمَالِ ، وَالتَّرْجِيحُ بِمَعْنَى قَائِمٍ فِي الْحَالِ ، وَهَذَا فِيمَا لَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ صَحِيحٌ ، وَكَذَا فِيمَا يَحْتَمِلُهَا عِنْدَ الْبَعْضِ ، لِأَنَّ الشُّيُوعَ طَارِئٌ ، وَعِنْدَ الْبَعْضِ لَا يَصِحُّ ، لِأَنَّهُ تَنْفِيزُ الْهِبَةِ فِي الشَّائِعِ ، وَصَارَ كَقِيَامَةِ الْبَيِّنَتَيْنِ عَلَى الْإِرْتِهَانِ وَهَذَا أَصَحُّ.

إذا ادعى الزوج شراء العبد وادعت زوجته أنه مهرها : " قَالَ (وَإِذَا ادَّعى أَحَدُهُمَا الشَّرَاءَ ، وَادَّعَتْ امْرَأَتُهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا عَلَيْهِ فَهُمَا سَوَاءٌ) ، لِاسْتَوَائِهِمَا فِي الْقُوَّةِ ، فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ ، يُثْبِتُ الْمَلِكُ بِنَفْسِهِ ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ: الشَّرَاءُ أَوْلَى ، وَلَهَا عَلَى الزَّوْجِ الْقِيَمَةُ ، لِأَنَّهُ أَمَكَّنَ الْعَمَلَ بِالْبَيِّنَتَيْنِ بِتَقْدِيمِ الشَّرَاءِ ، إِذِ التَّزْوُجُ عَلَى عَيْنِ مَمْلُوكَةٍ لِلْغَيْرِ صَحِيحٌ ، وَتَجِبُ قِيَمَتُهُ عِنْدَ تَعَذُّرِ تَسْلِيمِهِ .

إذا ادعى أحدهما رهنا وقبضا والآخر هبة وقبضا : "وَإِذَا ادَّعى أَحَدُهُمَا رَهْنًا وَقَبْضًا وَالْآخَرُ هِبَةً وَقَبْضًا وَأَقَامَا بَيِّنَةً فَالرَّهْنُ أَوْلَى) وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ ، وَفِي الْقِيَاسِ الْهِبَةُ أَوْلَى لِأَنَّهَا تُثْبِتُ الْمَلِكُ وَالرَّهْنُ لَا يُثْبِتُهُ.

وَجْهُ الاسْتِحْسَانِ : أَنَّ الْمَقْبُوضَ بِحُكْمِ الرَّهْنِ مَضْمُونٌ ، وَبِحُكْمِ الْهِبَةِ غَيْرُ مَضْمُونٍ ، وَعَقْدُ الضَّمَانِ أَقْوَى ، بِخِلَافِ الْهِبَةِ بِشَرْطِ الْعَوَضِ ، لِأَنَّهُ يَبِيعُ انْتِهَاءً وَالْبَيْعُ أَوْلَى مِنَ الرَّهْنِ ، لِأَنَّهُ عَقْدُ ضَمَانٍ يُثْبِتُ الْمَلِكُ صُورَةً وَمَعْنَى ، وَالرَّهْنُ لَا يُثْبِتُهُ إِلَّا عِنْدَ الْهَلَاكِ مَعْنَى لَا صُورَةً ، فَكَذَا الْهِبَةُ بِشَرْطِ الْعَوَضِ .

إذا أقام الخارجان بينة مقيدة على الملك وتاريخ أحدهما أقدم : " (وَإِنْ أَقَامَ الْخَارِجَانِ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمَلِكِ وَالتَّارِيخَ ، فَصَاحِبُ التَّارِيخِ الْأَقْدَمُ أَوْلَى) ، لِأَنَّهُ أَثْبَتَ أَنَّهُ أَوَّلُ الْمَالِكِينَ ، فَلَا يَتَلَقَّى الْمَلِكُ إِلَّا مِنْ جِهَتِهِ ، وَلَمْ يَتَلَقَّ الْآخَرَ مِنْهُ⁽⁴⁹⁵⁾).

(495) (ولأن الملك ثبت للبينة الأقدم ، ومن القواعد الفقهية " إبقاء ماكان على ماكان " وما أثبتته البينة الأخرى محتمل ، لمعارضة هذه البينة له ، فتساقطتا فيما تعارضتا فيه ، ويبقى استصحاب الحال لذات الأقدم ، وبهذا أخذت مجلة الأحكام العدلية ، نصت المادة 1760 على أنه " بَيِّنَةُ مَنْ تَارِيخُهُ مُقَدَّمٌ أَوْلَى فِي دَعْوَى الْمَلِكِ الْمُوَرَّخِ " ، وفي هذا: البحر الرائق 397/7 ، خزانة الأكملة ، للجرجاني 761/3 .

إذا ادعى الشراء من غير صاحب اليد وتاريخ أحدهما أقدم : "قَالَ: (وَلَوْ ادَّعَى الشَّرَاءَ مِنْ وَاحِدٍ) مَعْنَاهُ مِنْ غَيْرِ صَاحِبِ الْيَدِ ، وَأَقَامَا الْبَيِّنَةَ عَلَى تَارِيخَيْنِ فَأَلَّوْهُ أُولَى) ، لِمَا بَيَّنَّا أَنَّهُ أَثْبَتَهُ فِي وَقْتٍ لَا مُنَازَعَ لَهُ فِيهِ .

إذا ادعى كل منهما الشراء من آخر ببينة مؤرخة : "(وَإِنْ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ عَلَى الشَّرَاءِ مِنْ آخَرَ ، وَذَكَرَا تَارِيخًا) ، فَهُمَا سَوَاءٌ ، لِأَنَّهُمَا يُثْبِتَانِ الْمَلِكَ لِبَايَعِيهِمَا ، فَيَصِيرُ كَأَنَّهُمَا حَضَرَا ، ثُمَّ يُخَيَّرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَمَا ذَكَرْنَا مِنْ قَبْلُ . ادعى كل منهما الشراء من آخر وإحدى البينتين مؤرخة دون الأخرى : "(وَلَوْ وَقَّتْ إِحْدَى الْبَيِّنَتَيْنِ وَقْتًا ، وَلَمْ تُوقَّتِ الْآخَرَى ، قَضَى بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ) ، لِأَنَّ تَوْقِيتَ إِحْدَاهُمَا لَا يَدُلُّ عَلَى تَقَدُّمِ الْمَلِكِ ، لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْآخَرُ أَقْدَمَ ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ الْبَايِعُ وَاحِدًا ، لِأَنَّهُمَا اتَّفَقَا عَلَى أَنَّ الْمَلِكَ لَا يُتْلَقَى إِلَّا مِنْ جِهَتِهِ ، فَإِذَا أَثْبَتَ أَحَدُهُمَا تَارِيخًا يَحْكُمُ بِهِ حَتَّى يَبَيَّنَ أَنَّهُ تَقَدَّمَ شِرَاءً غَيْرِهِ (496).

إذا ادعى الأول الشراء من آخر ، والثاني الهبة والقبض ، والثالث الميراث من أبيه ، والرابع الصدقة : وَلَوْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا الشَّرَاءَ مِنْ رَجُلٍ ، وَالْآخَرُ الْهَبَةَ وَالْقَبْضَ مِنْ غَيْرِهِ ، وَالثَّلَاثُ الْمِيرَاثَ مِنْ أَبِيهِ ، وَالرَّابِعُ الصَّدَقَةَ وَالْقَبْضَ مِنْ آخَرَ ، قَضَى بَيْنَهُمْ أَرْبَاعًا) ، لِأَنَّهُمْ يَتَلَفَّوْنَ الْمَلِكَ مِنْ بَاعَتِهِمْ فَيَجْعَلُ كَأَنَّهُمْ حَضَرُوا وَأَقَامُوا الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمَلِكِ الْمُطْلَقِ.

إذا أقام الخارج بيينة على ملك مؤرخ وصاحب اليد بيينة على ملك أقدم : "قَالَ: (وَإِنْ أَقَامَ الْخَارِجُ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَلِكٍ مُؤَرَّخٍ وَصَاحِبُ الْيَدِ بَيِّنَةَ عَلَى مَلِكٍ أَقْدَمَ تَارِيخًا كَانَ أُولَى) ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَهُوَ رَوَايَةٌ عَنْ مُحَمَّدٍ ، وَعَنْهُ أَنَّهُ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ رَجَعَ إِلَيْهِ ، لِأَنَّ الْبَيِّنَتَيْنِ قَامَتَا عَلَى مُطْلَقِ الْمَلِكِ ، وَلَمْ يَتَعَرَّضَا لِجِهَةِ الْمَلِكِ ، فَكَانَ التَّقَدُّمُ وَالتَّأَخُّرُ سَوَاءً (497).

(496) ، لِأَنَّ الْبَايِعَ إِنْ كَانَ وَاحِدًا كَانَ التَّعَاقُبُ ضَرُورِيًّا ، وَقَدْ ثَبَتَ لِأَحَدِهِمَا بِالْبَيِّنَةِ مَلِكٌ فِي وَقْتٍ ، وَمَلِكٌ غَيْرُهُ مَشْكُوكٌ إِنْ تَأَخَّرَ لَمْ يَضُرَّ ، وَإِنْ تَقَدَّمَ مَلِكٌ فَتَعَارَضَا فَيُرَجَّحُ بِالْوَقْتِ ، وَأَمَّا إِذَا كَانَ مُتَعَدِّدًا ، فَكَمَا جَازَ أَنْ يَقَعَ مُتَعَاقِبَيْنِ ، جَازَ أَنْ يَقَعَ مَعًا ، وَفِي ذَلِكَ تَعَارُضٌ أَيْضًا ، فَضَعُفُ قُوَّةِ الْوَقْتِ عَنِ التَّرْجِيحِ لِتَضَاعُفِ التَّعَارُضِ . العناية 261/8، 262.

(497) رَوَى ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْهُ - أَيْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ - أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ هَذَا الْقَوْلِ ، وَهُوَ أَنَّ بَيِّنَةَ ذِي الْيَدِ إِذَا كَانَتْ أَقْدَمَ تَارِيخًا كَانَتْ أُولَى مِنْ بَيِّنَةِ الْخَارِجِ ، وَقَالَ: لَا أَقْبَلُ مِنْ ذِي الْيَدِ بَيِّنَةَ عَلَى تَارِيخٍ وَغَيْرِهِ إِلَّا لِلنَّتَاجِ ، لِأَنَّ النَّتَاجَ دَلِيلٌ عَلَى أَوْلِيَةِ الْمَلِكِ دُونَ التَّارِيخِ ، لِأَنَّ الْبَيِّنَتَيْنِ قَامَتَا عَلَى مُطْلَقِ الْمَلِكِ وَلَمْ يَتَعَرَّضَا لِجِهَةِ الْمَلِكِ فَكَانَ التَّقَدُّمُ وَالتَّأَخُّرُ سَوَاءً . العناية 262/8.

وَلَهُمَا : أَنَّ الْبَيِّنَةَ مَعَ التَّارِيخِ مُتَضَمِّنَةٌ مَعْنَى الدَّفْعِ ، فَإِنَّ الْمَلِكَ إِذَا ثَبَتَ لِشَخْصٍ فِي وَقْتٍ ، فُقُبْتُهِ لِغَيْرِهِ بَعْدَهُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِالتَّلَقِّي مِنْ جِهَتِهِ ، وَبَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ عَلَى الدَّفْعِ مَقْبُولَةٌ⁽⁴⁹⁸⁾ ، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ لَوْ كَانَتْ الدَّارُ فِي أَيْدِيهِمَا وَالْمَعْنَى مَا بَيَّنَّا .

إذا أقام الخارج وذو اليد البينة على ملك مطلق ووقعت إحدى البينتين دون الأخرى : وَلَوْ أَقَامَ الْخَارِجُ وَذُو الْيَدِ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَلِكٍ مُطْلَقٍ ، وَوَقَعَتْ إِحْدَاهُمَا دُونَ الْأُخْرَى ، فَعَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ الْخَارِجُ أَوْلَى .

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَهُوَ رَوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ: صَاحِبُ الْوَقْتِ أَوْلَى ، لِأَنَّهُ أَقْدَمُ ، وَصَارَ كَمَا فِي دَعْوَى الشَّرَاءِ إِذَا ارَّخْتَ إِحْدَاهُمَا كَانَ صَاحِبُ التَّارِيخِ أَوْلَى⁽⁴⁹⁹⁾ ، وَلَهُمَا: أَنَّ بَيِّنَةَ ذِي الْيَدِ إِنَّمَا تُقْبَلُ لِتَضَمُّنِهَا مَعْنَى الدَّفْعِ ، وَلَا دَفْعَ هَاهُنَا ، حَيْثُ وَقَعَ الشُّكُّ فِي التَّلَقِّي مِنْ جِهَتِهِ⁽⁵⁰⁰⁾ ، وَعَلَى هَذَا إِذَا كَانَتْ الدَّارُ فِي أَيْدِيهِمَا .

إذا أقام الخارجان بينة على الملك المطلق ووقعت إحدى البينتين دون الأخرى : وَلَوْ كَانَتْ فِي يَدِ ثَالِثٍ ، وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا فَهُمَا سَوَاءٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: الَّذِي وَقَّتْ أَوْلَى ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ: الَّذِي أَطْلَقَ أَوْلَى ، لِأَنَّهُ ادَّعَى أَوَّلِيَّةَ الْمَلِكِ بِدَلِيلِ اسْتِحْقَاقِ الزَّوَادِ ، وَرُجُوعِ الْبَاعَةِ بَعْضُهُمْ عَلَى الْبَعْضِ ، وَلِأَبِي يُوسُفَ أَنَّ التَّارِيخَ يُوجِبُ الْمَلِكَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ بَيِّقِينَ ، وَالْإِطْلَاقُ يَحْتَمِلُ غَيْرَ الْأَوَّلِيَّةِ ، وَالتَّرْجِيحُ بِالتَّيَقُّنِ ؛ كَمَا لَوْ ادَّعَى الشَّرَاءُ ، وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ التَّارِيخَ يُضَامُهُ⁽⁵⁰¹⁾ اِحْتِمَالُ عَدَمِ التَّقَدُّمِ فَسَقَطَ اعْتِبَارُهُ ، فَصَارَ كَمَا لَوْ أَقَامَا الْبَيِّنَةَ عَلَى مَلِكٍ مُطْلَقٍ ، بِخِلَافِ الشَّرَاءِ ، لِأَنَّهُ أَمْرٌ حَادِثٌ ، فَيُضَافُ إِلَى أَقْرَبِ الْأَوْقَاتِ ، فَيَتَرَجَّحُ جَانِبُ صَاحِبِ التَّارِيخِ .

إذا أقام كل من الخارج وصاحب اليد بينة على نتاج الدابة أنها له : "قَالَ (وَإِنْ أَقَامَ الْخَارِجُ وَصَاحِبُ الْيَدِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً عَلَى النَّتَاجِ ، فَصَاحِبُ الْيَدِ أَوْلَى) ، لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ قَامَتْ عَلَى مَا لَا تَدُلُّ عَلَيْهِ فَاسْتَوَيَا ، وَتَرَجَّحَتْ بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ بِالْيَدِ ، فَيَقْضِي لَهُ ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ ،

(498) ولأن نقل الملكة حاصل لمن سبق ، والعقد عليه بعده لا يصح ، لأن بينة ذي اليد أولى من غير التاريخ ، فأولى أن يكون أولى مع التاريخ . الفتاوى الهندية 95/4 ، العقود الدرية 590/1 .

(499) وهو المفتى به عند الحنفية ، وقول أشهب من المالكية ، وابن رزين من الحنابلة . قرة عيون الأخيار 22/12 ، 23 ، 39 ، الذخيرة 184/10 ، الإنصاف 359/11 .

(500) وهو قول عند المالكية ، ووجه عند الحنابلة ، ولأن الملك قد يكون ثابتاً لصاحب البينة المطلقة قبل ثبوته لصاحب البينة المؤرخة ، فترجح بينته ، وهذا مردود : لأن انتقال الملكية لا يثبت مع الشك . خزانة الأكمال 761/3 ، قرة عيون الأخيار 22/12 ، 23 . التاج والإكليل 253/8 ، الإنصاف 359/11 .

(501) أى : يزاحمه ، البناية 394/9 .

خَلَا فَمَا يَقُولُهُ عِيسَى بْنُ أَبَانَ⁽⁵⁰²⁾ إِنَّهُ تَهَاتَرُ الْبَيْنَتَانِ ، وَيُتْرَكُ فِي يَدِهِ ، لَا عَلَى طَرِيقِ الْقَضَاءِ ، وَلَوْ تَلَقَّى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْمَلِكَ مِنْ رَجُلٍ أَقَامَ الْبَيْنَةَ عَلَى النَّتَاجِ عِنْدَهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ إِقَامَتِهَا عَلَى النَّتَاجِ فِي يَدِ نَفْسِهِ إِذَا أَقَامَ أَحَدُهُمَا الْبَيْنَةَ عَلَى الْمَلِكِ ، وَالْآخَرُ عَلَى النَّتَاجِ ، فَصَاحِبُ النَّتَاجِ أَوْلَى أُيْهُمَا كَانَ ، لِأَنَّ بَيْنَتَهُ قَامَتْ عَلَى أَوْلِيَّةِ الْمَلِكِ ، فَلَا يَتَّبْتُ لِلْآخَرِ إِلَّا بِالتَّلَقِّي مِنْ جِهَتِهِ ، وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَتْ الدَّعْوَى بَيْنَ خَارِجَيْنِ فَبَيْنَةُ النَّتَاجِ أَوْلَى لِمَا ذَكَرْنَا (وَلَوْ قَضَى بِالنَّتَاجِ لِصَاحِبِ الْيَدِ ثُمَّ أَقَامَ ثَالِثُ الْبَيْنَةِ عَلَى النَّتَاجِ يَقْضِي لَهُ إِلَّا أَنْ يُعِيدَهَا ذُو الْيَدِ) لِأَنَّ الثَّالِثَ لَمْ يَصِرْ مَقْضِيًّا عَلَيْهِ بِتِلْكَ الْقَضِيَّةِ ، وَكَذَا الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ بِالْمَلِكِ الْمُطْلَقِ إِذَا أَقَامَ الْبَيْنَةَ عَلَى النَّتَاجِ تُقْبَلُ وَيُقَضُّ الْقَضَاءُ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ النَّصِّ. وَالأول بمنزلة الاجتهاد.

قَالَ (وَكَذَلِكَ النَّسْجُ فِي الثِّيَابِ الَّتِي لَا تُنْسَجُ إِلَّا مَرَّةً) كَعَزْلِ الْفُطْنِ (وَكَذَلِكَ كُلُّ سَبَبٍ فِي الْمَلِكِ لَا يَتَكَرَّرُ) ، لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى النَّتَاجِ ، كَحَلْبِ اللَّبَنِ ، وَاتِّخَاذِ الْجُبْنِ وَاللَّبْدِ ، وَالْمِرْعَزَى⁽⁵⁰³⁾ وَجَزَّ الصُّوفِ ، وَإِنْ كَانَ يَتَكَرَّرُ فُضِيَ بِهِ لِلْخَارِجِ ، بِمَنْزِلَةِ الْمَلِكِ الْمُطْلَقِ ، وَهُوَ مِثْلُ الْخَزْ وَالْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ وَزِرَاعَةِ الْحِنْطَةِ وَالْحُبُوبِ ، فَإِنْ أَشْكَلَ يَرْجِعُ إِلَى أَهْلِ الْخُبْرَةِ ، لِأَنَّهُمْ أَعْرِفَ بِهِ ، فَإِنْ أَشْكَلَ عَلَيْهِمْ فُضِيَ بِهِ لِلْخَارِجِ ، لِأَنَّ الْقَضَاءَ بَيْنَتِهِ هُوَ الْأَصْلُ ، وَالْعُدُولُ عَنْهُ بِخَبَرِ النَّتَاجِ ، فَإِذَا لَمْ يَعْلَمْ يَرْجِعُ إِلَى الْأَصْلِ.

إِذَا أَقَامَ الْخَارِجُ الْبَيْنَةَ عَلَى الْمَلِكِ الْمُطْلَقِ ، وَصَاحِبِ الْيَدِ الْبَيْنَةَ عَلَى الشَّرَاءِ : "قَالَ (وَإِنْ أَقَامَ الْخَارِجُ الْبَيْنَةَ عَلَى الْمَلِكِ الْمُطْلَقِ ، وَصَاحِبُ الْيَدِ الْبَيْنَةَ عَلَى الشَّرَاءِ مِنْهُ ، كَانَ صَاحِبُ الْيَدِ أَوْلَى) ، لِأَنَّ الْأَوَّلَ إِنْ كَانَ يَدَّعِي أَوْلِيَّةَ الْمَلِكِ ، فَهَذَا تَلَقَّى مِنْهُ ، وَفِي هَذَا لَا تَنَافِي ، فَصَارَ كَمَا إِذَا أَقَرَّ بِالْمَلِكِ لَهُ ثُمَّ ادَّعَى الشَّرَاءَ مِنْهُ⁽⁵⁰⁴⁾ .

إِذَا أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيْنَةَ مُطْلَقَةً عَلَى الشَّرَاءِ مِنْ آخَرٍ : "قَالَ (وَإِنْ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيْنَةَ عَلَى الشَّرَاءِ مِنَ الْآخَرِ وَلَا تَارِيخَ مَعَهُمَا ، تَهَاتَرَتِ الْبَيْنَتَانِ ، وَتُتْرَكُ الدَّارُ فِي يَدِ ذِي الْيَدِ) ، قَالَ : وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ ، وَعَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ يَقْضَى بِالْبَيْنَتَيْنِ ، وَيَكُونُ لِلْخَارِجِ ، لِأَنَّ الْعَمَلَ بِهِمَا مُمَكِّنٌ ، فَيَجْعَلُ كَأَنَّهُ اشْتَرَى ذُو الْيَدِ مِنَ الْآخَرِ وَقَبْضَ ثُمَّ بَاعَ الدَّارَ

⁽⁵⁰²⁾ عِيسَى بْنُ أَبَانَ بْنِ صَدَقَةَ ، وَلِيَ الْقَضَاءَ بِالْبَصْرَةِ ، فِي شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ سَنَةِ إِحْدَى عَشَرَ وَمِائَتَيْنِ . وَكَانَ عِيسَى سَهْلًا فَقِيهًا سَرِيعَ الْإِنْفَازِ لِلْأَحْكَامِ ، تَفَقَّهَ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ قِيلَ إِنَّهُ لَزِمَهُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ . أَخْبَارُ الْقَضَاءِ ، لِأَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ خَلْفِ بْنِ حَيَّانَ بْنِ صَدَقَةَ الضَّبِّيِّ الْبَغْدَادِيِّ ، الْمُلقَّبُ بِـ "وَكَيْعٍ" (المتوفى: 306 هـ) 170/2 ، الجواهر المضوية في طبقات الحنفية 401/1 .

⁽⁵⁰³⁾ والمرعزي : بكسر الميم والعين ، فَإِذَا شَدَّتِ الزَّاي قَصُرَتْ ، وَإِذَا خَفَفَتْ مَدَّتْ ، وَقَدْ يَقَالُ : مَعَزَا بَفَتْحِ الْمِيمِ مَخْفَفًا مَمْدُودًا ، وَهِيَ كَالصُّوفِ تَحْتَ شَعْرِ الْغَنَمِ ، أَوْ الزَّغَبِ الَّذِي تَحْتَ شَعْرِ الْعَنْزِ . الْبَنَاءُ 396/9 ، الْبَحْرُ الرَّائِقُ 192/1 .

⁽⁵⁰⁴⁾ فيقضى ببينته ، وبهذا أخذت مجلة الأحكام العدلية ، فنصت المادة 1757 علي أنه : " بينة الخارج أولى في دعوى الملك المطلق " وفي هذا: البناية 379/9 .

، لِأَنَّ الْقَبْضَ دَلَالَةٌ السَّبْقِ عَلَى مَا مَرَّ، وَلَا يَعْكِسُ الْأَمْرَ ، لِأَنَّ الْبَيْعَ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا يَجُوزُ وَإِنْ كَانَ فِي الْعَقَارِ عِنْدَهُ، وَلَهُمَا : أَنَّ الْإِقْدَامَ عَلَى الشَّرَاءِ إِفْرَارٌ مِنْهُ بِالْمَلِكِ لِلْبَائِعِ ، فَصَارَ كَأَنَّهُمَا قَامَتَا عَلَى الْإِفْرَارَيْنِ وَفِيهِ التَّهَاتُرُ بِالْإِجْمَاعِ، كَذَا هَاهُنَا، وَلِأَنَّ السَّبَبَ يُرَادُ لِحُكْمِهِ وَهُوَ الْمَلِكُ ، وَلَا يُمْكِنُ الْقَضَاءُ لِذِي الْيَدِ إِلَّا بِمَلِكٍ مُسْتَحَقٍّ ، فَبَقِيَ الْقَضَاءُ لَهُ بِمُجَرَّدِ السَّبَبِ وَأَنَّهُ لَا يُفِيدُهُ(505).

إذا أقام كل واحد منهما بينة مطلقة على نقد الثمن : "ثُمَّ لَوْ شَهِدَتِ الْبَيِّنَتَانِ عَلَى نَقْدِ الثَّمَنِ ، فَأَلْفُ بِالْأَلْفِ قِصَاصٌ عِنْدَهُمَا إِذَا اسْتَوَيَا ، لَوْجُودُ قَبْضٍ مَضْمُونٍ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، وَإِنْ لَمْ يَشْهَدُوا عَلَى نَقْدِ الثَّمَنِ ، فَأَلْقِصَاصٌ مَذْهَبٌ مُحَمَّدٌ لِلْوُجُوبِ عِنْدَهُ(506).

إذا أقام كل واحد منهما بينة مطلقة على البيع والقبض : "وَلَوْ شَهِدَ الْفَرِيقَانِ بِالْبَيْعِ وَالْقَبْضِ تَهَاتَرَتَا بِالْإِجْمَاعِ(507)، لِأَنَّ الْجَمْعَ غَيْرُ مُمَكِّنٍ عِنْدَ مُحَمَّدٍ ، لِحَوَازِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْبَيْعَيْنِ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ.

إذا أقام كل واحد منهما بينة مقيدة في العقار ولم تثبت قبضا وبينة الخارج أسبق : "وَإِنْ وُقِّتَتِ الْبَيِّنَتَانِ فِي الْعَقَارِ وَلَمْ تُثَبَّتْ قَبْضًا ، وَوُقِّتَ الْخَارِجُ أَسْبَقُ يُقْضَى لِصَاحِبِ الْيَدِ عِنْدَهُمَا ، فَيُجْعَلُ كَأَنَّ الْخَارِجَ اشْتَرَى أَوَّلًا ثُمَّ بَاعَ قَبْلَ الْقَبْضِ مِنْ صَاحِبِ الْيَدِ، وَهُوَ جَائِزٌ فِي الْعَقَارِ عِنْدَهُمَا ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَقْضَى لِلْخَارِجِ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ لَهُ بَيْعُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ فَبَقِيَ عَلَى مَلِكِهِ، وَإِنْ أَثَبَّتَا قَبْضًا ، يَقْضَى لِصَاحِبِ الْيَدِ ، لِأَنَّ الْبَيْعَيْنِ جَائِزَانِ عَلَى الْقَوْلَيْنِ، وَإِنْ كَانَ وَقْتُ صَاحِبِ الْيَدِ أَسْبَقُ يُقْضَى لِلْخَارِجِ فِي الْوَجْهَيْنِ(508) ، فَيُجْعَلُ كَأَنَّهُ اشْتَرَاهَا ذُو الْيَدِ وَقَبْضٌ ، ثُمَّ بَاعَ وَلَمْ يُسَلِّمْ ، أَوْ سَلَّمَ ، ثُمَّ وَصَلَ إِلَيْهِ بِسَبَبٍ آخَرَ.

إذا أقام أحد المدعين شاهدين والآخر أربعة : "قَالَ: (وَإِنْ أَقَامَ أَحَدُ الْمُدَّعِيَيْنِ شَاهِدَيْنِ وَالْآخَرُ أَرْبَعَةً فَهُمَا سَوَاءٌ) لِأَنَّ شَهَادَةَ كُلِّ الشَّاهِدِينَ عِلَّةٌ تَامَةٌ كَمَا فِي حَالَةِ الْإِنْفِرَادِ، وَالتَّرْجِيحُ لَا يَقَعُ بِكَثْرَةِ الْعِلَلِ بَلْ بِقُوَّةِ فِيهَا عَلَى مَا عُرِفَ.

(505) و لِأَنَّا إِذَا قَضَيْنَا بَبَيِّنَةٍ ذِي الْيَدِ ، إِنَّمَا نَقْضِي لِيَزُولَ مَلِكُهُ إِلَى الْخَارِجِ ، فَلَمْ يَكُنِ السَّبَبُ مُفِيدًا لِحُكْمِهِ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ ، فَبَقِيَ الْقَضَاءُ لَهُ بِمُجَرَّدِ السَّبَبِ) ، وَذَلِكَ غَيْرُ مُفِيدٍ. العناية 273/8.

(506) فَإِنَّ الْبَيْعَيْنِ لَمَّا ثَبَّتَا عِنْدَهُ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُوجِبًا الثَّمَنِ عِنْدَ مُشْتَرِيهِ فَيُنْقَاصُ الْوُجُوبُ بِالْوُجُوبِ. العناية 273/8.

(507) لَكِنْ عَلَى اخْتِلَافِ التَّخْرِيجِ، فَعِنْدَهُمَا : بِاعْتِبَارِ أَنَّ دَعَوَاهُمَا مِثْلَ هَذَا الْبَيْعِ إِفْرَارٌ مِنْ كُلِّ مِنْهُمَا بِالْمَلِكِ لِصَاحِبِهِ، وَفِي مِثْلِ الْإِفْرَارِ تَهَاتُرُ الشُّهُودِ ، فَكَذَلِكَ هَاهُنَا ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ بِاعْتِبَارِ أَنَّ بَيْعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَائِزٌ لَوْجُودِ الْبَيْعِ بَعْدَ الْقَبْضِ ، وَلَيْسَ فِي الْبَيْعَيْنِ ذِكْرُ التَّارِيخِ ، وَلَا دَلَالَةٌ تَارِيخٍ حَتَّى يُجْعَلَ أَحَدُهُمَا سَابِقًا وَالْآخَرُ لَاحِقًا، وَإِذَا جَازَ الْبَيْعَانِ وَلَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا أَوْلَى مِنَ الْآخَرِ فِي الْقَبُولِ تَسَاقُطًا ، فَبَقِيَ الْعَيْنُ عَلَى يَدِ صَاحِبِ الْيَدِ كَمَا كَانَتْ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ (لِأَنَّ الْجَمْعَ غَيْرُ مُمَكِّنٍ) لِأَنَّ الْجَمْعَ عِبَارَةٌ عَنْ إِمْكَانِ الْعَمَلِ بِهِمَا وَهَاهُنَا لَمْ يُمْكِنَ . العناية 273/8، 274.

(508) أَي فِي الْوَجْهِ الَّذِي شَهِدُوا بِالْقَبْضِ ، وَفِي الْوَجْهِ الَّذِي لَمْ يَشْهَدُوا بِهِ . البناية 400/9.

إذا ادعى أحدهما ببيئته على أن له جميع الدار ، وادعى الآخر ببيئته أن له نصفها ، والدار في يد ثالث لا يملكها : " قَالَ (وَإِذَا كَانَتْ دَارٌ فِي يَدِ رَجُلٍ ادَّعَاهَا اثْنَانِ ، أَحَدُهُمَا جَمِيعَهَا ، وَالْآخَرُ نِصْفَهَا ، وَأَقَامَا الْبَيِّنَةَ ، فَلصاحب الجميع ثلاثة أرباعها ، ولصاحب النصف ربعها عند أبي حنيفة) ، اعتبراً بطريق المنازعة ، فإن صاحب النصف لا ينازع الآخر في النصف ، فسلم له بلا منازع ، واستوت منازعتهم في النصف الآخر ، فينصف بينهما ، (وقالاً: هي بينهما أثلاثاً) فاعتبراً طريق العول ، والمضاربة ، فصاحب الجميع يضرب بكل حقه سهمين وصاحب النصف بسهم واحد فتقسم أثلاثاً ، ولهذه المسألة نظائر وأضداد لا يحتملها هذا المختصر ، وقد ذكرنا في الزيادات.

إذا ادعى أحدهما ببيئته على أن له جميع الدار ، وادعى الآخر ببيئته أن له نصفها ، والدار في أيديهما : " قَالَ (وَلَوْ كَانَتْ فِي أَيْدِيهِمَا ، سَلِمَ لِصَاحِبِ الْجَمِيعِ نِصْفُهَا عَلَى وَجْهِ الْقَضَاءِ ، وَنِصْفُهَا لَا عَلَى وَجْهِ الْقَضَاءِ) ، لَأَنَّهُ خَارِجٌ فِي النِّصْفِ ، فَيَقْضَى بَبَيِّنَتِهِ ، وَالنِّصْفُ الَّذِي فِي يَدَيْهِ ، صَاحِبُهُ لَا يَدَّعِيهِ ، لِأَنَّ مُدَّعَاهُ النِّصْفَ وَهُوَ فِي يَدِهِ سَالِمٌ لَهُ ، وَلَوْ لَمْ يَنْصَرِفْ إِلَيْهِ دَعْوَاهُ كَانَ ظَالِمًا بِإِمْسَاكِهِ ، وَلَا قَضَاءَ بِدُونِ الدَّعْوَى فَيُتْرَكُ فِي يَدِهِ⁽⁵⁰⁹⁾.

إذا تنازعا في دابة وأقام كل منهما بينة مؤرخة أنها نتجت عنده وسن الدابة يوافق أحد التاريخين : " قَالَ (وَإِذَا تَنَازَعَا فِي دَابَّةٍ وَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً أَنَّهَا نَتَجَتْ عَنْهُ ، وَذَكَرَا تَارِيخًا ، وَسِئُ الدَّابَّةِ يُوَافِقُ أَحَدَ التَّارِيخَيْنِ فَهُوَ أَوْلَى) ، لِأَنَّ الْحَالَ يَشْهَدُ لَهُ فَيُتَرَجَّحُ ، (وَإِنْ أَشْكَلَ ذَلِكَ كَانَتْ بَيْنَهُمَا) ، لَأَنَّهُ سَقَطَ التَّوَقُّيْتُ فَصَارَ كَأَنَّهُمَا لَمْ يَذْكُرَا تَارِيخًا.

وَإِنْ خَالَفَ سِئُ الدَّابَّةِ الْوَقْتَيْنِ بَطَلَتْ الْبَيِّنَتَانِ ، كَذَا ذَكَرَهُ الْحَاكِمُ⁽⁵¹⁰⁾ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لَأَنَّهُ ظَهَرَ كَذِبُ الْفَرِيقَيْنِ فَيُتْرَكُ فِي يَدِ مَنْ كَانَتْ فِي يَدِهِ⁽⁵¹¹⁾.

⁽⁵⁰⁹⁾ (وَلَأَنَّهُ اجْتَمَعَ فِيهِ بَيِّنَةُ الْخَارِجِ وَذِي الْيَدِ ، وَبَيِّنَةُ الْخَارِجِ أَوْلَى ، فَيَقْضَى لَهُ بِذَلِكَ وَنِصْفُهَا لَا عَلَى وَجْهِ الْقَضَاءِ وَهُوَ الَّذِي كَانَ بِيَدِهِ ، لِأَنَّ صَاحِبَهُ لَمْ يَدَّعِهِ ، وَلَا قَضَاءَ بِدُونِ الدَّعْوَى فَيُتْرَكُ فِي يَدِهِ . العناية 278/8.

⁽⁵¹⁰⁾ (هو : مُحَمَّدٌ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْحَاكِمِ ، أَبُو الْفَضْلِ الْمُرُوزِيِّ السَّلْمِيُّ الْحَنْفِيُّ الْوَزِيرُ الْحَاكِمُ الشَّهِيدُ ، عَالِمٌ مَرُوءٍ الشَّهِيرُ بِالْحَاكِمِ ، قَتَلَهُ الْعَسْكَرُ وَهُوَ سَاجِدٌ فِي رَبِيعِ الْآخِرِ سَنَةِ أَرْبَعٍ وَثَلَاثِينَ وَثَلَاثِينَ ، وَكَانَ يَحْفَظُ سِتِينَ أَلْفًا مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَتَصَانِيفَهُ تَدُلُّ عَلَى كَمَالِ فَضْلِهِ ، مِنْهَا ، الْكَافِيُّ ، وَالْمُنْتَقَى . الْفَوَائِدُ الْبَهِيَّةُ فِي تَرَاجُمِ الْحَنْفِيَّةِ ، لِأَبِي الْحَسَنِاتِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَيِّ الْلُكْنَوِيِّ الْهَنْدِيِّ ص 186 ، إِتْحَافُ الْمُرتَقِي بِتَرَاجِمِ شُيُوخِ الْبَيْهَقِيِّ ، مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْفَتَّاحِ النَّحَالِ ص 437.

⁽⁵¹¹⁾ (هَذَا إِذَا كَانَا خَارِجَيْنِ ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا ذَا الْيَدِ ، فَإِنْ وَافَقَ سِئُ الدَّابَّةِ تَارِيخَهُ أَوْ أَشْكَلَ ، فُضِيَ بِهِ لِذِي الْيَدِ ، إِمَّا لِيُظْهَرَ عِلَامَةُ الصِّدْقِ فِي شَهْوَدِهِ ، أَوْ لِيُفُوتَ اعْتِبَارُ التَّوَقُّيْتِ بِالْأَشْكَالِ ، وَإِنْ كَانَ سِئُ الدَّابَّةِ بَيْنَ وَفَتِ الْخَارِجِ وَذِي الْيَدِ قَالَ عَامَّةُ الْمَشَايخِ : نَهَانَتْ الْبَيِّنَتَانِ وَتُتْرَكُ الدَّابَّةُ فِي يَدِ ذِي الْيَدِ . العناية 278/8.

إذا أقام أحدهما بينة على آخر أن ما تحت يده عبده غصبته منى ، والآخر ادعى أنه له
وديعة عنده : " قَالَ (وَإِذَا كَانَ عَبْدٌ فِي يَدِ رَجُلٍ أَقَامَ رَجُلَانِ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ أَحَدُهُمَا بِغَصْبٍ ،
وَالْآخَرُ بِوَدِيعَةٍ فَهُوَ بَيْنَهُمَا) ، لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الْإِسْتِحْقَاقِ.

(فصل في التنازع بالأيدي)

إذا تنازعا في دابة أحدهما راكبها والآخر متعلق بلجامها أو غير هذا: "قَالَ (وَإِذَا تَنَازَعَا فِي دَابَّةٍ أَحَدُهُمَا رَاكِبُهَا وَالْآخَرُ مُتَعَلِّقٌ بِلِجَامِهَا ، فَالرَّاکِبُ أَوْلَى) ، لِأَنَّ تَصَرُّفَهُ أَظْهَرَ ، فَإِنَّهُ يَخْتَصُّ بِالْمِلْكِ ، (وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا رَاكِبًا فِي السَّرَجِ وَالْآخَرُ رَدِيفُهُ فَالرَّاکِبُ أَوْلَى) ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَا رَاكِبَيْنِ حَيْثُ تَكُونُ بَيْنَهُمَا ، لِاسْتَوَائِهِمَا فِي التَّصَرُّفِ .

إذا تنازعا في بعير وعليه حمل لأحدهما : "(وَكَذَا إِذَا تَنَازَعَا فِي بَعِيرٍ وَعَلَيْهِ حِمْلٌ لِأَحَدِهِمَا فَصَاحِبُ الْحِمْلِ أَوْلَى)، لِأَنَّهُ هُوَ الْمُتَصَرِّفُ .

تنازعا في قميص أحدهما لابس له والآخر متعلق بكمه : "(وَكَذَا إِذَا تَنَازَعَا فِي قَمِيصٍ أَحَدُهُمَا لِأَبْسُهُ وَالْآخَرُ مُتَعَلِّقٌ بِكُمِّهِ فَالْأَبْسُ أَوْلَى) لِأَنَّهُ أَظْهَرُهُمَا تَصَرُّفًا (وَلَوْ تَنَازَعَا فِي بَسَاطٍ أَحَدُهُمَا جَالِسٌ عَلَيْهِ وَالْآخَرُ مُتَعَلِّقٌ بِهِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا) مَعْنَاهُ لَا عَلَى طَرِيقِ الْقَضَاءِ لِأَنَّ الْقُعُودَ لَيْسَ بِيَدٍ عَلَيْهِ فَاسْتَوِيَا.

تنازعا في ثوب في يد رجل وطرف منه في يد آخر : "قَالَ: (وَإِذَا كَانَ ثَوْبٌ فِي يَدِ رَجُلٍ وَطَرَفٌ مِنْهُ فِي يَدِ آخَرَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ) ، لِأَنَّ الزِّيَادَةَ مِنْ جِنْسِ الْحُجَّةِ ، فَلَا تُوجِبُ زِيَادَةً فِي الْإِسْتِحْقَاقِ.

ادعى صبي في يد رجل أنه حر أو أنه عبد فلان : "قَالَ: (وَإِذَا كَانَ صَبِيٌّ فِي يَدِ رَجُلٍ وَهُوَ يُعَبِّرُ عَنْ نَفْسِهِ ، فَقَالَ: أَنَا حُرٌّ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ)، لِأَنَّهُ فِي يَدِ نَفْسِهِ ، (وَلَوْ قَالَ أَنَا عَبْدٌ لِفُلَانٍ ، فَهُوَ عَبْدٌ لِلَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ) ، لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِأَنَّهُ لَا يَدَ لَهُ حَيْثُ أَقَرَّ بِالرَّقِّ ، (وَإِنْ كَانَ لَا يُعَبِّرُ عَنْ نَفْسِهِ فَهُوَ عَبْدٌ لِلَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ) ، لِأَنَّهُ لَا يَدَ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ لَمَّا كَانَ لَا يُعَبِّرُ عَنْهَا وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَتَاعِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ يُعَبِّرُ، فَلَوْ كَبِرَ ، وَادَّعَى الْحُرِّيَّةَ ، لَا يَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ ، لِأَنَّهُ ظَهَرَ الرَّقُّ عَلَيْهِ فِي حَالِ صِغَرِهِ.

إذا كان الحائط لرجل عليه جذوع ولآخر عليه هرادي : "قَالَ: (وَإِذَا كَانَ الْحَائِطُ لِرَجُلٍ عَلَيْهِ جُذُوعٌ أَوْ مُتَّصِلٌ بِنَائِهِ ، وَالْآخَرُ عَلَيْهِ هَرَادِيٌّ ⁽⁵¹²⁾) ، فَهُوَ لِصَاحِبِ الْجُذُوعِ وَالْإِتِّصَالِ، وَالْهَرَادِيٍّ لَيْسَتْ بِشَيْءٍ) ، لِأَنَّ صَاحِبَ الْجُذُوعِ صَاحِبُ اسْتِعْمَالٍ ، وَالْآخَرُ صَاحِبُ تَعَلُّقٍ ، فَصَارَ كَدَابَّةٍ تَنَازَعَا فِيهَا ، وَلِأَحَدِهِمَا حِمْلٌ عَلَيْهَا ، وَلِلْآخَرِ كُوزٌ مُعَلَّقٌ بِهَا، وَالْمُرَادُ

(⁵¹²) (هرادي): جمع هردية، قصبات تضم – ملتوية - بطاقات من الكرم ، فترسل عليها قضبان الكرم ، أو هي خشبات توضع على الجذوع ويلقى عليها التراب . البناية 408/9 ، درر الحكام شرح غرر الأحكام 350/2.

بِالِاتِّصَالِ مُدَاخَلَةً لِبَيْنِ جِدَارِهِ فِيهِ ، وَلِبَيْنِ هَذَا فِي جِدَارِهِ ، وَقَدْ يُسَمَّى اتِّصَالُ تَرْبِيعٍ⁽⁵¹³⁾ ، وَهَذَا شَاهِدٌ ظَاهِرٌ لِصَاحِبِهِ ، لِأَنَّ بَعْضَ بِنَائِهِ عَلَى بَعْضِ بِنَاءِ هَذَا الْحَائِطِ.

وَقَوْلُهُ: "الْهَرَادِيُّ لَيْسَتْ بِشَيْءٍ" يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا اِغْتِبَارَ لِلْهَرَادِيِّ أَصْلًا، وَكَذَا الْبَوَارِيُّ ، لِأَنَّ الْحَائِطَ لَا تُبْنَى لَهَا أَصْلًا ، حَتَّى لَوْ تَنَازَعَا فِي حَائِطٍ وَلِأَحَدِهِمَا عَلَيْهِ هَرَادِيٌّ ، وَلَيْسَ لِلْآخَرِ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، فَهُوَ بَيْنَهُمَا.

إِذَا كَانَ الْحَائِطُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَيْهِ جُذُوعٌ ثَلَاثَةٌ فَهُوَ بَيْنَهُمَا) لِاسْتَوَائِهِمَا ، وَلَا مُعْتَبَرٌ بِالْأَكْثَرِ مِنْهَا بَعْدَ الثَّلَاثَةِ ، وَإِنْ كَانَ جُذُوعُ أَحَدِهِمَا أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ ، فَهُوَ لِصَاحِبِ الثَّلَاثَةِ ، وَلِلْآخَرِ مَوْضِعُ جِذْعِهِ فِي رِوَايَةٍ، وَفِي رِوَايَةٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا تَحْتَ خَشْبَتِهِ، ثُمَّ قِيلَ مَا بَيْنَ الْخَشْبِ بَيْنَهُمَا، وَقِيلَ عَلَى قَدَرِ خَشْبِهِمَا، وَالْقِيَاسُ أَنَّ يَكُونَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، لِأَنَّهُ لَا مُعْتَبَرٌ بِالْكَثَرَةِ فِي نَفْسِ الْحُجَّةِ ، وَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ الْإِسْتِعْمَالَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ بِقَدَرِ خَشْبَتِهِ ، وَجْهُ الْأَوَّلِ: أَنَّ الْحَائِطَ يُبْنَى لَوْضِعِ كَثِيرِ الْجُذُوعِ دُونَ الْوَاحِدِ وَالْمُثْنَى ، فَكَانَ الظَّاهِرُ شَاهِدًا لِصَاحِبِ الْكَثِيرِ، إِلَّا أَنَّهُ يَبْقَى لَهُ حَقُّ الْوَضْعِ ، لِأَنَّ الظَّاهِرَ لَيْسَ بِحُجَّةٍ فِي اسْتِحْقَاقِ يَدِهِ.

إِذَا كَانَ لِأَحَدِهِمَا جُذُوعٌ وَلِلْآخَرِ اتِّصَالٌ: "(وَلَوْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا جُذُوعٌ وَلِلْآخَرِ اتِّصَالٌ فَالْأَوَّلُ أَوْلَى) وَيُرْوَى الثَّانِي أَوْلَى. وَجْهُ الْأَوَّلِ: أَنَّ لِصَاحِبِ الْجُذُوعِ التَّصَرُّفَ وَلِصَاحِبِ الْإِتِّصَالِ الْيَدَ وَالتَّصَرُّفُ أَقْوَى.

وَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ الْحَائِطَيْنِ بِالِاتِّصَالِ يَصِيرَانِ كِبْنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ ضَرُورَةِ الْقَضَاءِ لَهُ بِبَعْضِهِ الْقَضَاءُ بِكُلِّهِ ، ثُمَّ يَبْقَى لِلْآخَرِ حَقُّ وَضْعِ جُذُوعِهِ لِمَا قُلْنَا، وَهَذِهِ رِوَايَةُ الطَّحَاوِيِّ⁽⁵¹⁴⁾ ، وَصَحَّحَهَا الْجُرْجَانِيُّ⁽⁵¹⁵⁾.

إِذَا كَانَتْ دَارُ مِنْهَا فِي يَدِ رَجُلٍ عَشْرَةُ أَبْيَاتٍ وَفِي يَدِ آخَرٍ بَيْتٌ: "قَالَ: (وَإِذَا كَانَتْ دَارٌ مِنْهَا فِي يَدِ رَجُلٍ عَشْرَةُ أَبْيَاتٍ ، وَفِي يَدِ آخَرٍ بَيْتٌ ، فَالْسَّاحَةُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ) ، لِاسْتَوَائِهِمَا فِي اسْتِعْمَالِهَا وَهُوَ الْمُرُورُ فِيهَا.

⁽⁵¹³⁾ صفة هذا الاتصال : أن يكون الحائط المتنازع فيه من الجانبين متصلًا بحائطين لأحدهما، والحائطان متصلان بحائط له مقابلة بالاتصال بحائط المتنازع . البناءه 409/9.

⁽⁵¹⁴⁾ الطحاوي : أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي الطحاوي، أبو جعفر: فقيه انتهت إليه رئاسة الحنفية بمصر. ولد ونشأ في (طحا) من صعيد مصر، وتفقّه على مذهب الشافعي، ثم تحول حنفياً ، ورحل إلى الشام سنة 268هـ فاتصل بأحمد بن طولون، فكان من خاصته، وتوفي بالقاهرة سنة 321هـ . الإعلام ، للزركلي 206/1

⁽⁵¹⁵⁾ الجرجاني : يوسف بن علي بن محمد الجرجاني، أبو عبد الله ، تفقه على أبي الحسن الكرخي ، كان عالماً تفقه على أبي حنيفة رضي الله عنه وأصحابه ومن تصانيفه خزانة الأكمل في ست مجلدات ت بعد سنة 522هـ. الجواهر المضية 228/2، 229.

إذا ادعى رجلان أرضاً أنها في يده : " قَالَ: (وَإِذَا ادَّعَى رَجُلَانِ أَرْضًا) يَعْنِي يَدَّعِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا (أَنَّهَا فِي يَدِهِ ، لَمْ يَقْضِ أَنَّهَا فِي يَدٍ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَتَّى يُقِيمَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا فِي أَيْدِيهِمَا) ، لِأَنَّ الْيَدَ فِيهَا غَيْرُ مُشَاهِدَةٍ لِتَعَذُّرِ إِحْضَارِهَا، وَمَا غَابَ عَنِ عِلْمِ الْقَاضِي ، فَالْبَيِّنَةُ تُشَبِّهُهُ ، وَإِنْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا الْبَيِّنَةَ جُعِلَتْ فِي يَدِهِ) ، لِإِقْيَامِ الْحُجَّةِ ، لِأَنَّ الْيَدَ حَقٌّ مَقْصُودٌ ، (وَإِنْ أَقَامَا الْبَيِّنَةَ جُعِلَتْ فِي أَيْدِيهِمَا) ، لِمَا بَيَّنَّا فَلَا يَسْتَحِقُّ لِأَحَدِهِمَا مِنْ غَيْرِ حُجَّةٍ ، (وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا قَدْ لَبِنَ فِي الْأَرْضِ أَوْ بَنَى أَوْ حَفَرَ فَهِيَ فِي يَدِهِ) لَوْجُودِ التَّصَرُّفِ وَالِاسْتِعْمَالِ فِيهَا⁽⁵¹⁶⁾.

(⁵¹⁶) الجامع الصغير وشرحه ص 383، 384.

(بَابُ دَعْوَى النَّسَبِ)

باع جارية فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر فادعاه البائع : "(وَإِذَا بَاعَ جَارِيَةً فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَادَّعَاهُ الْبَائِعُ) ، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلِّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ بَاعَ ، فَهُوَ ابْنُ الْبَائِعِ ، وَأُمُّهُ أُمَّ وَلَدِهِ لَهُ ، (وَفِي الْقِيَاسِ هُوَ قَوْلُ زُفَرٍ وَالشَّافِعِيِّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ دَعْوَتُهُ بَاطِلَةٌ) ، لِأَنَّ الْبَيْعَ اعْتَرَفَ مِنْهُ بِأَنَّهُ عَبْدٌ فَكَانَ فِي دَعْوَاهُ مُنَاقِضًا وَلَا نَسَبَ بِدُونِ الدَّعْوَى.

وَجْهُ الْإِسْتِحْسَانِ : أَنَّ اتِّصَالَ الْعُلُقِ بِمِلْكِهِ شَهَادَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى كَوْنِهِ مِنْهُ ، لِأَنَّ الظَّاهِرَ عَدَمُ الزَّوْنِ ، وَمَبْنَى النَّسَبِ عَلَى الْخَفَاءِ فَيُعْفَى فِيهِ التَّنَاقُضُ ، وَإِذَا صَحَّتِ الدَّعْوَى اسْتَنَدَتْ إِلَى وَقْتِ الْعُلُقِ ، فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ بَاعَ أُمَّ وَلَدِهِ فَيُفْسَخُ الْبَيْعُ ، لِأَنَّ بَيْعَ أُمِّ الْوَلَدِ لَا يَجُوزُ ، (وَيُرَدُّ الثَّمَنُ) ، لِأَنَّهُ قَبْضُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ (وَإِنْ ادَّعَاهُ الْمُشْتَرِي مَعَ دَعْوَةِ الْبَائِعِ أَوْ بَعْدَهُ فَدَعْوَةُ الْبَائِعِ أُولَى) ، لِأَنَّهَا أَسْبَقُ ، لِاسْتِنَادِهَا إِلَى وَقْتِ الْعُلُقِ وَهَذِهِ دَعْوَةُ اسْتِيلَادٍ.

باع جارية فجاءت بولد لأكثر من سنتين فادعاه البائع : "(وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ مِنْ وَقْتِ الْبَيْعِ لَمْ تَصِحَّ دَعْوَةُ الْبَائِعِ) ، لِأَنَّهُ لَمْ يُوْجَدْ اتِّصَالُ الْعُلُقِ بِمِلْكِهِ تَيَقُّنًا ، وَهُوَ الشَّاهِدُ وَالْحُجَّةُ ، (إِلَّا إِذَا صَدَّقَهُ الْمُشْتَرِي) فَيُثْبِتُ النَّسَبَ ، وَيَحْمِلُ عَلَى الْإِسْتِيلَادِ بِالنِّكَاحِ ، وَلَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ ، لِأَنَّا تَيَقَّنَا أَنَّ الْعُلُقَ لَمْ يَكُنْ فِي مِلْكِهِ فَلَا يُثْبِتُ حَقِيقَةَ الْعِنَقِ وَلَا حَقَّهُ ، وَهَذِهِ دَعْوَةُ تَحْرِيرٍ ، وَغَيْرُ الْمَالِكِ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ.

باع جارية فجاءت بولد لأكثر من ستة ولأقل من سنتين فادعاه البائع : "(وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الْبَيْعِ وَلِأَقَلِّ مِنْ سَنَتَيْنِ ، لَمْ تُقْبَلْ دَعْوَةُ الْبَائِعِ فِيهِ إِلَّا أَنْ يُصَدَّقَهُ الْمُشْتَرِي) ، لِأَنَّهُ احْتَمَلَ أَنْ لَا يَكُونَ الْعُلُقُ فِي مِلْكِهِ فَلَمْ تُوجَدْ الْحُجَّةُ فَلَا بُدَّ مِنْ تَصَدِيقِهِ ، وَإِذَا صَدَّقَهُ يُثْبِتُ النَّسَبَ ، وَيَبْطُلُ الْبَيْعُ ، وَالْوَلَدُ حُرٌّ ، وَالْأُمُّ أُمَّ وَلَدِهِ لَهُ ، كَمَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى لِتَصَادُقِهِمَا ، وَاحْتِمَالِ الْعُلُقِ فِي الْمَلِكِ .

باع جارية فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر ثم مات فادعاه البائع : " قال: (فَإِنْ مَاتَ الْوَلَدُ فَادَّعَاهُ الْبَائِعُ ، وَقَدْ جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلِّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ، لَمْ يَثْبُتِ الْإِسْتِيلَادُ فِي الْأُمِّ) ، لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ لِلْوَلَدِ ، وَلَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ بَعْدَ الْمَوْتِ ، لِعَدَمِ حَاجَتِهِ إِلَى ذَلِكَ فَلَا يَتَّبَعُهُ اسْتِيلَادُ الْأُمِّ .

باع جارية فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر ثم ماتت الأم فادعاه البائع : "(وَإِنْ مَاتَتْ الْأُمُّ فَادَّعَاهُ الْبَائِعُ وَقَدْ جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلِّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ، يَثْبُتُ النَّسَبُ فِي الْوَلَدِ وَأَخَذَهُ الْبَائِعُ) ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ هُوَ الْأَصْلُ فِي النَّسَبِ ، فَلَا يَضُرُّهُ فَوَاتُ النَّبْعِ ، وَإِنَّمَا كَانَ الْوَلَدُ أَصْلًا ، لِأَنَّهَا تُضَافُ إِلَيْهِ ، يُقَالُ : أُمُّ الْوَلَدِ ، وَتُسْتَفِيدُ الْحُرِّيَّةُ مِنْ جِهَتِهِ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - "أَعْتَقَهَا

وَلَدَهَا⁽⁵¹⁷⁾ ، وَالثَّابِتُ لَهَا حَقُّ الْحُرِّيَّةِ ، وَلَهُ حَقِيقَتُهَا ، وَالْأَدْنَى يَتَّبِعُ الْأَعْلَى (وَيَرُدُّ الثَّمَنَ كُلَّهُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالَا: يَرُدُّ حِصَّةَ الْوَلَدِ ، وَلَا يَرُدُّ حِصَّةَ الْأُمِّ) ، لِأَنَّهُ نَبِيْنٌ أَنَّهُ بَاعَ أُمَّ وَلَدِهِ ، وَمَالِيَتُهَا غَيْرُ مُتَقَوِّمَةٍ عِنْدَهُ فِي الْعَقْدِ وَالْغَضَبِ ، فَلَا يَضْمَنُهَا الْمُشْتَرِي ، وَعِنْدَهُمَا مُتَقَوِّمَةٌ فَيَضْمَنُهَا.

وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: وَإِذَا حَمَلَتْ الْجَارِيَّةُ فِي مِلْكٍ رَجُلٍ فَبَاعَهَا فَوَلَدَتْ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فَادَّعَى الْبَائِعُ الْوَلَدَ وَقَدْ أَعْتَقَ الْمُشْتَرِي الْأُمَّ فَهُوَ ابْنُهُ يَرُدُّ عَلَيْهِ بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ، وَلَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي إِنَّمَا أَعْتَقَ الْوَلَدَ فَدَعَا بَاطِلَةً⁽⁵¹⁸⁾.

وَوَجْهُ الْفَرْقِ : أَنَّ الْأَصْلَ فِي هَذَا الْبَابِ الْوَلَدُ ، وَالْأُمُّ تَابِعَةٌ لَهُ عَلَى مَا مَرَّ ، وَفِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ : قَامَ الْمَانِعُ مِنَ الدَّعْوَةِ وَالْإِسْتِيلَادِ ، وَهُوَ الْعَتَقُ فِي النَّبْعِ وَهُوَ الْأُمُّ ، فَلَا يَمْتَنِعُ ثُبُوتُهُ فِي الْأَصْلِ ، وَهُوَ الْوَلَدُ ، وَلَيْسَ مِنْ ضَرُورَاتِهِ ، كَمَا فِي وَلَدِ الْمَغْرُورِ فَإِنَّهُ حُرٌّ ، وَأُمُّهُ أَمَةٌ لِمَوْلَاهَا ، وَكَمَا فِي الْمُسْتَوْلَدَةِ بِالنِّكَاحِ ، وَفِي الْفَصْلِ الثَّانِي : قَامَ الْمَانِعُ بِالْأَصْلِ ، وَهُوَ الْوَلَدُ ، فَيَمْتَنِعُ ثُبُوتُهُ فِيهِ وَفِي النَّبْعِ ، وَإِنَّمَا كَانَ الْإِعْتَاقُ مَانِعًا ، لِأَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ النَّقْضَ ، كَحَقِّ اسْتِلْحَاقِ النَّسَبِ ، وَحَقِّ الْإِسْتِيلَادِ ، فَاسْتَوَيَا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، ثُمَّ الثَّابِتُ مِنَ الْمُشْتَرِي حَقِيقَةُ الْإِعْتَاقِ ، وَالثَّابِتُ فِي الْأُمِّ حَقُّ الْحُرِّيَّةِ ، وَفِي الْوَلَدِ لِلْبَائِعِ حَقُّ الدَّعْوَةِ ، وَالْحَقُّ لَا يُعَارِضُ الْحَقِيقَةَ ، وَالتَّدْبِيرُ ، بِمَنْزِلَةِ الْإِعْتَاقِ ، لِأَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ النَّقْضَ ، وَقَدْ ثَبَتَ بِهِ بَعْضُ آثَارِ الْحُرِّيَّةِ ، وَقَوْلُهُ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ يَرُدُّ عَلَيْهِ بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ قَوْلُهُمَا ، وَعِنْدَهُ يَرُدُّ بِكُلِّ الثَّمَنِ ، هُوَ الصَّحِيحُ كَمَا ذَكَرْنَا فِي فَصْلِ الْمَوْتِ.

إِذَا بَاعَ عَبْدًا وَلَدَ عِنْدَهُ وَبَاعَهُ الْمُشْتَرِي مِنْ آخَرٍ ثُمَّ ادَّعَاهُ الْبَائِعُ الْأَوَّلُ : "قَالَ: (وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَدَ عِنْدَهُ ، وَبَاعَهُ الْمُشْتَرِي مِنْ آخَرٍ ، ثُمَّ ادَّعَاهُ الْبَائِعُ الْأَوَّلُ ، فَهُوَ ابْنُهُ ، وَيَبْطُلُ الْبَيْعُ) ، لِأَنَّ الْبَيْعَ يَحْتَمِلُ النَّقْضَ ، وَمَا لَهُ مِنْ حَقِّ الدَّعْوَةِ لَا يَحْتَمِلُهُ ، فَيُنْقَضُ الْبَيْعُ لِأَجْلِهِ ، وَكَذَا إِذَا كَاتَبَ الْوَلَدَ أَوْ رَهْنَهُ أَوْ أَجَرَهُ ، أَوْ كَاتَبَ الْأُمَّ أَوْ رَهْنَهَا أَوْ زَوَّجَهَا ، ثُمَّ كَانَتْ الدَّعْوَةُ ، لِأَنَّ هَذِهِ الْعَوَارِضَ تَحْتَمِلُ النَّقْضَ فَيُنْقَضُ ذَلِكَ كُلُّهُ ، وَتَصِحُّ الدَّعْوَةُ ، بِخِلَافِ الْإِعْتَاقِ وَالتَّدْبِيرِ عَلَى مَا مَرَّ ، وَبِخِلَافِ مَا إِذَا ادَّعَاهُ الْمُشْتَرِي أَوَّلًا ، ثُمَّ ادَّعَاهُ الْبَائِعُ ، حَيْثُ لَا يَتَّبِعُ النَّسَبُ مِنَ الْبَائِعِ ، لِأَنَّ النَّسَبَ الثَّابِتَ مِنَ الْمُشْتَرِي لَا يَحْتَمِلُ النَّقْضَ ، فَصَارَ كَالْإِعْتَاقِ.

ادَّعَى نَسَبَ أَحَدِ التَّوَأْمَيْنِ : " قَالَ (وَمَنْ ادَّعَى نَسَبَ أَحَدِ التَّوَأْمَيْنِ ثَبَتَ نَسَبُهُمَا مِنْهُ) ، لِأَنَّهُمَا مِنْ مَاءٍ وَاحِدٍ ، فَمِنْ ضَرُورَةِ ثُبُوتِ نَسَبِ أَحَدِهِمَا ثُبُوتُ نَسَبِ الْآخَرِ ، وَهَذَا لِأَنَّ التَّوَأْمَيْنِ

(⁵¹⁷) (المستدرك ، للحاكم رقم 2191 ، وقال الذهبي في سنده : "حسين بن عبد الله متروك" ، السنن الصغرى للبيهقي رقم 3494 عن ابن عباس (رضى الله عنه)
(⁵¹⁸) (الجامع الصغير ص 413.

وَلَدَانِ بَيْنَ وَلَادَتِهِمَا أَقَلُّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ، فَلَا يُتَصَوَّرُ عُلوْقُ الثَّانِي حَدِيثًا ، لِأَنَّهُ لَا حَبْلَ لِأَقَلِّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ⁽⁵¹⁹⁾.

وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: إِذَا كَانَ فِي يَدِهِ غُلَامَانِ تَوَآمَنَ وَلَدَا عَنْدَهُ فَبَاعَ أَحَدَهُمَا وَأَعْتَقَهُ الْمُشْتَرِي ثُمَّ ادَّعَى الْبَائِعُ الَّذِي فِي يَدِهِ فَهُمَا ابْنَاهُ وَبَطَلَ عِتْقُ الْمُشْتَرِي⁽⁵²⁰⁾؛ لِأَنَّهُ لَمَّا ثَبَتَ نَسَبُ الْوَلَدِ الَّذِي عَنْدَهُ لِمُصَادَفَةِ الْعُلُوقِ وَالِدَعْوَةِ مَلَكُهُ إِذِ الْمَسْأَلَةُ مَفْرُوضَةٌ فِيهِ ، ثَبَتَ بِهِ حُرِّيَّةُ الْأَصْلِ فِيهِ ، فَيُثَبِّتُ نَسَبُ الْآخَرِ ، وَحُرِّيَّةُ الْأَصْلِ فِيهِ ضَرُورَةٌ ، لِأَنَّهُمَا تَوَآمَنَ ، فَتَبَيَّنَ أَنَّ عِتْقَ الْمُشْتَرِي وَشِرَاءَهُ لَأَقَى حُرِّيَّةَ الْأَصْلِ فَبَطَلَ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ الْوَلَدُ وَاحِدًا ، لِأَنَّ هُنَاكَ يَبْطُلُ الْعِتْقُ فِيهِ مَقْصُودًا ، لِحَقِّ دَعْوَةِ الْبَائِعِ ، وَهُنَا ثَبَتَ تَبَعًا لِحُرِّيَّتِهِ فِيهِ حُرِّيَّةُ الْأَصْلِ ، فَافْتَرَقَا (وَلَوْ لَمْ يَكُنْ أَصْلُ الْعُلُوقِ فِي مَلِكِهِ ، ثَبَتَ نَسَبُ الْوَلَدِ الَّذِي عَنْدَهُ ، وَلَا يُنْقَضُ الْبَيْعُ فِيمَا بَاعَ) ، لِأَنَّ هَذِهِ دَعْوَةُ تَحْرِيرٍ ، لِإِنْعَادِ شَاهِدِ الْإِنِّصَالِ ، فَيَقْتَصِرُ عَلَى مَحَلِّ وَلَايَتِهِ.

قَالَ : (وَإِذَا كَانَ الصَّبِيُّ فِي يَدِ رَجُلٍ فَقَالَ: هُوَ ابْنُ عَبْدِ فُلَانٍ الْغَائِبِ ، ثُمَّ قَالَ: هُوَ ابْنِي ، لَمْ يَكُنْ ابْنُهُ أَبَدًا، وَإِنْ جَحَدَ الْعَبْدُ أَنْ يَكُونَ ابْنَهُ) ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، (وَقَالَا: إِذَا جَحَدَ الْعَبْدُ فَهُوَ ابْنُ الْمَوْلَى) وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ ، إِذَا قَالَ: هُوَ ابْنُ فُلَانٍ وَلَدَ عَلَى فِرَاشِهِ ، ثُمَّ ادَّعَاهُ لِنَفْسِهِ ، لَهُمَا : أَنَّ الْإِقْرَارَ ارْتَدَّ بَرْدَ الْعَبْدِ ، فَصَارَ كَأَنَّ لَمْ يَكُنْ الْإِقْرَارُ ، وَالْإِقْرَارُ بِالنَّسَبِ يَرْتَدُّ بِالرَّدِّ ، وَإِنْ كَانَ لَا يَحْتَمِلُ النِّقْضَ؛ أَلَا يَرَى أَنَّهُ يَعْمَلُ فِيهِ الْإِكْرَاهُ وَالْهَزْلُ ، فَصَارَ كَمَا إِذَا أَقَرَّ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِإِعْتَاقِ الْمُشْتَرَى ، فَكَذَّبَهُ الْبَائِعُ ، ثُمَّ قَالَ : أَنَا أَعْتَقْتُهُ ، يَتَحَوَّلُ الْوَلَاءُ إِلَيْهِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا صَدَّقَهُ ، لِأَنَّهُ يَدَّعِي بَعْدَ ذَلِكَ نَسَبًا ثَابِتًا مِنَ الْغَيْرِ، وَبِخِلَافِ مَا إِذَا لَمْ يُصَدِّقْهُ وَلَمْ يُكْذِّبْهُ ، لِأَنَّهُ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْمُقَرَّرِ لَهُ عَلَى اعْتِبَارِ تَصَدِيقِهِ ، فَيَصِيرُ كَوَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ ، فَإِنَّهُ لَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْ غَيْرِ الْمُلَاعَنِ؛ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يُكْذِّبَ نَفْسَهُ.

وَلِأَبِي حَنِيفَةَ : أَنَّ النَّسَبَ مِمَّا لَا يَحْتَمِلُ النِّقْضَ بَعْدَ ثُبُوتِهِ ، وَالْإِقْرَارُ بِمِثْلِهِ لَا يَرْتَدُّ بِالرَّدِّ ، فَبَقِيَ ، فَتَمْتَنِعُ دَعْوَتُهُ، كَمَنْ شَهِدَ عَلَى رَجُلٍ بِنَسَبِ صَغِيرٍ فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ لِنُهْمَةٍ ، ثُمَّ ادَّعَاهُ

(⁵¹⁹) (قال) : أي القدوري (ومن ادعى نسب أحد التوأمين) التوأم : اسم للولد إذا كان معه آخر في بطن واحد، يقال : هما توأمين ، كما يقال: هما زوجان ، وقولهما هما توأم ، وهما زوج خطأ؛ كذا في " المغرب " . وقال شمس الأئمة: يجوز أن يقال: غلامان توأم وتوأمين، قال: ذكر التوأم مكان التوأمين صحيح في اللغة (ثبت نسبهما منه) أي نسب التوأمين من المدعي ، (لأنهما) خلقاً (من ماء واحد، فمن ضرورة ثبوت نسب أحدهما ثبوت نسب الآخر، وهذا) أشار به إلى قوله " فمن ضرورة ثبوت نسب أحدهما ثبوت الآخر " ، (لأن التوأمين ولدان بين ولادتهما أقل من ستة أشهر) إنما قيد بذلك ، لأنه إذا كان بينهما ستة أشهر فصاعداً بتوأمين، لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر (فلا يتصور علوق الثاني حادثاً، لأنه لا حبل في أقل من ستة أشهر) . البناية 10/419، المغرب في ترتيب المغرب ص58.

(⁵²⁰) (الجامع الصغير وشرحه ص 413، 414.

لِنَفْسِهِ، وَهَذَا لِأَنَّهُ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْمُقَرَّرِ لَهُ عَلَى اعْتِبَارِ تَصْدِيقِهِ، حَتَّى لَوْ صَدَّقَهُ بَعْدَ التَّكْذِيبِ يَنْبُتُ النَّسَبُ مِنْهُ، وَكَذَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْوَلَدِ ، فَلَا يَرْتَدُّ بِرَدِّ الْمُقَرَّرِ لَهُ.

وَمَسْأَلَةُ الْوَلَاءِ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ، وَلَوْ سَلِمَ ، فَالْوَلَاءُ قَدْ يَنْطُلُ بِاعْتِرَاضِ الْأَقْوَى ، كَجَرِّ الْوَلَاءِ مِنْ جَانِبِ الْأُمِّ إِلَى قَوْمِ الْأَبِ.

وَقَدْ اعْتَرَضَ عَلَى الْوَلَاءِ الْمُؤَفُّوفِ مَا هُوَ أَقْوَى ، وَهُوَ دَعْوَى الْمُسْتَرِي ، فَيَنْطُلُ بِهِ، بِخِلَافِ النَّسَبِ عَلَى مَا مَرَّ ، وَهَذَا يَصْلُحُ مَخْرَجًا عَلَى أَصْلِهِ فِيمَنْ يَبِيعُ الْوَلَدَ وَيَخَافُ عَلَيْهِ الدَّعْوَةَ بَعْدَ ذَلِكَ فَيَقْطَعُ دَعْوَاهُ إِقْرَارُهُ بِالنَّسَبِ لِغَيْرِهِ.

قَالَ: (وَإِذَا كَانَ الصَّبِيُّ فِي يَدِ مُسْلِمٍ ، وَنَصْرَانِيٍّ ، فَقَالَ النَّصْرَانِيُّ: هُوَ ابْنِي ، وَقَالَ الْمُسْلِمُ: هُوَ عَبْدِي ، فَهُوَ ابْنُ النَّصْرَانِيِّ ، وَهُوَ حُرٌّ) ، لِأَنَّ الْإِسْلَامَ مُرَجِّحٌ ، فَيَسْتَدْعِي تَعَارُضًا، وَلَا تَعَارُضَ ، لِأَنَّ نَظَرَ الصَّبِيِّ فِي هَذَا أَوْفَرَ ، لِأَنَّهُ يَنَالُ شَرَفَ الْحُرِّيَّةِ حَالًا ، وَشَرَفَ الْإِسْلَامِ مَالًا، إِذْ دَلَائِلُ الْوَحْدَانِيَّةِ ظَاهِرَةٌ، وَفِي عَكْسِهِ : الْحُكْمُ بِالْإِسْلَامِ تَبَعًا ، وَحَرَمَانُهُ عَنِ الْحُرِّيَّةِ ، لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي وَسْعِهِ اكْتِسَابُهَا (وَلَوْ كَانَتْ دَعْوَتُهُمَا دَعْوَةَ الْبُتَّةِ فَالْمُسْلِمُ أَوْلَى) تَرْجِيحًا لِلْإِسْلَامِ ، وَهُوَ أَوْفَرُ النَّظَرَيْنِ.

ادعت امرأة صبيًا أنه ابنها : "قَالَ (وَإِذَا ادَّعَتْ امْرَأَةٌ صَبِيًّا أَنَّهُ ابْنُهَا ، لَمْ تَجُزْ دَعْوَاهَا ، حَتَّى تَشْهَدَ امْرَأَةٌ عَلَى الْوِلَادَةِ) وَمَعْنَى الْمَسْأَلَةِ : أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ ذَاتَ زَوْجٍ ، لِأَنَّهَا تَدَّعِي تَحْمِيلَ النَّسَبِ عَلَى الْغَيْرِ ، فَلَا تُصَدَّقُ إِلَّا بِحُجَّةٍ، بِخِلَافِ الرَّجُلِ ، لِأَنَّهُ يُحْمَلُ نَفْسُهُ النَّسَبَ، ثُمَّ شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ كَافِيَةٌ فِيهَا ، لِأَنَّ الْحَاجَةَ إِلَى تَعْيِينِ الْوَلَدِ(521).

النسب يثبت بالفراش القائم : "أَمَّا النَّسَبُ فَيُثَبِّتُ بِالْفِرَاشِ الْقَائِمِ، وَقَدْ صَحَّ "أَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - قَبِلَ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ عَلَى الْوِلَادَةِ(522)" ، (وَلَوْ كَانَتْ مُعْتَدَّةً ، فَلَا بُدَّ مِنْ حُجَّةٍ تَامَّةٍ) عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَدْ مَرَّ فِي الطَّلَاقِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَنكُوحَةً وَلَا مُعْتَدَّةً قَالُوا: يَنْبُتُ النَّسَبُ مِنْهَا بِقَوْلِهَا، لِأَنَّ فِيهِ إِلْزَامًا عَلَى نَفْسِهَا دُونَ غَيْرِهَا.

(وَإِنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ ، وَزَعَمَتْ أَنَّهُ ابْنُهَا مِنْهُ وَصَدَّقَهَا فَهُوَ ابْنُهَا ، وَإِنْ لَمْ تَشْهَدْ امْرَأَةٌ ، لِأَنَّهُ التَّرَمَّ نَسَبُهُ ، فَأَغْنَى ذَلِكَ عَنِ الْحُجَّةِ.

(وَإِنْ كَانَ الصَّبِيُّ فِي أَيْدِيهِمَا ، وَزَعَمَ الزَّوْجُ أَنَّهُ ابْنُهُ مِنْ غَيْرِهَا ، وَزَعَمَتْ أَنَّهُ ابْنُهَا مِنْ غَيْرِهِ ، فَهُوَ ابْنُهَا) ، لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْوَلَدَ مِنْهُمَا ، لِإِقَامِ أَيْدِيهِمَا ، أَوْ لِإِقَامِ الْفِرَاشِ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ

(521) ولأن الولادة مما لا يحضرها الرجال، فإذا شهدت قابلة يثبت النسب، وإذا لم يكن لها زوج فالقول لها من غير بينة كما في الرجل. البناية 424/9.

(522) (السنن الصغرى ، للبيهقي رقم 3294 ، وقال : "حديث حذيفة: أن النبي صلى الله عليه وسلم «أجاز شهادة القابلة» لم يصح إسناد» ، سنن الدارقطني رقم 4556.

كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُرِيدُ إِبْطَالَ حَقِّ صَاحِبِهِ ، فَلَا يُصَدِّقُ عَلَيْهِ ، وَهُوَ نَظِيرُ تَوْبٍ فِي يَدِ رَجُلَيْنِ ، يَقُولُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا : هُوَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ آخَرَ غَيْرِ صَاحِبِهِ ، يَكُونُ التَّوْبُ بَيْنَهُمَا ، إِلَّا أَنْ هُنَاكَ يَدْخُلُ الْمُقَرَّرُ لَهُ فِي نَصِيبِ الْمُقَرَّرِ ، لِأَنَّ الْمَحَلَّ يَحْتَمِلُ الشَّرِكَةَ ، وَهَاهُنَا لَا يَدْخُلُ ، لِأَنَّ النَّسَبَ لَا يَحْتَمِلُهَا.

اشترى جارية فولدت عنده فاستحقها آخر : "قَالَ (وَمَنْ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَلَدَتْ وَلَدًا عِنْدَهُ فَاسْتَحَقَّهَا رَجُلٌ ، غَرِمَ الْأَبُ قِيمَةَ الْوَلَدِ يَوْمَ يُخَاصِمُ) ، لِأَنَّهُ وَلَدُ الْمَغْرُورِ ، فَإِنَّ الْمَغْرُورَ : مَنْ يَطْأُ امْرَأَةً مُعْتَمِدًا عَلَى مِلْكِ يَمِينٍ ، أَوْ نِكَاحٍ ، فَتَلِدُ مِنْهُ ، ثُمَّ تُسْتَحَقُّ ، وَوَلَدُ الْمَغْرُورِ (523) حُرٌّ بِالْقِيمَةِ بِاجْتِمَاعِ الصَّحَابَةِ (524) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - ، وَلِأَنَّ النَّظَرَ مِنَ الْجَانِبَيْنِ وَاجِبٌ ، فَيُجْعَلُ الْوَلَدُ حُرًّا الْأَصْلُ فِي حَقِّ أَبِيهِ ، رَقِيقًا فِي حَقِّ مُدَّعِيهِ ، نَظَرًا لَهُمَا ، ثُمَّ الْوَلَدُ حَاصِلٌ فِي يَدِهِ مِنْ غَيْرِ صُنْعِهِ فَلَا يَضْمَنُهُ إِلَّا بِالْمَنْعِ ، كَمَا فِي وَلَدِ الْمَغْصُوبَةِ ، فَلِهَذَا تُعْتَبَرُ قِيمَةُ الْوَلَدِ يَوْمَ الْخُصُومَةِ ، لِأَنَّهُ يَوْمُ الْمَنْعِ.

(وَلَوْ مَاتَ الْوَلَدُ لَا شَيْءَ عَلَى الْأَبِ) ، لِانْعِدَامِ الْمَنْعِ ، وَكَذَا لَوْ تَرَكَ مَالًا ، لِأَنَّ الْإِرْثَ لَيْسَ بِبَدَلٍ عَنْهُ ، وَالْمَالُ لِأَبِيهِ ، لِأَنَّهُ حُرُّ الْأَصْلِ فِي حَقِّهِ ، فَيَرِثُهُ ، (وَلَوْ قَتَلَهُ الْأَبُ يَغْرِمُ قِيمَتَهُ) ، لَوْجُودِ الْمَنْعِ ، وَكَذَا لَوْ قَتَلَهُ غَيْرُهُ فَأَخَذَ دِيَّتَهُ ، لِأَنَّ سَلَامَةَ بَدَلِهِ لَهُ كَسَلَامَتِهِ ، وَمَنْعَ بَدَلِهِ كَمَنْعِهِ ، فَيَغْرِمُ قِيمَتَهُ ، كَمَا إِذَا كَانَ حَيًّا (وَيَرْجِعُ بِقِيمَةِ الْوَلَدِ عَلَى بَائِعِهِ) ، لِأَنَّهُ ضَمِنَ لَهُ سَلَامَتَهُ ، كَمَا يَرْجِعُ بِثَمَنِهِ ، بِخِلَافِ الْعَقْرِ ، لِأَنَّهُ لَزِمَهُ لِاسْتِيفَاءِ مَنَافِعِهَا ، فَلَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْبَائِعِ (525) ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

(523) قال الزيلعي : "لأن المغرور أن يشتري رجل جارية ، ويتملكها بسبب من أسباب الملك ظاهرا ، فاستولدها ، ثم تستحق الجارية ، أو يتزوج امرأة على أنها حرة ، ثم يظهر بالبينة أنها أمة ، وإذا ثبت أنه ولد المغرور ، فهو حر بالقيمة ، كذا روى عن عمر وعلي . وقال الزرقاني البناية على الهداية 32/6 ، الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير ص 403.

(524) قال الزرقاني : (حدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أو عثمان بن عفان) شك الراوي (قضى أحدهما في امرأة غرت رجلا بنفسها وذكرت أنها حرة) ، وهي أمة ، (فتزوجها فولدت له أولادا ، فقضى أن يفدي ولده بمثلهم) قال أبو عمر: قد روي ذلك عن عمر وعثمان جميعا ، وولد المغرور حر عند الجمهور. وقال أبو ثور وداود: رقيق ولا قيمة فيهم على أحد. قال الطحاوي: وهو القياس لكنهم تركوه لاتفاق الصحابة على أنهم أحرار ، وعلى الأب قيمتهم. أبو عمر: لا دخل للقياس فيما يخالف السلف فاتباعهم خير من الابتداع. (قال مالك: والقيمة عدل) من المثل (في هذا إن شاء الله) وعليه اعتمد أهل مذهبه ، وقال مرة: عليه المثل ، ثم رجع . شرح الزرقاني على الموطأ 57/4.

(525) قال العيني : بالنسبة للعقر أى المهر : معناه " أن المغرور لا يرجع على بائعه بعقد وجب عليه ، لأن - أى المهر - ضمان المنفعة ، وهي ليست من أجزاء المبيع حقيقة. البناية على الهداية 427/9.

كتاب الصلح

أنواع الصلح وحكمه⁽⁵²⁶⁾:

قَالَ (الصُّلْحُ)⁽⁵²⁷⁾ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ: صُلْحٌ مَعَ إِقْرَارٍ، وَصُلْحٌ مَعَ سُكُوتٍ: وَهُوَ أَنْ لَا يُقَرَّرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَلَا يُنْكَرَ ، وَصُلْحٌ مَعَ إنْكَارٍ ، وَكُلُّ ذَلِكَ جَائِزٌ⁽⁵²⁸⁾) ، لِإِطْلَاقِ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ [النساء: 128] وَلِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: "كُلُّ صُلْحٍ جَائِزٌ فِيمَا بَيْنَ

الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا"⁽⁵²⁹⁾ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَجُوزُ مَعَ إنْكَارٍ أَوْ سُكُوتٍ لِمَا رَوَيْنَا، وَهَذَا بِهِذِهِ الصِّفَةِ ، لِأَنَّ الْبَدَلَ كَانَ حَلَالًا عَلَى الدَّافِعِ حَرَامًا عَلَى الْآخِذِ فَيَنْقَلِبُ الْأَمْرُ، وَلِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَدْفَعُ الْمَالَ لِقَطْعِ الْخُصُومَةِ ، وَهَذَا رِشْوَةٌ⁽⁵³⁰⁾) ، وَلَنَا مَا تَلَوْنَا وَأَوَّلُ مَا رَوَيْنَا ، وَتَأْوِيلُ آخِرِهِ "أَحَلَّ حَرَامًا " لِعَيْنِهِ ، كَالْخَمْرِ " أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا " لِعَيْنِهِ ، كَالصُّلْحِ عَلَى أَنْ لَا يَطَأَ الضَّرَّةَ ، وَلِأَنَّ هَذَا صُلْحٌ بَعْدَ دَعْوَى صَحِيحَةٍ فَيُقْضَى بِجَوَازِهِ ، لِأَنَّ الْمُدَّعَى يَأْخُذُهُ عَوَضًا عَنْ حَقِّهِ فِي زَعْمِهِ وَهَذَا مَشْرُوعٌ، وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَدْفَعُهُ لِدَفْعِ الْخُصُومَةِ

(526) كافة العناوين الجانبية المظلمة في كتاب الصلح من وضع المحقق .
(527) الصلح لغة : اسم للمصالحة ، واصطلاحاً: عبارة عن عقد وضع لرفع المنازعة بالتراضي .
نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار ، لقاضى زادة أفندى ، وهى تكملة فتح القدير 403/8 ،
المعرب فى ترتيب المغرب ، لأبى الفتح المطرزي ص 270 ، راجع المادة رقم 1531 من
مجلة الأحكام العدلية.

(528) نصت المادة رقم 1556 من مجلة الأحكام العدلية على أنه "إذا تمَّ الصُّلْحُ فَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنَ الطَّرَفَيْنِ فَقَطُّ الرُّجُوعُ عَنْهُ وَيَمْلِكُ الْمُدَّعَى بِالصُّلْحِ بَدْلَهُ، وَلَا يَبْقَى لَهُ حَقٌّ فِي الدَّعْوَى، وَلَيْسَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَيْضًا اسْتِرْدَادُ بَدَلِ الصُّلْحِ مِنْهُ".

(529) أخرجه الحاكم فى المستدرک ، عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عون، عن أبيه ، عن جده ، برقم 7059، قال الذهبي : واه.

(530) ولقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: 188] والصلح على الإنكار من أكل

المال بالباطل ، ولأنه لم يثبت له حق يجوز أن يعاوض عليه. ، والصلح على الإنكار محرم للحلال ومحل للحرام ، لأنه يحل المعاوضة على غير حق ثابت وذلك حرام ، ويحرم على المدعي باقي حقه وذلك حلال ، ولأنه صلح على مجرد الدعوى فوجب أن يكون باطلا ، كما لو ادعى قتل عمد فصولح عليه مع الإنكار، ولأنه اعتاض عن حق لم يثبت له ، فوجب أن لا يملك عوضه ، ولأنه صالح من لم يعلم صدقه فوجب أن لا يصح ، كما لو علم كذبه ، ولأنه نوع معاوضة لا يصح مع الجهالة فوجب أن لا يصح مع الإنكار كالبيع ، ولأن الصلح لما لم يجز على مجهول الوصف فأولى أن لا يجوز على مجهول العين. الحاوى للمواردى 369/6 ، 370 ، 293/7.

عَنْ نَفْسِهِ ، وَهَذَا مَشْرُوعٌ أَيْضًا ، إِذْ الْمَالُ وَقَايَةُ الْآنْفُسِ ، وَدَفْعُ الرِّشْوَةِ لِدَفْعِ الظُّلْمِ أَمْرٌ جَائِزٌ⁽⁵³¹⁾.

المعتبر في الصلح عن إقرار : قَالَ (فَإِنْ وَقَعَ الصُّلْحُ عَنْ إِقْرَارٍ أُعْتَبِرَ فِيهِ مَا يُعْتَبَرُ فِي الْبَيَاعَاتِ إِنْ وَقَعَ عَنْ مَالٍ بِمَالٍ) ، لَوْجُودِ مَعْنَى الْبَيْعِ ، وَهُوَ مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ فِي حَقِّ الْمُتَعَاقِدِينَ بِتَرَاضِيهِمَا (فَنَجْزِي فِيهِ الشُّفْعَةَ⁽⁵³²⁾) إِذَا كَانَ عَقَارًا، وَيُرَدُّ بِالْعَيْبِ، وَيَتَّبَعُ فِيهِ خِيَارُ الرُّوْيَةِ وَالشَّرْطِ، وَيُفْسِدُهُ جَهَالَةُ الْبَدَلِ) ، لِأَنَّهَا هِيَ الْمُفْضِيَةُ إِلَى الْمُنَازَعَةِ دُونَ جَهَالَةِ الْمَصَالِحِ عَنْهُ ، لِأَنَّهُ يَسْقُطُ وَيُشْتَرَطُ الْقُدْرَةُ عَلَى تَسْلِيمِ الْبَدَلِ⁽⁵³³⁾.

المعتبر في الصلح عن مال بمنافع : (وَإِنْ وَقَعَ عَنْ مَالٍ بِمَنَافِعٍ ، يُعْتَبَرُ بِالْإِجَارَاتِ) ، لَوْجُودِ مَعْنَى الْإِجَارَةِ ، وَهُوَ تَمْلِكُ الْمَنَافِعِ بِمَالٍ ، وَالْإِجَارَةُ فِي الْعُقُودِ لِمَعَانِيهَا ، فَيُشْتَرَطُ التَّوَقُّيْتُ فِيهَا وَيَبْطُلُ، الصُّلْحُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا فِي الْمُدَّةِ لِأَنَّهُ إِجَارَةٌ.

الصلح عن السكوت والإنكار في حق المدعى والمدعى عليه لافتداء اليمين : قال: (وَالصُّلْحُ عَنْ السُّكُوتِ وَالْإِنْكَارِ فِي حَقِّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، لِإِفْتِدَاءِ الْيَمِينِ ، وَقَطْعِ الْخُصُومَةِ ، وَفِي حَقِّ الْمُدَّعَى بِمَعْنَى الْمُعَاوَضَةِ) لِمَا بَيَّنَّا⁽⁵³⁴⁾.

(⁵³¹) فَدَفْعُ الرِّشْوَةِ لِدَفْعِ الضَّرَرِ عَنْ نَفْسِهِ فَجَائِزٌ لِلدَّافِعِ . العناية 408/8.
(⁵³²) الشفعة لغة : الشفع ، الضم ، لِأَنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ: شَفَعْتُ الرَّسُولَ بَآخِرَ، أَيِ جَعَلْتُهُمَا اثْنَيْنِ، واصطلاحاً : تملك البقعة جبراً على المشتري بما قام عليه . البحر الرائق 143/8، درة الغواص في أوهام الخواص ، للقاسم بن علي بن محمد بن عثمان، أبو محمد الحريري البصري (المتوفى: 516هـ) ص217.

(⁵³³) وَهَذَا لَيْسَ عَلَى إِطْلَاقِهِ بَلْ فِيهِ تَفْصِيلٌ، وَهُوَ أَنَّ الصُّلْحَ بِإِغْتِيَارِ بَدَلِيهِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا عَلَى مَعْلُومٍ، وَهُوَ جَائِزٌ لَا مَحَالَةَ ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ عَنْ مَجْهُولٍ عَلَى مَجْهُولٍ، فَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ فِيهِ إِلَى التَّسْلِيمِ وَالتَّسَلُّمِ مِثْلُ أَنْ يَدَّعِيَ حَقًّا فِي دَارِ رَجُلٍ وَادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَقًّا فِي أَرْضٍ بِيَدِ الْمُدَّعَى وَاصْطَلَحَا عَلَى تَرْكِ الدَّعْوَى جَازًا، وَإِنْ أُحْتِيجَ إِلَيْهِ وَقَدْ اصْطَلَحَا عَلَى أَنْ يَدْفَعَ أَحَدُهُمَا مَالًا وَلَمْ يُبَيِّنْهُ عَلَى أَنْ يَتْرَكَ الْآخَرَ دَعْوَاهُ أَوْ عَلَى أَنْ يُسَلِّمَ إِلَيْهِ مَا ادَّعَاهُ لَمْ يَجُزْ ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ عَنْ مَجْهُولٍ عَلَى مَعْلُومٍ وَقَدْ أُحْتِيجَ فِيهِ إِلَى التَّسْلِيمِ، كَمَا لَوْ ادَّعَى حَقًّا فِي دَارِ رَجُلٍ وَلَمْ يُسَمِّهِ فَاصْطَلَحَا عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ الْمُدَّعَى مَالًا مَعْلُومًا لِيُسَلِّمَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِلَى الْمُدَّعَى مَا ادَّعَاهُ وَهُوَ لَا يَجُوزُ، وَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ فِيهِ إِلَى التَّسْلِيمِ كَمَا إِذَا اصْطَلَحَا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ عَلَى أَنْ يَتْرَكَ الْمُدَّعَى دَعْوَاهُ جَازًا ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ عَنْ مَعْلُومٍ عَلَى مَجْهُولٍ وَقَدْ أُحْتِيجَ فِيهِ إِلَى التَّسْلِيمِ لَا يَجُوزُ، وَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ إِلَيْهِ جَازًا .
وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ : أَنَّ الْجَهَالََةَ الْمُفْضِيَةَ إِلَى الْمُنَازَعَةِ الْمَانِعَةَ عَنِ التَّسْلِيمِ وَالتَّسَلُّمِ هِيَ الْمُفْسِدَةُ ، فَمَا لَا يَجِبُ فِيهِ التَّسْلِيمُ وَالتَّسَلُّمُ جَازًا، وَمَا وَجَبَا فِيهِ لَمْ يَجُزْ مَعَ الْجَهَالَةِ ، لِأَنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى تَسْلِيمِ الْبَدَلِ شَرْطٌ لِكُونِهِ فِي مَعْنَى الْبَيْعِ . العناية شرح الهداية 409/8.

(⁵³⁴) يشير بهذا إلى ما ذكره بقوله : "لأن المدعى يأخذه عوضاً عن حقه في زعمه " تكملة فتح القدير 410/8.

(وَيَجُوزُ أَنْ يَخْتَلَفَ حُكْمُ الْعَقْدِ فِي حَقِّهِمَا كَمَا يَخْتَلِفُ حُكْمُ الْإِقَالَةِ⁽⁵³⁵⁾) فِي حَقِّ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَغَيْرِهِمَا) وَهَذَا فِي الْإِنْكَارِ ظَاهِرٌ، وَكَذَا فِي السُّكُوتِ ، لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ الْإِفْرَارَ وَالْجُحُودَ فَلَا يَنْبُتُ كَوْنُهُ عَوَضًا فِي حَقِّهِ بِالشَّكِّ.

أثر الصلح عن دار في وجوب الشفعة : قَالَ (وَإِذَا صَلَحَ عَنْ دَارٍ لَمْ يَجِبْ فِيهَا الشُّفْعَةُ) مَعْنَاهُ إِذَا كَانَ عَنْ إِنْكَارٍ أَوْ سُكُوتٍ ، لِأَنَّهُ يَأْخُذُهَا عَلَى أَصْلِ حَقِّهِ ، وَيُدْفَعُ الْمَالُ دَفْعًا لِحُصُومَةِ الْمُدَّعِي ، وَزَعْمُ الْمُدَّعِي لَا يُلْزِمُهُ⁽⁵³⁶⁾ .

أثر الصلح على دار في وجوب الشفعة: بِخِلَافِ مَا إِذَا صَلَحَ عَلَى دَارٍ حَيْثُ يَجِبُ فِيهَا الشُّفْعَةُ ، لِأَنَّ الْمُدَّعِيَّ يَأْخُذُهَا عَوَضًا عَنْ الْمَالِ ، فَكَانَ مُعَاوَضَةً فِي حَقِّهِ ، فَتُلْزِمُهُ الشُّفْعَةُ بِإِقْرَارِهِ وَإِنْ كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يُكَذِّبُهُ⁽⁵³⁷⁾.

أثر استحقاق بعض المصالح عنه في الصلح عن إقرار : قَالَ (وَإِذَا كَانَ الصُّلْحُ عَنْ إِقْرَارٍ ، وَاسْتَحَقَّ بَعْضَ الْمَصَالِحِ عَنْهُ ، رَجَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِحِصَّةِ ذَلِكَ مِنَ الْعَوَضِ) ، لِأَنَّهُ مُعَاوَضَةٌ مُطْلَقَةٌ كَالْبَيْعِ ، وَحُكْمُ الْإِسْتِحْقَاقِ فِي الْبَيْعِ هَذَا⁽⁵³⁸⁾.

أثر استحقاق بعض المصالح عنه في الصلح عن سكوت أو إنكار : (وَإِنْ وَقَعَ الصُّلْحُ عَنْ سُكُوتٍ أَوْ إِنْكَارٍ فَاسْتَحَقَّ الْمُتَنَازِعُ فِيهِ رَجَعَ الْمُدَّعَى بِالْحُصُومَةِ ، وَرَدَّ الْعَوَضُ) ، لِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَا بَدَلَ الْعَوَضِ إِلَّا لِيُدْفَعَ خُصُومَتُهُ عَنْ نَفْسِهِ، فَإِذَا ظَهَرَ الْإِسْتِحْقَاقُ تَبَيَّنَ أَنَّ لَا خُصُومَةَ لَهُ ، فَيَبْقَى الْعَوَضُ فِي يَدِهِ غَيْرَ مُشْتَمِلٍ عَلَى غَرَضِهِ فَيَسْتَرِدُّهُ، وَإِنْ اسْتَحَقَّ بَعْضُ ذَلِكَ رَدَّ حِصَّتَهُ وَرَجَعَ بِالْحُصُومَةِ فِيهِ ، لِأَنَّهُ خَلَا الْعَوَضُ فِي هَذَا الْقَدْرِ عَنِ الْغَرَضِ⁽⁵³⁹⁾.

أثر استحقاق المصالح عليه في الصلح عن إقرار أو إنكار : "وَلَوْ اسْتَحَقَّ الْمُصَالِحَ عَلَيْهِ عَنْ إِقْرَارٍ رَجَعَ بِكُلِّ الْمَصَالِحِ عَنْهُ ، لِأَنَّهُ مُبَادَلَةٌ، وَإِنْ اسْتَحَقَّ بَعْضُهُ رَجَعَ بِحِصَّتِهِ. وَإِنْ كَانَ الصُّلْحُ عَنْ إِنْكَارٍ أَوْ سُكُوتٍ رَجَعَ إِلَى الدَّعْوَى فِي كُلِّهِ ، أَوْ بِقَدْرِ الْمُسْتَحَقِّ إِذَا اسْتَحَقَّ بَعْضُهُ ، لِأَنَّ الْمُبْدَلَ فِيهِ هُوَ الدَّعْوَى، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إِذَا بَاعَ مِنْهُ عَلَى الْإِنْكَارِ شَيْئًا ، حَيْثُ يَرْجِعُ بِالْمُدَّعَى ، لِأَنَّ الْإِقْدَامَ عَلَى الْبَيْعِ إِقْرَارٌ مِنْهُ بِالْحَقِّ لَهُ ، وَلَا كَذَلِكَ الصُّلْحُ ، لِأَنَّهُ قَدْ يَقَعُ لِدَفْعِ

⁽⁵³⁵⁾ (الإقالة : فسخ في حق المتعاقدين ببيع جديد في حق ثالث ، عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف: ببيع جديد في حق الكل . الاختيار لتعليل المختار 11/2.

⁽⁵³⁶⁾ أى لأن المدعى عليه يأخذها ، ليستبقى الدار على ملكه ، لا أنه يشتريها ، ويدفع المال ، لدفع الخصومة على زعمه ، والإنسان يؤاخذ بما فى زعمه ، ولا يلزمه زعم غيره. العناية على الهداية 410/8.

⁽⁵³⁷⁾ (فصار كأنه قال: اشتريتها من المدعى عليه وهو ينكر، فتجب فيها الشفعة. البناءة 10/7.

⁽⁵³⁸⁾ (أي الرجوع بالحصة من العوض . البناءة 7/10.

⁽⁵³⁹⁾ (أي عن غرض المدعى عليه . البناءة 8/10.

الْخُصُومَةِ، وَلَوْ هَلَكَ بَدَلُ الصُّلْحِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ ، فَالْجَوَابُ فِيهِ كَالْجَوَابِ فِي الْإِسْتِحْقَاقِ فِي الْفَصْلَيْنِ⁽⁵⁴⁰⁾.

أثر استحقاق المصالح عليه في دعوى الحق غير الثابت : قَالَ (وَإِنْ ادَّعَى حَقًّا فِي دَارٍ وَلَمْ يُبَيِّنْهُ فَصُولِحَ مِنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ اسْتَحَقَّ بَعْضَ الدَّارِ لَمْ يَرُدَّ شَيْئًا مِنَ الْعَوَضِ ، لِأَنَّ دَعْوَاهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِيهَا بَقِيَّةٌ) ، بِخِلَافِ مَا إِذَا اسْتَحَقَّ كُلُّهُ ، لِأَنَّهُ يَعْرِى الْعَوَضُ عِنْدَ ذَلِكَ عَنْ شَيْءٍ يُقَابِلُهُ فَيَرْجِعُ بِكُلِّهِ عَلَى مَا قَدَّمَاهُ فِي الْبُيُوعِ.

المصالحة على جزء من المدعى به : " وَلَوْ ادَّعَى دَارًا فَصَالَحَهُ عَلَى قِطْعَةٍ مِنْهَا ، لَمْ يَصِحَّ الصُّلْحُ ، لِأَنَّ مَا قَبَضَهُ مِنْ عَيْنِ حَقِّهِ ، وَهُوَ عَلَى دَعْوَاهُ فِي الْبَاقِي ، وَالْوَجْهُ فِيهِ أَحَدُ أَمْرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَزِيدَ بِهِمَا فِي بَدَلِ الصُّلْحِ فَيَصِيرَ ذَلِكَ عَوَضًا عَنْ حَقِّهِ فِيهَا بَقِيَّةً ، أَوْ يُلْحَقَ بِهِ ذِكْرُ الْبَرَاءَةِ عَنْ دَعْوَى الْبَاقِي⁽⁵⁴¹⁾.

(540) أَيِ فَصْلِ الْإِقْرَارِ وَالْإِنْكَارِ ، فَإِنْ كَانَ عَنْ إِقْرَارٍ رَجَعَ بَعْدَ الْهَلَاكِ إِلَى الْمُدَّعِي ، وَإِنْ كَانَ عَنْ إِنْكَارٍ رَجَعَ بِالْدَّعْوَى. العناية 411/8.

(541) مِثْلُ أَنْ يَقُولَ بَرُّنْتُ مِنْ دَعْوَايَ فِي هَذِهِ الدَّارِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ لِمُصَادَفَةِ الْبَرَاءَةِ الدَّعْوَى وَهُوَ صَحِيحٌ ، حَتَّى لَوْ ادَّعَى بَعْدَ ذَلِكَ وَجَاءَ بِبَيِّنَةٍ لَمْ تُقْبَلْ. العناية 412/8.

فصل

الصلح في دعوى الأموال : (وَالصُّلْحُ جَائِزٌ عَنْ دَعْوَى الْأَمْوَالِ) ، لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْبَيْعِ عَلَى مَا مَرَّ⁽⁵⁴²⁾.

الصلح في دعوى المنافع : قَالَ (وَالْمَنَافِعُ ، لِأَنَّهَا تُمْلِكُ بِعَقْدِ الْإِجَارَةِ ، فَكَذَا بِالصُّلْحِ) ، وَالْأَصْلُ فِيهِ : أَنَّ الصُّلْحَ يَجِبُ حَمْلُهُ عَلَى أَقْرَبِ الْعُقُودِ إِلَيْهِ وَأَشْبَهَهَا بِهِ اخْتِيَالًا لِلتَّصْحِيحِ تَصَرُّفِ الْعَاقِدِ مَا أَمَكَنَ⁽⁵⁴³⁾.

الصلح عن جناية العمد والخطأ : قَالَ (وَيَصِحُّ عَنْ جِنَايَةِ الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ) أَمَّا الْأَوَّلُ : فَلَقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَعْهُ﴾ [البقرة: 178] الْآيَةُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - : "إِنَّهَا نَزَلَتْ فِي الصُّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ"⁽⁵⁴⁴⁾ ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ النِّكَاحِ ، حَتَّى أَنَّ مَا صَلَحَ مُسَمًّى فِيهِ صَلَحَ هَاهُنَا ، إِذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُبَادَلُهُ الْمَالِ بِغَيْرِ الْمَالِ إِلَّا أَنْ عِنْدَ فَسَادِ التَّسْمِيَةِ هُنَا يُصَارُ إِلَى الدِّيَةِ ، لِأَنَّهَا مُوجِبُ الدَّمِ⁽⁵⁴⁵⁾.

الصلح على خمر : "وَلَوْ صَلَحَ عَلَى خَمْرٍ ، لَا يَجِبُ شَيْءٌ"⁽⁵⁴⁶⁾ ، لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ بِمُطْلَقِ الْعَفْوِ.

الصلح في النكاح على خمر أو مال مجهول : "وَفِي النِّكَاحِ يَجِبُ مَهْرُ الْمَثَلِ فِي الْفَصْلَيْنِ"⁽⁵⁴⁷⁾ ، لِأَنَّهُ الْمَوْجِبُ الْأَصْلِيُّ ، وَيَجِبُ مَعَ السُّكُوتِ عَنْهُ حُكْمًا ، وَيَدْخُلُ فِي إِطْلَاقِ جَوَابِ الْكِتَابِ الْجِنَايَةِ فِي النَّفْسِ وَمَا دُونَهَا.

⁽⁵⁴²⁾ (فما جاز بيعه جاز الصلح عنه . البناءة 10/10.

⁽⁵⁴³⁾ (أي بقدر الإمكان، فإن كان عن مال بمال اعتبر بالشبهات، وإن كان على منافع اعتبر بالإجازات. البناءة 10/10.

⁽⁵⁴⁴⁾ (تفسير ابن كثير 490/1.

⁽⁵⁴⁵⁾ (قَالَ الْبَابَرْتِي : " فَلَوْ صَلَحَهُ عَلَى سُكْنَى دَارٍ أَوْ خِدْمَةِ عَبْدٍ سَنَةً جَازَ ، لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ الْمَعْلُومَةَ صَلَحَتْ صَدَاقًا ، فَكَذَا بَدَلًا فِي الصُّلْحِ وَإِنْ صَلَحَ عَلَى ذَلِكَ أَبَدًا لَمْ يَجْزِ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَصْلُحْ صَدَاقًا لِحَالَتِهِ فَكَذَا بَدَلًا ، وَلَا يُتَوَهَّمُ لَزُومُ الْعَكْسِ فَإِنَّهُ غَيْرُ لَازِمٍ وَلَا هُوَ مُلْتَزِمٌ ، أَلَا تَرَى أَنَّ الصُّلْحَ عَنْ الْقَتْلِ الْعَمْدِ عَلَى أَقَلِّ مِنْ عَشْرَةِ - دَرَاهِمٍ - صَحِيحٌ ، وَإِنْ لَمْ يَصْلُحْ صَدَاقًا ، وَأَنَّهُ إِذَا صَلَحَ عَلَى أَنْ يَغْفُو مَنْ عَلَيْهِ عَنْ قِصَاصٍ لَهُ عَلَى آخَرٍ جَازَ ، وَإِنْ لَمْ يَصْلُحْ الْعَفْوُ عَنْ الْقِصَاصِ صَدَاقًا ، لِأَنَّ كَوْنَ الصَّدَاقِ مَالًا مَنْصُوصًا عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ [النساء: 24] وَبَدَلُ الصُّلْحِ

فِي الْقِصَاصِ لَيْسَ كَذَلِكَ ، فَيُكْتَفَى بِكَوْنِ الْعَوَضِ فِيهِ مُتَقَوِّمًا ، وَالْقِصَاصُ مُتَقَوِّمٌ حَتَّى صَلَحَ الْمَالُ عَوَضًا عَنْهُ فَيَجُوزُ أَنْ يَقَعَ عَوَضًا عَنْ قِصَاصٍ آخَرَ ، وَقَوْلُهُ : "إِلَّا أَنْ عِنْدَ فَسَادِ التَّسْمِيَةِ" اسْتِثْنَاءٌ مِنْ قَوْلِهِ : "إِنْ مَا صَلَحَ مُسَمًّى فِيهِ صَلَحَ هَاهُنَا" بِمَعْنَى لَكِنْ : أَيْ لَكِنْ إِذَا فَسَدَتِ التَّسْمِيَةُ بِجَهَالَةٍ فَاحْشَهِ أَوْ بِتَّسْمِيَةٍ مَا لَيْسَ بِمَالٍ مُتَقَوِّمٍ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا . العناية 415/8.

⁽⁵⁴⁶⁾ (لأنه لما لم يسم مالا متقوما ، صار ذكره والسكوت عنه شيئان، ولو سكت بعد العفو مطلقا وفيه لا يجب شيء فكذا في ذكر الخمر. البناءة 11/10.

الصلح على مال في حق الشفعة: وَهَذَا بِخِلَافِ الصُّلْحِ عَنْ حَقِّ الشُّفْعَةِ عَلَى مَالٍ ، حَيْثُ لَا يَصِحُّ ، لِأَنَّهُ حَقُّ التَّمْلُكِ ، وَلَا حَقٌّ فِي الْمَحَلِّ قَبْلَ التَّمْلُكِ⁽⁵⁴⁸⁾.

الصلح على مال في القصاص: "وَأَمَّا الْقِصَاصُ فَمِلْكُ الْمَحَلِّ فِي حَقِّ الْفِعْلِ ، فَيَصِحُّ الْإِعْتِيَاظُ عَنْهُ ، وَإِذَا لَمْ يَصِحَّ الصُّلْحُ تَبْطُلُ الشُّفْعَةُ ، لِأَنَّهَا تَبْطُلُ بِالْإِعْرَاضِ وَالسُّكُوتِ ، وَالْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ بِمَنْزِلَةِ حَقِّ الشُّفْعَةِ ، حَتَّى لَا يَجِبَ الْمَالُ بِالصُّلْحِ عَنْهُ ، غَيْرَ أَنَّ فِي بُطْلَانِ الْكَفَالَةِ رَوَائِثَيْنِ⁽⁵⁴⁹⁾ عَلَى مَا عُرِفَ فِي مَوْضِعِهِ.

الصلح على مال في جناية الخطأ والقصاص: وَأَمَّا الثَّانِي : وَهُوَ جِنَايَةُ الْخَطَأِ ، فَلِأَنَّ مُوجِبَهَا الْمَالُ ، فَيَصِيرُ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْعِ ، إِلَّا أَنَّهُ لَا تَصِحُّ الزِّيَادَةُ عَلَى قَدْرِ الدِّيَةِ ، لِأَنَّهُ مُقَدَّرٌ شَرْعًا ، فَلَا يَجُوزُ إِبْطَالُهُ فَتَرُدُّ الزِّيَادَةُ ، بِخِلَافِ الصُّلْحِ عَنِ الْقِصَاصِ ، حَيْثُ تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَى قَدْرِ الدِّيَةِ ، لِأَنَّ الْقِصَاصَ لَيْسَ بِمَالٍ ، وَإِنَّمَا يَتَقَوَّمُ بِالْعَقْدِ ، وَهَذَا إِذَا صَلَّحَ عَلَى أَحَدِ مَقَادِيرِ الدِّيَةِ ، أَمَّا إِذَا صَلَّحَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ جَازَ ، لِأَنَّهُ مُبَادَلَةٌ بِهَا ، إِلَّا أَنَّهُ يُسْتَرْطُ الْقَبْضُ فِي الْمَجْلِسِ ، كَيْ لَا يَكُونَ افْتِرَاقًا عَنْ دَيْنٍ بِدَيْنٍ ، وَلَوْ قَضَى الْقَاضِي بِأَحَدِ مَقَادِيرِهَا فَصَالِحٌ عَلَى جِنْسٍ آخَرَ مِنْهَا بِالزِّيَادَةِ جَازَ ، لِأَنَّهُ تَعَيَّنَ الْحَقُّ بِالْقَضَاءِ ، فَكَانَ مُبَادَلَةً ، بِخِلَافِ الصُّلْحِ ابْتِدَاءً ، لِأَنَّ تَرْضَائِيهِمَا عَلَى بَعْضِ الْمَقَادِيرِ بِمَنْزِلَةِ الْقَضَاءِ فِي حَقِّ التَّعْيِينِ ، فَلَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَى مَا تَعَيَّنَ⁽⁵⁵⁰⁾.

الصلح عن دعوى حد أو حق عام: قَالَ (وَلَا يَجُوزُ عَنْ دَعْوَى حَدٍّ) ، لِأَنَّهُ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى لَا حَقَّهُ ، وَلَا يَجُوزُ الْإِعْتِيَاظُ عَنْ حَقِّ غَيْرِهِ ، وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ الْإِعْتِيَاظُ إِذَا ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ نَسَبَ وَلَدِهَا ، لِأَنَّهُ حَقُّ الْوَلَدِ لَا حَقَّهَا ، وَكَذَا لَا يَجُوزُ الصُّلْحُ عَمَّا أَسْرَعَهُ إِلَى طَرِيقِ الْعَامَةِ ، لِأَنَّهُ حَقُّ الْعَامَةِ ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُصَالِحَ وَاحِدٌ عَلَى الْإِنْفِرَادِ عَنْهُ؛ وَيَدْخُلُ فِي إِطْلَاقِ الْجَوَابِ حَدُّ الْقَذْفِ ، لِأَنَّ الْمُغْلَبَ فِيهِ حَقُّ الشَّرْعِ⁽⁵⁵¹⁾.

(⁵⁴⁷) أى فى فصل تسمية المال المجهول ، وفصل الخمر ، لأن المهر هو الموجب الأصلي فى النكاح ، ويجب حكما مع السكوت عنه ، وتحقيقه أن المهر من ضرورات عقد النكاح ، فإنه ما شرع إلا بالمال ، فإذا لم يكن المسمى صالحا ، صار كما لو لم يسم مهرا. العناية على الهداية 416/8.

(⁵⁴⁸) وأخذ البذل هنا أخذ مال فى مقابلة ما ليس بشيء ثابت فى المحل ، وذلك رشوة حرام. البناية 12/10.

(⁵⁴⁹) فى رواية كتاب الشُّفْعَةِ وَالْحَوَالَةِ وَالْكَفَالَةِ تَبْطُلُ وَهُوَ رِوَايَةُ أَبِي حَفْصٍ ، وَبِهِ يُفْتَى لِأَنَّ السُّقُوطَ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْعَوَضِ ، وَإِذَا سَقَطَتْ لَا تَعُودُ وَفِي الصُّلْحِ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي سُلَيْمَانَ لَا تَبْطُلُ لِأَنَّ الْكَفَالَةَ بِالنَّفْسِ وَقَدْ تَكُونُ مُوصِلَةً إِلَى الْمَالِ فَأَخَذَتْ حُكْمَهُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ الْعِنَايَةِ 416/8.

(⁵⁵⁰) وَلَوْ قَضَى الْقَاضِي بِأَحَدِ الْمَقَادِيرِ زِيَادَةً عَلَى مَقْدَارِ الدِّيَةِ لَمْ يَجْزْ ، فَكَذَا هَذَا الْعِنَايَةِ 417/8.

(⁵⁵¹) وَلِقَائِلُ أَنْ يَقُولَ: لَوْ كَانَ الْمُغْلَبُ فِيهِ حَقُّ الشَّرْعِ ، لَوَجِبَ أَنْ لَا يُحَدَّ الْمُسْتَأْمَنُ إِذَا قَذَفَ ، كَمَا لَوْ زَنَى ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ يُحَدُّ لِأَنَّهُ حَقُّ الْعَبْدِ. وَالْجَوَابُ : أَنَّ حَدَّ الْقَذْفِ يَشْتَمِلُ عَلَى الْحَقَّيْنِ لَا مَحَالَةَ ، فَيُعْمَلُ بِكُلِّ مِنْهُمَا بِحَسَبِ مَا يَلِيقُ بِهِ ، وَمَا يَلِيقُ بِالْحَرْبِيِّ أَنْ يَكُونَ حَقُّ الْعَبْدِ ، لِإِمْكَانِ الْإِسْتِيفَاءِ ،

مصالحة المرأة رجلا في دعوى النكاح : قَالَ (وَإِذَا ادَّعى رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ نِكَاحًا وَهِيَ تَجْحَدُ ، فَصَالَحْتُهُ عَلَى مَالٍ بَدَلْتُهُ حَتَّى يَتْرُكَ الدَّعْوَى جَارَ ، وَكَانَ فِي مَعْنَى الْخُلْعِ) ، لِأَنَّهُ أَمَكَّنَ تَصْحِيحُهُ خُلْعًا فِي جَانِبِهِ بِنَاءً عَلَى زَعْمِهِ ، وَفِي جَانِبِهَا بَدَلًا لِلْمَالِ ، لِدَفْعِ الْخُصُومَةِ. قَالُوا: وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى إِذَا كَانَ مُبْطَلًا فِي دَعْوَاهُ⁽⁵⁵²⁾.

مصالحة الرجل امرأة في دعوى النكاح : قَالَ (وَإِذَا ادَّعَتْ امْرَأَةٌ عَلَى رَجُلٍ نِكَاحًا فَصَالَحَهَا عَلَى مَالٍ بَدَلْتُهُ لَهَا جَارَ) قَالَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : هَكَذَا ذَكَرَ فِي بَعْضِ نُسَخِ الْمُخْتَصَرِ⁽⁵⁵³⁾ ، وَفِي بَعْضِهَا قَالَ: لَمْ يَجْزُ ، وَجْهُ الْأَوَّلِ : أَنْ يَجْعَلَ زِيَادَةً فِي مَهْرِهَا، وَجْهُ الثَّانِي : أَنَّهُ بَدَلُ لَهَا الْمَالِ لِتَتْرُكَ الدَّعْوَى ، فَإِنْ جُعِلَ تَرَكُ الدَّعْوَى مِنْهَا فُرْقَةً فَالزَّوْجُ لَا يُعْطَى الْعِوَضَ فِي الْفُرْقَةِ، وَإِنْ لَمْ يُجْعَلْ فَالْحَالُ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ الدَّعْوَى ، فَلَا شَيْءَ يُقَابِلُهُ الْعِوَضُ فَلَمْ يَصِحَّ⁽⁵⁵⁴⁾.

صالح الرجل آخر على دعوى أنه عبده :قَالَ (وَإِنْ ادَّعى عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ عَبْدُهُ فَصَالَحَهُ عَلَى مَالٍ أَعْطَاهُ جَارَ ، وَكَانَ فِي حَقِّ الْمُدَّعِي بِمَنْزِلَةِ الْإِعْتَاقِ عَلَى مَالٍ) ، لِأَنَّهُ أَمَكَّنَ تَصْحِيحُهُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فِي حَقِّهِ لِرَّعْمِهِ ، وَلِهَذَا يَصِحُّ عَلَى حَيَوَانٍ فِي الذِّمَّةِ إِلَى أَجَلٍ ، وَفِي حَقِّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَكُونُ لِدَفْعِ الْخُصُومَةِ؛ لِأَنَّهُ يَزْعُمُ أَنَّهُ حُرٌّ فَجَارَ ، إِلَّا أَنَّهُ لَا وِلَاءَ لَهُ لِإِنْكَارِ الْعَبْدِ ، إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ فَتُقْبَلَ وَيَنْبُتَ الْوِلَاءُ.

صلح العبد المأذون له في القتل العمد :قَالَ (وَإِذَا قَتَلَ الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ لَهُ رَجُلًا عَمْدًا ، لَمْ يَجْزُ لَهُ أَنْ يُصَالِحَ عَنْ نَفْسِهِ، وَإِنْ قَتَلَ عَبْدٌ لَهُ رَجُلًا عَمْدًا فَصَالَحَهُ ، جَارَ) ، وَوَجْهُ الْفَرْقِ أَنَّ رَقَبَتَهُ لَيْسَتْ مِنْ تِجَارَتِهِ ، وَلِهَذَا لَا يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِيهِ بَيْعًا فَكَذَا اسْتِخْلَاصًا بِمَالِ الْمُؤَلَى وَصَارَ كَالْأَجْنَبِيِّ، أَمَّا عَبْدُهُ فَمِنْ تِجَارَتِهِ وَتَصَرُّفُهُ فِيهِ نَافِذٌ بَيْعًا فَكَذَا اسْتِخْلَاصًا، وَهَذَا لِأَنَّ الْمُسْتَحَقَّ كَالزَّائِلِ عَنْ مِلْكِهِ وَهَذَا شِرَاؤُهُ فَيَمْلِكُهُ.

وَمَا يَلِيْقُ بِالْإِمَامِ أَنْ يَكُونَ حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى ، لِأَنَّهُ لَيْسَ فَوْقَهُ إِمَامٌ يَسْتَوْفِيهِ مِنْهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. العناية 277/5.

(⁵⁵²) فَإِنْ أَقَامَ عَلَى النَّزْوِيجِ بَيِّنَةٌ بَعْدَ الصُّلْحِ ، لَمْ تُقْبَلْ لِأَنَّ مَا جَرَى كَانَ خُلْعًا فِي زَعْمِهِ ، وَلَا فَايِدَةً فِي إِقَامَتِهَا بَعْدَهُ، وَإِنْ كَانَ مُبْطَلًا فِي دَعْوَاهُ لَمْ يَحِلَّ لَهُ مَا أَخَذَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى، وَهَذَا عَامٌّ فِي جَمِيعِ أَنْوَاعِ الصُّلْحِ، إِلَّا أَنْ يُسَلِّمَهُ بِطِيبٍ عَنْ نَفْسِهِ فَيَكُونُ تَمْلِكًا عَلَى طَرِيقِ الْهَبَةِ . العناية 419/8

(⁵⁵³) أى مختصر القدورى، أحمد بن محمد بن جعفر القدورى ت 428هـ .
(⁵⁵⁴) لِأَنَّ الْفُرْقَةَ لَمَّا لَمْ تُوجَدْ كَانَتْ دَعْوَاهَا عَلَى حَالِهَا لِبَقَاءِ النَّكَاحِ فِي زَعْمِهَا ، فَلَمْ يَكُنْ ثَمَّةَ شَيْءٍ يُقَابِلُهُ الْعِوَضُ ، فَكَانَ رِشْوَةً. العناية 419/8.

غصب ثوبا معلوم القيمة فصالح على أكثر من قيمته: قَالَ (وَمَنْ غَصَبَ ثَوْبًا يَهُودِيًّا⁵⁵⁵) قِيمَتُهُ دُونَ الْمِائَةِ ، فَاسْتَهْلَكَهُ فَصَالَحَهُ مِنْهَا عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ ، جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: يَبْطُلُ الْفَضْلُ عَلَى قِيمَتِهِ بِمَا لَا يَتَغَابَنُ⁵⁵⁶ (النَّاسُ فِيهِ) ، لِأَنَّ الْوَاجِبَ هِيَ الْقِيَمَةُ ، وَهِيَ مُقَدَّرَةٌ فَالزِّيَادَةُ عَلَيْهَا تَكُونُ رَبًّا ، بِخِلَافِ مَا إِذَا صَالَحَ عَلَى عَرَضٍ ، لِأَنَّ الزِّيَادَةَ لَا تَظْهَرُ عِنْدَ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ ، وَبِخِلَافِ مَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيهِ ، لِأَنَّهُ يَدْخُلُ تَحْتَ تَقْوِيمِ الْمُقَوِّمِينَ فَلَا تَظْهَرُ الزِّيَادَةُ ، وَلِأَبِي حَنِيفَةَ : أَنَّ حَقَّهُ فِي الْهَالِكِ بَاقٍ ، حَتَّى لَوْ كَانَ عَبْدًا وَتَرَكَ أَخَذَ الْقِيَمَةَ يَكُونُ الْكَفْنَ عَلَيْهِ ، أَوْ حَقُّهُ فِي مِثْلِهِ صُورَةً وَمَعْنَى ، لِأَنَّ ضَمَانَ الْعُدْوَانِ بِالْمِثْلِ ، وَإِنَّمَا يَنْتَقِلُ إِلَى الْقِيَمَةِ بِالْقَضَاءِ ، فَقَبْلَهُ إِذَا تَرَاضَيَا عَلَى الْأَكْثَرِ كَانَ اعْتِيَاظًا ، فَلَا يَكُونُ رَبًّا ، بِخِلَافِ الصُّلْحِ بَعْدَ الْقَضَاءِ ، لِأَنَّ الْحَقَّ قَدْ انْتَقَلَ إِلَى الْقِيَمَةِ⁵⁵⁷).

العبد بين رجلين أعتقه أحدهما فصالحه الآخر على أكثر من نصف قيمته: قَالَ (وَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا وَهُوَ مُوسِرٌ ، فَصَالَحَهُ الْآخَرُ عَلَى أَكْثَرِ مِنْ نِصْفِ قِيَمَتِهِ فَالْفَضْلُ بَاطِلٌ) وَهَذَا بِالِاتِّفَاقِ ، وَأَمَّا عِنْدَهُمَا : فَلِمَا بَيَّنَّا. وَالْفَرْقُ لِأَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّ الْقِيَمَةَ فِي الْعِتْقِ مَنْصُوصٌ عَلَيْهَا ، وَتَقْدِيرُ الشَّرْعِ لَا يَكُونُ دُونَ تَقْدِيرِ الْقَاضِي ، فَلَا يَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ ، وَبِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ ، لِأَنَّهَا غَيْرُ مَنْصُوصٍ عَلَيْهَا (وَإِنْ صَالَحَهُ عَلَى عُرُوضٍ جَازَ) ، لِمَا بَيَّنَّا أَنَّهُ لَا يَظْهَرُ الْفَضْلُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

⁵⁵⁵ (يهود قوم من أهل الكتاب ينسب إليهم الثوب ، يقال : ثوب يهودى ، وإنما خصه بالذكر ،

إشارة إلى كونه معلوم القيمة ، وكل قيمي معلوم القيمة حكمه كذلك . العناية على الهداية 420/8.

⁵⁵⁶ (الغبن نوعان : غبن فاحش : وهو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين ، وهذا لا يتسامح فيه

التجار ، وغبن غير فاحش ، أو بسير : وهو ما يدخل تحت تقويم المقومين ، ويتسامح فيه التجار .

الاختيار لتعليق المختار 23/1.

⁵⁵⁷ (فتكون الزيادة ربا لا محالة. البناية 19/10.

باب التبرع بالصلح والتوكل به

التوكيل بالصلح عن دم العمد أو بعض ما يدعيه من الدين: (وَمَنْ وَكَّلَ رَجُلًا بِالصُّلْحِ عَنْهُ فَصَالَحَ ، لَمْ يَلْزَمْ الْوَكِيلَ مَا صَالَحَ عَنْهُ إِلَّا أَنْ يَضْمَنَهُ ، وَالْمَالُ لَازِمٌ لِلْمُوكِّلِ) وَتَأْوِيلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إِذَا كَانَ الصُّلْحُ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ ، أَوْ كَانَ الصُّلْحُ عَنْ بَعْضِ مَا يَدَّعِيهِ مِنَ الدَّيْنِ ، لِأَنَّهُ إِسْقَاطٌ مَحْضٌ ، فَكَانَ الْوَكِيلُ فِيهِ سَفِيرًا وَمُعَبَّرًا ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ، كَالْوَكِيلِ بِالنِّكَاحِ ، إِلَّا أَنْ يَضْمَنَهُ ، لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ هُوَ مُوَآخِذٌ بِعَقْدِ الضَّمَانِ لَا بِعَقْدِ الصُّلْحِ ، أَمَّا إِذَا كَانَ الصُّلْحُ عَنْ مَالٍ بِمَالٍ ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْعِ فَتَرْجِعُ الْحُقُوقُ إِلَى الْوَكِيلِ ، فَيَكُونُ الْمُطَالِبُ بِالْمَالِ هُوَ الْوَكِيلُ دُونَ الْمُوكِّلِ⁽⁵⁵⁸⁾.

صلح الفضولي: قَالَ (وَإِنْ صَالَحَ رَجُلٌ عَنْهُ بِغَيْرِ أَمْرِهِ ، فَهُوَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ⁽⁵⁵⁹⁾): إِنْ صَالَحَ بِمَالٍ وَضَمِنَهُ ، تَمَّ الصُّلْحُ) ، لِأَنَّ الْحَاصِلَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَيْسَ إِلَّا الْبَرَاءَةُ ، وَفِي حَقِّهَا هُوَ وَالْأَجَنْبِيُّ سَوَاءٌ ، فَصُلْحٌ أَصِيلًا فِيهِ إِذَا ضَمِنَهُ ، كَالْفُضُولِيِّ⁽⁵⁶⁰⁾ بِالْخُلْعِ إِذَا ضَمِنَ الْبَدَلَ ، وَيَكُونُ مُتَبَرِّعًا عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، كَمَا لَوْ تَبَرَّعَ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ بِأَمْرِهِ ، وَلَا يَكُونُ لِهَذَا الْمُصَالِحِ شَيْءٌ مِنَ الْمُدَّعَى ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ لِلَّذِي فِي يَدِهِ ، لِأَنَّ تَصْحِيحَهُ بِطَرِيقِ الْإِسْقَاطِ ، وَلَا فَرْقَ فِي هَذَا بَيْنَ مَا إِذَا كَانَ مُقْرًا أَوْ مُنْكَرًا⁽⁵⁶¹⁾.

(⁵⁵⁸) قَالَ صَاحِبُ النَّهَائِيَةِ مَا مَعْنَاهُ: إِنَّهُ لَا بُدَّ لِتَأْوِيلِ الْمَسْأَلَةِ مِنْ قَيِّدٍ آخَرَ ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْمُصَالِحُ فِي الْمُعَاوَضَاتِ عَلَى الْإِنْكَارِ ، فَإِنْ كَانَ لَا يَجِبُ عَلَى الْوَكِيلِ شَيْءٌ ، وَإِنْ كَانَ فِيهَا لِأَنَّ الصُّلْحَ عَلَى الْإِنْكَارِ مُعَاوَضَةٌ بِإِسْقَاطِ الْحَقِّ فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الطَّلَاقِ بِجَعْلٍ وَذَلِكَ جَائِزٌ مَعَ الْأَجَنْبِيِّ جَوَازُهُ مَعَ الْخَصْمِ 423/8 ، 424.

(⁵⁵⁹) ووجه ذلك : أن الفضولي عند الصلح على مال ، إما أن قرن بذكر المال ضمان نفسه ، أو لا ، فالأول : هو الوجه الأول ، والثاني : أما إن أضاف المال إلى نفسه ، أو لا ، فالأول : هو الوجه الثاني ، والثاني : إما أن يسلم المال المذكور أم لا ، فالأول : هو الوجه الثالث ، والثاني هو الرابع . حاشية سعدى أفندى على تكملة فتح القدير 424/8.

(⁵⁶⁰) الفضولي : "جمع فضل ، غلب في الاشتغال بما لا يعنيه ، وما لا ولاية له فيه " . البحر الرائق 147/3.

(⁵⁶¹) أما إذا كان منكرا فظاهر ، لأنه في زعم المدعى عليه أنه لا شيء عليه ، فيكون متبرعا في إسقاط الخصومة منه ، وزعم المدعى لم ينفذ إليه ، وأما إذا كان مقرا بالدين وبالصلح ، ينبغي أن يصير مشتريا ما في ذمته بما أدى ، إلا أن شراء الدين من غير المذكور لا يصح ، لأن فيه تملك الدين من غير من عليه الدين ، وذا لا يجوز ، بخلاف ما لو كان المدعى به عينا ، والمدعى عليه مقرا ، فإنه يصير مشتريا لنفسه إذا كان بغير أمره ، لأن شراء الشيء من مالكه صحيح وإن كان في يد غيره. البناية 22/10.

(وَكَذَلِكَ إِنْ قَالَ صَالِحُكَ عَلَى أَلْفِي هَذِهِ أَوْ عَلَى عَبْدِي هَذَا ، صَحَّ الصُّلْحُ وَلَزِمَهُ تَسْلِيمُهَا) ،
لِأَنَّهُ لَمَّا أَضَافَهُ إِلَى مَالِ نَفْسِهِ فَقَدْ التَّزَمَ تَسْلِيمَهُ ، فَصَحَّ الصُّلْحُ (وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ عَلَى أَلْفٍ
وَسَلَّمَهَا) ، لِأَنَّ التَّسْلِيمَ إِلَيْهِ يُوجِبُ سَلَامَةَ الْعَوَضِ لَهُ فَيَتِمُّ الْعَقْدُ لِحُصُولِ مَقْصُودِهِ (562).

(وَلَوْ قَالَ صَالِحُكَ عَلَى أَلْفٍ فَالْعَقْدُ مَوْقُوفٌ ، فَإِنْ أَجَازَهُ الْمُدْعَى عَلَيْهِ جَازَ وَلَزِمَهُ الْأَلْفُ ،
وَإِنْ لَمْ يُجْزِهِ بَطَلَ) لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْعَقْدِ إِنَّمَا هُوَ الْمُدْعَى عَلَيْهِ ، لِأَنَّ دَفْعَ الْخُصُومَةِ حَاصِلٌ
لَهُ ، إِلَّا أَنَّ الْفُضُولِيَّ يَصِيرُ أَصِيلًا بِوَاسِطَةِ إِضَافَةِ الضَّمَانِ إِلَى نَفْسِهِ ، فَإِذَا لَمْ يُضِفْهُ بَقِيَ عَاقِدًا
مِنْ جِهَةِ الْمَطْلُوبِ فَيَتَوَقَّفُ عَلَى إِجَازَتِهِ (563).

قَالَ الْعَبْدُ الضَّعِيفُ (564) عَصَمَهُ اللَّهُ : وَوَجْهُ آخِرٌ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ صَالِحُكَ عَلَى هَذِهِ الْأَلْفِ أَوْ
عَلَى هَذَا الْعَبْدِ وَلَمْ يَنْسُبْهُ إِلَى نَفْسِهِ ، لِأَنَّهُ لَمَّا عَيَّنَّهُ لِلتَّسْلِيمِ صَارَ شَارِطًا سَلَامَتَهُ لَهُ فَيَتِمُّ بِقَوْلِهِ.

وَلَوْ اسْتَحَقَّ الْعَبْدُ أَوْ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَرَدَّهُ فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَى الْمُصَالِحِ ، لِأَنَّهُ التَّزَمَ الْإِيْفَاءَ مِنْ
مَحَلِّ بَعْيِهِ وَلَمْ يَلْتَزِمْ شَيْئًا سِوَاهُ ، فَإِنْ سَلِمَ الْمَحَلُّ لَهُ تَمَّ الصُّلْحُ ، وَإِنْ لَمْ يَسَلِّمْ لَهُ لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ
بِشَيْءٍ. بِخِلَافِ مَا إِذَا صَالَحَ عَلَى دَرَاهِمٍ مُسَمَّاةٍ وَضَمِنَهَا وَدَفَعَهَا ، ثُمَّ أُسْتُحِقَّتْ ، أَوْ وَجَدَهَا
رُيُوفًا ، حَيْثُ يَرْجِعُ عَلَيْهِ ، لِأَنَّهُ جَعَلَ نَفْسَهُ أَصِيلًا فِي حَقِّ الضَّمَانِ ، وَلِهَذَا يُجْبَرُ عَلَى التَّسْلِيمِ ،
فَإِذَا لَمْ يُسَلِّمْ لَهُ مَا سَلَّمَهُ يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِبَدَلِهِ (565) ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

(562) وهو سلامة البديل للمدعي، فإذا حصل المقصود تم العقد لا محالة. البناية 23/10.

(563) أي على إجازة المدعى عليه ، فإن قبل لزمه المال، وإن رده بطل الصلح. البناية 23/10.

(564) أي مصنف كتاب الهداية ، وهو أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني
المرغيناني ت 593 هـ . البناية على الهداية 238/4.

(565) أي يرجع عليه ببذل ما لم يسلم إليه، البناية 24/10.

باب الصلح في الدين

الصلح على المستحق بعقد المداينة: (وَكُلُّ شَيْءٍ وَقَعَ عَلَيْهِ الصُّلْحُ وَهُوَ مُسْتَحَقٌّ بِعَقْدِ الْمُدَايِنَةِ⁵⁶⁶) لَمْ يُحْمَلْ عَلَى الْمُعَاوَضَةِ، وَإِنَّمَا يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ اسْتَوْفَى بَعْضَ حَقِّهِ وَأَسْقَطَ بَاقِيَهُ، كَمَنْ لَهُ عَلَى آخَرٍ أَلْفٌ دِرْهَمٍ فَصَالَحَهُ عَلَى خَمْسِمِائَةٍ، وَكَمَنْ لَهُ عَلَى آخَرٍ أَلْفٌ جِيَادٌ، فَصَالَحَهُ عَلَى خَمْسِمِائَةِ زُيُوفٍ جَازٍ، وَكَأَنَّهُ أَبْرَأَهُ عَنْ بَعْضِ حَقِّهِ، وَهَذَا لِأَنَّهُ تَصَرَّفَ الْعَاقِلُ يَتَحَرَّى تَصْحِيحَهُ مَا أَمَكَنَ، وَلَا وَجَهَ لِتَصْحِيحِهِ مُعَاوَضَةً لِإِفْضَائِهِ إِلَى الرَّبَا، فَجُعِلَ إِسْقَاطُ لِلْبَعْضِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى، وَلِلْبَعْضِ وَالصَّفَةِ فِي الثَّانِيَةِ⁽⁵⁶⁷⁾.

الصلح عن جميع الدين المؤجل: (وَلَوْ صَالَحَ عَلَى أَلْفٍ مُؤَجَّلَةٍ جَازٍ، وَكَأَنَّهُ أَجَلَ نَفْسِ الْحَقِّ) ، لِأَنَّهُ لَا يُمَكِّنُ جَعْلَهُ مُعَاوَضَةً، لِأَنَّهُ بَيَعَ الدَّرَاهِمَ بِمِثْلِهَا نَسِيئَةً لَا يَجُوزُ، فَحَمَلْنَاهُ عَلَى التَّأْخِيرِ، (وَلَوْ صَالَحَهُ عَلَى دَنَانِيرٍ إِلَى شَهْرٍ لَمْ يَجُزْ)، لِأَنَّ الدَّنَانِيرَ غَيْرُ مُسْتَحَقَّةٍ بِعَقْدِ الْمُدَايِنَةِ، فَلَا يُمَكِّنُ حَمْلُهُ عَلَى التَّأْخِيرِ، وَلَا وَجَهَ لَهُ سِوَى الْمُعَاوَضَةِ، وَبَيَعَ الدَّرَاهِمَ بِالدَّنَانِيرِ نَسِيئَةً لَا يَجُوزُ فَلَمْ يَصِحَّ الصُّلْحُ⁽⁵⁶⁸⁾.

الصلح عن بعض الدين المؤجل: قال: (وَلَوْ كَانَتْ لَهُ أَلْفٌ مُؤَجَّلَةٌ فَصَالَحَهُ عَلَى خَمْسِمِائَةٍ حَالَةً لَمْ يَجُزْ)، لِأَنَّ الْمُعَجَّلَ خَيْرٌ مِنَ الْمُؤَجَّلِ، وَهُوَ غَيْرُ مُسْتَحَقٍّ بِالْعَقْدِ، فَيَكُونُ بِإِزَاءِ مَا حَطَّ عَنْهُ، وَذَلِكَ اعْتِيَاظٌ عَنِ الْأَجَلِ، وَهُوَ حَرَامٌ⁽⁵⁶⁹⁾.

الصلح عن الدين المؤجل مع زيادة في الوصف أو الجودة: (وَإِنْ كَانَ لَهُ أَلْفٌ سُودٌ فَصَالَحَهُ عَلَى خَمْسِمِائَةِ بَيْضٍ لَمْ يَجُزْ)، لِأَنَّ الْبَيْضَ غَيْرُ مُسْتَحَقَّةٍ بِعَقْدِ الْمُدَايِنَةِ، وَهِيَ زَائِدَةٌ وَصْفًا، فَيَكُونُ مُعَاوَضَةً الْأَلْفِ بِخَمْسِمِائَةٍ وَزِيَادَةٍ وَصْفٍ وَهُوَ رَبَا، بِخِلَافِ مَا إِذَا صَالَحَ عَنِ الْأَلْفِ الْبَيْضَ عَلَى خَمْسِمِائَةِ سُودٍ، حَيْثُ يَجُوزُ، لِأَنَّهُ إِسْقَاطُ كُلِّهِ قَدْرًا وَوَصْفًا، وَبِخِلَافِ مَا إِذَا

⁵⁶⁶) أي من جنس ما يستحقه المدعي على المدعى عليه بعقد المداينة أي البيع بالدين. البناية 25/10،

⁵⁶⁷) (فجعل إسقاطا للبعض): أي لبعض الدين (في المسألة الأولى) وهي مسألة مسامحة الألف بخمسمائة (وللبعض): أي وجعل إسقاطا لبعض الدين (والصفة): أي وإسقاطا للصفة (في الثانية): أي في المسألة الثانية وهي مصالحة الجياد بالزيوف. البناية 26/10.

⁵⁶⁸) لأنه يؤدي إلى الربا. البناية 26/10.

⁵⁶⁹) رُوي أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - فَهَاهُ عَنِ ذَلِكَ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَقَالَ: إِنَّ هَذَا يُرِيدُ أَنْ أَطْعِمَهُ الرَّبَا، وَهَذَا لِأَنَّ حُرْمَةَ رَبَا النِّسَاءِ لَيْسَتْ إِلَّا لِشُبْهَةِ مُبَادَلَةِ الْمَالِ بِالْأَجَلِ، فَحَقِيقَةُ ذَلِكَ أُولَى. البناية 26/10، العناية 472/8.

صَالِحَ عَلَى قَدْرِ الدِّينِ وَهُوَ أَجَوَدُ ، لِأَنَّهُ مُعَاوَضَةُ الْمِثْلِ بِالْمِثْلِ ، وَلَا مُعْتَبَرٌ بِالصِّفَةِ إِلَّا أَنَّهُ يُشْتَرَطُ الْقَبْضُ فِي الْمَجْلِسِ⁽⁵⁷⁰⁾.

الصلح على إسقاط أحد نوعي الثمن : وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَمِائَةُ دِينَارٍ فَصَالَحَهُ عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ حَالَةً أَوْ إِلَى شَهْرٍ ، صَحَّ الصُّلْحُ ، لِأَنَّهُ أَمَكَّنَ أَنْ يُجْعَلَ إِسْقَاطًا لِلدَّائِنِ كُلِّهَا ، وَالْدَّرَاهِمُ إِلَّا مِائَةً ، وَتَأْجِيلًا لِلْبَاقِي ، فَلَا يُجْعَلُ مُعَاوَضَةً تَصَحُّيحًا لِلْعَقْدِ ، أَوْ لِأَنَّ مَعْنَى الْإِسْقَاطِ فِيهِ أَلْزَمُ⁽⁵⁷¹⁾.

الصلح في الدين على بعضه مقابل إسقاط باقيه : قَالَ (وَمَنْ لَهُ عَلَى آخَرٍ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَقَالَ أَدِّ إِلَيَّ غَدًا مِنْهَا خَمْسِمِائَةً عَلَى أَنَّكَ بَرِيءٌ مِنَ الْفَضْلِ فَفَعَلَ ، فَهُوَ بَرِيءٌ ، فَإِنْ لَمْ يَدْفَعْ إِلَيْهِ الْخَمْسِمِائَةَ غَدًا عَادَ عَلَيْهِ الْأَلْفُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : لَا يَعُودُ عَلَيْهِ) ، لِأَنَّهُ إِبْرَاءٌ مُطْلَقٌ ؛ أَلَا تَرَى أَنَّهُ جَعَلَ أَدَاءَ الْخَمْسِمِائَةِ عَوَضًا حَيْثُ ذَكَرَهُ بِكَلِمَةٍ عَلَى وَهِيَ لِلْمُعَاوَضَةِ ، وَالْأَدَاءُ لَا يَصِحُّ عَوَضًا ، لِكُونِهِ مُسْتَحَقًّا عَلَيْهِ فَجَرَى وَجُودُهُ مَجْرَى عَدَمِهِ ، فَبَقِيَ الْإِبْرَاءُ مُطْلَقًا ، فَلَا يَعُودُ كَمَا إِذَا بَدَأَ بِالْإِبْرَاءِ ، وَلَهُمَا : أَنَّ هَذَا إِبْرَاءٌ مُقَيَّدٌ بِالشَّرْطِ ، فَيَقُوتُ بِقَوَاتِهِ ، لِأَنَّهُ بَدَأَ بِأَدَاءِ الْخَمْسِمِائَةِ فِي الْغَدِ ، وَأَنَّهُ يَصْلُحُ غَرَضًا جَذَارَ إِفْلَاسِهِ وَتَوَسُّلًا إِلَى تِجَارَةِ أَرْبَحٍ مِنْهُ ، وَكَلِمَةُ "عَلَى" إِنْ كَانَتْ لِلْمُعَاوَضَةِ فَهِيَ مُحْتَمِلَةٌ لِلشَّرْطِ ، لَوْجُودِ مَعْنَى الْمُقَابَلَةِ فِيهِ ، فَيَحْمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْحَمْلِ عَلَى الْمُعَاوَضَةِ تَصَحُّيحًا لِتَصَرُّفِهِ ، أَوْ لِأَنَّهُ مُتَعَارَفٌ ، وَالْإِبْرَاءُ مِمَّا يَتَقَيَّدُ بِالشَّرْطِ ، وَإِنْ كَانَ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ كَمَا فِي الْحَوَالَةِ ، وَسَتَخْرُجُ الْبُدْءُ بِالْإِبْرَاءِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

قَالَ الْعَبْدُ الضَّعِيفُ⁽⁵⁷²⁾ : وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى وَجْهِ : أَحَدُهَا مَا ذَكَرْنَاهُ.

وَالثَّانِي : إِذَا قَالَ صَالِحُكَ مِنْ الْأَلْفِ عَلَى خَمْسِمِائَةٍ تَدْفَعُهَا إِلَيَّ غَدًا وَأَنْتَ بَرِيءٌ مِنَ الْفَضْلِ عَلَى أَنَّكَ إِنْ لَمْ تَدْفَعْهَا إِلَيَّ غَدًا فَالْأَلْفُ عَلَيْكَ عَلَى حَالِهِ.

وَجَوَابُهُ : أَنَّ الْأَمْرَ عَلَى مَا قَالَ لِأَنَّهُ أَتَى بِصَرِيحِ التَّقْيِيدِ فَيُعْمَلُ بِهِ.

وَالثَّالِثُ : إِذَا قَالَ أَبْرَأْتُكَ مِنْ خَمْسِمِائَةٍ مِنَ الْأَلْفِ عَلَى أَنْ تُعْطِيَنِي الْخَمْسِمِائَةَ غَدًا وَالْإِبْرَاءُ فِيهِ وَاقِعٌ ، أَعْطَى الْخَمْسِمِائَةَ أَوْ لَمْ يُعْطَ ، لِأَنَّهُ أَطْلَقَ الْإِبْرَاءَ أَوَّلًا ، وَأَدَاءَ الْخَمْسِمِائَةِ لَا يَصْلُحُ عَوَضًا مُطْلَقًا ، وَلَكِنَّهُ يَصْلُحُ شَرْطًا فَوْقَ الشُّكِّ فِي تَقْيِيدِهِ بِالشَّرْطِ فَلَا يَتَقَيَّدُ بِهِ ، بِخِلَافِ مَا إِذَا

(570) (لأنه صرف، والبخية : اسم لما هو الموجود من الدراهم السود ، وهو نقد بيت المال ، وقال أبو الفتح المطرزي : "الدراهم البخية : نوع من أجود الدراهم ، نسبت فيما زعموا إلى "بخ" أمير ضربها ، وقيل : كتب عليها "بخ" ، وهى كلمة استحسان واستجادة .". البناية 27/10 ، العناية 472/8 ، المغرب في ترتيب المغرب ص 35.

(571) (لأنه مبني على الحطيطة ، والخط هاهنا أكثر ، فيكون الإسقاط أَلْزَمُ . البناية 27/10.

(572) (أى المصنف صاحب الهداية ، وهو الإمام المرغينانى.

بَدَأَ بِأَدَاءِ خَمْسِمِائَةٍ لِأَنَّ الْإِبْرَاءَ حَصَلَ مَقْرُونًا بِهِ، فَمِنْ حَيْثُ إِنَّهُ لَا يَصْلُحُ عَوْضًا يَقَعُ مُطْلَقًا، وَمِنْ حَيْثُ إِنَّهُ يَصْلُحُ شَرْطًا لَا يَقَعُ مُطْلَقًا فَلَا يَنْبُتُ الْإِطْلَاقُ بِالشَّكِّ فَافْتَرَقَا.

وَالرَّابِعُ: إِذَا قَالَ أَدَّ إِلَيَّ خَمْسِمِائَةٍ عَلَى أَنَّكَ بَرِيءٌ مِنْ الْفَضْلِ وَلَمْ يُؤَقِّتْ لِلْأَدَاءِ وَقْتًا.

وَجَوَابُهُ: أَنَّهُ يَصِحُّ الْإِبْرَاءُ وَلَا يَعُودُ الدَّيْنُ لِأَنَّ هَذَا إِبْرَاءٌ مُطْلَقٌ، لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يُؤَقِّتْ لِلْأَدَاءِ وَقْتًا لَا يَكُونُ الْأَدَاءُ غَرْضًا صَحِيحًا لِأَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ فِي مُطْلَقِ الْأَرْزَامِ فَلَمْ يَتَقَيَّدْ بَلْ يُحْمَلْ عَلَى الْمُعَاوَضَةِ وَلَا يَصْلُحُ عَوْضًا، بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ لِأَنَّ الْأَدَاءَ فِي الْغَدِ غَرْضٌ صَحِيحٌ.

وَالْخَامِسُ: إِذَا قَالَ إِنْ أَدَّيْتُ إِلَيَّ خَمْسِمِائَةٍ أَوْ قَالَ إِذَا أَدَّيْتُ أَوْ مَتَى أَدَّيْتُ.

فَالْجَوَابُ فِيهِ: أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْإِبْرَاءُ، لِأَنَّهُ عُلِّقَ بِالشَّرْطِ صَرِيحًا، وَتَعْلِيْقُ الْبَرَاءَاتِ بِالشَّرْطِ بَاطِلٌ، لِمَا فِيهَا مِنْ مَعْنَى التَّمْلِيكِ حَتَّى يَرْتَدَّ بِالرَّدِّ، بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ، لِأَنَّهُ مَا أَتَى بِصَرِيحِ الشَّرْطِ فَحُمِلَ عَلَى التَّقْيِيدِ بِهِ⁽⁵⁷³⁾.

الصلح عن الإقرار: قَالَ (وَمَنْ قَالَ لِأَخَرٍ: لَا أَفِرُّ لَكَ بِمَالِكَ حَتَّى تُؤَخِّرَهُ عَنِّي، أَوْ تَحْطَ عَنِّي، فَفَعَلَ جَازَ عَلَيْهِ⁽⁵⁷⁴⁾)، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُكْرَهٍ، وَمَعْنَى الْمَسْأَلَةِ: إِذَا قَالَ ذَلِكَ سِرًّا، أَمَّا إِذَا قَالَ عَلَانِيَةً يُؤْخَذُ بِهِ⁽⁵⁷⁵⁾.

(573) قَالَ صَاحِبُ النَّهَائَةِ: - وَهُوَ حَسَامُ الدِّينِ حَسَنُ السَّغْنَاقِيِّ - فِي حَصْرِ الْوُجُوهِ عَلَى خَمْسَةِ: إِنَّ رَبَّ الدَّيْنِ فِي تَعْلِيْقِ الْإِبْرَاءِ بِأَدَاءِ الْبَعْضِ، لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَبْدَأَ بِالْأَدَاءِ أَوْ لَا، فَإِنْ بَدَأَ بِهِ فَلَا يَخْلُو، وَإِمَّا أَنْ يَذْكُرَ مَعَهُ بَقَاءَ الْبَاقِي عَلَى الْمَدْيُونِ صَرِيحًا عِنْدَ عَدَمِ الْوَفَاءِ بِالشَّرْطِ أَوْ لَا، فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ، فَهُوَ الْوَجْهُ الْأَوَّلُ، وَإِنْ ذَكَرَهُ فَهُوَ الْوَجْهُ الثَّانِي، وَإِنْ لَمْ يَبْدَأْ بِالْأَدَاءِ، فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَبْدَأَ بِالْإِبْرَاءِ أَوْ لَا، فَإِنْ بَدَأَ بِهِ، فَهُوَ الْوَجْهُ الثَّالِثُ، وَإِنْ لَمْ يَبْدَأْ بِالْإِبْرَاءِ فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَبْدَأَ بِحَرْفِ الشَّرْطِ أَوْ لَا، فَإِنْ لَمْ يَبْدَأْ فَالْوَجْهُ الرَّابِعُ وَإِنْ بَدَأَ فَهُوَ الْخَامِسُ. أَمَّا الْوَجْهُ الْأَوَّلُ: فَقَدْ ذَكَرْنَاهُ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي: ظَهَرَ مِمَّا تَقَدَّمَ، وَالثَّالِثُ: وَهُوَ الْمَوْعُودُ بِاسْتِخْرَاجِ الْجَوَابِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الثَّابِتَ أَوَّلًا لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ، فَإِذَا قُدِّمَ الْإِبْرَاءُ حَصَلَ مُطْلَقًا ثُمَّ يَذْكُرُ مَا بَعْدَهُ وَقَعَ الشَّكُّ، لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ عَوْضًا فَهُوَ بَاطِلٌ لِمَا تَقَدَّمَ فَلَمْ يَزَلْ بِهِ الْإِطْلَاقُ، وَإِنْ كَانَ شَرْطًا يُقَيَّدُ بِهِ وَزَالَ الْإِطْلَاقُ، فَإِذَا وَقَعَ الشَّكُّ لَمْ يَبْطُلْ بِهِ الثَّابِتُ أَوَّلًا، وَفِي عَكْسِهَا عَكْسُ ذَلِكَ، وَالرَّابِعُ: وَجْهُهُ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُؤَقِّتْ لِلْأَدَاءِ وَقْتًا، ظَهَرَ أَنَّ آدَاءَ الْبَعْضِ لَمْ يَكُنْ لِعَرْضٍ، لِكُونِهِ وَاجِبًا فِي مُطْلَقِ الْأَرْزَامِ، فَلَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ فِي مَعْنَى الشَّرْطِ لِيَحْصَلَ بِهِ التَّقْيِيدُ فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا جِهَةُ الْعَوْضِ، وَهُوَ غَيْرُ صَالِحٍ لِذَلِكَ كَمَا تَقَدَّمَ، وَالْخَامِسُ تَعْلِيْقُ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْإِبْرَاءَ لَا يَحْتَمِلُهُ فَلَا يَكُونُ صَحِيحًا. العناية 429/8، 430.

(574) أي هذا التصرف وهو التأخير أو الحط جاز على رب الدين حتى لا يتمكن من مطالبته في الحال، ولا مطالبة ما حط عنه. البناية 31/10.

(575) أي يؤخذ المقر بجميع المال في الحال بلا خلاف، لأنه إقرار منه بالحق. البناية 31/10.

فصل في الدين المشترك

صلح أحد الشريكين في الدين في جميع نصيبه : قَالَ (وَإِذَا كَانَ الدَّيْنُ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ ، فَصَالَحَ أَحَدُهُمَا مِنْ نَصِيبِهِ عَلَى تَوْبٍ ، فَشَرِيكُهُ بِالْخِيَارِ ، إِنْ شَاءَ اتَّبَعَ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ بِصِفَةٍ ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ نِصْفَ الثَّوْبِ ، إِلَّا أَنْ يَضْمَنَ لَهُ شَرِيكُهُ رُبْعَ الدَّيْنِ) ، وَأَصْلُ هَذَا : أَنَّ الدَّيْنَ الْمُشْتَرَكِ⁽⁵⁷⁶⁾ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، إِذَا قَبِضَ أَحَدُهُمَا شَيْئًا مِنْهُ ، فَلِصَاحِبِهِ أَنْ يُشَارِكُهُ فِي الْمَقْبُوضِ ، لِأَنَّهُ ارْتَدَادٌ بِالْقَبْضِ ، إِذْ مَالِيَّةُ الدَّيْنِ بِاعْتِبَارِ عَاقِبَةِ الْقَبْضِ ، وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ رَاجِعَةٌ إِلَى أَصْلِ الْحَقِّ ، فَتَصِيرُ كَزِيَادَةِ الْوَلَدِ وَالنَّمْرِ ، وَلَهُ حَقُّ الْمُشَارَكَةِ ، وَلَكِنَّهُ قَبْلَ الْمُشَارَكَةِ بَاقٍ عَلَى مَالِكِ الْقَابِضِ ، لِأَنَّ الْعَيْنَ غَيْرُ الدَّيْنِ حَقِيقَةً ، وَقَدْ قَبِضَهُ بَدَلًا عَنْ حَقِّهِ فَيَمْلِكُهُ حَتَّى يَنْفَذَ تَصَرُّفَهُ فِيهِ ، وَيَضْمَنَ لِشَرِيكِهِ حِصَّتَهُ ، وَالدَّيْنُ الْمُشْتَرَكُ يَكُونُ وَاجِبًا بِسَبَبٍ مُتَّحِدٍ ، كَتَمَنِ الْمُبِيعُ إِذَا كَانَ صَفَقَةً وَاحِدَةً ، وَتَمَنِ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ وَالْمَوْرُوثِ بَيْنَهُمَا ، وَقِيَمَةُ الْمُسْتَهْلَكِ الْمُشْتَرَكِ.

إِذَا عَرَفْنَا هَذَا فَنَقُولُ فِي مَسْأَلَةِ الْكِتَابِ: لَهُ أَنْ يَتَّبَعَ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَصْلُ ، لِأَنَّ نَصِيبَهُ بَاقٍ فِي ذِمَّتِهِ ، لِأَنَّ الْقَابِضَ قَبِضَ نَصِيبِهِ ، لَكِنَّ لَهُ حَقَّ الْمُشَارَكَةِ ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ نِصْفَ الثَّوْبِ ، لِأَنَّ لَهُ حَقَّ الْمُشَارَكَةِ إِلَّا أَنْ يَضْمَنَ لَهُ شَرِيكُهُ رُبْعَ الدَّيْنِ لِأَنَّ حَقَّهُ فِي ذَلِكَ⁽⁵⁷⁷⁾.

صلح أحد الشريكين في الدين في نصف نصيبه : قَالَ (وَلَوْ اسْتَوْفَى نِصْفَ نَصِيبِهِ مِنَ الدَّيْنِ كَانَ لِشَرِيكِهِ أَنْ يُشَارِكُهُ فِيمَا قَبِضَ) ، لِمَا قُلْنَا (ثُمَّ يَرْجِعَانِ عَلَى الْغَرِيمِ بِالْبَاقِي) ، لِأَنَّهُمَا لَمَّا اشْتَرَكَا فِي الْمَقْبُوضِ لَا بُدَّ أَنْ يَبْقَى الْبَاقِي عَلَى الشَّرِكَةِ.

صلح أحد الشريكين عن نصيبه بسلعة : قَالَ (وَلَوْ اشْتَرَى أَحَدُهُمَا بِنَصِيبِهِ مِنَ الدَّيْنِ سِلْعَةً ، كَانَ لِشَرِيكِهِ أَنْ يُضْمَنَهُ رُبْعَ الدَّيْنِ) ، لِأَنَّهُ صَارَ قَابِضًا حَقَّهُ بِالْمَقَاصَةِ كَامِلًا ، لِأَنَّ مَبْنَى الْبَيْعِ

(576) عُرِفَ الدَّيْنُ الْمُشْتَرَكُ : بِأَنَّهُ الَّذِي يَكُونُ وَاجِبًا بِسَبَبٍ مُتَّحِدٍ ، كَتَمَنِ مَبِيعَ صَفَقَةٍ وَاحِدَةٍ ، بِأَنَّ كَانَ لِكُلِّ مِنْهُمَا عَيْنٌ عَلَى حِدَةٍ ، فَبَاعَا صَفَقَةً وَاحِدَةً ، وَتَمَنِ مَالٍ مُشْتَرَكٍ ، وَمَوْرُوثٍ مُشْتَرَكٍ وَقِيَمَةِ مُسْتَهْلَكٍ مُشْتَرَكٍ . العناية 8 / 433.

(577) لما فرغ المصنف - رَحِمَهُ اللَّهُ - من بيان الأصل قال: إذا عرفنا (هذا) : وترك عليه (فنقول في مسألة الكتاب) : أي مختصر القدوري (له أن يتبع الذي عليه الأصل) : أي للساكت أن يتبع المديون (لأن نصيبه باق في ذمته) : ولم يستوفه (لأن القابض قبض نصيبه لكن له حق المشاركة وإن شاء أخذ نصف الثوب) ونصف الثوب قدر ربع الدين، لأن الثوب صولح عليه بنصف الدين ، فيكون الثوب قدر نصف الدين ، ونصف النصف ربع لا محالة (لأن له حق المشاركة إلا أن يضمن له شريكه ربع الدين، لأن حقه في ذلك) أي لأن حقه في الأصل كان في الدين. البناية 33/10.

عَلَى الْمَمَاكِسَةِ⁽⁵⁷⁸⁾ ، بِخِلَافِ الصُّلْحِ ، لِأَنَّ مَبْنَاهُ عَلَى الْإِغْمَاضِ وَالْحَطِيطَةِ ، فَلَوْ أَلْزَمْنَاهُ دَفْعَ رُبْعِ الدِّينِ يَتَضَرَّرُ بِهِ ، فَيَتَخَيَّرُ الْقَابِضُ كَمَا ذَكَرْنَا ، وَلَا سَبِيلَ لِلشَّرِيكِ عَلَى التَّوْبِ فِي الْبَيْعِ ، لِأَنَّهُ مَلَكُهُ بِعَقْدِهِ ، وَالِاسْتِيفَاءُ بِالْمَقَاصَةِ بَيْنَ ثَمَنِهِ وَبَيْنَ الدِّينِ .

وَلِلشَّرِيكِ أَنْ يَتَّبَعَ الْغَرِيمَ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَا ، لِأَنَّ حَقَّهُ فِي ذِمَّتِهِ بَاقٍ ، لِأَنَّ الْقَابِضَ اسْتَوْفَى نَصِيبَهُ حَقِيقَةً ، لَكِنَّ لَهُ حَقَّ الْمُشَارَكَةِ ، فَلَهُ أَنْ لَا يُشَارِكُهُ ، فَلَوْ سَلَّمَ لَهُ مَا قَبِضَ ، ثُمَّ تَوَى⁽⁵⁷⁹⁾ مَا عَلَى الْغَرِيمِ لَهُ أَنْ يُشَارِكَ الْقَابِضَ ، لِأَنَّهُ رَضِيَ بِالتَّسْلِيمِ لِيُسَلَّمَ لَهُ مَا فِي ذِمَّةِ الْغَرِيمِ ، وَلَمْ يُسَلِّمْ ، وَلَوْ وَقَعَتِ الْمَقَاصَةُ⁽⁵⁸⁰⁾ بَدِينٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ ، لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ الشَّرِيكُ⁽⁵⁸¹⁾ ، لِأَنَّهُ قَاضٍ بِنَصِيبِهِ لَا مُقْتَضٍ ، وَلَوْ أَبْرَاهُ عَنْ نَصِيبِهِ ، فَكَذَلِكَ لِأَنَّهُ إِتْلَافٌ وَلَيْسَ بِقَبْضٍ ، وَلَوْ أَبْرَاهُ عَنْ الْبَعْضِ كَانَتْ قِسْمَةُ الْبَاقِي عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ السَّهَامِ ، وَلَوْ آخَرَ أَحَدُهُمَا عَنْ نَصِيبِهِ صَحَّ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ، اعْتِبَارًا بِالْإِبْرَاءِ الْمُطْلَقِ ، وَلَا يَصِحُّ عِنْدَهُمَا ، لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى قِسْمَةِ الدِّينِ قَبْلَ الْقَبْضِ ، وَلَوْ غَصَبَ أَحَدُهُمَا عَيْنًا مِنْهُ أَوْ اشْتَرَاهَا شِرَاءً فَاسِدًا وَهَلَكَ فِي يَدِهِ فَهُوَ قَبْضٌ ، وَالِاسْتِجَارُ بِنَصِيبِهِ قَبْضٌ ، وَكَذَا الْإِحْرَاقُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ⁽⁵⁸²⁾ -

(578) المماكسة : من المكس في البيع ، وهو استنقاص الثمن من باب ضرب . البناية 5 / 171 ، المعرب في ترتيب المغرب ص 431 ، 432 .

(579) "التوى: الهلاك ، مقصور يكتب بالياء ، لأنهم يقولون : توى ما له يتوى توى ، إذا هلك " . المقصور والممدود ، لابن ولاد أبو العباس أحمد بن محمد بن الوليد التميمي المصري (المتوفى: 332هـ) 22/1 .

(580) أصل المقاصة: المماثلة، من قولهم: قص الخبر: إذا حكاه، فأداه على مثل ما سمع ، والقصاص في الجراح: أن يستوفي مثل جرحه، وكذلك سميت المقاصة في الدين؛ لأن على كل واحد منهما لصاحبه مثل ما للآخر . النَّظْمُ الْمُسْتَعْدَبُ فِي تَفْسِيرِ غَرِيبِ أَلْفَاظِ الْمَهْدَبِ ، لابن بطال 114/2 .

(581) وَإِذَا تَزَوَّجَ بِنَصِيبِهِ مِنَ الدِّينِ لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ الشَّرِيكُ فِي ظَاهِرِ الرَّوَايَةِ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَقْبِضْ مِنْ حِصَّتِهِ شَيْئًا مَضْمُونًا يَقْبَلُ الشَّرِكَةُ ، فَإِنَّهُ يَمْلِكُ بِهِ الْبُذْءَ ، وَإِنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ مُتَقَوِّمٍ وَلَا مَضْمُونٍ عَلَى أَحَدٍ ، فَكَانَ كَالْجَنَائَةِ ، وَرَوَى بِشَرٍّ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يَرْجِعُ ، لِأَنَّ التَّزَوُّجَ وَإِنْ كَانَ بِالنَّصِيبِ لَفْظًا ، فَهُوَ بِمِثْلِهِ مَعْنَى ، فَيَكُونُ دَيْنُ الْمَهْرِ الْوَاجِبِ لِلْمَرْأَةِ آخِرَ الدَّيْنَيْنِ ، فَيَصِيرُ قَضَاءً لِلأَوَّلِ فَيَتَحَقَّقُ الْقَضَاءُ وَالِاقْتِضَاءُ ، وَالصُّلْحُ عَلَى نَصِيبِهِ بِجَنَائَةِ الْعَمْدِ إِتْلَافٌ كَالْتَّزَوُّجِ بِهِ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَقْبِضْ شَيْئًا قَابِلًا لِلشَّرِكَةِ بَلْ أَتْلَفَ نَصِيبَهُ . العناية 437/8 .

(582) وَصُورَةُ الْإِحْرَاقِ : مَا إِذَا رَمَى النَّارَ عَلَى ثَوْبِ الْمَذْبُورِ فَأَحْرَقَهُ وَهُوَ يُسَاوِي نَصِيبَ الْمُحْرَقِ ، وَأَمَّا إِذَا أَخَذَ الثَّوْبَ ثُمَّ أَحْرَقَهُ فَإِنَّ لِلشَّرِيكِ السَّكْتَ أَنْ يَتَّبَعَ الْمُحْرَقَ بِالْإِجْمَاعِ ، لِمُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّ الْإِحْرَاقَ إِتْلَافٌ لِمَالٍ مَضْمُونٍ فَكَانَ كَالْغَصَبِ ، وَالْمَذْبُورُ صَارَ قَاضِيًا لِنَصِيبِهِ بِطَرِيقِ الْمَقَاصَةِ ، فَيُجْعَلُ الْمُحْرَقُ مُقْتَضِيًا ، وَلِأَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّ مُتْلَفَ نَصِيبِهِ بِمَا صَنَعَ لَا قَابِضٌ ، لِأَنَّ الْإِحْرَاقَ إِتْلَافٌ فَكَانَ هَذَا نَظِيرَ الْجَنَائَةِ ، فَإِنَّهُ لَوْ جَنَى عَلَى نَفْسِ الْمَذْبُورِ حَتَّى سَقَطَ نَصِيبُهُ مِنَ الدِّينِ لَمْ يَكُنْ لِلْآخِرِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ ، فَكَذَا إِذَا جَنَى بِالْإِحْرَاقِ . العناية 437/8 .

رَحِمَهُ اللَّهُ - وَالتَّزَوُّجُ بِهِ إِتْلَافٌ فِي ظَاهِرِ الرَّوَايَةِ⁽⁵⁸³⁾ ، وَكَذَا الصُّلْحُ عَلَيْهِ مِنْ جِنَايَةِ الْعَمْدِ⁽⁵⁸⁴⁾ .

صلح أحد الشريكين في السلم على رأس المال : قَالَ (وَإِذَا كَانَ السَّلْمُ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ ، فَصَالَحَ أَحَدُهُمَا مِنْ نَصِيْبِهِ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ ، لَمْ يَجُزْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ . وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يَجُوزُ الصُّلْحُ) ، اِعْتِبَارًا بِسَائِرِ الدُّيُونِ ، وَيَمَّا إِذَا اشْتَرَيَا عَبْدًا فَأَقَالَ أَحَدُهُمَا فِي نَصِيْبِهِ . وَلَهُمَا أَنَّهُ لَوْ جَازَ فِي نَصِيْبِهِ خَاصَّةً يَكُونُ قِسْمَةُ الدَّيْنِ فِي الدِّمَّةِ ، وَلَوْ جَازَ فِي نَصِيْبِهِمَا لَا بُدَّ مِنْ إِجَازَةِ الْآخِرِ بِخِلَافِ شِرَاءِ الْعَيْنِ ، وَهَذَا لِأَنَّ الْمُسْلِمَ فِيهِ صَارَ وَاجِبًا بِالْعَقْدِ ، وَالْعَقْدُ قَامَ بِهِمَا فَلَا يَنْفَرِدُ أَحَدُهُمَا بِرَفْعِهِ ، وَلِأَنَّهُ لَوْ جَازَ لَشَارَكَهُ فِي الْمَقْبُوضِ ، فَإِذَا شَارَكَهُ فِيهِ رَجَعَ الْمُصَالِحُ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ بِذَلِكَ فَيُؤَدِّي إِلَى عَوْدِ السَّلْمِ بَعْدَ سُقُوطِهِ . قَالُوا: هَذَا إِذَا خَلَطَا رَأْسَ الْمَالِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُونَا قَدْ خَلَطَاهُ فَعَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ هُوَ عَلَى الْخِلَافِ ، وَعَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي هُوَ عَلَى الْإِتْفَاقِ⁽⁵⁸⁵⁾ .

(583) ظاهر الرواية : وَهِيَ مَسَائِلُ مَرْوِيَّةٌ عَنْ أَصْحَابِ الْمَذْهَبِ ، وَهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ ، وَيَلْحَقُ بِهِمْ زُفَرٌ ، وَالْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ وَغَيْرُهُمَا مِمَّنْ أَخَذَ عَنِ الْإِمَامِ ، لَكِنَّ الْعَالِبَ الشَّائِعَ فِي ظَاهِرِ الرَّوَايَةِ أَنْ يَكُونَ قَوْلُ الثَّلَاثَةِ ، وَكُتِبَ ظَاهِرُ الرَّوَايَةِ ، كُتِبَ مُحَمَّدُ السَّنَّةُ الْمُبْسُوطُ وَالزِّيَادَاتُ وَالْجَامِعُ الصَّغِيرُ وَالسِّيَرُ الصَّغِيرُ وَالْجَامِعُ الْكَبِيرُ ، وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ بِظَاهِرِ الرَّوَايَةِ؛ لِأَنَّهَا رُوِيَتْ عَنْ مُحَمَّدٍ بِرَوَايَاتِ الثَّقَاتِ ، فَهِيَ ثَابِتَةٌ عَنْهُ إِمَّا مُتَوَاتِرَةً أَوْ مَشْهُورَةً عَنْهُ .. رد المحتار 69/1 ، رسم المفتي ص 16 .

(584) وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِقَوْلِهِ عَمْدًا لِأَنَّهُ فِي الْخَطَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ ، وَأُطْلِقَ فِي الْإِيضَاحِ فَقَالَ: وَلَوْ شَجَّهُ مُوضِحَةً فَصَالَحَهُ عَلَى حَصَّتِهِ لَمْ يَلْزَمْ الشَّرِيكَ شَيْءٌ لِأَنَّ الصُّلْحَ عَنِ الْمَوْضِحَةِ بِمَنْزِلَةِ النِّكَاحِ ، وَأَرَى أَنَّهُ قَيَّدَهُ بِذَلِكَ لِأَنَّ الْأَرْضَ قَدْ يَلْزَمُ الْعَاقِلَةَ فَلَمْ يَكُنْ مُقْتَضِيًا لَشَيْءٍ . العناية 437/8 .

(585) قوله (فعلى الوجه الأول) : أراد به النكته الأولى ، وهي لزوم قسمة الدين في الذمة (هو على الخلاف) : المذكور (وعلى الوجه الثاني) : أراد به النكته الثانية (هو) : قوله : "ولأنه لو جاز لشاركه ... إلى آخره " (على الاتفاق) : أي صح صلح أحدهما على الاتفاق على رأس ماله ، لأن رأس المال إذا لم يكن مخلوطا ، وقبضه صاحبه لم يكن لشريكه أن يشاركه فيه ، لأنه لا حق له فيه لأنه مال الغير . البناية 37/10 .

فصل في التخرج

تخرج أحد الورثة من تركة العقار أو العروض : (وَإِذَا كَانَتْ الشَّرِكَةُ بَيْنَ وَرَثَةٍ فَأَخْرَجُوا)⁽⁵⁸⁶⁾ أَحَدَهُمْ مِنْهَا بِمَالٍ أَعْطَوْهُ إِيَّاهُ ، وَالتَّرِكَةُ عَقَارٌ أَوْ عُرُوضٌ ، جَازَ قَلِيلًا كَانَ مَا أَعْطَوْهُ إِيَّاهُ أَوْ كَثِيرًا) ، لِأَنَّهُ أَمَكَّنَ تَصْحِيحَهُ بَيْنًا ، وَفِيهِ أَثَرُ عُثْمَانَ ، فَإِنَّهُ صَالِحٌ تَمَاضَرَ الْأَشْجَعِيَّةَ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ رُبْعِ ثَمَانِيَةِ أَلْفِ دِينَارٍ⁽⁵⁸⁷⁾.

تخرج أحد الورثة من تركة أثمان : قَالَ (وَإِنْ كَانَتْ التَّرِكَةُ فِضَّةً فَأَعْطَوْهُ ذَهَبًا ، أَوْ كَانَ ذَهَبًا فَأَعْطَوْهُ فِضَّةً ، فَهُوَ كَذَلِكَ) ، لِأَنَّهُ بَيَعَ الْجِنْسَ بِخِلَافِ الْجِنْسِ ، فَلَا يُعْتَبَرُ التَّسَاوِي ، وَيُعْتَبَرُ التَّقَابُضُ فِي الْمَجْلِسِ ، لِأَنَّهُ صَرَفٌ ، غَيْرَ أَنَّ الَّذِي فِي يَدِهِ بَقِيَّةُ التَّرِكَةِ إِنْ كَانَ جَاحِدًا ، يَكْتَفِي بِذَلِكَ الْقَبْضِ ، لِأَنَّهُ قَبْضُ ضَمَانٍ ، فَيُنُوبُ عَنْ قَبْضِ الصُّلْحِ ، وَإِنْ كَانَ مُقِرًّا لَا بُدَّ مِنْ تَجْدِيدِ الْقَبْضِ ، لِأَنَّهُ قَبْضُ أَمَانَةٍ ، فَلَا يَنْبُؤُ عَنْ قَبْضِ الصُّلْحِ ، (وَإِنْ كَانَتْ التَّرِكَةُ ذَهَبًا وَفِضَّةً وَغَيْرَ ذَلِكَ فَصَالِحُهُ عَلَى ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ ، فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَا أَعْطَوْهُ أَكْثَرَ مِنْ نَصِيبِهِ مِنْ ذَلِكَ الْجِنْسِ حَتَّى يَكُونَ نَصِيبُهُ بِمِثْلِهِ ، وَالزِّيَادَةُ بِحَقِّهِ مِنْ بَقِيَّةِ التَّرِكَةِ) احْتِرَازًا عَنِ الرَّبَا ، وَلَا بُدَّ مِنَ التَّقَابُضِ فِيمَا يُقَابَلُ نَصِيبَهُ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، لِأَنَّهُ صَرَفٌ فِي هَذَا الْقَدْرِ ، وَلَوْ كَانَ بَدَلُ الصُّلْحِ عَرْضًا جَازَ مُطْلَقًا ، لِعَدَمِ الرَّبَا ، وَلَوْ كَانَ فِي التَّرِكَةِ دَرَاهِمٌ وَدَنَانِيرُ ، وَبَدَلُ الصُّلْحِ دَرَاهِمٌ وَدَنَانِيرُ أَيْضًا ، جَازَ الصُّلْحُ كَيْفَمَا كَانَ صَرَفًا لِلْجِنْسِ إِلَى خِلَافِ الْجِنْسِ ، كَمَا فِي الْبَيْعِ ، لَكِنْ يُشْتَرَطُ التَّقَابُضُ لِلصَّرْفِ⁽⁵⁸⁸⁾.

(586) (التَّخَارُجُ تَفَاعُلٌ مِنَ الْخُرُوجِ ، وَهُوَ أَنْ يَصْطَلِحَ الْوَرَثَةُ عَلَى إِخْرَاجِ بَعْضِهِمْ مِنَ الْمِيرَاثِ بِمَالٍ مَعْلُومٍ ، نَصَتْ الْمَادَّةُ 48 مِنْ قَانُونِ الْمَوَارِيثِ رَقْمَ 77 لِسَنَةِ 1943 م عَلَى أَنَّ "التَّخَارِجَ" هُوَ أَنْ يَتَصَالَحَ الْوَرَثَةُ عَلَى إِخْرَاجِ بَعْضِهِمْ مِنَ الْمِيرَاثِ عَلَى شَيْءٍ مَعْلُومٍ ، فَإِذَا تَخَارَجَ أَحَدُ الْوَرَثَةِ مَعَ آخَرٍ مِنْهُمْ اسْتَحَقَّ نَصِيبُهُ وَحُلَ مَحَلَّةٌ فِي الشَّرِكَةِ ، وَإِذَا تَخَارَجَ أَحَدُ الْوَرَثَةِ مَعَ بَاقِيهِمْ ، فَإِنْ كَانَ الْمَدْفُوعُ لَهُ مِنَ التَّرِكَةِ قِسْمَ نَصِيبِهِ بَيْنَهُمْ بِنِسْبَةِ أَنْصَائِهِمْ فِيهَا ، وَإِنْ كَانَ الْمَدْفُوعُ مِنْ مَالِهِمْ ، وَلَمْ يَنْصَ فِي عَقْدِ التَّخَارِجِ عَلَى طَرِيقَةِ قِسْمَةِ نَصِيبِ الْخَارِجِ قِسْمَ عَلَيْهِمْ بِالسُّوِيَةِ بَيْنَهُمْ " ، وَوَجَّهُ تَأْخِيرِهِ : قَلَّةُ وَقُوعِهِ ، فَإِنَّهُ قَلَّمَا يَرْضَى أَحَدٌ بِأَنْ يَخْرُجَ مِنَ الثَّيْنِ بِغَيْرِ اسْتِيفَاءِ حَقِّهِ ، وَسَبَبُهُ : طَلَبُ الْخَارِجِ مِنَ الْوَرَثَةِ ذَلِكَ عِنْدَ رِضَا غَيْرِهِ بِهِ . الْعِنَايَةُ شَرْحُ الْهَدَايَةِ 439/8 ، فَهْهُ الْفَرَائِضُ ، د/فَرْجُ زَهْرَانِ ص 892.

(587) (أخرجه البيهقي بسنده عن معاوية بن عبد الله بن جعفر ، عن السائب بن يزيد ابن أخت نمر ، وقال : وهذا إسناد موصول . معرفة السنن رقم 14843 ، 44 .)
(588) (أي : لأجل كونه صرفاً . البنائة 39/10 .)

الصلح على دين التركة بإخراج المصالح عنه على أن يكون الدين له : قَالَ (وَإِذَا كَانَ فِي التَّرَكَةِ دَيْنٌ عَلَى النَّاسِ ، فَأَدْخَلُوهُ فِي الصُّلْحِ عَلَى أَنْ يُخْرِجُوا الْمُصَالِحَ عَنْهُ وَيَكُونَ الدَّيْنُ لَهُ ، فَالْصُّلْحُ بَاطِلٌ) ، لِأَنَّ فِيهِ تَمْلِيكَ الدَّيْنِ مِنْ غَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ وَهُوَ حِصَّةُ الْمُصَالِحِ (589).

الصلح عن دين التركة بشرط براءة الغرماء : (وَإِنْ شَرَطُوا أَنْ يَبْرَأَ الْغَرَمَاءُ مِنْهُ ، وَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهِمْ بِنَصِيبِ الْمُصَالِحِ ، فَالْصُّلْحُ جَائِزٌ) ، لِأَنَّهُ إِسْقَاطٌ ، وَهُوَ تَمْلِيكَ الدَّيْنِ مِمَّنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ ، وَهُوَ جَائِزٌ ، وَهَذِهِ حِيلَةُ الْجَوَازِ ، وَأُخْرَى : أَنْ يُعْجَلُوا قَضَاءُ نَصِيبِهِ مُتَبَرِّعِينَ ، وَفِي الْوَجْهَيْنِ ضَرَرٌ بِبَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ (590) ، وَالْأَوْجُهُ : أَنْ يُقْرِضُوا الْمُصَالِحَ مِقْدَارَ نَصِيبِهِ ، وَيُصَالِحُوا عَمَّا وَرَاءَ الدَّيْنِ ، وَيُحِيلَهُمْ عَلَى اسْتِيفَاءِ نَصِيبِهِ مِنَ الْغَرَمَاءِ (591).

وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي التَّرَكَةِ دَيْنٌ وَأَعْيَانُهَا غَيْرُ مَعْلُومَةٍ ، وَالصُّلْحُ عَلَى الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ ، قِيلَ لَا يَجُوزُ لِاحْتِمَالِ الرَّبَا ، وَقِيلَ : يَجُوزُ لِأَنَّهُ شُبْهَةُ الشُّبْهَةِ (592) ، وَلَوْ كَانَتْ التَّرَكَةُ غَيْرَ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ لَكُنَّهَا أَعْيَانٌ غَيْرُ مَعْلُومَةٍ ، قِيلَ : لَا يَجُوزُ ، لِكُونِهِ بَيِّنًا ، إِذْ الْمُصَالِحُ عَنْهُ عَيْنٌ ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَجُوزُ ، لِأَنَّهُ لَا تَفْضِي إِلَى الْمُنَازَعَةِ ، لِقِيَامِ الْمُصَالِحِ عَنْهُ فِي يَدِ الْبَقِيَّةِ مِنَ الْوَرَثَةِ ، وَإِنْ كَانَ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ مُسْتَعْرَقٌ لَا يَجُوزُ الصُّلْحُ وَلَا الْقِسْمَةُ ، لِأَنَّ التَّرَكَةَ لَمْ يَتَمَلَّكْهَا الْوَارِثُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَعْرَقًا لَا يَنْبَغِي أَنْ يُصَالِحُوا مَا لَمْ يَقْضُوا دَيْنَهُ فَتُقَدِّمَ حَاجَةَ الْمَيِّتِ ، وَلَوْ فَعَلُوا قَالُوا يَجُوزُ. وَذَكَرَ الْكَرْخِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي الْقِسْمَةِ أَنَّهَا لَا تَجُوزُ اسْتِحْسَانًا وَتَجُوزُ قِيَاسًا (593).

(589) أي تملك الدين من غير من عليه حصة المصالح بكسر اللام. البناءة 40/10.
(590) أَمَّا فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ: فَلِأَنَّ بَقِيَّةَ الْوَرَثَةِ لَا يُمَكِّنُهُمُ الرُّجُوعُ عَلَى الْغَرَمَاءِ ، وَفِي الْوَجْهِ الثَّانِي : لَزُومُ النَّقْدِ عَلَيْهِمْ بِمُقَابَلَةِ الدَّيْنِ الَّذِي هُوَ نَسِيبَةٌ ، وَالنَّفَقُ خَيْرٌ مِنَ النِّسِيبَةِ . العناية 422/8 .

(591) وهذا في الوجهين ظاهر؛ لأنهم إذا أعطوا المصالح شيئاً بمقابلة الدين، أو قدر الدين ولم يحصل لهم الدين فقد حصل لهم ضرر دنيوي ، وليس في الصورة الثالثة مثل ذلك من الضرر؛ لأنهم وإن خرج منهم قدر الدين لكن حصل لهم الدين بمقابلته ، فانتفى عنهم الضرر إلا ضرر النقد ، فإن العين خير من الدين . تبیین الحقائق 51/5.

(592) وإنما المعتبر الشبهة لا شبهة الشبهة، وذلك لأنه لو علم أعيان التركة ، ولكن جهل قدر بدل الصلح من نصيب المصالح يكون شبهة، فإذا لم يعلم أعيان التركة يكون شبهة الشبهة ، لأنه يحتمل أن يكون في التركة كلي ووزني، ويحتمل أن لا يكون، والقائل بعدم الجواز المرغيناني، والقائل بالجواز هو أبو جعفر الهندواني. وفي " فتاوى قاضي خان " : والصحيح ما قاله أبو جعفر. البناءة 40/10، 41.

(593) وَجْهُ الْإِسْتِحْسَانِ : أَنَّ الدَّيْنَ يَمْنَعُ تَمَلُّكَ الْوَرَثَاتِ ، إِذْ مَا مِنْ جُزْءٍ إِلَّا وَهُوَ مَشْغُولٌ بِالدَّيْنِ ، فَلَا تَجُوزُ الْقِسْمَةُ قَبْلَ قَضَائِهِ ، وَوَجْهُ الْقِيَاسِ : أَنَّ التَّرَكَةَ لَا تَخْلُو عَنْ قَلِيلِ الدَّيْنِ ، فَتُقَسَّمُ نَفْيًا لِلضَّرَرِ عَنِ الْوَرَثَةِ . العناية 444/8.

كتاب الجنايات (594)

1- أوجه القتل:

الهداية: قَالَ (595) (الْقَتْلُ عَلَى خَمْسَةِ أَوْجِهٍ (596): عَمْدٌ، وَشِبْهُ عَمْدٍ، وَخَطَأٌ، وَمَا أُجْرِي مَجْرَى الْخَطَأِ، وَالْقَتْلُ بِسَبَبٍ) وَالْمُرَادُ (597) بَيَانُ قَتْلِ تَتَعَلَّقُ بِهِ الْأَحْكَامُ.

2- القتل العمد وموجباته

قَالَ (فَالْعَمْدُ مَا نَعَمَدَ ضَرْبُهُ بِسِلَاحٍ أَوْ مَا أُجْرِي مَجْرَى السِّلَاحِ كَالْمُحَدَّدِ مِنَ الْخَشَبِ وَلِيطَةِ الْقَصَبِ (598) وَالْمَرْوَةِ الْمُحَدَّدَةِ (599) وَالنَّارِ) ؛ لِأَنَّ الْعَمْدَ هُوَ الْقَصْدُ، وَلَا يُوقَفُ عَلَيْهِ إِلَّا بِدَلِيلِهِ وَهُوَ اسْتِعْمَالُ الْأَلَةِ الْقَاتِلَةِ فَكَانَ مُتَعَمِّدًا فِيهِ عِنْدَ ذَلِكَ (600)

(594) الجنايات جمع جنائية وهي لغة: اسم لما يُكْتَسَبُ مِنَ الشَّرِّ تَسْمِيَةً بِالْمَصْدَرِ مِنْ جَنَى عَلَيْهِ شَرًّا، وَهُوَ عَمٌّ. ينظر: لسان العرب لابن منظور، مادة (جنى)، 154/14. والجناية شرعا: كل اعتداء مُحَرَّمٌ شَرْعًا حَلًّا بِالنَّفُوسِ وَالْأَطْرَافِ، فَإِنْ حُلَّ بِالنَفْسِ: يُسَمَّى قَتْلًا ؛ وَهُوَ فِعْلٌ مِنَ الْعِبَادِ تَزُولُ بِهِ الْحَيَاةُ، وَزَوَالُ الْحَيَاةِ بَدُونِ قَتْلِ الْعِبَادِ يُسَمَّى مَوْتًا. وَإِنْ حُلَّ بِالْأَطْرَافِ: يُسَمَّى قَطْعًا وَجَرْحًا.

وشرعت الجنايات لصيانة الأنفس والأطراف. وسببها: كل اعتداء على النفس والأطراف. وشرط الجنايات: كَوْنُ الْمَجْنِي عَلَيْهِ إِنْسَانًا مَعْصُومَ الدَّمِ.

(595) القدوري، أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان الفقيه الحنفي، المعروف بالقدوري؛ انتهت إليه رئاسة الحنفية بالعراق. وكان حسن العبارة في النظر. وسمع الحديث، وروى عنه أبو بكر الخطيب صاحب التاريخ، وصنف في مذهبه المختصر المشهور وغيره. وكانت ولادته سنة اثنتين وستين وثلاثمائة، وتوفي يوم الأحد الخامس من رجب سنة ثمان وعشرين وأربعمائة ببغداد. والقدوري بضم القاف والدال وسكون الواو وفي آخرها راء نسبة إلى بيع القدور. ينظر: وفيات الأعيان لابن خلكان 79/1، الجواهر المضية في طبقات الحنفية لمحيي الدين الحنفي 336/2.

(596) المراد بالقتل هنا هو : الْقَتْلُ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ حُكْمٌ مِنْ قِصَاصٍ وَدِيَّةٍ وَكَفَّارَةٍ وَجَزْمَانٍ إِرْثٍ خَمْسَةُ أَوْجِهٍ، لِأَنَّ الْقَتْلَ لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ حَصَلَ بِسِلَاحٍ أَوْ بِغَيْرِ سِلَاحٍ، فَإِنْ حَصَلَ بِسِلَاحٍ فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ كَانَ بِهِ قَصْدُ الْقَتْلِ أَوْ لَا، فَإِنْ كَانَ فَهُوَ الْعَمْدُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَهُوَ الْخَطَأُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِسِلَاحٍ فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ كَانَ مَعَهُ قَصْدُ التَّأْدِيبِ وَالضَّرْبِ أَوْ لَا، فَإِنْ كَانَ فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ كَانَ جَارِيًا مَجْرَى الْخَطَأِ أَمْ لَا، فَإِنْ كَانَ فَهُوَ هُوَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَهُوَ الْقَتْلُ بِالسَّبَبِ.

(597) (والمراد) أي مراد القدوري.

(598) الليطة بكسر اللام قشر القصب.

(599) المروة المحددة: وهي القطعة من الحجر الصوان، يكون لها أطراف تقطع ما أصابته.

(وَمُوجِبُ ذَلِكَ الْمَأْتَمُ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} [النساء: 93] الآية، وَقَدْ نَطَقَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ السُّنَّةِ (601)، وَعَلَيْهِ انْعَقَدَ إِجْمَاعُ الْأُمَّةِ. قَالَ (وَالْقَوْدُ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ} [البقرة: 178] إِلَّا أَنَّهُ تَقَيَّدَ بِوَصْفِ الْعَمْدِيَّةِ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «الْعَمْدُ قَوْدٌ» (602) أَيُّ مُوجِبُهُ، وَلِأَنَّ (603) الْجَنَایَةَ بِهَا تَتَكَامَلُ وَحِكْمَةُ الزَّجْرِ عَلَيْهَا تَتَوَقَّرُ، وَالْعُقُوبَةُ الْمُتَنَاهِيَّةُ لَا شَرَعَ لَهَا دُونَ ذَلِكَ (604).

3-مدى جواز العفو والمصالحة عن القصاص

الهداية: قَالَ (إِلَّا أَنْ يَغْفُوَ الْأَوْلِيَاءُ) (605) أَوْ يُصَالِحُوا (606) ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمْ ثُمَّ هُوَ وَاجِبٌ عَيْنًا (607)، وَلَيْسَ لِلْوَلِيِّ أَخْذُ الدِّيَةِ إِلَّا بِرِضَا الْقَاتِلِ (608) وَهُوَ أَحَدُ قَوْلِي الشَّافِعِيِّ، إِلَّا أَنَّ

(600) القتل العمد: أن يقصد القتل بآلة موضوعة للقتل كالبنديقية، أو تقتل غالباً، وهى ما أُجريت مجرى السلاح في تفريق الأجزاء كالمحدد من الخشب وليطة القصب وهى قشره، وهى دليل القصد.

(601) ومنها: قوله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فِي خُطْبَتِهِ بِعَرَفَاتٍ «إِنْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ، كَحَرَمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بِلَدِكُمْ هَذَا» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ 886/2 رَقْم 1218.

وَمِنْهَا قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لِزَوَالِ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ». «خَرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي سَنَنِهِ 68/3 رَقْم 1395.

وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لَنْ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ، مَا لَمْ يُصِْبْ دَمًا حَرَامًا» خَرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ 2/9 رَقْم 6862..

وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَهُ إِلَّا رَجُلٌ يَمُوتُ كَافِرًا أَوْ الرَّجُلُ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا» أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ 391/4 رَقْم 8031.

وَالْأَحَادِيثُ فِي هَذَا الْبَابِ كَثِيرَةٌ جِدًّا.

(602) أَخْرَجَهُ الدَّارِقُطْنِيُّ فِي سَنَنِهِ 82/4 رَقْم 3136.

(603) دَلِيلُ الْمَعْقُولِ عَلَى حَرَمَةِ الْقَتْلِ

(604) أَيُّ لَا شَرْعِيَّةَ لِلْعُقُوبَةِ الْمُتَنَاهِيَّةِ بِدُونِ الْعَمْدِيَّةِ.

(605) لَفْظُ الْقُدُورِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -

(606) لَفْظُ الْمَصْنُفِ (الْمَرْغَانِي) - رَحِمَهُ اللَّهُ -.

(607) هَلِ الْقَصَاصُ وَاجِبٌ عَلَى التَّعْيِينِ أَمْ التَّخْيِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الدِّيَةِ؟ فَعِنْدَ الْحَنْفِيَّةِ أَنَّ الْقَصَاصَ وَاجِبٌ عَيْنًا.

(608) هَلِ يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ أَخْذُ الدِّيَةِ بِدُونِ رِضَا الْقَاتِلِ؟ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى قَوْلَيْنِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: ذَهَبَ الْحَنْفِيَّةُ وَأَحَدُ قَوْلِي الشَّافِعِيِّ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ أَخْذُ الدِّيَةِ بِدُونِ رِضَا الْقَاتِلِ، إِلَّا أَنَّ لِلْوَلِيِّ حَقَّ الْعُدُولِ إِلَى الْمَالِ مِنْ غَيْرِ مَرْضَاةِ الْقَاتِلِ، لِأَنَّهُ تَعَيَّنَ مَدْفَعًا لِلْهَلَاكِ فَيَجُوزُ بِدُونِ رِضَاهِ.

لَهُ حَقُّ الْعُدُولِ إِلَى الْمَالِ مِنْ غَيْرِ مَرْضَاةِ الْقَاتِلِ؛ لِأَنَّهُ تَعَيَّنَ مَدْفَعًا لِلْهَلَاكِ فَيَجُوزُ بِدُونِ رِضَاهُ، وَفِي قَوْلِ الْوَاجِبِ أَحَدُهُمَا لَا بَعِيْنُهُ وَيَتَعَيَّنُ بِاخْتِيَارِهِ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْعَبْدِ شَرْعٌ جَابِرٌ وَفِي كُلِّ وَاحِدٍ نَوْعٌ جَبْرٌ فَيَتَخَيَّرُ

وَلَنَا مَا تَلَوْنَا مِنَ الْكِتَابِ (609) وَرَوَيْنَا مِنَ السُّنَّةِ (610)، وَلِأَنَّ (611) الْمَالَ لَا يَصْلُحُ مُوجِبًا لِعَدَمِ الْأُمَثَالَةِ، وَالْقِصَاصُ يَصْلُحُ لِلتَّمَاثُلِ، وَفِيهِ مَصْلَحَةُ الْأَحْيَاءِ زَجْرًا وَجَبْرًا فَيَتَعَيَّنُ، وَفِي الْخَطَا وَجُوبِ الْمَالِ ضَرُورَةُ صَوْنِ الدِّمِّ عَنِ الْإِهْدَارِ، وَلَا يُتَيَقَّنُ بِعَدَمِ قَصْدِ الْوَلِيِّ بَعْدَ اخْتِيارِ الْمَالِ فَلَا يَتَعَيَّنُ مَدْفَعًا لِلْهَلَاكِ (612)،

4-الكفارة والميراث في القتل العمد

القول الثاني: ذهب الشافعي في قول أن الواجب أحدهما لا بعينه -القصاص أو الدية- ويتعين باختياره، واستدلوا على ذلك بالمعقول وهو أَنَّ حَقَّ الْعَبْدِ شَرْعٌ جَابِرٌ وَفِي كُلِّ وَاحِدٍ -القصاص أو الدية- نَوْعٌ جَبْرٌ فَيَتَخَيَّرُ.

(609) قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ} [البقرة: 178] الآية وَوَجْهُ التَّمَسُّكِ بِهِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَكَرَ فِي الْخَطَا الدِّيَةَ فَتَعَيَّنَ أَنَّ يَكُونَ الْقِصَاصُ الْمَذْكُورُ فِيهِ فِيمَا هُوَ ضِدُّ الْخَطَا وَهُوَ الْعَمْدُ، وَلَمَّا تَعَيَّنَ بِالْعَمْدِ لَا يُعَدَّلُ عَنْهُ لِنُفْذِ الزِّيَادَةِ عَلَى النَّصِّ بِالرَّأْيِ.

(610) قوله صلى الله عليه وسلم: «الْعَمْدُ قَوْدٌ» (610) وَوَجْهُ التَّمَسُّكِ بِالسُّنَّةِ أَنَّ الْأَلْفَ وَاللَّامَ فِي قَوْلِهِ الْعَمْدُ قَوْدٌ لِلْجِنْسِ، إِذْ لَا مَعْهُودَ يَنْصَرِفُ إِلَيْهِ، فَبِهِ تَنْصِصُ عَلَى أَنَّ حُكْمَ جِنْسِ الْعَمْدِ ذَلِكَ، فَمَنْ عَدَلَ عَنْهُ إِلَى غَيْرِهِ زَادَ عَلَى النَّصِّ أَثَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - فِي قَوْلِهِ: الْعَمْدُ قَوْدٌ لَا مَالَ فِيهِ إِلَى ذَلِكَ.

(611) المعقول.

(612) جواب عَنْ قَوْلِهِ "لِأَنَّهُ تَعَيَّنَ مَدْفَعًا لِلْهَلَاكِ" بقوله "وَلَا يُتَيَقَّنُ بِعَدَمِ قَصْدِ الْوَلِيِّ..." وَغُورِضُ بَقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِمَّا يُودَى وَإِمَّا يُقَادُ » أخرج البخاري في صحيحه 5/9 رقم 6880. وَبِأَنَّ الشَّرْعَ أَوْجَبَ الْقِصَاصَ لِمَعْنَى الْإِنْتِقَامِ وَتَشْفِي صُدُورِ الْأَوْلِيَاءِ، بِخِلَافِ الْقِيَاسِ فَإِنَّ الْجَمَاعَةَ تُقْتَلُ بِوَاحِدٍ وَالْقِيَاسُ لَا يَقْتَضِيهِ، فَكَانَ لِمَعْنَى النَّظَرِ لِلْوَلِيِّ وَذَلِكَ بِتَمَكُّنِهِ مِنَ الْقِصَاصِ وَاخْتِيارِ الدِّيَةِ.

وَالْجَوَابُ أَنَّ الْحَدِيثَ خَبَرٌ وَاحِدٌ فَلَا يُعَارِضُ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ الْمَشْهُورَةَ، وَأَنَّ الْقِصَاصَ لِمَعْنَى النَّظَرِ لِلْوَلِيِّ عَلَى وَجْهِ خَاصٍّ وَهُوَ الْإِنْتِقَامُ وَتَشْفِي الصُّدُورِ، فَإِنَّهُ شَرْعٌ زَجْرًا عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ إِفْنَاءِ قَبِيلَةٍ بِوَاحِدٍ لَا لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَأْخُذُونَ أَمْوَالًا كَثِيرَةً عِنْدَ قَتْلِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، بَلْ الْقَاتِلُ وَأَهْلُهُ لَوْ بَذَلُوا مَا مَلَكُوهُ وَأَمثالُهُ مَا رَضِيَ بِهِ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ، فَكَانَ إِيْجَابُ الْمَالِ فِي مُقَابَلَةِ الْقَتْلِ الْعَمْدِ تَضْيِيعُ حِكْمَةِ الْقِصَاصِ، وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ الْأَصْلَ هُوَ الْقِصَاصُ لَمْ يَجْزِ الْمَصِيرُ إِلَى غَيْرِهِ بِغَيْرِ ضَرُورَةٍ مِثْلُ أَنْ يَغْفُو أَحَدُ الْأَوْلِيَاءِ فَإِنَّهُ تَعَدَّرَ الْإِسْتِيفَاءُ حِينَئِذٍ، أَوْ أَنْ يَكُونَ مَحَلُّ الْقِصَاصِ نَاقِصًا بِأَنْ تَكُونَ يَدُ قَاطِعِ الْيَدِ أَقَلَّ أَصْبُعًا وَأَمثالُ ذَلِكَ.

الهداية: وَلَا كَفَّارَةَ فِيهِ عِنْدَنَا: وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - تَجِبُ (613)؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ إِلَى التَّكْفِيرِ فِي الْعَمْدِ أَمْسُ مِنْهَا إِلَيْهِ فِي الْخَطَا فَكَانَ أَدْعَى إِلَى إِيْجَابِهَا وَلَنَا أَنَّهُ كَبِيرَةٌ مَحْضَةٌ، وَفِي الْكَفَّارَةِ مَعْنَى الْعِبَادَةِ فَلَا تُنَاطُ بِمِثْلِهَا، وَلِأَنَّ الْكَفَّارَةَ مِنَ الْمَقَادِيرِ، وَتَعْيُنُهَا فِي الشَّرْعِ لِدَفْعِ الْأَذْنَى لَا يُعَيِّنُهَا لِدَفْعِ الْأَعْلَى وَمِنْ حُكْمِهِ حَرَمَانُ الْمِيرَاثِ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «لَا مِيرَاثَ لِقَاتِلٍ» (614).

5-المقصود بالقتل شبه العمد

الهداية: قَالَ (وَشِبْهُ الْعَمْدِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ أَنْ يَتَعَمَّدَ الضَّرْبَ بِمَا لَيْسَ بِسِلَاحٍ وَلَا مَا أُجْرِيَ مَجْرَى السِّلَاحِ) وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ: إِذَا ضَرَبَهُ بِحَجَرٍ عَظِيمٍ أَوْ بِخَشَبَةٍ عَظِيمَةٍ فَهُوَ عَمْدٌ وَشِبْهُ الْعَمْدِ أَنْ يَتَعَمَّدَ ضَرْبَهُ بِمَا لَا يُقْتَلُ بِهِ غَالِبًا؛ لِأَنَّهُ يَتَقَاصَرُ مَعْنَى الْعَمْدِيَّةِ بِاسْتِعْمَالِ آلَةٍ صَغِيرَةٍ لَا يُقْتَلُ بِهَا غَالِبًا لِمَا أَنَّهُ يَقْصِدُ بِهَا غَيْرَهُ كَالْتَّأْدِيبِ وَنَحْوِهِ

(613) اختلف الفقهاء في وجوب الكفارة في القتل العمد على قولين: القول الأول: ذهب الحنفية إلى أنه لَا كَفَّارَةَ فِي الْقَتْلِ الْعَمْدِ سَوَاءً وَجَبَ فِيهِ الْقِصَاصُ أَوْ لَمْ يَجِبْ كَالْأَبِ إِذَا قَتَلَ ابْنَهُ عَمْدًا. القول الثاني: ذهب الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - إلى أنه تَجِبُ الكفارة في القتل العمد، لِأَنَّ الْحَاجَةَ إِلَى التَّكْفِيرِ فِي الْعَمْدِ أَمْسُ مِنْهَا إِلَيْهِ فِي الْخَطَا لِأَنَّهَا لَسْتُ الدَّنْبِ وَالذَّنْبُ فِي الْعَمْدِ أَعْظَمُ. واستدل الحنفية على عدم وجوب الكفارة في القتل العمد بالمعقول لِأَنَّهُ كَبِيرَةٌ مَحْضٌ، وَمَا هُوَ كَذَلِكَ لَا يَكُونُ سَبَبًا لِمَا فِيهِ مَعْنَى الْعِبَادَةِ وَالْكَفَّارَةِ فِيهَا ذَلِكَ.

(614) قال ابن حجر العسقلاني في الدراية في تخريج أحاديث الهداية 260/2 رقم 1005: "حَدِيثُ" لَا مِيرَاثَ لِقَاتِلٍ "أَصْحَابُ السُّنَنِ إِلَّا أَبَا دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ قَالَ التِّرْمِذِيُّ لَا يَصِحُّ وَفِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي قُرُوزَةَ وَهُوَ مَتْرُوكٌ وَقَالَ النَّسَائِيُّ إِسْحَاقُ مَتْرُوكٌ وَإِنَّمَا أَخْرَجْتَهُ لِئَلَّا يَتْرَكَ مِنَ الْوَسْطِ يَعْنِي بَيْنَ اللَّيْثِ وَالزُّهْرِيِّ وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ وَلَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا وَلِلنَّسَائِيِّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ وَقَالَ الصَّوَابُ رَوَايَةُ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ عَمْرًا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ أَنْتَهَى وَهُوَ فِي الْمَوْطِ وَأَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَالِكٍ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَةَ مِنْ طَرِيقِ أَبِي خَالِدٍ الْأَحْمَرِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ الْمَدَلْجِي قَتَلَ ابْنَهُ فَأَخَذَ مِنْهُ عَمْرًا مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ الْحَدِيثُ وَفِيهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ وَقَدْ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ يَحْيَى ابْنِ سَعِيدٍ فَقَالَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْأَوَّلِ أَصَحُّ. وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَةَ وَغَيْرُهُ فِي سُنَنِهِ بَلْفُظٍ «الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ» 913/2 رقم 2735

فَكَانَ شِبْهُ الْعَمْدِ، وَلَا يَتَقَاصَرُ بِاسْتِعْمَالِ آلَةٍ لَا تَلْبَثُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْصِدُ بِهِ إِلَّا الْقَتْلَ كَالسَّيْفِ فَكَانَ عَمْدًا مُوجِبًا لِلْقَوْدِ (615)

وَلَهُ (616) قَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «أَلَا إِنَّ قَتِيلَ خَطَا الْعَمْدِ قَتِيلُ السَّوْطِ وَالْعَصَا، وَفِيهِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ» (617) وَلِأَنَّ الْآلَةَ غَيْرُ مَوْضُوعَةٍ لِلْقَتْلِ وَلَا مُسْتَعْمَلَةٌ فِيهِ؛ إِذْ لَا يُمَكِّنُ اسْتِعْمَالُهَا عَلَى غُرَّةٍ مِنَ الْمَقْصُودِ قَتْلَهُ، وَبِهِ يَحْصُلُ الْقَتْلُ غَالِبًا فَقُصِرَتِ الْعَمْدِيَّةُ نَظَرًا إِلَى الْآلَةِ، فَكَانَ شِبْهُ الْعَمْدِ كَالْقَتْلِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا الصَّغِيرَةِ.

6- موجبات القتل شبه العمد

الهداية: قَالَ (618) (وَمُوجِبُ ذَلِكَ عَلَى الْقَوْلَيْنِ (619) الْإِثْمُ) ؛ لِأَنَّهُ قَتَلَ وَهُوَ قَاصِدٌ فِي الضَّرْبِ (وَالْكَفَّارَةُ) لِشِبْهِهِ بِالْخَطَا (وَالِدِّيَّةُ مُغْلَظَةٌ عَلَى الْعَاقِلَةِ) وَالْأَصْلُ (620) أَنَّ كُلَّ دِيَّةٍ وَجِبَتْ بِالْقَتْلِ ابْتِدَاءً لَا بِمَعْنَى يَحْدُثُ مِنْ بَعْدِ فَهِيَ عَلَى الْعَاقِلَةِ اعْتِبَارًا بِالْخَطَا، وَتَجِبُ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ لِقَضِيَّةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (621) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، وَتَجِبُ مُغْلَظَةً، وَسَنُبَيِّنُ

(615) اختلف الفقهاء في المقصود بالقتل شبه العمد: القول الأول: قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - شِبْهُ الْعَمْدِ هُوَ أَنْ يَتَعَمَّدَ الضَّرْبَ بِمَا لَيْسَ بِسِلَاحٍ وَلَا أُجْرِي مَجْرَاهُ سِوَاهُ كَانَ الْهَلَاكُ بِهِ غَالِبًا كَالْحَجَرِ وَالْعَصَا الْكَبِيرَيْنِ وَمِدْقَةِ الْقَصَارِ أَوْ لَمْ يَكُنْ كَالْعَصَا الصَّغِيرَةِ. القول الثاني: قَالَ الصَّاحِبَانِ شِبْهُ الْعَمْدِ هُوَ أَنْ يَتَعَمَّدَ الضَّرْبَ بِمَا لَا يَحْصُلُ الْهَلَاكُ بِهِ غَالِبًا كَالْعَصَا الصَّغِيرَةِ إِذَا لَمْ يُوَالِ فِي الضَّرَبَاتِ. فَأَمَّا إِذَا وَالَى فِيهَا فَقِيلَ شِبْهُ عَمْدٍ عِنْدَهُمَا وَقِيلَ عَمْدٌ مَحْضٌ، قَالَا: سُمِّيَ هَذَا النَّوْعُ شِبْهُ الْعَمْدِ لِاقْتِصَارِ مَعْنَى الْعَمْدِ فِيهِ وَإِلَّا لَكَانَ عَمْدًا، وَاقْتِصَارُهُ إِنَّمَا يُتَصَوَّرُ فِي اسْتِعْمَالِ آلَةٍ لَا يُقْتَلُ بِهَا غَالِبًا كَالْعَصَا الصَّغِيرَةِ فَإِنَّهُ يُقْصَدُ بِاسْتِعْمَالِهَا غَيْرُ الْقَتْلِ كَالْتَأْدِيبِ وَنَحْوِهِ. لَا فِي اسْتِعْمَالِ آلَةٍ لَا تَلْبَثُ فَإِنَّهُ لَا يُقْصَدُ بِاسْتِعْمَالِهَا إِلَّا الْقَتْلُ. (616) لِلْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ.

(617) أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِي السَّنَنِ الْكُبْرَى 353/6 رَقْم 6972. وَوَجْهُ الاسْتِدْلَالِ أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - جَعَلَ قَتِيلَ السَّوْطِ وَالْعَصَا مُطْلَقًا شِبْهُ عَمْدٍ فَتَخْصِيصُهُ بِهِ بِالصَّغِيرَةِ إِبْطَالٌ لِلْإِطْلَاقِ وَهُوَ لَا يَجُوزُ، وَلِأَنَّ الْعَصَا الْكَبِيرَةَ وَالصَّغِيرَةَ تَسَاوَيَا فِي كَوْنِهِمَا غَيْرَ مَوْضُوعَتَيْنِ لِلْقَتْلِ وَلَا مُسْتَعْمَلَتَيْنِ لَهُ، إِذْ لَا يُمَكِّنُ الاسْتِعْمَالُ عَلَى غُرَّةٍ مِنَ الْمَقْصُودِ قَتْلَهُ، وَبِالْإِسْتِعْمَالِ عَلَى غُرَّةٍ يَحْصُلُ الْقَتْلُ غَالِبًا، وَإِذَا تَسَاوَيَا وَالْقَتْلُ بِالْعَصَا الصَّغِيرَةِ شِبْهُ عَمْدٍ فَكَذَا بِالْكَبِيرَةِ.

(618) أَيِ الْقَدُورِيِّ.

(619) مُوجِبُ الْقَتْلِ شِبْهُ الْعَمْدِ عَلَى الْقَوْلَيْنِ: يَعْني قَوْلَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَوْلَهُمَا

(620) أَيِ الْأَمْرِ الْكَلِيِّ.

(621) رَوَى أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَضَى بِالِدِّيَّةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ، وَالْمَرْوِيُّ عَنْهُ كَالْمَرْوِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأَنَّهُ مِمَّا لَا يُعْرَفُ بِالرَّأْيِ.

صِفَةُ التَّغْلِيظِ مِنْ بَعْدِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى (وَيَتَعَلَّقُ بِهِ حِرْمَانُ الْمِيرَاثِ) ؛ لِأَنَّهُ جَزَاءُ الْقَتْلِ، وَالشُّبْهَةُ تُؤَثِّرُ فِي سُقُوطِ الْقِصَاصِ دُونَ حِرْمَانِ الْمِيرَاثِ، وَمَالِكٌ وَإِنْ أَنْكَرَ مَعْرِفَةَ شُبْهِ الْعَمْدِ فَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا أَسْلَفْنَاهُ. (622)

7- القتل الخطأ وموجبه (623)

الهداية: قَالَ (وَالْخَطَأُ عَلَى نَوْعَيْنِ: خَطَأً فِي الْقَصْدِ، وَهُوَ أَنْ يَرْمِيَ شَخْصًا يَظُنُّهُ صَيِّدًا، فَإِذَا هُوَ آدَمِيٌّ، أَوْ يَظُنُّهُ حَرْبِيًّا فَإِذَا هُوَ مُسْلِمٌ وَخَطَأً فِي الْفِعْلِ، وَهُوَ أَنْ يَرْمِيَ غَرَضًا فَيُصِيبُ آدَمِيًّا، وَمُوجِبُ ذَلِكَ الْكُفَّارَةُ، وَالِدِّيَّةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسْلِمَةً إِلَى أَهْلِهِ} [النساء: 92] الْآيَةِ، وَهِيَ عَلَى عَاقِلَتِهِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ، قَالَ (وَالْخَطَأُ عَلَى نَوْعَيْنِ: خَطَأً فِي الْقَصْدِ، وَهُوَ أَنْ يَرْمِيَ شَخْصًا يَظُنُّهُ صَيِّدًا، فَإِذَا هُوَ آدَمِيٌّ، أَوْ يَظُنُّهُ حَرْبِيًّا فَإِذَا هُوَ مُسْلِمٌ وَخَطَأً فِي الْفِعْلِ، وَهُوَ أَنْ يَرْمِيَ غَرَضًا فَيُصِيبُ آدَمِيًّا، وَمُوجِبُ ذَلِكَ الْكُفَّارَةُ، وَالِدِّيَّةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسْلِمَةً إِلَى أَهْلِهِ} [النساء: 92] الْآيَةِ، وَهِيَ عَلَى عَاقِلَتِهِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ، لِمَا بَيَّنَّاهُ (وَلَا إِثْمَ فِيهِ) يَعْنِي فِي الْوَجْهَيْنِ (624) قَالُوا: الْمُرَادُ إِثْمُ الْقَتْلِ، فَأَمَّا فِي نَفْسِهِ فَلَا يَعْرِى عَنِ الْإِثْمِ مِنْ حَيْثُ تَرَكَ الْعَزِيمَةَ وَالْمُبَالَغَةَ فِي التَّنَبُّتِ فِي حَالِ الرَّمْيِ، إِذْ شَرَعُ الْكُفَّارَةُ يُؤْذِنُ بِاعْتِبَارِ هَذَا الْمَعْنَى (وَيُحْرَمُ عَنِ الْمِيرَاثِ) ؛ لِأَنَّ فِيهِ إِثْمًا فَيَصِحُّ تَغْلِيْقُ الْحَرَمَانِ بِهِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا تَعَمَّدَ الضَّرْبَ مَوْضِعًا مِنْ جَسَدِهِ فَأَخْطَأَ فَأَصَابَ مَوْضِعًا آخَرَ فَمَاتَ حَيْثُ يَجِبُ الْقِصَاصُ؛ لِأَنَّ الْقَتْلَ قَدْ وَجَدَ بِالْقَصْدِ إِلَى بَعْضِ بَدَنِهِ، وَجَمِيعُ الْبَدَنِ كَالْمَحَلِّ الْوَاحِدِ

(622) قوله " فَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا أَسْلَفْنَاهُ": قيل: أراد قوله عليه السلام: "ألا إن قَتِيلَ خَطَأَ الْعَمْدِ قَتِيلُ السُّوْطِ وَالْعَصَا" الحديث، ولكن المعهود من المصنف في مثله أنه يقول ما رويناه، والحق أن يقال : إنما قال : ما أسلفنا نظرا إلى الحديث والمعنى المعقول.

(623) ما المقصود بالقتل الخطأ؟، وما أنواعه؟ وهل يَأْتُمُ الْقَاتِلُ خَطَأً؟، وما موجبه؟.

(624) لا يَأْتُمُ الْقَاتِلُ خَطَأً فِي النُّوعَيْنِ، لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « إِنْ اللَّهُ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنَّسِيَانَ، وَمَا اسْتَكْرَهَا عَلَيْهِ » أخرجه ابن ماجه في سننه 659/1 رقم 2043.

8-حكم القتل الذي جرى مجرى الخطأ وموجبه

الهداية: قَالَ (وَمَا أُجْرِي مَجْرَى الْخَطَا مِثْلُ النَّائِمِ يَنْقَلِبُ عَلَى رَجُلٍ فَيَقْتُلُهُ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْخَطَا فِي الشَّرْعِ)، (625)

8-حكم القتل بسبب، وموجبه (626)

الهداية: وَأَمَّا الْقَتْلُ بِسَبَبٍ كَحَافِرِ الْبُئْرِ وَوَاضِعِ الْحَجَرِ فِي غَيْرِ مَلِكِهِ، وَمُوجِبُهُ إِذَا تَلَفَ فِيهِ أَدَمِي الدِّيَّةَ عَلَى الْعَاقِلَةِ ؛ لِأَنَّهُ سَبَبُ التَّلَفِ وَهُوَ مُتَعَدٍّ فِيهِ فَأَنْزَلَ مَوْقِعًا دَافِعًا فَوَجَبَتْ الدِّيَّةُ (وَلَا كَفَّارَةٌ فِيهِ وَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ جُرْمَانُ الْمِيرَاثِ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُلْحَقُ بِالْخَطَا فِي أَحْكَامِهِ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ أَنْزَلَهُ قَاتِلًا. وَلَنَا أَنَّ الْقَتْلَ مَعْدُومٌ مِنْهُ حَقِيقَةٌ فَأُلْحِقَ بِهِ فِي حَقِّ الضَّمَانِ فَبَقِيَ فِي حَقِّ غَيْرِهِ عَلَى الْأَصْلِ، وَهُوَ إِنْ كَانَ يَأْتُمُّ بِالْحَفْرِ فِي غَيْرِ مَلِكِهِ لَا يَأْتُمُّ بِالْمَوْتِ عَلَى مَا قَالُوا، وَهَذِهِ كَفَّارَةُ ذَنْبِ الْقَتْلِ وَكَذَا الْجُرْمَانُ بِسَبَبِهِ (وَمَا يَكُونُ شَبَهُ عَمْدٍ فِي النَّفْسِ فَهُوَ عَمْدٌ فِيمَا سِوَاهَا) ؛ لِأَنَّ إِتْلَافَ النَّفْسِ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ آلَةِ، وَمَا دُونَهَا لَا يَخْتَصُّ إِتْلَافُهُ بِآلَةٍ دُونَ آلَةٍ. (627)

8-مَا يُوجِبُ الْقِصَاصَ وَمَا لَا يُوجِبُهُ

الهداية: قَالَ (الْقِصَاصُ وَاجِبٌ بِقَتْلِ كُلِّ مُحَقُّونِ الدَّمِ عَلَى التَّأْيِيدِ إِذَا قَتَلَ عَمْدًا) أَمَّا الْعَمْدِيَّةُ

(625)المقصود بالقتل الذي جرى مجرى الخطأ، هو أنه لم يقصد الفعل أو الشخص لكنه انقلب عليه فقتله.

وحكمه: حكم القتل الخطأ من وجوب الكفارة والدية على العاقلة مخففة في ثلاث سنين.

(626)المقصود بالقتل بسبب: أن يتسبب إنسان بحفر بئر أو وضع حجر في غير ملكه فيقتل شخصا.

موجب القتل بسبب: الدية على العاقلة، ؛ لِأَنَّهُ سَبَبُ التَّلَفِ وَهُوَ مُتَعَدٍّ فِيهِ فَأَنْزَلَ مَوْقِعًا دَافِعًا فَوَجَبَتْ الدِّيَّةُ.

(627)اختلف الفقهاء في وجوب الكفارة على القتل بسبب على قولين: القول الأول: ذهب الحنفية إلى أنه لا تجب بالقتل بسبب الكفارة أو الحرمان من الميراث. القول الثاني: ذهب الشافعية إلى أن القتل بسبب يلحق بالقتل الخطأ في أحكامه، ومنها وجوب الكفارة والحرمان من الميراث، لِأَنَّ الشَّرْعَ أَنْزَلَهُ قَاتِلًا فيضمن.

واستدل الحنفية على أن القتل بسبب لا يوجب كفارة أو الحرمان من الميراث، لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ تَجِبُ بِالْقَتْلِ وَهُوَ مَعْدُومٌ مِنْهُ حَقِيقَةٌ لِعَدَمِ اتِّصَالِ فِعْلِهِ بِهِ، وَإِنَّمَا أُلْحِقَ بِهِ فِي حَقِّ الضَّمَانِ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ صِيَانَةً لِلدَّمَاءِ عَنِ الْهَدَرِ فَيَبْقَى فِي حَقِّ غَيْرِهِ عَلَى الْأَصْلِ. فَإِنْ قِيلَ: الْحَافِرُ فِي غَيْرِ مَلِكِهِ يَأْتُمُّ وَمَا فِيهِ إِثْمٌ مِنَ الْقَتْلِ يَصِحُّ تَغْلِيْقُ الْجُرْمَانِ بِهِ كَمَا ذَكَرْتُمْ فِي الْخَطَا.

فَلَمَّا بَيَّنَّاهُ، وَأَمَّا حَقُّ الدِّمِّ عَلَى التَّائِبِ فَلِنَتَنَبَّيْ شُبْهَةَ الْإِبَاحَةِ وَتَتَحَقَّقَ الْمُسَاوَاةُ(628)

9- حكم قتل المسلم الذمي(629)

الهداية: قَالَ (وَالْمُسْلِمُ بِالذِّمِّيِّ) خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ. لَهُ قَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ» (630) وَلِأَنَّهُ لَا مُسَاوَاةَ بَيْنَهُمَا وَقَتَ الْجَنَائَةِ، وَكَذَا الْكُفْرُ مُبِيحٌ فَيُورِثُ الشُّبْهَةَ،

(628) لما فرغ من بيان أقسام القتل وكان من جملة العمد: وهو قد يوجب القصاص، وقد لا يوجبه، احتاج إلى التفصيل ذلك في باب على حدة. مَا يُوجِبُ الْقَصَاصَ وَمَا لَا يُوجِبُهُ: فَالْقَصَاصُ وَاجِبٌ بِشُرُوطٍ وَمِنْهَا: أَنْ يَكُونَ الْمَقْتُولُ مُحَقَّنٌ الدِّمِّ عَلَى التَّائِبِ، وَأَنْ يَكُونَ الْقَتْلُ عَمْدًا. هَذِهِ ضَابِطَةٌ كُلِّيَّةٌ لِمَعْرِفَةِ مَنْ يَجِبُ لَهُ الْقَصَاصُ، وَحَقُّ الدِّمِّ مَنَعُهُ أَنْ يَسْفِكَ. (629) اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - فِي ثُبُوتِ اقْتِصَاصِ الْمُسْلِمِ بِالذِّمِّيِّ، إِلَى قَوْلَيْنِ: الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: ذَهَبَ عَامَّةُ الْعُلَمَاءِ إِلَى عَدَمِ اقْتِصَاصِ الْمُسْلِمِ مِنَ الذِّمِّيِّ. الْقَوْلُ الثَّانِي: ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - إِلَى ثُبُوتِهِ وَهُوَ مَذْهَبُ النَّخَعِيِّ وَالشَّعْبِيِّ. اسْتَدَلَّ الْأَوَّلُونَ بِمَا رَوَى أَبُو حَنِيفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: هَلْ عِنْدَكُمْ كِتَابٌ؟ قَالَ: " لَا، إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ، أَوْ فَهْمٌ أُعْطِيَهِ رَجُلٌ مُسْلِمٌ، أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ. قَالَ: قُلْتُ: فَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ، وَفَكَائِكَ الْأَسِيرِ، وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ » أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ 33/1 رَقْم 111. . وَبِأَنَّ الْقَصَاصَ يَعْتَمِدُ الْمُسَاوَاةَ فِي وَقْتِ الْجَنَائَةِ وَلَا مُسَاوَاةَ بَيْنَهُمَا فِيهِ. وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِوَقْتِ الْجَنَائَةِ لِأَنَّ الْقَاتِلَ إِذَا كَانَ ذِمِّيًّا وَقَتَ الْقَتْلِ ثُمَّ أَسْلَمَ فَإِنَّهُ يُقْتَصُّ مِنْهُ بِالْإِجْمَاعِ، وَبِأَنَّ الْكُفْرَ مُبِيحٌ لَدِمِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ} [البقرة: 193] أَيْ فِتْنَةُ الْكُفْرِ فَيُورِثُ شُبْهَةَ عَدَمِ الْمُسَاوَاةِ.

واستدل الحنفية إلى ثبوت القصاص من المسلم لو قتل ذميًّا بما رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ «أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الدِّمَةِ فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: أَنَا أَحَقُّ مَنْ وَفَى بِذِمَّتِهِ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ» أَخْرَجَهُ مُسْنَدُ الْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ رَوَايَةُ أَبِي نَعِيمٍ ص 104، وَرَفَعَهُ الدَّرَاقُطْنِيُّ فِي سَنَنِهِ 157/4 رَقْم 3260 بَلْفُظٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَقَادَ مُسْلِمًا قَتَلَ يَهُودِيًّا». وَقَالَ الرَّمَادِيُّ: أَقَادَ مُسْلِمًا بِذِمِّيٍّ، وَقَالَ: «أَنَا أَحَقُّ مَنْ وَفَى بِذِمَّتِهِ».، وَفِي دَلَالَتِهِ عَلَى الْمَطْلُوبِ جَلَاءٌ لَا يُمَارَى. وَرَدَّ بِأَنَّ مَذَاهِبَهُ عَلَى ابْنِ السَّلْمَانِيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ. قَالَ صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَافِظُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - ابْنُ السَّلْمَانِيِّ حَدِيثُهُ مُنْكَرٌ، رُوِيَ عَنْهُ رَبِيعَةُ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَتَلَ مُسْلِمًا بِمُعَاهِدٍ» أَخْرَجَهُ الدَّرَاقُطْنِيُّ فِي سَنَنِهِ 156/4 رَقْم 3259. وَهُوَ مُرْسَلٌ مُنْكَرٌ. وَقَالَ الدَّرَاقُطْنِيُّ: ابْنُ السَّلْمَانِيِّ لَا يَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ إِذَا وَصَلَ فَكَيْفَ إِذَا أُرْسِلَ.

وَالْجَوَابُ أَنَّ الطَّعْنَ بِالْإِرْسَالِ وَالطَّعْنَ الْمُبْهَمُ مِنْ أَيْمَةِ الْحَدِيثِ غَيْرُ مَقْبُولٍ، وَقَدْ عُرِفَ فِي الْأَصُولِ

وَأَمَّا الْمَعْقُولُ فَلِأَنَّ الْقَصَاصَ يَعْتَمِدُ الْمُسَاوَاةَ فِي الْعِصْمَةِ وَهِيَ ثَابِتَةٌ نَظَرًا إِلَى التَّكْلِيفِ عِنْدَهُ أَوْ الدَّارِ عِنْدَنَا فَيُثَبَّتُ. وَالْمَخْتَارُ أَنَّهُ يَقْتُلُ الْمُسْلِمَ بِالذِّمِّيِّ

(630) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي سَنَنِهِ 77/3 رَقْم 1412، وَقَالَ: "حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ" ..

وَلَنَا مَا رُوِيَ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَتَلَ مُسْلِمًا بِذِمِّيٍّ» (631) وَلِأَنَّ الْمُسَاوَاةَ فِي الْعِصْمَةِ ثَابِتَةٌ نَظْرًا إِلَى التَّكْلِيفِ وَالِدَّارِ وَالْمُبِيحِ كُفْرُ الْمُحَارِبِ دُونَ الْمُسَالِمِ، وَالْقَتْلُ بِمِثْلِهِ يُؤْذِنُ بَانْتِفَاءِ الشُّبْهَةِ، وَالْمُرَادُ بِمَا رَوَى الْحَرْبِيُّ لِسِيَاقِهِ «وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ» وَالْعَطْفُ لِلْمُغَايِرَةِ

11-حكم قتل المسلم بالمستأمن والذمي بالمستأمن والمستأمن بالمستأمن:
الهداية: قَالَ (وَلَا يُقْتَلُ بِالْمُسْتَأْمَنِ) (632)؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَحْفُوفِ الدِّمِّ عَلَى التَّأْيِيدِ، وَكَذَلِكَ كُفْرُهُ بَاعِثٌ عَلَى الْحِرَابِ؛ لِأَنَّهُ عَلَى قَصْدِ الرَّجُوعِ. (وَلَا يُقْتَلُ الذِّمِّيُّ بِالْمُسْتَأْمَنِ) (633) لِمَا بَيَّنَّا، (وَيُقْتَلُ الْمُسْتَأْمَنُ بِالْمُسْتَأْمَنِ) (634) قِيَاسًا لِلْمُسَاوَاةِ، وَلَا يُقْتَلُ اسْتِحْسَانًا لِقِيَامِ الْمُبِيحِ (635)

(631) قال ابن حجر في: الدراية في تخريج أحاديث الهداية 262/2 رقم 1008: "حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَ مُسْلِمًا بِذِمِّيٍّ الدَّارِ قُطْنِيٍّ مِنْ طَرِيقِ رِبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التُّيْلَمَانِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَ مُسْلِمًا بِمَعَاهِدٍ وَقَالَ أَنَا أَكْرَمُ مِنْ وَفِي بِذِمَّتِهِ؟".
(632) المستأمن، هو من دخل بلادنا دخولا قانونيا، من خلال تأشيرة الدخول من خلال الأجهزة المختصة.

(633) اختلف الفقهاء في قتل الذمي بالمستأمن على قولين: القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه إِذَا ارْتَكَبَ الذِّمِّيُّ الْقَتْلَ الْعَمْدَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ ، إِذَا كَانَ الْقَتِيلُ مُسْلِمًا أَوْ مِنْ أَهْلِ الدِّمَةِ بِلا خِلَافٍ ، وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ الْقَتِيلُ مُسْتَأْمَنًا.

القول الثاني: ذهب ابو حنيفة إلى أنه لَا يُقْتَلُ الذِّمِّيُّ بِالْمُسْتَأْمَنِ لِأَنَّ الْمُسْتَأْمَنَ لَيْسَ مَحْفُوفَ الدِّمِّ عَلَى التَّأْيِيدِ، فَكَانَ فِي حَقِّ دَمِهِ شُبْهَةٌ تُسْقِطُ الْقِصَاصَ ؛ وَلِأَنَّ الذِّمِّيَّ مُحَرَّرَ نَفْسِهِ بَدَارِنَا عَلَى التَّأْيِيدِ فَلَا تَتَحَقَّقُ الْمُسَاوَاةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُسْتَأْمَنِ. يراجع : العناية شرح الهداية 220/10.

(634) هل يقتص من المستأمن إذا قتل مستأمنًا؟.

(635) للحنفية في قتل المسلم بالمستأمن قولان: القول الأول: ذهب الحنفية في ظاهر الرواية إلى أنه لَا قِصَاصَ عَلَى مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ بِقَتْلِ مُسْتَأْمَنٍ ، لِأَنَّهُمْ اشْتَرَطُوا فِي الْقِصَاصِ أَنْ يَكُونَ الْمَقْتُولُ فِي حَقِّ الْقَاتِلِ مُحْفُوفَ الدِّمِّ عَلَى التَّأْيِيدِ ، وَالْمُسْتَأْمَنُ عِصْمَتُهُ مُؤَقَّتَةٌ ، لِأَنَّهُ مَصُونُ الدِّمِّ فِي حَالِ أَمَانِهِ فَقَطْ ، وَلِأَنَّهُ مِنْ دَارِ أَهْلِ الْحَرْبِ حَكْمًا ؛ لِقَصْدِهِ الْإِنْتِقَالَ إِلَيْهَا ، فَلَا يُمْكِنُ الْمُسَاوَاةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ دَارِنَا فِي الْعِصْمَةِ ، وَالْقِصَاصِ يَعْتَمِدُ الْمُسَاوَاةُ ، وَلَكِنْ عَلَيْهِ دِيَةٌ. يراجع: بدائع الصنائع 236 / 7 ، وحاشية ابن عابدين 343 / 5 ، 249 / 3 ، وفتح القدير 357 / 4 .

القول الثاني: وروى عن أبي يوسف أنه يقتل المسلم بالمستأمن يراجع: بدائع الصنائع 231 / 7 ، واستدل بقوله تعالى : {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ} سورة التوبة / 6 . والمختار أنه بدخول المستأمن إلى بلادنا تنطبق عليه احكام المواطنين، ومن ثم يقتص من قاتله، لأننا مأمورون بعدم الغدر

13-حكم قتل الرجل بالمرأة والكبير بالصغير والصحيح بالأعمى.

الهداية: (وَيُقْتَلُ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ، وَالْكَبِيرُ بِالصَّغِيرِ، وَالصَّحِيحُ بِالْأَعْمَى وَالزَّمَنُ (636) وَبِنَاقِصِ الْأَطْرَافِ وَبِالْمَجْنُونِ) لِلْعُمُومَاتِ، وَلِأَنَّ فِي اعْتِبَارِ النَّفَاوَتِ فِيمَا وَرَاءَ الْعِصْمَةِ (637) امْتِنَاعَ الْقِصَاصِ (638) وَظُهُورَ التَّقَاتِلِ وَالتَّفَانِي.

14-قتل الرجل بابنه

الهداية: قَالَ (وَلَا يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِابْنِهِ) لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ» (639) وَهُوَ بِإِطْلَاقِهِ حُجَّةٌ عَلَى مَالِكٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي قَوْلِهِ يُقَادُ إِذَا ذَبَحَهُ ذَبْحًا، وَلِأَنَّهُ سَبَبٌ لِإِحْيَائِهِ، فَمِنْ الْمُحَالِ أَنْ يُسْتَحَقَّ لَهُ إِفْنَاؤُهُ وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ لَهُ قَتْلُهُ، وَإِنْ وَجَدَهُ فِي صَفِّ الْأَعْدَاءِ مُقَاتِلًا أَوْ زَانِيًا وَهُوَ مُحَصَّنٌ، وَالْقِصَاصُ يَسْتَحِقُّهُ الْمَقْتُولُ ثُمَّ يَخْلُفُهُ وَارِثُهُ، وَالْجَدُّ مِنْ قَبْلِ الرَّجَالِ أَوْ النِّسَاءِ، وَإِنْ عَلَا فِي هَذَا بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ، وَكَذَا الْوَالِدَةُ وَالْجَدَّةُ مِنْ قَبْلِ الْأَبِ أَوْ الْأُمِّ قَرِبَتْ أَوْ بَعُدَتْ لِمَا بَيَّنَّا، وَيُقْتَلُ الْوَلَدُ بِالْوَالِدِ لِعَدَمِ الْمُسْقِطِ.

15-ورث قِصاصًا على أبيه

الهداية: قَالَ (وَمَنْ وَرِثَ قِصَاصًا عَلَى أَبِيهِ سَقَطَ) لِحُرْمَةِ الْأَبُوَّةِ قَالَ (وَلَا يُسْتَوْفَى الْقِصَاصُ إِلَّا بِالسَّيْفِ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُفْعَلُ بِهِ مِثْلُ مَا فَعَلَ إِنْ كَانَ فِعْلًا مَشْرُوعًا، فَإِنْ مَاتَ وَإِلَّا تُحْزَرَ رَقَبَتُهُ؛ لِأَنَّ مَبْنَى الْقِصَاصِ عَلَى الْمُسَاوَاةِ وَلَنَا قَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «لَا قَوْدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ» (640) وَالْمُرَادُ بِهِ السَّلَاحُ، وَلِأَنَّ فِيمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ اسْتِيفَاءُ الزِّيَادَةِ لَوْ لَمْ يَحْصُلِ الْمَقْصُودُ بِمِثْلِ مَا فَعَلَ فَيَحْزَرُ فَيَجِبُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ كَمَا فِي كَسْرِ الْعَظَمِ.

(636) هو من طال مرضه زماناً.

(637) أي عصمة الدم.

(638) فإنه لا بد بين كل اثنين من تفاوت، فلا يتحقق التساوي.

(639) أخرجه الدراقطني في سننه 168/4 رقم 3277.

(640) أخرجه ابن ماجه في سننه 889/2 رقم 2667.

16- قُتِلَ وَلَهُ أَوْلِيَاءُ صِغَارٌ وَكِبَارٌ (641)

الهداية: قَالَ (وَمَنْ قُتِلَ وَلَهُ أَوْلِيَاءُ صِغَارٌ وَكِبَارٌ) (642) فَلِلْكَبَارِ أَنْ يَقْتُلُوا الْقَاتِلَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ حَتَّى يُدْرِكَ الصَّغَارُ) ؛ لِأَنَّ الْقِصَاصَ مُشْتَرِكٌ بَيْنَهُمْ وَلَا يُمَكِّنُ اسْتِيفَاءُ الْبَعْضِ (643) لِعَدَمِ التَّجَزِّي، وَفِي اسْتِيفَائِهِمُ الْكُلَّ (644) إِبْطَالُ حَقِّ الصَّغَارِ فَيُؤَخَّرُ إِلَى إِدْرَاكِهِمْ كَمَا إِذَا كَانَ بَيْنَ الْكَبِيرَيْنِ وَأَحَدُهُمَا غَائِبٌ أَوْ كَانَ بَيْنَ الْمَوْلَيْنِ (645)، وَلَهُ أَنَّهُ حَقٌّ (646) لَا يَتَجَزَّأُ لِثُبُوتِهِ بِسَبَبٍ لَا يَتَجَزَّأُ وَهُوَ الْقَرَابَةُ، وَاحْتِمَالُ الْعَفْوِ مِنَ الصَّغِيرِ مُنْقَطِعٌ فَيُثَبِّتُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَمَلًا كَمَا فِي وَلَايَةِ الْإِنْكَاحِ، بِخِلَافِ الْكَبِيرَيْنِ؛ لِأَنَّ احْتِمَالَ الْعَفْوِ مِنَ الْعَائِبِ ثَابِتٌ وَمَسْأَلَةُ الْمَوْلَيْنِ مَمْنُوعَةٌ (647)

17- ضرب رجل بمر فقتله

الهداية : قَالَ (وَمَنْ ضَرَبَ رَجُلًا بِمَرٍّ) (648) فَقَتَلَهُ، فَإِنْ أَصَابَهُ بِالْحَدِيدِ قُتِلَ بِهِ وَإِنْ أَصَابَهُ بِالْعُودِ فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ) قَالَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - (649): وَهَذَا إِذَا أَصَابَهُ بِحَدِّ الْحَدِيدِ لَوْجُودِ الْجُرْحِ

(641) حكم من قُتِلَ وَلَهُ أَوْلِيَاءُ صِغَارٌ وَكِبَارٌ، فهل يقتص الكبار أم ينتظر حتى يدرك الصغار؟
إِذَا كَانَ أَوْلِيَاءُ الْقَتِيلِ صِغَارًا وَكِبَارًا، فَمَا أُنْ يَكُونُ فِيهِمُ الْأَبُ أَوْ لَا، فَإِنْ كَانَ فِيهِمُ الْأَبُ فَلَهُمُ الْإِسْتِيفَاءُ عِنْدَ عُلَمَائِنَا - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - بِالِاتِّفَاقِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْأَبُ فِيهِمْ فَقَدْ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ عَلَى قَوْلَيْنِ: الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: لِأَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّ لَهُمُ الْإِسْتِيفَاءُ.
الْقَوْلُ الثَّانِي: ذَهَبَ الصَّاحِبَانِ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ حَتَّى يُدْرِكَ الصَّغَارُ وَوَجْهُهُمَا ظَاهِرٌ عَلَى مَا ذَكَرَ. وَوَجْهُ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مَبْنِيٌّ عَلَى ثُبُوتِ التَّفَرُّقَةِ بَيْنَ الصَّغَارِ وَالْغَائِبِ مِنْ حَيْثُ احْتِمَالُ الْعَفْوِ فِي الْحَالِ وَعَدَمِهِ، فَإِنَّهُ فِي الْعَائِبِ مَوْهُومٌ فَالِإِسْتِيفَاءُ يَقَعُ مَعَ الشُّبْهَةِ وَهُوَ لَا يَجُوزُ، وَفِي الصَّغِيرِ مَا يُؤَسِّسُ حَالَ الْإِسْتِيفَاءِ فَانْتَقَى الشُّبْهَةَ، وَإِذَا انْتَقَى الشُّبْهَةَ وَهُوَ حَقٌّ لَا يَتَجَزَّى لِثُبُوتِهِ بِسَبَبٍ لَا يَتَجَزَّأُ وَهُوَ الْقَرَابَةُ يَثْبُتُ لِكُلِّ وَاحِدٍ كَمَلًا كَالْوَلَايَةِ فِي الْإِنْكَاحِ.
(642) بَأَنَّ كَانَ لِلْمَقْتُولِ أَخَوَانِ: أَحَدُهُمَا صَغِيرٌ وَالْآخَرُ كَبِيرٌ.

(643) أي بعض القصاص.

(644) أي كل القصاص.

(645) صورته: فيما إذا كان العبد مشتركاً بين الكبير والصغير، فقتل العبد، ليس للكبير ولاية استيفاء القصاص قبل أن يدرك الصغير بالاتفاق.

(646) أي أن حق القصاص.

(647) قوله: "ممنوعة": في فوائد مولانا حميد الدين عبد بين مولييين، وأحدهما صغير، قتل عمداً، قال بعض مشايخنا: عند أبي حنيفة له ولاية استيفاء القصاص.

(648) مرّ: بفتح الميم وتشديد الراء: هو الذي يعمل به في الطين. ينظر: المغرب للمطرزي ص 439. وقال العيني: المر-بفتح الميم وتشديد الراء- وهو خشبة طويلة في رأسها حديدة عريضة من فوقها خشبة عريضة، يضع الرجل رجله عليها ويحفر بها الأرض.

فَكَمَلَ السَّبَبُ، وَإِنْ أَصَابَهُ بِظَهْرِ الْحَدِيدِ فَعِنْدَهُمَا يَجِبُ (650)، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ
اعْتِبَارًا مِنْهُ لِلْأَلَةِ (651)، وَهُوَ الْحَدِيدُ (652)

وَعَنْهُ إِنَّمَا يَجِبُ إِذَا جَرَحَ، (653) وَهُوَ الْأَصَحُّ عَلَى مَا نُبَيِّنُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَعَلَى هَذَا
الضَّرْبِ (654) بِسِنَجَاتِ الْمِيزَانِ؛ وَأَمَّا إِذَا ضَرَبَهُ بِالْعُودِ (655) فَإِنَّمَا تَجِبُ الدِّيَّةُ لَوْجُودِ قَتْلِ
النَّفْسِ الْمَعْصُومَةِ وَامْتِنَاعِ الْقِصَاصِ حَتَّى لَا يُهْدَرَ الدَّمُ، ثُمَّ قِيلَ: هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْعَصَا الْكَبِيرَةِ
فَيَكُونُ قَتْلًا بِالْمَقْتَلِ (656)، وَفِيهِ خِلَافٌ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَى مَا نُبَيِّنُ، وَقِيلَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ السَّوْطِ،
وَفِيهِ خِلَافٌ الشَّافِعِيِّ وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْمُوَالَاةِ

لَهُ أَنَّ الْمُوَالَاةَ فِي الضَّرَبَاتِ إِلَى أَنْ مَاتَ دَلِيلُ الْعَمْدِيَّةِ فَيَتَحَقَّقُ الْمُوجِبُ
وَلَنَا مَا رَوَيْنَا «أَلَا إِنَّ قَتِيلَ خَطَا الْعَمْدِ» وَيُرْوَى "شَبَهُ الْعَمْدِ" الْحَدِيثَ وَلَآنَ فِيهِ شُبُهَةٌ عَدَمِ
الْعَمْدِيَّةِ؛ لِأَنَّ الْمُوَالَاةَ قَدْ تُسْتَعْمَلُ لِلتَّأْدِيبِ أَوْ لَعَلَّهُ اعْتَرَاهُ الْقَصْدُ فِي خِلَالِ الضَّرَبَاتِ فَيَعْرِى
أَوَّلُ الْفِعْلِ عَنْهُ وَعَسَاهُ أَصَابَ الْمَقْتَلِ، وَالشُّبُهَةُ دَارِئَةٌ لِلْقَوْدِ فَوَجِبَ الدِّيَّةُ

18- مَنْ غَرَّقَ صَبِيًّا أَوْ بَالِغًا فِي الْبَحْرِ

الهداية: قَالَ (657) (وَمَنْ غَرَّقَ صَبِيًّا أَوْ بَالِغًا فِي الْبَحْرِ فَلَا قِصَاصَ) عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَالَ:
يُقْتَصُّ مِنْهُ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، غَيْرَ أَنَّ عِنْدَهُمَا يُسْتَوْفَى حَزًّا وَعِنْدَهُ يُغَرَّقُ كَمَا بَيَّنَّاهُ مِنْ
قَبْلُ (658)

(649) أي المصنف

(650) القصاص.

(651) قوله: "اعتباراً منه للألة وهو الحديد" لأن الحديد معد لذلك في الدنيا والآخرة، قال تعالى
(وانزلنا الحديد فيه بأس شديد) وهو القتل، وقوله تعالى (ولهم مقامع من حديد).

(652) لأن الحديد سلاح كله.

(653) قوله: "إنما يجب إذا جرح" لأن بدون الجرح لا يتكامل إفساد الظاهر، فلا يستدعي العقوبة
المتناهية.

(654) أي على هذا الخلاف.

(655) بعود المر.

(656) يكون شبه عمد.

(657) أي محمد في الجامع الصغير.

(658) قوله: "كما بيناه" في أوائل هذا الباب: إشارة إلى قوله: يفعل به كما فعل إن كان فعلاً
مشروعاً.

لَهُمْ قَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «مَنْ غَرَّقَ غَرَقْنَاهُ» (659) وَلِأَنَّ الْأَلَةَ (660) قَاتِلَةٌ فَاسْتَعْمَلَهَا أَمَارَةُ الْعَمْدِيَّةِ، وَلَا مِرَاءَ فِي الْعِصْمَةِ (661) وَلَهُ قَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «أَلَا إِنَّ قَتِيلَ خَطَا الْعَمْدِ» (662) قَتِيلُ السَّوْطِ وَالْعَصَا» (663) وَفِيهِ «وَفِي كُلِّ خَطَا أَرَشُ» (664) ؛ لِأَنَّ الْأَلَةَ غَيْرُ مُعَدَّةٍ لِلْقَتْلِ، وَلَا مُسْتَعْمَلَةٌ فِيهِ لِتَعَذُّرِ اسْتِعْمَالِهِ فَتَمَكَّنَتْ شُبُهَةٌ عَدَمِ الْعَمْدِيَّةِ وَلِأَنَّ الْقِصَاصَ يُنْبِئُ عَنِ الْمُمَاتِلَةِ، وَمِنْهُ يُقَالُ: اقْتَصَّ أَثَرُهُ، وَمِنْهُ الْقُصَّةُ لِلْجَلَمَيْنِ (665)، وَلَا تَمَاتِلَ بَيْنَ الْجَرْحِ وَالْدَقِّ لِقُصُورِ الثَّانِي عَنْ تَخْرِيبِ الظَّاهِرِ، وَكَذَا لَا يَتَمَاتِلَانِ فِي حِكْمَةِ الزَّجْرِ؛ لِأَنَّ الْقَتْلَ بِالسَّلَاحِ غَالِبٌ وَبِالْمُنْقَلِ نَادِرٌ، وَمَا رَوَاهُ (666) غَيْرُ مَرْفُوعٍ (667) أَوْ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى السِّيَاسَةِ، وَقَدْ أُوْمِتَ إِلَيْهِ (668) إِضَافَتُهُ إِلَى نَفْسِهِ فِيهِ (669)، وَإِذَا امْتَنَعَ الْقِصَاصُ وَجَبَتْ الدِّيَّةُ، وَهِيَ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ (670) وَاخْتِلَافُ الرَّاوَيْتَيْنِ (671) فِي الْكُفَّارَةِ.

19- جَرَحَ رَجُلًا عَمْدًا فَلَمْ يَزَلْ صَاحِبَ فِرَاشٍ حَتَّى مَاتَ

(659) قال ابن حجر العسقلاني في الدراية في تخريج أحاديث الهداية 266/2 رقم 1012: "حديث من غرق غرقناه النبيهقي من رواية عمران بن يزيد بن البراء عن أبيه عن جده بهذا وفيه ومن حرق حرقناه ومن عرض عرضنا له وفي إسناداه من لا يعرف" (660) أي ماء البحر . (661) أي عصمة المقتول. (662) أي شبه العمد. (663) أخرجه الدارقطني في سننه 100/4 رقم 3168. (664) أخرجه الدارقطني في سننه 1050/4 رقم 3176. (665) الْجَلْمُ : الَّذِي يُجْزُ بِهِ الشَّعْرُ وَالصُّوفُ، وَالْجَلْمَانِ شَفَرَتَاهُ، وَهَكَذَا يُقَالُ مُتَنَّى كَالْمَقْصِّ وَالْمَقْصَيْنِ. وَالْجَلْمُ: مُصَدَّرُ جَلَمِ الْجُرُورِ يَجْلِمُهَا جَلْمًا وَاجْتَلَمَهَا إِذَا أَخَذَ مَا عَلَى عِظَامِهَا مِنَ اللَّحْمِ. لسان العرب لابن منظور 102/12. (666) أي الشافعي وهو: "من غرق غرقناه". (667) أي غير متصل إليه عليه الصلاة والسلام، فلا يكون حجة عنده، لأنه لا يرى العمل بالموقوف. (668) أي أشارت إليه ، أي إلى الحمل على السياسة، إضافة النبي صلى الله عليه وسلم فعل التغريق إلى نفسه، حيث قال: غرقناه، ولم يقل من غرق يغرق. (669) أي في الحديث. (670) في أول كتاب الجنايات. (671) أي عن أبي حنيفة إنما كان في الكفارة، فإنه روى أن لا كفارة في شبه العمد، وروى الطحاوي أن فيه الكفارة عنده، وأما الدية، فإنها واجبة عنده من غير تردد.

الهداية : قَالَ (وَمَنْ جَرَحَ رَجُلًا عَمْدًا فَلَمْ يَزَلْ) (672) صَاحِبَ فِرَاشٍ حَتَّى مَاتَ فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ) لُجُودِ السَّبَبِ (673) وَعَدَمَ مَا يُبْطِلُ حُكْمَهُ فِي الظَّاهِرِ فَأُضِيفَ إِلَيْهِ (674).

20- قَتَلَ مُسْلِمٌ مُسْلِمًا ظَنَّ أَنَّهُ مُشْرِكٌ أَثْنَاءَ التَّقَاءِ الصَّفِينِ

الهداية: قَالَ (وَإِذَا التَّقَى الصَّفَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ فَقَتَلَ مُسْلِمٌ مُسْلِمًا ظَنَّ أَنَّهُ مُشْرِكٌ فَلَا قَوْدَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ) ؛ لِأَنَّ هَذَا أَحَدُ نَوْعِي الْخَطَا (675) عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ، (676) وَالْخَطَا بِنَوْعِيهِ لَا يُوجِبُ الْقَوْدَ وَيُوجِبُ الْكَفَّارَةَ، وَكَذَا الدِّيَّةُ عَلَى مَا نَطَقَ بِهِ نَصُّ الْكِتَابِ (677) «وَلَمَّا اخْتَلَفَتْ سُيُوفُ الْمُسْلِمِينَ (678) عَلَى الْيَمَانِ أَبِي حُدَيْفَةَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - بِالْأُتَيْةِ» قَالُوا: إِنَّمَا تَجِبُ الدِّيَّةُ إِذَا كَانُوا (679) مُخْتَلَطِينَ، فَإِنْ كَانَ فِي صَفِّ الْمُشْرِكِينَ لَا تَجِبُ (680) لِسُقُوطِ عِصْمَتِهِ بِتَكْثِيرِ سَوَادِهِمْ قَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «مَنْ كَثُرَ سَوَادُ قَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ» (681)

21-تعدد أسباب الجريمة

الهداية: قَالَ (وَمَنْ شَجَّ نَفْسَهُ وَشَجَّهَ رَجُلٌ وَعَقَرَهُ أَسَدٌ وَأَصَابَتْهُ حَيَّةٌ فَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ فَعَلَى الْأَجْنَبِيِّ ثُلُثُ الدِّيَةِ) ؛ لِأَنَّ فِعْلَ الْأَسَدِ وَالْحَيَّةِ جِنْسٌ وَاحِدٌ لِكُونِهِ هَدْرًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَفِعْلُهُ بِنَفْسِهِ هَدْرٌ فِي الدُّنْيَا مُعْتَبَرٌ فِي الْآخِرَةِ حَتَّى يَأْتِمَ عَلَيْهِ

(672) في أول كتاب الجنايات.

(673) الجرح.

(674) الحكم.

(675) وهو خطأ في القصد.

(676) قبيل باب ما يوجب القصاص وما لا يوجب.

(677) وهو قوله تعالى (ومن قتل مؤنثا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله) @

(678) اختلفت: أي توالى سيوف المسلمين، روى أن سيوف المسلمين توالى على اليمان أبي حذيفة في بعض الليالي في غزو خندقة، فقتلوه على ظن أنه مشرك، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية، فوهبها لهم حذيفة.

(679) كفار ومسلمين.

(680) أي الدية.

(681) أخرجه الزيلعي في نصب الراية 346 / 4.

وَفِي النَّوَادِرِ (682) أَنَّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ يُغَسَّلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يُغَسَّلُ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ

وَفِي شَرْحِ السَّيْرِ الْكَبِيرِ (683) ذَكَرَ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ اخْتِلَافَ الْمَشَايخِ (684) عَلَى مَا كَتَبْنَاهُ فِي كِتَابِ التَّجْنِيسِ وَالْمَزِيدِ فَلَمْ يَكُنْ هَدْرًا مُطْلَقًا (685) وَكَانَ جِنْسًا آخَرَ (686)، وَفِعْلُ الْأَجْنَبِيِّ مُعْتَبَرٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَصَارَتْ ثَلَاثَةُ أَجْنَاسٍ فَكَانَ النَّفْسَ تَلَفَتْ بِثَلَاثَةِ أَفْعَالٍ فَيَكُونُ التَّلَافُ بِفِعْلِ كُلِّ وَاحِدٍ ثَلَاثُهُ فَيَجِبُ عَلَيْهِ ثَلَاثُ الدِّيَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

22- مَنْ شَهَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ سَيْفًا

الهداية: قَالَ (وَمَنْ شَهَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ سَيْفًا فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْتُلُوهُ) لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «مَنْ شَهَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ سَيْفًا فَقَدْ أَطْلَ دَمَهُ» (687) وَلِأَنَّهُ بَاغٍ فَتَسْقُطُ عِصْمَتُهُ بِبَغْيِهِ، وَلِأَنَّهُ تَعَيَّنَ طَرِيقًا لِدَفْعِ الْقَتْلِ عَنْ نَفْسِهِ فَلَهُ قَتْلُهُ

وَقَوْلُهُ فَعَلَيْهِمْ وَقَوْلُ مُحَمَّدٍ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ فَحَقُّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَقْتُلُوهُ إِشَارَةٌ إِلَى الْوُجُوبِ، وَالْمَعْنَى وَجُوبُ دَفْعِ الضَّرَرِ.

23- شَهَرَ الْمَجْنُونُ عَلَى غَيْرِهِ سِلَاحًا فَقَتَلَهُ الْمَشْهُورُ عَلَيْهِ (688)

(682) النواذر، وهي غير ظاهر الرواية؛ لأنها لم تظهر كما ظهرت كتب ظاهر الرواية، ولم تُزَوَّ إلا بطريق الأحاد بين صحيح وضعيف، "كالرَّقِيَّاتِ"، و"الكَيْسَانِيَّاتِ"، و"الْجُزْجَانِيَّاتِ"، و"الْهَارُونِيَّاتِ" من تصانيف محمد التي رواها عنه الأحاد، ولم تبلغ حد التواتر، ولا الشهرة عنه. (683) كتاب "شرح السير الكبير" لمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى: 483هـ).

(684) المراد بالمشايخ: مَنْ لم يدرك الإمام. وذاك بعد وفاة حسن بن زياد اللؤلؤي قرابة 204هـ.

(685) متعلق بقوله هدر في الدنيا معتبر في الآخرة.

(686) من حيث إنه هدر من وجه دون وجه.

(687) قال ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية 267/2 رقم 1015: "حَدِيثٌ مِنْ شَهَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ سَيْفًا فَقَدْ أَطْلَ دَمَهُ لَمْ أَجِدْ بِهِذَا اللَّفْظَ وَفِي النَّسَائِيِّ عَنْ ابْنِ الزَّبِيرِ رَفَعَهُ مِنْ شَهَرَ سَيْفِهِ ثُمَّ وَضَعَهُ فِدْمَهُ هَدْرًا وَأَخْرَجَهُ".

(688) إِنَّ شَهَرَ الْمَجْنُونُ عَلَى غَيْرِهِ سِلَاحًا فَقَتَلَهُ الْمَشْهُورُ عَلَيْهِ عَمْدًا فَقَوْلَانِ لِلْفُقَهَاءِ: الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: ذَهَبَ الْحَنِفِيَّةُ إِلَى أَنَّ عَلَيْهِ الدِّيَةَ فِي مَالِهِ. الْقَوْلُ الثَّانِي: قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ قَتَلَهُ دَافِعًا عَنْ نَفْسِهِ فَيُعْتَبَرُ بِالْبَالِغِ الشَّاهِرِ، وَلِأَنَّهُ يَصِيرُ مَحْمُولًا عَلَى قَتْلِهِ بِفِعْلِهِ فَأَشْبَهَ الْمَكْرَةَ. وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ الصَّبِيُّ وَالْذَّابَّةُ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يَجِبُ الضَّمَانُ فِي الدَّابَّةِ وَلَا يَجِبُ فِي الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ، وَلِأَبِي يُوسُفَ أَنَّ فِعْلَ الدَّابَّةِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ أَصْلًا حَتَّى لَوْ تَحَقَّقَ لَا يُوجِبُ الضَّمَانُ

الهداية: قَالَ (وَإِنْ شَهَرَ الْمَجْنُونُ عَلَى غَيْرِهِ سِلَاحًا فَقَتَلَهُ الْمَشْهُورُ عَلَيْهِ عَمْدًا فَعَلَيْهِ الدِّيَّةُ فِي مَالِهِ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ الصَّبِيُّ وَالْدَّابَّةُ (689)، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يَجِبُ الضَّمَانُ (690) فِي الدَّابَّةِ وَلَا يَجِبُ فِي الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ لِلشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَتَلَهُ دَافِعًا عَنْ نَفْسِهِ فَيُعْتَبَرُ (691) بِالْبَالِغِ الشَّاهِرِ، وَلِأَنَّهُ يَصِيرُ مَحْمُولًا عَلَى قَتْلِهِ بِفَعْلِهِ فَأَشْبَهَ الْمُكَرَّهَ

وَلِأَبِي يُوسُفَ أَنَّ فِعْلَ الدَّابَّةِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ أَصْلًا حَتَّى لَوْ تَحَقَّقَ لَا يُوجِبُ الضَّمَانُ أَمَّا فِعْلُهُمَا مُعْتَبَرٌ فِي الْجُمْلَةِ حَتَّى لَوْ حَقَّقْنَاهُ يَجِبُ عَلَيْهِمَا الضَّمَانُ، وَكَذَا عِصْمَتُهُمَا لِحَقِّهِمَا وَعِصْمَةُ الدَّابَّةِ لِحَقِّ مَالِكِهَا فَكَانَ فِعْلُهُمَا مُسْقِطًا لِلْعِصْمَةِ دُونَ فِعْلِ الدَّابَّةِ، وَلَنَا أَنَّهُ قَتَلَ شَخْصًا مَعْصُومًا (692) أَوْ أَتْلَفَ مَالًا (693) مَعْصُومًا حَقًّا لِلْمَالِكِ وَفِعْلُ الدَّابَّةِ لَا يَصْلُحُ مُسْقِطًا (694) وَكَذَا فِعْلُهُمَا (695)، وَإِنْ كَانَتْ عِصْمَتُهُمَا حَقًّا لِعَدَمِ اخْتِيَارِ صَحِيحٍ وَلِهَذَا لَا يَجِبُ الْقِصَاصُ بِتَحَقُّقِ الْفِعْلِ مِنْهُمَا، بِخِلَافِ الْعَاقِلِ الْبَالِغِ؛ لِأَنَّ لَهُ اخْتِيَارًا صَحِيحًا، وَإِنَّمَا لَا يَجِبُ الْقِصَاصُ لَوْجُودِ الْمُبِيحِ وَهُوَ دَفْعُ الشَّرِّ فَتَجِبُ الدِّيَّةُ.

24- مَنْ شَهَرَ عَلَى غَيْرِهِ سِلَاحًا فِي الْمِصْرِ فَضْرَبَهُ ثُمَّ قَتَلَهُ الْآخَرُ

الهداية: قَالَ (696) (وَمَنْ شَهَرَ عَلَى غَيْرِهِ سِلَاحًا فِي الْمِصْرِ فَضْرَبَهُ ثُمَّ قَتَلَهُ الْآخَرُ فَعَلَى الْقَاتِلِ الْقِصَاصُ) مَعْنَاهُ: إِذَا ضْرَبَهُ فَأَنْصَرَفَ؛ لِأَنَّهُ خَرَجَ مِنْ أَنْ يَكُونَ مُحَارِبًا بِالْإِنْصِرَافِ فَعَادَتْ عِصْمَتُهُ.

أَمَّا فِعْلُهُمَا مُعْتَبَرٌ فِي الْجُمْلَةِ حَتَّى لَوْ حَقَّقْنَاهُ يَجِبُ عَلَيْهِمَا الضَّمَانُ، وَكَذَا عِصْمَتُهُمَا لِحَقِّهِمَا وَعِصْمَةُ الدَّابَّةِ لِحَقِّ مَالِكِهَا فَكَانَ فِعْلُهُمَا مُسْقِطًا لِلْعِصْمَةِ دُونَ فِعْلِ الدَّابَّةِ. وَاسْتَدَلَّ الْحَنَفِيُّ لِقَوْلِهِمْ أَنَّ عَلَيْهِ الدِّيَّةَ فِي مَالِهِ لِأَنَّهُ قَتَلَ شَخْصًا مَعْصُومًا أَوْ أَتْلَفَ مَالًا مَعْصُومًا حَقًّا لِلْمَالِكِ وَفِعْلُ الدَّابَّةِ لَا يَصْلُحُ مُسْقِطًا وَكَذَا فِعْلُهُمَا، وَإِنْ كَانَتْ عِصْمَتُهُمَا حَقًّا لِعَدَمِ اخْتِيَارِ صَحِيحٍ وَلِهَذَا لَا يَجِبُ الْقِصَاصُ بِتَحَقُّقِ الْفِعْلِ مِنْهُمَا، بِخِلَافِ الْعَاقِلِ الْبَالِغِ؛ لِأَنَّ لَهُ اخْتِيَارًا صَحِيحًا، وَإِنَّمَا لَا يَجِبُ الْقِصَاصُ لَوْجُودِ الْمُبِيحِ وَهُوَ دَفْعُ الشَّرِّ فَتَجِبُ الدِّيَّةُ. (689) يَعْنِي إِذَا صَالَا عَلَى إِنْسَانٍ، فَقَتَلَهُ الْمَصُولُ عَلَيْهِ عَمْدًا يَضْمَنُ الدِّيَّةَ وَالْقِيَمَةَ. (690) أَيِ الْقِيَمَةِ.

(691) الصبي والمجنون والدابة.

(692) وهو الصبي والمجنون.

(693) الدابة.

(694) أي للعصمة.

(695) أي فعل الصبي والمجنون لا يصلح مسقطا للعصمة.

(696) أي محمد

25- مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ لَيْلًا وَأَخْرَجَ السَّرِقَةَ فَاتَّبَعَهُ وَقَتَّلَهُ

قَالَ (وَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ لَيْلًا وَأَخْرَجَ السَّرِقَةَ فَاتَّبَعَهُ وَقَتَّلَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ) (697) لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «قَاتِلْ دُونَ مَالِكَ» (698) وَلِأَنَّهُ يُبَاحُ لَهُ الْقَتْلُ دَفْعًا فِي الْإِبْتِدَاءِ فَكَذَا اسْتَرْدَادًا فِي الْإِنْتِهَاءِ (699)، وَتَأْوِيلُ الْمَسْأَلَةِ إِذَا كَانَ لَا يَتِمَّكُنُ مِنَ الْإِسْتِرْدَادِ إِلَّا بِالْقَتْلِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

[بَابُ الْقِصَاصِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ] (700)

26- مَنْ قَطَعَ يَدَ غَيْرِهِ عَمْدًا مِنَ الْمِفْصَلِ

الهداية: قَالَ (701): (وَمَنْ قَطَعَ يَدَ غَيْرِهِ عَمْدًا مِنَ الْمِفْصَلِ قُطِعَتْ يَدُهُ) (702) وَإِنْ كَانَتْ يَدُهُ أَكْبَرَ مِنَ الْيَدِ الْمَقْطُوعَةِ (703) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَالْجُرُوحُ قِصَاصٌ} [المائدة: 45] وَهُوَ يُنْبِئُ عَنِ الْمُمَاتَلَةِ، فَكُلُّ مَا أُمِكنَ رِعَايَتُهَا فِيهِ يَجِبُ فِيهِ الْقِصَاصُ وَمَا لَا فَلَا، وَقَدْ أُمِكنَ فِي الْقَطْعِ مِنَ الْمِفْصَلِ فَاعْتَبِرْ، وَلَا مُعْتَبَرٌ بِكِبَرِ الْيَدِ وَصِغَرِهَا لِأَنَّ مَنَفْعَةَ الْيَدِ لَا تَخْتَلِفُ بِذَلِكَ، وَكَذَلِكَ الرَّجُلُ وَمَارِئُ الْأَنْفِ وَالْأُذُنُ لِإِمْكَانِ رِعَايَةِ الْمُمَاتَلَةِ.

27- مَنْ ضَرَبَ عَيْنَ رَجُلٍ فَقَلَعَهَا

قَالَ: (وَمَنْ ضَرَبَ عَيْنَ رَجُلٍ فَقَلَعَهَا لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ) لِامْتِنَاعِ الْمُمَاتَلَةِ فِي الْقَلْعِ، وَإِنْ كَانَتْ

(697) أَيِ الْقَاتِلِ الْمَسْرُوقِ مِنْهُ

(698) أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِي السَّنَنِ الْكُبْرَى 450/3 رَقْم 3530، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيُّ فِي الدَّرَايَةِ فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ الْهَدَايَةِ 268/2 رَقْم 1017: "حَدِيثُ قَاتِلِ دُونَ مَالِكِ الْبُخَارِيِّ فِي تَارِيخِهِ مِنْ طَرِيقِ قَهِيدِ بْنِ مَطْرَفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ أَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَأْخُذَ مَالِي قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْشُدْهُ اللَّهَ تَعَالَى وَالْإِسْلَامَ ثَلَاثًا قَالَ قَدْ فَعَلْتُ قَالَ قَاتِلْ دُونَ مَالِكِ الْحَدِيثِ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بَلْفُظٍ قَاتَلَهُ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ".

(699) لِأَنَّهُ أَسْهَلُ مِنَ الْإِبْتِدَاءِ.

(700) لَمَّا فَرِغَ مِنْ بَيَانِ الْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ أَتْبَعَهُمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ التَّبَعِ وَهُوَ الْقِصَاصُ فِي الطَّرَفِ.

(701) أَيِ الْقُدُورِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -.

(702) هَذَا كَلَامُ الْقُدُورِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -.

(703) وَهَذَا كَلَامُ الْمُصَنِّفِ الْمَرْغِينَانِيِّ .

قَائِمَةً فَذَهَبَ ضَوْءُهَا فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ لِإِمْكَانِ الْمُمَاتَلَةِ عَلَى مَا قَالَ فِي الْكِتَابِ (704): تُحْمَى لَهُ الْمِرَاةُ وَيُجْعَلُ عَلَى وَجْهِهِ قُطْنٌ رَطْبٌ وَتُقَابِلُ عَيْنُهُ بِالْمِرَاةِ فَيَذْهَبُ ضَوْءُهَا، وَهُوَ مَأْثُورٌ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ (705) -

28-القصاص في السن

قَالَ (706): (وَفِي السَّنِّ الْقِصَاصُ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَالسَّنَّ بِالسَّنِّ} [المائدة: 45] (وَإِنْ كَانَ سِنٌّ مَنْ يُقْتَصُّ مِنْهُ أَكْبَرُ مِنْ سِنِّ الْآخَرِ) لِأَنَّ مَنَفْعَةَ السَّنِّ لَا تَتَفَاوَتْ بِالصَّغَرِ وَالْكِبَرِ. قَالَ: (وَفِي كُلِّ شَجَةٍ تَتَحَقَّقُ فِيهَا الْمُمَاتَلَةُ الْقِصَاصُ) لِمَا تَلَوْنَا (707).

قَالَ (708) (وَلَا قِصَاصَ فِي عَظْمٍ إِلَّا فِي السَّنِّ) (709) وَهَذَا اللَّفْظُ مَرْوِيٌّ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -، وَقَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «لَا قِصَاصَ فِي الْعَظْمِ» (710) وَالْمُرَادُ غَيْرُ السَّنِّ، وَلِأَنَّ اعْتِبَارَ الْمُمَاتَلَةِ فِي غَيْرِ السَّنِّ مُتَعَدِّرٌ لِاحْتِمَالِ الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ، بِخِلَافِ السَّنِّ لِأَنَّهُ يُبْرَدُ بِالْمِبْرَدِ، وَلَوْ قَلَعَ مِنْ أَصْلِهِ يُفْلَعُ الثَّانِي فَيَتِمَّ اثْنَانِ.

29-شِبْهُ عَمْدٍ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ

الهداية: قَالَ (711): (وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ شِبْهُ عَمْدٍ إِنَّمَا هُوَ عَمْدٌ أَوْ خَطَأٌ) لِأَنَّ شِبْهُ الْعَمْدِ

(704) يَعْني الْقُدُورِي.

(705) رَوَى أَنَّ هَذَا حَدَّثَ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَسَأَلَ عَنْهُ الصَّحَابَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ فِيهِ شَيْءٌ حَتَّى جَاءَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَقَضَى بِذَلِكَ وَعَمَلَ عَلَيْهِ عُثْمَانُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَكَانَ بِمَحْضَرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -

(706) أَيِ الْقُدُورِي - رَحِمَهُ اللَّهُ -.

(707) إِشَارَةٌ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: 45].

(708) أَيِ الْقُدُورِي - رَحِمَهُ اللَّهُ -.

(709) قَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي الدَّرَايَةِ فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ الْهَدَايَةِ 269/2 رَقْمَ 1018: "قَوْلُهُ رَوَى عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عُمَرَ قَالَا لَا قِصَاصَ فِي عَظْمٍ إِلَّا فِي السَّنِّ لَمْ أَجِدْهُ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ وَالشَّعْبِيِّ قَالَا لَيْسَ فِي الْعِظَامِ قِصَاصٌ مَا خِلا السَّنِّ وَالرَّأْسِ"

(710) قَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي الدَّرَايَةِ فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ الْهَدَايَةِ 269/2 رَقْمَ 1018: "قَوْلُهُ رَوَى عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عُمَرَ قَالَا لَا قِصَاصَ فِي عَظْمٍ إِلَّا فِي السَّنِّ لَمْ أَجِدْهُ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ وَالشَّعْبِيِّ قَالَا لَيْسَ فِي الْعِظَامِ قِصَاصٌ مَا خِلا السَّنِّ وَالرَّأْسِ"

(711) أَيِ الْقُدُورِي - رَحِمَهُ اللَّهُ -.

يَعُودُ إِلَى الْآلَةِ، وَالْقَتْلُ هُوَ الَّذِي يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِهَا دُونَ مَا دُونَ النَّفْسِ لِأَنَّهُ لَا يَخْتَلِفُ إِتْلَافُهُ بِاخْتِلَافِ الْآلَةِ فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الْعَمْدُ وَالْخَطَأُ.

30-الْقِصَاصَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ(712)

(وَلَا قِصَاصَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ، وَلَا بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ، وَلَا بَيْنَ الْعَبْدَيْنِ) خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ إِلَّا فِي الْحُرِّ يَقْطَعُ طَرَفَ الْعَبْدِ. وَيُعْتَبَرُ الْأَطْرَافُ بِالنَّفْسِ لِكُونِهَا تَابِعَةً لَهَا.

وَلَنَا أَنَّ الْأَطْرَافَ يُسَلَكُ بِهَا مَسْلَكُ الْأَمْوَالِ فَيَنْعَدِمُ التَّمَثُّلُ بِالتَّفَاوُتِ فِي الْقِيَمَةِ، وَهُوَ مَعْلُومٌ قَطْعًا بِتَقْوِيمِ الشَّرْعِ فَأَمَكَّنَ اعْتِبَارُهُ. بِخِلَافِ التَّفَاوُتِ فِي الْبُطْشِ لِأَنَّهُ لَا ضَاطِبَ لَهُ فَاعْتُبِرَ أَصْلُهُ، وَبِخِلَافِ الْأَنْفُسِ لِأَنَّ الْمُتَلَفَ إِزْهَاقُ الرُّوحِ وَلَا تَفَاوُتَ فِيهِ.

(وَيَجِبُ الْقِصَاصُ فِي الْأَطْرَافِ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ) لِلتَّسَاوِي بَيْنَهُمَا فِي الْأَرَشِ(713)

31-قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ مِنْ نِصْفِ السَّاعِدِ أَوْ جَرَحَهُ جَائِفَةً فَبَرَأَ مِنْهَا

قَالَ(714): (وَمَنْ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ مِنْ نِصْفِ السَّاعِدِ أَوْ جَرَحَهُ جَائِفَةً(715) فَبَرَأَ مِنْهَا فَلَا قِصَاصَ عَلَيْهِ) لِأَنَّهُ لَا يُمَكَّنُ اعْتِبَارُ الْمُمَاتِلَةِ فِيهِ، إِذِ الْأَوَّلُ كَسْرُ الْعَظْمِ وَلَا ضَاطِبَ فِيهِ، وَكَذَا الْبُرْءُ نَادِرٌ فَيُنْفَضِي الثَّانِي إِلَى الْهَلَاكِ ظَاهِرًا.

(712) اختلف الفقهاء في القصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس على قولين: القول الأول: ذهب الحنفية إلى أنه لا قصاص بين الرجل والمرأة. القول الثاني: ذهب الشافعي إلى جريان القصاص بين الرجل والمرأة باعتبار الأطراف بالنفوس لأنها تابعة للنفوس فكما يجري القصاص بين الرجال والنساء في النفوس فكذلك في الأطراف. واستدل الحنفية على أنه لا قصاص بين الرجل والمرأة، لأنَّ الأطراف يسلك بها مسلك الأموال فينعدم التمثال بالتفاوت في القيمة وهو معلوم قطعاً بتقويم الشرع.

والمختار القول الثاني بجريان القصاص بين الرجل والمرأة باعتبار الأطراف بالنفوس لأنها تابعة للنفوس فكما يجري القصاص بين الرجال والنساء في النفوس فكذلك في الأطراف. (713) يطلق الأرش عند الفقهاء على المال الواجب فيما دون النفس بالجناية عليه.

(714) أي القدوري رحمه الله.

(715) الجائفة: لغة الجراحة التي وصلت الجوف. فلو وصلت إلى جوف عظم الفخذ لم تكن جائفة لأنَّ العظم لا يعدُّ مجوفاً. المغرب للمطرزي: 96/1. ولا يخرج معناها الاصطلاح عن المعنى اللغوي، فهي الجرح الذي ينفذ ويصل إلى جوف، كبطن، وصدر، وتغرة نحر،

32- قطع اليد الشلاء أو ناقصة الأصابع بالصحيحة

قَالَ (716): (وَإِذَا كَانَتْ يَدُ الْمَقْطُوعِ صَاحِبَةً وَيَدُ الْقَاطِعِ شَلَاءً أَوْ نَاقِصَةً الْأَصَابِعِ فَالْمَقْطُوعُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ قَطَعَ الْيَدَ الْمَعْيِبَةَ وَلَا شَيْءَ لَهُ غَيْرُهَا وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الْأَرْضَ كَامِلًا) لِأَنَّ اسْتِيفَاءَ الْحَقِّ كَامِلًا مُتَعَذِّرٌ فَلَهُ أَنْ يَتَجَوَّزَ بِدُونِ حَقِّهِ وَلَهُ أَنْ يَعْدِلَ إِلَى الْعَوَضِ (717) كَالْمِثْلِيِّ (718) إِذَا انْصَرَمَ (719) عَنْ أَيْدِي النَّاسِ بَعْدَ الْإِتْلَافِ (720) ثُمَّ إِذَا اسْتَوْفَاهَا نَاقِصًا فَقَدْ رَضِيَ بِهِ فَيَسْقُطُ حَقُّهُ كَمَا إِذَا رَضِيَ بِالرَّدِيِّ مَكَانَ الْجَيِّدِ (وَلَوْ سَقَطَتْ الْمُؤَوَّفَةُ (721) قَبْلَ اخْتِيَارِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَوْ قُطِعَتْ ظُلْمًا فَلَا شَيْءَ لَهُ) عِنْدَنَا لِأَنَّ حَقَّهُ مُتَعَيِّنٌ فِي الْقِصَاصِ، وَإِنَّمَا يَنْتَقِلُ إِلَى الْمَالِ بِاخْتِيَارِهِ فَيَسْقُطُ بِفَوَاتِهِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا قُطِعَتْ بِحَقِّ عَلَيْهِ مِنْ قِصَاصٍ أَوْ سَرِقَةٍ حَيْثُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْأَرْضُ لِأَنَّهُ أَوْفَى بِهِ حَقًّا مُسْتَحَقًّا فَصَارَتْ سَالِمَةً لَهُ مَعْنَى.

33- شَجَّ رَجُلًا فَاسْتَوْعَبَتْ الشَّجَّةُ مَا بَيْنَ قَرْنَيْهِ وَهِيَ لَا تَسْتَوْعِبُ مَا بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّاجِّ

وَجَنَبَيْنِ ، وَخَاصِرَةٍ ، وَمَثَانَةٍ ، وَعَجَّانٍ ، وَكَذَا لَوْ أَدْخَلَ مِنَ الشَّرَجِ شَيْئًا فَخَرَقَ بِهِ حَاجِزًا فِي الْبُطْنِ . وَلَوْ نَفَذَتْ الطَّعْنَةُ أَوْ الْجُرْحُ فِي الْبُطْنِ وَخَرَجَتْ مِنْ مَحَلٍّ آخَرَ فَجَائِفَتَانِ . وَتَحَصَّلُ الْجَائِفَةُ بِكُلِّ مَا يُفْضِي إِلَى بَاطِنِ جَوْفٍ ، فَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَحِيفَ بِحَدِيدَةٍ أَوْ خَشَبَةٍ مُحَدَّدَةٍ ، وَلَا بَيْنَ أَنْ تُكُونَ الْجَائِفَةُ وَاسِعَةً أَوْ ضَيِّقَةً وَلَوْ قَدَّرَ ابْنُ عَبَّادٍ 356 / 5 .
وقد اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَا قِصَاصَ فِي الْجَائِفَةِ . وَأَنَّ فِيهَا ثُلُثَ الدِّيَةِ سَوَاءً أَكَانَتْ عَمْدًا أَمْ خَطَأً ، لِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي كِتَابِهِ ، وَحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ الَّذِي فِيهِ : " وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ " أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ 217 / 2 . وَعَلَيْهِ الْإِجْمَاعُ ؛ وَلِأَنَّهُ لَا تُؤْمَنُ الزِّيَادَةُ فِيهَا فَلَمْ يَجِبْ فِيهَا قِصَاصٌ وَلِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ : " لَا قَوْدَ فِي الْمَأْمُومَةِ وَلَا الْجَائِفَةِ " أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهٍ فِي سَنَنِهِ 881 / 2 ، وَأَعْلَاهُ الْمَنَاوِي بِجَهَالَةِ أَحَدِ رَوَاتِهِ وَضَعَفَ آخَرُ . فَيُضِ الْقَدِيرُ 6 / 436 .

. وَاتَّفَقُوا فِي الْجَائِفَةِ إِذَا نَفَذَتْ مِنْ جَانِبٍ لِآخَرَ أَنَّهَا جَائِفَتَانِ فِي كُلِّ مِنْهُمَا ثُلُثُ الدِّيَةِ . حَاشِيَةُ ابْنِ عَبَّادٍ 356 / 5 ، وَمَوَاهِبُ الْجَلِيلِ 246 / 6 ، وَرَوُضَةُ الطَّالِبِينَ 256 / 9 ، وَكُشَافُ الْقِنَاعِ 54 / 6 - 56 . .

(716) أي القدوري رحمه الله.

(717) أرش

(718) كالمتلي: يعني لم يبق منه إلا ناقص الصفة، كان المالك بالخيار، إن شاء أخذه ناقصا، وإن شاء عدل إلى القيمة، كذا هنا، فيسقط حقه، كما إذا رضى بالردى مكان الجيد.
(719) انقطع.

(720) أي أُلِفَ المتلي ثم انصرم هو.

(721) أي المعيبة الشلاء.

قَالَ(722): (وَمَنْ شَجَّ رَجُلًا فَاسْتَوْعَبَتْ الشَّجَّةُ(723) مَا بَيْنَ قَرْنَيْهِ وَهِيَ لَا تَسْتَوْعِبُ مَا بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّاجِّ فَالْمَسْجُوجُ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ اقْتَصَّ بِمَقْدَارِ شَجَّتِهِ يَنْتَدِي مِنْ أَيِّ الْجَانِبَيْنِ شَاءَ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الْأَرْضَ) لِأَنَّ الشَّجَّةَ مُوجِبَةٌ لِكُونِهَا مَشْبِيئَةً فَقَطُّ فَيَزْدَادُ الشَّيْنُ بِزِيَادَتِهَا، وَفِي اسْتِيفَائِهِ مَا بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّاجِّ زِيَادَةٌ عَلَى مَا فَعَلَ، وَلَا يُلْحَقُهُ مِنَ الشَّيْنِ بِاسْتِيفَائِهِ قَدْرَ حَقِّهِ مَا يُلْحَقُ الْمَسْجُوجَ فَيَنْتَقِصُ فَيُخَيَّرُ كَمَا فِي الشَّلَاءِ وَالصَّحِيحَةِ، وَفِي عَكْسِهِ يُخَيَّرُ أَيْضًا لِأَنَّهُ يَنْعَذِّرُ الْإِسْتِيفَاءَ كَامِلًا لِلتَّعَدِّي إِلَى غَيْرِهِ. حَقُّهُ، وَكَذَا إِذَا كَانَتْ الشَّجَّةُ فِي طُولِ الرَّأْسِ وَهِيَ تَأْخُذُ مِنْ جَبْهَتِهِ إِلَى قَفَاهُ وَلَا تَبْلُغُ إِلَى قَفَا الشَّاجِّ فَهُوَ بِالْخِيَارِ لِأَنَّ الْمَعْنَى لَا يَخْتَلِفُ.

34-الْقِصَاصُ فِي اللِّسَانِ وَفِي الذِّكْرِ

قَالَ(724): (وَلَا قِصَاصَ فِي اللِّسَانِ وَلَا فِي الذِّكْرِ) وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ إِذَا قُطِعَ مِنْ أَصْلِهِ يَجِبُ لِأَنَّهُ يُمَكِّنُ اعْتِبَارُ الْمُسَاوَاةِ. وَلَنَا أَنَّهُ يَنْقَبِضُ وَيَنْبَسِطُ فَلَا يُمَكِّنُ اعْتِبَارُ الْمُسَاوَاةِ (إِلَّا أَنْ تُقَطَعَ الْحَشَفَةُ) لِأَنَّ مَوْضِعَ الْقُطْعِ مَعْلُومٌ كَالْمَفْصِلِ، وَلَوْ قُطِعَ بَعْضُ الْحَشَفَةِ أَوْ بَعْضُ الذِّكْرِ فَلَا قِصَاصَ فِيهِ لِأَنَّ الْبَعْضَ لَا يُعْلَمُ مَقْدَارُهُ، بِخِلَافِ الْأُذُنِ إِذَا قُطِعَ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ لِأَنَّهُ لَا يَنْقَبِضُ وَلَا يَنْبَسِطُ وَلَهُ حَدٌّ يُعْرَفُ فَيُمَكِّنُ اعْتِبَارُ الْمُسَاوَاةِ، وَالشَّفَةُ إِذَا اسْتَقْصَاهَا بِالْقُطْعِ يَجِبُ الْقِصَاصُ لِإِمْكَانِ اعْتِبَارِ الْمُسَاوَاةِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا قُطِعَ بَعْضُهَا لِأَنَّهُ يَنْعَذِّرُ اعْتِبَارُهَا.

35-اصْطَلَحَ الْقَاتِلُ وَأَوْلِيَاءُ الْقَتِيلِ عَلَى مَالٍ

ما الحكم إِذَا اصْطَلَحَ الْقَاتِلُ وَأَوْلِيَاءُ الْقَتِيلِ عَلَى مَالٍ؟

قَالَ(725): (وَإِذَا اصْطَلَحَ الْقَاتِلُ (726) وَأَوْلِيَاءُ الْقَتِيلِ عَلَى مَالٍ سَقَطَ الْقِصَاصُ وَوَجَبَ الْمَالُ(727) قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا(728)) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} [البقرة:

(722)أي القدوري رحمه الله.

(723)لصغر رأسه.

(724)أي القدوري رحمه الله.

(725)أي القدوري رحمه الله.

(726)عن القصاص.

(727)المسمى.

(728)أزيد على مقدار الدية.

[178] الْآيَةُ عَلَى مَا قِيلَ نَزَلَتْ الْآيَةُ فِي الصُّلْحِ. وَقَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ» (729) الْحَدِيثُ، وَالْمُرَادُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ الْأَخْذُ بِالرِّضَا عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَهُوَ الصُّلْحُ بِعَيْنِهِ، وَلِأَنَّهُ حَقٌّ ثَابِتٌ لِلْوَرْتَةِ يَجْرِي فِيهِ الْإِسْقَاطُ عَفْوًا فَكَذَا تَعْوِيضًا لِأَشْتِمَالِهِ عَلَى إِحْسَانِ الْأَوْلِيَاءِ وَإِحْيَاءِ الْقَاتِلِ فَيَجُوزُ بِالْتَّرَاضِي. وَالْقَلِيلُ وَالكَثِيرُ فِيهِ سَوَاءٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ نَصٌّ مُقَدَّرٌ فَيَفُوضُ إِلَى اصْطِلَاحِهِمَا كَالْخُلْعِ وَغَيْرِهِ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرُوا حَالًا وَلَا مُوَجَّلًا فَهُوَ حَالٌ لِأَنَّهُ مَالٌ وَاجِبٌ بِالْعَقْدِ، وَالْأَصْلُ فِي أَمْثَالِهِ الْحُلُولُ نَحْوُ الْمَهْرِ وَالنَّمَنِ، بِخِلَافِ الدِّيَةِ لِأَنَّهَا مَا وَجَبَتْ بِالْعَقْدِ.

36- عَفَا أَحَدُ الشَّرَكَاءِ مِنَ الدَّمِ أَوْ صَالَحَ مِنْ نَصِيْبِهِ عَلَى عَوَضٍ
(وَإِذَا عَفَا أَحَدُ الشَّرَكَاءِ مِنَ الدَّمِ أَوْ صَالَحَ مِنْ نَصِيْبِهِ عَلَى عَوَضٍ سَقَطَ حَقُّ الْبَاقِيْنَ عَنْ الْقِصَاصِ وَكَانَ لَهُمْ نَصِيْبُهُمْ مِنَ الدِّيَةِ) .

وَأَصْلُ هَذَا أَنَّ الْقِصَاصَ حَقٌّ جَمِيعُ الْوَرْتَةِ، وَكَذَا الدِّيَةُ خِلَافًا لِمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ فِي الزَّوْجَيْنِ. لَهُمَا أَنَّ الْوَرَاثَةَ خِلَافَةٌ وَهِيَ بِالنَّسَبِ دُونَ السَّبَبِ لِانْقِطَاعِهِ بِالْمَوْتِ، وَلَنَا «أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أَمَرَ بِتَوْرِيثِ امْرَأَةِ أَشِيمِ الضَّبَابِيِّ مِنْ عَقْلِ زَوْجِهَا أَشِيمٍ» (730)، وَلِأَنَّهُ حَقٌّ يَجْرِي فِيهِ الْإِرْثُ، حَتَّى أَنْ مَنْ قُتِلَ وَلَهُ ابْنَانِ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا عَنْ ابْنٍ كَانَ الْقِصَاصُ بَيْنَ الصُّلْبِيِّ وَابْنِ الْإِبْنِ فَيَنْتَبِثُ لِسَائِرِ الْوَرْتَةِ، وَالزَّوْجِيَّةُ تَبْقَى بَعْدَ الْمَوْتِ حُكْمًا فِي حَقِّ الْإِرْثِ أَوْ يَنْتَبِثُ بَعْدَ الْمَوْتِ مُسْتَنَدًا إِلَى سَبَبِهِ وَهُوَ الْجُرْحُ، وَإِذَا تَبَتَّ لِلْجَمِيعِ فَكُلُّ مَنْهُمْ يَتِمَكَّنُ مِنَ الْإِسْتِيفَاءِ وَالْإِسْقَاطِ عَفْوًا وَصُلْحًا وَمِنْ ضَرُورَةِ سُقُوطِ حَقِّ الْبَعْضِ فِي الْقِصَاصِ سُقُوطُ حَقِّ الْبَاقِيْنَ فِيهِ، لِأَنَّهُ لَا يَتَجَزَأُ، بِخِلَافِ مَا إِذَا قُتِلَ رَجُلَيْنِ وَعَفَا أَحَدُ الْوَلَدَيْنِ لِأَنَّ الْوَاجِبَ هُنَاكَ قِصَاصَانِ مِنْ غَيْرِ شُبْهَةٍ لِاخْتِلَافِ الْقَتْلِ وَالْمَقْتُولِ وَهَاهُنَا وَاحِدٌ لِاتِّحَادِهِمَا، وَإِذَا سَقَطَ الْقِصَاصُ يَنْقَلِبُ نَصِيبُ الْبَاقِيْنَ مَالًا لِأَنَّهُ امْتَنَعَ لِمَعْنَى رَاجِعٍ إِلَى الْقَاتِلِ، وَلَيْسَ لِلْعَافِي شَيْءٌ مِنَ الْمَالِ لِأَنَّهُ أَسْقَطَ حَقَّهُ بِفِعْلِهِ وَرِضَاهُ، ثُمَّ يَجِبُ مَا يَجِبُ مِنَ الْمَالِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ وَقَالَ

(729) أخرجه البخاري في صحيحه 5/9 رقم 6880.

(730) أخرجه الدارقطني في سننه 135/5 رقم 4089.

زُفِرُ: يَجِبُ فِي سَنَتَيْنِ فِيمَا إِذَا كَانَ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ وَعَفَا أَحَدُهُمَا، لِأَنَّ الْوَاجِبَ نِصْفُ الدِّيَةِ فَيُعْتَبَرُ بِمَا إِذَا قُطِعَتْ يَدُهُ خَطَأً.

وَلَنَا أَنَّ هَذَا بَعْضُ بَدَلِ الدَّمِ وَكُلُّهُ مُؤَجَّلٌ إِلَى ثَلَاثِ سِنِينَ فَكَذَلِكَ بَعْضُهُ، وَالْوَاجِبُ فِي الْيَدِ كُلُّ بَدَلِ الطَّرَفِ وَهُوَ فِي سَنَتَيْنِ فِي الشَّرْعِ وَيَجِبُ فِي مَالِهِ لِأَنَّهُ عَمْدٌ.

37- قَتَلَ جَمَاعَةً وَاحِدًا عَمْدًا

قَالَ (731): (وَإِذَا قَتَلَ جَمَاعَةً وَاحِدًا عَمْدًا أُقْتَصَّ مِنْ جَمِيعِهِمْ) لِقَوْلِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِيهِ: لَوْ تَمَالَا عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ، وَلِأَنَّ الْقَتْلَ بِطَرِيقِ التَّغَالِبِ غَالِبٌ، وَالْقِصَاصُ مَرْجَرَةٌ لِلْسُّفَهَاءِ فَيَجِبُ تَحْقِيقًا لِحِكْمَةِ الْإِحْيَاءِ (732).

38- قَتَلَ وَاحِدًا جَمَاعَةً

(وَإِذَا قَتَلَ وَاحِدًا جَمَاعَةً فَحَضَرَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِينَ قَتَلَ لِحِمَاةِهِمْ وَلَا شَيْءَ لَهُمْ غَيْرُ ذَلِكَ، فَإِنْ حَضَرَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ قُتِلَ لَهُ وَسَقَطَ حَقُّ الْبَاقِينَ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُقْتَلُ بِالْأَوَّلِ مِنْهُمْ وَيَجِبُ لِلْبَاقِينَ الْمَالُ، وَإِنْ اجْتَمَعُوا وَلَمْ يُعْرِفْ الْأَوَّلُ قُتِلَ لَهُمْ وَقُسِمَتِ الدِّيَاتُ بَيْنَهُمْ، وَقِيلَ يُفْرَعُ بَيْنَهُمْ فَيُقْتَلُ

(731) أَبِي الْقَدُورِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ.

(732) إِذَا تَعَدَّدَ الْقَاتِلُ أُقْتَصَّ مِنْ جَمِيعِهِمْ، وَالْقِيَاسُ لَا يَقْتَضِيهِ لِإِنْتِفَاءِ الْمُسَاوَاةِ، لَكِنَّهُ تَرَكَ الْقِيَاسَ بِمَا رُوِيَ أَنَّ سُبُعَةَ مِنْ أَهْلِ صَنْعَاءَ قَتَلُوا رَجُلًا فَقَضَى عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِالْقِصَاصِ عَلَيْهِمْ وَقَالَ: لَوْ تَمَالَا عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ. وَالتَّمَالُؤُ التَّعَاوُنُ، وَصَنْعَاءُ الْيَمَنُ: قَصَبَتُهَا. وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَتَلَ ثَلَاثَةً بِوَاحِدٍ. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ قَتَلَ جَمَاعَةً بِوَاحِدٍ، وَكَانَتْ الصَّحَابَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - مُتَوَافِرِينَ وَلَمْ يَنْكُرْ عَلَيْهِمْ أَحَدٌ فَحَلَّ مَحَلَّ الْإِجْمَاعِ، وَلِأَنَّ الْقَتْلَ بِطَرِيقِ التَّغَالِبِ غَالِبٌ فَإِنَّ الْقَتْلَ بِغَيْرِ حَقٍّ لَا يَتَحَقَّقُ غَالِبًا إِلَّا بِالْإِجْتِمَاعِ، لِأَنَّ الْوَاحِدَ يُقَاوِمُ الْوَاحِدَ، وَمَا غَلَبَ وَفُوعُهُ مِنَ الْفَسَادِ يُوجِبُ مَرْجَرَةً فَيَجِبُ الْقِصَاصُ تَحْقِيقًا لِحِكْمَةِ الْإِحْيَاءِ، فَإِنَّهُ لَوْ لَمْ يَجِبْ لَمَا عَجَزَ الْمُفْسِدُ عَنْ أَنْ يَجْمَعَ عَلَيْهِ أَمْثَالُهُ وَيَقْتُلَ لِعِلْمِهِ أَنَّ الْقِصَاصَ فَيُؤَدِّي إِلَى سَدِّ بَابِ الْقِصَاصِ. وَلِقَائِلُ أَنْ يَقُولَ: مَا ذَكَرْتُمْ مِنَ الْمَعْقُولِ إِنْ لَمْ يَكُنْ قِيَاسًا عَلَى مُجْمَعٍ عَلَيْهِ لَا يَكُونُ مُعْتَبَرًا فِي الشَّرْعِ، وَإِنْ كَانَ فَلَا يَرْبُوْ عَلَى الْقِيَاسِ الْمُقْتَضِي لِعَدَمِهِ الْمُؤَيَّدِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة: 45] وَالْجَوَابُ أَنَّهُ قِيَاسٌ عَلَى سَائِرِ أَبْوَابِ الْعُقُوبَاتِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَى مَا يُوجِبُ الْفَسَادَ مِنْ أَفْعَالِ الْعِبَادِ، وَيَرْبُوْ عَلَى ذَلِكَ بِقُوَّةِ أَثَرِهِ الْبَاطِنِ وَهُوَ إِحْيَاءُ حِكْمَةِ الْإِحْيَاءِ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة: 45] لَا يُنَافِيهِ لِأَنَّهُمْ فِي إِزْهَاقِ الرُّوحِ الْغَيْرِ الْمُتَجَزِّي كَشَخْصٍ وَاحِدٍ، وَإِذَا كَانَتْ الْمَسْأَلَةُ بِالْعَكْسِ وَحَضَرَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِينَ قَتَلَ بِجَمَاعَتِهِمْ.

لِمَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ. لَهُ أَنَّ الْمَوْجُودَ مِنَ الْوَاحِدِ قِتْلَاتٌ وَالَّذِي تَحَقَّقَ فِي حَقِّهِ قَتْلٌ وَاحِدٌ فَلَا تَمَاطُلٌ، وَهُوَ الْقِيَاسُ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ، إِلَّا أَنَّهُ عُرِفَ بِالشَّرْعِ. وَلَنَا أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قَاتِلٌ يَوْصَفُ الْكَمَالَ فَجَاءَ التَّمَاطُلُ أَصْلُهُ الْفَصْلُ الْأَوَّلُ، إِذْ لَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَمَا وَجَبَ الْقِصَاصُ، وَلِأَنَّهُ وَجِدَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ جُرْحٌ صَالِحٌ لِلْإِزْهَاقِ فَيُضَافُ إِلَى كُلِّ مِنْهُمْ إِذْ هُوَ لَا يَتَجَزَّأُ، وَلِأَنَّ الْقِصَاصَ شَرَعَ مَعَ الْمُنَافِي لِتَحْقِيقِ الْإِحْيَاءِ وَقَدْ حَصَلَ بِقَتْلِهِ فَاكْتَفَى بِهِ.

39-سقوط القصاص بالموت

قَالَ(733): (وَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ إِذَا مَاتَ سَقَطَ الْقِصَاصُ) لِفَوَاتِ مَحَلِّ الْإِسْتِيفَاءِ فَاشْتَبَهَ مَوْتَ الْعَبْدِ الْجَانِي، وَبَتَّاتِي فِيهِ خِلَافُ الشَّافِعِيِّ إِذْ الْوَاجِبُ أَحَدُهُمَا عِنْدَهُ.

40-قَطْعَ رَجُلَانِ يَدِ رَجُلٍ وَاحِدٍ

قَالَ(734): (وَإِذَا قَطَعَ رَجُلَانِ يَدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ فَلَا قِصَاصَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَعَلَيْهِمَا نِصْفُ الدِّيَةِ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: تُقَطَّعُ يَدَاهُمَا، وَالْمُفْرَضُ إِذَا أَخَذَ سَكِينًا وَأَمَرَهُ عَلَى يَدِهِ حَتَّى انْقَطَعَتْ لَهُ الْإِعْتِبَارُ بِالْأَنْفُسِ، وَالْأَيْدِي تَابِعَةٌ لَهَا فَأَخَذَتْ حُكْمَهَا، أَوْ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِجَامِعِ الرَّجْرِ. وَلَنَا أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَاطِعٌ بَعْضَ الْيَدِ، لِأَنَّ الْإِنْقِطَاعَ حَصَلَ بِاعْتِمَادِيهِمَا وَالْمَحَلُّ مُتَجَزِّئٌ فَيُضَافُ إِلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَعْضُ فَلَا مُمَاتَلَّةَ، بِخِلَافِ النَّفْسِ لِأَنَّ الْإِنْزِهَاقَ لَا يَتَجَزَّأُ، وَلِأَنَّ الْقَتْلَ بِطَرِيقِ الْاجْتِمَاعِ غَالِبُ حَذَارِ الْغَوْثِ، وَالْاجْتِمَاعُ عَلَى قَطْعِ الْيَدِ مِنَ الْمِفْصَلِ فِي حَيْزِ النُّدْرَةِ لِإِفْتِقَارِهِ إِلَى مُقَدَّمَاتٍ بَطِينَةٍ فَيُلْحَقُهُ الْغَوْثُ. قَالَ (وَعَلَيْهِمَا نِصْفُ الدِّيَةِ) لِأَنَّهُ دِيَّةُ الْيَدِ الْوَاحِدَةِ وَهُمَا قَطَعَاَهَا.

(733)أي القدوري رحمه الله.

(734)أي القدوري رحمه الله.

41- قَطَعَ وَاحِدٌ يَمِينِي رَجُلَيْنِ (735)

(وَإِنْ قَطَعَ وَاحِدٌ يَمِينِي (736) رَجُلَيْنِ فَحَضَرَا فَلَهُمَا أَنْ يَفْطَعَا يَدَهُ وَيَأْخُذَا مِنْهُ نِصْفَ الدِّيَةِ يَفْسِمَانِهِ نِصْفَيْنِ سَوَاءً قَطَعَهُمَا مَعًا أَوْ عَلَى التَّعَاقُبِ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: فِي التَّعَاقُبِ يُقْطَعُ بِالْأَوَّلِ، وَفِي الْقِرَانِ يُقَرَّعُ لِأَنَّ الْيَدَ اسْتَحَقَّهَا الْأَوَّلُ فَلَا يَنْبُتُ الْإِسْتِحْقَاقُ فِيهَا لِلثَّانِي كَالرَّهْنِ بَعْدَ الرَّهْنِ، وَفِي الْقِرَانِ الْيَدُ الْوَاحِدَةُ لَا تَفِي بِالْحَقِّينِ فَتُرْجَحُ بِالْقُرْعَةِ. وَلَنَا أَنَّهُمَا اسْتَوَيَا فِي سَبَبِ الْإِسْتِحْقَاقِ فَيَسْتَوِيَانِ فِي حُكْمِهِ كَالْغَرِيمَيْنِ فِي التَّرَكَةِ، وَالْقِصَاصُ مِلْكُ الْفِعْلِ يَنْبُتُ مَعَ الْمُنَافِي فَلَا يَظْهَرُ إِلَّا فِي حَقِّ الْإِسْتِيفَاءِ.

أَمَّا الْمَحَلُّ فَخُلُوُّ عَنْهُ فَلَا يَمْنَعُ ثُبُوتُ الثَّانِي، بِخِلَافِ الرَّهْنِ لِأَنَّ الْحَقَّ ثَابِتٌ فِي الْمَحَلِّ. فَصَارَ كَمَا إِذَا قَطَعَ الْعَبْدُ يَمِينَيْهِمَا عَلَى التَّعَاقُبِ فَتُسْتَحَقُّ رَقَبَتُهُ لَهُمَا، وَإِنْ حَضَرَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَقَطَعَ يَدَهُ فَلِأَخَرِ عَلَيْهِ نِصْفُ الدِّيَةِ، لِأَنَّ لِلْحَاضِرِ أَنْ يَسْتَوْفِيَ لِثُبُوتِ حَقِّهِ وَتَرُدُّدِ حَقِّ الْعَائِبِ، وَإِذَا اسْتَوْفَى لَمْ يَبْقَ مَحَلُّ الْإِسْتِيفَاءِ فَيَتَعَيَّنُ حَقُّ الْآخَرِ فِي الدِّيَةِ لِأَنَّهُ أَوْفَى بِهِ حَقًّا مُسْتَحَقًّا.

42- رَمَى رَجُلًا عَمْدًا فَفَنَذَ السَّهْمُ مِنْهُ إِلَى آخَرِ فَمَاتَا

(وَمَنْ رَمَى رَجُلًا عَمْدًا فَفَنَذَ السَّهْمُ مِنْهُ إِلَى آخَرِ فَمَاتَا فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ لِلأَوَّلِ وَالدِّيَةُ لِلثَّانِي عَلَى عَاقِلَتِهِ) لِأَنَّ الْأَوَّلَ عَمْدٌ وَالثَّانِي أَحَدُ نَوْعِي الْخَطَا، كَأَنَّهُ رَمَى إِلَى صَيِّدٍ فَأَصَابَ آدَمِيًّا وَالْفِعْلُ يَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الْأَثَرِ.

(735) اختلف الفقهاء في قَطَعَ وَاحِدٌ يَمِينِي رَجُلَيْنِ فَحَضَرَا على قولين: القول الأول: قال الحنفية: لَهُمَا أَنْ يَفْطَعَا يَدَهُ وَيَأْخُذَا مِنْهُ نِصْفَ الدِّيَةِ يَفْسِمَانِهِ نِصْفَيْنِ سَوَاءً قَطَعَهُمَا مَعًا أَوْ عَلَى التَّعَاقُبِ. القول الثاني: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: فِي التَّعَاقُبِ يُقْطَعُ بِالْأَوَّلِ، وَفِي الْقِرَانِ يُقَرَّعُ لِأَنَّ الْيَدَ اسْتَحَقَّهَا الْأَوَّلُ فَلَا يَنْبُتُ الْإِسْتِحْقَاقُ فِيهَا لِلثَّانِي كَالرَّهْنِ بَعْدَ الرَّهْنِ، وَفِي الْقِرَانِ الْيَدُ الْوَاحِدَةُ لَا تَفِي بِالْحَقِّينِ فَتُرْجَحُ بِالْقُرْعَةِ.

واستدل الحنفية على قولهم بأنَّهُمَا اسْتَوَيَا فِي سَبَبِ الْإِسْتِحْقَاقِ فَيَسْتَوِيَانِ فِي حُكْمِهِ كَالْغَرِيمَيْنِ فِي التَّرَكَةِ، وَالْقِصَاصُ مِلْكُ الْفِعْلِ يَنْبُتُ مَعَ الْمُنَافِي فَلَا يَظْهَرُ إِلَّا فِي حَقِّ الْإِسْتِيفَاءِ. أَمَّا الْمَحَلُّ فَخُلُوُّ عَنْهُ فَلَا يَمْنَعُ ثُبُوتُ الثَّانِي، بِخِلَافِ الرَّهْنِ لِأَنَّ الْحَقَّ ثَابِتٌ فِي الْمَحَلِّ. فَصَارَ كَمَا إِذَا قَطَعَ الْعَبْدُ يَمِينَيْهِمَا عَلَى التَّعَاقُبِ فَتُسْتَحَقُّ رَقَبَتُهُ لَهُمَا، وَإِنْ حَضَرَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَقَطَعَ يَدَهُ فَلِأَخَرِ عَلَيْهِ نِصْفُ الدِّيَةِ، لِأَنَّ لِلْحَاضِرِ أَنْ يَسْتَوْفِيَ لِثُبُوتِ حَقِّهِ وَتَرُدُّدِ حَقِّ الْعَائِبِ، وَإِذَا اسْتَوْفَى لَمْ يَبْقَ مَحَلُّ الْإِسْتِيفَاءِ فَيَتَعَيَّنُ حَقُّ الْآخَرِ فِي الدِّيَةِ لِأَنَّهُ أَوْفَى بِهِ حَقًّا مُسْتَحَقًّا.

(736) قَيِّدُ بَدَلِكِ، لِأَنَّهُ لَوْ قَطَعَ يَمِينُ أَحَدِهِمَا وَيَسَارُ الْآخَرِ قُطِعَتْ يَدَاهُ. لَا يُقَالُ: تَنْتَفِي الْمُمَاطِلَةُ حِينَئِذٍ، لِأَنَّهُ مَا قَوَّتَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جِنْسُ الْمُنْفَعَةِ وَهُوَ قَوَّاهُ عَلَيْهِ، لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي حَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ مَا اسْتَوْفَاهُ، وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ تَقْوِيَتُ جِنْسِ الْمُنْفَعَةِ وَلَا زِيَادَةُ عَلَى حَقِّهِ.

43- قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ خَطَأً ثُمَّ قَتَلَهُ عَمْدًا

في حكم الفعلين:

قَالَ (737): (وَمَنْ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ خَطَأً ثُمَّ قَتَلَهُ عَمْدًا قَبْلَ أَنْ تَنْبِرَ يَدُهُ أَوْ قَطَعَ يَدَهُ عَمْدًا ثُمَّ قَتَلَهُ خَطَأً أَوْ قَطَعَ يَدَهُ خَطَأً فَبَرِنَتْ يَدُهُ ثُمَّ قَتَلَهُ خَطَأً أَوْ قَطَعَ يَدَهُ عَمْدًا فَبَرَأَتْ ثُمَّ قَتَلَهُ عَمْدًا فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ بِالْأَمْرَيْنِ جَمِيعًا) وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الْجَرَاحَاتِ وَاجِبٌ مَا أَمَكَّنَ تَتْمِيمًا لِلأَوَّلِ، لِأَنَّ الْقَتْلَ فِي الْأَعْمِ يَقَعُ بِضَرَبَاتٍ مُتَعاقِبَةٍ، وَفِي اعْتِبَارِ كُلِّ ضَرْبَةٍ بِنَفْسِهَا بَعْضُ الْحَرَجِ، إِلَّا أَنْ لَا يُمَكِّنَ الْجَمْعُ فَيُعْطَى كُلُّ وَاحِدٍ حُكْمَ نَفْسِهِ، وَقَدْ تَعَذَّرَ الْجَمْعُ فِي هَذِهِ الْفُصُولِ فِي الْأَوَّلَيْنِ لِاخْتِلَافِ حُكْمِ الْفَعْلَيْنِ، وَفِي الْآخَرَيْنِ لِتَخَلُّلِ الْبُرءِ وَهُوَ قَاطِعٌ لِلْسَّرَايَةِ، حَتَّى لَوْ لَمْ يَتَخَلَّلْ وَقَدْ تَجَانَسَا بِأَنْ كَانَا خَطَأَيْنِ يَجْمَعُ بِالْإِجْمَاعِ لِإِمْكَانِ الْجَمْعِ وَاكْتَفَى بِدِيَةِ وَاحِدَةٍ (وَإِنْ كَانَ قَطَعَ يَدَهُ عَمْدًا ثُمَّ قَتَلَهُ عَمْدًا قَبْلَ أَنْ تَنْبِرَ يَدُهُ، فَإِنْ شَاءَ الْإِمَامُ قَالَ: اقْطَعُوهُ ثُمَّ أَقْتُلُوهُ، وَإِنْ شَاءَ قَالَ: أَقْتُلُوهُ) وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَالَا: يُقْتَلُ وَلَا تُقَطَّعُ يَدُهُ لِأَنَّ الْجَمْعَ مُمَكِّنٌ لِتَجَانُسِ الْفَعْلَيْنِ وَعَدَمِ تَخَلُّلِ الْبُرءِ فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا. وَلَهُ أَنَّ الْجَمْعَ مُتَعَذِّرٌ، إِمَّا لِاخْتِلَافِ بَيْنِ الْفَعْلَيْنِ هَذَيْنِ لِأَنَّ الْمُوجِبَ الْقَوْدُ وَهُوَ يَعْتَمِدُ الْمُسَاوَاةَ فِي الْفِعْلِ وَذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ الْقَتْلُ بِالْقَتْلِ وَالْقَطْعُ بِالْقَطْعِ وَهُوَ مُتَعَذِّرٌ، أَوْ لِأَنَّ الْحَزَّ يَقْطَعُ إِضَافَةَ السَّرَايَةِ إِلَى الْقَطْعِ، حَتَّى لَوْ صَدَرَ مِنْ شَخْصَيْنِ يَجِبُ الْقَوْدُ عَلَى الْحَازِّ فَصَارَ كَتَخَلُّلِ الْبُرءِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا قَطَعَ وَسَرَى لِأَنَّ الْفِعْلَ وَاحِدًا، وَبِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَا خَطَأَيْنِ لِأَنَّ الْمُوجِبَ الدِّيَةَ وَهِيَ بَدَلُ النَّفْسِ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ الْمُسَاوَاةِ، وَلِأَنَّ أَرَشَ الْيَدِ إِنَّمَا يَجِبُ عِنْدَ اسْتِحْكَامِ أَثَرِ الْفِعْلِ وَذَلِكَ بِالْحَزِّ الْقَاطِعِ لِلْسَّرَايَةِ فَيَجْتَمِعُ ضَمَانُ الْكُلِّ وَضَمَانُ الْجُزْءِ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَا يَجْتَمِعَانِ. أَمَّا الْقَطْعُ وَالْقَتْلُ قِصَاصًا يَجْتَمِعَانِ (738).

(737) أي القدوري رحمه الله.

(738) الْقَطْعُ وَالْقَتْلُ إِذَا حَصَلَ فِي شَخْصٍ وَاحِدٍ كَانَا عَلَى وَجْهِهِ: أَنْ يَكُونَا خَطَأَيْنِ أَوْ عَمْدَيْنِ، أَوْ يَكُونَ الْقَتْلُ خَطَأً وَالْقَطْعُ عَمْدًا أَوْ بِالْعَكْسِ، فَذَلِكَ بِالنَّسْمَةِ الْعَقْلِيَّةِ أَرْبَعَةً. ثُمَّ إِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِمَّا أَنْ يَكُونَ قَبْلَ الْبُرءِ أَوْ بَعْدَهُ فَذَلِكَ ثَمَانِيَةٌ أَوْجُهُ، وَكُلُّ ذَلِكَ إِمَّا أَنْ يَتَحَقَّقَ مِنْ شَخْصٍ وَاحِدٍ أَوْ شَخْصَيْنِ فَذَلِكَ سِتَّةٌ عَشَرَ وَجْهًا، فَإِنْ كَانَا مِنْ شَخْصَيْنِ يُفْعَلُ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُوجِبٌ فِعْلُهُ مِنَ الْقِصَاصِ وَأَخِذَ الْأَرَشَ مُطْلَقًا، لِأَنَّ التَّدَاخُلَ إِنَّمَا يَكُونُ عِنْدَ اتِّحَادِ الْمَحَلِّ لَا غَيْرُ، وَإِنْ كَانَا مِنْ شَخْصٍ وَاحِدٍ فَإِيجَابُ مُوجِبِ الْفَعْلَيْنِ أَوْ إِهْذَارُ أَحَدِهِمَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَصْلٍ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ

44-قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ فَعَفَا الْمَقْطُوعَةُ يَدُهُ عَنِ الْقَطْعِ ثُمَّ مَاتَ مِنْ ذَلِكَ (739)

قَالَ (740): (وَمَنْ قَطَعَ (741) يَدَ رَجُلٍ فَعَفَا الْمَقْطُوعَةُ يَدُهُ عَنِ الْقَطْعِ ثُمَّ مَاتَ مِنْ ذَلِكَ (742) فَعَلَى الْقَاطِعِ الدِّيَّةُ فِي مَالِهِ، وَإِنْ عَفَا عَنِ الْقَطْعِ (743) وَمَا يَحْدُثُ مِنْهُ ثُمَّ مَاتَ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ عَفُوٌّ عَنِ النَّفْسِ، ثُمَّ إِنْ كَانَ (744) خَطَأً فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ، وَإِنْ كَانَ عَمْدًا فَهُوَ مِنْ

- بَقُولِهِ (وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ الْجَمْعَ) يَعْنِي الْاِكْتِفَاءَ بِمُوجِبِ أَحَدِهِمَا وَاجِبٌ مَا أُمَكَّنَ تَتْمِيمًا لِلأَوَّلِ، لِأَنَّ الْقَتْلَ فِي الْأَعْمَى: يَعْنِي فِي غَالِبِ الْأَوْقَاتِ يَقَعُ بِضَرَبَاتٍ مُتَعاقِبَةٍ، وَفِي اعْتِبَارِ كُلِّ ضَرْبَةٍ بِنَفْسِهَا بَعْضُ الْحَرَجِ فَيُجْعَلُ الثَّانِي مُتَمِّمًا لِلأَوَّلِ وَيُجْعَلُ الْكُلُّ وَاحِدًا، إِلَّا أَنْ لَا يُمَكِّنَ الْجَمْعُ إِمَّا بِاخْتِلَافِ الْفَعْلَيْنِ وَصَفًا أَوْ مُوجِبًا أَوْ بِتَخَلُّلِ الْبُرءِ، فَحِينَئِذٍ يُعْطَى كُلُّ وَاحِدٍ حُكْمَ نَفْسِهِ. فَإِنْ تَخَلَّلَ الْبُرءُ فَلَا جَمْعَ أَصْلًا لِأَنَّ الْفِعْلَ الْأَوَّلَ قَدْ انْتَهَى فَيَكُونُ الْقَتْلُ بَعْدَهُ ابْتِدَاءً، فَلَا بُدَّ مِنْ اعْتِبَارِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَإِنْ لَمْ يَتَخَلَّلْ وَقَدْ اخْتَلَفَا جِنْسًا فَكَذَلِكَ كَمَا فِي الصُّورَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ، وَإِنْ تَجَانَسَا خَطَأً جُمِعَ بِالْإِجْمَاعِ لِإِمْكَانِ الْجَمْعِ بِانْتِفَاءِ الْمَانِعِ وَهُوَ تَخَلُّلُ الْبُرءِ وَالْاِخْتِلَافُ وَاكْتِفَاءُ بَدِيَّةٍ وَاحِدَةٍ، وَإِنْ تَجَانَسَا عَمْدًا بَانَ كَانَ قَطَعَ يَدَهُ عَمْدًا ثُمَّ قَتَلَهُ عَمْدًا قَبْلَ أَنْ تُثْبِرَ يَدُهُ، فَقَدْ اخْتَلَفَ فِيهِ عَلَى قَوْلَيْنِ: الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - الْوَلِيُّ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يَقْطَعَ ثُمَّ يَقْتُلَ وَبَيْنَ أَنْ يَقْتُلَ . الْقَوْلُ الثَّانِي: قَالَ الصَّاحِبَانِ: يَقْتُلُ وَلَا يَقْطَعُ، لِأَنَّ الْجَمْعَ مُمَكِّنٌ لِتَجَانُسِ الْفَعْلَيْنِ وَعَدَمِ تَخَلُّلِ الْبُرءِ فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بَلْ الْجَمْعُ مُتَعَدِّرٌ إِمَّا لِاخْتِلَافِ بَيْنِ الْفَعْلَيْنِ لِأَنَّ الْمُوجِبَ الْقَوْدَ وَهُوَ يَعْتَمِدُ الْمُسَاوَاةَ فِي الْفِعْلِ وَذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ الْقَتْلُ بِالْقَتْلِ وَالْقَطْعُ بِالْقَطْعِ وَهُوَ مُتَعَدِّرٌ لِخُلُوعِ الْقَطْعِ إِذَا ذَكَ عَنْ الْجَزَاءِ، وَإِمَّا لِأَنَّ الْحَزَّ يَقْطَعُ إِضَافَةً السَّرَايَةِ إِلَى الْقَطْعِ حَتَّى لَوْ صَدَرَ مِنْ شَخْصَيْنِ وَجَبَ الْقَوْدُ عَلَى الْحَازِّ، وَإِذَا انْقَطَعَ إِضَافَةُ السَّرَايَةِ إِلَيْهِ صَارَ كَتَخَلُّلِ الْبُرءِ وَلَا جَمْعَ فِيهِ بِالِاتِّفَاقِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا قَطَعَ وَسَرَى لِأَنَّ الْفِعْلَ وَاحِدًا، وَبِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَا خَطَائِنِ لِأَنَّ الْمُوجِبَ هُوَ الدِّيَّةُ وَهُوَ بَدَلُ النَّفْسِ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ الْمُسَاوَاةِ. وَلِأَنَّ أَرَشَ الْيَدِ دَلِيلٌ آخَرٌ عَلَى جَوَازِ الْجَمْعِ إِذَا كَانَا خَطَائِنِ.

(739) اختلف الفقهاء في حكم سرية القطع والشجة والجراحة على النفس بعد العفو، فهل يسري العفو إلى ذلك على قولين: القول الأول: ذهب أبو حنيفة رحمه الله- إلى أَنَّ الْعَفْوَ عَنِ الْقَطْعِ وَالشَّجَةِ وَالْجَرَاةِ لَيْسَ بِعَفْوٍ عَمَّا يَحْدُثُ مِنْهُ، فَإِذَا وَقَعَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَعَفَا الْمَجْنِي عَلَيْهِ عَنْهُ ثُمَّ سَرَى وَمَاتَ فَعَلَى الْجَانِي الدِّيَّةُ فِي مَالِهِ عِنْدَهُ. القول الثاني: ذهب الصَّاحِبَانِ إِلَى أَنَّ الْعَفْوَ عَنِ الْقَطْعِ وَالشَّجَةِ وَالْجَرَاةِ عَفْوٌ عَمَّا يَحْدُثُ مِنْهُ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْعَفْوَ عَنِ الْقَطْعِ عَفْوٌ عَنْ مُوجِبِهِ، لِأَنَّ الْفِعْلَ عَرَضٌ لَا يَبْقَى فَلَا يُتَصَوَّرُ الْعَفْوُ عَنْهُ فَيَكُونُ الْعَفْوُ عَنْهُ عَفْوًا عَنْ مُوجِبِهِ وَمُوجِبُهُ إِمَّا الْقَطْعُ أَوْ الْقَتْلُ إِذَا اقْتَصَرَ أَوْ سَرَى فَكَانَ الْعَفْوُ عَفْوًا عَنْهُمَا، وَلِأَنَّ اسْمَ الْقَطْعِ يَتَنَاوَلُ السَّارِيَ وَالْمُقْتَصِرَ فَإِنَّ الْإِذْنَ بِالْقَطْعِ إِذْنٌ بِهِ وَبِمَا حَدَثَ مِنْهُ. حَتَّى إِذَا قَالَ شَخْصٌ آخَرُ أَقْطَعُ يَدِي فَقَطَعَهُ ثُمَّ سَرَى إِلَى النَّفْسِ لَمْ يَضْمَنْ وَالْعَفْوُ إِذْنٌ انْتِهَاءً فَيُعْتَبَرُ بِالْإِذْنِ ابْتِدَاءً، فَصَارَ كَمَا إِذَا عَفَا عَنْ الْجَنَاحَةِ فَإِنَّهُ يَتَنَاوَلُ السَّارِيَ وَالْمُقْتَصِرَ، فَكَذَا هَذَا.

(740) أي محمد رحمه الله.

(741) عمداً أو خطأ

(742) القطع.

(743) المقطوعة يده.

(744) قطع.

جَمِيعِ الْمَالِ) وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَالَا: إِذَا عَفَا عَنِ الْقَطْعِ فَهُوَ عَفْوٌ عَنِ النَّفْسِ أَيْضًا، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إِذَا عَفَا عَنِ الشَّجَةِ ثُمَّ سَرَى إِلَى النَّفْسِ وَمَاتَ، لَهُمَا أَنَّ الْعَفْوَ عَنِ الْقَطْعِ عَفْوٌ عَنِ مُوجِبِهِ، وَمُوجِبُهُ الْقَطْعُ لَوْ اقْتَصَرَ أَوْ الْقَتْلُ إِذَا سَرَى، فَكَانَ الْعَفْوُ عَنْهُ عَفْوًا عَنْ أَحَدٍ مُوجِبِيهِ أَیْهُمَا كَانَ، وَلِأَنَّ اسْمَ الْقَطْعِ يَتَنَاوَلُ السَّارِيَ وَالْمُقْتَصِرَ فَيَكُونُ الْعَفْوُ عَنِ قَطْعِ عَفْوًا عَنْ نَوْعِيهِ وَصَارَ كَمَا إِذَا عَفَا عَنِ الْجَنَايَةِ فَإِنَّهُ يَتَنَاوَلُ الْجَنَايَةَ السَّارِيَةَ وَالْمُقْتَصِرَةَ. كَذَا هَذَا. وَلَهُ أَنَّ سَبَبَ الضَّمَانِ قَدْ تَحَقَّقَ وَهُوَ قَتْلُ نَفْسٍ مَعْصُومَةٍ مُتَقَوِّمَةٍ وَالْعَفْوُ لَمْ يَتَنَاوَلْهُ بِصَرِيحِهِ لِأَنَّهُ عَفَا عَنِ الْقَطْعِ وَهُوَ غَيْرُ الْقَتْلِ، وَبِالسَّرِّيَةِ نَبَّيْنِ أَنَّ الْوَاقِعَ قَتْلٌ وَحَقُّهُ فِيهِ وَنَحْنُ نُوجِبُ ضَمَانَهُ. وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ الْقِصَاصُ وَهُوَ الْقِيَاسُ لِأَنَّهُ هُوَ الْمُوجِبُ لِلْعَمْدِ، إِلَّا أَنْ فِي الْإِسْتِحْسَانِ تَجِبُ الدِّيَّةُ، لِأَنَّ صُورَةَ الْعَفْوِ أَوْرَثَتْ شُبُهَةً وَهِيَ دَارِيَّةٌ لِلْقَوْدِ. وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ السَّارِيَ نَوْعٌ مِنَ الْقَطْعِ، وَأَنَّ السَّرِّيَةَ صِفَةٌ لَهُ، بَلْ السَّارِيَ قَتْلٌ مِنَ الْإِبْتِدَاءِ، وَكَذَا لَا مُوجِبَ لَهُ مِنْ حَيْثُ كَوْنِهِ قَطْعًا فَلَا يَتَنَاوَلُهُ الْعَفْوُ، بِخِلَافِ الْعَفْوِ عَنِ الْجَنَايَةِ لِأَنَّهُ اسْمُ جِنْسٍ، وَبِخِلَافِ الْعَفْوِ عَنِ الشَّجَةِ وَمَا يَحْدُثُ مِنْهَا لِأَنَّهُ صَرِيحٌ فِي الْعَفْوِ عَنِ السَّرِّيَةِ وَالْقَتْلِ، وَلَوْ كَانَ الْقَطْعُ خَطًا فَقَدْ أَجْرَاهُ مَجْرَى الْعَمْدِ فِي هَذِهِ الْوُجُوهِ وَفَقًّا وَخِلَافًا، أَذَنْ بِذَلِكَ إِطْلَاقُهُ، إِلَّا أَنَّهُ إِنْ كَانَ خَطًا فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ، وَإِنْ كَانَ عَمْدًا فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ، لِأَنَّ مُوجِبَ الْعَمْدِ الْقَوْدُ وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقُّ الْوَرَثَةِ لِمَا أَنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ فَصَارَ كَمَا إِذَا أَوْصَى بِإِعَارَةِ أَرْضِهِ. أَمَّا الْخَطَا فَمُوجِبُهُ الْمَالُ، وَحَقُّ الْوَرَثَةِ يَتَعَلَّقُ بِهِ فَيُعْتَبَرُ مِنَ الثُّلُثِ.

45-قَطَعَتِ الْمَرْأَةُ يَدَ رَجُلٍ فَتَزَوَّجَهَا عَلَى يَدِهِ ثُمَّ مَاتَ

قَالَ(745): (وَإِذَا قَطَعَتِ الْمَرْأَةُ يَدَ رَجُلٍ فَتَزَوَّجَهَا عَلَى يَدِهِ(746) ثُمَّ مَاتَ(747) فَلَهَا مَهْرٌ مِثْلُهَا، وَعَلَى عَاقِلَتِهَا الدِّيَّةُ إِنْ كَانَ خَطَاً، وَإِنْ كَانَ عَمْدًا فَفِي مَالِهَا) وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، لِأَنَّ

(745) أي محمد رحمه الله.

(746) أي على موجب يده.

(747) قيد بالموت في وجوب مهر المثل، لأنه لو لم يمت، فتزوجها على اليد، صحت التسمية، ويصير أرش ذلك، وهو خمسة آلاف درهم مهرا لها بالإجماع، سواء كان القطع عمداً أو خطأ، تزوجها على القطع، أو على القطع وما يحدث عنه، أو على الجنابة، لأنه لما برأ تبين أن موجبها

الْعَفْوُ عَنِ الْيَدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَفْوًا عَمَّا يَحْدُثُ مِنْهُ عِنْدَهُ فَالْتَزَوْجُ عَلَى الْيَدِ لَا يَكُونُ تَزَوُّجًا عَلَى مَا يَحْدُثُ مِنْهُ. ثُمَّ الْقَطْعُ إِذَا كَانَ عَمْدًا يَكُونُ هَذَا تَزَوُّجًا عَلَى الْقِصَاصِ فِي الطَّرَفِ وَهُوَ لَيْسَ بِمَالٍ فَلَا يَصْلُحُ مَهْرًا، لَا سِيَّمَا عَلَى تَقْدِيرِ السُّقُوطِ فَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ، وَعَلَيْهَا الدِّيَّةُ فِي مَالِهَا لِأَنَّ التَّزَوُّجَ وَإِنْ كَانَ يَتَضَمَّنُ الْعَفْوَ عَلَى مَا نُبَيِّنُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى لَكِنْ عَنِ الْقِصَاصِ فِي الطَّرَفِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ (748)، وَإِذَا سَرَى (749) تَبَيَّنَ أَنَّهُ قَتْلُ النَّفْسِ (750) وَلَمْ يَتَنَاوَلْهُ الْعَفْوُ فَتَجِبُ الدِّيَّةُ وَتَجِبُ فِي مَالِهَا لِأَنَّهُ عَمْدٌ (751). وَالْقِيَاسُ أَنْ يَجِبَ الْقِصَاصُ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ (752). وَإِذَا وَجِبَ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ وَعَلَيْهَا الدِّيَّةُ تَقَعُ الْمُقَاصَّةُ (753) إِنْ كَانَا عَلَى السَّوَاءِ، وَإِنْ كَانَ فِي الدِّيَّةِ فَضْلٌ تَرُدُّهُ (754) عَلَى الْوَرَثَةِ (755)، وَإِنْ كَانَ فِي الْمَهْرِ فَضْلٌ يَرُدُّهُ الْوَرَثَةُ عَلَيْهَا، وَإِذَا كَانَ الْقَطْعُ خَطَأً يَكُونُ هَذَا تَزَوُّجًا عَلَى أَرْضِ الْيَدِ، وَإِذَا سَرَى إِلَى النَّفْسِ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَا أَرْضَ لِلْيَدِ وَأَنَّ الْمُسَمَّى مَعْدُومٌ فَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ، كَمَا إِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى مَا فِي الْيَدِ وَلَا شَيْءَ فِيهَا. وَلَا يَتَقَاصَّنِ لِأَنَّ الدِّيَّةَ تَجِبُ عَلَى الْعَاقِلَةِ فِي الْخَطَأِ وَالْمَهْرِ لَهَا.

46-تَزَوَّجَهَا عَلَى الْيَدِ وَمَا يَحْدُثُ مِنْهَا أَوْ عَلَى الْجَنَايَةِ ثُمَّ مَاتَ مِنْ ذَلِكَ وَالْقَطْعُ عَمْدٌ قَالَ (756): (وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى الْيَدِ وَمَا يَحْدُثُ مِنْهَا أَوْ عَلَى الْجَنَايَةِ ثُمَّ مَاتَ مِنْ ذَلِكَ وَالْقَطْعُ عَمْدٌ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا) لِأَنَّ هَذَا تَزَوُّجٌ عَلَى الْقِصَاصِ وَهُوَ لَا يَصْلُحُ مَهْرًا فَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ، وَصَارَ كَمَا إِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى خَمْرِ أَوْ خِنْزِيرٍ وَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَيْهَا (757)، لِأَنَّهُ

الأرض دون القصاص، لأن القصاص لا يجري في الأطراف بين الرجل والمرأة، والأرض يصلح صداقا، كذا ذكره الإمام قاضي خان والمحجوبي. البناية 139/13.

(748) أي العمد.

(749) أي القطع.

(750) لا قطع اليد.

(751) فلا يتحملها العاقلة.

(752) من أنه هو الموجب للعمد.

(753) تقع المقاصة {بين دية الزوج ومهر المرأة} أي إذا حلت الدية لا في الحال، لتأجيل الدية وحلول مهر المثل.

(754) المرأة.

(755) ورثة الزوج.

(756) أي محمد رحمه الله.

(757) أي لا دية ولا قصاص.

لَمَّا جَعَلَ الْقِصَاصَ مَهْرًا فَقَدْ رَضِيَ بِسُقُوطِهِ بِجَهَةِ الْمَهْرِ فَيَسْقُطُ أَصْلًا كَمَا إِذَا أَسْقَطَ
الْقِصَاصَ بِشَرْطِ أَنْ يَصِيرَ مَالًا فَإِنَّهُ يَسْقُطُ أَصْلًا

(وَأِنْ كَانَ (758) خَطَأً (759) يُرْفَعُ (760) عَنِ الْعَاقِلَةِ مَهْرُ مِثْلِهَا (761)، وَلَهُمْ ثُلُثُ مَا تَرَكَ
وَصِيَّةً (762)) لِأَنَّ هَذَا (763) تَزْوُجٌ عَلَى الدِّيَةِ (764) وَهِيَ تَصْلُحُ مَهْرًا (765) إِلَّا
أَنَّهُ (766) يُعْتَبَرُ بِقَدْرِ مَهْرِ الْمِثْلِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ لِأَنَّهُ مَرِيضٌ مَرَضَ الْمَوْتِ وَالتَّزْوُجُ مِنْ
الْحَوَائِجِ الْأَصْلِيَّةِ وَلَا يَصِحُّ فِي حَقِّ الزِّيَادَةِ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ لِأَنَّهُ مُحَابَاةٌ فَيَكُونُ وَصِيَّةً فَيُرْفَعُ
عَنِ الْعَاقِلَةِ لِأَنَّهُمْ يَتَحَمَّلُونَ عَنْهَا، فَمِنْ الْمُحَالِ أَنْ تَرْجِعَ عَلَيْهِمْ بِمُوجِبِ جَنَائِثِهَا، وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ
وَصِيَّةٌ لَهُمْ لِأَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ الْوَصِيَّةِ لَمَّا أَنَّهُمْ لَيْسُوا بِقَتْلَةٍ، فَإِنْ كَانَتْ تَخْرُجُ مِنَ الثُّلُثِ تَسْقُطُ،
وَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ يَسْقُطُ ثُلُثُهُ. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: كَذَلِكَ الْجَوَابُ فِيمَا إِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى الْيَدِ،
لِأَنَّ الْعَفْوَ عَنِ الْيَدِ عَفْوٌ عَمَّا يَحْدُثُ مِنْهُ عِنْدَهُمَا فَاتَّفَقَ جَوَابُهُمَا فِي الْفَصْلَيْنِ.

47-قُطِعَتْ يَدُهُ فَأَقْنَصَ لَهُ مِنَ الْيَدِ ثُمَّ مَاتَ (767)

(758) قطع.

(759) فيجب الدية له على عاقلتها.

(760) أي يسقط.

(761) أي قدر مهر المثل.

(762) يعني أن الزائد على مهر مثلها يكون وصية في حق العاقلة، فينظر بعد إسقاط مهر المثل،
إن كان للميت، وهو الزوج مال سوى الزائد على مهر المثل، والزائد يخرج من الثلث يكون
للعاقلة، وإن لم يكن مال يأخذ العاقلة ثلث الزائد على مهر المثل، والثلثان لورثة الزوج.

(763) تزوج

(764) لأنها مال

(765) عفو

(766) محاباة

(767) اختلف الفقهاء فمن قُطِعَتْ يَدُهُ فَأَقْنَصَ لَهُ مِنَ الْيَدِ ثُمَّ مَاتَ عَلَى قَوْلَيْنِ: القول الأول: ذهب إلى
أَنْ مَنْ قُطِعَتْ يَدُهُ فَأَقْنَصَ لَهُ مِنَ الْيَدِ ثُمَّ مَاتَ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ الْمُقْتَصُّ مِنْهُ، لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّ الْجَنَائِةَ كَانَتْ قَتْلَ
عَمْدٍ وَحَقُّ الْمُقْتَصِّ لَهُ الْقَوْدُ، وَاسْتِيفَاءُ الْقَطْعِ لَا يُوجِبُ سُقُوطَ الْقَوْدِ كَمَا كَانَ لَهُ الْقَوْدُ إِذَا اسْتَوْفَى
طَرَفَ مَنْ عَلَيْهِ الْقَوْدُ.

القول الثاني: ذهب أبو يُوسُفَ إلى أَنَّهُ يَسْقُطُ حَقُّهُ فِي الْقِصَاصِ، لِأَنَّهُ لَمَّا أَقْدَمَ عَلَى الْقَطْعِ فَقَدْ أَبْرَأَهُ
عَمَّا وَرَاءَهُ.

ويجاب عليه: إِنَّمَا أَقْدَمَ عَلَى الْقَطْعِ ظَنًّا مِنْهُ أَنَّ حَقَّهُ فِيهِ وَبَعْدَ السَّرَايَةِ تَبَيَّنَ أَنَّهُ فِي الْقَوْدِ فَلَمْ يَكُنْ
مُبْرِنًا عَنْهُ بِدُونِ الْعِلْمِ بِهِ.

قَالَ(768): (وَمَنْ قُطِعَتْ يَدُهُ(769) فَاقْتَصَرَ لَهُ مِنَ الْيَدِ ثُمَّ مَاتَ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ الْمُقْتَصِّرُ مِنْهُ) لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّ الْجَنَائِيَّةَ كَانَتْ قَتَلَ عَمْدٍ وَحَقُّ الْمُقْتَصِّرِ لَهُ الْقَوْدُ، وَاسْتِيفَاءُ الْقَطْعِ لَا يُوجِبُ سُقُوطَ الْقَوْدِ كَمَا كَانَ لَهُ الْقَوْدُ إِذَا اسْتَوْفَى طَرَفَ مَنْ عَلَيْهِ الْقَوْدُ. وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يَسْقُطُ حَقُّهُ فِي الْقِصَاصِ، لِأَنَّهُ لَمَّا أَقْدَمَ عَلَى الْقَطْعِ فَقَدْ أَبْرَأَهُ عَمَّا وَرَاءَهُ. وَنَحْنُ نَقُولُ: إِنَّمَا أَقْدَمَ عَلَى الْقَطْعِ ظَنًّا مِنْهُ أَنَّ حَقَّهُ فِيهِ وَبَعْدَ السَّرَايَةِ تَبَيَّنَ أَنَّهُ فِي الْقَوْدِ فَلَمْ يَكُنْ مُبْرَأًا عَنْهُ بِدُونِ الْعِلْمِ بِهِ.

48-مَنْ قَتَلَ وَلِيَّهِ عَمْدًا فَقَطَعَ يَدَ قَاتِلِهِ ثُمَّ عَفَا

قَالَ(770): (وَمَنْ قَتَلَ وَلِيَّهِ عَمْدًا فَقَطَعَ(771) يَدَ قَاتِلِهِ ثُمَّ عَفَا(772) وَقَدْ قُضِيَ لَهُ بِالْقِصَاصِ أَوْ لَمْ يُقْضَ فَعَلَى قَاطِعِ الْيَدِ دِيَّةُ الْيَدِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَالَا: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ) لِأَنَّهُ اسْتَوْفَى حَقَّهُ فَلَا يَضْمَنُهُ، وَهَذَا لِأَنَّهُ اسْتَحَقَّ إِتْلَافَ النَّفْسِ بِجَمِيعِ أَجْزَائِهَا، وَلِهَذَا لَوْ لَمْ يَعْفُ لَا يَضْمَنُهُ، وَكَذَا (773) إِذَا سَرَى(774) وَمَا بَرَأَ(775) أَوْ مَا عَفَا وَمَا سَرَى، أَوْ قَطَعَ ثُمَّ حَزَّ رَقَبَتَهُ قَبْلَ الْبُرْءِ أَوْ بَعْدَهُ وَصَارَ كَمَا إِذَا كَانَ لَهُ قِصَاصٌ فِي الطَّرَفِ فَقَطَعَ أَصَابِعَهُ ثُمَّ عَفَا لَا يَضْمَنُ الْأَصَابِعَ. وَلَهُ أَنَّهُ اسْتَوْفَى غَيْرَ حَقِّهِ، لِأَنَّ حَقَّهُ فِي الْقَتْلِ. وَهَذَا قَطْعٌ وَإِبَانَةٌ، وَكَانَ الْقِيَاسُ أَنْ يَجِبَ الْقِصَاصُ إِلَّا أَنَّهُ سَقَطَ لِلشُّبْهَةِ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يُتْلَفَهُ تَبَعًا، وَإِذَا سَقَطَ وَجَبَ الْمَالُ، وَإِنَّمَا لَا يَجِبُ فِي الْحَالِ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَصِيرَ قَتْلًا بِالسَّرَايَةِ فَيَكُونُ مُسْتَوْفِيًا حَقَّهُ، وَمِلْكُ الْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ ضَرُورِيٌّ لَا يَظْهَرُ إِلَّا عِنْدَ الْإِسْتِيفَاءِ أَوْ الْعَفْوِ أَوْ الْإِعْتِيَاظِ لِمَا أَنَّهُ تَصَرَّفَ فِيهِ، فَأَمَّا قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ يَظْهَرْ لِعَدَمِ الضَّرُورَةِ بِخِلَافِ مَا إِذَا سَرَى لِأَنَّهُ اسْتِيفَاءٌ. وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَعْفُ وَمَا سَرَى، فَلُنَّا: إِنَّمَا يَتَبَيَّنُ كَوْنُهُ قَطْعًا بِغَيْرِ حَقٍّ بِالْبُرْءِ حَتَّى لَوْ قَطَعَ وَمَا عَفَا وَبَرَأَ الصَّحِيحُ أَنَّهُ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ، وَإِذَا قَطَعَ ثُمَّ حَزَّ رَقَبَتَهُ قَبْلَ الْبُرْءِ فَهُوَ اسْتِيفَاءٌ وَلَوْ

(768)أي محمد رحمه الله.

(769)عمدا.

(770)أي محمد رحمه الله.

(771)عمدا

(772)أي أبرأ القاطع القاتل عن القصاص.

(773)أي قطع اليد

(774)وعفا

(775)تأكيد لقوله: سرى.

حَزَّ بَعْدَ الْبُرِّ فَهُوَ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ هُوَ الصَّحِيحُ، وَالْأَصَابِعُ وَإِنْ كَانَتْ تَابِعَةً قِيَامًا بِالْكَفِّ
فَالْكَفُّ تَابِعَةٌ لَهَا غَرَضًا، بِخِلَافِ الطَّرَفِ لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ لِلنَّفْسِ مِنْ كُلِّ وَجْهِ.

49-سرت الجناية إلى النفس بعد استيفاء القصاص من الطرف(776)

قَالَ: (وَمَنْ لَهُ الْقِصَاصُ فِي الطَّرَفِ إِذَا اسْتَوْفَاهُ ثُمَّ سَرَى إِلَى النَّفْسِ وَمَاتَ يَضْمَنُ دِيَةَ النَّفْسِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا: لَا يَضْمَنُ) لِأَنَّهُ اسْتَوْفَى حَقَّهُ وَهُوَ الْقَطْعُ، وَلَا يُمَكِّنُ التَّقْيِيدُ بِوَصْفِ السَّلَامَةِ لِمَا فِيهِ مِنْ سَدِّ بَابِ الْقِصَاصِ، إِذِ الْإِحْتِرَازُ عَنِ السَّرَايَةِ لَيْسَ فِي وَسْعِهِ فَصَارَ كَالْإِمَامِ (777) وَالْبَزَّازِ وَالْحَجَّامِ وَالْمَأْمُورِ بِقَطْعِ الْيَدِ (778). وَلَهُ أَنَّهُ قَتْلٌ بِغَيْرِ حَقٍّ لِأَنَّ حَقَّهُ فِي الْقَطْعِ وَهَذَا وَقَعَ قَتْلًا وَلِهَذَا لَوْ وَقَعَ ظُلْمًا كَانَ قَتْلًا. وَلِأَنَّهُ جُرْحٌ أَفْضَى إِلَى فَوَاتِ الْحَيَاةِ فِي مَجْرَى الْعَادَةِ وَهُوَ مُسَمًّى الْقَتْلِ، إِلَّا أَنَّ الْقِصَاصَ سَقَطَ لِلشُّبْهَةِ فَوَجَبَ الْمَالُ بِخِلَافِ مَا اسْتَشْهَدَا بِهِ مِنَ الْمَسَائِلِ إِلَّا أَنَّهُ مُكَلَّفٌ فِيهَا بِالْفِعْلِ، إِمَّا تَقْلُدًا كَالْإِمَامِ أَوْ عَقْدًا كَمَا فِي غَيْرِهِ مِنْهَا.

وَالْوَاجِبَاتُ لَا تَتَقَيَّدُ بِوَصْفِ السَّلَامَةِ كَالرَّمِيِّ إِلَى الْحَرْبِيِّ، وَفِيمَا نَحْنُ فِيهِ لَا التَّزَامَ وَلَا وَجُوبَ، إِذْ هُوَ مَنْدُوبٌ إِلَى الْعَفْوِ فَيَكُونُ مِنْ بَابِ الْإِطْلَاقِ فَاشْبَهَ الْإِصْطِيَادَ.

(776) اختلف الفقهاء فمن له القصاص في الطرف إذا استوفاه ثم سرى إلى النفس ومات على قولين:

القول الأول: قال أبو حنيفة رحمه الله- من له القصاص في الطرف إذا استوفاه ثم سرى إلى النفس ومات يضمن دية النفس. القول الثاني: قال صاحبان: من له القصاص في الطرف إذا استوفاه ثم سرى إلى النفس ومات لا يضمن، لأنه استوفى حقه وهو القطع، ولا يمكن التقيد بوصف السلامة لما فيه من سد باب القصاص، إذ الاحتراز عن السراية ليس في وسعه فصار كالإمام والبزاز والحجّام والمأمور بقطع اليد.

واستدل لأبي حنيفة بأنه قتلٌ بغير حقٍّ لأنَّ حقه في القطع وهذا وقع قتلًا ولهذا لو وقع ظلمًا كان قتلًا. ولأنَّه جرحٌ أفصى إلى فوات الحياة في مجرى العادة وهو مسمى القتل، إلا أنَّ القصاص سقط للشبهة فوجب المال بخلاف ما استشهدا به من المسائل إلا أنَّه مكلفٌ فيها بالفعل.

(777) أي القاضي إذا قطع يد السارق فمات من ذلك فإنه لا شيء عليه.

(778) كما إذا قال أقطع يدي ففعل فمات لا شيء على القاطع.

50-(بَابُ الشَّهَادَةِ فِي الْقَتْلِ) (779)

قَالَ(780): (وَمَنْ قُتِلَ(781) وَلَهُ ابْنَانِ حَاضِرٌ وَغَائِبٌ فَأَقَامَ الْحَاضِرُ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْقَتْلِ ثُمَّ قَدِمَ الْغَائِبُ فَإِنَّهُ يُعِيدُ الْبَيِّنَةَ) عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَالَا: لَا يُعِيدُ (وَإِنْ كَانَ خَطَاً لَمْ يُعِدْهَا بِالْإِجْمَاعِ) وَكَذَلِكَ الدَّيْنُ يَكُونُ لِأَبِيهِمَا عَلَى آخَرٍ. لَهُمَا فِي الْخِلَافَةِ أَنَّ الْقِصَاصَ طَرِيقُ الْوَرَاثَةِ كَالدَّيْنِ، وَهَذَا لِأَنَّهُ عَوَضٌ عَنْ نَفْسِهِ فَيَكُونُ الْمَلِكُ فِيهِ لِمَنْ لَهُ الْمَلِكُ فِي الْمَعْوِضِ كَمَا فِي الدِّيَةِ، وَلِهَذَا لَوْ انْقَلَبَ مَا لَا يَكُونُ لِلْمَيِّتِ، وَلِهَذَا يَسْقُطُ بِعَفْوِهِ بَعْدَ الْجَرْحِ قَبْلَ الْمَوْتِ فَيَنْتَصِبُ أَحَدُ الْوَرَثَةِ خَصْماً عَنِ الْبَاقِينَ. وَلَهُ أَنَّ الْقِصَاصَ طَرِيقُ الْخِلَافَةِ دُونَ الْوَرَاثَةِ؛ أَلَا تَرَى أَنَّ مَلِكَ الْقِصَاصِ يَثْبُتُ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْمَيِّتُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ، بِخِلَافِ الدَّيْنِ وَالْدِّيَةِ لِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْمَلِكِ فِي الْأَمْوَالِ، كَمَا إِذَا نَصَبَ شَبَكَةً فَتَعَلَّقَ بِهَا صَيْدٌ بَعْدَ مَوْتِهِ فَإِنَّهُ يَمْلِكُهُ، وَإِذَا كَانَ طَرِيقُهُ الْإِثْبَاتِ ابْتِدَاءً لَا يَنْتَصِبُ أَحَدُهُمْ خَصْماً عَنِ الْبَاقِينَ فَيُعِيدُ الْبَيِّنَةَ بَعْدَ حُضُورِهِ (فَإِنْ كَانَ أَقَامَ الْقَاتِلُ الْبَيِّنَةَ أَنَّ الْغَائِبَ قَدْ عَفَا فَالشَّاهِدُ خَصْماً وَيَسْقُطُ الْقِصَاصُ) لِأَنَّهُ ادَّعَى عَلَى الْحَاضِرِ سُقُوطَ حَقِّهِ فِي الْقِصَاصِ إِلَى مَالٍ، وَلَا يُمَكِّنُهُ إِبْتِائُهُ إِلَّا بِإِثْبَاتِ الْعَفْوِ مِنَ الْغَائِبِ فَيَنْتَصِبُ الْحَاضِرُ خَصْماً عَنِ الْغَائِبِ (وَكَذَلِكَ عَبْدٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ قُتِلَ عَمْدًا وَاحِدُ الرَّجُلَيْنِ غَائِبٌ فَهُوَ عَلَى هَذَا) لِمَا بَيَّنَّاهُ. (782)

(779) لما كان القتل بعد تحققه ربما يجحد، فيحتاج من له القصاص إلى إثباته بالبينة، فبين الشهادة فيه باب على حدة.
(780) أي محمد رحمه الله.
(781) عمدا

(782) (وَمَنْ قُتِلَ وَلَهُ ابْنَانِ حَاضِرٌ وَغَائِبٌ فَأَقَامَ الْحَاضِرُ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْقَتْلِ ثُمَّ قَدِمَ الْغَائِبُ فَالْقَتْلُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ خَطَاً أَوْ عَمْدًا، فَإِنْ كَانَ خَطَاً فَلَا يُعِيدُ بِالْإِجْمَاعِ، وَإِنْ كَانَ عَمْدًا فَلِلْفُقَهَاءِ قَوْلَانِ: الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: ذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّهُ يُعِيدُ الْبَيِّنَةَ، لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ اسْتِيفَاءَ الْقِصَاصِ حَقُّ الْوَرَثَةِ عِنْدَهُ الْقَوْلُ الثَّانِي: ذَهَبَ الصَّاحِبَانِ إِلَى أَنَّهُ لَا يُعِيدُ، لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ اسْتِيفَاءَ الْقِصَاصِ حَقُّ الْمُورِثِ عِنْدَهُمَا. وَكَذَلِكَ الدَّيْنُ يَكُونُ لِأَبِيهِمَا عَلَى آخَرٍ، وَلَيْسَ لِأَبِي حَنِيفَةَ تَمَسُّكٌ بِصِحَّةِ الْعَفْوِ مِنَ الْوَارِثِ حَالِ حَيَاةِ الْمُورِثِ اسْتِحْسَانًا، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُمَا ذَلِكَ بِصِحَّةِ الْعَفْوِ مِنَ الْمُورِثِ الْمَجْرُوحِ اسْتِحْسَانًا لِلدَّفَاعِ. وَالْقِيَاسُ عَدَمُ الْجَوَازِ، أَمَّا مِنْ جِهَةِ الْمُورِثِ فَلِأَنَّ الْقَتْلَ لَمْ يُوجَدْ بَعْدُ، وَأَمَّا مِنْ جِهَةِ الْوَارِثِ فَلَوْفَوْعِهِ قَبْلَ ثُبُوتِ حَقِّهِ. وَوَجْهُ الاسْتِحْسَانِ أَنَّ السَّبَبَ قَدْ تَحَقَّقَ فَصَحَّ مِنْ كُلِّ مِنْهُمَا لِذَلِكَ، وَإِذَا ظَهَرَ ذَلِكَ ظَهَرَ وَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ الْقِصَاصَ طَرِيقُ الْوَرَاثَةِ كَالدَّيْنِ، وَمَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ الدَّيْنِ، وَحُكْمُهُ أَنْ يَنْتَصِبَ أَحَدُ الْوَرَثَةِ خَصْماً عَنِ الْبَاقِينَ، وَاسْتَدَلَّ لَهُمَا عَلَى أَنَّ طَرِيقَهُ طَرِيقُ الْوَرَاثَةِ بِقَوْلِهِ وَهَذَا لِأَنَّهُ عَوَضٌ نَفْسٍ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة: 45] فَيَكُونُ الْمَلِكُ فِيهِ لِمَنْ لَهُ الْمَلِكُ فِي الْمَعْوِضِ كَمَا فِي الدِّيَةِ، وَلِهَذَا لَوْ انْقَلَبَ مَا لَا يَكُونُ لِلْمَيِّتِ نُفْضَى بِهِ دِيُونُهُ وَتُنْفَقُ مِنْهُ وَصَايَاهُ. وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ طَرِيقَهُ طَرِيقُ الْخِلَافَةِ، وَهُوَ أَنْ يَثْبُتَ لِمَنْ

51-كَانَ الْأَوْلِيَاءُ ثَلَاثَةً فَشَهِدَ اثْنَانِ مِنْهُم عَلَى الْآخَرِ أَنَّهُ قَدْ عَفَا

قَالَ(783): (فَإِنْ كَانَ الْأَوْلِيَاءُ ثَلَاثَةً فَشَهِدَ اثْنَانِ مِنْهُم عَلَى الْآخَرِ أَنَّهُ قَدْ عَفَا(784) فَشَهِدَتْهُمَا بَاطِلَةٌ وَهُوَ عَفُوٌّ مِنْهُمَا(785)) لِأَنَّهُمَا يَجْرَانِ(786) بِشَهَادَتِهِمَا إِلَى أَنْفُسِهِمَا مَعْنًا وَهُوَ انْقِلَابُ الْقَوْدِ مَالًا (فَإِنْ صَدَّقَهُمَا الْقَاتِلُ فَالِدِّيَّةُ بَيْنَهُمْ أَثَلَاثًا) مَعْنَاهُ: إِذَا صَدَّقَهُمَا وَحْدَهُ، لِأَنَّهُ لَمَّا صَدَّقَهُمَا فَقَدْ أَقَرَّ بِتُلْنِي الدِّيَّةِ لَهُمَا فَصَحَّ إِفْرَارُهُ، إِلَّا أَنَّهُ يَدَّعِي سُقُوطَ حَقِّ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ وَهُوَ يُنْكِرُ فَلَا يُصَدِّقُ وَيَعْرَمُ نَصِيبَهُ (وَإِنْ كَذَّبَهُمَا فَلَا شَيْءَ لَهُمَا وَلِلْآخَرِ ثُلُثُ الدِّيَّةِ) وَمَعْنَاهُ: إِذَا كَذَّبَهُمَا الْقَاتِلُ أَيْضًا، وَهَذَا لِأَنَّهُمَا أَقَرَّا عَلَى أَنْفُسِهِمَا بِسُقُوطِ الْقِصَاصِ فَقَبِلَ وَادَّعَى انْقِلَابَ نَصِيبِهِمَا مَالًا فَلَا يُقْبَلُ إِلَّا بِحُجَّةٍ، وَيَنْقَلِبُ نَصِيبُ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ مَالًا لِأَنَّ دَعْوَاهُمَا الْعَفْوُ عَلَيْهِ وَهُوَ يُنْكِرُ بِمَنْزِلَةِ ابْتِدَاءِ الْعَفْوِ مِنْهُمَا فِي حَقِّ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ، لِأَنَّ سُقُوطَ الْقَوْدِ مُضَافٌ إِلَيْهِمَا، وَإِنْ صَدَّقَهُمَا الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ وَحْدَهُ غَرِمَ الْقَاتِلُ ثُلُثَ الدِّيَّةِ لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ لِإِقْرَارِهِ لَهُ بِذَلِكَ.

52-شَهِدَ الشُّهُودُ أَنَّهُ ضَرَبَهُ فَلَمْ يَزَلْ صَاحِبُ فِرَاشٍ حَتَّى مَاتَ

قَالَ(787): (وَإِذَا شَهِدَ الشُّهُودُ أَنَّهُ ضَرَبَهُ فَلَمْ يَزَلْ صَاحِبُ فِرَاشٍ حَتَّى مَاتَ فَعَلَيْهِ الْقَوْدُ إِذَا كَانَ عَمْدًا) لِأَنَّ الثَّابِتَ بِالشَّهَادَةِ كَالثَّابِتِ مُعَايِنَةً، وَفِي ذَلِكَ الْقِصَاصُ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ،(788) وَالشَّهَادَةُ عَلَى قَتْلِ الْعَمْدِ تَتَحَقَّقُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ، لِأَنَّ الْمَوْتَ بِسَبَبِ الضَّرْبِ إِنَّمَا يُعْرَفُ إِذَا صَارَ بِالضَّرْبِ صَاحِبُ فِرَاشٍ حَتَّى مَاتَ، وَتَأْوِيلُهُ إِذَا شَهِدُوا أَنَّهُ ضَرَبَهُ بِشَيْءٍ جَارِحٍ.

يَحْلِفُ ابْتِدَاءً، كَالْعَبْدِ إِذَا اتَّهَبَ فَإِنَّهُ يَتَّبِعُ الْمَلِكَ لِلْمَوْلَى ابْتِدَاءً بِطَرِيقِ الْخِلَافَةِ لِأَنَّ الْعَبْدَ لَيْسَ بِأَهْلٍ لِلْمَلِكِ، كَمَا أَنَّ الْمَيِّتَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْقِصَاصِ لِكُونِهِ مَلَكٌ الْفِعْلُ وَلَا يُتَصَوَّرُ الْفِعْلُ مِنَ الْمَيِّتِ وَالْوَرَاثَةُ هُوَ أَنْ يَتَّبِعَ الْمَلِكُ لِلْمُورِثِ ابْتِدَاءً ثُمَّ لِلْوَارِثِ.

(783)أي محمد رحمه الله.

(784)عن القصاص.

(785)لأنهما بالشهادة زعما أن القود قد سقط، وزعمهما يعتبر في حقهما.

(786)تعليل لقوله: فشهادتهما باطلة.

(787)أي محمد رحمه الله.

(788)في كتاب الجنایات

53-اختلف شاهد القتل في الأيام أو في البلد أو في الذي كان به القتل

قَالَ(789): (وَإِذَا اختلفَ شاهدُ القتلِ في الأيامِ أو في البلدِ أو في الذي كان به القتلُ فهو باطلٌ) لِأَنَّ القتلَ لَا يُعَادُ وَلَا يُكْرَرُ، وَالْقَتْلُ فِي زَمَانٍ أَوْ فِي مَكَانٍ غَيْرِ الْقَتْلِ فِي زَمَانٍ أَوْ مَكَانٍ آخَرَ، وَالْقَتْلُ بِالْعَصَا غَيْرُ الْقَتْلِ بِالسَّلَاحِ لِأَنَّ الثَّانِيَّ عَمْدٌ وَالْأَوَّلَ شِبْهُ الْعَمْدِ، وَيَخْتَلِفُ أَحْكَامُهُمَا فَكَانَ عَلَى كُلِّ قَتْلِ شَهَادَةٌ فَرَدٌّ (وَكَذَا إِذَا قَالَ أَحَدُهُمَا: قَتَلَهُ بِعَصَا وَقَالَ الْآخَرُ لَا أَدْرِي بِأَيِّ شَيْءٍ قَتَلَهُ فَهُوَ بَاطِلٌ) لِأَنَّ الْمُطْلَقَ يُغَايِرُ الْمُقَيَّدَ.(790)

55-أقرَّ رجلانِ كلُّ واحدٍ منهما أَنَّهُ قَتَلَ فُلَانًا

قَالَ(791): (وَإِذَا أَقَرَّ رَجُلَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهُ قَتَلَ فُلَانًا فَقَالَ الْوَلِيُّ: قَتَلْتُمَاهُ جَمِيعًا فَلَهُ أَنْ يَقْتُلَهُمَا، وَإِنْ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ قَتَلَ فُلَانًا وَشَهِدَ آخَرُونَ عَلَى آخَرَ بِقَتْلِهِ وَقَالَ الْوَلِيُّ: قَتَلْتُمَاهُ جَمِيعًا بَطَلَ ذَلِكَ كُلُّهُ) وَالْفَرْقُ أَنَّ الْإِقْرَارَ وَالشَّهَادَةَ يَتَنَاوَلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَجُودَ كُلِّ الْقَتْلِ وَوُجُوبَ الْقِصَاصِ، وَقَدْ حَصَلَ التَّكْذِيبُ فِي الْأُولَى مِنَ الْمُقَرِّ لَهُ وَفِي الثَّانِيَةِ مِنَ الْمَشْهُودِ لَهُ، غَيْرَ أَنَّ تَكْذِيبَ الْمُقَرِّ لَهُ الْمُقَرِّ فِي بَعْضٍ مَا أَقَرَّ بِهِ لَا يُبْطِلُ إِقْرَارَهُ فِي الْبَاقِي، وَتَكْذِيبُ الْمَشْهُودِ لَهُ الشَّاهِدَ فِي بَعْضٍ مَا شَهِدَ بِهِ يُبْطِلُ شَهَادَتَهُ أَصْلًا، لِأَنَّ التَّكْذِيبَ تَفْسِيقٌ وَفَسْقُ الشَّاهِدِ يَمْنَعُ الْقَبُولَ، أَمَّا فِسْقُ الْمُقَرِّ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الْإِقْرَارِ. (792)

(789)أي محمد رحمه الله.

(790) فإن المطلق يوجب الدية في ماله، والمقيد بالعصا على العاقلة، لأنه يحتمل أن يكون عمداً، ويحتمل أن يكون شبه عمداً، ويحتمل أن يكون خطأً، والقتل بالعصا شبه عمداً، فلم يثبت الاتفاق في المشهود به، والاتفاق شرط.

(791)أي محمد رحمه الله.

(792)هاتان مسألتان مبناهما على أن تكذيب المقر له المقر في بعض ما أقرَّ به لا يبطل إقراره في الباقي، فإن من أقرَّ بألف درهم وصدقه المقر له في النصف وكذبه في النصف يصح الإقرار فيما صدقه، وتكذيب المشهود له الشاهد في بعض ما يشهد به يبطل شهادته أصلاً لكونه تفسيقاً له، وفسق الشاهد يمنع القبول، بخلاف فسق المقر وقيد بقوله في بعض ما أقرَّ به لأنه إذا أكذبه في كل ما أقرَّ به بطل الإقرار لأنه رد لإقراره، وعلى هذا لو قال المقر له بدل قوله قتلتما صدقتما لم يكن له أن يقتل واحداً منهما لأن معنى قوله صدقتما معنى قوله صدقت لكل واحدٍ منهما ومعناه أنت قتلت وحدك وفي ذلك تكذيب الآخر في الجميع وهو تكذيب لهما.

56-باب(793) اغْتِبَارِ حَالَةِ الْقَتْلِ

قَالَ(794): (وَمَنْ رَمَى مُسْلِمًا فَأَرْتَدَّ الْمَرْمِيُّ إِلَيْهِ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ ثُمَّ وَقَعَ بِهِ السَّهْمُ فَعَلَى الرَّامِي الدِّيَّةُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ. وَقَالَا: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ) لِأَنَّهُ بِالْإِرْتِدَادِ أَسْقَطَ تَقْوَمَ نَفْسِهِ فَيَكُونُ مُبْرَأًا لِلرَّامِي عَنْ مُوجِبِهِ كَمَا إِذَا أَبْرَأَهُ بَعْدَ الْجُرْحِ قَبْلَ الْمَوْتِ. وَلَهُ أَنَّ الضَّمَانَ يَجِبُ بِفِعْلِهِ وَهُوَ الرَّمْيُ إِذْ لَا فِعْلَ مِنْهُ بَعْدَ قُنْعَتِهِ حَالَةَ الرَّمْيِ وَالْمَرْمِيَّ إِلَيْهِ فِيهَا مُتَقَوِّمٌ. وَلِهَذَا تُعْتَبَرُ حَالَةُ الرَّمْيِ فِي حَقِّ الْحِلِّ حَتَّى لَا يَحْرُمَ بَرْدَةُ الرَّامِي بَعْدَ الرَّمْيِ، وَكَذَا فِي حَقِّ التَّكْفِيرِ حَتَّى جَازَ بَعْدَ الْجُرْحِ قَبْلَ الْمَوْتِ. وَالْفِعْلُ وَإِنْ كَانَ عَمْدًا فَالْقَوْدُ سَقَطَ لِلشُّبْهَةِ وَوَجِبَتْ الدِّيَّةُ. (795)

57-رَمَى إِلَيْهِ وَهُوَ مُرْتَدٌّ فَأَسْلَمَ

(وَلَوْ رَمَى إِلَيْهِ وَهُوَ مُرْتَدٌّ فَأَسْلَمَ ثُمَّ وَقَعَ بِهِ السَّهْمُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا، وَكَذَا إِذَا رَمَى حَرْبِيًّا فَأَسْلَمَ) لِأَنَّ الرَّمْيَ مَا انْعَقَدَ مُوجِبًا لِلضَّمَانِ لِعَدَمِ تَقْوَمِ الْمَحِلِّ فَلَا يَنْقَلِبُ مُوجِبًا لِيَصِيرُورَتِهِ مُتَقَوِّمًا بَعْدَ ذَلِكَ.

58-قُضِيَ عَلَيْهِ بِالرَّجْمِ فَرَمَاهُ رَجُلٌ ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُ الشُّهُودِ ثُمَّ وَقَعَ بِهِ الْحَجَرُ

(793)قوله:"باب" لما كانت الأحوال صفات لذواتها، ذكرها بعد ذكر نفس القتل وما يتعلق به.

(794)أي محمد رحمه الله.

(795)مَنْ رَمَى مُسْلِمًا فَأَرْتَدَّ الْمَرْمِيُّ إِلَيْهِ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ ثُمَّ وَقَعَ بِهِ السَّهْمُ فَلِلْفَقْهَاءِ قَوْلَانِ: الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: عَلَى الرَّامِي الدِّيَّةُ لَوَرْتَدَّ الْمُرْتَدُّ. الْقَوْلُ الثَّانِي: قَالَ الصَّاحِبَانِ: لَا شَيْءَ عَلَى الرَّامِي لِأَنَّهُ بِالْإِرْتِدَادِ أَسْقَطَ تَقْوَمَ نَفْسِهِ وَذَلِكَ إِبْرَاءٌ لِلضَّامِنِ، لِأَنَّ مَنْ أَخْرَجَ الْمُتَقَوِّمَ عَنِ التَّقْوَمِ سَقَطَ حَقُّهُ كَالْمَعْصُوبِ مِنْهُ إِذَا أَعْتَقَ الْمَعْصُوبَ فَإِنَّهُ صَارَ مُبْرَأًا لِلْعَاصِبِ عَنِ الضَّمَانِ بِإِسْقَاطِ حَقِّهِ وَصَارَ بِهِ مُبْرَأًا كَمَا إِذَا أَبْرَأَهُ الرَّامِي عَنِ الْجِنَايَةِ أَوْ حَقِّهِ بَعْدَ الْجُرْحِ أَيْ انْعِقَادِ سَبَبِهِ وَهُوَ الرَّامِي قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهُ السَّهْمُ. وَاسْتَدَلَّ لِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الضَّمَانَ يَجِبُ بِفِعْلِهِ وَهُوَ الرَّمْيُ إِذْ لَا فِعْلَ مِنْهُ بَعْدَهُ، وَمَا هُوَ كَذَلِكَ فَالْمُعْتَبَرُ فِيهِ وَقْتُ الْفِعْلِ كَالْعَصَبِ، فَيُعْتَبَرُ حَالَةُ الرَّمْيِ وَالْمَرْمِيَّ إِلَيْهِ فِيهَا مُتَقَوِّمٌ، وَاسْتَوْضَحَ اعْتِبَارَ وَقْتِ الرَّمْيِ بِمَا إِذَا رَمَى صَيِّدًا ثُمَّ ارْتَدَّ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ ثُمَّ أَصَابَ فَإِنَّ رِدَّتَهُ بَعْدَ الرَّمْيِ لَا تَحْرُمُ لِأَنَّ فِعْلَهُ ذِكَاةٌ شَرْعًا وَقَدْ تَمَّ مُوجِبًا لِلْحِلِّ بِشَرْطِهِ وَهُوَ التَّسْمِيَةُ، وَبِمَا إِذَا كَانَتْ الْجِنَايَةُ خَطَأً فَكَفَّرَ بَعْدَ الرَّمْيِ قَبْلَ الْإِصَابَةِ فَإِنَّهُ صَحِيحٌ.

قَالَ(796): (وَمَنْ قُضِيَ عَلَيْهِ بِالرَّجْمِ فَرَمَاهُ رَجُلٌ ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُ الشُّهُودِ ثُمَّ وَقَعَ بِهِ الْحَجَرُ فَلَا شَيْءَ عَلَى الرَّامِي) لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ حَالَةُ الرَّمِي وَهُوَ مُبَاحُ الدَّمِ فِيهَا.

الدراسة الموضوعية

جامعة الأزهر الشريف
كلية الشريعة والقانون بالقاهرة
قسم الفقه

وسائل الإثبات في الفقه الحنفي
للسنة الثالثة بكليات الشريعة والقانون والشعب المناظرة
إعداد

أ.د / عبدالمطلب عبدالرزاق حمدان
استاذ الفقه المتفرغ
بكلية الدراسات بالاسادات

أ.د / محمد عبدالستار الجبالي
استاذ الفقه المتفرغ
بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة

د / حسن علي الليثي

د / محمد سعيد الرملاوي

مدرس الفقه بكلية الدراسات بدمياط

أستاذ الفقه المساعد
بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله المعلم
الأمين الهادي إلى الحق وإلى الطريق المستقيم اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى
بهديه إلى يوم الدين.

وبعد ،،

فمن الموضوعات المقررة على طلاب الفرقة الثالثة بقسميها الإثبات في الفقه الإسلامي ، وقد قمنا
بمعالجة هذا الموضوع في تمهيد وأربعة فصول وخاتمة:

التمهيد : في مفهوم الإثبات الشرعي .

الفصل الأول : في الشهادة .

الفصل الثاني : في الإقرار .

الفصل الثالث : في اليمين .

الفصل الرابع : في الطرق الإجتهادية .

الفصل الخامس : في الحجر

الفصل السادس : في الرهن

المؤلفون

تمهيد

"مفهوم الإثبات الشرعي ، وبيان الوسائل التي يعتمد عليها القاضي عند نظر الدعوى"
الإثبات الشرعي معناه :

هو تثبت من يسند حقاً لنفسه أو لغيره يقره الشارع بناءً على دليل يتأكد منه ، أو يغلب على الظن أنه المظهر أو المبين لهذا الحق لمن يدعيه .
والإثبات في العادة والغالب لا يطلب إلا عند التنازع على حق "مابين اثنين فأكثر" ، وكل واحد يدعيه لنفسه دون غيره ، أو ينكره على من يدعيه أو يجوز من غيره ولو كان لا يدعيه لنفسه (1) .

ولما كان هذا الإثبات يطلب من كل مدع لهذا الحق والقاضي هو الذي يختص بفض النزاع ، فإن الأمر يتطلب أن يصل هذا النزاع إلى علم القاضي ، ومن هنا كان لابد من رفع دعوى قضائية حتى يحكم القاضي ويثبت على مقتضاها ، ولهذا يقتضي الحال أن نبدأ بتعريف الدعوى .

تعريف الدعوى :

في اللغة : تعني الطلب والتمني ، وتجمع على دعاوى بفتح الواو وكسر ها ، وهذا يشمل الدعوى إلى الله بمعنى الدعاء وطلب الحاجة منه سبحانه وتعالى ، كما يشمل دعوى الشيء أي ادعائه بمعنى ملكيته ، أو نسبته سواء نوزع فيه أو لم ينزاع (1) .

وشرعاً : هي إخبار عن وجوب حق على غيره عند حاكم يصح حكمه ، وقال ابن نجيم : هي إضافة الشيء إلى نفسه حالة المنازعة (2) .

أركان الدعوى : الركن هو ما لابد منه ، وكان جزءاً من حقيقة الشيء ، فالركوع مثلاً لابد منه في الصلاة ، وهو جزء من حقيقتها ، ولهذا يسمى ركناً من أركان الصلاة ، وأما إذا كان هذا الشيء لابد منه لكنه ليس جزءاً من الحقيقة بل خارجاً عنها ، فيسميه العلماء شرط كالوضوء لابد منه لصحة الصلاة لكنه ليس جزءاً من حقيقة الصلاة بل هو خارج عنها ، ولهذا فهو شرط من شروط صحة الصلاة وليس ركناً من أركانها (3) .

وأركانها كالتالي

1- مدعي 2- مدعى عليه 3- مدعى به

وتختلف عبارات الفقهاء في مفهوم المدعي والمدعى عليه .

فالمدعى : هو من لا يجبر على الخصومة إذا تركها .

والمدعى عليه : من إذا ترك الخصومة يجبر عليها .

وقيل المدعي : من يضيف إلى نفسه ماليس بثابت .

والمدعى عليه :- من يتمسك بما هو ثابت بظاهر اليد ، فلو أداه عن رجل ، فأدعى الوفاء أو البراءة

صار مدعياً لدعواه ماليس بثابت ، وهو فراغ ذمته بعد اتفاقها على الشغل .

وقيل المدعي : من لا يستحق إلا بحجة كالخارج .

والمدعى عليه : من يستحق بقوله من غير حجة كذي اليد .

(1) تبين الحقائق- شرح كنز الدقائق للزيلعي - ج 5 - ص 2 ، ونظرية الدعوى والإثبات في الفقه الإسلامي ، أ. د. نصر فريد محمد واصل - ص 6 - ط / دار الاتحاد العربي .

(1) المصباح المنير ج 2 ص 264 مادة " دعا " .

(2) البحر الرائق شرح كنز الدقائق ج 7 ص 191 .

(3) غاية الوصول إلى دقائق علم الوصول أ. د. جلال عبد الرحمن .

وقيل المدعي : من يضيف ما عند غيره إلى نفسه .

والمدعى عليه : ما يضيف ما عنده إلى نفسه ⁽¹⁾ .

ولا يخفى وضوح القول الأول والأخير ، وذلك لأن المدعى يطلب مافى يد غيره على أنه حقه ، وهو مجبر على التماذى في المطالبة به ، بخلاف المدعى عليه فهمو متمسك بما في يده ، وللمدعى أن يثبت أنه حقه بشتى أنواع الوسائل .

والدعوى بهذا المفهوم الذى أوردناه إذا صحت عند القاضى أوجبت على الخصم الحضور إلى مجلس القاضى قال تعالى (وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون) ⁽¹⁾ ، منهم الله تبارك وتعالى على ترك الحضور ، وهو الإعراض عن الإجابة .

وعن علي - رضي الله عنه - أن امرأة الوليد بن عقبة جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تستعدي على زوجها ، فأعادها ، فقالت أبى أن يجيء ، فأعطاه هدية من ثوبه فجاءت به ⁽²⁾ .

ولأن الناس يحضرون بمجرد دعوة الحاكم من لدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا هذا من غير تكبر ، فإذا حضر وادعى انكاراً فتسمع البينة عليه دفعا للضرر على المدعى إلا أن يكون أخرساً ⁽³⁾ .

والأصل فيها : ما روي عن النبي صل الله عليه وسلم - أنه قال : " لو ترك الناس لدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم ، ولكن البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه " ⁽⁴⁾ وفى رواية " واليمين على من أنكر "

ويروى : " أن حضرمياً وكندياً اختصما بين يدي رسول الله - صل الله عليه وسلم - في شىء ، فقال للمدعى : ألك بينة ؟ قال لا ، فقال : لك يمينه ليس غير ذلك " ⁽¹⁾ .

شروط صحة الدعوى :

يشترط لصحة الدعوى شروطاً بعضها يتعلق بالمدعى وقدرته على رفع الدعوى بنفسه ، وبعضها يتعلق بالمدعى عليه سواء كان شخصاً اعتبارياً - كالوقف - أو طبيعياً كالإنسان ، وبعضها يتعلق بالمدعى عليه .

وبيانها كالتالى :

⁽¹⁾ الهداية شرح بداية المبتدي ج 3 ص 155 ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ج 6 ص 224 ، والإختيار لتعليل المختار ص 154 / 155 ، البحر الرائق ج 7 ص 193 .

⁽¹⁾ سورة النور : آية رقم (48) .

⁽²⁾ بدائع الصنائع ج 6 ص 224 ، الهداية ج 3 ص 155 .

والإستعداد : يقال استدعيت الأمير على الظالم طلبت منه النصرة ، فالإستعداد : طلب التقوية والنصرة ، المصباح المنير ج ص 543 مادة (عدا) .

⁽³⁾ الإختيار لتعليل المختار ص 155 ، بدائع الصنائع ج 6 ص 222 .

⁽⁴⁾ الحديث متفق عليه ، والرواية الثانية للبيهقي سبل السلام ج 4 ص 132 .

⁽¹⁾ نصب الراية لتخريج أحاديث الهداية ج 4 ص 80 .

الشرط الأول : أن تكون الدعوى بشيء معلوم الجنس والقدر ، لأن الدعوى للإلزام ، والقضاء بالمجهول غير ممكن (2) .
والسبب في عدم صحة الدعوى بالمجهول :

أن القصد من رفع الدعوى إنما هو طلب فصل الخصومة بالحكم فيها طبقاً لإرادة المشرع ، والحكم عبارة عن إلزام بحق على كلا طرفي الخصومة كل منها قبل الآخر طبقاً لنظرية الحق والواجب في الفقه الإسلامي ، لأن كل حق لابد وأن يقابله واجب كما أن كل واجب لابد وأن يقابله حق ، ولا يمكن استيفاء ذلك الحق أو المطالبة بالإلزام بالواجب في أمر مجهول . ويستثنى من ذلك الوصية حيث جوزها الشارع معلوماً ومجهولاً حقاً على أن يتبرع الناس من أموالهم ، والمعلوم أن الوصية تبرع لما بعد الموت أي موت الموصي بحيث لا يعطى الموصى إليه الوصية إلا بعد موت الموصي فإن أعطيت له في حياة الموصي بناء على تصريح منه كان ذلك هبة أوتبرعاً حال الحياة (1) .

الشرط الثاني : أن يكون المدعى به مما يحتمل الثبوت وليبيان هذا الشرط نقول اشترط الفقهاء لصحة الدعوى أن يكون المدعى به قابلاً للثبوت بأن لا يكون مستحيلًا في الحس أو في العقل ، أو في العادة ، لأن الدعوى تكون في حال المستحيل الحسى والعقلى بغية الكذب فلا تحتمل الصدق بحال من الأحوال . **ومثال العقلى :** ادعائه أن شخصاً ابنه ، مع أنه لا يولد مثله لمثله كأن يكون المدعى فى الأربعين من عمره ، والمدعى بنوته في الخامسة والثلاثين من عمره ، فهذا الأمر عقلاً لا يتصور .

ومثال الحسى : ادعائه مثل الجبل ذهباً أو فضة ، فإن ادعى أنه أعطاه أو أخذ منه مثل هذا الجبل ذهباً ، فمثل هذه الدعوى لا يلتفت إليها ، لأن هذه القضية لا تتصور ، لأننا لم نسمع أو لم نر أن رجلاً يمتلك مثل الجبل ذهباً أو فضة فهي من المستحيلات .

ومثال العادى : ادعاء من هو مشهور بالفقر أنه أقرض آخر من ماله مائة ألف دينار ، ثم يطالبه ببذلها ، ومثل هذه الدعوى كما يرى بعض الفقهاء أنه لا يلتفت إليها ، والراجح هو النظر في مثل هذه الدعاوى والتحقيق فيها ، لأنه لا يخفى علينا أن هناك بعض المتسولين يموتون ويتركون أموالاً كثيرة من احترافهم لمهن التسول ، وتراهم على وجه الدنيا ملابسهم رثة لا يرى عليهم أثر الثراء (1) .

الشرط الثالث : أن تكون الدعوى في مجلس القضاء ، فإذا رفعت الدعوى في غير مجلس القضاء فلا تكون صحيحة بالقياس على الشهادة فإنها لا تسمع إلا أما القاضي (2) .

الشرط الرابع : أن تكون الدعوى بلسان المدعى أو وكيله وهو رأي الإمام (أبو حنيفة رحمه الله) إذا كان هناك عذر ، فإن لم يكن به عذر فيشترط أن تكون بلسانه .
ويرى صاحبان : أنه لا يشترط ذلك ، حتى لو وكل المدعى رجلاً بالخصومة من غير عذر ولم يرض به المدعى عليه تصح الدعوى ، ورأي صاحبان هو ما عليه الفتوى في المذهب الحنفي ،

(2) الهداية شرح بداية المبتدي ج3 ص155 ، الإختيار ص155 .

(1) البحر الرائق ج7 ص195 ، الدعوى والإثبات أ . د نصر فريد واصل ص10 .

(1) بدائع الصنائع ج6 ص222 ، البحر الرائق ج7 ص192 ، القضاء في الفقه الإسلامى أ . د رأفت عثمان ص118 .

(2) الهداية شرح بداية المبتدي ج3 ص155 ، بدائع الصنائع – ج 6 ص222 .

وهو مايجري عليه الأمر في المحاكم الآن⁽³⁾ من توكيل المحامين بدلاً من الخصم ويقوم المحامي بالتوكيل بالنظر في كل أمور الدعوى .

الشرط الخامس : تعيين المدعى عليه ، فيشترط أثناء رفع الدعوى من المدعي أن يذكر المدعى عليه ، باسمه فإن لم يعينه ، فتعتبر دعوته كأن لم تكن .

الشرط السادس : أن يكون المدعي مكلفاً ، أي يكون بالغاً عاقلاً ، وعلى هذا فلا تصح الدعوى من الصبي والمجنون لرفع القلم عنهما هذا ما قرره الشافعية .

ويرى الحنفية : أن الصبي إذا كان مأذوناً له في المخاصمة قبلت دعوته⁽¹⁾ .

ويرى المالكية : أن البلوغ ليس بشرط ، فإذا ادعى غير البالغ وأقام شاهداً قبلت من الدعوى⁽²⁾ .

الشرط السابع : حضور الخصم ، فلا تسمع الدعوى والبيينة إلا على خصم حاضر ، إلا إذ التمس المدعي بذلك كتاباً للقضاء به فيجيبه القاضي إليه وهذا عند الحنفية⁽³⁾ .

ويرى الشافعية : أن حضور المدعى عليه إلى مجلس القضاء ليس بشرط لسماع الدعوى والبيينة فيجوز القضاء على الغائب عندهم ، وعند الحنفية لا يجوز .

استدل الشافعية⁽¹⁾ :

1-بقوله تعالى (وأن احكم بينهم بما أنزل الله)⁽²⁾ ففي هذه الآية الكريمة جاء الحكم عاماً بعدم الفصل بين الحاضر والغائب .

2- ماروي عن عائشة رضى الله عنها قالت : دخلت هند بنت عتبة امرأة سفيان على رسول الله - صل الله عليه وسلم - فقالت : يا رسول الله - صل الله عليه وسلم-، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه ، فهل علي في ذلك جناح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - " خذي مايكفيك وولدك بالمعروف"⁽³⁾ .

وجه الدلالة : دل هذا الحديث الشريف على جواز القضاء على الغائب لأن أبا سفيان لم يكن حاضراً أثناء حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم .

واستدل الحنفية : بما روي من آيات وأحاديث تؤكد وتثبت عدم صحة الحكم على الغائب .

من الكتاب (وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون)⁽⁴⁾ :

وجه الدلالة : ذمهم الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة لإعراضهم عن الحضور ، وهذا يدل على أنه يجب عليهم أن يحضروا للحكم ، ولو نفذ الحكم مع الغيبة لم يجب الحضور ولم يستحقوا الذم ، فدل على عدم جواز الحكم على الغائب⁽⁵⁾ .

⁽³⁾ بدائنه الصنائع ج6 ص 222 ، البحر الرائق ج6 ص192 .

⁽¹⁾ مغني المحتاج ج ص 267 ، بدائع الصنائع ج6 ص 222 ، أما الصبي الذي لا يعقل والمجنون فلا تصح دعواه .

⁽²⁾ الشرح الصغير ج ص286 .

⁽³⁾ بدائع الصنائع ج6 ص 222 ، البحر الرائق ج7 ص192 .

⁽¹⁾ ووافقهم في ذلك المالكية والحنابلة والظاهرية لاحظ / الشرح الصغير ج5 ص25 ، مغني المحتاج ج4 ص 368 ، والمغني ج11 ص412 ، والمحلى لابن حزم ج9 ص226 .

⁽²⁾ سورة المائدة : آية رقم 44 .

⁽³⁾ صحيح مسلم ج12 ص7

⁽⁴⁾ سورة النور آية 48 .

⁽⁵⁾ مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر ج2 ص185 .

ومن السنة المشرفة : ماروي عن رسول الله - صل الله عليه وسلم - أنه قال لسيدنا على رضي الله عنه " لا تقض لأحد الخصمين مالم تسمع كلام الآخر " (6) .

وجه الدلالة : نهى رسول الله - صل الله عليه وسلم - علياً عن القضاء لأحد الخصمين قبل سماع كلام الآخر ، والقضاء بالحق حال غيبة المدعى عليه قضاء لأحد الخصمين قبل سماع كلام الآخر فكان منهياً عنه (1) .

ومن المعقول : أن القاضي مأمور بالقضاء بالحق قال الله تبارك وتعالى (ياداوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق) (2) .

وقال عليه الصلاة والسلام لعمر بن العاص : اقضي بين هذين ، قال أقضي وأنت حاضر بيننا ، فقال عليه الصلاة والسلام اقضي بينهما بالحق ، والحق اسم للكائن الثابت ، ولا ثبوت مع احتمال العدم ، واحتمال العدم ثابت في البيئة لاحتمال الكذب ، فلم يكن الحكم بالبيئة حكماً بالحق ، فكان ينبغي أن لا يجوز الحكم بها أصلاً إلا أنها جعلت حجة لضرورة فصل الخصومات والمنازعات ولم يظهر حال الغيبة (3) .

ويرد على أدلة القول الأول : القائلين بالجواز بما يلي :

أن حديث عائشة لا يدل على جواز القضاء على الغائب ، لأن ما قاله رسول الله - صل الله عليه وسلم - لهند لم يكن قضاء وإنما كان فتوى ، قال النووي: حديث هند وقضيتها كانت بمكة وكان زوجها أبو سفيان حاضراً بها لا غائباً عنها ، وشرط القضاء على الغائب أن يكون غائباً عن البلد ، وهذا الشرط غير متحقق في هذه القضية (4) .

ويرد على أدلة الحنفية بما يلي :

أولاً: الاستدلال بالآية ، بأنه لا منافاة بين ذمهم على عدم الحضور لأنه واجب عليهم وبين نفوذ الحكم عند الغيبة فيمكن أن يجتمع الأمرين : الذم على عدم الحضور ، ونفوذ الحكم عند الغيبة (1) .

ويناقش استدلال الحنفية بالحديث : بأن هذا الحديث نقول به إذا نقاضي إليه رجلان لم يجز الحكم قبل سماع كل منهم ، وهذا يقتضي أن يكونا حاضرين ، ويفارق الحاضر الغائب ، فإن البيئة لا تسمع على الحاضر إلا بحضوره ، والغائب خلافه (2) .

ونقل عن الحنفية : القول بالجواز ، ومفاده : أنه إنما لا يجوز القضاء عندنا على الغائب إذا لم يكن عنه خصم حاضر ، فإن كان يجوز ، لأنه يكون قضاء على الحاضر حقيقة ومعنى ، والخصم الحاضر الوكيل والوصى والوارث ومن كان بينه وبين الغائب اتصال فيما وقع فيه الدعوى ، لأن الوكيل والوصى نائبان عنه بصريح النيابة ، والوارث نائب عنه شرعاً ، وحضرة الغائب كحضرة المنوب عنه ، فلا يكون قضاء على الغائب معنى (3) .

(6) نصب الرأية لتخريج أحاديث الهداية ج 4 ص 82 .

(1) بدائع الصنائع ج 6 ص 222 ، 223 .

(2) سورة ص آية (26) .

(3) بدائع الصنائع ج 6 ص 223 .

(4) صحيح مسلم ج 12 - ص 192 .

(1) صحيح مسلم ج 12 ص 8 .

(2) البحر الرائق ج 7 ص 192 .

(3) بدائع الصنائع ج 6 ص 223 ، قال الزيلعي : ويترتب على صحتها وجوب احضار الخصم والمطالبة بالجواب بلا أو نعم وإقامة البيئة أو اليمين إذا أنكر . البحر الرائق ج 7 ص 192 .

ومن هذا المعنى يفهم : أنه يجوز القضاء على الغائب إن كان له خصم ينوب عنه . وبهذا نرى رجحان القول الأول القائل بالجواز ، لكي لا تضيع الحقوق ، فإذا ظهرت البيئة للقاضي حكم بها على الغائب .

الشرط الثامن : عدم التناقض في الدعوى ، وهو أن لا يسبق منه ما يناقض دعواه لاستحالة وجود الشيء مع ما يناقضه وينافيه ، حتى لو أقر بعين في يد لرجل ، فأمر القاضي بدفعها إليه ثم ادعى أنه كان اشتراها منه قبل ذلك ، لأن الشراء منه قبل ذلك ، لأن الشراء يوجب الملك للمشتري فكان مناقضاً للإقرار ، والإقرار يناقضه فلا يصح (1) .

وبناء على ماتقدم من شروط يمكن أن تكون هناك دعوى صحيحة ودعوى فاسدة .

فالدعوى الصحيحة : هي التي استجمعت كل الأركان والشروط .

والفاسدة : هي التي اختل منها ركن من أركانها أو شرط من شروطها .

تكييف وسائل الإثبات : بعد أن بينا حد الدعوى وأركانها وشروطها نقول : إذا رفعت الدعوى إلى القاضي وكانت صحيحة سأل القاضي المدعى عليه لينكشف وجه الحكم ، فإن أقر أو أنكر فبرهن المدعي قضى عليه .

ومن الوسائل التي يثبت بها صحة الدعوى من عدمه :

الشهادة – البيئة ، أو الإقرار ، أو اليمين ، وقد اقتصر بعض الفقهاء على ذلك ، واقتصاراً على ماورد بشأنه النص ، وزاد بعض الفقهاء وسائل أخرى : هي اليمين المردودة ، والنكول عنها ، والكتابة ، وشهادة الإستكشاف ، والقرائن القاطعة ، وقول الخبراء والمعاينة ، واستجواب الخصم ، وهذه الوسائل مبناها على الإجتهد المبني على النص أيضاً (2) .

ونتناول فيما يلي أهم وسائل الإثبات في الفقه الإسلامي الفصول التالية :

الفصل الأول : في الشهادة .

الفصل الثاني : في الإقرار .

الفصل الثالث : في اليمين .

الفصل الرابع : في الطرق الإجتهدية .

الفصل الخامس : في الحجر

الفصل السادس : في الرهن

(1) بدائع الصنائع ج 6 ص 224 .

(2) لاحظ / بدائع الصنائع ج 6 ص 266 ، تكملة فتح القدير ج 6 ص 2 ، الإختيار لتعليق المختار ص 199 ، مجمع الأنهر ج 2 ص 185 ، حاشية الدسوقي ج 4 ص 146 ، مغني المحتاج ج 4 ص 368 ، المغني لابن قدامة ج 9 ص 63 ، المحلى لابن حزم ج 8 ص 250 ، البحر الزخار ج 6 ص 3 .

الفصل الأول الشهادة

ويقع هذا الفصل في عدة مباحث :

تمهيد : في مفهوم الشهادة ومشروعيتها .

المبحث الأول : حكم التحمل والأداء .

المبحث الثاني : في شروط الشهادة .

المبحث الثالث : في أداء الشهادة في الحدود .

المبحث الرابع : شروط الشهادة .

الفصل الأول

في مفهوم الشهادة وشروطها وأنواعها والأثر المترتب عليها

مفهوم الشهادة في اللغة:

تطلق الشهادة في اللغة على عدة معاني منها: الإطلاع على الشيء ومعاينته، تقول شهدت الشيء بمعنى اطلعت عليه وعاینته فأنا شاهد، والجمع أشهاد وشهود وأشهدت فلان على كذا، وشهدت على الرجل بكذا أو شهدت له بمعنى الإطلاع والمعاينة في الجميع⁽¹⁾.

والشهادة أصلها الحضور ، قال - صل الله عليه وسلم - الغنيمة لمن شهد الواقعة أي حضرها⁽²⁾ ، ومنه شهد الرجل المكان الفلاني وشهد الجندي الحرب ، أي حضر كل منهما المكان والحرب وعاین ذلك بنفسه ومن قوله تعالى (فمن شهد منكم الشهر فليصمه)⁽³⁾ أي من كان حاضراً في الشهر مقيماً غير مسافر فليصم ماحضر وأقام منه من أيام⁽⁴⁾.

وتعني الشهادة أيضاً : العلم بما استفاض واشتهر حتى أصبح في منزلة المعاينة والإطلاع بالنفس ، ومنه قوله تعالى (شهد الله أنه لا إله إلا هو)⁽¹⁾ أي علم و بین⁽²⁾. والشهيد الذي حضرته الوفاة في الغزو ، حتى لو مضى وقت الصلاة ، وهو حي لا يسمى شهيداً ، لأن الوفاة لم تحضر في الغزو⁽³⁾.

مفهوم الشهادة في الاصطلاح :

وهي: إخبار صدق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء .

محترزات التعريف: إخبار جنس في التعريف يشمل الإخبار الصادقة والإخبار الكاذبة وصدق يخرج الكاذبة كشهادة الزور فانها خارجة لأنها ليست شهادة

وفي مجلس القضاء يخرج أي شهادة في غير مجلس القضاء فلا يعتد بها⁽¹⁾.

وجاء في تعريفها أنها: الإخبار عن أمر حضره الشهود وشاهدوه إما معاينة نحو القتل والزنا ، أو سماعاً ، كالعقود والإقرارات فلا يجوز له أن يشهد إلا بما حضره أو علمه عياناً أو سماعاً ولهذا لا يجوز له أداء الشهادة حتى يذكر الحادثة⁽²⁾.

(1) المعجم الوجيز ص 352/ 353 ، مادة شهد المبسوط ج 11 ص 112 .

(2) نصب الراية ج 4 ص 82 - البحر الرائق ج 7 ص 55 .

(3) سورة البقرة آية (185) .

(4) المصباح المنير ج 1 ص 147 مادة " شهد " ، المعجم الوجيز ص 352 .

(1) سورة آل عمران آية (18) .

(2) بدأت بالشهادة كأول وسيلة من وسائل إثبات الدعوى دون الإقرار ، لأن الإقرار حجه قاصرة على المقر لا تتعداه إلى غيره بخلاف الشهادة : فهي حجه مطلقة ثابتة في حق جميع الناس غير مقتصرة على المقضى عليه ، لذا تسمى البينة ، لأنها مبينة يظهر بها الملك ، لذا قال الحنفية : البينة أقوى من الإقرار بدائع الصنائع ج 6 ص 226 ، فتح القدير ج 6 ص 2 .

(3) تكملة فتح القدير ج 7 ص 363 ، تبين الحقائق ج 4 ص 206 ، حاشية الدسوقي ج 4 ص 164 ، النظم المستعذب شرح غريب المذهب ج 2 ص ، الشرح الكبير ج 4 ص 164 ، مغنى المحتاج ج 4 ص 426 .

(1) العناية على الهداية ج 7 ص 364 ، والزور : تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته حتى يخيل إلى من سمعه أو من رآه بخلاف ما هو به فهو تمويه الباطل بما يوهم أنه حق ، سبل السلام ج 4 ص 130 .

(2) تكملة فتح القدير ج 6 ص 2 ، الفتاوى الهندية ج 3 ص 450 .

دليل مشروعية الشهادة: والشهادة حجة شرعية مظهرة للحق مشروعة بقوله تعالى «{وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمَّ قَلْبُهُ} [البقرة: 283] وَهَذَا وَإِنْ كَانَ نَهْيًا عَنِ الْإِبَاءِ وَعَنِ الْكُتْمَانِ لَكِنَّ النَّهْيَ عَنِ الشَّيْءِ يَكُونُ أَمْرًا بِضِدِّهِ إِذَا كَانَ لَهُ ضِدٌّ وَاحِدٌ؛ لِأَنَّ الْإِنْتِهَاءَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِالِاشْتِعَالِ بِهِ فَكَانَ أَدَاءُ الشَّهَادَةِ فَرَضًا قَطْعًا كَفَرِيضَةِ الْإِنْتِهَاءِ عَنِ الْكُتْمَانِ فَصَارَ كَالْأَمْرِ بِهِ بَلْ أَكْذَ وَلِهَذَا أُسْنِدَ الْإِثْمُ إِلَى الْأَلَةِ الَّتِي وَقَعَ بِهَا الْفِعْلُ وَهِيَ الْقَلْبُ؛ لِأَنَّ إِسْنَادَ الْفِعْلِ إِلَى مَحَلِّهِ أَقْوَى مِنْ إِسْنَادِهِ إِلَى كُلِّهِ، وَقَوْلُهُمْ: أَبْصَرْتُهُ بَعَيْنِي أَكْذَ مِنْ قَوْلِهِمْ أَبْصَرْتَهُ، وَإِسْنَادُهُ إِلَى أَشْرَفِ الْجَوَارِحِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ أَعْظَمُ الْجَرَائِمِ (4).

ومن السنة الشريفة :

1- ماروى عن الأشعث بن قيس الكندى (رضي الله عنه) قال : كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر ، فاختصمنا إلى رسول الله صل الله عليه وسلم - فقال : " شاهداك أو يمينه " ، قلت إذن يحلف ولا يبالى ، فقال عليه الصلاة والسلام " من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان " وفي رواية " ألك بينة " (5).

2- وقوله - صل الله عليه وسلم- " إذا رأيت مثل الشمس فاشهد وإلا فذع " (1).

3- وقوله - صل الله عليه وسلم - " ألا أخبركم بخير الشهداء هو الذي يأتي الشهادة قبل أن يسألها " (2).

ففي هذه الأحاديث دلالة واضحة على أن الشهادة وسيلة من وسائل الإثبات في الحقوق وغيرها ، ولذا طلب الرسول - صل الله عليه وسلم - من المدعي الشهادة أي شهادة الشهود على دعواه ، ومن المدعى عليه اليمين .

فقال - صل الله عليه وسلم - " البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر " (3) .
والبينة بهذا هي الشهادة بالإجماع ، لأن فيها إحياء الحقوق وصون العقود عن التجاحد ، وحفظ الأموال إلى أربابها .

ولهذا قال - صل الله عليه وسلم - " أكرموا شهودكم فإن الله يستخرج بهم الحقوق " (4) .

الدليل من الإجماع :

أجمع أهل العلم من لدن رسول الله - صل الله عليه وسلم - إلى يومنا هذا على الأخذ بالشهادة واعتبارها حجة في الإثبات من غير تكثير من أحد ، ودعت الحاجة إلى ذلك لحصول التجايد بين الناس ، وذكر شريح القاضي فقال : القضاة جمرة ، فنحه عنك بعودين ، يعني بشاهدين ، وإنما الخصم داء والشهود شفاء فأفرغ الشفاء على الداء (1) .

(4) فتح القدير ج 6 ص 2 ، الإختيار ص 200 ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج 18 ص 105 .

(5) أخرجه البخاري في صحيحه ج 2 ص 889 ، وفي صحيح مسلم ج 123 .

(1) حديث صحيح سبل السلام ج 4 ص 131 .

(2) أخرجه مسلم في صحيحه ج 3 ص 1344 ، وفي سنن الترمذى ج 4 ص 544 ، وابن حبان ج 11 ص 470 .

(3) رواه الحاكم وصحيح اسناده ، وأخرجه الزيلعي في نصب الراية ج 4 ص 82 .

(4) سبل السلام ج 4 ص 130 ، العناية على الهداية ج 6 ص 2 .

(1) المغنى لابن قدامة ج 9 ص 146 .

حكم الشهادة : وجوب الحكم على الحاكم بمقتضاها ، والقياس لا يقتضي ذلك لإحتمال الكذب فاشتربت العدالة ليرجح جانب الصدق ، وورود النصوص بالإستشهاد دليل على وجوبها ⁽²⁾ .

ركن الشهادة : وركنها لفظ " أشهد " لأن النصوص اشترطت هذا اللفظ إذ الأمر القرآني ورد بهذه اللفظة ، ولأن فيها زيادة تأكيد ، فإن قوله " أشهد " من ألفاظ اليمين وهو يتضمن معنى الشهادة أي الإطلاع على الشيء فلو قال : " شهدت " لا يجوز لأن الماضي موضوع للإخبار عما وقع والشهادة يقصد بها الإخبار في الحال ⁽³⁾ .

وأما المتعارف الناس في حقوق العباد ، فهي : الإخبار عن كون مافى يده لغيره ، فكل من أخبر بأن مافى يد غيره لغيره فهو شاهد ⁽¹⁾ .

المبحث الأول

في حكم التحمل والأداء ⁽²⁾

أداء الشهادة وتحملها فرض يلزم الشهود بحيث لا يسعهم كتمانهم وتأكيد الفريضة يكون بوصفين : للزوم ، وعدم الكتمان ، وعدم الكتمان دلالة على تأكيد ، وهي شرط مطالبة المدعي تحقيقاً لسبب الأداء .

ومن هنا ندرك أن تحمل الشهادة وأداؤها فرض على كل إنسان ولكن على سبيل الفائدة ، وذلك بما يحفظ على الناس حقوقهم ، وعدم ضياعها ، والدليل على ذلك : - قوله تعالى (ولا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا) وقوله تعالى (ولا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أِثْمٌ قَلْبِهِ) .

وفي هذا دليل على النهي عن كتمانها على وجه المبالغة والنهي عن أحد النقيضين ، وهو الكتمان يستلزم ثبوت النقيض الآخر ، الإعلان - لئلا يرتفع النقيضان ، فإذا كان الكتمان منهياً عنه كان الإعلان ثابتاً وثبوته بالأداء ، ومالم يجب لا يثبت ، فكان إظهار الأداء واجباً ⁽³⁾ .

ويكون الأداء على سبيل الفرض العيني إذا كان الشاهد في موضع لا يوجد فيه غيره للشهادة أو لا يصلح لها إلا هو ، لأن الشهادة قد تثبت في حقه لأداء الحق وبيانه ، لأنه لا يعرف إلا من جهته في هذه الحالة ، فيعتبر من يتخلف عن تحمل الشهادة أو أدائها كمن يتخلف عن أداء فرض عين عليه كالصلاة والزكاة ، حيث يجبر شرعاً على أدائها، ويعاقب على تركها حتى لا تضيع الحقوق على أصحابها ⁽¹⁾ .

⁽²⁾ فتح القدير ج7 ص 364/ 365 ، بدائع الصنائع ج6 ص226 ، حاشية ابن عابدين ج4 ص385 ، المغني ج9 ص216 .

⁽³⁾ وخالف في ذلك المالكية ، فقالوا : إنه يكفي كل لفظ يؤدي معنى الشهادة من الألفاظ الأخرى كالإعلام والأخبار ، والإشهاد ، وحاشية السوقي ج4 ص165 ، بلغة السالك لأقرب المسالك ج3 ص301 .

⁽¹⁾ بدائع الصنائع ج6 ص226 ، الفتاوى الهندية ج3 ص450 .

⁽²⁾ التحمل عبارة عن فهم الحادثة وضبطها ، والأداء : صلاحية الإنسان لأن يلتزم بعبارته ، ومناطها : ثبوت العقل والتمييز ، ويراد بالتمييز معرفة معاني الألفاظ ، بدائع الصنائع ج6 ص226 .

⁽³⁾ فتح القدير ج7 ص364 ، المبسوط ج16 ص177 ، الشرح الكبير للدردير ج4 ص199 ، مغني المحتاج ج4 ص45 ، المغني ج9 ص146 .

⁽¹⁾ الفقه الإسلامي وأدلته د / وهبة الزحيلي ج6 ص556 .

ويكون التحمل والأداء على سبيل الكفاية لا العين، إذا توافر العدد الكثير، لأن المقصود بالشهادة حفظ الحقوق، وذلك يتحقق من البعض ولا يحتاج إلى الكل .
سبب تحمل الشهادة: وسبب تحملها معاينة مايتحملها له، ومشاهدته بما يختص بمشاهدته من السماع من المسموعات ، والإبصار في المبصرات .
سبب أداء الشهادة⁽¹⁾ .

1- إما طلب المدعي منه الشهادة، وهو أمر مشترط في الأداء لأنها حقه فيتوقف على طلبه كسائر الحقوق، وسببية الطلب تثبت بقوله تعالى (ولا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا) .
2- وإما خوف فوت حق المدعي إذا لم يعلم المدعى كونه شاهداً فإن من عنده شهادة لا يعلم بها صاحب الحق وخاف فوت الحق يجب عليه أن يشهد بلا طلب ، وسببية خوف الفوات إنما تثبت كي لا يفوت الحق على صاحبه⁽²⁾ .
أركان الشهادة :
وهي تتحقق في الأركان التالية :

شاهد ، مشهود له ، مشهود عليه .
مشهود به، صيغة⁽³⁾ .
ولكل هذه الأركان شروط لصحتها نتناولها فيما يلي .

(1) بدائع الصنائع ص226 ، فتح القدير ج7 ص265 .

(2) حاشية ابن عابدين ج3 ص440 .

(3) بدائع الصنائع ج6 ص277، والبحر الرائق ج7 ص56 .

المبحث الأول

شروط الشهادة

لا قيمة للشهادة إذا لم تكن صحيحة متفقة مع قصد الشارع وإرادته وذلك يتطلب شروط صحة هذه الشهادة ، ولما كانت هذه الأركان السابق ذكرها هي التي تكون ماهية الشهادة ، فإن الأمر يتطلب منا بيان شروط صحة هذه الأركان ، ليتمكن القول بأن الشهادة صحيحة شرعاً وملزمة من حيث ما يترتب عليها من آثار شرعية .

ولبيان هذه الشروط نقول إن الشرائط في الأصل نوعان :

أحدهما : شروط تحمل الشهادة .

ثانيهما : شروط أداء الشهادة ⁽¹⁾ .

أولاً: شروط تحمل الشهادة :

أحدهما: أن يكون عاقلاً وقت التحمل فلا يصح التحمل من المجنون والصبي الذي لا يعقل ، لأن تحمل الشهادة عبارة عن فهم الحادثة وضبطها وذلك لا يحصل إلا بآلة الفهم والضبط وهو العقل ، وهي غير متحققة منها وبناء عليه ، فإنه لا تقبل شهادة غير مكلف من صبي لا يعقل ، أو مجنون ، لحديث " رفع القلم عن ثلاث " وعد منهم الصبي والمجنون .

ولأنهما إذا كانا لم يؤتمنا شرعاً على أموالهما فلا ن لا يؤتمنا على حفظ حقوق غيرهما أولى ⁽¹⁾ .

الثاني : أن يكون بصيراً وقت التحمل ، فلا يصح التحمل من الأعمى وهذا عند أبي حنيفة ومحمد .

وقال زفر : تقبل فيما فيه التسامع ، لأنه يسمع .

وقال أبو يوسف إن كان بصيراً وقت التحمل تقبل لوجود العلم بالنظر ، وعند الأداء يحتاج إلى القول ، وهو قادر عليه ، ويعرفه بالنسبة كما في الميت . وقال الشافعي : إن البصر ليس بشرط لصحة التحمل . ولصحة الأداء .

وحجته في ذلك : أن الحاجة إلى البصر عند التحمل لحصول العلم بالمشهود به وذلك يحصل بالسمع ، ولأعمى سماع صحيح فيصح تحمله للشهادة ، ويقدر على الأداء بعد التحمل ⁽²⁾ .

الثالث : أن يكون التحمل بمعينة المشهود به بنفسه لا بغيره إلا في أشياء مخصوصة يصح التحمل فيها بالتسامع من الناس ، لقوله - صل الله عليه وسلم - " إذا رأيت مثل الشمس فأشهد وإلا فدع " ولا يعلم مثل الشمس إلا بالمعينة بنفسه ، فلا تطلق الشهادة بالتسامع إلا في أشياء مخصوصة ، وهي النكاح ، والنسب ، والموت ، فله تحمل الشهادة فيها بالتسامع من الناس ، وإن لم يعاين بنفسه لأن مبنى هذه الأشياء على الإشتهار فقامت الشهرة فيها مقام المعينة ⁽³⁾ .

تفسير التسامع : التسامع هو أن يشتهر خير ويستفيض بين الناس وتتواتر به الأخبار ليحصل له نوع من اليقين .

وقال محمد بن الحسن : هو أن يشتهر ذلك ويستفيض ، وتتواتر به الأخبار عنده من غير تواطؤ على الكذب ، لأن الثابت بالتواتر والمحسوس بحس البصر والسمع سواء ، فكانت الشهادة بالتسامع شهادة عن معينة ⁽¹⁾ .

⁽¹⁾ بدائع الصنائع ج 6 ص 226 ، فتح القدير ج 7 ص 432 .

⁽¹⁾ الإختيار ص 210 مع البدائع .

⁽²⁾ بدائع الصنائع ج 6 ص 226 ، ومغنى المحتاج ج 4 ص 445 .

⁽³⁾ بدائع الصنائع ج 6 ص 266 ، المبسوط ج 16 ص 111 ، فتح القدير ج 2 ص 263 .

⁽¹⁾ بدائع الصنائع ج 6 ص 266 ، فتح القدير ج 7 ص 265 .

وقال المالكية: تجوز الشهادة بالتسامع في عشرين حالة منها عزل القاضى أو الولى أو الوكيل ، وفى كفر ، ونكاح ، ونسب ، ورضاع ، وبيع ، وهبة ، ووصية وغيرها .

والتسامع عندهم: هو أن يكون المنقول عنه غير معين ولا محصور وذلك بأن يشتهر النسب – مثلاً – المشهود به بين الناس العدول وغيرهم ، ويشترط أن يقول الشهود : سمعنا أو لم نزل نسمع فاشيا من أهل العدول وغيرهم أن فلاناً ابن فلان⁽²⁾ .

وقال الشافعية: تجوز الشهادة بالتسامع أو الإستفاضة في النسب والموت، والوقف، والنكاح، وملكية الأشياء ، فإن استفاض في الناس أن فلاناً ابن فلان ، جاز أن يشهد به ، لأن سبب النسب لا يدرك بالمشاهدة ، وإن استفاض فى الناس أن فلاناً مات ، جاز أن يشهد به ، لأن أسباب الموت كثيرة ويتعذر الإطلاع عليها⁽³⁾ .

وقال الحنابلة : تصح الشهادة بالإستفاضة فى النسب والولادة والنكاح والموت ، والملك ، والولاية والعزل⁽¹⁾ .

ولا يشهد باستفاضة إلا عدد يقع بهم العلم⁽²⁾ .

ومن هنا يتبين لنا اتفاق الفقهاء في جواز الشهادة بالتسامع في أشياء كثيرة ، ولكنهم اشترطوا في صحتها سماع الشهود من جمع كثير لا يؤمن تواطئهم (أي توافقهم) على الكذب بحيث يحصل العلم (اليقين) أو النطق القوى بخبرهم ، ولا بد أن يقول اشهد بكذا .

(2) حاشية الدسوقي ج4 ص 198 .

(3) مغني المحتاج ج4 ص161 .

(1) المغني لابن قدامة ج9 ص161 .

(2) الروض المربع ص482 . قال البهوتي : ومن شهد بعقد نكاح أو غيره من العقود فلا بد في صحة شهادته به من ذكر شروطه لإختلاف الناس في بعض الشروط وربما اعتقد الشاهد ماليس بصحيح صحيحاً وإن شهد برضاع ذكر عدد الرضعات ، وأنه شرب من ثديها أو لبن حلب منها .

المبحث الثاني في أداء الشهادة في الحدود

أداء الشهادة في الحدود يخير فيها الشاهد بين الأداء أو الترك . لأنه يتوقى عن هتك حرمة المسلم حسبة الله والستر أفضل نقلاً وعقلاً .

أما الأول : فقوله - صل الله عليه وسلم - لهزال ، وهو رجل من أسلم " لو سترته بثوبك لكان خيراً لك " (1)

والمراد بمرجع الضمير في قوله " سترته بثوبك " لماعز - رضي الله عنه - لما روي أبو داود عن يزيد بن نعيم عن أبيه " أن ماعز بن مالك أتى النبي - صل الله عليه وسلم - فأقر عنده أربع مرات فأمر برجمه وقال لهزال "لو سترته بثوبك لكان خيراً لك " ، وأن هزال هو الذي أشار على ماعز أن يأتي النبي - صل الله عليه وسلم - ويقر عنده ولم يكن شاهداً ، لأن ماعز إنما حد بالإقرار . يؤيده : ما أخرج أبو داود عن ابن المنكر أن هزالاً أمر ماعزاً أن يأتي النبي - صل الله عليه وسلم - فيخبره .

ورواه ابن سعد في الطبقات جاء فيه : قوله لهزال : بئسما صنعت لو سترته بطرف ردائك لكان خيراً لك قال يا رسول الله لو أدر أن في الأمر سعة " (2) . وفي هذا دليل على جواز الستر بل الستر أفضل بدليل : قول الرسول - صل الله عليه وسلم - " من ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة " (1) .

وأما المعقول : فلأن الستر والكتمان إنما يحرم لخوف فوات حق المحتاج إلى الأموال ، والله تعالى غني عن العالمين ، وليس ثمة خوف فوات الحق فيه وفيه صيانة عرض أخيه المسلم ، ولا شك في فضل ذلك (2) .

دفع إقامة الحد في السرقة : لدفع إقامة الحد في السرقة فيجب على الشاهد أن يشهد بالمال ، وعبر المرغيناني عن ذلك فقال : " إلا أنه يجب أن يشهد بالمال في السرقة فيقول أخذ ولا يقول سرق محافظة على الستر " وفيه درء لإقامة الحد ، بشرط عدم ضياع الحق .

وهو استثناء منقطع لأن الشهادة بالمال ليست بداخله في الحدود أي أنه استدرك من قوله تعالى " مخير في الحدود " فإنه يقتضي أن لا يشهد بالسرقة فقد يتبادر أنه لا يشهد فيها مطلقاً لإستلزامه الحد ، فقال : يجب أن يشهد بالمال إحياء لحق مالكة على وجه لا يوجب الحد ، فيقول : أخذ المال ولا يقول سرق فإن الأخذ أعم من كونه غصباً أو على ادعاء أنه ملكه مودعاً عند الأخذ منه وغير ذلك فلا تستلزم الشهادة بالأخذ مطلقاً ثبوت الحد بها مع أن فيه مصلحة للمسروق منه ، لأنه إذا قال سرق فتثبت السرقة ، ويجب القطع ، وبه ينتفى ضمان المال إن كان أتلفه .

(1) نصب الراية لتخريج أحاديث الهداية ج4 ص74 .

(2) رواه أبو داود والنسائي والحاكم والبزار وأحمد والطبري عن نعيم بن هزال ، نصب الراية لتخريج أحاديث الهداية ج4 ص74 .

(1) رواه الترمذی عن ابن عمر ، ورواه أبو نعيم عن مسلم بن مخلد مرفوعاً ورواه ابن ماجه عن ابن عباس مرفوعاً نصب الراية ج4 ص79 .

(2) تكملة فتح القدير ج6 ص5 والعناية على هامشة .

ومن هنا نلاحظ أن الأخبار الواردة في طلب الستر قد بلغت مبلغاً لا تنحط به عن درجة الشهرة ،
لتعدد متونها مع قبول الأمه لها فصح التخصيص بها ، أو مستند الإجماع على تخيير الشاهد في
الحدود ، فثبوت الإجماع دليل ثبوت المخصص⁽¹⁾ .
وإنما يصح ذلك التخيير ويجوز إذا كان قبل الحضور إلى الحاكم أو القاضي لأداء الشهادة ، أما بعد
الحضور فلا .

ودليل ذلك : وما روي أن صفوان بن أمية نام في المسجد وتوسد رداءه فجاء سارق وأخذ رداء
صفوان ، فأخذ صفوان بالسارق إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمر به رسول الله - صلى
الله عليه وسلم - أن تقطع يده فقال صفوان : إنني لم أرد هذا يا رسول الله ، هو صدقة عليه ، فقال
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "فهلا قبل أن تأتيني به"⁽²⁾ .

وروى ابن مسعود - رضي الله عنه - أن أول حد أقيم في الإسلام السارق أتى به إلي النبي - صلى
الله عليه وسلم - فلما قامت البينة قال : انطلقوا فاقطعوه ، فنظر الناس في وجهه كأنما سعى عليه والله
الرماد ، فقالوا يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لكأن هذا الأمر اشتد عليك ؟ فقال : وكيف لا
يشتد عليا وأنتم أعوان الشيطان على أخيكم ، فقالوا : فهلا خليت سبيله يا رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - قال : " أفلا كان هذا قبل أن تأتوني به " إن الإمام إذا بلغه حد فليس له أن يعطله " ثم قرأ
(وليصفوا وليصفحوا) ⁽³⁾ .

ومن هذه النصوص يتضح أن الحدود إذا بلغت الإمام لا تجوز الشفاعة فيها .
يدل على ذلك : ما روي عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : " إن قریشاً أهمهم شأن المرأة
المخزومية التي سرقت ، فقالوا من يكلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ومن يجتريء عليه إلا
أسامة فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " أتشفع في حد من حدود الله " ، ثم قام خطيباً فقال :
أيها الناس إنما هلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف
أقاموا عليه الحد ، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ⁽¹⁾ .

من هذا الحديث يتبين أن الحدود إذا بلغت الإمام فإنه لا يجوز للإمام أن يستتر أو يعفو بل يجب عليه
أن يقيم الحد ، لما روي عن ابن عمر قال : " اشفعوا ما لم يصل إلى الولي ، فإذا وصل فعفا فلا عفا
عند الله " وادعى ابن عبد البر الإجماع على ذلك ⁽¹⁾ .

(1) فتح القدير ج 6 ص 6 ، الهداية شرح بداية المبتدي ج 3 ص 116 ، بدائع الصنائع ج 6 ص 266 ، الاختيار
ص 200 .

(2) موطأ مالك ص 521 ط / دار الشعب ، سبل السلام ج 4 ص 6 .

(3) سبل السلام ج 4 ص 26 .

(1) سنن ابن ماجه ج 2 ص 851 ، نيل الأوطار ج 7 ص 235 ، 236 .

(1) سبل السلام ج 4 ص 26 .

المبحث الثالث شروط أداء الشهادة

أما شروط أداء الشهادة فأنواع :

الأول : يرجع إلى الشاهد .

الثاني : يرجع إلى نفس الشهادة .

الثالث : يرجع إلى مكان الشهادة .

الرابع : إلى المشهود به .

وإليك البيان :

الشروط الواجب توافرها في الشاهد :

وحول الشروط الواجب توافرها في الشاهد نفصل بين حالتين :

1- شروط تعم الشهادات كلها .

2- شروط تختص ببعض الشهادات دون البعض الآخر .

أما الشروط العامة فهي كما يلي:

الأول : العقل : - يشترط في الشاهد أن يكون عاقلاً ، لأن من لا يعقل لا يعرف الشهادة فكيف يقدر على أدائها .

الثاني : البلوغ : - فلا تقبل شهادة الصبي غير البالغ ، لأنه لا يقدر على الأداء إلا بالتحفظ ، والتحفظ بالذكر ، والتذكر بالتفكر ، ولا يوجد من الصبي عادة .

ولأن الشهادة فيها معنى الولاية ، والصبي مولى عليه ولأنه لو كان له شهادة للزمته الإجابة عند الدعوة ، لقوله تعالى (ولا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا) أى دعوا للأداء فلا يلزمه إجماعاً⁽¹⁾ .

ولقوله تعالى (ممن ترضون من الشُّهَدَاءِ) والصبي ممن لا يرضى ولأن الصبي لا يَأْتُمُ بكتمان الشهادة ، فدل على أنه ليس بشاهد .

وأما شهادة الصبيان بعضهم على بعض فتجوز عند الإمام مالك في الجراح وفي القتل خلافاً لجمهور الفقهاء⁽²⁾ .

الثالث : الحرية : لقوله تعالى : (ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء)⁽³⁾ والشهادة شيء فلا يقدر على أدائها بظاهر الآية الكريمة .

ولأن الشهادة تجري مجرى الولايات والتمليكات .

أما الولاية : فإن فيه تنفيذ القول على الغير وأنه من باب الولاء .

وأما التملك : فإن الحاكم يملك الحكم بالشهادة فكان الشاهد ملكه الحكم والعبد لا ولاية له على غيره ولا يملك فلا شهادة له ، وكذا المدبر ، وأم الولد والمكاتب لأنهم عبيد⁽¹⁾ .

(1) بدائع الصنائع ج 6 ص 266 ، 267 .

(2) بدائع الصنائع ج 6 ص 266 ، الشرح الكبير للدردير ج 4 ص 165 ، المغني ج 9 ص 164 ، الفقه الإسلامي د/الزحيلي ج 6 ص 563 .

(3) سورة النحل آية رقم (75) .

(1) المدبر : هو العبد المعلق عتقه على موت سيده ، كأن يقول له أنت حر بعد موتي .

أم الولد : هي الأمة التي استولدها سيدها ، فولدها منه حر ومنزلتها بهذا الولد تكون أرقى من غيرها .
والمكاتب : هو الذي كاتب سيده على مال منجم - مجزء - إذا أدى النجوم عتق .

الرابع : البصر : - وهو شرط عند أبي حنيفة ومحمد فلا تقبل شهادة الأعمى عندهما سواء كان بصيراً وقت التحمل أو لا .

وعند أبي يوسف : ليس بشرط حيث تقبل شهادته إن كان بصيراً وقت التحمل ، وهذا إذا كان المدعى به شيئاً وقت التحمل ، وهذا إذا كان المدعى به شيئاً لا يحتاج إلى الإشارة إليه وقت الأداء .
فأما إن كان شيئاً يحتاج إلى الإشارة إليه وقت الأداء لا تقبل شهادته إجماعاً .
وجه قول أبي يوسف : أن اشتراط البصر ليس لعينه بل لحصول العلم بالمشهود به ، وإذا حصل إذا كان بصيراً وقت التحمل .

وجه قولهما : أنه لا بد من معرفة المشهود له ، والإشارة إليه عند الشهادة فإذا كان أعمى عند الأداء لا يعرف المشهود له من غيره ، فلا يقدر على أداء الشهادة ⁽¹⁾ .
الخامس : النطق : - فلا تقبل شهادة الأخرس ، لأن مراعاة لفظة الشهادة شرط لصحة أدائها ولا عبارة للأخرس فلا شهادة له .

وأجاز المالكية قبول شهادة الأخرس إن فهمت إشارته ، لأنها تقوم مقام نطقه في طلاقه ونكاحه وطهارته فكذا في شهادته ⁽²⁾ .

السادس : الإسلام : - اتفق الفقهاء على اشتراط كون الشاهد مسلماً ، فلا تقبل شهادة الكافر على المسلم ، لأنه متهم في حقه ، وأجاز الحنفية والحنابلة شهادة الكافر في الوصية في السفر بالشروط التي ذكرها الله تعالى ، لقوله تعالى (يا أيها الذين ءامنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتم مصيبة الموت) ⁽³⁾ .

قال ابن عباس في هذه الآية : لمن مات وعنده المسلمون فأمر الله أن يشهد الوصية عدلين من المسلمين ، ثم قال تعالى (أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض) فهذا لمن مات، وليس عنده أحد من المسلمين ، فأمر الله عز وجل أن يشهد رجلين من غير المسلمين ، فإن ارتيب بشهادتهما استحلفا بعد الصلاة بالله لانشتري بشهادتنا ثمناً قليلاً وقضى به ابن مسعود في زمن عثمان ، وكذا على ، وقضى به أبو موسى الأشعري في الكوفة وكثير من التابعين .
وروى عن سعيد بن المسيب " أو آخران من غيركم " قال من أهل الكتاب وفي رواية صحيحة عنه " من غير أهل ملكتكم " .

وصح عن شريح القاضي قال : " لا تجوز شهادة المشركين على المسلمين إلا في الوصية ، ولا تجوز في الوصية إلا أن يكون مسافراً " .

وصح عن الشعبي " أو آخران من غيركم " قال : من اليهود والنصارى ⁽¹⁾ وقال مالك والشافعي : أنها لا تجوز ⁽²⁾ . لأن الشهادة ولاية ولا ولاية للكافر على المسلم لقوله تعالى (ولن يجعل الله

المصباح المنير ج2 ص720 مادة " كتب " ، ومغني المحتاج ج2 ص409 ، بدائع الصنائع ج6 ص268 ، فتح القدير ج2 ص10 .

⁽¹⁾ بدائع الصنائع ج6 ص267 ، فتح القدير ج6 ص10 .

⁽²⁾ حاشية الدسوقي ج4 ص168 .

⁽³⁾ سورة المائدة آية رقم (106) .

⁽¹⁾ بدائع الصنائع ج6 ص268 ، والمغني لابن قدامة ج9 ص164 ، بداية المجتهد ج2 ص452 .

⁽²⁾ الشرح الكبير للدردير ج4 ص165 ، ومغني المحتاج ج6 ص327 ، بداية المجتهد ج2 ص452 .

للكافرين على المؤمنين سبيلا . ولأننا لو قبلنا شهادتهم ، لأوجبنا على القاضي أن يقضى بشهادتهم ولا يلزم على المسلم بقولهم شيء .
وأما الاستدلال بأية السفر على أنها منسوخة .

ويرد على ذلك :

1- بأن الله سبحانه وتعالى لم يمنع قبول قول الكفار على المسلمين للحاجة بنص القرآن الكريم على ذلك - والقاضي ملزم أن يقضي بالحق عند ظهور الحجة الصادقة .
2- ادعاء دعوى نسخ الآية .

يرده : ماصح عن عائشة - رضي الله عنها - فيما يرويه جبير بن نفير أنها قالت : هل تقرأ سورة المائدة ، قلت نعم قلت فإنها آخر سورة فما وجدتم فيها من حلال فحلوه وما وجدتم فيها من حرام فحرموه ، فالحق أن الآية محكمة وأن حكمها شرع دائم ، وأن شهادة غير المسلم جائزة مقبولة في الوصية إذا كان المسلم على سفر ، ولم يجد أحداً من المسلمين .

السابع : العدالة : - العدل هو من لا يطعن عليه في بطن ولا فرج .

وعلة ذلك : أن أكثر أنواع الفساد والشر ترجع إلى هذين العضوين .

وقيل العدل : هو من لم يعرف عليه جريمة في دينه فهو عدل .

وقيل : من غلبت حسناته سيئاته فهو عدل . يؤيده قوله - صل الله عليه وسلم - إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان ⁽¹⁾ .

وقيل العدل : من يجتنب الكبائر ، وأدى الفرائض ، وغلبت حسناته على سيئاته . وهو اختيار الإمام فخر الدين رحمه الله .

فالعدالة : هي كون حسنات الرجل أكثر من سيئاته ، وهذا يتناول اجتناب الكبائر وترك الإصرار على الصغائر ⁽²⁾ .

والحقيقة أن اجتناب الكبائر كلها هو شرط لصح الشهادة وبعد توقيها يلاحظ الشأن الغالب ، فمن كثرت معاصيه أثر ذلك في شهادته ومن ندرت منه المعصية قبلت شهادته وهذا هو حد العدالة المعتبرة ، حتى لا يترتب على التشدد سد باب الشهادة وإماتة الحقوق ⁽³⁾ .

ماهية الكبائر والصغائر : يقال : إن مافيه حد في كتاب الله عز وجل فهو كبيرة ومالا حد فيه فهو صغيرة .

وهذا القول ليس بسديد ، فإن أكل الربا كبيرة ولا حد فيه في كتاب الله سبحانه وتعالى .

وقال بعضهم : إن ما يوجب الحد فهو كبيرة ، ومالا يوجب الحد فهو صغيرة وهو منقوض أيضاً ، بأكل الربا فهو كبيرة ، ولا يوجب الحد وكذا يبطل بأشياء أخرى هي كبائر ولا توجب حد مثل عقوق الوالدين ، والفرار من الزحف ⁽¹⁾ .

وقال بعضهم : ما كان مقروناً بوعيد فهو كبيرة ، نحو قتل النفس ، وقذف المحصنات ، والزنا ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم والفرار من الزحف .

(1) بدائع الصنائع ج 6 ص 268 ، فتح القدير ج 6 ص 11 .

(2) الإختيار لتعليل المختار ص 203 ، فتح القدير ج 6 ص 11 ، بدائع الصنائع ج 6 ص 268 .

(3) الفقه الإسلامي أ . د / الزحيلي ج 6 ص 565 .

(1) بدائع الصنائع ج 6 ص 268 ، فتح القدير ج 6 ص 11 .

لقول رسول الله - صل الله عليه وسلم - " ألا أنبئكم بأكبر الكبائر فقالوا بلى يا رسول الله فقال الإشراف بالله ، وعقوق الوالدين ، وكان عليه الصلاة والسلام متكئاً فجلس ثم قال ألا وقول الزور ، ألا وقول الزور " (2) .

إذا تبين لنا مفهوم العدالة في عرف الشرع تبين لنا أنه لا عدالة لشارب الخمر ، لأن شربه كبيرة فتسقط به بالعدالة .

ومن مشايخ الحنفية من قال : إذا قال كان الرجل صالحاً في أموره تغلب حسناته على سيئاته ، ولا يعرف بالكذب ، ولا بشيء من الكبائر غير أنه يشرب الخمر أحياناً لصحة البدن ، والتقوى لا التلهي يكون عدلاً .

والفتوى التي عليها عامة المشايخ أنه لا يكون عدلاً لأن شرب الخمر كبيرة محضة . ولا شك أن القول الأول يؤدي إلى انتشار الفساد وهو ما يقع فيه كثير من الناس ، وهو أمر عمت به البلوى في زماننا ، وكذا لا عدالة لمن يحضر مجالس شرب ويجلس بينهم وإن كان لا يشرب ، لأن حضوره مجلس الفسق فسق (1) .

وإليك بعض الفروع التي تتعلق بالعدالة بيانها كالتالي : -

الفرع الأول : الإكتفاء بالعدالة الظاهرة .

حول اختلاف الفقهاء في العدالة هل هي مشترطة أم لا ؟

يثور السؤال التالي: هل يكتفى بظاهر عدالة المسلم أم لابد من السؤال عنه في السر والعلانية ؟
وخلاف الفقهاء كالتالي يرى الإمام أبو حنيفة: أنه يكتفى بظاهر عدالة المسلم إلا في الحدود والقصاص، فإن طعن فيه الخصم سأل عنه .

وقال أبو يوسف ومحمد: أنه لا تقبل الشهادة إلا من الشخص الذي ثبتت عدالته فإذا عرف القاضي فسقه ردت شهادته ، ويشترط أن يسأل عن الشاهد في جميع الحقوق سراً وعلانية لأن معرفة العدالة شرط في قبول الشهادة في جميع الحقوق (2) .

الدليل على الإكتفاء بالعدالة الظاهرة

أولاً : بما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله - صل الله عليه وسلم - قال :

" المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدوداً في قذف" (1) .

ثانياً : ما روي عن عمر - رضي الله عنه - قال : " المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدوداً حقاً ، أو مجرباً عليه شهادة زور ، أو ظنياً في ولاء أو قرابة " (2) .

ثالثاً : روي أن أعرابياً جاء إلى النبي - صل الله عليه وسلم - فشهد برؤية الهلال ، فقال له النبي - صل الله عليه وسلم - " أتشهد أن لا إله إلا الله فقال : نعم فقال : أتشهد أني رسول الله قال : نعم ، فصام وأمر الناس بالصيام " (3) .

ففي هذه الأحاديث الشريفة دلالة واضحة على الإكتفاء بعدالة المسلم الظاهرة .

(2) الحديث متفق عليه ، سبل السلام ج4 ص129 .

(1) بدائع الصنائع ج6 ص269 ، الإختيار ص203 ، فتح القدير ج6 ص11 .

(2) الإختيار ص202 ، مغني المحتاج ج4 ص388 ، المغني ج11 ص411 .

(1) قال الزيلعي رواه ابن أبي شيبه في مصنفه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، نصب الراية ج4 ص81 .

(2) قال ابن حزم هو جزء من كلام عمر - رضي الله عنه - كما روينا من طريق أبي عبيد قال : حدثنا جعفر بن برقان قال : كتب عمر إلى ابن أبي موسى . ثم ساق الحديث ، المحلى لابن حزم ج9 ص393 مسألة (1285) .

(3) نيل الأوطار للشوكاني ج4 ص186 .

ومن المعقول : أن العدالة هي الأصل ، لأنه ولد غير فاسق ، والفسق أمر طارئ مظنون ، فلا يجوز ترك الأصل بالظن .

الدليل على استثناء الحدود والقصاص : أن الأصل في الشاهد العدالة ، وكذا الأصل في المشهود عليه العدالة والشاهد وصفه بالزنا والقتل فتقابل الأصلان فرجحنا بالعدالة الباطنة ، ولأن الحدود مبناها على الإسقاط ، فيشترط فيها استقصاء معرفة حال الشهود ، ولأنها تدرأ بالشبهات .
حجة صاحبان ومن وافقهم : أن الحاكم يجب أن يحتاط في حكمه ، صيانته له عن النقص والإبطال وذلك بالسؤال في السر والعلانية في سائر الحقوق ، لأن القضاء قائم على الحجة ، وهي شهادة العدول⁽¹⁾ .

والفتوى في المذهب الحنفي على قول أبي يوسف ومحمد للإحتياط والمروى عن المتأخرين من الحنفية ، أن هذا الاختلاف عاصر وزمان لا اختلاف حجة وبرهان ، لأن زمن أبي حنيفة كان زمن الصلاح : لأنه زمن التابعين ، وشهد لهم النبي - صل الله عليه وسلم - بالخيرية بخلاف زمن صاحبين قال - صل الله عليه وسلم - " خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ، ثم إن بعدهم قوماً يشهدون ولا يستشهدون ، ويخونون ولا يؤتمنون ، وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن " (2) .

وفي هذا الحديث الشريف دلالة واضحة على أن الصحابة أفضل من التابعين ، والتابعين أفضل من تابعيهم ، وهذا الحديث يعارضه حديث أبو عبيدة قال : يا رسول الله هل هناك أحد خير منا ؟ أسلمنا معك ، وهاجرنا معك قال : قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني ، وفي رواية " يأتي على الناس زمان الصابر فيه على دينه له أجر خمسين منكم " .

والجمع بين هذه الأحاديث أولى فنقول : بأن الصحبة فضيلة رمزية لا يوازيها شيء من الأعمال ، لمن صحبه - صل الله عليه وسلم - وإن قصر عمله وأجره باعتبار الإجتهد في العبادة وتكون خيرتهم على من سيأتي بعدهم باعتبار كثرة الأجر لا بالنظر إلى ثواب الأعمال ، وهذا يكون في حق بعض الصحابة ، وأما مشاهير الصحابة فإنهم حازوا السبق من كل نوع من أنواع الخير⁽¹⁾ .

الفرع الثاني : شهادة الفاسق

اختلف الفقهاء في جواز القضاء بشهادة الفاسق على النحو التالي :

يرى الحنفية : أنه يجوز القضاء بشهادة الفاسق وينعقد النكاح بحضوره⁽²⁾ .

ويرى الشافعي : أنه لا يجوز للقاضي أن يقضى بشهادة الفاسق أصلاً .

وجه قول الشافعي : أن مبنى قبول الشهادات على الصدق ، ولا يظهر الصدق إلا بالعدالة ، لأن خبر من ليس بمعصوم عن الكذب يحتمل الصدق والكذب ، ولا يقع الترجيح إلا بالعدالة⁽¹⁾ .

وفي عدم انعقاد النكاح بشهادة الفاسق استدلل الشافعية

بقوله - صل الله عليه وسلم - " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل " (2) . ففيه أن العدالة مشترطة لا يجوز التخلي عنها .

(1) الإختيار لتعليق المختار ص 203 ، المغني لابن قدامة ج 11 ص 411 .

(2) ومعنى يظهر فيهم السمن : أي أنهم يتوسعون في المأكّل والمشارب لاحظ سبل السلام ج 4 ص 126 ، 127 .

(1) المبسوط ج 16 ص 113 ، بدائع الصنائع ج 6 ص 268 ، سبل السلام ج 4 ص 127 ، 128 .

(2) بدائع الصنائع ج 6 ص 168 .

(1) مغني المحتاج ج 4 ص 288 .

واستدل الحنفية : بقوله تعالى (واستشهدوا شاهدين من رجالكم) - وقوله - صل الله عليه وسلم - " لا نكاح إلا بشهود " والفاسق شاهد لقوله تعالى (ممن ترضون من الشهداء) قسم الله تعالى الشهود إلى مرضيين وغير مرضيين ، فيدل علي أن غير المرضي وهو الفسق شاهداً .

ولأن حضرة الشهود في باب النكاح لدفع تهمة الزنا لا للحاجة إلى شهادتهم عند الجحود والإنكار ، لأن النكاح يشتهر بعد وقوعه ، فيمكن دفع الجحود والإنكار بالشهادة بالتسامع ، والتهمة تندفع بحضر الفاسق فينعد النكاح بحضرته (3) .

ويرد على الشافعي : قوله " الركن صدق الشاهد " نقول نعم ، لكن الصدق على العدالة لا محالة ، فإن من الفسقة من لا يبالي بارتكابه أنواع من الفسق ، ويستتكف عن الكذب ، والكلام في فاسق تحري القاضي الصدق في شهادته فغلب على ظنه صدقه ، ولو لم يكن كذلك لا يجوز القضاء بشهادته عندنا .

وأما الحديث فقد روي عن بعض نقلة الحديث أنه لم يثبت عن رسول الله - صل الله عليه وسلم - ، ولن يثبت فلا حجة له فيه بل هو حجه عليه لأنه ليس فيه جعل العدالة صفة للشاهد ، لأنه لو كان كذلك ، لقال : " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل " بل هذا إضافة الشاهدين إلى العدل وهي كلمة التوحيد وكأنه قال عليه الصلاة والسلام " لا نكاح إلا بولي مقابل كلمة العدل ، وهي كلمة الإسلام ، والفاسق مسلم فينعد النكاح بحضرته " .

الفرع الثالث : شهادة المحدود في قذف إذا تاب .

اختلف الفقهاء في قبول شهادة المحدود في قذف بعد توبته على قولين :-

القول الأول : يرى الحنفية ، عدم قبول شهادته إذا تاب (1) .

القول الثاني : يرى جمهور الفقهاء : قبول شهادته بعد التوبة (2) .

فيكون تقديره ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً إلا الذين تابوا (1) .

ويجاب على ذلك : بأن هذا الإستثناء منصرف إلى ما يليه ، وهو قوله تعالى (وأولئك هم الفاسقون) وهو ليس بمعطوف على ما قبله ، لأن ما قبله طلبي ، وهو إخباري (2) .

سبب الخلاف : وهو أن الإستثناء إذا تعقب جملاً متعاطفة هل ينصرف إلى الكل أو الأخيرة .

عند الحنفية : ينصرف إلى الأخيرة .

وعند الجمهور : ينصرف إلى الكل .

فالحنفية يرون : أن الإستثناء في قوله تعالى (إلا الذين تابوا) يعود فقط إلى أقرب مذكور ، وهو وصفهم بالفسق (3) .

فيرتفع الفسق فقط إذا تابوا ولا يعود الإستثناء إلى غير ذلك .

وقال الجمهور : إن الإستثناء يتناول الأمرين جميعاً ، لأن الفسق متى ارتفع تقبل الشهادة (4) .

(2) الحديث أخرجه البيهقي وابن حبان عن عمران بن حصين وعائشة وأبي هريرة وجابر وغيرهم في نصب الراية لتخريج أحاديث الهداية ج3 ص167 .

(3) بدائع الصنائع ج6 ص271 .

(1) فتح القدير ج6 ص34 ، بدائع الصنائع ج6 ص271 .

(2) مغني المحتاج ج4 ص438 ، المغني لابن قدامة ج9 ص197 .

(1) بداية المجتهد ج2 ص452 ، مغني المحتاج ج4 ص438 ، المغني ج9 ص197 .

(2) بدائع الصنائع ج6 ص271 .

(3) فتح القدير ج6 ص29 .

تفصيل قول الحنفية : لا يقال إن رد الإستثناء إلى الجملة الأخيرة ينفي الفائدة ، لأنه معلوم شرعاً أن التوبة تزيل الفسق بغير هذه الآية .

وقد تقدم في هذه الآية ثلاث جمل هي قوله تعالى (**فاجلدوهم**) وقوله تعالى (**ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً**) وقوله تعالى (**وأولئك هم الفاسقون**) والظاهر من عطف (**ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً**) أنه داخل في حيز الحد للعطف مع المناسبة وقيد التأييد .

أما المناسبة : فلأن رد شهادته مؤلم لقلبه مسبب عن فعل لسانه ، كما أنه ألم قلب المقذوف بسبب فعل لسانه .

وكذا قيد التأييد : لا فائدة له إلا تأييد الرد ، وإلا لقال ولا تقبلوا لهم شهادة ، وأولئك هم الفاسقون تكون جملة مستأنفة لبيان تعليل عدم القبول ، ثم استثنى الذين تابوا ، وهذا لأن الرد على ذلك التقدير ليس إلا للفسق ويرتفع بالتوبة فلا معنى للتأييد على تقدير القبول بالتوبة .

ولا يخفى أن قول الحنفية هو الأولى بالأخذ والإعتبار ، لأن قياس جمهور الفقهاء المحدود في القذف ، على المحدود في الحدود الأخرى قياس في مقابلة النص ، لأن الحدود الأخرى لم تقرر بما يوجب أن الرد من تمام الحد ⁽¹⁾ .

الفرع الرابع : تزكية الشهود .

الذى يشهد بعدالة الشاهد يسمية الفقهاء معدلاً مزكياً .

والتزكية نوعان : تزكية في السر ، وتزكية في العلانية ، ويشترط في المزكي أو المعدل الشروط التي تشترط في الشاهد لأن التزكية شهادة بالعدالة ، ويختص المزكي بأن يكون عارفاً بأسباب الجرح والتعديل ويشترط فيه : أن يذكر سبب الجرح كالزنا والسرقة وشرب الخمر .

أما سبب التعديل فلا يجب ذكره ، لأن الأصل العدالة ولا بد أن يقول المزكي هو عدل جائز الشهادة وقيل : يكتفى بقوله هو عدل ، لأن الأصل هو الحرية تبعاً للدار ، وإن لم يكن عدلاً عنده قال : الله أعلم بحاله .

فإن اكتفى الحاكم أو القاضي بتزكية السر جاز :

قال محمد بن الحسن : لأن تزكية العلانية بلاء وفتنة ، ثم إنه لا بد في تزكية العلانية ، أن يجمع بين المزكي والشاهد لتنتفي شبهة تعديل غيره .

وتزكية السر : أن يبعث ورقة مختومة إلى المزكي فيها اسم الشاهد ونسبه ومصلاه ، ويردها المزكي كذلك سراً ⁽¹⁾ .

وقد كانت التزكية بالعلانية في عصر الصحابة رضي الله عنهم لأن القوم كانوا صلحاء ، والمعدل ما كان يتوقى عن الحرج لعدم مقابلة الجارح بالأذى ، ووقع الإكتفاء بتزكية السر في زماننا ، لأن العلانية بلاء وفتنة لمقابلتهم الجارح بالأذى .

وينبغي للقاضي أن يختار في هذه الحالة ، أوثق الناس وأورعهم ديانة ، وأعظمهم أمانة ، وأكثرهم بالناس خبرة ، وأعلمهم بالتمييز .

وينبغي للمزكي أن يسأل عن أحوال الشهود وتعرفها من جيرانهم وأهل سوقهم ، فإن ظهرت عدالتهم عنده كتب في آخر الورقة هو عندى جائز الشهادة ، وإلا كتب : أنه غير عدل وختم الورقة وردها . ويقول القاضي بعد ذلك للمدعى زد في شهودك ولا يقول جرحوا .

⁽⁴⁾ المغني لإبن قدامة ج9 ص197 .

⁽¹⁾ فتح القدير ج6 ص39 .

⁽¹⁾ الإختيار لتعليل المختار ص204 .

ويقبل في تزكية السر قول الوالد ، وكل ذى رحم ، والعبد والأعمى ، والمحدود في قذف ، لأنها أخبار.

وعند محمد : أنها شهادة فلا تقبل (1) .

قبول تزكية من واحد : اختلف الفقهاء في قبول التزكية من واحد على قولين : -

القول الأول : أنه يكفي بتزكية الواحد ، بهذا قال الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف ، وبقولهم قال مالك وأحمد في رواية (2) .

القول الثاني : يرى الإمام محمد بن الحسن ، أنه لابد من اثنيين وبه قال الشافعي وأحمد في رواية . وحجتهم في ذلك : أن التزكية في معنى الشهادة ، لأن ولاية القاضي تنبني على ظهور العدالة ، وهي بالتزكية ، فتوقفت عليها كما توقفت عليها فيشترط فيه العدد ، كما يشترط العدالة (1) .

وحججه القول الأول : أنه ليس في معنى الشهادة ، ولهذا لا يشترط فيه لفظ الشهادة ومجلس القضاء ، فلا يشترط فيه ما اشترط فيها (2) .

ويرد على الفريق الثاني : " قولهم باشتراط العدد كالشهادة " أن اشتراط العدد في أمر الشهادة أمر حكمي ثبت بالنص على خلاف القياس لأن القياس لا يقتضي ذلك لبقاء احتمال الكذب ، فيها لأن اقتطاعه إنما يكون بالتواتر ورجحان الصدق إنما هو بالعدالة لا العدد ، كما في رواية الأخبار ، فلم يثبت بالعدد المشروط لا العلم ولا العمل ، لكننا تركنا ذلك بنصوص الدلالة على العدد فلا يتعدها إلى التزكية (3) .

والرأي القائل بعدم اعتبار العدد هو القول الأولي بالقبول والرجحان ، وذلك لأنها لا تعتبر شهادة وإنما هي أخبار تقال عن الشاهد .

تزكية المدعى عليه : تزكية المدعى عليه للشاهد غير مقبولة .

معناها : أن يقول هم عدول إلا أنهم أخطأوا أو نسوا لما قالوا : صدقوا أو هم عدول صدقة ، فقد اعترف بالحق ، فيقضى بإقراره ، لا ببينته ، لأن البينة عند الجحود .

وقيل : يجوز تعديله .

وجه الظاهر : أن المدعي والشهود يزعمونه كاذباً في إنكاره مبطلاً في جحوده فلا يصلح مزكياً (1) .

حكم من يأتي الكبائر .

ولا عدالة لمن يأتي الكبائر التي يتعلق بها الحد ، وهي التي ذكرها الرسول - صل الله عليه وسلم - في الحديث المعروف ، وهي الإشراف بالله والفرار من الزحف وعقوق الوالدين ، وقتل النفس بغير حق ، وبهت المؤمن ، والزنا ، وشرب الخمر .

وقيل : إن هذا بناء على أن الكبيرة أعم مما فيه حد أو قتل .

وقال بعضهم : إن ما كان حراماً لعينه فهو كبيرة .

(1) فتح القدير ج 6 ص 14 ، 15 ، مع العناية على هامشه .

(2) الاختيار ص 205 ، بدائع الصنائع ج 6 ص 272 ، بداية المجتهد ج 2 ص 453 ، المغني لابن قدامة ج 9 ص 198 .

(1) مغني المحتاج ج 4 ص 439 ، المغني لابن قدامة ج 9 ص 198 .

(2) العناية على الهداية ج 6 ص 15 هامش فتح القدير .

(3) بدائع الصنائع ج 6 ص 272 .

(1) فتح القدير ج 6 ص 15 ، الاختيار لتعليل المختار ص 205 .

وقيل : ماثبتت حرمة بنص القرآن الكريم ، ونقل عن خواطر زادة : أنها ما كانت حراماً محضاً مسمى في الشرع فاحشة كاللواط ، أو لم يسم بها لكن شرع عليها عقوبة محضة بنص قاطع ، إما في الدنيا بالحد كاسرقة والزنا ، وقتل النفس بغير حق ، أو الوعيد بالنار في الآخرة كأكل مال اليتيم⁽¹⁾ .
وقد بنى الحنفية الكبيرة على ثلاث معان :

أحدهما : ماكان شنيعاً بين المسلمين ، وفيه هتك حرمة الله تعالى .
الثاني : أن يكون فيه منابذة المروءة والكرم ، وكل فعل يرفض المروءة والكرم فهو كبييرة .
الثالث : أن يصير على المعاصي والفجور .
حكم من يفعل الأفعال المستحقة .

وهي الأعمال المستقبحة ، وقيل : المستخفة – بفتح الخاء وكسرهما وهي التي يستخف الناس فاعلها ، أو الخصلة التي تستخف الفاعل فيبدو منه مالا يليق ، وعلى هذا المعنى قوله تعالى (**ولا يستخفك الذين لا يوقنون**) .

والحاصل فيه : أن ترك المروءة مسقط للعدالة وإن كان لا يستحي عن مثله ، لا يمتنع عن الكذب فيتهم .

والمروءة : هي الإنسانية ، والمراد بها الحياء وفعل المحاسن والمكارم التي يعتبرها الناس ، والبعد عن المساوىء والقبائح التي لا يرضى عنها أصحاب الفضائل والعقول .
وإنما اعتبرت المروءة من شروط العدالة ، لا من لا مروءة له لا حياء له ، ومن لا حياء له استباح أى شيء ولم ستورع عن الكذب في سبيل ذلك فترك لما رويناه من الحديث " إذا لم تستح فاصنع ما شئت "⁽¹⁾ .

سب السلف .

لا عدالة لمن يسب الصحابة والتابعين ومنهم الأئمة الأربعة وعلة ذلك : أنه إذا ظهر سب واحد من المسلمين تسقط عدالته فإذا أظهر في واحد من الصحابة كيف يكون مقبولاً .
ويقيد هنا : بإظهار السب ، لأنه لو اعتقده ولم يظهره فهو على عدالته تقبل شهادته لأن إظهار الشتيمة مجونة وسخف ولا يأتي به إلا الأوضاع والأسقاط وشهادة السخيف لا تقبل⁽²⁾ .

شهادة أهل الذمة .

شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض مقبولة ، لأن الشهادة من باب الولاية ، وهم أهل الولاية بعضهم على بعض فلا يمنع قبول الشهادة ، لأنه يتجنب محرم دينه ، والكذب محرم في جميع الأديان وهذا عند الحنفية .

. واستدل الحنفية : بما روى أن النبي – صل الله عليه وسلم - " أجاز شهادة النصارى بعضهم على بعض "

ومن المعقول : أن الذمي من أهل الولاية على جنسه بدليل ولايته على أولاده الصغار ومماليكه فجازت شهادته على جنسه⁽¹⁾ .

⁽¹⁾ تكلمة فتح القدير ج6 ص38 ، والعناية عليه .

⁽¹⁾ وقيل في تعريفها : أن يأتي الإنسان بما يعتذر منه مما يخسه عن مرتبته عند أهل الضمان ، وقيل : السميت الحسن وحفظ اللسان وتجنب السخف والمجون ، والإرتفاع عن كل خلق دنيء ، والسخف : رقة العقل . فتح القدير ج6 ص40 .

⁽²⁾ فتح القدير ج6 ص41 .

⁽¹⁾ العناية على الهداية ج6 ص44 .

والذى عليه المحاكم الآن هو ما قال به الحنفية من إجازة شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض ، لأن ملهم وإن اختلفت فلا تمنع من شهادة بعضهم على بعض في دار الإسلام .
ولأن الله تبارك وتعالى أثبت لهم الولاية بعضهم على بعض قال تعالى (**والذين كفروا بعضهم أولياء بعض**) فأثبت لهم الولاية بعضهم على بعض ، والولاية أعلى مرتبة من الشهادة وغاية الشهادة أن نشبهها بالولاية⁽²⁾ .

وهذا الرأى هو الأولى بالقبول والرجحان ، لأننا نجز شهادة بعضهم على بعض فكيف نحكم بينهم إن لم يوجد مسلم يشهد في الواقعة ؟

الشرط السابع : من شروط الشاهد

أن لا يجز الشاهد إلى نفسه مغنم ، ولا يدفع عن نفسه مغرمًا بشهادته . لقوله - صلى الله عليه وسلم - " لا شهادة لجار المغنم ولا لدافع المغرم .

ولأن شهادته إذا تضمنت معنى الدفع والنفع فقد صار متهمًا ، ولا شهادة لمتهم على لسان رسول الله - صل الله عليه وسلم .

ولأنه إذ جر النفع إلى نفسه بشهادته لم تقع شهادته لله بل لنفسه فلا تقبل⁽³⁾ .

اتهام الشاهد .

يشترط في الشاهد الذي لا تقبل شهادته ألا يكون متهمًا في شهادته وتتحقق التهمة بالخصومة ، أو العداوة ، أو بجلب منفعة ، أو دفع مضرة ، وبناءً على ذلك : لا تقبل شهادة الآباء للأبناء ، ولا شهادة الأبناء للآباء ، ولا شهادة العدو لعدوه ، ولا الخصم على خصمه ، ولا شهادة الوصي أو الوكيل للموصي أو الأصيل ، ولا شهادة أحد الزوجين للآخر ، ولا شهادة السفينة لمدينه المحجور عليه المفلس .

ولم يخالف في ذلك إلا الظاهرية ، فقد صححوا شهادة الجميع في ذلك إلا العدو إذا أخرجته العداوة إلى حد الإجحاف⁽¹⁾ .

وإليك بيان بعض هذه الفروع :

أولاً : شهادة الآباء للأبناء والعكس :

الأصل في رد الشهادة عند الجمهور : ما أخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه ، وعبد الرازق من قول شريح قال : " لا تجوز شهادة الابن لأبيه ، ولا الأب لابنه ، ولا المرأة لزوجها ، ولا الزوج لامرأته " .

ورغم أن هذا الحديث غريب إلا أن الخصاف ، وهو أبو بكر الرازى الذى شهد له أكابر المشايخ أنه كبير في العلم رواه بسنده إلى عائشة رضى الله عنها⁽²⁾ .

ولأن هذه الشهادة تتضمن معنى النفع والدفع فيكون فيها تهمة بدليل قوله - صل الله عليه وسلم - : " لا شهادة لجار المغنم ولا لدافع المغرم "⁽¹⁾ .

ولأن مال كل منهما للآخر ، لقوله - صل الله عليه وسلم - " أنت ومالك لأبيك "⁽²⁾ .

(2) القضاء في الفقه الإسلامي أ . د / رأفت عثمان ص 175 فما بعدها .

(3) بدائع الصنائع ج 6 ص 272 ، المبسوط ج 16 ص 120 .

(1) بداية المجتهد ج 2 ص 452 المحلى لابن حزم ج 9 ص 415 مسألة (1789) .

(2) فتح القدير ج 6 ص 31 ، بدائع الصنائع ج 6 ص 272 .

(1) البحر الرائق ج 6 ص 26 .

(2) نصب الراية لتخريج أحاديث الهداية ج 4 ص 87 ونيل الأوطار ج 8 ص 290 .

ولأن الولد جزء من أبيه وبضعه منه لقوله - صل الله عليه وسلم - "يا عائشة أن فاطمة جزء مني يربيني ما يربيهها " .

من هذا يتبين لنا الإتهام بهذه الشهادة حاصل لوجود الميل الطبيعي بينهم والتهمة تمنه الشهادة لما روى عن رسول الله - صل الله عليه وسلم - قال : " لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ، ولا ذي أحنة" (3) .

فالظنين : هو المتهم ، وذو الأحنة : أي صاحب العداوة وأما سائر القرابات ، كالأخ والعم والخال ونحوهم فتقبل شهادة بعضهم على بعض ، لأن هؤلاء ليس لبعضهم تسلط في مال البعض عرفاً ، فالتحقوا بالأجانب (4) .

وعلة رد شهادة الولد لأبيه :

1- أن المنافع بينهما متصلة ولهذا لا يجوز دفع الزكاة إليهم ، واتصالها يوجب أن تكون الشهادة لنفسه من وجه ، أو أن يتمكن فيه شبهة .

2- ماروى أن القاضي شريح : رد شهادة الحسن - رضي الله عنه - حين شهد لوالده " علي " - رضي الله عنه - فقال علي - رضي الله عنه - أما سمعت أنه - صل الله عليه وسلم - قال في الحسن والحسين " هما سيدا شباب أهل الجنة " قال : نعم صدق رسول الله - صل الله عليه وسلم - ولكن أنت بشاهد آخر ، فقيل : إنه عزله ، ثم أعاده ، وزاد في رزقه ، فرجع الإمام علي - رضي الله عنه - دليل على صحة قضاء شريح (1) .

ثانياً : شهادة أحد الزوجين للآخر :

وقع خلاف بين الفقهاء في قبول شهادة أحد الزوجين للآخر على قولين :

القول الأول : أنه لا تقبل شهادة أحدهما للآخر ، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد (2) .
القول الثاني : أن شهادة أحد الزوجين للآخر مقبولة .

بهذا قال الشافعي وأبي ثور وهي عن رواية أحمد ، وهو مذهب الظاهرية (3) .
واستدلوا : بأن الأملاك بينهما متميزة ، والأيدي متحيزة أي كل يد في حيز غير حيز الأخرى فهي ممنوعة عنه - فلا اختلاط فيها ولهذا يجري بينهما القصاص ، والحبس بالدين ، ولا معتبر بينهما من المنافع المشتركة ، ولهذا يقتص من أحدهما للآخر ، ويحبس بدينه ، وكل من كان كذلك تقبل شهادته في حق صاحبه ، كالأخوين وأولاد العم ، والغريم إذا شهد لمديونه المفلس بمال على آخر تقبل مع توهم أنه يشاركه في منفعته (1) .

(3) المحلى لابن حزم ج 9 ص 416 وما بعدها .

(4) بدائع الصنائع ج 6 ص 272 .

(1) البحر الرائق ج 6 ص 26 .

(2) وقال ابن أبي ليلى والثوري والنخعي لا تقبل شهادة الزوجة لزوجها وتقبل شهادة الزوج لها لعدم التهمة ، وعلة ذلك : أن لها حقاً في ماله ، لوجوب نفقتها عليه . بداية المجتهد ج 2 ص 23 ، المغني لابن قدامة ج 9 ص 416 ، 417 .

(3) استثنى الشافعية من ذلك شهادة الزوج على زوجته في الزنا لأن شهادته دعوى خيانة في حقه فلا تقبل منه لاتهامه فيها ولأنه خصم لها فيما يشهد . ج 2 ص 23 ، المغني ج 9 ص 193 .

(1) المحلى لابن حزم ج 9 ص 417 ، الدعوى والإثبات أ. د فريد نصر ص 66 .

واستدل الحنفية : بالسنة والمعقول .

من السنة المشرفة : بما روي عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله - صل الله عليه وسلم - " لا تجوز شهادة الولد لولده ، ولا الوالد لوالده ولا المرأة لزوجها ولا الزوج لامرأته " (2)

ففيه دليل على عدم قبول الشهادة بين الزوجين لأن شهادة أحدهما للآخر انتفاع لا يخفى ، لان في يساره بهذه الشهادة يسار لها .

ومن المعقول : أن كل واحد منهما يبسط في مال صاحبه بدليل قوله تعالى (**وقرن في بيوتكن**) حيث إن البيوت في الأغلب للأزواج ، ومع ذلك أضيفت إليهن ، باعتبار أن بين الزوج هو بيتها ، فكان ملكه ملكها ، ولأنها ترثه فوجدت التهمة التي تمنع من الشهادة ، كالابن مع أبيه أو الأب مع ابنه ، لأن يسار الرجل يزيد نفقة المرأة وبه تزيد قيمة بضعتها ، فكان كل واحد منهما منتفعاً بشهادته لصاحبه (1) .

ويجاب على قول الشافعي ومن وافقهم بما يلي : قوله كالغريم .

1-نقول : بأن الغريم لا ولاية له على المشهود به إذ هو مال المديون ولا تصرف له عليه ، بخلاف الزوج فإنه لكونه قواماً عليها هو الذي يتصرف في مالها عادة .

2- وأما القصاص: فإنه بعد الموت لا زوجية (2) .

والرأى القائل بعدم القبول هو الأولى بالقبول والرجحان ، لأن التهمة بين الزوج وزوجته قوية وذلك لما بينهما من مصالح مشتركة ، وفي شهادة أحدهما للآخر جر نفع لأحدهما ، يعود على الآخر ولو بعد حين .

ثالثا : شهادة الأجير لمن استأجره :

شهادة الأجير لمن استأجره لا تجوز ، لأنه يستوجب الأجر بمنافعه وأداء الشهادة من جملتها ، فيصير ، كالمستأجر عليها وهو استحسان ترك به وجه القياس .

والقياس : أنها مقبولة لكونها شهادة عدل لغيره من كل وجه ، إذ ليس له فيما شهد ملك ، ولا حق ، ولا شبهة اشتباه ، بسبب اتصال المنافع ، لكن الإجماع المنعقد على قول واحد من السلف حجة يترك به القياس .

والمراد بالأجير : هو التلميذ الخاص الذي يعد ضرر أستاذه ضرر نفسه ، ونفع استاذته نفع نفسه .

ومعنى قوله - صل الله عليه وسلم - " لا شهادة للقانع بأهل البيت " (1) .

والقانع : هو التابع لأهل البيت كالخادم لهم ، وهذا معنى أنه يطلب معاشه منهم .

وقيل : إن التلميذ الخاص : هو الذي يأكل معه وفي عياله وليس له أجره معلومة (2) . **وقيل الأجير :** هو الأجير مسانئة ، أو مشاهرة ، أو مياومة (1) ، لأنه إذا كانت إجارته على هذا الوجه ، دخلت

(2) بدائع الصنائع ج6 ص272 ، البحر الرائق ج6 ص36 .

(1) بدائع الصنائع ج6 ص272 .

(2) فتح القدير ج6 ص32 ، البحر الرائق ج6 ص36 .

(1) الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه باسناد حسن ، نصب الراية ج4 ص83 .

(2) فتح القدير ج6 ص32 .

(1) السنة : واحدة السنين ، وفي نقصانها قولان : أحدهما الواو والآخر الياء ، وأصلها السنه بوزن الجبهة ، وتصغيرها سنيهة واستأجره مسانئة ، ومسانئة بمعنى . والمشاهرة : من الشهر كالمعاونة من العام ، والمياومة من اليوم مختار الصحاح مادة " سنة " و " شهر " و " يوم " .

منفعته التي هي الأداء في أجرته فيكون مستوجباً الأجر بها ، فيصير كالمستأجر عليها ، لأن العقد وقع بموجب تمليك منافعه ، ولهذا يستحق الأجرة بتسليم نفسه ، وإن لم يعمل بخلاف الأجير المشترك حيث تقبل شهادته للمستأجر ، لأن العقد لم يقع موجباً لتمليك منافعه بل وقع على عمل معين له ، ولهذا لا يستحق الأجرة حتى يعمل⁽²⁾ .

الشرط الثامن : من شروط الشاهد

أن لا يكون خصماً له لقوله - صل الله عليه وسلم - " لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين"⁽³⁾ .
ولأنه إذا كان خصماً فشهادته تقع لنفسه فلا تقبل .
ويندرج تحت هذا الشرط ما يلي :

أولاً : شهادة العدو لعدوه .

ولا تقبل شهادة العدو لعدوه ، والعلة في ذلك : أنه خصم والخصومة قد تدفع إلى الميل والإنحياز ، فيتهم الخصم بميله في الشهادة ولذا ترد شهادته .
ولأن العداوة تورث التهمة ، ولا يؤمن القول فيها لقوله - صل الله عليه وسلم - " لا تجوز شهادة ذو الغمزة والقانع لأهل البيت " .
والمراد بالعدو الذي ترد شهادته : هو صاحب العداوة الدنيوية وهو من يبغض المشهود عليه بحيث يتمنى زوال نعمته ، ويحزن بسروره ويفرح بمصيبته⁽¹⁾ .

ثانياً : شهادة الوكيل لموكله :

لا تقبل شهادة الوكيل لموكله فيما فوض النظر فيه إلى كل منهما ، لأنهما يثبتان لأنفسهما حق المطالبة والتصرف وهذه تهمة لا تقبل معها الشهادة .
فإن كان الوكيل معزولاً من الوكالة قبل الشهادة وكان الحق المشهود به يتعلق بما قبل العزل ، وكان له في ذلك يد الإنسان بالوكالة فلا تقبل شهادته إن كان هو الخصم بنفسه لوجود التهمة . فإن كان الخصم هو الموكل بعد أن عزله فوجهان في قبول الشهادة .
أحدهما : تقبل ، لانتفاء التهمة عند الشهادة .

والثاني : لا تقبل ، لأن الشاهد يعقد الوكالة قبل العزل بملك الخصومة عن الحق المشهود عليه من حيث الجملة ، وقد لا يعرف لمشهود عليه قبل العزل من الوكالة فتبقى التهمة وترد الشهادة⁽¹⁾ .
الشرط التاسع : من شروط الشاهد أن يكون عالماً بالمشهود به وقت الأداء ذاكراً له .
وهذا عند أبي حنيفة وقال صاحبان : ليس بشرط حتى إنه لو رأى اسمه وخطه وخاتمه ، لكنه لا يتذكر الحادثة ، يحل له أن يشهد .

وجه قولهما : أنه لما رأى اسمه وخطه وخاتمه على الكتاب دل أنه تحمل الشهادة ، وهي معلومة في الكتاب فيحل له أدائها فإذا أداها تقبل .

ولأن النسيان أمر جبل عليه الإنسان خصوصاً عند طول المدة بالشئ ، لأن طول المدة ينسي ، فلو شرط تذكر الحادثة لأداء الشهادة لانسد باب الشهادة فيؤدي إلى تضييع الحقوق وهذا لا يجوز .

(2) فتح القدير ج 6 ص 32 .

(3) رواه الحاكم عن أبي هريرة مرفوعاً وفي اسناده نظر ، نيل الأوطار ج 8 ص 291 .

(1) بدائع الصنائع ج 6 ص 72 ، البحر الرائق ج 6 ص 36 ، المذهب للشيرازي ج 2 ص 33 . وذو الغمزة : أي صاحب الشحناء والحقد والقانع هو : الخادم المنقطع للخدمة فلا تقبل شهادته للتهمة بجلب النفع لنفسه كالأجير الخاص ، سبل السلام ج 4 ص 128 ، نيل الأوطار ج 8 ص 291 .

(1) بدائع الصنائع ج 6 ص 272 ، المذهب ج 2 ص 329 ، المغني لابن قدامة ج 9 ص 184 .

وجه قول أبي حنيفة : استدل بقوله (ولا تقف ما ليس لك به علم) وقوله (عليه الصلاة والسلام) " إذا علمت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع " .

ويرى : أنه لا اعتماد على الخط والختم ، لأن الخط يشبه الخط ، والختم يشبه الختم ، ويجرى فيه الإحتيال والتزوير ، ومن المعلوم أن الخط للتذكر فخط لا يذكر وجوده وعدمه بمنزلة واحدة . ولا يخفى أن قول الإمام أولى بالأخذ والإعتبار وذلك لما يحدث في هذا الزمان من قضايا خطيرة أهمها مانراه ونقرأه في الصحف عن فنون التزوير والإحتيال ، فاشتراط تذكر الحادثة أولى⁽¹⁾ .

وحول القضاء بالشهادة على الخط نتناول الأمور التالية :

أولاً : شهادة الشاهد على خط نفسه .

ثانياً : الشهادة على خط الشاهد الميت أو الغائب غيبة بعيدة .

ثالثاً : الشهادة على خط المقر .

أولاً : شهادة الشاهد على خط نفسه .

فإذا رأى الشاهد خطه على الكتاب لا يشهد مالم يتذكر الحادثة ويأخذ نفس المعني القاضي والراوى .

وعلة ذلك : أن الخط يشبه الخط ، والمشتبه لا يفيد العلم وهذا قول أبي حنيفة واستدل :

بقوله - صل الله عليه وسلم - " إذا علمت مثل الشمس فاشهد " ولا علم مع النسيان وشرط حل الرواية عنده : أن يحفظ من حين سمع إلى حين الرواية .

أما على قول أبي يوسف ومحمد : يحل له أن يشهد .

وقيل : إن هذا باتفاق ، يعني عدم جواز الشهادة إذا رأى ولم يتذكر⁽¹⁾ .

محل الخلاف : إذا وجد القاضي القضية في ديوانه تحت ختمه وكذا إذا رأى الشاهد رقم شهادته عنده تحت ختمه ، وكذلك الراوى للحديث الذى يجده مكتوباً بخطه ولم يتذكر ، ووجد شهادته مكتوبة بخط غيره وهو له خط معروف .

فالإمام أبو حنيفة : لا يرى جواز الحكم بذلك ، لأن الخط يشبه الخط ، والمشتبه لا يفيد العلم .

والصاحبان : يرون جوازه .

واحتجوا : بأن القاضي لكثرة انشغاله يعجز عن أن يحفظ كل حادثة ، ولهذا يكتب ، وإنما يحصل المقصود بالكتاب إذا جاز له الإعتماد عليه عند النسيان الذى لا يمكن التحرز عنه .

ثانياً : الشهادة على خط الميت أو الغائب .

الشهادة على خط الشاهد الغائب بمكان بعيد ، أو الذى مات جائزة بشروط :

1- ألا يكون في المستند المشهود على الخط فيه ريبه من محو أو كشط ، فإن فيه ريبه فلا تجوز الشهادة عليه ، سواء اعتذر عن ذلك أو لا .

2- أن يعرف الشهود أن صاحب الخط كان يعرف من شهد عليه ، فإن لم يعرف ذلك ، لم يشهدوا على خطه لاحتمال أنه شهد على من لا يعرف .

3- أن يعرف الشهود الخط معرفة تامة ، بلا شك ولا ريبه فلا بد في المعرفة من القطع .

4- أن يعرف الشهود ، أن المشهود على خطه تحمل الشهادة ووضع خطه وهو عدل واستمر عدلاً إلى موته وهذا ظاهر في الشهادة على خط الشاهد⁽¹⁾ .

(1) بدائع الصنائع ج6 ص272 ، فتح القدير ج6 ص32 .

(1) بدائع الصنائع ج6 ص272 ، مواهب الجليل ج6 ص187 ، 188 .

(1) الحجج القضائية أ . د محمود على أحمد ص121 فما بعدها .

ومن هنا ندرك أنه لا يجوز الشهادة على خط الشاهد الغائب إلا إذا كان بعيداً ، فإن كانت المسافة قريبة ولا مشقة في الحضور إلى مجلس القاضي لسؤاله عن صحة هذه الشهادة ، فإن الشهادة لا تجوز.

ثالثاً: الشهادة على خط المقر .

هذه الشهادة جائزة ، والمراد بالإقرار كتابة فإذا شهد عدلان على خط شخص في ورقة مكتوبة فإنه يعمل بها ، ولا تحتاج إلى يمين ولو شهد عدل واحد حلف الطالب واستحق ، وهذه الشهادة جائزة بالشروط التي قدمناها .

المبحث الخامس ما يتحمله الشاهد

وما يتحمله الشاهد نوعان :

أحدهما : ما يثبت حكمه بنفسه من غير أن يحتاج إلى الإشهاد ⁽¹⁾ مثل : البيع ، والإقرار ، والغصب ، والقتل ، وحكم الحاكم ، فإذا سمع الشاهد ما كان من المسموعات ، كالبيع والإقرار وحكم الحاكم ، أو رأى ما كان من المبصرات كالغصب والقتل – جاز له أن يشهد به ، وإن لم يشهد عليه .
والعلة في ذلك : أنه علم الموجب بنفسه ، وهو الحادثة ، وكل من علم ذلك جاز له الأداء ، لوجود ماهو الركن في جواز الأداء ، ويستدل على ذلك بقوله تعالى (**إلا من شهد بالحق وهم يعلمون**) وقوله – **صل الله عليه وسلم** - " إذا علمت مثل الشمس فاشهد وإلا فذع " .

والمراد بالحكم هنا : هو جواز الشهادة .

ومعنى إثبات الحكم بنفسه : أنه يثبت ما وضعه الشارع له ، وحكمه يترتب عليه بنفسه من غير أن يحتاج إلى غيره من قضاء قاض كالبيع ، فإنه يثبت حكمه ، أعني الملك بنفسه وكذا الإقرار يفيد ظهور المقر به بنفسه وكذا الغصب يثبت وجوب رد العين أو القيمة بنفسه ، ففي البيع : يشترط أن يقول " أشهد أنه باع ، ولا يقول أشهدني " لأنه كذب " .

شهادة المختبيء : لو اختفى الشاهد وسمع من وراء حجاب لا يجوز له أن يشهد ، ولو فسر للقاضي ، بأن قال اسمع بالسماع من وراء الحجاب لا يقبله .

وعلة ذلك : أن النعمة – وهي الكلام الخفي – تشبه النعمة ، والمشتبه لا يفيد العلم ، فانتفى المطلق للأداء .

إلا إذا كان داخل البيت وعلم أنه ليس فيه أحد سواه ثم جلس على الباب ، وليس في البيت مسلك غيره ، فسمع الداخل ولم يره له أن يشهد .

مثال ذلك : الشهادة على امرأة لا يعرفها .

سأل محمد بن الحسن أبا سفيان عنها قال : لا يجوز حتى يشهد جماعة أنها فلانة .

وهل يشترط رؤية وجهها : اختلف المشايخ فيه .

منهم من لم يشترط ، وإليه مال الإمام خواهر زاده .

وقيل : يشترط رؤية شخصها ، وفي الجامع الصغير : يشترط رؤية وجهها .

ومن هنا فلا بد من معرفة تفيد التمييز فلا حاجة إلى رؤية وجهها ولا شخصها ، كما اختاره شيخ الإسلام خواهر زاده . إلا إذا لم يوجد من يعرفها ، وإذا وجد حينئذ يجري الخلاف المذكور .

النوع الثاني : مالا يثبت الحكم فيه بنفسه ، وهو مالا يوجب الشهادة بنفسه وإنما بالنقل إلى مجلس القضاء والإنابة في الأداء .

مثال ذلك : الشهادة على الشهادة فإنها لا يثبت بها الحكم مالم يشهده فإذا سمع شاهداً يشهد بشيء لم يجز له أن يشهد على شهادته .

وعلة ذلك : أن الشهادة – أي شهادة الأصول – موجبة بالنقل إلى مجلس القضاء ، ولا يكون النقل إلا بالإبانة والتحميل ، وقيل : الأول وهو التوكيل ، وتوكيل إلا بأمر الموكل هذا قول محمد ، والثاني قول أبي حنيفة وأبي يوسف : فإنهما لم يجعلاه بطريق التوكيل بل بطريق التحميل ⁽¹⁾ .

(1) وإنما جاز الأداء بلا إشهاد : لأنه علم الموجب بنفسه وهو الركن المسوغ لأداء الشهادة ، فتح القدير ج 6 ص 16 .

المبحث السادس

شروط الصيغة

يشترط في الصيغة، أن تتضمن أركان الشهادة من حيث التصريح بذكر المشهود به وعليه ، وصاحب الحق الذي يشهد به ، وأن تكون الشهادة موافقة لدعوى المدعي فيما يدعيه. وتكون الشهادة بلفظ أشهد بكذا أو على كذا فإن كانت بغير ذلك فإنها لا تقبل، كألفاظ الإعلام والإخبار ونحوهما، كأن يقول الشاهد أعلم أو أتأكد، أو أتيقن، أو أعرف، فإنه لا يؤدي المعنى ، لأن لفظ أشهد من الشهادة، فلا بد من الإثبات بلفظها الذي لا يحتمل غيرها.

المبحث السابع

شروط المشهود به

اشتراط الفقهاء شروطا يجب توافرها في المشهود به. أحدها: أن تكون الشهادة بمعلوم ، فإن كانت بمجهول لم تقبل. وعلة ذلك: أن علم القاضي بالمشهود به شرط صحة قضائه ومالم يعلم لا يمكنه القضاء به. وعلى ذلك: يخرج ما إذا شهد رجلان عند القاضي أن فلانا وارث هذا الميت، لا وارث له غيره فإن هذه الشهادة غير مقبولة.

وعلة ذلك: أنهما شهدا بمجهول، لجهالة الوارث أسباب الوراثة واختلاف أحكامها، فلا بد أن يقولوا ابنه ووارثه لا يعلمون له وارثا غيره، أو أخوه لأبيه وأمه لا يعلمون له وارثا غيره. وعلى هذا لا تصح الشهادة إلا إذا وضح الشاهد للقاضي صاحب حق، ومن عليه الحق، ونفس الحق المشهود طبقا لما عرفه، ووقت التحمل للشهادة ، ولذا يجب عليه أن يشير إلى ثلاثة أشياء حتى تصبح شهادته وتقبل وهي: المدعي، والمدعي عليه، والعين المدعاة. وعلة ذلك: أن الغرض هو التعريف، والإشارة أقوى سبل التعريف.

فإن كانت الشهادة على غائب أو ميت، أو من سماع وجب ذكر ما يؤدي إلى التعريف به بذكر اسمه ونسبه، ووصفه للمشهود به وصفا يتأكد منه علم الشاهد، ومعرفة الحقيقة لما يشهد به، فإن جهل ذلك لم تصح الشهادة. وشرط التسامع عند الشهادة بذلك:

أن يكون الشاهد قد سمع من جمع لا يؤمن تواطؤهم على الكذب. الشرط الثاني: أن يكون المشهود به معلوما للشاهد عند أداء الشهادة حتى لو ظن لا تحل له الشهادة، وإن رأى خطه وختمه وأخبره الناس بما يتذكر بنفسه، وهذا عند أبي حنيفة (رحمه الله)، وعندهما، إن رأى خطه وختمه له أن يشهد على نحو ما قدمناه في الشهادة على الخط⁽⁷⁹⁷⁾.

الشروط الخاصة ببعض الشهادات:

وأما الشروط التي تخص بعض الشهادات دون البعض الآخر فأنواع: أحدها: أن تكون الدعوى في الشهادة القائمة على حقوق العباد من المدعي بنفسه أو نائبه. وعلة ذلك: أن الشهادة في هذا الباب شرعت لتحقيق قول المدعي، ولا يتحقق قوله إلا بدعواه إما بنفسه وإما بنائبه.

(¹) بدائع الصنائع ج 6 ص 265 ، العناية على الهداية ج 6 ص 17/16 ، اللباب شرح مختصر الكتاب ص 58

(⁷⁹⁷) لاحظ بدائع الصنائع ج 6 ص 277.

وأما حقوق الله تبارك وتعالى، فلا يشترط فيها الدعوى كأسباب الحرمات من الطلاق وغيره، وأسباب الحدود الخالصة حقا لله تعالى إلا أنه اشترطت الدعوى في باب السرقة ، لأن كون المسروق ملكا لغير السارق شرط لتحقيق كون الفعل سرقة شرعا، ولا يظهر ذلك إلا بالدعوى فشرطت الدعوى لهذا.

الثاني: العدد في الشهادة فيما يطلع عليه الرجال.

لقوله تعالى: (ثم لم يأتوا بأربعة شهداء) ولأن الواجب على الشاهد إقامة الشهادة لله عز وجل، ولا تقع الشهادة لله إلا أن تكون خالصة صافية عن جر النفع، ومعلوم أن في الشهادة منفعة للشاهد من حيث التصديق، لأن من صدق قوله يتلذذ به.

فاشترط العدد في الشهادة ليكون قول كل واحد مضافا إلى قول صاحبه فتصفوا الشهادة لله عز وجل، ولخوف السهو والنسيان ، لأن الإنسان مطبوع على السهو والغفلة فشرط العدد في الشهادة ليذكر البعض البعض عند اعتراض السهو والغفلة⁽¹⁾.

الشرط الثالث: اتفاق الشهادتين فيما يشترط العد فإن اختلفا لم تقبل.

وعلة ذلك: أن اختلافهما يوجب اختلاف الدعوى والشهادة، ولأنه عند اختلاف الشهادتين لم يوجد إلا أحد شطري الشهادة، ولا يكتفى به فيما يشترط فيه العدد.

ما يكون فيه الاختلاف:

الاختلاف في الشهادة: الاختلاف: هو سلب الاتفاق والاتحاد، والاتفاق يكون من الاختلاف كالمفرد من المركب ، إذ الاتفاق هو الاتحاد والواحد مقدم على المتعدد⁽⁷⁹⁸⁾.

والاختلاف غالبا يؤخر عن الاتفاق، لأن هذا ما يقتضيه الطبع لكون الاتفاق أصلا، والاختلاف إنما هو يعارض الجهل والكذب.

والاختلاف يكون في جنس المشهود به ، وقد يكون في قدره وقد يكون في الزمان، وقد يكون في المكان.

أولا: الاختلاف في جنس المشهود به: وهذا النوع قد يكون في العقد ، وقد يكون في المال.

الاختلاف في العقد: كأن يشهد أحدهما بالبيع، والآخر بالميراث أو الهبة فلا تقبل الشهادة، لاختلاف العقدين صورة ومعنى وذلك لأن كل واحد منهما شهد بعقد غير ما شهد به الآخر وليس على أحدهما شهادة شاهدين.

الاختلاف في المال: كأن يشهد أحدهما بمكيل والآخر بموزون فلا تقبل الشهادة، لأنهما جنسان مختلفان وليس على أحدهما شهادة شاهدين.

ثانيا: الاختلاف في قدر المشهود به: مثال ذلك: إذا ادعى رجل على رجل ألفي درهم، وأقام شاهدين شهد أحدهما بألفين ، والآخر بألف لا تقبل عند الإمام أبي حنيفة.

وعند أصحابين: تقبل على الألف.

وحجتهم: أن الشاهدين اتفقا على الألف وتفرد أحدهما بالزيادة فيثبت الحق فيما اتفقا عليه دون ما تفرد به أحدهما.

(1) فتح القدير ج 6 ص 17، بدائع الصنائع ج 6 ص 277، المهذب ج 2 ص 333، بداية المجتهد ج 2 ص 454، المغني ج 9 ص 149.

(798) حاشية سعد أفندي حلبى على هامش فتح القدير ج 6 ص 52.

واستدل الإمام: بأن شطر الشهادة خالف الدعوى، لأن المدعي يدعي ألفين، وأنه اسم وضع دلالة على عدد معلوم والاسم الموضوع على عدد لا يقع على ما دون ذلك العدد، فلم تكن الشهادة شاهدة على ما دخل تحت الدعوى فانفردت الشهادة عن الدعوى فيما يشترط فيه الدعوى فلا تقبل. واتفق الإمام وصاحبيه على أنه إذا كان المدعي يدعي ألفاً وخمسمائة فشهد أحد الشاهدين على الألف والآخر على ألف وخمسمائة تقبل الشهادة على الألف.

لاتفاق الشاهدين عليها لفظاً ومعنى، لأن الألف والخمسمائة اسم لعددتين، ألا ترى أنه يعطف أحدهما على الآخر فيقال: ألف وخمسمائة فكان كل واحد منهما بانفراد داخل تحت الدعوى، فالشهادة القائمة عليهما تكون قائمة على كل واحد منهما قصداً.

ثالثاً: الاختلاف في الزمان والمكان: يلاحظ أن الاختلاف في الإقرار بالشهادة؛ لأن القول مما يتكرر إن من باب القول كالبيع والشرء والطلاق بصيغة واحدة إنشاء وإخباراً لا يمنع القبول⁽¹⁾. وإن كان الاختلاف في الفعل كالقتل والقطع والغصب وإنشاء البيع والطلاق والعناق والنكاح ونحوهما، فإنه يمنع القبول.

ووجه الفرق: أن الإقرار مما يحتمل التكرار فيمكن التوفيق بين الشهادتين لسماعه عن الإقرار في زمانين ومكانين، فلا يحتمل الاختلاف بين الشهادتين.

بخلاف القتل والقطع وإنشاء البيع وغيره من العقود والفسوخ، لأن هذا لا يحتمل التكرار، فاختلاف الزمان والمكان فيها يوجب اختلاف الشهادتين فيمنع القبول⁽²⁾.

وجاء في الهداية: أن اختلاف الشاهدين في المكان يمنع القبول، فإذا شهد شاهدان أنه قتل زيداً يوم النحر بمكة، وآخران بقتله يوم النحر بالكوفة قبل أن يقضي القاضي بالأولى لم يقبلهما، لأن إحداهما كاذبة بيقين، وليست إحداهما بأولى من الأخرى⁽⁷⁹⁹⁾.

المبحث الثامن

أنواع الشهادة ومراتبها

ونتناول في هذا المبحث مطلبين:

المطلب الأول

في أنواع الشهادة

قسم الفقهاء الشهادة إلى أنواع خمسة أهمها ما يلي:

النوع الأول: الشهادة الأصلية، وهي تلك التي بموجبها يشهد الشاهد بما عاينه بالعين أو بالسمع بنفسه.

النوع الثاني: الشهادة الفرعية، وهي الشهادة على الشهادة، وهي مشروعة للعجز عن الأداء لمرض أو موت أو سفر، فلولاً مشروعتها لبطلت حقوق الناس.

النوع الثالث: شهادة التسامع، وهي التي تقوم فيها الشهرة مقام المعاينة.

النوع الرابع: شهادة التواتر وهي خبر جماعة يقع العلم بخبرهم ولا يتصور اتفاقهم على الكذب والتواتر حجة في النص والإثبات، لأنه يفيد القطع واليقين.

النوع الخامس: شهادة الاستكشاف، وهي الإخبار عن المخبر لمجرد الاستعلام واستطلاع الرأي كأخبار أهل الخبرة، والمترجم والمزكي⁽¹⁾.

(1) فتح القدير ج 6 ص 52 والعناية عليه، والبدائع ج 6 ص 278.

(2) المراجع السابقة.

(799) الهداية على الفتح ج 7 ص 443.

المطلب الثاني مراتب الشهادة ونصابها

نصاب الشهادة يتحدد حسب نوع الحق المشهود به الذي يتحمله الشاهد، وهو إما أن يكون حقا لله ، أو حقا للأفراد، أو حقا مشتركا.

وهي في كل إما أن يراد به المال، وإما أن يكون المقصود منه غير المال، وعليه فإن نصاب الشهادة ينحصر في البيئات التالية:

أولا: بيئة تحتاج إلى أربعة شهود من الذكور جميعا:

ويتحقق ذلك في جريمة الزنا، ودليل ذلك قوله تعالى (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم)⁽¹⁾ وقوله تعالى (لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء)⁽²⁾.

ولفظ أربعة نص في العدد، والذكورة ، وأما الإسلام والعدالة ، فقد تقدم اشتراطها.

والعلة في اشتراط أربعة: أن اشتراط الأربعة فيه دون القتل العمد وغيره لأن الله سبحانه وتعالى

يجب الستر على عباده ولا يرضى بإشاعة الفاحشة بين الناس ، قال تعالى (إن الذين يحبون أن

تشيع الفاحشة في الذين ءامنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون)⁽³⁾.

ولا تقبل في الزنا شهادة النساء ، لما روي عن أبي شيبه قال : حدثنا حفص عن الزهري قال: مضت

السنة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم — ، والخليفين من بعده أن " لا تجوز شهادة النساء في

الحدود والدماء " .

وما روي في حديث سعد بن عباد عن النبي — صل الله عليه وسلم — " قال: قلت يارسول الله"

أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء قال: نعم.

وقد ثبت عن النبي — صل الله عليه وسلم — أنه قال أربعة شهود وإلا حد في ظهرك"⁽¹⁾.

وجه الدلالة: في هذه الأحاديث النبوية الشريفة دلالة واضحة على أن لابد من أربعة في هذه الجريمة

، لأن النص أوجب شهادة الرجال بقوله تعالى " أربعة منكم" فقبول الشهادة امرأتين مع ثلاث رجال

مخالف للنص.

ولقد خصص الحديث الخليفين بأبي بكر وعمر (رضي الله عنهما) ، لأنهما اللذان كان معظم تقرير

الشرع وطرق الأحكام في زمانهما وبعدهما ما كان من غيرهما إلا الإتياع.

وخصصها أيضا: لما ورد في حقهما من قوله - صل الله عليه وسلم - " اقتدوا بالذين من بعدي أبي

بكر وعمر " .

ومن الإجماع: أن الإجماع منعقد على اشتراط الأربعة بالنسبة للزنا إلا ما حكى عن عطاء وحماد

قالا: تجوز شهادة ثلاثة رجال وامرأتين ، لأنه نقص واحد من عدد الرجال يقوم مقامه امرأتان وهو

قول شاذ⁽²⁾.

(1) أصول المرافعات الشرعية للعمروسي ص 734 فما بعدها ونظرية الدعوى والاثبات أ. د نصر فريد واصل ص 70.

(1) سورة النساء اية (15).

(2) سورة النور اية (13).

(3) سورة النور اية (19).

(1) نصب الراية ج 3 ص 306.

(2) تكملة فتح القدير ج 6 ص 7 مع العناية عليه.

ويرد هذا القول: بأنه مبني على القياس الذي يصادم النص ولا قياس مع النص الصريح، ثم إن القياس على الأموال لا يصح، وذلك لخفة حكمها، وشدة الحاجة إلى إثباتها لكثرة وقوعها، والاحتياط في حفظها، بخلاف الزنا، ولهذا زيد في عدد شهود الزنا على شهود المال⁽¹⁾.

ثانيا: بينة لا تصح إلا من رجلين:

وذلك في حقوق الله الخالصة ، وهي بقية الحدود والقصاص يقبل فيها شهادة رجلين ، وهل تقبل فيها شهادة النساء مع الرجال أو منفردات؟

خلاف بين جمهور الفقهاء والظاهرية:

اتفق الجمهور من الفقهاء على أن الحدود والقصاص يقبل فيها شهادة الرجال ولا تقبل شهادة النساء إلا مع رجل ولا منفردات.

واستدلوا بقوله تعالى: (واستشهدوا شاهدين من رجالكم) .

نص الله تبارك وتعالى على شهادة الرجال في الحدود والقصاص ولم ينص على النساء⁽²⁾.

وقال الظاهرية: تقبل شهادة النساء مع رجل في الحدود إذا كان النساء أكثر من واحدة.

واستدلوا: بظاهر قوله تعالى: **(فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء) .**

فظاهر الآية الكريمة يفيد أن شهادة النساء تقبل في كل شيء إذا كان معهن رجل⁽¹⁾.

ثالثا: بينة يقصد فيها المال أصلا:

وذلك يتحقق في كل المعاملات ، سواء كان الحق مالا أم لا، كالنكاح والطلاق والوكالة، والوصية ، والهبة ، والإقرار، والإبراء ونحو ذلك كالعنق ، يقبل فيها شهادة رجل وامرأتين بنص الآية عند الحنفية⁽²⁾.

وقال الشافعي: بعدم قبول شهادة النساء مع الرجال إلا في الأموال وتوابعها، كالإعارة ، والإجارة، والكفالة، والأجل، وشرط الخيار.

واستدل بأن الأصل في شهادتين عدم القبول لنقصان العقل واختلال الضبط، وقصور الولاية، فإنها لا تصلح للإمارة ولهذا لا تقبل في الحدود ولا تقبل شهادة الأربع منهن وحدهن إلا أنها مستثناة من ذلك الأصل في الأموال ضرورة إحياء حقوق العباد لكثرة وقوعها، ودنو خطرهما فلا يلحق بها ما هو أعظم وأقل وجودا كالنكاح والطلاق ، والرجعة، والإسلام والردة، والولاء، والعدة، والجرح، والتعديل، والعفو عن القصاص⁽³⁾.

واستدل الحنفية: بأن الأصل فيها القبول لوجود مال يبتنى عليه أهلية الشهادة، التي يحصل بها العلم والضبط الذي يبقى به العلم إلى وقت الأداء، والأداء الذي يحصل به العلم للقاضي، ولكون القبول أصلا قبل إخبارها في الأخبار.

ويناقد قول الشافعي بما يلي:

أولا: قوله اختلال الضبط.

⁽¹⁾ العناية على الهداية جـ 6 ص 7.

⁽²⁾ المبسوط جـ 16 ص 117، فتح القدير جـ 6 ص 7، الشرح الكبير جـ 4 ص 185، بداية المجتهد جـ 2 ص 453.

⁽¹⁾ المحلى لابن حزم جـ 9 ص 174، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ص 129. الفقه الاسلامي د وهبه الزحيلي جـ 572.

⁽²⁾ فتح القدير جـ 6 ص 7، الاختيار 210.

⁽³⁾ مغني المحتاج جـ 4 ص 441

يجاب عليه: بأنه بعد التسليم يجبر بضم الأخرى إليها، فلم يبق بعد ذلك إلا شبهة البدلية، فلا تقبل فيما يندريء بالشبهات، وتقبل فيما يثبت بها، وهذه الحقوق المذكورة من النكاح وغيره مما يثبت بها، أما النكاح والطلاق فظاهر لثبوتها مع الهزل وأما الوكالة والإيصاء، والأموال، فإنه يجري فيها كتاب القاضي إلى القاضي، والشهادة على الشهادة، وذلك أمانة ثبوتها مع الشبهة، لذلك تثبت بشهادة النساء مع الرجال.

ثانياً: قوله نقصان العقل وقصور الولاية:

يجاب عن الأول: إنه لا نقصان في عقلهن فيما هو مناط التكليف.

وبيان ذلك: أن للنفس الإنسانية أربع مراتب:

- 1- استعداد العقل ويسمى العقل الهولاني وهو الحاصل لجميع أفراد الإنسان من مبدأ فطرتهم.
 - 2- أن تحصل البدييات باستعمال الحواس في الجزئيات فيتهياً لاكتساب الفكريات بالفكرة، ويسمى العقل بالملكة وهو مناط التكليف.
 - 3- أن تحصل النظريات المفروغ منها متى شاء من غير افتقار إلى اكتساب ، ويسمى العقل بالفعل.
 - 4- أن يستحضرها ويلتفت إليها مشاهدة ويسمى العقل المستفاد.
- وليس فيما هو مناط التكليف ، وهو العقل بملكة ففیهن نقصان بمشاهدة حالهن في تحصيل البدييات باستعمال الحواس في الجزئيات وبالتنبيه إن نسيت ، فإنه لو كان في ذلك نقصان لكان تكليفهن دون تكليف الرجال في الأركان ، وليس كذلك.
- أما قوله صل الله عليه وسلم - " هن ناقصات عقل ودين " المراد به العقل بالفعل ، وذلك لم يصلحن للولاية والخلافة والإمارة وبهذا ظهر الجواب عن الثاني.

ثالثاً: (عدم قبول الأربع).

يجاب عنه: بأن القياس يقتضي قبول ذلك أيضاً، لكنه ترك ذلك كي لا يكثر خروجهن.

الراجح: هو ما قال به الحنفية ، وذلك لأن المرأة من أهل الشهادة كما بينت الآية ، فتقبل لوجود المشاهدة والحفظ والأداء كالرجل، وأما زيادة النسيان في المرأة فتجبر بزيادة العدد، وإليه الإشارة في قوله تعالى: (أن تضل احدهما فتذكر إحداهما الأخرى).

النوع الثالث: بينة لا ثبات مالا يطلع عليه إلا النساء في الغالب وهذا النوع تقبل فيه شهادة النساء وحدهن، لما روي عن سعيد بن المسيب عن عطاء بن أبي رباح وطاووس قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم - " شهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه". وفي رواية أخرى بلفظ: رواه عبد الرزاق في مصنفه عن الزهري قال: " مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع غيرهن، من ولادات النساء وعيوبهن".

واختلف الفقهاء في بيان الحالات التي تجوز فيها شهادة النساء على النحو التالي:

مذهب الحنفية : أن شهادة النساء مقبولة في الولادة والبكارة وعيوب النساء في موضع لا يطلع عليه الرجال، واشتروطوا أن تكون مسلمة حرة، سواء كانت واحدة ، أو اثنتين، والاثنتين أحوط، وبهذا قال أحمد بن حنبل (رحمه الله).

وفي الرضاع: لا تقبل شهادة النساء المنفردات - أي ليس معهن رجل، لأنه لا يجوز أن يطلع عليه محارم المرأة من الرجال فلا توجد الضرورة إلى شهادتهن منفردات.

وكذلك يرى الإمام أبي حنيفة أن شهادتهن منفردات غير مقبولة على استهلال الصبي بالنسبة للإرث، لأن الاستهلال صوت الصبي عند الولادة وهو ما يطلع عليه الرجال، فلا تكون شهادتهن فيه حجة.

وقال صاحبان : وبقولهما قال الشافعي وأحمد:

تقبل شهادتهن على الاستهلال للإرث لأن الاستهلال صوت عند الولادة ، ولا يحضرها الرجال عند الولادة عادة وهذا هو الراجح كما قال الكمال ابن الهمام للعرف والعادة. وقال المالكية والشافعية والحنابلة: تقل شهادة النساء منفردات فيما لا يراه الرجال غالبا كبكارة وثبوبة وولادة وحيض ورضاع واستهلال ولد، وعيوب نساء تحت الثياب كجراحة ورتق وقرن وبرص، وانقضاء عدة.

ودليلهم: خبر الزهري السابق ذكره ، ويقاس عليه ما لم يذكر في الجبر على ما ذكر فيه مما شاركه في الضابط المذكور من ولادة وعيوب النساء.

واختلفوا في العدد المشترك في شهادة النساء منفردات:

يقول الحنفية والجنابلة : تقبل شهادة امرأة واحدة والثنتان أحوط عند الحنفية ، لما فيه من معنى الإلزام، ولما جاء في باب ثبوت النسب من جواز شهادة امرأة واحدة ما نصه: " إذا تزوج رجل امرأة فجاءت بولد لستة أشهر فصاعدا فجدد الزوج الولادة تثبت الولادة بشهادة امرأة واحدة. وقال الشافعي: باشتراط أربع من النسوة، لأن اثنتين يقومان مقام رجل.

لقوله تعالى (فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان) .

واشتراط مالك: اثنتين

وحجته: أن المعتبر في الشهادة أمران العدد والذكورة ، وقد سقط اعتبار الذكورة فبقى العدد. والراجح: هو القول الأول القائل بجواز شهادة امرأة واحدة يؤيده ما روي عن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بن أبي إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما، قال: فتنحيت فذكرت ذلك له ، فقال: كيف وقد زعمت أنها أرضعتكما، فنهاه عنها". وفي رواية: " دعها عنك".

ولما روي أن النبي — صل الله عليه وسلم — أجاز شهادة القابلة.

الشهادة على البكارة: إن شهدت النساء أنها بكر، يؤجل العنين سنة فإذا مضت السنة ، وقال وصلت إليها فأنكرت، ترى النساء، فإن قلن هي بكر تخيرت، فإن اختارت الفرقة فرق بينهما في الحال.

وإنما يفرق بقولهن؛ لأنها تأيدت بمؤيد وهو موافقة الأصل إذ البكارة أصل، ولو لم تتأيد شهادتهن بمؤيد اعتبرت في توجه الخصومة لا في إلزام الخصم.

المبحث التاسع

في الشهادة على الشهادة

الشهادة على الشهادة جائزة بإجماع العلماء في كل الحقوق التي لا تسقط بالشبهة لشدة الحاجة إليها. وعلة الجواز: تثبت بما يلي:

أولاً: قوله تعالى: (وأشهدوا ذوي عدل منكم) .

ثانياً: أن الحاجة تدعو إلى ذلك لإحياء الحقوق، لأنه قد يعجز شاهد الأصل عن أداء الشهادة لمرض أو موت أو سفر، فلو لم تجز الشهادة على شهادته، لأدى إلى ضياع الحقوق.

صفة الإشهاد: وصفة الإشهاد في الشهادة على الشهادة لها عبارتان مختصرة ومطولة.

أما المختصرة: فهي أن يقول شاهد الأصل ، إشهد على شهادتي أنني أشهد لفلان على فلان كذا، أو يقول على فلان كذا فأشهد على شهادتي بذلك.

أما المطولة: فهي أن يقول شاهد الأصل ، اشهد أن لفلان على فلان كذا، وأشهدك على شهادتي هذه، وأمرك أن تشهد على شهادتي هذه فأشهد.

شروط قبول الشهادة على الشهادة: يشترط لقبول الشهادة على الشهادة عدة شروط:

أحدهما: تعذر حضور الأصل مجلس القضاء ، ويتحقق التعذر بالموت، أو السفر أو المرض، أما الموت فظاهر.

وأما المريض: فالمراد به مريض لا يستطيع معه الحضور مجلس القضاء.

وأما السفر: الذي يعذر فيه عند قبول الشهادة على الشهادة.

ففيه قولان:

الأول: مسافة قصر، لأن بعد المسافة عذر والشرع قد اعتبر ذلك في المدة، حتى يترتب عليها كثير من الأحكام.

الثاني: أن يكون شاهد الأصل بموضع لا يمكنه أن يشهد ثم يرجع من يومه.

والمسافة المعتبرة عند الحنفية هنا تقدر بمسيرة ثلاثة أيام ولياليها فصاعداً.

وعلة ذلك: أن المعجز عن أداء الشهادة من الأصيل بعد المسافة، ومدة السفر بعيدة حكماً، حتى أدير على هذه المسافة عدة أحكام أصبحت رخصاً، كالفطر في الصيام، وقصر الصلاة، وامتداد المسح على الخفين، وعدم وجوب الأضحية، والجمعة، وحرمة خروج المرأة بلا محرم أو زوج.

ثانيها: تعيين وتسمية شهود الأصل، وذلك حتى يعرف القاضي عدالتهم، لأن العدالة شرط في صحة الشهادة، وإذا لم يعرف شهود الأصل لم تعلم عدالتهم، وعدالتهم شرط في القبول، لأن الفرع مبني على الأصل، وإذا ردت شهادة الأصل ردت شهادة الفرع من باب أولى.

مجال قبول الشهادة على الشهادة

وقع الخلاف في الحقوق التي تقبل فيها هذه الشهادة.

يرى الحنفية: أن الشهادة على الشهادة تقبل في جميع الحقوق التي لا تسقط بالشبهة، فهي جائزة في الأقارير، والحقوق، وأقضية القضاة وكتبهم وكل شئ إلا الحدود والقصاص، وحد القذف بهذا القول قال أحمد والشافعي في قول.

وأصحاب هذا الرأي يرون أن الشهادة على الشهادة لا تقبل في حد من حدود الله الخالصة، وكذا القصاص، وحد القذف.

واستدلوا: بما روي عن علي - رضي الله عنه - قال: " لا تقبل شهادة على شهادة في حد أو قصاص".

ومن المعقول: أن الحدود مبنية على الستر والدرء والإسقاط بالرجوع عن الإقرار، والشهادة على الشهادة فيها شبهة، حيث إنه يتطرق إليها احتمال الغلط والسهو والكذب في شهود الفرع مع احتمال ذلك في شهود الأصل، وهذا احتمال زائد لا يوجد في شهادة الأصل فوجب أن لا يقبل فيما يندري بالشبهات.

ويرى الإمام مالك والشافعي في أحد قوليه: أن الشهادة على الشهادة تقبل في الحدود كحد الردة، وحد الزنا، وحد السرقة وغيرها، كما تقبل في المال.

وعلة ذلك: أنها حقوق تثبت بالشهادة، وكل ما يثبت بالشهادة يثبت بالشهادة على الشهادة، ولأن الفروع عدول وقد نقلوا شهادة الأصول فالحكم بشهادة الأصول لا بشهادتهم وصاروا كالمترجم.

مما سبق يتبين أن حد القذف عند الحنفية الغالب فيه حق الله تعالى، ومن هنا قالوا بعدم قبول الشهادة على الشهادة في الحدود والقصاص.

لما روي عن علي - رضي الله عنه - لا تقبل شهادة على شهادة في حد أو قصاص.

وعند الشافعية والمالكية الغالب في حد القذف حق العبد.

والعلة في ذلك: أن القصاص حق العبد، وحق العبد مبني على المشاحنة، وحق الله مبني على المسامحة والمساهلة والقذف كالقصاص يغلب فيه حق العبد على حق الله فوجب مراعاة ذلك الحق، وهو حق العبد وحقوق العباد كلها لا تسقط بالشبهة، فإذا جاز فيه الشهادة على الشهادة للضرورة

وحرصا على عدم ضياع الحقوق على أصحابها بأي سبب، إلا إذا كان هذا الإسقاط من جهتهم؛ لأنهم أصحاب الحق⁽¹⁾.

أسباب تحمل الشهادة على الشهادة: لتحمل الشهادة على الشهادة أسباب أهمها مايلي:
أحدهما: أن يلتمس الشاهد الأصل من الشاهد الفرع رعاية الشهادة وحفظها فيقتل الأصل للفرع
مثلا: أنا شاهد بأن فلان على فلان كذا، وأشهدك على شهادتي.
الثاني: أن يسمع رجل رجلا آخر يشهد أمام القاضي أن فلان على فلان كذا من المال ، فله أن يشهد على شهادته وأن يلتمس منه الأصل هذه الشهادة.
الثالث: أن يسمعه يقول : اشهد أن فلان على فلان ألفا من الجنيهاات عن ثمن مبيع أو قرض أو غيرها فيجوز لمن سمعه أن يشهد على هذه الشهادة إذا كان قد بين سبب الشهادة حتى لو لم يطلب منه الأصل ذلك ؛ لأن بيان السبب رافع لاحتمال الوعد والتساهل⁽¹⁾.

شروط تحمل الشهادة على الشهادة:

وشرط تحمل الشهادة على الشهادة ما ذكرنا من عموم الشهادات وأما الذي يختص بها فأنواع:
الأول: الإشهاد، حتى لا يصح التحمل بنفس السماع دون الإشهاد حتى لو قال أشهد أن فلان كذا فيسمع من إنسان لكن لم يقل اشهد أنت لم يصح التحمل، بخلاف سائر الشهادات أنه يصح التحمل فيها بنفس معاينة الفعل وسماع الإقرار.
وجه الفرق: أن الفروع يشهدون نيابة عن الأصول فلا بد من الإنابة منهم وذلك بالإشهاد، بخلاف سائر الشهادات، لأن تحمل الشاهد في سائرهما بطريق الإحالة بنفسه لا بغيره فيصح التحمل فيها بطريق المعاينة.

الثاني: الإشهاد على شهادته فإنه لو قال اشهد بمثل ما شهدت، أو كما شهدت أو على ما شهدت لا يصح التحمل مالم يقل على شهادتي، لأن معنى التحمل والإنابة لا يحصل إلا بالإشهاد على شهادته.
الثالث: عدد التحمل، وهو أن يتحمل من كل واحد من شاهدي الأصل اثنان حتى لو تحمل من أحدهما واحد ، وتحمل من الآخر واحد لا يصح التحمل.
لأن الشهادة حق ثابت في ذمة الشاهد والحقوق الثابتة في الذمم لا ينقلها إلى القاضي إلا شاهدان.
ولو تحمل اثنان من أحدهما شهادته ، ثم تحملا من الآخر شهادته جاز التحمل؛ لأنه اجتمع على التحمل من كل واحد منهما شاهدان⁽¹⁾.

صفة أداء الشهادة على الشهادة:

وصفة أدائها أيضا لها عبارتان:
الأولى: مختصرة، وهي أن يقول : شهد فلان عندي أن فلان على فلان كذا وأشهدني على شهادته بذلك فأنا أشهد على شهادته بذلك.
الثانية: المطولة، وهي أن يقول شهد عندي أن فلان على فلان كذا، وأشهدني على شهادته بذلك ، وأنا أشهد الآن على شهادته بذلك.
ولو لم يقل وأمرني أن أشهد على شهادته بذلك جاز (لأن معنى التحمل والإنابة يتأدى بقوله أشهدني على شهادته) فكان قوله: وأمرني أن أشهد على شهادته من باب التأكيد⁽²⁾.

(1) فتح القدير ج 6 ص 74، 75 والمراجع السابقة.

(1) الفقه الاسلامي للزحيلي ج 6 ص 575، بدائع الصنائع ج 6 ص 282.

(1) فتح القدير ج 6 ص 75 بدائع الصنائع ج 6 ص 282.

(2) المراجع السابقة.

وأما الذي يختص بأداء الشهادة: أن يكون المشهود عليه ميتا أو غائبا مسرة سفر أو مريضا لا يستطيع أن يحضر إلى مجلس القضاء.

وعلة ذلك: أن جواز هذه الشهادة للحاجة والضرورة ولا تتحقق الضرورة إلا في هذه المواضع. وأما الذكورة فليست بشرط لأداء هذه الشهادة فتقبل فيها شهادة النساء مع الرجال، لقوله تعالى: (فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء).

فظاهر النص يقتضي أن يكون للنساء مع الرجال شهادة على الإطلاق من غير فصل إلا ما قيد بدليل. **إنكار شهود الأصل الشهادة:**

لو أنكر شهود الأصل الشهادة بأن قالوا: ما لنا شهادة على هذه الحادثة، وماتوا أو غابوا، ثم جاء الفروع يشهدون على شهادتهم أو أنكر شهود الأصل تحميل الشهادة لغيرهم بأن قالوا، لم نشهدهم على شهادتنا ، وماتوا أو غابوا ، لم تقبل شهادة الفرع، لأن التحميل شرط، ولم يتوافر في ذلك بسبب تعارض الخبرين⁽³⁾.

(3) بدائع الصنائع ج 6 ص 282، الفقه الاسلامي للزحيلي ج 6 ص 576.

المبحث العاشر عقوبة شاهد الزور

شاهد الزور هو الذي أقر على نفسه أنه شهد بالزور أو شهد بقتل رجل فجاء حيا. التشهير بشاهد الزور: اختلف الفقهاء في الشاهد إذا أقر على نفسه أنه شهد زورا أو اشتهر بين الناس بقول الزور كيف يعزر؟..

قال الإمام أبو حنيفة: يعزر الشاهد زورا بالتشهير في الأسواق إن كان سوقيا أو بين قومه إن كان غير سوقيا، وذلك بعد صلاة العصر في مكان تجمع الناس ويقول المرسل معه: إنا وجدنا هذا شاهد زور فاحذروه وحذروه الناس، ولا يعزر بالضرب، أو بالحبس⁽¹⁾.

وقال صاحبان والشافعية: نوجعه ضربا، ونحبسه حتى يتوب، لأن من شهد بالزور يفسق وترد شهادته لأنها من الكبائر، فإن ثبت أنه شاهد زور ورأى الإمام تعزيره بالضرب، أو بالحبس، أو بالزجر فعل، وأن رأى أن يشهر أمره في السوق أو المصلى، أو القبيلة فعل، وينادي عليه أن هذا شاهد زور فاعرفوه⁽²⁾.

استدل صاحبان ومن وافقهم بما يلي: من السنة المشرفة
ماروى خزيمة بن فاتك قال: صل رسول الله - صل الله عليه وسلم - صلاة الصبح، فلما انصرف، قام قائما ثم قال: عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله ثلاث مرات" ثم تلا قوله عز وجل (**فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور**)⁽¹⁾.

وجه الدلالة: أن شاهد الزور أتى بكبيرة من الكبائر على ما صرح به النبي صل الله عليه وسلم " فيما رواه البخاري أنه - صل الله عليه وسلم - قال: ألا أخبركم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال: الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس، ثم قال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور فما زال يكررها " حتى قلنا لعله سكت" فإذا كانت كبيرة وليس فيها تقدير شرعي ففيها التعزير".

ولأبي حنيفة: أن شريحا (رحمه الله) كان يشهر ولا يضرب، وهو مروب عن محمد بن الحسن فيس كتاب الآثار عن أبي حنيفة عن الهيثم ابن أبي الهيثم " أن شريحا كان إذا أخذ شاهد الزور، فإن كان من أهل السوق قال للرسول: قل لهم أن شريحا يعرفكم ويقول لكم إنا وجدنا هذا شاهد زور فاحذروه، وإن كان من العرب أرسل به إلى مجلس قومه أجمع ويقال لهم مثل ما قيل في المرة الأولى. وماروى أن شريح أتى بشاهد زور فنزع عمامته عن رأسه، وخفقه بالدرة خفقان وبعث به إلى المسجد يعرفه الناس.

ومن المعقول: أن المقصود هو التوصل إلى الانزجار، وهو يحصل بالتشهير، بل ربما يكون أعظم عند الناس من الضرب فيكتفى به.

ويرد على قول صاحبين:

1- بأن ما ورد من ضرب عمر لشاهد الزور والتسخيم كان سياسة فإذا رأى الحاكم مصلحة، كان له أن يفعل ذلك.

أن الاستدلال على السياسة بالتبليغ إلى الأربعين، ولا يبلغ بالتعزير إلى الحدود فليس بشئ، فإن ذلك مختلفا فيه.

(1) فتح القدير ج 6 ص 83، تبين الحقائق ج 3 ص 241.

(2) بدائع الصنائع ج 6 ص 281، المهذب للشيرازي ج 2 ص 338.

(1) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة، الترغيب والترهيب ج 2 ص 221.

— فمن العلماء من يجيزه، وقد أجاز أبي يوسف (رحمه الله) أن يبلغ به خمسة وسبعون، وتسعة وسبعون فجاز كون رأي عمر - رضي الله عنه - كذلك — .
ويلاحظ في المسألة ثلاثة أوجه:

أحدها: إن رجوع على سبيل الإصرار مثل أن يقول: شهدت في هذه زور، ولا أرجع عن مثل ذلك ، فإنه يعزر بالاتفاق.

الثاني: إن رجوع على سبيل التوبة لا يعزر اتفاقاً.

الثالث: إن كان لا يعرف حاله فعلى الاختلاف المذكور⁽¹⁾.

الرأي الرابع :

وبعد بيان أقوال الفقهاء، وأدلتهم وبيان ما ورد عليها من مناقشات نلاحظ أن الجمع بين القولين ما أمكن هو الأولى، فيكتفى بالتعزير على قول الإمام أبي حنيفة لأن شهادة الزور ليس فيه حد مقدر، ولأن المقصود هو الزجر، وهو يتأتى بالتشهير به، فيكتفى به، فإن رأى الإمام أو القاضي الضرب أو الحبس فعل بشرط أن لا يصل به عدد الضربات إلى الحد المقدر ، لأنه أمر منهي عنه.

ومن أدلة النهي : ما روي عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: " من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين".

ومن هنا كان الجمع بين القولين ما أمكن هو الأولى⁽²⁾.

توبة شاهد الزور:

إذا تاب هل تقبل شهادته أم لا؟

قالوا: إن كان فاسقاً تقبل توبته، لأن الحامل له على الزور فسقه وقد زال بالتوبة، ومدة ظهور التوبة عند بعض المشايخ ستة أشهر وعند آخرين سنة، قالوا: والصحيح أنه مفوض إلى رأي القاضي.
وإن كان مستوراً لا تقبل أصلاً، وكذا إن كان عدلاً على رواية بشر عن أبي يوسف، لأن الحامل له على ذلك غير معلوم، فكان الحال قبل التوبة وبعدها سواء. وروي عن أبي جعفر أنها تقبل، وعليه الفتوى⁽²⁾.

المبحث الحادي عشر

الرجوع عن الشهادة

هو أن ينفي الشاهد ما أثبتته، وقيل هو انتقال الشاهد بعد أداء الشهادة إلى عدم الجزم به دون نقيضه، وهو أن يقول الشاهد: رجعت عما شهدت به، ونحوه، فلو أنكر شهادته بعد القضاء لا يكون رجوعاً. والأصل فيه:

أولاً: قول عمر - رضي الله عنه - في كتاب القاضي، فلا يمنعك قضاء قضيتته وراجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن ترجع فيه إلى الحق، فإن الحق قديم لا يبطل، والرجوع إلى الحق خير من التماذي في الباطل⁽¹⁾.

وكذلك الأمر في الشاهد فإن المعنى يجمعها، لأن الرجوع عن الشهادة الباطلة رجوع من الباطل إلى الحق، والرجوع يكون بقوله شهدت بزور وما أشبهه.

(1) فتح القدير ج 6 ص 84.

(2) المراجع السابقة.

(2) المراجع السابقة.

(1) الأشباه والنظائر للسيوطي ص 480.

ثانياً: أن الشاهد بشهادته تسبب في إتلاف المال على المشهود عليه بإخراجه من ملكه يدا وتصرفاً، فإن أزاله بغير عوض ضمن الجميع ، وإن كان بعوض إن كان مثلاً له، لاضمان عليه، وإن كان أقل منه، ضمن النقصان⁽²⁾.

ركنه: هو قول الشاهد رجعت عما شهدت به، أو شهدت بزور وهو أمر مشروع مرغوب فيه ديانة لأن فيه خلاصاً من عقاب الكبيرة⁽³⁾.

وشرطه: أن يكون عند القاضي سواء كان القاضي المشهود عنده أو عند غيره، لأنه يحتاج فيه إلى حكم الحاكم بمقتضى الرجوع فلا بد من مجلس القاضي كما في الشهادة، ولأنه توبة والشهادة جنائية ، فيشترط استواءهما في الجهر والإخفاء⁽⁴⁾.

وحكمه: إيجاب التعزير على حال سواء رجع قبل القضاء بشهادته أو بعد القضاء.

ثم إن شهادته التي رجع عنها بعد الحكم إن كانت مال: لزمه غرمه⁽¹⁾.

وإن كانت في دم: لزمه غرم الدية في الخطأ والعمد، بهذا قال الحنفية والمالكية.

وقال أشهب والشافعي: يقتص منه في العمد.

وإن كانت في حد : فإن رجع قبل الحكم حد، وإن رجع بعده حد أيضاً.

وإن كانت في عتق: لزمه قيمة العبد لسيده.

ويصح الرجوع عن الشهادة مطلقاً قبل الحكم وبعده في مجلس القضاء أو غيره.

لأن الشهادة إخبار وإعلام ، وذلك لا يعرف إلا من جهة الشاهد فإنه قد يخبر بالشئ ثم يتبين له كذبه أو غلطه، أو وهمه وما أشبه ذلك⁽²⁾.

ومن هنا وجب الرجوع عن تلك الشهادة التي تبين عدم صدقها ، حتى لا يترتب عليها انتقال حق الشخص لآخر دون وجه حق، مع أن ذلك هو الأصل، إلا أن هذا الرجوع لا يمكن ترتب الآثار الشرعية عليه من الناحية العلمية إلا إذا كان في مجلس القضاء والحكم.

وعلة ذلك: إن الرجوع عن الشهادة يبطلها، وذلك البطلان حكم شرعي وهو يحتاج إلى حكم حاكم، ولا يكون ملزماً إلا في مجلس القضاء.

ولابد أن يقول الشاهد رجعت عن شهادتي ، أو أن يكذب نفسه في شهادته السابقة ، بأن يقول كنت كاذباً في شهادتي عليه حتى يمكن الحكم بأن الشاهد رجع عن شهادته⁽³⁾.

كيفية الرجوع : والرجوع عن الشهادة إما أن يكون قبل الحكم بها أو بعد الحكم.

فإن كان الأول : سقطت الشهادة عن اثبات الحق بها على الغريم.

وعلة ذلك : أن الحق إنما يثبت بقضاء القاضي ولا قضاء ها هنا لأن القاضي لا يقضي بكلام متناقض ولا ضمان عليهما، لأن الضمان بالإتلاف ولا إتلاف هنا يقضي بالضمان، لأنهما ما أتلفا عليه شيئاً، لا على المدعى ولا على المدعي عليه أما على المدعي عليه فظاهر، وأما على المدعي،

(2) فتح القدير والعناية على هامشه جـ 6 ص 85، الاختيار ص 220.

(3) فتح القدير جـ 6 ص 85.

(4) فتح القدير جـ 6 ص 85، والاختيار ص 220.

(1) الفتاوى الهندية جـ 3 ص 534.

(2) بدائع الصنائع جـ ص 281، جواهر الإكليل جـ 2 ص 245.

(3) نظرية الدعوى والإثبات د / نصر فريد واصل ص 99، 98، المراجع السابقة.

فلأن الشهادة إن كانت حقا في الواقع، ورجعوا عنها صاروا كاتمين للشهادة ولا ضمان على من يكتمها⁽¹⁾.

أما إن كان الرجوع عنها بعد الحكم: فإنه لا يفسخ الحكم. وعلة ذلك: أن الشهادة والرجوع عنها سواء في احتمال الصدق والكذب إلا أن الأول ترجح بالقضاء فلا ينقض الثاني.

وعلى الشهود ضمان ما أتلوه بشهادتهم وذلك لإقرارهم على أنفسهم بسبب الضمان.

أقول الفقهاء في الرجوع عن الشهادة وكيفية:

إذا رجع الشهود أو بعضهم عن الشهادة ، فرجوعهم هذا إما أن يكون قبل الحكم على المشهود عليه، أو بعد صدور الحكم وقبل التنفيذ، وبيان ذلك على الوجه التالي:

أولا: الرجوع عن الشهادة قبل صدور الحكم:

اتفق الفقهاء على أن الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم قبل صدور الحكم من القاضي، فإن شهادتهم تبطل، ويسقط الحد عن الجناة ولا تعتبر هذه شهادة.

العلة في ذلك: أن الشاهد كذب نفسه برجوعه عن الشهادة أمام مجلس القضاء ، فيدرء الحد بشبهة الرجوع وتبطل الشهادة، ويسقط الحد عن الجناة⁽²⁾.

وخالف هذا الاتفاق أبو ثور ، فقال: لا تبطل الشهادة بالرجوع.

وهذا القول مردود من وجهين:

أحدها: أن صدور الحكم من القاضي إنما يكون بعد صدور الشهادة من الشهود، وفي رجوع الشهود عن الشهادة دليل على تكذيب أنفسهم فيما شهدوا به ، وابتقاء الشهادة ينتفي الحكم⁽³⁾.

الثاني: أن القاضي لا يحكم في واقعة، إلا بإحدى الوسائل المثبتة التي يغلب على الظن صدق قائلها، وهذا الرجوع من الشهود فيه تكذيب لهذا الظن، لأن الشاهد إما أن يكون صادقا في الشهادة كاذبا في الرجوع، وإما أن يكون صادقا في الرجوع كاذبا في الشهادة، وهذا يوقع الشك في الشهادة⁽¹⁾.

ثانيا: الرجوع عن الشهادة بعد صدور الحكم وقبل التنفيذ:

وقد وقع خلاف بين الفقهاء في هذه الحالة ، وبيانه في قولين:

القول الأول: يرى جمهور الفقهاء⁽²⁾ : أنه لو شهد الشهود على الحادثة ، ثم رجعوا عن شهادتهم بعد الحكم وقبل التنفيذ فإن شهادتهم تبطل ويسقط الحد عن الجناة لأن الرجوع شبهة يدرأ بها الحد.

قال ابن قدامة: فإن كان المحكوم به عقوبة كالحدود والقصاص فلا يجوز استيفاءه عند الرجوع عن الشهادة؛ لأن الحد يندرى بالشبهات، ورجوعهما من أعظم الشبهات ، فلا يجوز استيفاءه كما لو رجعا بعد الحكم، بخلاف المال فإنه يمكن جبره بإلزام الشاهدين عوضا، والحدود والقصاص لا يجبر بإيجاب مثله على الشاهدين⁽³⁾.

(1) فتح القدير ج 6 ص 86، 85، والاختيار ص 220، 221.

(2) المبسوط ج 16 ص 178، الفتاوى الهندية ج 3 ص 535، مواهب الجليل ج 6 ص 199، جواهر الإكليل ج 2 ص 245، مغني المحتاج ج 4 ص 458.

(3) المغني لابن قدامة ج 8 ص 153.

(1) المغني لابن قدامة ج 8 ص 153، 154.

(2) المبسوط ج 17 ص 185، بدائع الصنائع ج 6 ص 289، مغني المحتاج ج 4 ص 456، مواهب الجليل ج 6 ص 200، اللمحي لابن حزم ج 8 ص 248.

(3) المغني لابن قدامة ج 8 ص 154.

القول الثاني: قال به المالكية في الرواية المشهورة عنهم: أنه إذا رجع الشهود أو بعضهم بعد أداء الشهادة، وبعد صدور الحكم، وقبل التنفيذ، فيؤخذ بهذه الشهادة، ويقام الحد على الجناة وبه قال أبو ثور⁽⁴⁾.

واستدلوا: بما روي عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في شاهد شهد ثم رجع عن شهادته بعد أن حكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم "تمضي شهادته الأولى لأهلها والأخرى باطلة".

دل هذا الحديث على قبول شهادة الشاهد وعدم بطلانها بعد رجوعه عنها. وهذا القول مردود، لأن في الرجوع تكذيب للنفس فيما شهد به، وبانتفاء الشهادة ينتفي الحكم ويحمل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما بعد تنفيذ الحكم على المشهود عليه. والراجح هو قول جمهور الفقهاء القائلين ببطلان الشهادة وسقوط الحد عن الجناة، لأن في الرجوع شبهة درائة الحد.

شرائط وجوب الرجوع عن الشهادة: اشترط الفقهاء عدة شروط للرجوع عن الشهادة بيانها كالتالي: أحدها: أن يكون الرجوع بعد القضاء، فإن كان قبله لا يجب الضمان، لأن الركن في وجوب الضمان بالشهادة وقوع الشهادة إتلافاً، ولا تصير إتلافاً إلا إذا صارت حجة، ولا تصير حجة إلا بالقضاء، فلا تصير إتلافاً إلا به.

الثاني: أن تكون في مجلس القضاء فلا عبرة بالرجوع عند غير القاضي، كما لا عبرة بالشهادة عند غيره.

الثالث: أن يكون المتلف بالشهادة عين مال، حتى لو كان منفعة لا يجب الضمان لأن الأصل أن المنافع غير مضمونة بالإتلاف عند الحنفية.

الرابع: أن يكون الإتلاف بغير عوض، فإن كان بعوض لا يجب الضمان، سواء كان العوض عين مال أو منفعة لها حكم عين المال، لأن الإتلاف بعوض يكون إتلافاً صورة لا معنى.

ما يترتب على الرجوع عن الشهادة ومقدار الواجب من الضمان: الأصل أن مقدار الواجب منه يكون على قدر الإتلاف؛ لأن سبب الوجوب هو الإتلاف، والحكم يتقدر بقدر العلة، والعبرة فيه لبقاء من بقي من الشهود بعد رجوع من رجع منهم.

مثال ذلك: لو شهد الشاهدان بمال، وقضى القاضي به، وأخذ المدعي ثم رجع الشهود، فعليهم الضمان للمشهود عليه، لوجود التسبب على وجه التعدي، وإنه موجب للضمان كحافر البئر.

وإليك نماذج لمقدار الواجب عند الرجوع

من الأمثلة:

1- أن يشهد شاهدان على رجل بأنه طلق زوجته طلاقاً بائناً، سواء كان بعوض — خلعا — أو بثلاث، أو قبل الدخول، أو شهدا بالرضاع الذي يثبت به التحريم أو شهدا باللعان ونحو ذلك، وفرق القاضي بين الزوجين بناء على شهادة الشهود، ثم رجع الشاهدين عن شهادتهما⁽¹⁾.

فإن الحنفية والمالكية: يرون التفريق بين الدخول وعدمه. — أنهما لو شهدا أنه طلقها بعد ما دخل بها فقضى بشهادتهما ثم رجعا عن الشهادة فلا غرم عليهما. وعلة ذلك: أنهما لم يتلفا بشهادتهما عليه مالا، وإنما فوتاه البضع ولا قيمة له، لأنها استحققت جميع الصداق بالدخول⁽²⁾.

(4) مواهب الجليل ج 6 ص 199، حاشية الصاوي ج 5 ص 655، حاشية الدسوقي ج 40 ص 210.

(1) السراج الوهاج ص 613.

ب — وإن كان الطلاق قبل الدخول ففوضى القاضي بنصف المهر، ثم رجعا ضمنا للزوج ذلك. وعلة ذلك: أن شهادتهما وإن لم توجب على الزوج شيئا لكنها أكدت الواجب، لأن الواجب قبل الدخول، كان محتملا للسقوط⁽³⁾.

ويرى الشافعية والحنابلة: أهما لو شهدا بطلاق بائن أو رضاع أو لعان وفرق القاضي فرجعا أي الشاهدين دام الفراق، ويجب على الشاهدين للزوج في هذه الحالة مهر المثل، سواء كانت الشهادة قبل الدخول أو بعده في الأظهر.

وعلى ذلك: فالشاهدين قد فوتا على الزوج بضع زوجته في الظاهر، لحصول الحيلولة بشهادتهما فهما كالغاصب⁽⁸⁰⁰⁾.

ويعترض على ما قاله الشافعية: بأنهم حكموا في مسألة الرضاع عن فساد من الزوجه الكبرى — كأن تريد فساد عقده على زوجها الصغرى التي عقد عليها وهي في سن الرضاع فلو حدث وأرضعت رزوجه الكبرى زوجته الصغرى فإنهم قد حكموا بنصف المهر، فلماذا لم يحكموا في هذه المسألة بمثل مسألة الرضاع.

ويجاب عن ذلك: بالفرق بين الرضاع وبين الحكم في مسألتنا أن الفرق في الرضاع الحقيقة، أي تنفيذ ظاهرا وباطنا، فلا توجب إلا النصف كالمفارقة في الطلاق.

الرأي الرابع: ولعل الأولى بالأخذ والاعتبار هو ما قال به الشافعية ومن وافقهم بوجوب مهر المثل في الأظهر، وذلك لما فيه الردع والزجر، فإنه إذا تيقن الشهود أنهما إذا أقدما على ذلك فشهدوا بشهادة تخالف الواقع لزمهما الغرم، كان ذلك أدعى لتفكير الشاهد مرارا لقول الحق.

ولبيان مسألتنا الرضاع ولزوم الغرم نسوق أقوال الفقهاء في هذه المسألة على الوجه التالي: القول الأول:

يرى الحنفية والشافعية والحنابلة والزيدية، أنه إذا أرضعت الزوجة الصغرى حرمتا عليه⁽¹⁾. أما الصغرى: فلأنها صارت ابنته من الرضاع.

وأما الكبرى: فلأنها صارت أم زوجته، فيجب فسخ العقد، ويجب للصغيرة نصف المهر المسمى إن كان صحيحا، وإلا نصف مهر مثلها⁽²⁾.

وعلة ذلك: أن نكاح الصغيرة انفسخ قبل دخوله بها من غير جهتها، والفسخ إذا جاء من أجنبي كان كطلاق الزواج في وجوب الصداق عليه وهو هنا نصف المهر⁽³⁾.

القول الثاني: يرى المالكية: أنه لا مهر للصغيرة.

(2) بدائع الصنائع ج 6 ص 283، حاشية الدسوقي ج 4 ص 210، حاشية الصاوي على الشرح الصغير ج 5 ص 650، 651.

(3) الهداية شرح بداية المبتدي ج 1 ص 134، لسان الحكام في معرفة الأحكام ص 249، الكافي في فقه أهل المدينة ص 919، حاشية الدسوقي ج 4 ص 717.

(800) مغني المحتاج ج 4 ص 458، السراج الوهاج ص 313، المقنع في فقه الإمام أحمد ج 3 ص 717.

(1) هذا إذا كان اللبن من الزوج، فإن كان بلبن غيره لم تصر الصغيرة بنتا له بل ربيبة محرمة، إن كانت الكبيرة مدخولا بها. الوجيز للغزالي ج 2 ص 108.

(2) تبين الحقائق ج 2 ص 186، مغني المحتاج ج 3 ص 420، حاشية الجمل ج 3 ص 481.

(3) تبين الحقائق ج 2، ص 186، مغني المحتاج ج 3، ص 420، المغني لابن قدامه ج 8، ص 135، البحر الزخار ج 3، ص 269.

وعلة ذلك: أن الفرقة جاءت من قبلها لوجود علة الفرقة منها وهي ارتضاعها والذي وجد من المرضعة هو التمكين من الرضاع إقامها الثدي فكانت محصلة للشرط، والحكم للعلة لا للشرط، فلا يجب على الزوجة للصغيرة شيء كما لا يجب على الزوج للمرضعة شيء⁽¹⁾.

ويناقش هذا الدليل: بأن الفرقة من المرضعة، أو الرضیعة، كانت توجب سقوط المهر، وإنما يجب نصف المهر مقدراً بالمسمى ابتداء صلة للمرأة، ولم يوجد من الصغيرة ما يوجب خروجها عن استحقاق النظر، لأن فعلها لا يوصف بالخطر، لأنها ليست من أهل الرضا، لنجعل فعلها دلالة على الرضا بارتفاع النكاح، فلا تحرم نصف الصداق بخلاف الكبيرة فإن إقدامها دليل على الرضا بارتفاع النكاح، ولهذا لا يجب لها شيء سواء تعمدت الإفساد أم لا⁽²⁾.

رجوع الزوج بما غرم:

اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول: يرى الحنفية والزيدية: أنه غرم الزوج نصف المهر فإنه يرجع على الكبيرة بما أداه فتغرم الكبيرة للزوج نصف المهر إذا كانت تعمدت الإفساد⁽³⁾ وإن كانت لم تتعمد الإفساد فأخذت الصغيرة ثديها لا يرجع الزوج بما غرم⁽⁴⁾.

واستدلوا: بقوله تعالى: (**فَاتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا**)⁽¹⁾.

فجعل الحيلولة عنها كاستهلاك قدر المنفق عليها⁽²⁾.

ومن المعقول: أنها متسببة لا مباشرة ، فإنها باشرت بالإرضاع وهو ليس بموضوع لإفساد النكاح، بل هو سبب موضوع للجزئية، وإنما ثبت الفساد في هذه الصورة باتفاق الحال، والمتسبب إنما يضمن إذا كان متعدياً.

ألا ترى أن من حفر بئراً في داره لا يضمن ما وقع فيها وإن حفرها في الطريق يضمن، والمرضعة هنا ليست علة فساد النكاح، لأن فسادها بالجزئية، وسببها الارتضاع إلا أنه لولا الارضاع لم يوجد الارتضاع فصارت محصلة محل علة الفساد فيضاف الفساد إليها بوصف التعدي⁽³⁾.

(1) الشرح الصغير ج2، ص720 فما بعدها، القوانين الفقهية، ص206، 207.

(2) الهداية شرح بداية المبتدي ج1، ص224، مغني المحتاج ج3، ص42، المغني لان قدامه ج8، ص153.

(3) وتعتمد الإفساد له شروط:

الأول: أن تكون عاقلة فلا رجوع على المجنونة.

الثاني: أن تعلم أن الرضاع مفسد، وتكون متعدياً إذا علمت بالنكاح وقصدت بالإرضاع الفساد أما إذا لم تعلم بالنكاح، أو علمت بالنكاح ولكنها قصدت دفع الجوع والهلاك عن الصغيرة دون الإفساد لا تكون متعدياً لأنها مأمورة بذلك.

الثالث: أن تكون في حالة يقظة، فلو أرضعت وهي نائمة لا تكون متعمدة.

الرابع: أن يكون الرضاع من غير ضرورة، كأن ترضع الصغيرة وهي شبعانة فإن أرضعتها على أنها جائعة ثم ظهر أنها شبعانة لا تكون متعمدة فإن فات شيء من ذلك لم تكن متعمدة، والقول قولها مع يمينها أنها لم تتعمد الفساد لأنه شيء في باطنها، لا يقف عليه غيرها، فلا بد من قبول قولها فيه. تبين الحقائق ج2، ص187، البحر الرائق ج3، ص249، الهداية ج1، ص263.

⁴ وحل الغرم: إذا لم يأذن الزوج، فإن أذن فلا غرم، لأن ضمان المتلفات لا تختلف بهذه الأسباب، مغني المحتاج ج3، ص420.

(1) سورة الممتحنة آية رقم (11).

(2) البحر الرائق شرح كنز الدقائق ج3، ص249، البحر الزخار ج3، ص270.

(3) تبين الحقائق ج2، ص186.

ويرد هذا الدليل: بأن ما يضمن في العمد يضمن في الخطأ ، لأن المرضعة أفسدت النكاح وقررت عليه نصف الصداق فلزمها الضمان كما لو قصدت الإفساد⁽⁴⁾.

القول الثاني: يرد الشافعية والحنابلة ومحمد بن الحسن من الحنفية، أنه يرجع على الكبيرة بنصف المهر المثل سواء تعمدت الإفساد أم لم تتعمد وسواء قصدت فسخ النكاح أم لا .
وحجتهم في ذلك: أن الغرم ضمان الإلتلاف، وأنه يختلف بالعمد والخطأ، والدليل على ذلك: أن الفرقة حصلت من قبلها بإرضاعها وهي بهذا أكدت ما كان على شرف السقوط وهو نصف المهر والتأكيد جار مجرى الإلتلاف، فصارت متلفة عليه مالهم فتضمن⁽⁸⁰¹⁾، كشهود الطلاق قبل الدخول إذا رجعوا عن شهادتهم⁽⁸⁰²⁾.

الرأي الرابع: وما يمكن ترجيحه في هذه المسألة هو قول الشافعية ومن وافقهم بوجوب النصف عليها سواء تعمدت أم لا، وذلك لأن تعمدته واضح من إرضاعها لها لكي يشاركها في الزوج امرأة أخرى فتعامل بنقيض مقصودها، فتحرم من الزواج، وتعاقب بالغرم سواء تعمدت أم لا.
ومن الأمثلة أيضاً:

- 1- لو شهد شاهدان على رجل أنه قتل فلانا عمداً فقضى القاضي بالقصاص واقتص منه - أي من الذي شهدوا عليه، ثم رجعا عن شهادتهما، وخلاف الفقهاء يتن فيما يلي:
يرى الحنفية والمالكية: أنه لا يقتص منهما ، وإنما يضمنان الدية في مالهما في ثلاث سنوات، لأنهما معترفان والعاقلة لا تعقل الاعتراف.
واستدلوا: بأنهما لم يباشرا القتل ، بل حدث التسبب منهما، والقصاص عند الحنفية لا يجب في جريمة القتل بالتسبب، بل لا بد في القصاص من القتل مباشرة، ولم يوجد القتل بالمباشرة هنا ، لأن الشهادة لا تفضي إلى القتل غالباً، وإن أفضت إلي القضاء به، فيرجع إلى التوسط في الصلح على الدية⁽¹⁾.
ويرى الشافعية والحنابلة وبعض المالكية: أنه إذا رجع الشهود، وقد نفذ القصاص، أو رجم الزنا، أو الجلد ومات المجلود أو المقطوع وقال الشهود: تعمدنا الشهادة فيقتص منهم، أو يلزمون بدية مغلظة في مالهم موزعة على عدد رؤوسهم لتسببهم في إهلاك المشهود عليه.
واستدلوا: بما روى الشعبي أن رجلين شهدا عند علي - رضي الله عنه - على رجل أنه سرق ، فقطعه، ثم أتياه برجل آخر فقال: إنا أخطأنا بالأول، وهذا هو السارق . فأبطل شهادتهما على الآخر، وضمنها الدية. وقال: "لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعكما"⁽²⁾.
ففيه دليل على أنه عند التعمد يجب القصاص.
وإن قال الشاهدان اللذان رجعا: أخطأنا، فعليهما الدية مخففة في أموالهما عند الحنابلة، لأن العاقلة لا تحمل الاعتراف **وعند الشافعية:** عليهما نصف الدية، وعلى القاض النصف الآخر توزيعاً للدية على من باشر القتل ومن تسبب فيه.

⁽⁴⁾ المغني لان قدامه ج8، ص155.

⁽⁸⁰¹⁾ السراج الوهاج ص 462، تبين الحقائق ج2، ص186، مغني المحتاج ج3، ص420، المغني لابن قدامه

ج8، ص153.

⁽⁸⁰²⁾ وقد أتينا بهذه المسألة لبيان ما قاله الشافعية في شهود الطلاق قبل الدخول إذا رجعوا.

⁽¹⁾ بدائع الصنائع ص285، الشرح الكبير ج6، ص307.

⁽²⁾ الوجيز للغزالي ج2، ص158، المهذب للشيرازي ج2، ص420، المغني لابن قدامه ج9، ص347.

المبحث الثاني عشر في الاستئجار لأداء الشهادة

حول جواز أخذ الأجرة على أداء الشهادة بين الفقهاء أن أداء الشهادة فرض لمن تعينت عليه، وهناك من الفروض من لا يقبل النيابة، وذلك كالصوم والصلاة فإنهما من الفرائض التي لا تقبل قيام الغير فيها، ولا يصح دفع الأجرة لشخص يؤديها بدلا من غيره.
وإنما لا تصح النيابة في ذلك: لأن العمل الذي يكون فرض عين على شخص تكون منفعته قاصرة على من أداه، فلا معنى لاستئجار الغير على القيام به.
قال الزيلعي: لأن القربة متى وقعت كانت للعامل، فلا يجوز له أخذ الأجرة على عمل وقع له كما في الصلاة والصوم⁽¹⁾.

ولهذا فإنه لم يرد نص الفقهاء بالقول بإجارة الغير للصلاة أو الصوم.
لأن القياس يقتضي أن العبادات لا ينوب فيها أحد عن أحد، فإنه لا يصلي أحد عن أحد باتفاق⁽²⁾.
أما غير العبادات، والأعمال الأخرى التي يصل نفعها إلى غير من أداها فإننا نجد أن من الفقهاء من يقول بجواز الإجارة فيها.
ففي أداء الشهادة وأخذ الأجرة عليها: نلاحظ: أن بعض فقهاء الحنابلة فرقوا بين يسار المؤدي للشهادة وعد يساره.
أ- فإن كان عنده ما يكفيه وعياله: فلا يجوز له أخذ الأجرة على الشهادة لأن أداء الشهادة فرض على سبيل الكفاية، وفرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين.
ب- وإن لم يكن عند الشاهد ما يكفيه وعياله: فيفرق بن حالتين:
الأولى: أن تتعين عليه الشهادة، فإذا تعينت عليه الشهادة ففيه قولين: الأول: جواز أخذ الأجرة. والثاني: عدم الجواز، لئلا يأخذ العوض على أداء فرض عين عليه.
الثانية: إذا لم تتعين عليه الشهادة، جاز أخذ الأجرة على الشهادة.
وعلة ذلك: أن النفقة على عيال الشاهد فرض عين عليه، فلا يشتغل عنه فرض بفرض الكفاية، فإذا أخذ الأجرة جمع بين الأمرين⁽¹⁾.
وقال الشافعية: إن الشاهد لا يستحق أجرة إلا أجرة الركوب ثم له أن لا يركب، والواضح من قولهم: أنه إذا تعينت على الشاهد الشهادة فليس له أخذ الأجرة، لئلا يأخذ الأجرة على فرض عين عليه، أما إذا لم تتعين فيحتمل قولين⁽²⁾.
وعن الزيدية قولان: يجوز حيث لا تتعين، ولا كالمتعين⁽³⁾.
ورأي الحنابلة بالتفريق هو الأولى بالأخذ والاعتبار وذلك إذا دعت الحاجة إلى أخذ الأجرة لنفقة أولاده أو من يعولهم.

(1) تبين الحقائق ج-5، ص124.

(2) بداية المجتهد ج-1، ص309.

(1) المغني لابن قدامه ج-9، ص158.

(2) الوجيز للغزالي ج-2، ص255.

(3) البحر الزخار ج-4، ص53.

الفصل الثاني

في الإقرار وأحكامه

المبحث الأول مفهوم الإقرار ومشروعيته وحكمه وألفاظه

أولاً: مفهوم الإقرار

الإقرار في اللغة: مصدر للفعل أقر يقال: قر فلان بالمنزل إذا سكن وثبت فهو في الأصل : التسكين، والثبات والقرار: هو السكون والثبات ، ويقال: قررت عند كذا ، أي أثبتته، ويقال: استقر الأمر على كذا: أي ثبت عليه. ومنه قيل لليوم الأول من أيام التشريق يوم القر؛ لأن الناس يقرون في "منى" للنحر.

وسميت "منى" أيام القر؛ لأنهم يثبتون بها، ويسكنون عن سفرهم وحركتهم في هذه الأيام. ويطلق أيضاً على الدعاء ، ويقال: قر الله عينه، إذا أعطاه ما يكفيه فسكنت نفسه، ولا تطمع إلى شيء آخر⁽¹⁾.

وفي الشرع: اعتراف صادر من المقر يظهر به حق ثابت فيسكن قلب المقر له إلى ذلك⁽²⁾. وترمي اصطلاحات الفقهاء إلى أنه: إخبار من يصح إخباره بحق لغيره عليه⁽³⁾. ومن هذا يتبين لنا: أن الإقرار يطلق ويراد به المعاني التالية: الثبوت والاستقرار ، كما هو عند أهل اللغة وإليه أشار أهل الفقه.

ولا يخفى أن الإقرار هو سيد الأدلة؛ لأن المقر يخبر عن نفسه وعن الأشياء التي عليه بنفسه، ويسمى بالشهادة على النفس، وبما أن الإقرار إخبار متردد بين الصدق والكذب، فكان محتملاً لهذين الأمرين إلا أنه جعل حجة بدليل معقول، وهو أنه ظهر رجحان الصدق على الكذب فيه؛ لأن الإنسان غير متهم فيما يقر به على نفسه، فإن المال محبوب للمرء طبعاً، فلا يقر لغيره كاذباً، فلم يكن في الإقرار تهمة أو ريبة⁽⁴⁾.

دليل مشروعية الإقرار: الإقرار حجة شرعية دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والمعقول. أما الكتاب:

- 1- قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ) ⁽²⁾ . قالوا: إن الشهادة على النفس إقرار، فلو لا أن الإقرار حجة لما أمر بإقامة الشهادة على النفس الإقرار بها، قال تعالى: (بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ) قال ابن عباس: أي شاهد الحق.
- 2- قوله تعالى: (وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ) ⁽³⁾ ففيه إقرار المرء على نفسه؛ لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالإملا، فلو لم يكن إقراراً لما كان للإملا معنى.
- 3- وقوله تعالى: (قَالَ أَفَرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي) ⁽⁴⁾ قَالُوا أَفَرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ) فالله سبحانه وتعالى طلب منهم الإقرار، ولو لم يكن الإقرار حجة لما طلبه⁽⁴⁾. ومن السنة المشرفة:

(1) مختار الصحاح 527، 528 مادة قر، والمصباح المنير ج2، ص681 باب القاف مع الراء.
(2) الهداية شرح بداية المبتدئ ج3 ص180، تبیین الحقائق ج5 ص2، بدائع الصنائع ج7، ص203، مغني المحتاج ج2 ص237.

(3) تبیین الحقائق ج5 ص2، والمحلي لابن حزم ج8، ص250، البحر الزخار ج6 ص3.

(1) الفقه الإسلامي أ.د/ الزحيلي ج6 ص611، البحر الزخار ج6 ص3.

(2) سورة النساء آية رق (135).

(3) سورة البقرة آية رقم (282).

(4) تبیین الحقائق ج5 ص2.

1- ما روى في صحيح مسلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " رجم ماعز والغامدية بإقرارهما"⁽⁵⁾.

والثابت فيه تكرار الإقرار، بما روى من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: أتى رجل من الأسلميين وهو في المسجد فقال يا رسول الله: إني زنيت، فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال يا رسول الله: إني زنيت، فأعرض عنه حتى فعل ذلك أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: أبك جنون؟ قال: لا، قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم، فقال - صلى الله عليه وسلم - " ارجموه".

وهذا الحديث الشريف استدل به الإمام أبي حنيفة وأحمد على اشتراط التكرار في الإقرار في هذه الحالة.

هذا بخلاف ما يراه فقهاء الشافعية القائلين بأن التكرار في خبر ماعز ليس المراد منه التكرار، وإنما المراد منه الشك في عقل المقر؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عندما طلب من ماعز التكرار إنما لشك منه في عقل ماعز، ولهذا قال له: " أبك جنون؟"، ولم يكرر ذلك في خبر الغامدية؛ لأن الإقرار إخبار، والخبر لا يزيد بالتكرار، فقد علق النبي - صلى الله عليه وسلم - الاعتراف على مجرد الإقرار فقال: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فعلق الرجم على مجرد الاعتراف. والظاهر: هو الاكتفاء بأقل ما يصدق عليه اللفظ وهو المرة الواحدة وهو قول مالك (رحمه الله).

2- ما روي عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما - أنهما قالوا: " إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله أنشدك الله ألا قضيت لي بكتاب الله وقال الخصم وهو أفقه منه: نعم فاقض بيننا بكتاب الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل: قال: إن ابني كان عسيفا على هذا يعني أجيرا فزني بامرأته وأنى أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة فسألت أهل العلم، فاخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس - رجل من اسلم - إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها قال: فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله فرجمت⁽¹⁾.

وأما الإجماع: فإن الأمة الإسلامية أجمعت على صحة الإقرار وكونه حجة من لدن رسول الله إلى يومنا هذا من غير تكير.

أما المعقول: أنه خبر صدق لعدم التهمة في ذلك ففي المال مثلا المال محبوب إلى النفس، فلا يكذب في الإقرار به لغيره، وهو حجة مظهرة للحق ملزمة، حتى لو أقر بدين أو عين على أنه بالخيار ثلاثة أيام لزمه المال، وبطل الخيار وإن صدقه المقر له في الخيار؛ لأن الخيار للفسخ، والإقرار لا يحتمل الفسخ، لأنه إخبار، والفسخ يرد على العقود⁽¹⁾.

ثالثا حكم الإقرار:

ظهور ما أقر به المقر؛ لأنه إخبار عن كائن سابق حتى لو أقر لغيره بمال، والمقر له يعلم كذبه لا يحل له أخذه على كره منه، إلا أن يعطيه بطيب نفس منه فحينئذ يكون تمليكا مبتدأ كالهبة⁽²⁾.

(5) صحيح البخاري ج 6 ص 2502 ح/6438، وصحيح مسلم ج 3 ص 1319 ح/1691.

(1) صحيح مسلم ج 3 ص 1325 ح 1697، نيل الأوطار للشوكاني ج 7 ص 86.

(1) الاختيار لتعليل المختار ص 182، فتح القدير ج 4 ص 117.

(2) الاختيار لتعليل المختار ص 183.

شرطه: أن يكون المقر به مما يجب تسليمه إلى المقر له حتى لو أقر بكف تراب ، أو حبة حنطة لا يصح.

رابعاً: ألفاظ الإقرار:

الإقرار إما أن يكون بلفظ صريح أو بلفظ ضمنى أو دلالة.

أولاً: الإقرار بلفظ صريح: وذلك كأن يقول إنسان لفلان على ألف جنيه فكلمة " على " تفيد الإيجاب والإلزام لغة وشرعا قال تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلٌ) ⁸⁰³. أو أن يعبر بلفظ نعم، فإنها تقع إجاباً وتصديقاً، قال تعالى: (فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ) ⁸⁰⁴.

أو أن يعبر بما في ذمته كأنه يقول " لفلان في ذمتي ألف جنيه؛ لأن ما في الذمة هو الدين ، فيكون إقراراً بالدين.

وكذلك لفظ " بلى " تقع إقراراً صحيحاً؛ لأنه جواب للسؤال بحرف النفي، قال تعالى: (أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى) ⁸⁰⁵.

مثاله: أن يقول " أليس لي عندك ألف جنيه " فيقول: بلى.

ما يخرج عن الألفاظ:

1— لو قال : له من مالي ألف جنيه: لا يكون إقراراً، بل هبة وإذا كان هبة لا يملكها المخاطب إلا بالقبول والقبض.

2— لو قال : له عندي جنيه " فهو وديعة؛ لأن عندي لا تدل على التزام شئ في الذمة ، بل هي كلمة تفيد الوجود وليس لهذا المعنى دلالة على الالتزام.

3— لو قال: " لفلان عندي ألف جنيه عارية " فهو قرض؛ لأن عندي تستعمل في الأمانات ، وقد فسرت بالعارية؛ لأن عارية الأموال تكون قرضاً، إذ لا يمكن الانتفاع بها إلا باستهلاك عينها وإعارة ما لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاكه يكون قرضاً في العرف ⁽¹⁾.

ثانياً: الإقرار الضمني أو دلالة: قد يكون الإقرار بلفظ يدل على التزام الشئ ضمناً أو دلالة مثل أن يقول شخص لغيره " لي عندك ألف جنيه " فيقول: قد قضيتها؛ لأن القضاء يدل على تسليم مثل الواجب الملتزم به في الذمة فيقضي سبق الالتزام بهذا المبلغ، ولا يثبت الوفاء إلا بالبينة. وكذلك دعوى الصدقة والهبة بأن قال : " تصدقت بها على أو وهبتها لي " كان ذلك إقراراً منه مثل دعوى القضاء؛ لأن التملك بالصدقة أو بالهبة يقتضي أسبقية الوجوب والالتزام. ولو قال رجل لآخر: " لي عليك جنيه " فقال لك حقاً أو صدقاً يكون إقراراً؛ لأن معناه تصديقه فيما يدعيه.

الإقرار المكتوب: لو ادعى رجل على رجل آخر مالاً، وأخرج بذلك مكتوباً بخط يده يدل على إقراره له بالمال، وأنكر المدعي عليه أنه خطه، فاستكتب فكتب فكان بين الخطين مشابهة ظاهرة دلالة على أنها خط كاتب واحد ، قال أئمة بخاري: إنه حجة يقضي بها وقد نص محمد بن الحسن : على أنه لا يكون حجة؛ لأنه لو قال: هذا خطي وأنا كتبتة غير أنه ليس علي هذا المال ، لا يلزمه شئ فهذا أولى.

⁸⁰³ جزء من الآية رقم [97] سورة آل عمران.

⁸⁰⁴ جزء من الآية رقم [44] سورة الأعراف.

⁸⁰⁵ جزء من الآية رقم [172] سورة الأعراف.

(¹) بدائع الصنائع ج 7 ص 207، تكملة فتح القدير ج 6 ص 296، المغني ج 5 ص 137

ولو كتبه بخطه صكا فقبل له : تشهد به، فقال : نعم، يكون إقرارا ، فإن لم يقل شيئا ، لا يكون إقرارا⁽¹⁾.

(1) المبسوط ج 8 ص 154، تكملة فتح القدير ج 6 ص 286، بدائع الصنائع ج 7 ص 220، الفقه الإسلامي للزحيلي ج 6 ص 613، 616.

المبحث الثاني أركان الإقرار وشروطه

وبناء على ما سبق أن سقناه من تعريفات للفقهاء في الإقرار يمكن أن نستخلص الأركان التي لابد منها لتحقيق الإقرار وهي كما يلي:

- 1- المقر، وهو المخبر.
 - 2- المقر له، وهو صاحب الحق.
 - 3- الحق، وهو المقر به.
- وهذا عند جمهور الفقهاء، أما عند الحنفية فتعد هذه الأركان الثلاثة، شروطاً لصحة الصيغة؛ لأن الإقرار يحتاج إلى ركن واحد وهو الصيغة، وتتحقق بقول المقر لفلان على كذا. ومن هذا يتبين أن ما اعتبره جمهور الفقهاء أركاناً للإقرار اعتبره الأحناف شروطاً في صحة الصيغة، ولهذا نجد الخلاف بينهم خلاف نظري لا جوهري⁽²⁾.
- ### شروط صحة الإقرار:

يشترط في المقر عدة شروط بيانها كالتالي:

- 1- البلوغ: فلا يصح إقرار الصبي؛ لأن إقراره غير لازم لانعدام أهلية الالتزام. واستثنى الحنفية ما إذا كان الصبي مأذوناً له؛ لأنه ملحق بالبالغ بحكم الأذن. ويدخل في الأذن كل ما كان طريقه التجارة، كالدين والوديعة والعارية والمضاربة، فيصح إقراره بها فيلحق الصبي المأذون له في التجارة بالبالغ في هذه الأمور. وعلة ذلك: أن الإذن يدل على عقله، فلو لم يكن عاقلاً لما أذن له وليه بخلاف ما ليس من باب التجارة، كالمهر والجنابة فلا يقع تحت الأذن؛ لأنها ليست بمبادلة مال بمال⁽¹⁾.
- ### أقوال الفقهاء في إقرار الصبي:
- اتفق الفقهاء على أن الصبي إذا كان غير مميز فإقراره باطل ولا يترتب عليه أي أثر، وكذلك الحكم بالنسبة لإقرار الصبي المميز عند جمهور الفقهاء وذلك لاشتراط تكليف المقر عند الجميع.
- واستدلوا: بحديث [رفع القلم عن ثلاث]⁽²⁾ منهم الصبي، فهذا الحديث الشريف يمنع تكليفه، والقول بصحة إقراره يوجب تكليفه؛ لأن الإقرار يترتب عليه حكم بالالتزام، ولا التزام إلا بناء على تكليف⁽³⁾.

ويرى الحنفية والزيدية: أن إقراره صحيح.

- واستدلوا: بأن الحكم بصحة هذا الإقرار ضرورة من ضرورات التجارة التي أجاز له مزاولتها ابتلاء وتدريباً له على الأمور المالية والتصرف فيها بنفسه بمقدرة وكفاءة بعد بلوغه لقوله تعالى: **وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ**⁽⁴⁾.

(2) حاشية ابن عابدين ج 8 ص 103، مجمع الأنهر ج 2 ص 262، الهداية شرح بداية المبتديء ج 3 ص 180، الشرح الكبير للدريديري ج 3 ص 397، المهذب للشيرازي ج 3، 343، المغني لابن قدامة ج 5 ص 138.

(1) حاشية ابن عابدين ج 8 ص 103، بدائع الصنائع ج 7 ص 220.

(2) أخرجه ابن حبان في صحيحه ج 1 ص 355، ح/ 142 باب التكليف.

(3) نظرية الدعوى والإثبات أ د / نصر فريد واصل ص 27.

(4) سورة النساء آية 6، المبسوط ج 17 ص 184.

2- العقل: فلا يصح الإقرار من المجنون؛ لأن إقراره غير لازم لانعدام أهلية الإلتزام وكذا المغمى عليه والسكران.

ولا شك أن زوال العقل مانع من التكليف، وقد ورد بشأنه النص الصريح في قوله صلى الله عليه وسلم [رفع القلم عن ثلاث]، عن الصبي حتى يبلغ ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، والمجنون والمغمى عليه قد زال عقلهما فهما زائلا الإدراك. أما السكران : فاختلف فيه الفقهاء:

فيرى ابن القيم وأبي ثور والمزني والظاهرية أنه لا ينبغي على إقرار السكران حكم شرعي يلزم هذا السكران حتى بعد إفاقته لا في الأموال ولا في غيره. واستدلوا:

1- بقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى)⁽¹⁾.

2- ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أمر الصحابة باستكاه ما عز لما أقر بالزنا بين يديه". ليعلم من رائحة فمه أكان شاربا للخمر أم لا.

3- فتوى عثمان وابن عباس بأن السكران لا يقع طلاقه.

والذي عليه الحنفية: أن إقرار السكران جائز في الحقوق كلها إلا في الحدود الخالصة، والردة بمنزلة سائر التصرفات تنفذ من السكران كما تنفذ من الصاحي⁽²⁾.

وجمهور الفقهاء: فرقوا بين من زال عقله بسبب مباح أو حرام، فما كان سكره بسبب مشروع كضرورة العطش أو الغلط أو حتى المرض على رأي، فإنه لا يترتب على إقراره أي أثر شرعي لا في المال ولا في غير المال⁽³⁾.

أما السكر بمحرم : فإقراره صحيح ويترتب عليه التصرفات الشرعية من حيث وجوب الإلتزام بما أقر به في كل شيء إلا فيما يقبل الرجوع من الحقوق الخالصة لله وهي الحدود؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات والرجوع عن الإقرار في الحدد شبهة دائرة للحد فلذا لم يلزم الحكم به شرعاً.

واستدلوا: بأن السكران أقدم على السكر مع علمه بأنه محرم شرعاً ومنهي عنه، فأقدامه عليه هو رضاء ضمنى بكل ما يصدر عنه أثناء سكره، ولا يخرج الإقرار عن تلك الآثار ، فيعامل بنقيض قصده ليزم بما أقر به شرعاً حتى يكون ذلك رادعاً له، وحتى لا يكون السكر وسيلة للتهرب من الحقوق والإلتزامات - تحت ستار زوال العقل بالمسكرات⁽⁴⁾. وهو ما أراه راجحاً؛ لما فيه من الردع والزجر لصيانة حقوق الناس وأموالهم.

3_ الطوعية والاختيار.

أي أن يقر مختاراً طواعية فلا يصح إقرار المكره قال تعالى: [إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ]⁸⁰⁶ فإن كان الإكراه مسقطاً لحكم الكفر ففي هذا أولى.

هذا ومن الملاحظ في هذا الشرط أنه إن كان المقر مكرهاً فلا يصح إقراره؛ لأن الإقرار حجة ملزمة على صاحبه، وذلك لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما

(1) سورة النساء آية 43

(2) فتح القدير ج 6 ص 284، مغني المحتاج ج 3 ص 279، البحر الزخار ج 6 ص 5.

(3) السراج الوهاج ص 254.

(4) فتح القدير ج 6 ص 284، تبیین الحقائق ج 5 ص 3، والمغني لابن قدامة ج 5 ص 139.

⁸⁰⁶ من الآية رقم 106 سورة النحل.

استكروهوا عليه⁽¹⁾ . والحديث يدل دلالة واضحة على أن المكره لا نية له، وعله فإذا وقع عليه الإكراه لم يؤخذ به، ولم يترتب عليه حكم.

ولأهمية هذا الشرط نتناول الإكراه بشيء من التفصيل:

الإكراه لغة: حمل الإنسان غيره على ما يكرهه قهراً.

وفي الشرع: هو الإلزام والإجبار على ما يكره الإنسان طبعاً أو شرعاً ، فيقدم عليه عدم الرضا ليدفع ما هو أضر منه.

أو هو: حمل الشخص غيره على ما لا يرضاه من قول أو فعل ، ولا يختار مباشرته لو خلى ونفسه.

وقيل: هو اسم لفعل يفعله المرء بغيره، فينتقي به راه أو يفسد اختيار مع بقاء أهليته⁽²⁾.

والأصل فيه: قوله تعالى : **(لَا مَن أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ)**⁸⁰⁷.

ومن السنة: ما روى أن عمار بن ياسر - رضي الله عنه - أكرهه المشركون على الكفر، فأعطاهم

بلسانه ما أرادوا، ثم جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يبكي، فقال: ما وراءك؟ فقال

شر نلت منك، فقال كيف وجدت قلبك؟ قال: مطمئناً بالإيمان، فجعل رسول الله يمسح عينيه ويقول:

مالك إن عادوا فعد، ونزل قوله تعالى: **(لَا مَن أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ)**⁸⁰⁸.

أنواعه: يتنوع إلى نوعين:

1- **الإكراه الملجئ:** وهو الذي كون التهديد فيه بقتل النفس أو إتلاف العضو، أو الضرب الشديد الذي يخشى منه تلف النفس أو العضو.

وهذا النوع معدم للرضا، ومفسد للاختيار؛ لأن المكره يستطيع تحمل الأذى، وهو غير مؤثر في أهلية الأداء.

2- **الإكراه غير الملجئ:** وهو الذي يكون فيه التهديد بما لا يشق على النفس احتماله كالتهديد بالضرب الذي لا يخشى منه التلف أو إتلاف بعض المال.

وحكمه: أنه غير مفسد للاختيار، ولكنه يعدم الرضا، ولا تأثير له على الأهلية⁽¹⁾.

وصورة إقرار المكره:

أن يسأله القاضي أو الحاكم عن المدعي به، فيجيب بالنفي، ويضرب ليقر، فإذا أقر حينئذ فإن إقراره غير صحيح.

لا شك في أن ضرب المتهم لكي يقر محرم شرعاً فلقد ورد عن الفقهاء العبارات التالية:

"ولا يحل حبس أحد بدون وجه حق، ومتى حب بحق يجب المسارعة بالنظر في أمره، فإن كان مذنباً أخذ بذنبه وإن كان بريئاً أطلق سراحه، ويحرم ضرب المتهم لما فيه من إذلاله وإهدار كرامته".

وهل يضرب إذا إنهم بالسرقة فيه رأيان :

المختار عند الأحناف والغزالي : أن المتهم بالسرقة لا يضرب لاحتمال كونه بريئاً ، فترك الضرب

في مذنب أهون من ضرب برئ .

(1) كشف الخفاء مزيل الالباس عنا اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس لإسماعيل بن محمد العجلون ج 1 ص 522 حديث رقم 1393 - تحقيق أحمد القلاش ، نشر مؤسسة الرسالة.

(2) فتح القدير ج 6 ص 284، الفتاوى الهندية ج 5 ص 303.

⁸⁰⁷ من الآية رقم 106 سورة النحل.

⁸⁰⁸ من الآية رقم 106 سورة النحل.

(1) فتح القدير ج 6 ص 284، الاختيار ص 148، الهداية ج 3 ص 275.

وفى الحديث عنه - صلى الله عليه وسلم - لأن يخطئ الإمام فى العفو خير من أن يخطئ فى العقوبة .

وأجاز الإمام مالك سجن المتهم بالسرقة ، وأجاز أصحابه ضربه لإظهار المال المسروق من جهته ، وجعل السارق عبدة لغيره .

ومتى أقر المتهم فى هذه الأحوال فإنه لا قيمة لإقراره؛ لأنه يشترط فى الإقرار الاختيار وهنا إنما أقر تحت ضغط التعذيب⁽¹⁾ .

لو ادعى بعد الإقرار أنه كان مكرهاً :

لو أقر المدعى عليه لكنه بعد الإقرار ادعى أنه كان مكرهاً ساعة الإقرار ، فإما أن تكون هناك قرينة دالة على صدقة فى دعواه الإكراه أم لا ، فإن كان هناك قرينة تدل على صدقة كما لو كلن قد حبس قبل الإقرار فإنه يصدق بيمينه ، فإذا حلف على ما إدعاه من الإكراه أم لا ، فإن كان هناك قرينة تدل على صدقة كما لو كان قد حبس قبل الإقرار فإنه يصدق بيمينه ، فإذا حلف على ما ادعاه من الإكراه سقط الإقرار وأما إذا لم تكن هناك قرينة تدل على صدقة فلا اعتبار بأدعائه الإكراه فى إقرار⁽²⁾ .

الإكراه على الإقرار بالعقود : لو أكره على البيع أو الشراء أو الإجازة ، أو الإقرار بقتل أو ضرب شديد أو حبس ، ففعل ثم زال الإكراه .

فالحكم فيه عند الحنفية : أن المكره بالخيار إن شاء أمضى البيع وإن شاء فسخه ، ورجع بالمبيع .

وعلى ذلك : أن الملك يثبت بالعقد لصدوره من أهله فى محله إلا أنه فقد شرط الحل ، وهو التراضى ، فصار كفيرع من الشروط المفسدة .

ويرى جمهور الفقهاء : أن عبارة المكره غير صحيحة بناء عليه فلا يعتد بقوله فى سائر العقود .

وعلة ذلك : أن عبارته صدرت عن إكراه معدم لرضاه ولحديث ، رفع عن أمتى الخطأ والنسيان ، وما أسنكرهوا عليه .

ويترتب على ذلك عند تمام البيع حالة الإكراه : أن الملك يثبت عند الإمام وصاحبه ، وعند زفر : لا يثبت .

وجه قوله : أنه بيع موقوف على الإجازة ، والموقوف قبل الإجازة لا يفيد الملك .

وعلة القول الأول : أن ركن البيع صدر من أهله مضافاً إلى محله والفساد لفقد شرطه وهو التراضى ، فصار كسائر الشروط المفيدة ، فيثبت الملك عند القبض⁽¹⁾ .

الإكراه على الزنا : من المتفق عليه أنه لا حد على مكرهه على الزنا لقوله تعالى (**وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه**) ولقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - عفى عن أمتى الخطأ والنسيان ، وما أسنكرهوا عليه .

وقد جاء فى سنن البيهقي : أن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - أتى بامرأة جهدها العطش فمرت على راع فاستسقته فأبى إلا أن تمكنه من نفسها ففعلت فشاور الناس فى رجمها ، فقال على بن أبى طالب - رضى الله عنه - هذه مضطرة ، أرى أن يخلى سبيلها ففعل .

ولأنها مسلوقة الاختيار فلم يجب عليها الحد فى رجمها .

(1) حاشية الجمل ج3 ث 430 ، فقه السنة ج3 ص 353 ، 354 .

(2) الفضاء فى الفقه الإسلامى ص 148 .

(1) البناية على الهداية ج2 ص 104 ، والجنايات فى الفقه الإسلامى بحث الزنا وعقوبته أ0د/ نصر فريد محمد واصل ص 268 .

ما روى أن امرأة استكرهت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدرا عنها الحد .

وللفقهاء أقوال في الإكراه على القتل بيانها كالتالي :-

القول الأول ك أن القصاص على المكره - بالكسر - إن كان القتل عمداً ، وهو قول أبي حنيفة ومحمد ورواية عن الشافعية .

واستدلوا : بأن القاتل المباشر ، وهو المكره - بالفتح - محمول على القتل بطبعه إثارة لحياته فيصير في مقام الآلة بالنسبة للمكره - وأعتبرت في حقه فيسند الحكم الشرعي اليه ، وهو القتل العمد العدوان الموجب للقصاص ⁽¹⁾ .

القول الثاني : أن القصاص يندرى بالشبهات ، وقد تحققت الشبهة في حق كل واحد منهما ، أما المكره - بالفتح - فهو محمول عليه ، وأما الكره - بالكسر - فلعدم المباشرة .

القول الثالث : إن القصاص يجب على المكره - بالفتح - لأن الفعل صدر من المكره حقيقة وحسا ، للمباشرة ، ولذا قرر الشرع حكمه عليه وهو الأثم ، لأن المباشرة موجبة للقتل ، وهو قول الشافعي : لأن المباشر اختار قتل غيره لأحياء نفسه ، وهذا التحول والاختيار ينفي عنه صفة الإكراه ⁽²⁾ .
يرجحان الصدق على الكذب في إقراره والإقرار يعتبر شهادة على النفس ، والشهادة ترد بالتهمة ⁽¹⁾ .
إقرار المريض لورثته :

وعلى هذا لو أقر المريض مرض الموت لمن يتهم بمودته كابنه البار به أو زوجته التي يميل إليها .
فالحنفية يرون: أن إقرار المريض لورثته باطل إلا أن يصدق ببقية الورثة .

واستدلوا : بما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : لا وصية توارث ولا إقرار بدين " **وعلة البطلان :** أنه تعلق به حق لجميع الورثة بإقراره لبعضهم إبطال لحق الباقيين ، كما أن فيه إيقاع العداوة بينهم لما فيه من إثارة البعض على البعض وأنه منشأ للعداوة ، والبغضاء ، وقضية يوسف عليه السلام ، أكبر شاهد على ذلك .

ولأن حالة المرض حالة الاستغناء ، والقربة سبب التعلق إلا أن هذا التعلق لم يظهر في حق الأجنبي لحاجته إلى المعاملة في الصحة ، ولأنه لو أتجز عن الإقرار بالمرض يمتنع الناس عن المعاملة معه ، وعلى ذلك فإن أقر الأجنبي جاز وأن أحاط بجميع ما أقر به والقياس : أنه لا يجوز إلا في حدود الثلث .

ويرى الإمام مالك : أن الإقرار لا يصح سواء كان لوارث أم لغير واث ، إلا إذا أجازته الورثة **وقال الشافعي في قول :**

أنه لا يصح إقراره لورثته كإقراره للأجنبي .

وعلة ذلك : أنه إظهار لحق ثابت لترجيح جانب الصدق فيه ، وصار كالإقرار لأجنبي .

أما الحنابلة : فقالوا بعدم صحة إقرار المريض لورثته .

وعلة ذلك : إن إقراره فيه حرمان لبقية الورثة ، ولا يخفى أنه يتفق مع رأى الحنفية .

ومن الملاحظ أن جميع الفقهاء متفقون على عدم صحة إقرار المريض لأحد الورثة إلا في حدود الثلث ، لأن الشرع قد قصر تصرفه عليه ومنه الزيادة ويشترط إجازة الورثة له ، وذلك لما فيه من إثارة البعض على البعض وهو منشأ للعداوة والبغضاء .

(1) المراجع السابقة

(2) فتح القدير ج6 ص 285 ، مغنى المحتاج ج3 ص 280 .

(1) بدائع الصنائع ج7 ص 214 .

خامساً : أن يكون المقر معلوماً : فلو قال رجلان " لفلانة على واحد منا ألف درهم " لا يصح الإقرار لأن المقر إذا لم يكن معلوماً لا يتمكن المقر له من المطالبة بالدين فلا يكون في هذا الإقرار فائدة فلا يصح .

ثانياً : شروط المقر له :

أن يكون محقق الوجود وقت الإقرار حقيقة سواء كان موجوداً في الظاهر أو حملاً في البطن ، فلو كان المقر له مجهولاً بأن قال إنسان : لواحد من الناس على ألف درهم " لا يصح الإقرار لأنه لا يملك أحد مطالبته بمقتضى إقراره .

ولو قال : لحمل هند على ألف درهم ، فإن جاءت به في مدة يعلم أنه كان قائماً وقت الإقرار لزم المقر ما أقر به وأن جاءت به ميتاً ، فالمال للموصى والمورث لأنه إقرار في الحقيقة لهما ، وأن جاء بولدين حيين فالمال بينهما .

فإن أبهم الإقرار ، فلم يبين سبباً صالحاً يتصور لثبوت الملك للحمل كالإرث والوصية ، لم يصح الإقرار عند أبي يوسف وقيل : وأبو حنيفة معه ، لأنه لم يثبت للجنين شيء من الحقوق المالية ، سواء أكان من جهة التجارة والمعاملة أم من جهة الجناية ومطلق الإقرار ينصرف إلى الإقرار بحق ثابت بسبب التجارة فيعتبر كأن المقر شرح به وهو غير مقبول منه .

وقال محمد بن الحسن ومالك وأحمد : يصح الإقرار للحمل ، إذا أطلقه المقر ، أي لم يسنده إلى سبب كارث أو وصية ويحمل إقراره على سبب الملكية المتصور للحمل ، وهو قول الشافعي في الأظهر .

هذا هو حكم الإقرار للحمل ، وأما الإقرار بالحمل فجاز اتفاقاً .
كما إذا أقر بحمل شاة لرجل ، صح إقراره والتزم المقر بما أقر به ، سواء بين سبباً صالحاً لثبوت الملك أو أبهم ، لأن لإقراره وجهاً صحيحاً وهو الوصية بالحمل من جهة غير المقر ، بأن أوصى بالحمل مالك الشاة لرجل ، ومات فأقر وارثه وهو عالم بوصية مورثة بأن هذا الحمل لفلان⁽¹⁾ .

ثانياً : أن يكون المقر له معيناً تعييناً يتوقع معه الطلب ، وعلى هذا لو قال شخص : على مال لرجل من أهل البلد لم يصح الإقرار ، وأما لو قال : على مال لأحد هؤلاء الثلاثة فيصح .

ثالثاً : عدم تكذيبه للمقر ، كان يقول المقر ، ليس لي عليك شيء فلو كذبه في إقراره له بمال ، فإن المال يترك في يد المقر ، لأن يده تشعر بالملك بحسب الظاهر ويسقط الإقرار .

شروط المقر به :

ويشترط فيه أن يكون ممكناً عقلاً وشرعاً ، وإلا يتعلق به حق للغير ، لأن حق الغير معصوم محترم ، فلا يجوز إبطاله من غير رضاه .

وأن يكون المقر به مما يجب تسليمه إلى المقر له ، فلو أقر بأنه غصب حفنه من تراب أو حبة من قمح أو أي شيء من هذا القبيل لا يصح لأن المقر به لا يلزمه تسليمه إلى المقر له⁽²⁾ .

شروط الصيغة :

يشترط في الصيغة أن تكون منجزة مثبتة للحق على سبيل اليقين والجزم وأن تكون أمام القاضي ، إن كانت تتعلق بحد من حدود الله الخالصة .

(1) تكملة فتح القدير ج6 ص 306 ، حاشية الدسوقي ج3 ص 398 ، المهذب ج2 ص 344 ، المغنى لابن قدامه ج5 ص 141 ، الفقه الإسلامي أ0د/ الزحيلي ج6 ص 631 .

(2) القضاء في الفقه الإسلامي ، أ0د/ رأفت عثمان ص 155 .

وتتحقق الصيغة قول المقر لفلان على كذا⁽¹⁾.

المبحث الثالث

الإقرار في الأموال

يصح الإقرار بالأموال سواء كان المال عيناً من الأعيان أم ديناً ثابتاً في الذمة ، سواء كان المقر به معلوماً أم مجهولاً باتفاق بين الفقهاء .

لأن جهالة المقر به لا تمنع صحة الإقرار ، لأن الحق قد يلزم الإنسان مجهولاً بأن أتلف مالا لا يدري ما قيمته ، أو يطالب بتعويض جنائية على أعضاء الإنسان لا يعلم مقداره فلا تمنع الجهالة صحة الإقرار وعلى ذلك يصح أن يكون المقر على شئ أو حق فيلزمه مجهولاً ، ثم يطالب ببيان المجهول ليتمكن الغير من استيفائه فإن لم يبين أجبره القاضى على البيان بالحبس ونحوه .

هذا بخلاف جهالة المقر فإنها تفسد الإقرار لجهالة المقضى عليه بوجوب دفع الحق إلى صاحبه ، فلا يتمكن المقر له من المطالبة فيصبح الإقرار عدم الفائدة⁽¹⁾ .

وتظهر هذه الأحكام في المسائل التالية :-

1- في الغصب :

أ- إذا أقر أنه غصب من فلان مالا فالإقرار صحيح ويلزمه البيان لأن الغصب لا يرد إلا علماهو مال له قيمة .

ب- إذا أقر بأنه غصب شاة أو ثوباً ، فيصدق في بيان كون ذلك سليماً أو معيباً لأن الغصب يقع على حسب ما يصادف الشخص عادة سواء كان سليماً أو معيباً .

ج- لو قال : غصب داراً يصدق سواء كانت الدار في بلدة قريبة أم بعيدة ويصدق في بيان مكان الدار ، لأن أبهم المكان فكان القول قوله في بيان المكان ويلزمة تسليم الدار إلى المغصوب منه إن قدر على التسليم ، وإن عجز عن التسليم بأن خربت الدار ، فالقول قول المقر عد أبي حنيفة أبي يوسف ويضمن العقار عندهما .

العلة : لأنه غير مضمون القيمة بالغصب ، وإنما هو مضمون الرد ، لأن معنى الغصب إزالة يد المالك عن ماله بفعل في المال أم يوجد في العقار .

وعند محمد : يضمن قيمة الدار ، لأن العقار عنده مضمون الرد إن كان موجوداً ومضمون القيمة أيضاً إن كان هالكا لأن الغصب إزالة يد المالك عن ماله والفعل في المال ليس بشرط وقد تحقق هذا المعنى بإبعاد يد المالك على العقار⁽¹⁾ .

وخلافهم هذا راجع إلى اختلافهم في ضمان العقار المغصوب بالهلاك مثاله إذا غصب عقاراً فهلك بأفة سماوية كنزول سبيل ويده على العقار .

فقال الشيخان : لا يضمنه لعدم تحقق الغصب بإزالة اليد لأن العقار في محل بلا نقل .

وقال محمد : يضمنه لتحقيق إثبات اليد الغاصبة التي يترتب على ثبوتها زوال يد المالك لاستحالة اجتماع اليدين على محل واحد في حالة واحدة

(1) فتح القدير ج2 ص 306 ، حاشية الدسوقي ج3 ص 398 المذهب ج1 ص 344 ، المغنى لابن قدامة ج5 ص 141 .

(1) الفقه الإسلامي ج6 ص 633 .

(1) بدائع الصنائع ج7 ص 215 ، تكملة فتح القدير ج6 ص 286 المبسوط ج17 ص 185 .

2- فإذا هدمه الغاصب بقعله كان عليه الضمان باتفاق لأن ما فعله إتلاف والعقار يضمن بالاتلاف (2).
في المكيال والميزان : لو قال المقر " على مد حنطة أو رطل شعير " بيانه بحسب مد البلد أو رطل البلد ، ومقالة في لموزون والمعدود لو قال لفلان على ألف درهم فهو على ما يتعارفه الناس في الوزون والعد في المعدود.

المبحث الرابع

الاستثناء في الإقرار

الاصل في الاستثناء : تكلم بالباقي بعد الثنيا ، والاستثناء صحيح بغير خلاف فهو ثابت في لغة العرب ، وورد في الكتاب والسنة ما يؤيد ذلك .
قال الله تعالى : (فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عام) (1) .
المعنى : لبث فيهم تسعمائة وخمسين سنة ، فهذا استثناء الأقل من الأكثر وقوله تعالى (فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس) (2) .
وقوله تعالى : (إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين) (3) .
وهذا استثناء الأكثر لأن الذين ابتعوا أكثر العباد .

وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - في الشهيد : يكفر عنه خطاياه كلها إلا الدين (4) .
فإذا أقر رجل بشئ واستثنى منه كان مقرا بالباقي بعد الاستثناء فإذا قال على مائة إلا عشرة كان مقرا بتسعين ولذا قالوا في الاستثناء أنه تكلم بالباقي بعد الثنيا .
ولا يصح الاستثناء إلا أن يكون متصلا بالكلام السابق بأن يتصل المستثنى منه بحيث يعد كلاماً واحدا عرفاً ، قال عليه الصلاة والسلام من حلف وقال إن شاء الله متصلاً بيمينه فلا حث عليه شرط الاتصال في المشيئة وأنها استثناء وأن الأصل لزوم الإقرار - إلا أن القدر المستثنى يبطل بالاتصال لأن الكلام لا يتم إلا باخره ، فإذا أنقطع الكلام فقد تم ولا يعتبر الاستثناء بعده .
أنواع الاستثناء :

1- القليل من الكثير :

" إذا قال المقر " على عشرة دراهم إلا ثلاثة دراهم يلزمة سبعة ، لأن الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا كأنه قال : لفلان على سبعة ، لأن الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا كأنه قال لفلان على سبعة دراهم . وكذا لو قال لفلان على ألف درهم سوى دراهم يلزمة ما عدا المستثنى لأي سوى من ألفاظ الاستثناء .

2- استثناء الكثير من القليل :

إذا قال المقر لفلان على شعرة دراهم
وروى عن أبي يوسف أنه لا يصح وعليه عشرة والصحيح جواب ظاهر الرواية لأن المنقول عن أئمة اللغة أن الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا وهذا المعنى كما يوجد في استثناء القليل من الكثير يوجد في استثناء الكثير من القليل .

(2) المراجع السابقة .

(1) الفقه الإسلامي ج6 ص 633 .

(2) سورة العنكبوت آية (14) .

(3) سورة ص آية (72) .

(4) رواه مسلم والترمذي والنسائي عن أنس : التاج الجامع للأصول ج4 ص 297 .

إلا أن هذا النوع من الاستثناء غير مستحسن عند أهل اللغة لأنهم إنما وضعوا الاستثناء لحاجاتهم إلى استدراك الغلط ومثل هذا الغلط يندر وقوعه غايه الندرة فلا حاجة إلى استدراكه لكنه يحتمل الوقوع في الجملة فيصح .

3- استثناء الكل من الكل :

وهذا النوع من الاستثناء باطل بأن يقول " لفلان على ألف درهم إلا ألف درهم " يلزمة ما أقر به ويبطل الاستثناء ويكون ما ذكره رجوعاً عن الإقرار ولا استثناء حقيقة ، والرجوع عن الإقرار في حقوق العباد باطل .

4- الاستثناء من المستثنى منه :

لو قال المقر له على ألف درهم إلا عشرة دراهم إلا درهما فاستثناء العشرة صحيح ، واستثناء الدرهم من العشرة صحيح ، لأن الاستثناء من المسائتي منه صحيح ويلحق به .

ودليلة قوله تعالى : (ءال لوط إنا لمنجوهم أجمعون إلا امرأته) استثنى آل لوط من الهالكين ثم استثنى امرأته من الناجين فكانت من الهالكين ⁽¹⁾ .

الثانية : إن كان المستثنى مما لا يثبت في الذمة لا يصح الاستثناء .

مثالة : أن يقول المقر : " لفلان على عشرة دراهم إلا ثوباً " .

قالوا إنه لا مجانسة بين الثوب والدرهم فلا يتحقق معنى الاستثناء فيكون المستثنى مجهولاً وجهالة المستثنى توجب جهالة المستثنى منه فلا يصح الاستثناء .

وقال محمد : لا يصح فيهما أى فى الوجهين وهو القياس وبه قال زفر وأحمد

وعلى ذلك : أن المستثنى غير داخل فى الإيجاب والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل تحت المستثنى منه ، فلا يكون استثناء لأنه لا يتصور فى خلاف الجنس فغير الجنس المذكور ، ليس بداخل فى الكلام .

وقال الشافعي : يصح فى الوجهين وبه قال مالك .

وعلة ذلك : أنهما أى المستثنى والمستثنى منه – اتخذا جنسا من حيث المالية فانتهى المانع بعد تحقيق المقتضى وهو التصرف اللفظي .

5- الاستثناء أو التعليق بمشيئة الله :

ومن أقر بحق وقال إن شاء الله ، كان يقول لفلان على مائه درهم إن شاء الله لم يلزمه شئ سواء قدم الألف على المشيئة أم لا لأنه لم يجزم الالتزام بل علقه بالمشيئة ومشيئة الله مغيبة عنا ولأن الاستثناء بمشيئة الله ، أما إبطال كما هو مذهب أبى يوسف أو تعليق على رأى محمد وثمره الخلاف تظهر فيما إذا قدم المشيئة فقال إن شاء الله أنت طالق ، عند أبى يوسف : لا يقع الطلاق لأنه إبطال وعند محمد : يقع لأنه تعليق – وكيفهما كان لا يلزمة الإقرار لأن الأقرار إخبار عما سبق والتعليق إنما يكون بالنسبة إلى المستقبل وبينهما منافاة ⁽²⁾ .

ويشترط فى صحة الإقرار بالنسب ما يلى :-

1- أن يكون المقر به مجهول النسب ، فإن كان معروف النسب من غيره لم يصح استلحافه بالإقرار لأن النسب الثابت من شخص لا ينتقل إلى غيره .

2- أن يكون المقر به محتمل الثبوت من نسب المقر ، فلا يكذبه الحس ظاهراً أو لا ينازع فيه منازع بأن يكون فى سن يمكن أن يكون منه بحيث يولد مثله لمثله فلو كان المقر به فى سن لا يتصور كونه

(1) الاختيار لتعليل المختار ص 191 .

(2) العناية على الهداية ص 314 ، 315 الفقه الإسلامى ج6 ص 632 .

منه أو كان المقر مقطوع الذكر والانثيين من زمن يتقدم على زمن بدء الحمل لم يثبت نسبه ، لأنه إذا نازعة فيه غيره تعارض الإقراران ، فلم يكن إلحاقه بأحدهما أولى من الآخر .

3- أن يصدق المقر له في إقراره إذا كان يستطيع التعبير عن نفسه لأن الولد له حق في نفسه ، فإن كان لا يستطيع التعبير لم يعتبر تصديقه .

4- إلا يكون فيه حمل النسب على الغير سواء كذبه المقر له لم صدقه لأن إقرار الإنسان حجة قاصرة على نفسه لا تتعداه على غيره ، لأن على غيره شهادة أو دعوى وشهادة الفرد فيما يطلع عليه الرجال غير مقبولة والدعوى المفردة ليست بحجة .

وبناء على ما سبق يمكن القول بجواز إقرار الرجل بالوالدين والولد والزوجة كأن يقول هذا أبنى أو أنا أبوه لأنه إقرار على نفسه .

ويشترط أن تكون الزوجة خالية عن زوج وعن عدة وأن يخلو المقر عن أخت الزوجة أو عمتها وأخالتها وإلا يكون في عصمته أربع سواها .

وكذلك المرأة يقبل إقرارها بالوالدين والزوج ، لأنه إقرار على نفسها ولا يقبل إقرارها بالولد ، لأنه يتوقف على تصديق الزوج ، أو شهادة القابلة ، والأصل في ذلك أن صحة هذا الإقرار تصديق المفسر لصير حجة في حقه فيلزمهما الأحكام بتصادفهما وتصور كونه منه لئلا يكذب العقل ، وأن لا يكون معروف النسب من غيره لئلا يكذب الشرع .

وأما المرأة فتحتاج إلى تصديق الزوج ، لأن فيه تحميل النسب عليه فلا يقبل تصديقه أو بينه وهي شهادة القابلة .

وإذا صح الإقرار بالنسب لإنسان شارك الورثة في الميراث ، لأنه إذا ثبت نسبه من المقر صار كالوارث المعروف فيشارك ورثة المقر⁽¹⁾ .

ثانياً : الإقرار بتحميل النسب على الغير يصح كما يصح الإقرار به على النفس عند الشافعية ومن وافقهم ، ولا يثبت عند الحنفية إلا ببيئة بواسطة رجلين أو رجل وامرأتين لأن في الإقرار حمل النسب على غيره فاعتبر بمثابة الشهادة فلزم فيه العدد المذكور ويثبت له الإرث إن لم يكن هناك وارث غيره .

وقال مالك : لا يثبت النسب إلا بإقرار اثنين لأنه حمل النسب على الغير يعتبر فيه العدد كالشهادة . وبناء على ما قاله الحنفية : نلاحظ أن الوارث المعروف أولى بالميراث من المقر له لأنه لما لم يثبت نسبه منه ، ثم يزاحم الوارث المعروف .

فلو أقر شخص بأخ وله عمة أو خلة فالإرث للعممة والخالة ، ولا شئ للمقر له لأنهما وارثان بيقين ، فكان حقهما ثابت بيقين فلا يجوز إبطاله يصرف الإرث إلى غيرهما .

وإن لم يكن للمقر له وارث معروف : استحق المقر له ميراثه لأنه له ولاية التصرف في مال نفسه عند عدم الوارث فيستحق جميع المال ، وإن لم يثبت نسبه منه ، لما فيه من حمل النسب على الغير .

(1) الاختيار لتعليل المختار ص 198 ، 199 - مع المراجع السابقة .

المبحث الخامس الرجوع عن الإقرار

الرجوع عن الإقرار إما أن يكون في حقوق الله الخالصة وإما أن يكون في حقوق الأدميين . ولقد صرح بعض الفقهاء إلى صحة الرجوع عن الإقرار في حقوق الله الخالصة فللمقر بالزنا أن يرجع عن إقراره بل صرحوا له بعدم الإقرار من أول الأمر سترًا على نفسه ويجب عليه أن يتوب بينه وبين الله تبارك وتعالى لقوله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أتى من هذه القادورات شيئًا فليستتر بستر الله تعالى ، ومن أبدى لنا صفحته أقمنا عليه الحد .

ولقد خير الفقهاء كما قدمنا - الشاهد في الحدود وخاصة في جريمة الزنا ، بين الشهادة حسبة لله تعالى وأن يستتر - والستر أولى - لقوله - صلى الله عليه وسلم - من ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة .

وكذلك يسن القاضي أن يعرض للمقر بالزنا بالرجوع بأن يقول لمقر " لعلك قبلت ، أو فأخذت ، أو باشرت في غير الفرج ، وما مائل هذا ، لأنه - صلى الله عليه وسلم - عرض لماعز عندما أعترف له بالزنا - بالرجوع - حيث قال له لعلك قبلت لعلك لمست ، لعلك فأخذت ، أبك جنون ؟

أما في التعريض للمقر بالسرقة بالرجوع فيقول القاضي للمقر بالسرقة مثلاً لعلك أخذت المسروق من غير حرزه أو أنك ظننته مالك ولا يقول له أرجع عن إقرارك لئلا يكون أمراً له بالكذب على احتمال أنه صادق في إقراره ، والرجوع فيه يكون في رفع العقوبة لا في ضياع المال بالرجوع لأن المال حق الإنسان والعقوبة حق الله تعالى ، وحق الله مبنى على المسامحة أما حد القذف فلأن فيه حقاً لله تعالى وحقاً للعبد على اختلاف بين الفقهاء في المذهب منهما فلا يجوز للقاضي أن يعرض فيه للمقر بالرجوع لأنه يؤدي إلى ضياع حق العبد الذي طعن في شرفه وعرضة ، وهو محتاج إلى دفع العار الذي التصق به .

لأنه بالإقرار ثبت حق الغير والمقر به يجب شرعاً أدائه إليه وهو لا يسقط بإسقاط صاحبه ، لهذا يحتاج الأمر إلى رضاه . وصفوة القول أنه إن كان الإقرار في حقوق الأدميين فإن هذه الحقوق تثبت للمقر له سواء كانت مالا أو عقوبة كحد القذف ، وذلك لأن حد القذف حد اجتماع فيه حقان ، حق الله وحق العباد ، وحق الله فيه غالب عند الحنفية بخلاف الشافعية الذين يرون أن حق العبد فيه غالب وبناء عليه فإنه لا يصح الرجوع فيها بعد الإقرار بها لأنها حقوق تثبت للمقر له فلا يملك المقر إسقاطها بغير رضا المقر له .

الفصل الثالث

في اليمين والرد والنكول

المبحث الأول

في اليمين في الدعاوى

تعريف اليمين: في اللغة له معان ثلاثة: أولها: القوة ومنه قوله تعالى: (لأخذنا منه باليمين)¹. أي القوة وثانيها: اليد اليمنى وقد سمي العضو باليمين لوفور قوته، ثالثها: القسم والحلف وأطلقت اليمين على الحلف، لأن الناس كانوا إذا تحالفوا يأخذ كل واحد منهم بيمين صاحبه.

وفي الشرع: هي عقد قوي به عزم الحالف على الفعل أو الترك. وهي بمعناها العام: تأكيد الكلام إثباتاً أو نفياً بذكر اسم الله أو صفة من صفاته. وتعرف اليمين القضائية بأنها: تأكيد ثبوت الحق أو نفيه أمام القاضي بذكر اسم الله أو بصفة من صفاته⁽²⁾.

دليل مشروعية اليمين: اليمين في ذاتها مشروعة بآيات كثيرة في القرآن الكريم منها قوله تعالى: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان)⁽³⁾. ولقد أقسم الله بأشياء من خلقه إظهاراً لقدرته تعالى فقال عز وجل (والضحى والليل إذا سجى) وقوله تعالى (والنجم إذا هوى) وأقسم بذاته فقال: (وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون).

كما أمر نبيه - صلى الله عليه وسلم - بالقسم للتدليل على صدق ما أوحى إليه قال تعالى: (ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق).

ومن السنة دلت على مشروعية اليمين أحاديث كثيرة منها: قوله - صلى الله عليه وسلم - "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه" وفي رواية للبيهقي: "ولكن البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه"⁽¹⁾.

وقوله - صلى الله عليه وسلم - ألا أن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت " قال عمر - رضى الله عنه - فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها ذاكراً ولا أثراً⁽²⁾. أي حاكياً وقوله - صلى الله عليه وسلم - "من حلف بغير الله فقد أشرك وفي لفظ فقد كفر"⁽³⁾. ولأن هذا النوع من الحلف لتعظيم غير الله، وهو المحلوف به وهذا التعظيم لا يستحقه إلا الله تعالى.

من هذه الأحاديث نستخلص الآتي: -

- 1- أن الحلف لا يكون إلا بالله.
- 2- وجوب اليمين على المنكر في الدعوى أمام القضاء لإثبات الحق.

(1) سورة الحاقة آية (45).

(2) الروض المربع ص 464 ، بدائع الصنائع ج6 ص 225 ، فتح القدير ج6 ص 153.

(3) سورة المائدة آية (89).

(1) رواه البيهقي وبعضه في الصحيحين ، سبل السلام ج4 ص 132 .

(2) المرجع السابق .

(3) نصب الراية لتخريج أحاديث الهداية ج 3 ص 295 .

المبحث الثاني

صيغة اليمين

اتفق الفقهاء على أن اليمين المنعقدة هي القسم بالله تعالى، أو بصفة من صفاته مثل: والله، ورب العالمين، والحي الذي لا يموت، ومن نفسي بيده، وعزة الله وعظمته، ولا يجوز الحلف بغير الله تعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم: «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفاً، فليحلف بالله أو ليصمت» قال عمر: «فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ذكراً ولا أنثراً» (1) أي حاكياً. ولقوله عليه السلام أيضاً: «من حلف بغير الله فقد أشرك» وفي لفظ: «فقد كفر» (2) وقوله فيما رواه النسائي: «لا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون»⁸⁰⁹ ولا تتعد اليمين اتفاقاً إذا قال: إن شاء الله تعالى، بشرط كونه متصلاً باليمين من غير سكوت عادي؛ لأن الاستثناء يزيل حكم اليمين، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من حلف، فقال: إن شاء الله، لم يحنث» صفة اليمين (متى يحلف على البت ومتى يحلف على نفي العلم):

قد اتفق الفقهاء على أن الحالف يحلف على البت والقطع على فعل نفسه، سواء في حال الإثبات أم النفي، فيقول مثلاً: والله ما بعثت أو ما اشتريت، أو لقد بعثت أو اشتريت؛ لأن الإنسان أعلم بأحواله وأفعاله، فتكون يمينه حجة قاطعة. فالأيمان كلها على البت والقطع، إلا على نفي فعل الغير، فإنها على نفي العلم؛ لحديث ابن عباس: «أن النبي صلى الله عليه وسلم استحلف رجلاً، فقال له: قل: والله الذي لا إله إلا هو، ماله عليك حق» وروى الأشعث بن قيس: «أن رجلاً من كُندة ورجلاً من حضرموت اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض من اليمن، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن أرضي اغتصبنيها أبو هذا، وهي في يده، قال: هل لك بينة؟ قال: لا، ولكن أحلفه، والله العظيم ما يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه، فتهياً الكندي لليمين»

اليمين بالطلاق أمام القاضي: قال جمهور الفقهاء على المفتي به عند الحنفية: إن اليمين بالطلاق لإثبات الحقوق وإنهاء الخصومات أمام القاضي حرام؛ لأن اليمين لا تكون إلا بالله، ولأن القسم لتعظيم المقسم به، ولا يجوز تعظيم غير الله. فإن طلبه الخصم، لم يجبه القاضي؛ لأنه حرام. وأجاز متأخرو الحنفية الحلف بالطلاق إذا طلبها الخصم وألح فيها، أو كان الحالف لا ينزجر إلا بها، لفساد الزمان، وقلة المبالاة بالحلف بالله تعالى

المبحث الثالث

شروط اليمين وأنواعه

أولاً: شروط اليمين: اشترط فقهاء الحنفية سبعة شروط في اليمين القضائية

- 1- أن يكون الحالف بالغاً عاقلاً مختاراً، فلا يحلف الصبي والمجنون.
- 2- أن يكون المدعى عليه منكر حق المدعي: فإن كان مقراً فلا حاجة للحلف أن يطلب الخصم اليمين من القاضي.
- 3- أن يطلب الخصم اليمين من القاضي وأن يوجهها القاضي إلى الحالف: لأن النبي صلى الله عليه وسلم استحلف رُكانة بن عبد يزيد في الطلاق، فقال: «الله ما أردت إلا واحدة» فقال رُكانة: «الله ما أردت إلا واحدة» (1).

⁸⁰⁹ «الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي» (8/ 6066):

- 4- أن تكون اليمين شخصية: فلا تقبل اليمين النيابة، لصلتها بذمة الحالف ودينه، فلا يحلف الوكيل أو ولي القاصر، ويوقف الأمر حتى يبلغ.
- 5- ألا تكون في الحقوق الخالصة لله تعالى كالحدود والقصاص.
- 6- أن تكون في الحقوق التي يجوز الإقرار بها: للحديث المتقدم: «واليمين على من أنكر» فلا تجوز اليمين في الحقوق التي لا يجوز الإقرار بها، فلا يحلف الوكيل والوصي والقيم؛ لأنه لا يصح إقرارهم على الغير واشترط أبو حنيفة أيضاً أن يكون المدعى به مما يحتمل البذل، فلا تصح اليمين في النسب والنكاح والرجعة والفيء في الإيلاء ونحوها
- 7- العجز عن البينة أو فقدها: ألا تكون البينة حاضرة في مجلس القضاء فلا يصح تحليف المدعى عليه عند أبي حنيفة، عملاً بالحديث "البينة على المدعى واليمين على من أنكر فإن حق المدعى في اليمين مرتب على عجزه عن إقامة البينة. وأجاز الصحابان التحليف حينئذ. ودليلهم على هذا الشرط الحديث السابق: «بَيِّنْكَ وَإِلَّا فِيمِينَهُ» فاليمين حق المدعى وواجبه على المدعى عليه، ولأنه يحتمل أن يقر المدعى عليه فيستغنى المدعى عن إقامة البينة،

أنواع اليمين:

يمين المدعى عليه: يمين المدعى عليه: وتسمى اليمين الأصلية أو الواجبة أو الدافعة أو الرافعة. وهي التي يحلفها المدعى عليه بطلب القاضي بناء على طلب المدعى لتأكيد جوابه عن الدعوى. وهي حجة المدعى عليه للحديث المتقدم: «ولكن اليمين على المدعى عليه»

يمين المدعي: وهي اليمين المردودة على المدعي عند غير الحنفية

المبحث الرابع

النكول عن اليمين ورده

القضاء بالنكول:

إذا نكل المدعى عليه عن اليمين، فإنه يقضى عليه بالمال، لكن ينبغي للقاضي أن يقول له: (إني أعرض عليك اليمين ثلاث مرات، فإن حلفت وإلا قضيت عليك) لاحتمال خشية القضاة ومهابة المجلس في المرة الأولى.

ودليلهم على القضاء بالنكول: أن القاضي شريح قضى على رجل بالنكول، فقال المدعى عليه: أنا أحلف، فقال شريح: مضى قضائي. وكانت لا تخفي قضاياه على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أنه أنكر عليه منكر، فيكون إجماعاً منهم على جواز القضاء بالنكول. وقضى عثمان على ابن عمر بالنكول. ورد عليه عبداً معيباً اشتراه منهم حينما نكل، ولأنه ظهر صدق المدعي في دعواه عند نكول المدعى عليه، فيقضى له، كما لو أقام البينة.

مجال القضاء بالنكول في الأموال

«وأما القضاء بالنكول في غير المال: (كنكاح وطلاق ولعان وحد وقصاص، ووصاية، ووكالة) فلا يقضى فيه بالنكول.

لكن المفتى به عند الحنفية هو قول الصحابين بأنه يقضى بالنكول إلا في الحدود والقصاص واللعان؛ لأنه في معنى الحد، ويقضى على السارق لأجل المال بالنكول، فيضمن المال المسروق، ولا تقطع يده»

الأثر المترتب على اليمين أمام القاضي:

«يترتب على حلف اليمين من المدعى عليه: إنهاء النزاع بين المتداعيين وسقوط الدعوى، وكذا انقطاع الخصومة والمطالبة في الحال، لا مطلقاً، بل مؤقتاً إلى غاية إحضار البينة في رأي الحنفية، فلا تبرأ ذمة المدعى عليه من الحق، وتظل مشغولة به إلى أن يتمكن المدعي من إثبات دعواه بوسيلة أخرى من وسائل الإثبات.

ما تجوز فيه اليمين من الحقوق:

هناك حقوق يجوز فيها اليمين بالاتفاق، وحقوق لا يجوز فيها اليمين اتفاقاً، وحقوق مختلف فيها على التفصيل التالي

1 - اتفق فقهاء الحنفية على عدم جواز التحليف في حقوق الله تعالى المحضة، سواء أكانت حدوداً كالزنا والسرقة وشرب المسكرات، أم عبادات كالصلاة والصوم والحج والنذر والكفارة، إلا إذا تعلق بها حق مالي لآدمي فيجوز؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات، ولا يقضى فيها بالنكول عند الحنفية والحنابلة؛ لأنه بذل عند أبي حنيفة، وإقرار فيه شبهة العدم عند أحمد والصاحبين، والحدود لا تحتل البذل، ولا تثبت دليل فيه شبهة؛ لأن النكول قائم مقام الإقرار، ولا يجوز إقامة الحد بما يقوم مقام غيره. ولأنه لو أقر، ثم رجع قبل منه وخلي من غير يمين، فلأن لا يستحلف مع عدم الإقرار أولى، ولأنه يستحب ستره.

وأما أن العبادات لا يستحلف فيها، فلأنها علاقة بين العبد وربّه، فلا يتدخل فيها أحد، قال الإمام أحمد: «لا يحلف الناس على صدقاتهم» فإذا ادعى الساعي الزكاة على رب المال وأن الحول قد تم وكمل النصاب، فالقول عند أحمد قول رب المال من غير يمين. ونقل عن أبي يوسف ومحمد أنه يستحلف؛ لأنها دعوى مسموعة، فتشبه حق الآدمي. أما إذا تعلق بالحدود وغيرها حق مالي للعباد كالمال في السرقة، فيجوز فيها الاستحلاف.

واتفق الفقهاء أيضاً على جواز اليمين في الأموال، وما يؤول إلى المال، فيحلف المدعى عليه إثباتاً ونفيّاً، لقوله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً، أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذابٌ أليم} [آل عمران: 77/3] وللحديث السابق عند الجماعة: «لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى أناس دماء قوم وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه».

3 - واتفق الفقهاء على جواز التحليف في الجنايات من قصاص وجروح وفي بعض مسائل الأحوال الشخصية.

والمفتى به عند الحنفية هو قول الصاحبين جواز التحليف إلا في الحدود والقصاص واللعان

المبحث الرابع القسامة

دعوى الدم والقسامة ودورها في إثبات الدعوى

مفهوم القسامة:

في اللغة: بفتح القاف والسين من غير تشديد وهي مشتقة من القسم وهو اليمين. وشرعاً: الإيمان المكررة في دعوى القتل، وهذه الإيمان تقسم إما على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم أو على المدعى عليهم الدم، وخص القسم على الدم بالقسامة. دليل مشروعتها:

روى الجماعة عن سهل بن أبي حثمة قال: «انطلق عبد الله بن سهل، ومحبيصة بن مسعود إلى خيبر، وهو يومئذ صلح، فتفرقا، فأتى محبيصة إلى عبد الله بن سهل، وهو يتشطح في دمه (3) قتيلا، فدفنه، ثم قدم المدينة، فانطلق عبد الرحمن بن سهل، ومحبيصة وحويصة ابنا مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم، فقال: كبر كبر (4)، وهو أحدث القوم، فسكت، فتكلما، قال: أتخلفون وتستحقون قاتلكم، أو صاحبكم (5)؟ فقالوا: وكيف، نحلف، ولم نشهد ولم نر؟ قال: فتبرئكم يهود بخمسين يمينا (1)، فقالوا: كيف نأخذ أيمان قوم كفار؟ فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده» (2).

وفي لفظ آخر: «أتخلفون خمسين يمينا، وتستحقون دم صاحبكم» أي يقتص لكم من قاتله حكم القسامة:

اختلف الفقهاء في حكم القسامة: فذهب جمهور الفقهاء إلى أن القسامة مشروعة وأنه يثبت بها القصاص أو الدية إذا لم تقتزن الدعوى ببينة أو إقرار، ووجد اللوث.

وذهب الحكم بن عيينة، وأبو قلابة، وإبراهيم بن عليه، وسليمان بن يسار، ومسلم بن خالد، وعمر بن عبد العزيز في رواية عنه، إلى عدم الأخذ بالقسامة، وعدم وجوب العمل بها؛ لأنها مخالفة لأصول الشرع المجمع على صحتها.

واستدلوا: بأن الأصل أن البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه، وبأن الإيمان لا تأثير لها في إثبات الدماء.

وبأن الشرع ورد بأنه لا يجوز الحلف إلا على ما علم قطعاً أو شوهد حساً وبأنه – صلى الله عليه وسلم – لم يحكم بها وإنما كانت حكماً جاهلياً فتلطف بهم رسول الله – صلى الله عليه وسلم.

ووجه بطلان دعواهم: ما ورد من أحاديث صحيحة تقرر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، فثبتت الحكم بهذا من الأجوبة الحسنة (1).

حكمة مشروعية القسامة:

شرعت القسامة لصيانة الدماء وعدم إهدارها، حتى لا يهدر دم في الإسلام أو يطل، وكى لا يفلت مجرم من العقاب، قال علي لعمر رضي الله عنهما فيمن مات من زحام يوم الجمعة، أو في الطواف: يا أمير المؤمنين لا يطل دم امرئ مسلم، إن علمت قاتله، وإلا فأعطه ديته من بيت المال. فالشريعة الإسلامية تحرص أشد الحرص على حفظ الدماء وصيانتها وعدم إهدارها، ولما كان القتل يكثر بينما تقل الشهادة عليه؛ لأن القاتل يتحرى بالقتل مواضع الخلوات، جعلت القسامة حفظاً للدماء

الشبهة التي تثبت بها القسامة: اتفق الفقهاء على أن القسامة لا تثبت بمجرد دعوى القتل على المدعى عليهم من دون شبهة.

ذهب الفقهاء إلى أن اللوث من شروط القسامة

واللوث: شبه الدلالة على حدث من الأحداث، ولا يكون بينة تامة يقال: لم يقم على اتهام فلان بالجناية إلا لوث.

واللوث: الجراحات والمطالبات بالأحقاد، وهو في الاصطلاح: أمر ينشأ عنه غلبة الظن بصدق المدعي

تفسير اللوث: فسرته الحنفية ووافقهم الحنابلة في رواية عن أحمد بأنه العداوة الظاهرة كنحو ما كان بين الأنصار وأهل خيبر وما بين القبائل والأحياء وأهل القرى الذين بينهم الدماء والحروب.

(1) سبل السلام ج4 ص 256 ، نيل الأوطار ج7 ص 186 .

مثل أن يشهد شاهد واحد على إقرار المقتول قبل أن يموت أن فلانا قتلني أو يشهد شاهدان على عداوة بينهما أو تهديد له منه أو نحو ذلك ومن اللوث التلطخ⁽²⁾

وذهب الحنفية إلى أنه إذا وجد القتل في محلة وبه أثر القتل من جراحة أو أثر ضرب أو خنق ولا يعلم من قتله استحلف خمسون رجلاً من أهل المحلة يتخيرهم الولي يقول كل واحد منهم: بالله ما قتلته ولا علمت له قاتلاً ولا يشترطون لوجوب القسامة أن يكون هناك علامة القتل على واحد بعينه، أو ظاهر يشهد لمدعي القتل من عداوة ظاهرة أو شهادة عدل أو جماعة غير عدول أن أهل المحلة قتلوه

ما يجب بالقسامة:

لا خلاف بين الفقهاء في حجية القسامة، ووجوب الدية على عواقل المدعى عليهم إذا كان القتل خطأ، وإنما الخلاف بينهم فيما يجب بها إذا كان القتل المدعى به عمداً اتفق فقهاء الحنفية على أن القسامة لا يجب بها القصاص، في (العمد) ومن باب الأولى شبه العمد والخطأ، وإنما تجب الدية حالة في مال (المتهم)، لما يلي:

أولاً: لخبر البخاري: «إما أن تدوا صاحبكم، أو تأذنوا بحرب» فقد أطلق النبي صلى الله عليه وسلم إيجاب الدية، ولم يفصل بين العمد والخطأ.

ثانياً: لو صلحت أيمان القسامة لإيجاب القصاص لذكره النبي صلى الله عليه وسلم.

ثالثاً: لأن القسامة حجة ضعيفة، مشتملة على شبهة؛ لأن اليمين تفيد غلبة الظن، فلا توجب القصاص.

رابعاً: يحتاط لأمر الدماء التي لا تراق بالشبهة، كالأثبات بالشاهد واليمين، لأن الحدود تدرأ بالشبهات.

من يبدأ باليمين في القسامة:

اختلف العلماء في كيفية القسامة على مذهبين:

المذهب الأول: لجمهور الفقهاء وهم المالكية والشافعية والحنابلة وربيعه، والليث، وأبو الزناد فقالوا: إن الأيمان في القسامة توجه إلى المدعين، فيكلفون حلفاً ليثبت مدعاهم ويحكم لهم به، فإن نكلوا عنها وجهت الأيمان إلى المدعى عليهم

ويرى الحنفية: أنه يحلف المدعى عليه، ولا يمين على المدعين فيحلف خمسون رجلاً من أهل القرية ما قتلناه ولا علمنا له قاتلاً، فتوجيه تلك الأيمان إلى المدعى عليهم ابتداءً، فإن حلفوا لزم أهل المحلة الدية

لأن سبب وجوب الدية هو التقصير في النصر، وعدم حفظ موضع القتل، فتجب عليهم. وقال الحنفية: إذا نكل من وجبت عليه القسامة من أهل المحلة حبس حتى يقر أو يحلف، وكذا إن نكل جميع المحلفين

وهل تجب القسامة على الصبي والمجنون والمرأة:

لا خلاف بين جمهور الفقهاء في أن أيمان القسامة توجه إلى الرجال الأحرار البالغين العقلاء من عشيرة المقتول الوارثين له، كما لا خلاف بينهم في عدم توجهها إلى الصبيان والمجانين. وإنما الخلاف بينهم في توجيهها إلى النساء أو غير الوارثين من العصبه.

(2) سبل السلام جـ 2 ص 254 ، مجمع الأنهر ج 2 ص 678 .

لا تجب القسامة على الصبي أو المجنون في أي موضع وجد القتل، سواء وجد في غير ملكه، أو في ملكه، لكن يشتركان في الدية مع العاقلة فيدخل معها إن وجد القتل في ملكهم؛ لأن وجوده في ملكهم كمباشرتهم القتل، والصبي والمجنون مؤاخذان بضمان الأفعال المالية.

هل تدخل المرأة في القسامة والدية: لا تدخل في القسامة والدية في قتل يوجد في غير ملكها. أما إن وجد في دارها أو في قرية لها، ليس بها غيرها، فعليها القسامة؛ لأنها أهل لليمين، فتستحلف وتكرر عليها الأيمان في قول الطرفين (أبي حنيفة ومحمد). وقال أبو يوسف: لا قسامة عليها، وإنما على عاقلتها؛ لأنها ليست من أهل النصرة.

وتدخل المرأة مع العاقلة في الدية في هذه المسألة، استثناء من نظام العاقلة.

ولا يحلف ولي القتل مع أهل المحلة، ولا يقضى له بالجناية بيمينه؛ لأن اليمين شرعت للدفع، لا للاستحقاق.

والقسامة والدية تجبان على الأقرب من عاقلة من وجد القتل فيهم، فرب الدار وقومه أخص، ثم أهل المحلة، ثم أهل المصر. وقوم الشخص أو قبيلته يرتبون أيضا: الأقرب فالأقرب.

ولا يدخل عند أبي حنيفة ومحمد السكان (كالمستأجرين والمستعيرين) مع الملاك في القسامة؛ لأن المالك هو المختص بنصرة البقعة دون السكان. وقال أبو يوسف: هي عليهم جميعا؛ لأن ولاية التدبير تكون بالسكنى وبالمالك»

المبحث الثاني

إثبات النسب بقول القائف

القائف جمعه قافة: وهم قوم يعرفون الأنساب بالشبه، والقائف: من عرفت منه معرفة الأنساب بالشبه، وتكررت منه الإصابة. والأصل في القائف: هو الذي يتبع الآثار والأشباه ويقفوها، أي يتبعها، فهو المتبع للشيء.

هل يجوز إثبات النسب بقول القائف

الأصل عند الحنفية ألا يحكم لأحد المتنازعين في الولد، إلا أن يكون هناك فراش، لقوله عليه الصلاة والسلام: «الولد للفراش» فإن عدم الفراش أو اشتراكا في الفراش، كان الولد بينهما، ولا يعمل بقول القائف، لما يلي:

- 1- أن العمل بالقيافة تعويل على مجرد الشبه، والشبه قد يقع بين الأجانب الذين لا تربطهم صلة القرابة وقد ينفي الشبه بين الأقارب.
- 2- لو أثر الشبه والقافة في إثبات نتاج الإنسان لأثر أيضا في نتاج الحيوان⁽²⁾.
- 3- لو كانت القافة طريقا شرعيا، لما عدل عنها داود وسليمان (عليهما السلام) في قصة الولد الذي ادعته المرأتان، بل حكم به داود للكبرى، وحكم به سليمان للصغرى بالقرينة التي استدل بها من شفقتها عليه بإقرارها به للكبرى ولم يعتبر القافة ولا الشبه⁽¹⁾.

(2) تكملة فتح القدير ج 7 ص 375 .

(1) الحجج القضائية أ. د/ محمود على أحمد ص 250 ، والقضاء في الفقه الإسلامي ص 246

القرائن ودورها في إثبات الدعوى

القرائن: جمع قرينة، وهي الأمانة ودلائل الحال المصاحبة للواقعة المراد إثباتها بحيث يقطع المستدل بأن هذه الأمارات هي سبب العلم اليقيني الذي حصل عنده في هذه الواقعة بالذات دون تردد ولا احتمال⁽¹⁾.

والقرينة: مأخوذة من المقارنة بمعنى المصاحبة وقد تكون دلالتها قوية أو ضعيفة على حسب قوة المصاحبة وضعفها، وقد ترتقي في درجة القطع أو تهبط الى درجة الاحتمال البعيد جداً بحيث يصبح الاحتجاج بها ضعيفاً.

والمرجع في ضابطها الى قوة الذهن والفتنة واليقظة وما يفيضه الله تعالى على عبادة من المواهب. ولهذا جاء تعريفها في مجلة الأحكام العدلية: أن القرائن القضائية هي الأدلة التي يستنبطها القاضي من وقائع الدعوى وأحوالها باجتهاده وإعمال فكرته وهي ترجع في الحقيقة إلى قوة الذهن وبراعة المحامي ووضوح الوقائع وغير ذلك وكل قرينة من هذا القبيل تقبل النقص.

وعرفها أساتذة الشريعة بأنها ما تدل على أمر خفي مصاحب لها بواسطة نص أو اجتهاد أو فهم يفيضه الله تعالى على من يشاء من عباده وهذا التعريف يتضح منه أن للقرينة ثلاثة أركان:

- 1- الأمر الظاهر " الدال " .
- 2- الأمر الخفي الذي يدل عليه الأمر الظاهر وهو المجهول في بادئ الأمر " المدلول " .
- 3- الصلة الموجودة بين الأمر الظاهر وبين الأمر الخفي الذي يتوصل بها إلى معرفة الأمر الخفي وتتضح هذه الصلة إذا توافرت قوة الذهن والفتنة واليقظة وبما يفيضه الله تبارك وتعالى على عبادة من المواهب العقلية⁽²⁾.

عمل الصحابة والتابعين بالقرائن : لقد قضى عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - في امرأة أتت إليه فشكت زوجها وقالت هو من خير أهل الدنيا يقوم الليل حتى الصباح ويصوم النهار حتى يمسي ثم أدركها حياؤها ، فقال عمر - رضى الله عنه - جزاك الله خيراً فقد أحسنت الثناء فلما ولت المرأة ، قال : كعب بن سور ، يا أمير المؤمنين لقد بالغت المرأة إليك في الشكوى ، قال أمير المؤمنين : كيف وما اشتكت ؟ قال كعب : قد اشتكت زوجها فقال عمر : علىّ بها ثم قال لكعب اقض بينهما قال أقضى وأنت شاهد قال عمر لكعب إنك قد فطنت إلى ما لم أفطن له قال كعب : للزوج إن الله يقول لك (فانكحوا ما طاب لكن من النساء مثني وثلاث ورباع) صم ثلاثة أيام وأفطر يوماً عندها وقم ثلاث ليال وبت عندها ليلة ، فقال عمر هذا أعجب من الأول وبعثة قاضياً إلى أهل البصرة .

يقول: الحاكم إذا لم يكن فقيه النفس في الأمارات ودلائل الحال ومعرفة الشواهد أضاع حقوقاً كثيرة على أصحابها وحكم بما يعلم الناس بطلانه ولا يشكون فيه اعتماداً على نوع ظاهر لم يلتفت إلى باطنة وسائر أحواله فهاهنا نوعنا من الفقه لا بد للحاكم منهما:

- 1 - فقه في أحكام الحوادث الكونية.
 - 2- فقه في نفس الواقع وأحوال الناس يميز به بين الصادق والكاذب والمحق والمبطل ثم يطابق بين هذا وهذا فيعطى الواقع حكمه من الواجب ولا يجعل الواجب مخالفاً للواقع⁽¹⁾.
- ولهذا لما قال رجل " لإياس بن معاوية " علمني القضاء قال إياس: القضاء لا يعلم إنما القضاء فهم ولكن قل علمني العلم.**

(1) نظرية الدعوى والإثبات أ0د/ نصر فريد ص 135 .

(2) المراجع السابقة .

(1) مجموعة رسائل بن عابدين ج2 ص 127 .

وهذا هو سر المسألة فإن الله سبحانه وتعالى قال: (وداود وسليمان إذ يحكمان إذ الحرث إذ نفشت فيه غم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما) (2).
فخص سليمان بفهم القضية وعممها بالعلم..

وكذلك كتب عمر الى قاضيه أبي موسى الأشعري في كتابه المشهور " الفهم الفهم فيما أدلى إليك " والذي اختص به إياس وشريح مع مشاركتها لأهل عصرهما في العلم هو الفهم في الواقع والاستدلال بالأمارات وشواهد الحال وهذا الذي فات كثيرا من الناس فأضاعوا كثيرا من الحقوق.
ثم قال ابن القيم: وهل القضاء بالنكول إلا رجوع الى مجرد القرينة الظاهرة التي علمنا بها ظاهرا أنه لولا صدق المدعى لدفع المدعى عليه دعواه باليمين فلما نكل كان نكوله قرينة ظاهرة دالة على صدق المدعى فتقدمت على أصل براءة الذمة وكثير من الأمارات والقرائن أقوى من النكول (1).

ونتوج ما سبق بما اقره الله سبحانه وتعالى من العمل بالقرائن إن كانت تدل على الحق وتظهره عندما حكى لنا القرآن الكريم قصة قميص يوسف (عليه السلام) حيث إن قطع القميص كان هو الشاهد على صدق براءته وهذا بناء على طلب الشاهد صاحب الخبرة والفتنة والفراسة.

فقد حكى القرآن الكريم قول هذا الشاهد ومقررا له في قوله تعالى (وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ هِيَ رَاوَدْتَنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (26) وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ (27) فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ) (2).

استدل على جواز إثبات الحكم بالعلامة، إذ أثبتوا بذلك كذب امرأة العزيز فيما نسبته ليوسف عليه الصلاة والسلام

وفيه دليل على فطنة الشاهد وفهمه للأمور حيث إنه توصل بقدر القميص إلى تمييز الصادق من الكاذب.

هذا ومع ما للقرائن من هذه المزايا التي لا تنكر، والتي يظهر بها وجه الحق، فإنه يجب الاحتياط الشديد في الأخذ بها.

وما أحسن ما قاله عابدين في رسالة بناء الأحكام على العرف.

قال: إن الحكم بالقرائن محتاج إلى نظر شديد وتوفيق وتأيد وكذا ما قاله صاحب معين الحكام، قال: وينبغي أن يكون القاضي غير زائد في الدماء وذلك أمر زائد على الفتنة.

وإنما نهى عن ذلك: لأنه قد يحمل على الحكم بالفراسة تعطيل الطرق الشرعية من البينة واليمين. ولهذا كان من الحكمة ألا يسترسل في الاعتماد عليها في هذا الزمان لأن فيه ضرب من المجازفة والمخاطرة.

• أقسام القرينة:

تنقسم إلى قسمين:

أحدهما: ما تكون دلالته قوية بحيث تصل إلى درجة اليقين.

1- لو ظهر إنسان من داره ومعه سكين في يده وهو ملوث في الدماء سريع الحركة، عليه أثر الخوف فدخلوا الدار في ذلك الوقت على الفور فوجدوا بها إنسانا مذبوحاً في ذلك الحين، وهو ملطخ

(2) سورة الأنبياء آية (78 ، 79) .

(1) الطرق الحكيمة في السياسة الشرعية ص 5 وما بعدها .

(2) سورة يوسف آية (26 - 27) .

بدمائه، ولم يكن في الدار غير ذلك الرجل الذي وجد بتلك الصفة وهو خارج من الدار يؤخذ به وهو ظاهر، إذ لا يشك أحد في أنه قاتله، والقول بأنه ذبح نفسه، أو أن غير ذلك الرجل قاتله ثم تسور الحائط فذهب احتمال بعيد لا يلتفت إليه إذ لم ينشأ عن دليل (2).

الثاني: ما تكون دلالاته ضعيفة بحيث تهبط إلى درجة الاحتمال البعيد الذي يعتبر في حكم العدم. مثاله: وجود رجل مع امرأة أجنبية عنه في مكان مظلم، ولم يلاحظ أحد من الشهود وقوع الزنا منهما، فإن هذا لا يعد حجة لإقامة الحد عليهما وإنما يستحقان التعزير على وجودهما معا بهذه الصورة، وقد روى عن ابن مسعود: أنه قضى في رجل وجد مع امرأة في ملحفه، ولم يقم عليهما الدليل بأكثر من ذلك أن يجلد أربعين جلدة ويشهر به بين الناس.

وثبت عن عمر - رضى الله عنه - أنه عزز رجلاً وجد معه امرأة بعد العتمة في ريبة بضربه دون المائة جلدة (1).

ما يشترط للعمل بالقرينة:

أحدهما: ما يقطع الاحتمال أصلاً كالمحكم والمتواتر.

والثاني: ما يقطع الاحتمال الناشئ عن الدليل الظاهر والنص. والخبر المنشور فالأول يسمونه علم اليقين، والثاني يسمونه علم الطمأنينة والقرينة القاطعة من قبيل العلم الثاني وهو علم الطمأنينة (2).

ومثالها: ظهور حمل امرأة ليست متزوجة - ظهور السكر من شخص.

الشرط الثاني: ألا يعارض القرينة قرينة أخرى أو دليل آخر فإن عارضها شيء من هذا فلا تصلح أن تكون من طرق الإثبات.

مثاله: ادعاء أخوه يوسف أكل الذئب له مع أن القميص جاءوا به غير ممزق فإنه لو كان حقاً ما يقولون لمزق الذئب قميصه (3).

هل تكفي القرائن لإثبات الزنا؟

ومع هذا الإجماع من الفقهاء على العمل بالقرائن وكونها طريقة من طرق إثبات الدعوى، إلا أن الفقهاء يختلفون في إثبات جريمة الزنا بهذا الطريقة

والأصل في كون الحمل قرينة على الزنا: أقوال أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم وأفعالهم - فقد روى عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - قال: الرجم في كتاب الله حق على من زنا من الرجال والنساء إذا كان محصناً، إذا قامت البينة أو كان الحمل أو الاعتراف.

وقد روى عن علي كرم الله وجهه أنه قال: يا أيها الناس إن الزنا زنيان، زنا سر وزنا علانية، فزنا السر: أن يشهد الشهود فيكون الشهود أول من يرمى، وزنا العلانية، أن يظهر الحبل والاعتراف.

والقرينة: وإن كانت دليلاً عند بعض الفقهاء، إلا أنها ليست دليلاً قاطعاً على ارتكاب هذه الجريمة، فيجوز للمرأة دفعها بأن تدعى حدوث الحمل بالوطء خطأ أو إكراها أو بحدوثه بدون إيلاج، أو من غير زنا ولا تكلف في ذلك كله إثبات ما تدعيه عند جمهور الفقهاء.

إلا أن المالكية قالوا: بتكليفها إثبات ما تدعيه من كونها وطنت مكرهة، أو في نكاح، أو بشبهة أو غير ذلك مما تدعيه مما يسقط الحد عنها، ولا يقبل دعواها الغصب على ذلك بلا قرينة تشهد لها بذلك.

(2) ونقله ابن عابدين أيضاً في رسالته ج2 ص 126 .

(1) محاضرات في علم القاضي أود/ عبد العال عطوه ص 29 .

(2) غاية الوصول إلى دقائق علم الأصول أود/ جلال الدين عبد الرحمن ص 40.

(3) نظرية الدعوى والإثبات أود/ نصر فريد محمد ص 140 .

والراجع: قول الجمهور القائلين بأن القرينة ليست دليلاً قاطعاً في الحدود لأن القرينة مبينة على الشبهة والحدود تدرا بالشبهات ومن هذا فلا يقام بها الحد لأن الحد لا يثبت إلا بينه ⁽¹⁾.

(¹) الشرح الصغير ج4 س 501 فما بعدها ، والجريمة والجنايات ، المصدرين الساقين ، وفي أول النظام الجنائي الإسلامي د/ محمد سليم العواض 213 ط ، دار المعارف .

الفصل الخامس

الحجر وأسبابه الشرعية

المبحث الأول مفهوم الحجر في اللغة والاصطلاح

الحجر في اللغة:

بتسكين الجيم معناه: المنع والتضييق تقول: حجر عليه القاضي يحجر حجراً "إذا منعه من التصرف"⁽¹⁾

ومنه سمي الحجر عند البيت الحرام؛ لأنه يمنع الطواف أن يطوفوا فيه، وإنما يطاف من ورائه، ومنه يقال: للعقل: حجراً؛ لأنه يمنع صاحبه عن تعاطي ما لا يليق به، فيمنعه من ارتكاب القبائح، حيث يقول المولي عز وجل (هل في ذلك قسم لذي حجر)⁽²⁾ أي لذي عقل⁽³⁾.

وعرفه الحنفية بأنه منع من نفاذ تصرف قولي - لا فعلي - «هو المنع من لزوم العقود والتصرفات القولية. فإذا باشر المحجور عقداً أو تصرفاً قولياً كالبيع أو الهبة لا ينفذ أي لا يلزم، ولا يترتب عليه حكمه، فلا يملك بالقبض. وإنما كان الحجر عند الحنفية من التصرفات القولية كون الحجر من التصرفات القولية؛ لأنها هي التي يتصور الحجر فيها بالمنع من نفاذها، أما الأفعال فلا يتصور الحجر فيها؛ لأن الفعل بعد وقوعه لا يمكن رفعه، بخلاف القول، فإنه يمكن رفعه بمنع انعقاده شرعاً أو منع نفاذه.

وللحنفية تعريف آخر أدق: وهو عبارة عن منع مخصوص متعلق بشخص مخصوص، عن تصرف مخصوص أو عن نفاذه، أي لزومه؛ لأن عقد المحجور ينعقد موقوفاً (3)»

وعرف ابن عابدين الحجر: بأنه عبارة عن منع مخصوص بشخص مخصوص عن تصرف مخصوص أو عن نفاذه⁽¹⁾.

وهنا يلاحظ: أن الإمام ابن عابدين أدخل في التعريف المنع من الفعل فلم يقصره على المنع من القول فقط كما هو واضح في التعريف السابق، وقال: إن هذا هو التحقيق فإنه إن جعل الحجر هو المنع من ثبوت حكم التصرف، فما وجه تقييده بالقولي ونفي الفعلي مع أن لكل منهما حكماً؟ وما قيل: من أن الفعل بعد وقوعه لا يمكن رده، فالمراد به هو رد حكم الفعل لا ذات الفعل كما هو الشأن في التصرفات القولية، فإنه لا يمكن رد ذات القول بل الممكن هو رد حكمه⁽²⁾.

(1) المغرب ص 103 ، المصباح المنير ص 111.

(2) الدر المختار 6 /143، مجمع الانهر 2 /437 سورة الفجر: آية 5

(3) تفسير ابن كثير 3 /315

(1) المصدر السابق

(2) المصدر السابق . هذا وقد عرف المالكية الحجر بمثل ما عرفه به الحنفية والشافعية فقد عرفوه : بأنه منع الإنسان من التصرف في ماله .

أدلة مشروعية الحجر

«ورد في القرآن الكريم آيات ثلاث تدل على مشروعية الحجر من حيث المبدأ، أولها قوله تعالى: {ولا توتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا} [النساء: 4/5] نهى الله تعالى فيها الأولياء عن إعطاء السفهاء أموالهم؛ لأن في إعطائهم تعريضا لضياعها، فدل النص على منعهم من التصرف في أموالهم، وهو معنى الحجر عليهم» والآية الثانية قوله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم} [النساء: 4/6] أمر الله تعالى باختبار اليتامى في حفظ أموالهم، بأن يدفع لهم شيء من أموالهم، لمعرفة خبرتهم في التصرفات، فإن آنس منهم الرشد قبل البلوغ، سلموا أموالهم، فدل النص على منع دفع أموالهم إليهم، قبل الرشد، وحجرهم عنها، حتى لا يتصرفوا فيها. والآية الثالثة قوله سبحانه: {فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل} [البقرة: 2/282] فسر الشافعي رضي الله عنه السفيه بالمبذر، والضعيف بالصبي، والكبير بالمختل، والذي لا يستطيع أن يمل بالمغلوب على عقله، فأخبر الله تعالى أن هؤلاء ينوب عنهم أولياؤهم، فدل على ثبوت الحجر عليهم. وثبت في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه (1). وحجر عثمان بسبب التبذير على عبد الله بن جعفر (2)

حكمة مشروعية الحجر

«ليس في الحجر إهدار حقيقي لكرامة الإنسان، وإنما هو رحمة ومصلحة وصون وتعاون، فهو رحمة بالمحجور عليه حتى يوفر له ماله في وقت تكثر فيه مسؤولياته، وتتعدد واجباته، فلا يواجه الحياة بوجه عبوس مقطب، ولا تتراكم عليه الهموم والمشكلات، ولا تصادمه الصعاب والمشاق، وإنما يجد في ماله سبيلا للنجاة، والعيش الكريم، وشق طريق الحياة، وهو صون لماله من عبث العابثين، وحد لهوى النفس بالإنفاق في وجوه غير صحيحة» من هنا: كان في مشروعية الحجر عناية من الله بخلقه. ورعاية منه - سبحانه - بالضعفاء من عباده فهو مشروع لحفظ أموالهم عليهم، حتى يحفظ لهم ماء وجوههم، ويعيشوا كرماء كما أراد لهم خالقهم⁽¹⁾

مراتب الحجر:

الحجر على مراتب:

قوي: وهو المنع عن أصل التصرف بعد انعقاده أي بطلانه كتصرف المجنون، متوسط: وهو المنع عن وصفه وهو النفاذ، كتصرف المميز، ضعيف: المنع عن وصف وصفه وهو كون النفاذ حالاً؛ مثل: تأخير نفاذ الإقرار من المحجور عليه للإفلاس إلى ما بعد فكه عنه وهو المنع عن الحجر عنه.

أقسام الحجر:

ينقسم الحجر إلى قسمين: الأول: حجر لمصلحة المحجور عليه؛ كالحجر على المجنون والصبي والسفيه والمبذر وغيرهما؛ فالحجر على هؤلاء وأمثالهم شرع رعاية لمصلحتهم حفاظاً على أموالهم من الضياع.

(1) تكملة البحر الرائق 8 / 88 ، تبين الحقائق 5 / 190 وما بعدها ، البحر والولاية علي المال في الشريعة الإسلامية ، د . عبد الفتاح النجار ، ص 4 .

والثاني: وهو حجر لمصلحة الغير؛ وذلك كالحجر على المدين المفلس صيانة لحق الغرماء الدائنين؛ والحجر على الراهن صيانة لحق المرتهن في العين المرهونة؛ والحجر على المريض مرض الموت صيانة لحق الورثة فيما زاد على الثلث؛ والحجر على الرقيق صيانة لحق سيده.

أسباب الحجر:

أسباب الحجر كثيرة؛ منها ما هو محل اتفاق؛ ومنها ما هو محل خلاف.

فقد اتفق الحنفية: على أن الجنون والصبا والرق من الأسباب الشرعية الموجبة للحجر. ويلحق بها أيضاً: المفتي الماجن والطبيب الجاهل والمكاري المفلس

وذهب صاحبان: إلى أنه يضاف إلى ما سبق السفه؛ والتبذير؛ ومطل الغني وركوب الدين؛ وخوف ضياع المال بالتجارة؛ والتلجئة⁽²⁾ ⁽³⁾ والذي عليه الفتوي في المذهب الحنفي: هو الحجر على الصغير والمجنون والرقيق والمفتي الماجن والطبيب الجاهل والمكاري المفلس بالاتفاق، والسفيه والمغفل والمديون على قول صاحبين وهو ما عليه الفتوي⁽⁴⁾.

(2) التلجئة : عقد ينشئه العاقد لضرورة أمر فيصير كالمدفع إليه ؛ينظر :الفتاوي الهندية 3/ 209

(3) بدائع الصنائع 7 / 169 ؛ العناية علي الهداية 254؛ 9 .

(4) لسان العرب 4 / 458 .

الحجر علي الصغير

الصغير في اللغة: هو وصف مأخوذ من صغر صغراً: قل حجمه أو سنه فهو صغير والصغر ضد الكبر.

وفي الاصطلاح: وصف يلحق بالإنسان من وقت ولادته إلى أن يبلغ الحلم لعدم تكامل قواه البشرية⁽¹⁾، هذا ولا خلاف بين الفقهاء: في أن الصبي الذي لا يعقل يحجر عليه ويمنع من ماله؛ لأن وضع المال في يده إتلاف له. وأيضاً: الصبي العاقل الذي لم يبلغ الحلم يمنع من ماله؛ فيظل محجوراً عليه بحكم الشرع حتى يبلغ؛ ثم يستمر الحجر عليه إلى أن يؤنس منه الرشد⁽²⁾.

حكم اختبار الصغير وتدريبه علي التجارة : لابس لولي الأمر أن يدفع إلي الصغير الذي لم يؤنس منه الرشد جزءاً من المال ليتاجر به ؛ وذلك من باب الاختبار والتدريب للصغير علي أعمال التجارة والبيع والشراء، قال الله - تعالى - : **(وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم) وجه الدلالة من الآية :** أن الله - سبحانه وتعالى - أذن للأولياء الذين يتولون أمور اليتامى أن يقوموا باختبارهم ؛ وذلك بالإذن لهم بالتجارة ؛ فإذا فعلوا ذلك فوجدوا من الصغار رشداً في ضبط المال وحسن التصرف ؛ ومعرفة التجارة ؛ فلم أن يقوموا بدفع المال إليهم ؛ لقوله - تعالى - : **(فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم)** فالرشد هو الاهتداء والاستقامة في حفظ المال وإصلاحه وحسن التصرف في التجارة⁽¹⁾.

الحجر (810) علي البالغ السفیه (811).

يتميز المذهب الحنفي باعتباره للكرامة الأدمية في تقديره حرمة ولايته على ماله، على مصلحة بقاء ماله أصلاً، فإذا تعارض الأمران: قدمت حرمة ولايته على حرمة ماله؛ حفاظاً على كرامته الأدمية، وعدم سلب ولايته على ماله، مما ينتقص من آدميته، وبالتالي لا يحجر على الحر البالغ العاقل السفیه، وتصرفه في ماله جائز وإن كان مبذراً مفسداً يتلف ماله فيما لا غرض له فيه ولا مصلحة ؛ لأنه مخاطب عاقل فلا يحجر عليه اعتباراً بالرشد، وهذا لأن في سلب ولايته إهداراً لأدميته وإحاقاً بالبهائم وهو أشد ضرراً من التبذير فلا يتحمل الأعلى لدفع الأدنى(812).

واستدل الحنفية على ما ذهبوا إليه بما روي: أن حبان بن منقذ كان يغبن في البياعات فطلب أولياؤه من النبي-عليه الصلاة والسلام- الحجر عليه، فقال له: «إذا ابتعت فقل لا خلاصة ولي الخيار ثلاثة أيام» ولم يحجر عليه⁽⁸¹³⁾ لأنه عاقل كامل العقل، ألا ترى أنه مكلف فلا يحجر عليه كالرشد بخلاف

(1) الموسوعة الكويتية 27 / 20 ؛ الحجر والولاية علي المال في الشريعة الإسلامية ص 8 .

(2) بدائع الصنائع 7 / 170.

(1) سورة النساء آية 6 .

(810) الحجر لغة (بفتح فسكون): المنع. إلا أن الفقهاء يريدون به المنع من التصرفات المالية كالحجر على السفیه أو القولية كالحجر على المفتي الماخن. أو العملية كالحجر على الطبيب. الموسوعة الكويتية 16/283 (811) يعرف السفیه بأنه خفة تعتري الإنسان فتحمله على العمل بخلاف موجب الشرع أو العقل مع قيام العقل. درر الحكام 2/274. وقد قيل في تعريفه أنه من يعمل عمل الجهال، كان جاهلاً في الحقيقة أو لا؛ لما قد يلقب العالم به؛ إذا ضيع الحدود، وتعاطى الأفعال الذميمة؛ وعلى ذلك ما جاء من الكتاب بتسفيه علماء أهل الكتاب. ثم قد يسمى الجهال به؛ لما أن الجهل هو السبب الباعث على فعل السفیه؛ فقوله - تعالى - : {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} يحتمل ذلك الوجهين. تفسير الماتريدي 3/19.

(812) الهداية في شرح بداية المبتدي 3/278

(813) الاختيار 2/96

المعتوه والصبي فإنهما ناقصا العقل، ولهذا لم يكلفا فلا يمكن القياس عليهما، ولو كان يحجر عليه نظراً له لكان رفع التكليف أنظر له، فحيث كلفه الشارع يعلم أنه لم ينظر له، فكيف ينظر له وهو كامل العقل والتقصير من جهته بسوء اختياره وقلة تدبيره مكابراً لعقله ومتابعاً لهواه⁽⁸¹⁴⁾.

ثم إن عند أبي حنيفة -رحمه الله- إذا بلغ الغلام سفياً منع عنه ماله إلى خمس وعشرين سنة وتصرفاته قبل ذلك نافذة؛ لأنه لا يحجر عليه عنده، فإذا بلغ ذلك سلم إليه ماله وإن لم يؤنس الرشد منه (815)، قال في الينابيع: إنما قدره أبو حنيفة بخمس وعشرين سنة؛ لأنه قد يصير جداً في هذا السن وولده قاضياً، وفي حجر ولده له مع كونه حراً بالغاً فيؤدي الحجر عليه إلى أمر قبيح (816). وذهب أبو يوسف ومحمد⁽⁸¹⁷⁾ إلى جواز الحجر على السفه ويمنع من التصرف في ماله واستدلوا على ما ذهبوا إليه بعموم قوله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم}⁽⁸¹⁸⁾ حيث علق دفع الأموال إليهم بوجود الرشد، فلا يجوز قبله⁽⁸¹⁹⁾ وبقوله تعالى: {ولا توتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفاً}⁽⁴⁾ ووجه الاستدلال بها أن الله نهانا عن الدفع إليهم ما داموا سفهاء وأمرنا بالدفع إن وجد منهم الرشد إذ لا يجوز الدفع إليهم قبل وجوده، ولأن منع المال جاء لعل السفه فيبقى المنع ما بقيت العلة؛ لأن الحكم يدور معهما (820)

ثم اختلفا فيما بينهما فقال أبو يوسف لا يصير محجوراً عليه إلا بحجر الحاكم ولا يصير مطلقاً بعد الحجر حتى يطلقه الحاكم.

وقال محمد: السفه لا يحتاج في الحجر عليه إلى قضاء القاضي لأن فسادَه في ماله يحجره وصلاحه فيه يطلقه يعني أنه ينحجر بنفس السفه ويذهب عنه الحجر بنفس الإصلاح في ماله، وفائدة الخلاف فيما باعه قبل حجر القاضي فعند أبي يوسف يجوز، وعند محمد لا يجوز.

ثم إذا صار محجوراً عليه عندهما يصير حكمه حكم الصبي الذي لم يبلغ إلا في أشياء معدودة، فإن حكمه فيها كحكم البالغ العاقل، وهي أنه إذا تزوج امرأة جاز نكاحه، وإن أعتق جاز عتقه، ولكنه يسعى العبد في قيمته.

(814) تبیین الحقائق 193/5

(815) العناية شرح الهداية 262/9

(816) وبيانه أن أدنى مدة يبلغ فيها الغلام اثنتا عشرة سنة، ثم يتزوج وتحبل له فتلد امرأته لستة أشهر فيكبر ولده ويبلغ لاثنتي عشرة سنة، ثم يتزوج وتحبل له فتلد امرأته لستة أشهر فذلك خمس وعشرون سنة، ومحال أن يكون جداً ولم يبلغ أشده لأنه وإن كان حراً عاقلاً وهو ما لا يصح الحجر عليه، إلا أنه لما بلغ هذا السن الذي يكون الإنسان فيه كالجد الذي له أحفاد - باعتبار أقل مدة البلوغ في الإنزال وهو اثنتا عشرة سنة وأقل مدة الحمل وهو ستة أشهر - وإذا لم يبق قابلاً للتأديب فلا فائدة في المنع فلزم دفع ماله إليه يفعل فيه كيف شاء. الجوهرة النيرة على مختصر القدوري 242/1.

(817) وهو قول الشافعي أيضاً. ينظر العزيز شرح الوجيز 67/5.

(818) النساء 6

(819) البحر الرائق 91/8

(820) تبیین الحقائق 195/5.

ويصح تدبيره واستيلاده وطلاقه ويجب في ماله الزكاة، ويجب عليه الحج إذا كان قادراً على الزاد والراحلة وتنفيذ وصيته في الثلث، ويجوز إقراره على نفسه بما يوجب العقوبة، كما إذا أقر بوجوب القصاص في النفس وفيما دونها (821).

الحجر على الفاسق (822)

ذهب الحنفية إلى عدم جواز الحجر على الفاسق إذا كان مصلحاً لماله، الفاسق إذا لم يكن سفيهاً مبذراً لماله لا يحجر عليه ، لأن مجرد الفسق فقط لا يوجب الحجر فإذا طرأ الفسق لم يحجر على الفاسق (823) لكرامته واستدل الحنفية على ذلك بعموم قوله تعالى: {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} (824) وقد أونس منه نوع رشد؛ لأنه مصلح لماله فنتناول له النكرة المطلقة، والرشد في المال مراد بقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فلا يكون الرشد في الدين مراداً؛ لأنه حينئذ يكون معلقاً برشدين، ولأن العدالة لا تعتبر في الرشد في الدوام، فلا تعتبر في الابتداء كالزهد في الدنيا، ولأن هذا مصلح لماله فأشبهه العدل، يحققه: أن الحجر عليه إنما كان لحفظ ماله عليه، فالمؤثر فيه ما أثر في تضييع المال أو حفظه، ولو كان الرشد صلاح الدين فالحجر على الكافر أولى من الحجر على الفاسق.

ثم إن كان الفاسق ينفق أمواله في المعاصي كشراء الخمر وآلات اللهو أو يتوصل به إلى الفساد فهو غير رشيد لتبذيره لماله وتضييعه إياه في غير فائدة على الخلاف في ذلك، وإن كان فسقه لغير ذلك كالكذب ومنع الزكاة وإضاعة الصلاة مع حفظه لماله دفع ماله إليه، لأن المقصود بالحجر حفظ المال، وماله محفوظ بدون الحجر، ولذلك لو طرأ الفسق عليه بعد دفع ماله إليه لم ينزع؛ ولأن الفاسق من أهل الولاية عندنا لإسلامه فيكون والياً للتصرف والفسق الأصلي والطارئ سواء (825)

الحجر على المدين

إذا أحاط الدين بمال المدين ، وطلب الغرماء الحجر عليه ذهب الحنفية إلى عدم جواز الحجر على المدين (826) قال أبو حنيفة: لا أحجر في الدين، وإذا وجبت ديون على رجل وطلب غрмаؤه حبسه والحجر عليه لم أحجر عليه؛ لأن في الحجر إهدار أهليته، فلا يجوز لدفع ضرر خاص، فإن كان له

(821) الجوهرة النيرة 1/242، درر الحكام 2/271، مجمع الأنهر 2/604.

(822) الفاسق هو: من يفعل محرماً يبطل العدالة من كبيرة أو إصرار على صغيرة، ولم تغلب طاعاته على معاصيه، واحترز بالمحرم عما يمنع قبول الشهادة لإخلاله بالمروءة، كالأكل في السوق، فإنه لا يمنع الرشد لأن الإخلال بالمروءة المختلف فيه ليس بحرام على المشهور، الموسوعة الفقهية الكويتية 17/98. وعرف الحنفية الرشد: بأنه الصلاح في المال فقط .

(823) التجريد للقدر 6/2936.

(824) [النساء:6]

(825) لسان الحكام 1/314.

(826) وذهب المالكية وهو قول عند الشافعية، إلى جواز الحجر على المدين حيث ينعقد بيعه موقوفاً على إجازة الدائنين واستدلوا بأن الحجر على المدين يمنع نفاذ تصرفه، والمنع من النفاذ لا يقتضي البطلان، وإنما يقتضي وقف نفاذ التصرف على إجازة الدائنين؛ لأن الحجر أصلاً مقرر لمصلحتهم، فإن أجازوا تصرفات المدين نفذت، وإن شاءوا ردوها فتبطل؛ ولأن تصرف المدين المحجور عليه كتصرف المريض مرض الموت الذي عليه ديون في صحته، فكل تصرف يصدر منهما ينعقد موقوفاً غير نافذ. الموسوعة الفقهية 30/252.

مال لم يتصرف فيه الحاكم؛ لأنه نوع حجر؛ ولأنه تجارة لا عن تراض فيكون باطلاً بالنص، ولكن يحبسهُ أبداً حتى يبيعه في دينه، إيفاء لحق الغرماء ودفعاً لظلمه (827) حتى ولو كان الدائن غير مسلم فالمسلم يحبس للذمي في الدين، وكذلك الحربي المستأمن يحبس، ويحبس له بالدين وبالحق يجب فيه الحبس عليه (828)

وقال محمد: إذا طلب غرماء المفلس الحجر عليه حجر القاضي عليه، ومنعه من البيع والتصرف والإقرار حتى لا يضر بالغرماء، وباع ماله إن امتنع من بيعه وقسمه بين غرمائه الحصص، فإن أقر في حال الحجر بإقرار لزمه ذلك بعد قضاء الديون،

ويفق على المفلس من ماله وعلى زوجته وأولاده الصغار وذوي أرحامه، وإن لم يعرف للمفلس مال وطلب غرماءه حبسه، وهو يقول لا مال لي حبسه الحاكم في كل دين التزمه بدلاً عن مال حصل في يده كضمن مبيع وبدل القرض، وفي كل دين بعقد كالمهر والكفالة ولم يحبسهُ فيما سوى ذلك كعوض المغضوب وأرش الجنايات إلا أن تقوم البيئة أن له مالاً (829).

الفرق بين الحجر بالدين والحجر بالسفه:

يظهر الفرق بينهما من ثلاثة وجوه:

أحدهما: أن الحجر علي السفه يكون لمعني فيه، وهو سوء اختياره وتصرفه، والحجر على المدين يكون لحق الغرماء بسبب الدين فيفتقر إلى القضاء.

الثاني: أن المحجور عليه بسبب السفه إذا أعتق عبداً وجبت عليه السعاية وأدي ولا يرجع بما سعي على المولي بعد زوال الحجر، بخلاف المحجور عليه بسبب الإفلاس والدين فإنه يرجع بذلك.

الثالث: أن المحجور عليه بسبب السفه لا يجوز إقراره لا حال الحجر ولا بعده ولا في المال القائم ولا في المال الحادث، أما المحجور عليه بسبب الدين فإنه لو أقر حالة الحجر ينفذ إقراره بعد زوال الحجر، وكذا حالة الحجر فيما سيحدث له من المال حالة الحجر (3).

نقض قضاء القاضي بالحجر:

إذا حجر القاضي علي السفه ثم رفع حكمه إلي قاض آخر، فقام هذا القاضي بإبطال الحكم الذي قضى به القاضي الأول ورفع عنه الحجر، فإن قضاءه جائز، لأن الحجر من القاضي فتوي وليس بقضاء، ولأن القضاء يقتضي وجود المقضي له والمقضي عليه ولا وجود لذلك، وعلي فرض أنه قضاء لا فتوي، فإن نفس القضاء مختلف فيه، فإن أبا حنيفة لم يقل به فصار محلاً للقضاء يحتاج إلي إمضاء، حتي إنه لو رفع المحجور عليه تصرفه بعد الحجر إلي قاض آخر نفذ إبطاله لاتصال الإمضاء به، فلا يقبل النقض بعد ذلك (1).

بيع السفه قبل حجر القاضي عليه:

إذا قام السفه بالبيع قبل أن يقوم القاضي بالحجر عليه.

(827) الهداية: 282/3.

(828) الأصل للشيباني: 497/10.

(829) المبسوط للسرخسي: 90/20.

(3) حاشية ابن عابدين 148/6، تكملة البحر الرائق 91/8.

(1) العناية علي الهداية 261/9 وما بعدها، تكملة البحر الرائق 91/8، مجمع الأنهر 441/2 وما بعدها.

فعند أبي يوسف جاز ذلك، لأنه لا بد من حجر القاضي عنده، حيث لا يتم الحجر عليه عنده بنفس السفه، لأن الحجر دائر بين الضرر وإهدار آدمية المحجور عليه، والنظر له وذلك بإبقاء المبيع على ملكه كما كان، فكان لا بد من مرجح وهو فعل القاضي.

وعند محمد بن الحسن: لا يجوز بيع السفه وإن لم يحجر عليه القاضي، لأنه يبلغ محجوراً عليه، فالحجر عليه يكون بنفس السفه وهي علة الحجر عند محمد، وهو بمنزلة الصبا، وهو موجود قبل القضاء فيترتب عليه الحكم⁽²⁾.
صور من تصرفات السفه:

1- زواج السفه وطلاقه

إذا تزوج السفه بامرأة، فإن فعله ذلك يقع جائزاً، حيث إن الزواج لا يؤثر فيه الهزل فلا يؤثر فيه السفه، ولأن الزواج من حوائجه الأصلية، فإن كان قد جعل لزوجته مهراً مسمى لزمه منه مقدار مهر المثل، لأنه من ضرورات النكاح وتسقط الزيادة، لأنه يصبر في حكم مريض مرض الموت في سقوط الزيادة.

وأيضاً: إذا تزوج بأربع نسوة فإنه يلزمه مهر المثل لا الزيادة، سواء تزوج بالأربعة في عقد واحد أو تزوج في كل يوم واحدة، فإنه يصح تسميته مهر المثل وتبطل الزيادة، لأن المهر من ضرورات النكاح.

وأيضاً: لو طلق السفه زوجته قبل الدخول بها وجب لها النصف من مهر المثل المسمى، لأن التسمية صحيحة إلى مقدار مهر المثل.

وإذا طلق المرأة المسرفة السفهية على مال وقبلت ذلك وقع الطلاق رجعيّاً ولا يلزمها المال أصلاً، لأنها سفهية، والسفه محجور عن المال، وإذا وقع الطلاق بلفظ الخلع وقع بائناً⁽¹⁾.

2- زكاة ونفقة أقارب السفه:

يجوز إخراج الزكاة من مال السفه، لأنها واجبة عليه، وكذا الإنفاق على أولاده وزوجته ومن تجب عليه نفقته من ذوي أرحامه، لأن إحياء أولاده وزوجته من حوائجه الأصلية، والإنفاق على ذي الرحم واجب عليه لقرابته، فكل ما وجب عليه مما أوجبه الله - تعالى - كالزكاة وحجة الإسلام، أو كان من حقوق الناس كنفقة من تجب عليه نفقته هو والمصلح فيه سواء، لأنه مخاطب والسفه لا يسقط شيئاً من حقوق الشرع عنه كما لا يبطل شيئاً من حقوق الناس.

وعلي القاضي أن يدفع قدر الزكاة إلى السفه ليصرفها إلى مصرفها الشرعي، لأنه لا بد من نية السفه في الزكاة، لكونها عبادة، والنية هي التي تميز العبادة عن العادة، فكان لا بد منها في الزكاة.

وعلي القاضي أن يبعث مع السفه أميناً معه حتى لا يصرف مال الزكاة في غير مصرفها الشرعي، وهذا بخلاف النفقة فإن القاضي ليس في حاجة لأن يقوم بدفعها إلى السفه، فله أن يقوم بدفعها إلى أمينه لإيصالها إلى مستحقيها، لأن النفقة ليست عبادة، فلا تحتاج إلى نية، وبالتالي فلا يشترط دفعها إلى السفه شخصياً⁽²⁾.

3- حج وعمره السفه:

إذا أراد السفه أن يؤدي حجة الإسلام، فإنه لا يمنع من ذلك، لأن الحج واجب عليه بإيجاب الله - تعالى - وليس للقاضي أن يسلم إليه النفقة اللازمة للقيام بالحج، وعليه أن يسلمها إلى شخص ثقة من

(2) العناية علي الهداية 264/9 .

(1) العناية علي الهداية 266/9 ، وتكملة البحر الرائق 93/8 .

(2) بدائع الصنائع 267/9 ، تكملة البحر الرائق 93/8 ، مجمع الأنهر 440/2 .

الحجاج، ليقوم بإنفاقها عليه في أثناء طريقه للقيام بأداء فريضة الحج، حتى لا يقوم السفية بإتلافها في غير وجهها المطلوب.

وأيضاً: لو أراد السفية أن يقوم بأداء العمرة فإنه لا يمنع منها، وذلك من باب الاستحسان لاختلاف العلماء في وجوبها، ولا يمنع السفية من القران، حيث إنه لا يمنع من السفر لكل واحد من الحج والعمرة على انفراد، فلا يمنع من الحج قارنا من باب أولى⁽¹⁾.

4- إقرار السفية المحجور عليه:

لو أقر السفية المحجور عليه أنه أخذ مال رجل بغير أمره فاستهلكه لم يصدق على ذلك، فإن صلح حاله سئل عما كان قد أقر به، فإن كان حقاً أخذ به، وإن أنكر أن يكون حقاً لا يؤخذ به⁽²⁾. وكذا: إذا أقر السفية بالنسب، إقرار السفية بالنسب يصح منه ويلحق المقر به بنسبه؛ إذ لا يؤثر عليه السفه لأنه ليس بمال، فيقبل إقراره كالحد.

أما إذا كان السفية المقر امرأة، فإنها تصدق في إقرارها في كل ما سبق إلا في إقرارها بالولد، فلا تصدق فيه لأن فيه تحميل النسب على الغير وهو الزوج⁽³⁾.

المطلب الخامس

الحجر علي ذي الغفلة

الغفلة في اللغة:

هي غيبة الشيء عن بال الإنسان، والرجل المغفل هو الذي لا فطنة له⁽¹⁾.

الغفلة في الاصطلاح:

هي ضد الفطنة: والمغفل: هو من اختل ضبطه وحفظه، ولا يهتدي إلى التصرفات الراجعة فيغبين في البياعات لسلامة قلبه، وعدم استعماله القوة المنبهة مع وجودها. وقيل: هو الإنسان البسيط الذي يخدع بسهولة ولا يميز بين الرأي السديد والخاطئ، ففيه من الغباء ما يوقعه دوماً في الغبن الفاحش.

ذو الغفلة هو من يغبين في البيوع لسلامة قلبه ولا يهتدي إلى التصرفات الراجعة. ويختلف عن السفية بأن السفية مفسد لماله ومتابع لهواه، أما ذو الغفلة فإنه ليس بمفسد لماله ولا يقصد الفساد.

حكم الحجر بسبب الغفلة:

اختلف الحنفية في ذلك على النحو التالي:

ذهب أبو حنيفة: إلى أن الغفلة ليست من الأسباب الموجبة للحجر، فلا يجوز الحجر علي الغافل بسبب الغفلة.

واستدل على ذلك: بأن الشخص المصاب بالغفلة ليس بمفسد ولا يقصد الإفساد، غاية الأمر أنه لا يهتدي إلى التصرفات الراجعة فيغبين في البياعات لسلامة قلبه.

وذهب صاحبان: إلى أن الغفلة من الأسباب الموجبة للحجر، فإنه يحجر علي ذي الغفلة كما يحجر على السفية، ويكون الحجر عليه من حين قضاء القاضي وذلك عند أبي يوسف، ومن حين ظهور أمارات الغفلة وذلك عند محمد، وبناء عليه:

(1) الهداية 276/9 ، تكملة البحر الرائق 93/8 ، مجمع الأنهر 440/2 وما بعدها .

(2) المبسوط للسرخسي 177/ 24 وما بعدها .

(3) العناية علي الهداية 394/8 وما بعدها .

(1) المصباح المنير ص 449 وما بعدها ، المغرب ص 342.

فإن الحجر يزول عنه بقضاء القاضي وذلك عند أبي يوسف، وبزوال الغفلة عند محمد.
واستدلا على ذلك بما يلي:
من السنة:

بما روي ((أن أهل حبان بن منقذ طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحجر عليه فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم ينكر عليهم)).
وجه الدلالة من الحديث:
أن الحجر لو لم يكن مشروعاً على ذي الغفلة لأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم طلبهم، وحيث لم ينكر عليهم ذلك، فدل على مشروعية الحجر عليه.
ومن المعقول:

أن في الحجر على ذي الغفلة صيانة لماله ونظراً له فشرع الحجر عليه رعاية لذلك.
اعترض على الصاحبين:

بأن الحديث الذي استدلا به دليل للإمام أبي حنيفة أيضاً، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يجبههم إلى طلبهم، وإنما قال لحبان: ((قل لا خلافة)) فلو كان الحجر عليه مشروعاً لأجابهم إليه ولم يحدث ذلك منه، فدل على المنع⁽¹⁾.
واستدل الصاحبان بأن الحجر بسبب الغفلة ثبت بدلالة قول الله - تعالى - : **(ولا تؤتوا السفهاء أموالكم)**، حيث إن المغفل يتلف الأموال كالسفيه
واعترض على ذلك:

بأن النص ورد في منع المال ولا نزاع فيه، وإنما النزاع في الحجر⁽²⁾.
هذا وقد جاء في القانون رقم 119 لسنة 1952 في المادة 65 أنه يحكم بالحجر على البالغ للجنون أو للعتة أو للسفه أو للغفلة ولا يرفع الحجر إلا بحكم وتقييم المحكمة على من يحجر عليه قيماً لإدارة أمواله وفقاً للأحكام المقررة في هذا القانون.

المطلب السادس

الحجر على المدين ((المفلس))

إذا أحاط الدين بمال المدين، وطلب الغرماء الحجر عليه اختلف الفقهاء في الحجر بسبب الدين وذلك على النحو التالي:
عند أبي حنيفة:

لا يحجر على الإنسان بسبب الدين، لو طلب الغرماء الحجر عليه، ولكن يحبس ليتولى هو بنفسه بيع ماله وقضاء ما عليه من الديون.
واستدل على ذلك بما يلي:

(1) أن في الحجر على المدين إهدار لأهليته، وهو ضرر عظيم لا يجوز ارتكابه لدفع ضرر أخف أخص منه.

(2) أن في بيع الحاكم ماله جبراً عنه مخالفة للنص الذي اشترط التراضي وهو قوله - تعالى - : **(إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم)**⁽¹⁾ فيكون البيع جبراً باطلاً.

(1) حاشية ابن عابدين 147/6 وما بعدها ، تكملة البحر الرائق 94 /8 ، تبیین الحقائق 198/5 وما بعدها .

(2) العناية على الهداية 268/ 9 وما بعدها .

(1) سورة النساء . آية 29 .

(3) أن قضاء الدين واجب عليه والمماطلة ظلم فيحبسه الحاكم دفعاً لظلمه وإيصالاً للحق إلى مستحقه ولا يكون ذلك إكراهاً على البيع، لأن المقصود من الحبس الحمل على قضاء الدين.
وعند صاحبين:

يجوز الحجر بسبب الدين لكن بشرط أن يطلب الغرماء ذلك، وللقاضي أن يبيع ماله إن امتنع هو من بيعه⁽²⁾.

واستدلاً على ذلك بما يلي:

من السنة:

بما روي ((أن معاذاً ركب دين فباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله وقسم ثمنه بين غرمائه بالحصص))⁽³⁾.

وجه الدلالة من الحديث: فقد دل الحديث على أنه يجوز الحجر على كل مديون، وعلى أنه يجوز للحاكم بيع مال المديون لقضاء دينه من غير فرق بين ما إذا كان المال مستغرقاً بالدين أم لا⁽¹⁾.
ومن المعقول:

(1) أن في الحجر على المدين رعاية لمصلحة الغير وهم الدائنون الغرماء، حتى لا يلحقهم الضرر إذا أقر للغير، أو ألجأه وأقر به لشخص يصعب انتزاعه منه.

(2) أن البيع واجب عليه لإيفاء ما عليه من الديون حتى إنه يحبس فيه، فإذا امتنع من البيع ناب القاضي منابه كما في حالة المجنون والعينين إذا امتنعا من التخليق فإن القاضي ينوب عنهما فكذا هنا⁽²⁾.

والذي يبدو أن القول بالحجر على المدين هو الأولي بالقبول لما فيه من رعاية لمصلحة حق الغرماء والدائنين.

الحجر على المدين الغائب:

عند أبي حنيفة: لا يجوز الحجر على المدين، سواء أكان غائباً أم حاضراً.

وعند صاحبين: يصح الحجر على المدين الغائب بشرط أن يعلم المحجور عليه، ويترتب على ذلك أن كل تصرف يكون قد باشره بعد الحجر وقبل العلم به صحيحاً عند صاحبين.

وعليه: فإذا ثبت الدين بإقرار المدين واعترافه أو بشهادة الشهود عليه إلا أنه غاب عند طلبه أمام مجلس القضاء قبل الحكم وامتنع من الحضور:

ف عند أبي يوسف: للقاضي أن ينصب وكيلاً عنه، ويحكم عليه بالمال، إن سأل الخصم ذلك.

أما إن سأل الخصم أن يحجر القاضي على المدين الغائب:

ف عند أبي حنيفة ومحمد: لا يحكم ولا يحجر عليه حتى يحضر الغائب، ثم يحكم عليه القاضي، وللقاضي أن يحجر عليه إذا حضر، وذلك عند محمد، لأنه إنما يحجر عليه بعد الحكم لا قبله⁽³⁾.

إقرار المدين المفلس:

لا يقبل على الغرماء إقرار المفلس بشيء من ماله الذي حجر عليه فيه، لاحتمال التواطؤ بين المفلس ومن أقر له، ويلزمه ما أقر به بعد فك الحجر عنه.

(2) وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة .

(3) المعجم الكبير 31/ 20.

(1) نيل الأوطار 292/5 وما بعدها .

(2) العناية على الهداية 292/9 - 275 ، تبين الحقائق 199 /5 وما بعدها .

(3) الفتاوي الهندية 62/5 .

فإذا أقر المدين المفلس المحجور عليه حال الحجر فإن إقراره يلزمه بعد قضاء الديون ولا يلزمه في الحال، لأنه تعلق بهذا المال حق الغرماء الأولين الذين تم الحجر عليه لأداء حقهم، وبالتالي فلا يمكنه إبطال حقهم بالإقرار لغيرهم حال الحجر، فلا يلزمه ما أقر به حال الحجر إلا بعد قضاء الديون.

استهلاك المحجور عليه مال غيره أثناء الحجر:

إذا استهلك المدين المحجور عليه مالا لشخص أثناء الحجر عليه، فإنه في هذه الحالة يضمنه لصاحبه، لأن صاحب المال المستهلك في هذه الحالة يصير أسوة بسائر الغرماء، فيلزم المحجور عليه الضمان، لأن استهلاكه مال الغير أمر مشاهد لا مرد له، بخلاف الإقرار فإن سببه أمر محتمل (1).

الإنفاق على المفلس وعلى أهله:

إذا تم الحجر على المفلس فإنه يتم الإنفاق عليه من ماله، كما يتم الإنفاق على زوجته وأولاده الصغار وعلى ذوي الأرحام الذين تجب الإنفاق عليه نفقتهم، لأن هذه الأمور من حاجاته الأصلية، ولا شك أن حاجته الأصلية تقدم على حق الغرماء، ولأن هذه الأمور من الحقوق التي تثبت لغيره فلا يبطله الحجر (2).

فيجب على الحاكم أن ينفق من مال المفلس عليه - أي على المفلس - بالمعروف، وهو أدنى ما ينفق على مثله، إلى أن يقسم ماله. وذلك لأن ملكه لم يزل عن ماله قبل القسمة. وكذلك ينفق على من تلزم المفلس نفقته، من زوجة وقريب ولو حدث بعد الحجر

إذا مرض المفلس في الحبس:

إذا مرض المفلس في المحبوس في حق الغرماء، فإنه لا يخلو إما من يكون له خادم يقوم بمعالجته أو لا، فإن كان له خادم يقوم بمعالجته فإنه يخرج من الحبس بكفيل، لأن في بقاءه في الحبس مع المرض ما يؤدي إلى هلاكه، والإنسان لا يجوز إهلاكه بسبب الدين بدليل أن الإنسان في حالة المخمصة الشديدة يجوز له أن يدفعها ولو بمال الغير، فكيف يجوز إهلاكه لمال الغير، هذا إذا كان الغالب عليه الهلاك، وهو ما عليه الفتوي.

وذهب أبو يوسف: إلى أنه لا يخرج المفلس المريض من الحبس بسبب المرض، سواء أكان له خادم يعالجه أم لا، لأن الهلاك بسبب المرض يستوي فيه أن يكون في الحبس أو في غيره (1).

ملازمة الغرماء للمدين المفلس:

من حق الدائن أن يلازم المدين - على تفصيل في هذه الملازمة - إلا إذا كان الدائن رجلا والمدين امرأة؛ لما في ملازمتها من الإفضاء إلى الخلوة بالأجنبية، ولكن يجوز للدائن أن يبعث بالمرأة تتوب عنه في ملازمتها

ليس لقاضي أن يحول بين المدين وبين غرمائه بعد خروجه من الحبس، فليس له أن يمنعهم من أن يدوروا معه أينما دار، وليس للغرماء أن يمنعوا المدين من التصرف والسفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لصاحب الحق يد ولسان)) (2).

(1) العناية على الهداية 276/9 ، مجمع الأنهر 443/2 ، الفتاوي الهندية 62/5 .

(2) الهداية 276/9 ، مجمع الأنهر 443/2 .

(1) العناية على الهداية 276/9 وما بعدها ، فتح القدير 276/9 وما بعدها ، الفتاوي الهندية 63/5 .

(2) الدراية في تخريج أحاديث الهداية 199/2 ، نصب الراية 166/4 .

فالمراد باليد في الحديث الملازمة، وباللسان التقاضي، والحديث مطلق في حق الزمان فيتناول الزمان الذي يكون بعد الإطلاق من الحبس وقبله. هذا وللغرماء أن يأخذوا ما ربحه من كسب ويقسمونه بينهم كل واحد منهم بقدر حصته من الدين، وذلك لاستواء حقوقهم في القوة.

قضاء القاضي بالإفلاس:

عند أبي حنيفة: لا يتحقق القضاء بالإفلاس، لأن المال غاد ورائح، فلا يحول بينه وبين الغرماء، ولأن وقوف الشهود على عدم المال من الأمور التي لا تتحقق إلا ظاهراً، فيصلح ذلك للدفع لا لإبطال حق الملازمة، فلا يبطل حق الغرماء بملازمة من حكم عليه القاضي بالإفلاس.

وعند صاحبين: إذا قضي القاضي بالإفلاس فله أن يحول بينه وبين الغرماء إلا إذا استطاع الغرماء الإتيان بالبينة التي تشهد بأن له مالاً، وذلك لأن القضاء بالإفلاس من الأمور التي تصح عند صاحبين، وفي هذه الحالة، وهي حالة القضاء بالإفلاس يثبت عسرة المفلس ويستحق النظرة إلى ميسرة.

وذلك لقول الله تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} (1) وقول النبي لغرماء معاذ: "خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك" وفي رواية < ولا سبيل لكم عليه > هذا: ولو دخل المفلس داره لا يتبعه الغرماء، بل يجلسون على باب داره إلى أن يخرج، إلا إذا أذن لهم بالدخول، حتى لا يختفي المفلس، أو يتمكن من الهرب من أي جانب آخر من الدار، فيفوت المقصود من الملازمة.

هذا وينبغي أن يلاحظ: أن هذه الملازمة تكون بين الرجال، فإذا كان الدائن رجلاً والمدين امرأة فإنه لا يلزمها، لأن ذلك يستلزم الخلوة بالمرأة وهو حرام، وإنما عليه أن يبعث امرأة أمينة تقوم بملازمتها.

بينة اليسار والإعسار:

إذا استطاع الغرماء أن يأتوا ببينة تشهد بانه أيسر واستغني، واستطاع المفلس أن يأتي ببينة تشهد بأنه مازال معسراً، فهنا تترجح بينة اليسار على بينة الإعسار، لأنها الأكثر إثباتاً حيث إن البينة التي تشهد بالإعسار تؤكد ما دل عليه غيره، إذا الأصل هو العسرة والافتقار⁽¹⁾.

الاختلاف في الحبس والملازمة:

إذا اختلف الغرماء والمدين فاختلف الغرماء حبس المدين، واختار المدين الملازمة، فالخيار للغرماء إلا إذا علم القاضي أن الغريم يتعدى حدود الملازمة، بأن كان يمنع المدين من الدخول إلى داره، أو كان الغريم يتبع المدين داخل داره بغير إذنه فحينئذ للقاضي أن يحبس المدين ويجيبه لطلبه، دفعاً للضرر عنه⁽²⁾.

المال المستفاد بعد الحجر:

إذا استفاد المدين المفلس مالاً بعد الحجر عليه فإنه لا يدخل في الحجر، فيصح تصرفه فيه، حيث إنه لم يتعلق به حق الغرماء، حيث إن حق الغرماء تعلق بالمال القائم في يده وقت الحجر، لا بالمال المستفاد بعده، وكذا يصح إقراره به⁽³⁾.

إعلان الحجر وإشهار التفليس:

(1) العناية علي الهداية 9/ 277 وما بعدها ، الفتاوي الهندية 5/ 63 وما بعدها .

(2) الفتاوي الهندية 5/ 64 .

(3) تبين الحقائق 5/ 200 ، الجوهرة النيرة 1/ 246 ، تكملة البحر الرائق 8/ 95 ، مجمع الأنهر 2/ 443 .

إذا حكم القاضي بالإفلاس وحجر على المفلس فإنه لا بد من إعلان هذا الإفلاس وإشهاره بين الناس ليعلموا الشخص الذي تم إعلان إفلاسه، فيتجنبوا معاملته حتى لا تضيع حقوقهم، وكان يتم الإعلان عن الإفلاس قديماً عن طريق النداء وعند المساجد (4).

وفي عصرنا هذا تعددت وسائل الإعلان التي يتم فيها إشهار التفليس، سواء في الوسائل المكتوبة كالمصحف والجرائد، أم في الوسائل المسموعة المرئية كالإذاعة والتلفزيون وغيرها من وسائل الإعلام، وكذلك عند أبواب المحاكم، وأصبح الأمر في عصرنا هذا لا يشكل صعوبة في معرفة المفلس نظراً لسرعة انتشار وسائل الإعلام (1).

آثار الحجر علي المفلس:

- (1) إذا حجر القاضي علي المفلس، تعلق بذلك من الآثار ما يلي:
- (2) تعلق حق الغرماء بماله، فيمنع من الإقرار على ذلك المال والتصرف فيه.
- (3) انقطاع الطلب عنه بدين جديد بعد الحكم بالإفلاس.
- (4) حلول الدين المؤجل في ذمة المدين.
- (5) استحقاق من وجد عين ماله عند المدين استرجاعه .
- (5) استحقاق بيع مال المفلس وقسمه بين الغرماء .

المطلب السابع الحجر علي الفاسق

الفسق في اللغة:

هو الخروج عن الطاعة، وعن الدين، وعن الاستقامة، وأصل الفسق خروج الشيء على وجه الفساد (1).

الفسق في الاصطلاح:

هو خروج عن الطاعة وتجاوز الحد بالمعصية (2).

حكم الحجر بسبب الفسق:

لا يحجر على الإنسان الفاسق إذا كان مصلحاً لماله، ولا فرق في ذلك بين الفسق الأصلي، وهو ما إذا بلغ فاسقاً، وبين الفسق الطاريء، أي الذي يطرأ عليه، وهو ما قال به أئمة الحنفية (3).

واستدلوا على ذلك بالكتاب والمعقول:

من الكتاب:

قول الله - تعالى - : (فإن أنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم) (4)
وجه الدلالة من الآية:

(4) العناية علي الهداية 271/9 .

(1) عبد الرحمن آل شيخ ، أحكام الحجر علي المفلس في الفقه الإسلامي ، ص 95 .

(1) المصباح المنير ص 473 ، المغرب ص 361 .

(2) شرح النووي علي صحيح مسلم 2 / 54 ، تحفة الأحوذى 7 / 324 .

(3) العناية علي الهداية 268/9 ، فتح القدير 9، 862 وما بعدها ، وهو ما ذهب إليه الجمهور من المالكية والشافعية في الأصح والحنابلة ، لأن مجرد الفسق فقط لا يوجب الحجر عليه .

(4) سورة النساء : آية 6 .

أن الله - سبحانه وتعالى - ذكر لفظ (رشداً) نكرة، والنكرة بإطلاقها تتناول القليل والكثير، والفاسق قد أونس منه نوع رشد، فتتناوله النكرة، حيث أصلح في ماله، ومن أصلح في ماله فقد أونس منه رشداً⁽⁵⁾.

وبمعني آخر: أن قوله (رشداً) نكرة في موضع الإثبات، والنكرة في موضع الإثبات تخص ولا تعم، فإذا وجد رشد ما فقد وجد الشرط، فيجب دفع المال إليه⁽⁶⁾.

ومن المعقول:

أن الفاسق من أهل الولاية لإسلامه، فيكون والياً للتصرف.

المطلب الثامن

الحجر علي مريض الموت

مريض الموت: هو من لا يستطيع الخروج لحوائجه خارج البيت، ولا تستطيع المرأة القيام بعملها داخل البيت⁽¹⁾،

ومرض الموت: هو الذي يخاف منه الهلاك غالباً.

فقد ذهب الجمهور من الحنفية ومن وافقهم: إلى أن مريض الموت يحجر على تبرعاته فيما زاد علي الثلث، وذلك للحفاظ علي حق الورثة.

وقال المالكية: إن المريض مرض الموت يمنع مما زاد علي قدر الحاجة من الأكل والمشرب والملبس والتداوي.

هذا: وإذا أجاز الورثة تبرعه بما زاد عن الثلث نفذ ذلك لوجود الإذن منهم، أما تبرعه في حدود الثلث فإنه يجوز بدون توقف على إجازة الورثة⁽²⁾.

المطلب التاسع

الحجر علي الشيخ المسن

لا يجوز الحجر علي الشخص الكبير - الشيخ الهرم - إلا إذا ثبت أن في عقله خللاً، أما إذا كان عقله صحيحاً ويتصرف تصرف العقلاء، فليس لأحد كائناً من كان أن يحجر عليه، إلا في حالة واحدة وهي ما إذا كان له غرماء يطالبونه ورفض السداد لهم، وخافوا من تبذير أمواله، فهنا يطلبون من القاضي أن يحجر عليه، ويتولى القاضي ذلك ويسدد لغرمائه حسب ديونهم.

وأيضاً: يحجر عليه إذا اختلف عقله، لأنه في هذه الحالة يكون أشبه بالمجنون، حيث يعجز عن التصرف في ماله على وجه المصلحة، وحفظه فأشبهه الصبي والسفيه⁽¹⁾.

⁽⁵⁾ المصباح المنير ص 473 ، المغرب ص 361 .

⁽⁶⁾ العناية علي الهداية 268/9 ، فتح القدير 268 ، 9 وما بعدها ، وهو ما ذهب إليه الجمهور من المالكية والشافعية في الأصح والحنابلة ، لأن مجرد الفسق فقط لا يوجب الحجر عليه .

⁽¹⁾ العناية علي الهداية 268/9 .

⁽²⁾ المبسوط للسرخسي 162/ 24 .

⁽¹⁾ الهداية 268/9 .

المطلب العاشر

الحجر علي الطبيب الجاهل، والمفتي الماجن، والمكاري المفلس

الحجر للمصلحة العامة:

ذهب الحنفية إلى فرض الحجر للمصلحة العامة على ثلاثة وهم: المفتي الماجن، والطبيب الجاهل، والمكاري المفلس.

أولاً: **الطبيب الجاهل:**

الطبيب الجاهل: هو الذي يعطي الأدوية للناس ويسقيهم إياها من غير علم، والذي لا يستطيع دفع الضرر عنهم عند ظهور المضرة والتهلكة⁽¹⁾.

ويدخل في ذلك: بعض المعالجين والمطبيين بالأعشاب الذين ظهروا بكثرة في عصرنا هذا وأضروا الكثير من المرضى.

فيجب الحجر علي الأطباء الجهلة حفاظاً على صحة العامة ودفع الضرر عنهم.

ثانياً: **المفتي الماجن:**

المفتي الماجن: هو الذي يعلم الناس الحيل الباطلة كتعليم المرأة الردة لتبين من زوجها، والذي يفتي عن جهل ولا يبالي بتحليل الحرام وتحريم الحلال⁽²⁾.

فيجب الحجر علي المفتي الماجن وهو ما انفرد به الإمام أبو حنيفة حيث أوجب الحجر علي المفتي الماجن على الرغم من أنه لا يقول بالحجر على الحر البالغ العاقل السفیه، ومع ذلك فقد قال بالحجر علي المفتي الماجن وذلك لدفع ضرره عن العامة.

ثالثاً: **المكاري المفلس:**

المكاري المفلس: هو من ليس لديه وسائل أخرى للنقل، كما أنه ليس لديه نقود لشراء ذلك، إلا أنه يقوم بكراء الناس دواب أو وسائل نقل يمكنه أن يقوم بتأجيرها لهم مع العلم بأنه ليس لديه هذه الوسائل ولا لديه نقود ليقوم بذلك، فإذا جاء وقت تسليمها للمتأجر هرب، واختفي⁽³⁾.

ومثل المكاري المفلس: من يأخذ أموال الناس لتوظيفها واستثمارها أو يأخذ معاملاتهم ثم يهرب ويختفي، أو يدخل في شراء أرض أو بستان أو عقار بالتقسيط، ولا قدرة له علي وفاء الأقساط، وربما يعتمد على إعادة البيع بثمن أعلي، لكي يمكنه الوفاء⁽¹⁾.

فمثل هؤلاء يجب الحجر عليهم دفعاً لضررهم عن الناس، حتى لا تضيع أموالهم وتتعطل مصالحهم، ولا تقضي حوائجهم.

نخلص من ذلك:

إلي أن الإمام أبا حنيفة قال بجواز الحجر علي الطبيب الجاهل والمفتي الماجن والمكاري المفلس، دفعاً لضررهم وإبعاد أذاهم عن أفراد المجتمع.

معني الحجر عليهم:

إن القول بالحجر علي الطبيب الجاهل والمفتي الماجن والمكاري المفلس لا يراد به حقيقة الحجر الذي هو المنع من نفوذ التصرف مثل سائر المحجور عليهم، بل المراد هو المنع الحسي، بأن يحول ولي الأمر بينهم وبين الناس، بدليل أن المفتي لو أفتي بعد الحجر وأصاب في فتواه جاز ذلك منه،

(1) حاشية ابن عابدين 383/3.

(2) العناية علي الهداية 151/4، بدائع الصنائع 224/3.

(3) إعلام الموقعين 159/4.

(1) إعلام الموقعين 159/4.

ولو أفتي قبل الحجر وأخطأ في فتواه لم يجز ذلك منه ، وأيضاً الطبيب لو باع الأدوية بعد الحجر نفذ بيعه فدل ذلك علي أن المراد ليس هو حقيقة الحجر وإنما المراد هو المنع الحسي أي منعهم من ممارسة عملهم حساً ، لأن الأول مفسد للأديان ، والثاني مفسد للأبدان ، والثالث مفسد للأموال . فمنع هؤلاء المفسدين دفع ضرر لاحق بالخاص والعام، وهو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر⁽²⁾ .

الفصل السادس

الرهن

المبحث الأول

تعريف الرهن:

الرهن لغة: الحبس مطلقاً، سواء كان حسياً كحبس الأعيان، أو معنوياً كحبس النفوس عن شهواتها بالصيام ونحوه، قال تعالى: **(كل نفس بما كسبت رهينة)**⁽¹⁾ ، أي حبيسة بما اقترفت من الذنوب والآثام، وجاء في الحديث: ((نفس المؤمن رهونة بدينه حتى يقضي عنه دينه)) رهونة أي محبوسة⁽²⁾ .

ويطلق الرهن لغة أيضاً علي: (العين المرهونة).

وشرعاً: حبس الشيء بحق يمكن استيفاءه منه، كالدين.

أو هو: حبس شيء مالي بحق مالي يمكن استيفاءه منه كلاً أو بعضاً

أو جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها أو من ثمنها إذا تعذر الوفاء

هذا ويسمي معطي الرهن: رهناء، ويسمي أخذه: مرتهناً، وتسمي العين المرهونة: رهناء، ومرهوناً ورهينة.

ورهن: أعطي الرهن، وارتهن إذا قبض الرهن وأخذه⁽³⁾ .

مشروعية الرهن

الرهن مشروع بالكتاب والسنة والإجماع:

فالكتاب: قوله تعالى: (وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة)⁽²⁾ أمر إرشاد للمؤمنين لا إيجاب لقوله تعالى: (فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي أؤتمن أمانته)، ولأنه تعالى أمر به عند عدم وجود الكاتب، ولما كانت الكتابة غير واجبة بدليل قوله تعالى: (فإن أمن بعضكم بعضاً) فذلك بدلها وهو الرهن.

والرهن مشروع باتفاق الفقهاء في الحضر والسفر خلافاً لمجاهد والظاهرية لإطلاق مشروعيته في السنة، وذكر السفر في الآية خرج مخرج الغالب لكون الكاتب في الماضي غير متوافر في السفر غالباً.

(2) موقع الإسلام أون لاين نت ، خطورة التجروء علي منصب الإفتاء

(1) سورة المدثر آية 38 .

(2) الترمذي 3/ 280 ، وردت (معلقة) بدل (مرهونة) .

(3) راجع : أنيس الفقهاء تحقيق د . أحمد الكبيسي ، ص 289 . المعاملات الشرعية للعلامة علي الخفيف ، المعاملات في الشريعة الإسلامية والقوانين المصرية للعلامة أحمد أبو الفتوح .

(2) سورة البقرة ، الآية 283 .

ولا يشترط أيضاً عدم وجود الكاتب، لثبوت جوازه في السنة مطلقاً، فالآية أرادت إرشاد الناس إلى وثيقة ميسرة لهم عند فقدان كاتب يكتب لهم الدين⁽³⁾ وأما السنة: فمنها ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى طعاماً من يهودي، ورهنه درعاً من حديد))⁽⁴⁾.
وجه الاستدلال: أن هذا الحديث واضح في جواز الرهن في كل ما كان مالاً متقوماً.
وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على جواز الرهن في الجملة. قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافاً⁽⁵⁾.

المبحث الثاني

حكمة مشروعية الرهن:

شرع الرهن لما فيه من فائدة متحققة لكل من المرتهن والراهن إذا الأول يأمن على دينه من الضياع، والثاني يحصل على ثقة الدائن فيقلل هذا من مخاصمته، والثقة في المعاملات سبيل الرواج وتعود بالفائدة على المتعاقدين⁽¹⁾.
وشرع الرهن أيضاً: وثيقة للاستيثاق ليضن الراهن بحبس عينه فيسارع إلى إيفاء الدين ليفتكها فينتفع بها ويصل المرتهن إلى حقه⁽²⁾.

أركان الرهن

أركان الرهن عند الحنفية اثنان هما الإيجاب والقبول، وهو أن يقول الراهن رهنك هذا الثوب مثلاً بمالك علي من الدين، فيقول المرتهن ارتهنت أو قبلت أو رضيت وما يجري مجراه.
وقيل: ركنه الإيجاب فقط، والقبول شرط، وعلى كل حال فلا يتم إلا بالقبض، لقوله تعالى: (فرهان مقبوضة) وهذا محل اتفاق.

هذا. ولفظ الرهن ليس بشرط لصحة الرهن، فلو اشترى شخص من آخر شيئاً بعشرة دراهم مثلاً ثم دفع المشتري إلى البائع ثوباً وقال له أمسك هذا الثوب حتى أعطيك الثمن، فالثوب رهن، لأنه أتى بمعني العقد، والعبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ والمباني⁽³⁾.
وكما ينعقد الرهن باللفظ ينعقد بالكتابة، وبالإشارة المفهمة للأخرس.

صفة عقد الرهن: عقد الرهن عقد جائز غير لازم قبل التسليم كعقود التبرعات الأخرى لأنه معتبر منها؛ لأن ما أعطاه الراهن للمرتهن غير مقابل بشيء، والقاعدة (لا يتم التبرع إلا بالقبض).
وهو من العقود العينية: وهي التي لا تعتبر تامة الالتزام إلا إذا حصل تسليم العين المعقود عليها (وهي هنا الرهن).

فإذا سلم الراهن للمرتهن تم العقد ولزم من جانب الراهن لا من جانب المرتهن، حتى جاز للمرتهن أن يفسخه ويرد المرهون إلى مالكة⁽⁴⁾.
هذا. والأصل أن يكون حبس الرهن عند المرتهن، وهل يجوز أن يحفظ الرهن عند غير المرتهن؟
نعم يجوز حفظ الرهن عند غير المرتهن باتفاق المتعاقدين، ويسمى هذا الغير: عدلاً، أو أميناً⁽¹⁾.

⁽³⁾ الفقه الإسلامي وادلته للزحيلي 5/181، 182، المعاملات لأحمد أبي الفتح ص 591.

⁽⁴⁾ أخرجه البخاري، الفتح 5/53، طبع السلفية.

⁽⁵⁾ المغني لابن قدامة 4/362، المعاملات في الشريعة الإسلامية لأحمد أبي الفتح ص 295.

⁽¹⁾ انظر: المعاملات لأبي الفتح، ص 592.

⁽²⁾ الاختيار لتعليل المختار، ج 2، ص 93.

⁽³⁾ انظر: البدائع 6/135، المعاملات الشرعية للعلامة علي الخفيف.

المبحث الثالث

شروط صحة الرهن:

أربعة أنواع: منها ما يرجع إلى نفس العقد، ومنها ما يرجع إلى المتعاقدين، ومنها ما يرجع إلى الشيء المرهون، ومنها ما يرجع إلى المرهون به.

أولاً: الشروط التي ترجع إلى نفس العقد:

ألا يكون الرهن معلقاً على شروط، ولا مضافاً إلى وقت لأن في الرهن والارتهان معني الإيفاء والاستيفاء فيشبه البيع، وأنه لا يحتمل التعليق بشرط والإضافة إلى وقت، كذا هنا.

ثانياً: الشروط التي ترجع إلى المتعاقدين (الراهن والمرتهن):

فيشترط أن يكونا عاقلين أو مميزين، فالمجنون والصبي غير المميز لا يجوز منهما الرهن والارتهان وكذا فاقد العقل.

ويجوز من المميزين إذا أذن لهما وليهما لأن الرهن من توابع التجارة.

ثالثاً: الشروط التي ترجع إلى المرهون لانعقاد الرهن:

هي الشروط التي ترجع إلى المبيع لانعقاد البيع إذ القاعدة: أن كل ما يصح بيعه يصح رهنه وبالعكس.

واليك هذه الشروط:

1_ أن يكون المرهون محلاً قابلاً للبيع، بأن يكون موجوداً وقت العقد، مالا مطلقاً متقوماً مقدور التسليم.

وعليه فلا يجوز رهن ما ليس بموجود عند العقد.

ولا رهن ما يحتمل الوجود والعدم، كما إذا رهن ما تلد أغنامه هذه السنة ونحو ذلك، ولا رهن الميتة والدم لانعدام ماليتهما، ولا رهن صيد الحرم والإحرام لأنه ميتة، ولا رهن الحر لأنه ليس بمال أصلاً، ولا رهن جزء شائع من عقار، لأن قبض الجزء الشائع لا يتصور بانفراده، وقبض الكل لا يقتضيه العقد⁽¹⁾.

ولا يجوز رهن الخمر والخنزير من المسلم سواء كان العاقدان أو أحدهما مسلماً؛ لانعدام مالية الخمر والخنزير في حق المسلم.

فإذا كان الراهن والمرتهن ذميين صح الرهن فيما بينهما في الخمر والخنزير.

ولو كان الراهن ذمياً والمرتهن مسلماً كانت الخمر مضمونة علي المسلم المرتهن، لأن الرهن إذا لم يصح كانت الخمر بمنزلة المغصوب في يد المسلم، وخمر الذمي مضمونة علي المسلم بالغصب.

وإذا كان الراهن مسلماً والمرتهن ذمياً لا تكون مضمونة علي أحد⁽¹⁾.

2_ أن يكون القابض أهلاً للقبض بأن يكون عاقلاً مميزاً، ولا يشترط فيه البلوغ، والذي يقبض الرهن: هو المرتهن أو من يقوم مقامه.

(1) انظر البدائع 135/6 ، الاختيار لتعليل المختار ، ج 2، ص 95 ، ط . المعاهد الأزهرية ، المعاملات لأبي الفتح .

(1) انظر : بدائع الصنائع 135/6 .

هذا ولا يشترط في الشيء المرهون أن يكون مملوكاً للراهن. بل يجوز أن يكون الرهن مستعاراً من مالك أجنبي بإذنه. ويد المستعير للرهن يد أمانة، فلا يضمن الراهن العين المستعارة للرهن إذا هلك قبل رهنه أو بعد فكه وإن استخدمه أو ركه من قبل، لأنه أمين خالف ثم عاد إلي الوفاق، أما المرتهن فيده يد ضمان، فإذا هلك العين المستعارة للرهن في يده صار مستوفياً حقه، ووجب للمعير على المستعير (الراهن) مثل الدين.

3_ أن يكون الرهن مفرغاً أي غير مشغول بما ليس بمرهون، فلا يصح قبض الدار التي فيها أمتعة الراهن.

4_ أن يكون الرهن مفرزاً مميزاً، فلا يصح قبض المشاع ⁽²⁾.

الشروط التي ترجع إلى المرهون به:

المرهون به: هو الحق الذي أعطي بسببه الرهن.

الشرط الأول: أن يكون حقاً واجب التسليم إلى صاحبه مثل القرض وضمن المبيع المؤجل لأنه لو لم يكن واجب التسليم فلا محل لأن يعطي به رهنًا لتوثيقه، إذا لا إلزام على المطالب بالحق حتى يستوجب التوثيق به ⁽³⁾.

الشرط الثاني: أن يمكن استيفاء الدين من المرهون، فإن لم يمكن الاستيفاء منه لم يصح الرهن؛ لأن الارتهان استيفاء، فإذا انتفى الاستيفاء انتفى الرهن والغرض منه ⁽⁴⁾.

الشرط الثالث: أن يكون الحق المرهون به معلوماً: فلا يصح الرهن بحق مجهول، مثل أن يسلمه رهنًا بأحد الدينين دون أن يعينه، كأن اشتري منه صفتين مختلفتي الثمن المؤجل، وسلم المشتري رهنًا للبائع بأحد هذين الثمنين ولم يعينه ⁽¹⁾.

رابعاً: الآثار التي تترتب على تسليم الرهن إلى المرتهن:

1_ حق حبس الرهن: فيكون للمرتهن حق حبسه إلى أن يستوفي الدين الذي رهن به. ولا يجوز له أن يحبسه بدين آخر لم يرهن به، سواء أكان سابقاً على الرهن أم لاحقاً له.

2_ حبس الرهن بأي جزء من الدين المرهون به، لأنه محبوس كله بجميع الدين المرهون فلا يسلم إلا بسداده كله.

3_ حق المطالبة بالدين مع الرهن: للمرتهن حق المطالبة بدينه متى كان حالاً لأن الرهن للتوثيق والدين معه قائم، فإذا حل الدين كان لصاحبه حق المطالبة به.

وإذا حضر الدين لم يسلم إلى الدائن إلا بعد إحضار الرهن، إذا لا موجب لبقائه في يد المرتهن بعد وفاء الدين.

4_ اختصاص المرتهن بالرهن: فالمرتهن أحق بالرهن من سائر الغرماء إذا كان الرهن لا يفي بسائر الديون فيستوفي دينه أولاً، وما بقي يكون لسائر الغرماء ⁽²⁾.

خامساً: تأثير الموت في الرهن:

⁽²⁾ انظر: المعاملات لأبي الفتح ص 595 ، والاختيار 93/2 ، اللباب شرح الكتاب ص 125 ط الجمالية ، حاشية الطحطاوي 250/4 ، حاشية ابن عابدين 331/5 .

⁽³⁾ انظر : الفقه الإسلامي للزحيلي 193/5 _ 194 ، المعاملات الشرعية للخفيف ، ص 435 ، 436 .

⁽⁴⁾ انظر : البدائع 6/ 143 ، والمراجع السابقة .

⁽¹⁾ المراجع السابقة .

⁽²⁾ انظر : المعاملات للشيخ علي الخفيف ، ص 437 ، المعاملات لأبي الفتح ، ص 596 وما بعدها ، الهداية 4 / 141 ، حاشية الطحطاوي 245/4 .

لا تأثير لوفاة كل من الراهن والمرتهن في الرهن.
فإذا توفي الراهن لم يكن لوارثه طلب العين المرهونة من المرتهن إلا إذا أوفي الدين، لأنه ورث العين معلقة بحق المرتهن، فلا يستخلصها إلا بإيفائه حقه.

وإذا مات المرتهن قام وارثه في احتباس الرهن مقامه، لأن حق الاحتباس حق مالي ينتقل إلى الورثة كسائر الحقوق المالية⁽¹⁾.

سادساً: حكم الانتفاع بالرهن:

ليس للراهن ولا للمرتهن الانتفاع بالمرهون مطلقاً إلا بإذن الآخر، وفي قول عندهم: لا يجوز الانتفاع للمرتهن ولو بإذن الراهن؛ لأنه ربما

وليس للراهن أن ينتفع بالمرهون استخداماً وركوباً ولبساً وغير ذلك لأن حق الحبس ثابت للمرتهن على سبيل الدوام وهذا يمنع الاسترداد والانتفاع وليس له أن يبيعه من غير المرتهن بغير إذنه، لما فيه من إبطال حقه من غير رضاه.

ولو باعه توقف نفاذ البيع على إجازة المرتهن، إن أجازته جاز، لأن عدم النفاذ لمكان حقه، فإذا رضي المرتهن زال المانع، وكان الثمن رهناً، سواء شرط المرتهن عند الإجازة كون الثمن رهناً أولاً.

وروي عن أبي يوسف: أن الثمن لا يكون رهناً إلا بالشرط، لأن الثمن ليس بمرهون حقيقة، بل المرهون هو المبيع، وقد زال حقه عنه بالمبيع إلا إذا شرط عند الإجازة أن يكون الثمن مرهوناً فلم يرض بزوال حقه عنه إلا ببذل.

وجه ظاهر الرواية: أن الثمن بدل المرهون فيقوم مقامه، وبه تبين أنه مازال حقه بالمبيع، لأنه زال إلى خلف، والزائل إلي خلف قائم معنى فيقام الخلف (الثمن) مقام الأصل⁽²⁾.

سابعاً: هلاك الرهن:

إذا هلك الرهن عند المرتهن وكان هلاكه بدون تعد أو تقصير فإنه يهلك بالأقل من قيمته وقت قبضه ومن الدين، فإذا كانت قيمة الرهن وقت تسليمه إلى المرتهن مساوية لقيمة الدين سقط الدين بهلاكه، وإن كانت أقل سقط من الدين بقدرها، وكان للمرتهن أن يطالب الراهن بما بقي له بعد ذلك من دينه، وإن كانت أكثر سقط بهلاكه الدين كله، ولم يكن للراهن أن يطالب المرتهن بزيادة الرهن على الدين؛ لأنها أمانة في يده فتهلك مجاناً.

الدليل علي ما تقدم:

1- ما روي ((أن رجلاً رهن فرساً بدين فنفق، فاخصموا إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم للمرتهن: ذهب حقك)).

2- ما روي عنه صلى الله عليه وسلم: ((إذا عمي الرهن هو بما فيه)).

قالوا: معناه والله أعلم - إذا هلك - أي الرهن، فاشتبهت قيمته.

3- إجماع الأمة على أن الرهن مضمون مع اختلافهم في كيفية الضمان.

4- ولأنه لما ملك حبسه صار مستوفياً حقه من وجه، لأنه للاستيثاق ليتوصل به إلى حقه مخافة الجحود، وقد تأكد هذا الاستيثاق بالهلاك، فلو وفاه ثانياً يؤدي إلى الربا⁽¹⁾.

(1) أحكام المعاملات الشرعية للعلامة علي الخفيف، ص 431.

(2) بدائع الصنائع 146/6 بتصرف، وانظر حاشية الطحطاوي 236/4.

(1) انظر: المعاملات للخفيف، ص 438. والاختيار لتعليل المختار 95/ 2، 96. وانظر: المعاملات لأبي الفتح ص 606، 607.

المبحث الرابع الجناية على الرهن

جناية الراهن على الرهن مضمونة، لأنه كالأجنبي في المالية حيث تعلق بها حق الغير حبساً واستيفاء.

وجناية المرتهن يسقط من الدين بقدرها، لأنه لو نقص لا بفعله يسقط فبفعله أولى.

وجناية الرهن على الراهن وماله هدر، والمراد جناية توجب المال لأنها جناية المملوك على مالكة.

حكم الرهن المستعار

يجوز للمدين أن يستعير مال غيره ليرهنه بإذنه، والإذن بالرهن لا يخلو من أن يكون مطلقاً أو مقيداً. فإن كان مطلقاً جاز للمستعير أن يرهنه بأي مقدار أراد، وبأي جنس شاء، وفي أي مكان، ومن أي إنسان أحب؛ لأن العمل بإطلاق اللفظ أصل من الشريعة الغراء.

وإن كان مقيداً بأن سمي المعير قدراً أو جنساً أو مكاناً أو إنساناً فليس للمستعير مخالفته. فلو أذن له المعير برهن العارية بعشرة جنيهات لا يجوز له أن يرهنها بأقل ولا بأكثر؛ لأن المعير قد تكون له مصلحة، وبالمخالفة تفوت تلك المصلحة.

وليس للمستعير أن ينتفع بما استعاره ليرهنه، لا قبل الرهن ولا بعده، فإن انتفع وهلك أثناء الانتفاع ضمنه.

وإذا هلك العارية بدون تعد في يد المستعير قبل رهنها فلا ضمان عليه، لأنها هلكت وقت القبض للعارية لا وقت قبض الرهن (1).

وضع الرهن تحت يد العدل

الأصل أن يحفظ الرهن عند المرتهن، أو من يقوم مقامه ممن هو في عياله وعند كل من يحفظ أمواله عنده، وإذا اتفق الراهن والمرتهن على أن يكون الرهن تحت يد عدل جاز ذلك، وقام قبض العدل مقام قبض المرتهن، وترتب على ذلك جميع ما ذكر من الأحكام الخاصة بالرهن، وليس للعدل في هذه الحالة أن يسلمه إلى واحد منهما إلا باتفاقهما لأنه وديع الراهن بالنسبة للعين، ووديع المرتهن بالنسبة للمالية. فيكون تسليمه الرهن إلى أحدهما تسليماً لأجنبي، إما بالنسبة للمالية وإما بالنسبة للعين وذلك لا يجوز.

وإذا سلم العدل الرهن إلى الراهن أو المرتهن لم يبطل الرهن، ووجب عليه أن يسترده، فإن هلك قبل استرداده ضمن العدل قيمته بتعديه بالتسليم، وأخذها منه الراهن والمرتهن جميعاً، ووضعها عنده أو عند غيره وتصير رهنًا لقيامها مقام المرهون.

وإذا أدي الراهن الدين إلى المرتهن سلمت القيمة عندئذ للعدل إن كان ضمانها بسبب تسليمه إلى الراهن، ذلك لأن الراهن قد وصله حقه بصيرورة الرهن إليه، والمرتهن قد وصله حقه بأداء الدين إليه، وإذا كان ضمانها في هذه الحال بسبب تسليمه إلى المرتهن كانت للراهن عوضاً عن ملكه وهو الرهن.

ويجوز للراهن أن يوكل العدل في بيع الرهن، وتسديد الدين من ثمنه وحينئذ لا يملك عزله من الوكالة قبل أداء مهمته (1).

(1) انظر : المعاملات لأبي الفتح ص 599 _ 600 ، المعاملات للخفيف ، ص 439 ، الاختيار لتعليل المختار 106/2 .

(1) انظر : الاختيار لتعليل المختار 105 / 2 ، المعاملات للخفيف ص 440 ، المعاملات لأبي الفتح ص 610 _ 611 .

نماء المرهون

زيادة المرهون المتصلة كالسمن وكبر الشجر تتبع الأصل، ونماء المرهون المنفصل كالولد والثمر واللبن والصوف رهن مع الأصل، بخلاف ما هو بدل عن المنفعة كأجرة والصدقة والهبة فلا تدخل في الرهن، وهي للراهن⁽²⁾.

نفقات الرهن

الأصل الذي تنبي عليه مسائل الإنفاق على الرهن: هو أن كل ما كان منه لحفظ الرهن وصيانته من الضياع والتلف فهو على المرتهن، لأن الحفظ واجب عليه، وذلك كأجرة الحافظ والمكان الذي يحفظ فيه، هذا إذا كانت قيمة الرهن مساوية للدين أو أقل منه، فإن كانت أكثر كان على المرتهن من النفقات ما يقابل الجزء المضمون، وهو المساوي للدين، وعلى الراهن ما يقابل الأمانة، وهو الزائد على المضمون إلا المسكن فإنه على المرتهن خاصة.

وكل ما كان من النفقات لازماً لبقاء العين المرهونة كالمؤنة ورم المباني، وعلف الدواب، أو واجباً أدائه للحكومة كالخراج فعلى الراهن⁽³⁾.

المبحث الخامس

حكم الرهن الفاسد

إذا فسد الرهن بسبب فقده شرطاً من شروط صحته (كأن كان مشاعاً) فلا حكم له حال قيام المرهون، حتى لا يثبت للمرتهن حق حبس الرهن، ويثبت للراهن حق استرداده منه، فإن منعه حتى هلك يضمن مثله إن كان مثلياً أو قيمته إن كان قيمياً باعتبار قيمته يوم قبضه؛ لأنه بالمنع صار غاصباً. وإن لم يمنعه ثم هلك الرهن في يده فقليل: يهلك هلاك الأمانات؛ لأن الرهن إذا لم يصح يكون القبض قبض أمانة؛ لأنه مأذون فيه من المالك، فأشبهه قبض الوديعة، وقيل: يهلك بالأقل من قيمته ومن الدين⁽¹⁾.

حكم الرهن الباطل: الرهن الباطل لا يتعلق به ضمان، ولا يملك به المرتهن حبس الرهن⁽²⁾.

(2) انظر: حاشية ابن عابدين 335/5، فتح القدير 9/129، الاختيار 97/2، المعاملات للخفيف ص 440، 441.

(3) انظر: المعاملات لأبي الفتح 609، 610، المعاملات للخفيف ص 441، 442 الاختيار لتعليل المختار 97/2.

(1) انظر: المعاملات لأبي الفتح ص 608، 609.

(2) المعاملات للخفيف ص 442.

فهرس الدراسة الموضوعية

الموضوع	صفحة
المقدمة	
التمهيد	
أولاً: مفهوم الإثبات الشرعي	
ثانياً: تعريف الدعوى في اللغة والشرع	
ثالثاً: أركان الدعوى	
رابعاً: شروط صحة الدعوى	
الأول: مفهوم الشهادة وشروطها وأنواعها	
أولاً: مفهوم الشهادة في اللغة	
ثانياً: مفهوم الشهادة في الاصطلاح	
ثالثاً: دليل مشروعية الشهادة	
رابعاً: حكم الشهادة	
المبحث الأول: حكم التحمل والأداء	
أولاً: سبب تحمل الشهادة	
المبحث الثاني: شروط الشهادة	
أولاً: شروط الشهادة	
المبحث الثالث: في أداء الشهادة في الحدود	
المبحث الرابع: شروط أداء الشهادة	
أولاً: الشروط التي يجب توافرها في الشاهد	
ثانياً: بعض الفروع التي تتعلق بالعدالة	
الفرع الأول: الاكتفاء بالعدالة الظاهرة	
الفرع الثاني: شهادة الفاسق	
ع الثالث: شهادة المحدود في قذف إذا تاب	
ع الرابع: تركية الشهود	
الخامس: في سقوط العدالة وعدم سقوطها	
ة الأولى: عدالة النائح والنائحة	
ة الثانية: المغنى وضارب الدف	
ة الثالثة: شهادة المخنث	
ة الرابعة: من يلعب بالطيور	
ة الخامسة: اللعب بالشطرنج	

	ة السادسة: ترك الصلاة	
	ة السابعة: من يأتي الكبائر	
	ة الثامنة: آكل الربا	
	ة التاسعة: من يفعل الأفعال المستحقة	
	ة العاشرة: ساب السلف	
	ة الحادية عشر: شهادة أهل الأهواء	
	ة الثانية عشر: شهادة أهل الذمة	
	ة الثالثة عشر: شهادة الحربي على الذمي	
	ة الرابعة عشر: شهادة الأقف	
	ة الخامسة: ما يتحمله الشاهد	
	ة السادسة: شروط الصيغة	
	ة السابعة: شروط المشهود به	
	ة الثامن: أنواع الشهادة ومراتبها	
	ة مطالب	
	ة الأول: في أنواع الشهادة	
	ة الثاني: مراتب الشهادة ونصابها	
	ة التاسع: في الشهادة على الشهادة	
	ة العاشر: عقوب شاهد الزور	
	ة الحادي عشر: الرجوع عن الشهادة	
	ة الثاني عشر: في الاستنجاز لأداء الشهادة	
	ة الثاني: في الإقرار وأحكامه	
	ة مباحث:	
	ة الأول: مفهوم الإقرار ومشروعيته وحكمه	
	ة الثاني: أركان الإقرار وشروطه	
	ة الثالث: الإقرار في الأموال	
	ة الرابع: الاستثناء في الإقرار	
	ة الخامس: الرجوع عن الإقرار	
	ة الثالث: في اليمين والرد والنكول	
	ة الأول: في اليمين في الدعاوى	

	١٠ الثاني: صيغة اليمين	
	١١ الثالث: في شروط اليمين وأنواعه	
	١٢ الرابع: النكول عن اليمين ورده	
	١٣ الرابع: في الوسائل الاجتهادية ودورها في إثبات	
	١٤ الأول: دعوى الدم والقسامة ودورها في إثبات	
	١٥ الثاني: إثبات النسب بقول القائف	
	١٦ الثالث: في القرائن ودورها في إثبات الدعوى	
	١٧ الحجر وأسبابه الشرعية	
	١٨ الأول: مفهوم الحجر في اللغة والاصطلاح	
	١٩ الثاني: أهمية دراسة موضوع الحجر	
	٢٠ الثالث: حكمة مشروعية الحجر	
	٢١ الرابع: أدلة مشروعية الحجر	
	٢٢ الخامس: مراتب الحجر	
	٢٣ السادس: أقسام الحجر	
	٢٤ السابع: أسباب الحجر الشرعية وفيه مطالب:	
	٢٥ الأول: الحجر على الصغير	
	٢٦ الثاني: الحجر على المجنون	
	٢٧ الثالث: الحجر على المعتوه	
	٢٨ الرابع: الحجر على السفیه	
	٢٩ الخامس: الحجر على ذي الغفلة	
	٣٠ السادس: الحجر على المدين المفلس	
	٣١ السابع: الحجر على الفاسق	
	٣٢ الثامن: الحجر على مريض الموت	

	التاسع: الحجر على الشيخ المسن	
	العاشر: الحجر على الطبيب الجاهل، والمفتي والمكاري المفلس	
	الحجرات الكيدي	
	الرهن	
	الأول: تعريف الرهن وأدلة مشروعيته	
	الثاني : حكمة مشروعية الرهن وأركانه	
	الثالث: شروط صحة الرهن	
	الرابع: الجناية على الرهن والرهن المستعار	
	الخامس: الرهن الفاسد والباطل	
	الخاتمة	